

Curso de Direito **COMERCIAL E DE EMPRESA**

Títulos de Crédito e
Contratos Empresariais

Ricardo Negrão

2

9ª edição

Esta edição está atualizada de
acordo com a Lei da Liberdade
Econômica e com anotações
ao PL n. 10.220/2018, que altera
a Lei n. 11.101/2005

saraiva  jur

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Saraiva.

A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal.

ISBN 9788553616169

Negrão, Ricardo

Comercial e de empresa: títulos de crédito e contratos empresariais / Ricardo Negrão. - Coleção Curso de direito volume 2 – 9. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.

496 p.

Bibliografia

1. Direito comercial - Brasil 2. Direito Societário 3. Sociedades comerciais I. Título.
20-0075

CDD 340

Índices para catálogo sistemático:

1. Direito comercial : Direito empresarial 347.7(81)

Direção executiva *Flávia Alves Bravin*

Direção editorial *Renata Pascual Müller*

Gerência editorial *Roberto Navarro*

Gerência de produção e planejamento *Ana Paula Santos Matos*

Gerência de projetos e serviços editoriais *Fernando Penteado*

Consultoria acadêmica *Murilo Angeli Dias dos Santos*

Planejamento *Clarissa Boraschi Maria (coord.)*

Novos projetos *Melissa Rodriguez Arnal da Silva Leite*

Edição *Marisa Amaro dos Reis*

Produção editorial *Rosana Peroni Fazolari*

Arte e digital *Mônica Landi (coord.) | Amanda Mota Loyola | Camilla Felix Cianelli Chaves | Claudirene de Moura Santos Silva | Deborah Mattos | Fernanda Matajs | Guilherme H. M. Salvador | Tiago Dela Rosa | Verônica Pivisan Reis*

Planejamento e processos *Clarissa Boraschi Maria (coord.) | Juliana Bojczuk Fermino | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Fernando Penteado | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Projetos e serviços editoriais *Juliana Bojczuk Fermino | Kelli Priscila Pinto | Marília Cordeiro | Mônica Gonçalves Dias | Tatiana dos Santos Romão*

Diagramação (Livro Físico) *Padovan Serviços Gráficos e Editoriais*

Revisão *Padovan Serviços Gráficos e Editoriais*

Capa *Tiago Dela Rosa*

Livro digital (E-pub)

Produção do e-pub *Guilherme Henrique Martins Salvador*

Data de fechamento da edição: 17-10-2019

Dúvidas?

Acesse sac.sets@somoseducacao.com.br

SUMÁRIO

ABREVIATURAS

AO LEITOR

LIVRO I - TÍTULOS DE CRÉDITO

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO À TEORIA GERAL DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

1.1. Noções

1.2. Classificação dos títulos de crédito

1.2.1. Classificação comum na doutrina

1.2.2. Classificação de Carvalho de Mendonça

1.2.3. Classificação de Vivante

1.2.4. Classificação portuguesa de Pupo Correia

1.2.5. Outras classificações mencionadas pela doutrina

1.3. Espécies reguladas no Direito Brasileiro

1.4. Princípios que regem os títulos de crédito

1.4.1. Cartularidade

1.4.2. Autonomia

1.4.3. Literalidade

1.5. Os arts. 887-926 do Código Civil e os títulos anteriormente regulamentados

1.6. Títulos de crédito virtuais ou eletrônicos

1.6.1. Títulos virtuais e princípios cambiais

1.6.2. Duplicata virtual

1.6.3. Avanço tecnológico e diplomas legislativos

Capítulo 2 - LETRA DE CÂMBIO

2.1. Origens

2.2. Direito aplicável

2.3. Conceito e requisitos formais

2.3.1. A denominação letra de câmbio

2.3.2. Mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada

2.3.3. O nome do sacado

2.3.4. A época do pagamento

2.3.5. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento

2.3.6. O nome do tomador

2.3.7. A data da emissão

2.3.8. O lugar da emissão

2.3.9. A assinatura do sacador

2.4. Reservas do Estado brasileiro

2.5. Institutos cambiários

2.5.1. Saque

2.5.2. Aceite

2.5.3. Endosso

2.5.4. Aval

2.6. Pagamento

2.7. A apresentação

2.8. Protesto

2.9. Ação cambial

Capítulo 3 - NOTA PROMISSÓRIA

3.1. Origens

3.2. Conceito

3.3. Requisitos da nota promissória

- 3.3.1. Requisitos essenciais
- 3.3.2. Preenchimento de nota incompleta
- 3.3.3. Requisitos não essenciais
- 3.3.4. Rigor formal
- 3.4. Direito aplicável – regras compatíveis
- 3.5. Ação cambial e vinculação a contrato

Capítulo 4 - CHEQUE

- 4.1. Conceito, natureza jurídica e características
- 4.2. Origens do cheque
- 4.3. Legislação e regime jurídico do cheque
- 4.4. Criação do cheque – requisitos
- 4.5. Revogação e oposição
- 4.6. Circulação do cheque
- 4.7. Pluralidade de exemplares e alterações no texto do cheque
- 4.8. Formas de lançamento e modalidades de endosso
- 4.9. Aval no cheque
- 4.10. Inoponibilidade das exceções pessoais
- 4.11. Modalidades de emissão
- 4.12. Apresentação, pagamento e prescrição
- 4.13. Ações judiciais

Capítulo 5 - DUPLICATA

- 5.1. Origens
- 5.2. Nota fiscal, fatura e duplicata – distinções, conceitos, natureza e espécies
 - 5.2.1. Nota fiscal
 - 5.2.2. Fatura
 - 5.2.3. Nota fiscal-fatura

- 5.2.4. Duplicata
 - 5.2.5. Espécies de duplicatas
 - 5.3. Criação e requisitos
 - 5.4. Aceite
 - 5.4.1. Remessa
 - 5.4.2. Falta de aceite
 - 5.4.3. Não devolução da duplicata e protesto por indicação
 - 5.4.4. Motivos para a recusa
 - 5.5. Triplicata
 - 5.6. Fatura, conta e duplicata de prestação de serviços
 - 5.7. Endosso
 - 5.8. Aval
 - 5.8.1. Aval em branco, antes do aceite
 - 5.8.2. Aval posterior ao vencimento do título
 - 5.8.3. Aval e ação monitória
 - 5.9. Pagamento da duplicata
 - 5.9.1. Protesto
 - 5.9.2. Prazo para pagamento
 - 5.9.3. Pagamento antecipado
 - 5.9.4. Prorrogação de vencimento
 - 5.10. Duplicata escritural
 - 5.11. Ações fundadas na duplicata – incidência de juros e correção monetária
 - 5.12. Aspectos penais relacionados à duplicata
- Capítulo 6 - CÉDULAS DE CRÉDITO
- 6.1. Origem
 - 6.2. Definição legal, espécies e conceitos

6.3. Características e requisitos essenciais

6.4. Encargos moratórios

Capítulo 7 - TÍTULOS DE CRÉDITO REPRESENTATIVOS

7.1. Títulos representativos

7.2. Conhecimento de depósito e warrants

7.2.1. Armazém-geral

7.2.2. Direitos e deveres dos contratantes

7.2.3. Devolução em mercadoria do mesmo gênero

7.2.4. Conhecimento de depósito e warrant – noções

7.2.5. Natureza jurídica

7.2.6. Requisitos legais de emissão

7.2.7. Circulação dos títulos

7.2.8. Responsabilidade dos endossantes do warrant

7.2.9. Responsabilidade dos endossantes do conhecimento de depósito

7.2.10. Warrants de produtores rurais

7.2.11. Certificado de depósito e warrants agropecuários

7.2.12. Títulos de cooperativa

7.3. Conhecimento de transporte

7.3.1. Origem, definição e conceito

7.3.2. Características

7.3.3. Espécies

7.3.4. Requisitos

7.3.5. Circulação

LIVRO II - CONTRATOS EMPRESARIAIS

Capítulo 8 - TEORIA GERAL DOS CONTRATOS

- 8.1. Fontes de obrigações
- 8.2. Conceito
- 8.3. Contratos empresariais
- 8.4. Princípios informadores
- 8.5. Classificação dos contratos

Capítulo 9 - COMPRA E VENDA EMPRESARIAL

- 9.1. Conceitos e distinções
- 9.2. Características
- 9.3. Elementos formadores
- 9.4. Forma e prova do contrato
- 9.5. Execução do contrato de compra e venda
- 9.6. Direitos dos contratantes
- 9.7. Obrigações do vendedor
 - 9.7.1. Entrega da coisa
 - 9.7.2. Vícios
 - 9.7.3. Evicção
- 9.8. Obrigações do comprador
- 9.9. Modalidades especiais de compra e venda
 - 9.9.1. Venda de coisa móvel à vista de amostras
 - 9.9.2. Venda de imóvel ad mensuram e ad corpus
- 9.10. Cláusulas especiais
 - 9.10.1. Pacto de melhor comprador e pacto comissório
 - 9.10.2. Retrovenda
 - 9.10.3. Venda a contento e venda sujeita a prova
 - 9.10.4. Preempção ou preferência
 - 9.10.5. Venda com reserva de domínio

- 9.10.6. Venda sobre documentos
- 9.10.7. Crédito documentário
- 9.11. Cláusulas de custos em contratos internacionais – incoterms
- 9.12. Outros contratos relacionados à compra e venda
 - 9.12.1. Contrato estimatório
 - 9.12.2. Hedging
- 9.13. Resumo gráfico

Capítulo 10 - CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO AGÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONCESSÃO MERCANTIL

- 10.1. Distinções doutrinárias
- 10.2. Agência e distribuição
 - 10.2.1. Conceito
 - 10.2.2. Representação empresarial autônoma
 - 10.2.3. Natureza
 - 10.2.4. Forma contratual
 - 10.2.5. Contratantes: natureza e classificação
 - 10.2.6. Elementos essenciais do contrato
 - 10.2.7. Elementos acessórios do contrato
 - 10.2.8. Qualificação jurídica e distinções
 - 10.2.9. Distinções com o mandato e a comissão
 - 10.2.10. Retribuição
 - 10.2.11. Extinção do contrato
- 10.3. Distribuição por conta própria (revenda ou concessão comercial)
 - 10.3.1. Objeto e características
 - 10.3.2. Revenda de automóveis

- 10.3.3. Objeto de concessão
- 10.3.4. Zona de atuação
- 10.3.5. Principais deveres e direitos
- 10.3.6. Convenções
- 10.3.7. Formalidade contratual
- 10.3.8. Resolução de contrato
- 10.3.9. Indenizações nas resoluções de contrato

Capítulo 11 - FRANQUIA (FRANCHISING)

- 11.1. Origens e evolução
- 11.2. Função e classificação
- 11.3. Definição legal, noções e modalidades
- 11.4. Natureza do contrato de franquía
- 11.5. Formação e elementos do contrato
- 11.6. Pré-contrato e contrato de pilotage
- 11.7. Circular de oferta de franquía
- 11.8. Extinção do contrato

Capítulo 12 - MANDATO

- 12.1. Definição legal
- 12.2. Características do mandato
- 12.3. Requisitos subjetivos do contrato
- 12.4. Requisitos objetivos do contrato
- 12.5. Requisitos formais do contrato
- 12.6. Substabelecimento
- 12.7. Direitos e obrigações dos contratantes
- 12.8. Efeitos do mandato em relação a terceiros – excesso e aparência
- 12.9. Extinção do contrato

Capítulo 13 - COMISSÃO EMPRESARIAL

13.1. Definição legal

13.2. Origens

13.3. Características

13.4. Distinções com outros contratos

13.5. Direitos e obrigações dos contratantes

13.5.1. Relação entre comissário e terceiro

13.5.2. Relação entre comissário e comitente

13.6. Da remuneração do comissário

13.7. Efeitos da falência sobre o contrato

13.8. Cláusula del credere

Capítulo 14 - CONTRATOS BANCÁRIOS

14.1. Origem e conceito da atividade bancária

14.2. Contratos bancários históricos

14.3. Depósito bancário

14.3.1. Conceito e natureza jurídica

14.3.2. Classificações

14.3.3. Contas conjuntas

14.4. Desconto e redesconto

14.5. Mútuo bancário e outras formas de operação ativa

14.5.1. Espécies contratuais

14.5.2. Limitações contratuais

14.6. Crédito documentário

Capítulo 15 - CONTRATOS MODERNOS DE CRÉDITO E DE FOMENTO

15.1. Contratos modernos de crédito e de fomento

15.2. Da classificação

15.3. Cartões de crédito

15.3.1. Conceito

15.3.2. Espécies

15.3.3. Características contratuais

15.3.4. Natureza das empresas emissoras

15.3.5. Outras obrigações

15.4. Faturização (factoring ou fomento mercantil)

15.4.1. Conceito

15.4.2. Sujeitos da relação

15.4.3. Cláusulas essenciais

15.4.4. Direito de regresso

15.4.5. Garantias

15.5. Arrendamento mercantil (leasing)

15.5.1. Definição legal

15.5.2. Objeto

15.5.3. Modalidades

15.5.4. Obrigações dos contratantes

15.6. Alienação fiduciária em garantia

15.6.1. Conceito

15.6.2. Objeto

15.6.3. Modalidades

15.6.4. Elementos do contrato

15.6.5. Proteção processual

Capítulo 16 - CONTRATO DE TRANSPORTE

16.1. Origens

16.2. Definição legal e noções

16.3. Classificação jurídica

16.4. Espécies e estrutura legislativa

16.5. Agências reguladoras

16.5.1. Agência Nacional de Aviação Civil

16.5.2. Agência Nacional de Transportes Terrestres e Agência Nacional de Transportes Aquaviários

16.6. Formação e prova do contrato

16.6.1. Bilhete de passagem

16.6.2. Conhecimento de transporte

16.7. Transporte de pessoas

16.8. Transporte de bagagem

16.9. Transporte de coisas

16.9.1. Contrato de transporte regular e fretamento

16.9.2. Regras comuns ao contrato de transporte de coisa

16.9.3. Contrato de transporte multimodal

Capítulo 17 - CONTRATO DE SEGURO

17.1. Breves noções históricas

17.2. Conceitos, noções e definições

17.3. Legislação aplicável

17.4. Características

17.5. Formação e desenvolvimento contratual

17.5.1. Emissão da apólice ou do bilhete de seguro

17.5.2. A boa-fé na formação do contrato

17.5.3. Objeto da prestação

17.5.4. Nulidade na formação do contrato

17.5.5. Sujeitos da relação de seguro

17.6. Direitos e obrigações das partes

17.7. Espécies contratuais

17.7.1. Seguro de dano

17.7.2. Seguro de pessoa

BIBLIOGRAFIA

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ÍNDICE DA LEGISLAÇÃO

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

A Jesus, meu Senhor e Salvador.

“As palavras dos meus lábios e o
meditar do meu coração
sejam agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha
e redentor meu!” (Sl. 19.14)

Em memória de meu pai, Professor Sebastião Ramos Nogueira,
emérito educador.

À minha mãe e primeira Professora, Elza Negrão Nogueira,
de notável caráter e senso de justiça.

À Maria Teresa, companheira, amiga, colaboradora e adjunta.

Aos meus amados filhos, Paula, André, Filipe, Augusta e Lucas.

Aos meus netinhos, Tito, Ana Luísa, Mariana e João Filipe.

ABREVIATURAS

ACC — Adiantamento de Crédito em Contrato de câmbio para exportação

ADIn — Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo

AgReg. — Agravo Regimental

AI — Agravo de Instrumento

Apel. — Apelação

art. — artigo

arts. — artigos

BACEN — Banco Central do Brasil

BSTJ — Boletim do Superior Tribunal de Justiça

BTN — Bônus do Tesouro Nacional

CADE — Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CBA — Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986)

c/c — combinado com

CC — Código Civil de 2002

CC16 — Código Civil de 1916

CCom — Código Comercial

CDC — Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990)

Cf. — Conforme

CIMC — Convenção Interamericana sobre Conflito em Matéria de Cheques – Decreto n. 1.240, de 15 de setembro de 1994

CF88 — Constituição Federal de 1988

CJF — Conselho da Justiça Federal.

CLT — Consolidação das Leis do Trabalho
CMN — Conselho Monetário Nacional
CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
COF — Circular de Oferta de Franquia
CP — Código Penal
CPC — Código de Processo Civil
CPC15 — Código de Processo Civil de 2015
CPC39 — Código de Processo Civil de 1939
CPC73 — Código de Processo Civil de 1973
CPF — Cadastro de Pessoas Físicas
CNSP — Conselho Nacional de Seguros Privados
CRDE — Câmara Reservada de Direito Empresarial (TJSP)
CTN — Código Tributário Nacional
CVM — Comissão de Valores Mobiliários
D. — Decreto
Des. — Desembargador
DJ — Diário da Justiça
DJU — Diário da Justiça da União
DNRC — Departamento Nacional de Registro do Comércio
DREI — Departamento de Registro Empresarial e Integração
ed. — edição
Edcl. — Embargos de declaração
EPP — Empresa de Pequeno Porte
IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS — Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias

Prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação

ICP — Infraestrutura de Chaves Públicas

IFA — International Franchise Association

IGP-DI — Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna

IN — Instrução Normativa

IPC — Índice de Preços ao Consumidor

IPI — Imposto sobre Produtos Industrializados

j. — julgado em

LBCD — Lei de Contabilidade Digital

LC — Lei do Cheque (Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985)

LD — Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968)

LDA — Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1996)

LF45 — Lei de Falências Anterior (Decreto-Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945)

LFE — Lei de Franquia Empresarial (Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994)

LLI — Lei de Locação de imóveis urbanos (Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991)

LPI — Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996)

LRCA — Lei que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos (Lei n. 4.866, de 9 de dezembro de 1965)

LREF — Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005)

LRM — Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (Lei n. 8.934, de 18 de novembro de 1994)

LRP — Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973)

LS — Lei Saraiva (Decreto n. 2.044, de 31 de dezembro de 1968)

LSA — Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

LUG — Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966)

ME — microempresa

MP — Medida Provisória

Min. — Ministro

n. — número

NF-e — Nota fiscal eletrônica

p. — página

PGFN — Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

PTAC — Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo

QGC — Quadro Geral de Credores

RAET — Regime de Administração Especial Temporária

RDBMCA — Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem

RE — Recurso Extraordinário

Rel. — Relator

REsp — Recurso Especial

Rev. — Revisor

RMS — Recurso em Mandado de Segurança

RT — Revista dos Tribunais

SINARM — Sistema Nacional de Armas

STF — Supremo Tribunal Federal

STJ — Superior Tribunal de Justiça

TFR — Tribunal Federal de Recursos

TJSP — Tribunal de Justiça de São Paulo

TR — Taxa Referencial

TRD — Taxa Referencial Diária

TST — Tribunal Superior do Trabalho

v. — veja

vol. — volume

v.u. — votação unânime

AO LEITOR

Além da alteração no título da obra, a partir da 6ª edição atualizamos o texto segundo as mudanças introduzidas pela Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil), acrescentando inúmeros comentários e alguns julgados dos Tribunais que entendemos pertinentes e necessários à compreensão da matéria.

Não houve alteração no número de capítulos. Esta obra ainda abrange todo o programa de Direito Comercial – Direito Empresarial das faculdades reconhecidas:

Volume I – Evolução Histórica do Direito Comercial, Teoria Geral da Empresa e Direito Societário.

Volume II – Títulos de Crédito e Contratos Empresariais.

Volume III – Recuperação Judicial e Extrajudicial, Falência, Procedimento Concursais Administrativos, incluindo a intervenção, a liquidação extrajudicial e o regime especial de administração temporária das instituições financeiras.

Nossa intenção é contribuir para o debate que, por certo, ocorrerá na doutrina e nos Tribunais.

Sempre grato pelas sugestões e críticas,

O Autor

LIVRO I

TÍTULOS DE CRÉDITO

Capítulo 1

INTRODUÇÃO À TEORIA GERAL DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Sumário: 1.1. Noções. 1.2. Classificação dos títulos de crédito. 1.2.1. Classificação comum na doutrina. 1.2.2. Classificação de Carvalho de Mendonça. 1.2.3. Classificação de Vivante. 1.2.4. Classificação portuguesa de Pup Correia. 1.2.5. Outras classificações mencionadas pela doutrina. 1.3. Espécies reguladas no Direito Brasileiro. 1.4. Princípios que regem os títulos de crédito. 1.4.1. Cartularidade. 1.4.2. Autonomia. 1.4.3. Literalidade. 1.5. Os arts 887-926 do Código Civil e os títulos anteriormente regulamentados. 1.6. Títulos de crédito virtuais ou eletrônicos. 1.6.1. Títulos virtuais e princípios cambiais. 1.6.2. Duplicata virtual. 1.6.3. Avanço tecnológico e diplomas legislativos.

1.1. Noções

Cesare Vivante (1910:136) afirma que “o documento de um crédito só adquire o caráter jurídico de um título de crédito, quando pela sua disciplina – que pode ser fixada pela lei ou pelo contrato – é necessário para transmitir ou exigir o direito literal e autônomo nele mencionado”.

Três noções podem ser extraídas da constatação de Vivante: (a) o título é documento ou quirógrafo¹ de um *crédito*, isto é, envolve relação de confiança e prazo entre credor e devedor; (b) além disso, nem todo documento é um título de crédito; para tanto deve haver uma disciplina jurídica, contratual ou legal, que o defina como tal; (c) o direito de crédito, em tese, existe e se transmite com o documento em que ele se materializa. Diz-se em tese porque a lei autoriza, em alguns casos, a substituição do documento original, como ocorre se houver perda ou extravio do título ou, ainda, na hipótese de não devolução da duplicata remetida para aceite do sacado.

A relação de confiança e concessão de prazo é inerente ao crédito. O título

somente será *de crédito* se representar uma operação com esses elementos, ou na superior expressão de Eunápio Borges (1975:7):

“Na noção de crédito estão implícitos os seguintes elementos:

a) a confiança: quem aceita, em troca de sua mercadoria ou de seu dinheiro, a promessa de pagamento futuro, confia no devedor. Confiança que pode não repousar exclusivamente no devedor, mas em garantias pessoais (aval, fiança) ou reais (penhor, hipoteca etc.) que ele ofereça em segurança da oportuna realização da prestação futura a que se obrigou; mas de qualquer forma é sempre a confiança elemento essencial do crédito;

b) o tempo, constituindo o prazo o intervalo, o período que medeia entre a prestação presente e atual e a prestação futura”.

Com estas considerações iniciais há de se ter em mente que os títulos de crédito são documentos que se reportam exclusivamente a relações que envolvam crédito e sua disciplina legal provê instrumentos ágeis de transmissibilidade, de segurança e de cobrança em Juízo.

Há documentos que seguem grande parte do regime disciplinador dos títulos de crédito, mas não representam pura relação de crédito, mas outra operação qualquer. São os chamados *títulos impróprios* ou *atípicos*, sobre os quais ensina Fran Martins (1995, 1:27): “são os títulos que não representam uma verdadeira operação de crédito, mas que, revestidos de certos requisitos dos títulos de crédito propriamente ditos, circulam com as garantias que caracterizam esses papéis”.

1.2. Classificação dos títulos de crédito

É grande a variedade de títulos de crédito, bem como sua classificação. A doutrina faz uso de vários critérios distintos para agrupá-los.

1.2.1. Classificação comum na doutrina

A doutrina brasileira e estrangeira prefere classificar os títulos de crédito quanto ao modo de circulação. É a anotada por Carvalho de Mendonça (1955, 5:58), em seu clássico *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*:

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MODO DE CIRCULAÇÃO

- a) **nominativos**, se o nome da pessoa, natural ou jurídica, com direito à prestação se acha anotado no próprio título ou nos registros especiais do instituto emissor, sendo transferíveis mediante ato formal;
- b) **à ordem**, se emitidos em benefício da pessoa indicada ou daquela a que esta determinar (*ordenar*) e transferíveis por meio do endosso, neles lançado;
- c) **ao portador**, se emitidos genericamente em favor do possuidor e transferíveis por simples tradição manual;
- d) **mistos**: títulos *nominativos* munidos de *cupões ao portador*.

Esta classificação, igualmente exposta e adotada por autores brasileiros e estrangeiros, recebe críticas de Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:389), que prefere distinguir os títulos em (a) ao portador e (b) nominativos, subdividindo estes em “à ordem” e “não à ordem”, justificando que para o direito brasileiro não faz sentido separar os títulos à ordem dos títulos nominativos, como ocorre na Itália, onde há previsão legislativa.

Respeitando a opinião do mestre paulista, há de se lembrar que o Código Civil de 2002 adotou expressamente a tríplice divisão, definindo-os em capítulos distintos, no Título VIII: (a) o Capítulo II trata do título ao portador e seu mecanismo de circulação vem expresso no art. 904: “A transferência de título ao portador se faz por simples tradição”; (b) o Capítulo III dispõe sobre o título à ordem e é encabeçado pelo art 910: “O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso no próprio título”; (c) finalmente, o Capítulo IV inicia-se com a definição de título nominativo: “É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente” (CC, art. 921).

1.2.2. Classificação de Carvalho de Mendonça

Carvalho de Mendonça (1955:55-56), após relatar “a dificuldade extrema do assunto sob o ponto de vista doutrinário” e pedir que não a censurássemos, sem apresentar outra que satisfizesse o senso científico, apresenta outra categorização, que observa duas ordens de conteúdo cartular:

DUAS ORDENS QUANTO AO CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO CARTULAR

• Títulos de crédito propriamente ditos: atestam uma <i>operação de crédito</i>. Por ex.: os títulos da dívida pública, as letras de câmbio, os <i>warrants</i>, as debêntures etc.	
• Títulos de crédito impropriamente ditos: “nos quais ainda que não representem uma operação de crédito, se encontram, a par da sua literalidade e autonomia, <i>id quod quacumque causa debetur</i>”.	• Títulos que permitem a disponibilidade de certas mercadorias. Por ex.: conhecimento de depósito, conhecimento de transporte. • Título que permite retirar a totalidade dos fundos existentes em poder do comerciante: cheque. • Títulos atributivos do complexo de direitos conexos à qualidade de sócio: ações das sociedades anônimas e comanditas por ações.

1.2.3. Classificação de Vivante

Esta segunda classificação do notável jurista brasileiro recebe em Vivante (1910:138-139) e, mais recentemente, em Pupo Correia (1999:107-108) outro tratamento, um pouco distinto do apresentado pelo tratadista pátrio. Para Vivante, os títulos, quanto ao conteúdo, podem distinguir-se em três categorias:

a) Títulos de crédito que representam um direito real: guias de transporte, conhecimento de carga, certificados de depósito e as cautelas do penhor. “Quem tem a posse destes títulos considera-se de posse das mercadorias, porque o seu depositário, o transportador, o capitão, o guarda do armazém, só as podem entregar ao legítimo possuidor do título”;

b) Títulos que conferem uma prestação, da parte do devedor, ao pagamento de uma soma (títulos de renda, escritos do tesouro, títulos de loteria, notas de bancos, cédulas prediais, letras de câmbio, cheques); à entrega de uma quantidade de mercadorias (ordens em gênero) ou a certo serviço (bilhetes de viagem, bilhetes de espetáculos públicos, selos de correio, bilhetes postais);

c) Títulos que atribuem ao possuidor alguns direitos de diversa índole: as ações

das sociedades comerciais, que conferem direito de exigir os dividendos e o capital e a tomar parte das assembleias.

1.2.4. Classificação portuguesa de Pupo Correia

Para Pupo Correia, o conteúdo dos títulos permite visualizar três ordens de categorias:

a) Títulos de crédito propriamente ditos: letras de câmbio, livrança (nota promissória), extratos de fatura (duplicatas), obrigações (debêntures), papel comercial, certificados de depósito e títulos de participação (que, em Portugal, pelo Decreto-lei n. 321/85, conferem remuneração pecuniária que inclui participação nos lucros da empresa – no Brasil são chamadas partes beneficiárias);

b) Títulos representativos: são os que “incorporam direitos sobre determinadas coisas”: conhecimento de depósito e *warrant*, guia de transporte, conhecimento de carga ou de embarque, guia de transporte aéreo;

c) Títulos de participação social: as ações.

1.2.5. Outras classificações mencionadas pela doutrina

a) Quanto ao emitente: os títulos podem ser públicos (apólices, letras do tesouro, títulos da dívida pública etc.) ou privados, quando emitidos por pessoas naturais ou jurídicas no interesse de seus negócios.

b) Quanto à causa subjacente ou à relação fundamental dividem-se em causais, os que se ligam a uma relação jurídica criadora, e abstratos, o que, desde a criação, abstraem a causa inicial;

c) Quanto à nacionalidade: nacionais e estrangeiros;

d) Quanto ao prazo: à vista e a prazo;

e) Quanto ao número: individuais e seriados;

f) Quanto às leis que os regem: bancários, cambiais, imobiliários, rurais, cooperativos, acionários etc.

1.3. Espécies reguladas no Direito Brasileiro

Apresentamos uma lista não exaustiva dos títulos de crédito regulados no Direito Brasileiro, ordenados em primeiro lugar pela norma legal e, em segundo lugar, por ordem alfabética de suas denominações:

LEGISLAÇÃO	DENOMINAÇÃO	DEFINIÇÃO LEGAL
Lei n. 165-A, de 17 de janeiro de 1890 (art. 4º). Lei n. 4.829, de 5 de novembro de 1965 (art. 25, V). Observação: no D. s/n, de 25 de abril de 1991, que trata de reconhecimento de cursos superiores, foi introduzido o art. 4º, que declarou revogados milhares de decretos relacionados em seu anexo, incluindo a Lei n. 165-A. Contudo, não há menção da revogação da Lei n. 4.829/65.	Bilhete de mercadoria	Lei n. 165-A – Art. 4º São válidos, e gozam de todas as garantias da letra de câmbio, os bilhetes à ordem pagáveis em mercadorias. Lei n. 4.829/65 – Art. 25. Poderão constituir garantia dos empréstimos rurais, de conformidade com a natureza da operação creditícia, em causa: ... V – Bilhete de mercadoria;
D. n. 1.102, de 21 de novembro de 1903 (art. 15).	Conhecimento de depósito	Art. 15. Os armazéns-gerais emitirão, quando lhes for pedido pelo depositante, dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominados – conhecimento de depósito e <i>warrant</i>.
		Art. 15. Os

D. n. 1.102, de 21 de novembro de 1903 (art. 15)	<i>Warrant</i>	armazéns-gerais emitirão, quando lhes for pedido pelo depositante, dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominados – conhecimento de depósito e <i>warrant</i> .
D. n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 (arts. 54-56), alterado pelo D. 57.663, de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme, arts. 75-78).	Nota promissória	Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso, no contexto.

2

LEGISLAÇÃO	DENOMINAÇÃO	DEFINIÇÃO LEGAL
D. n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 (art. 1º), alterado pelo D. 57.663, de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme).	Letra de câmbio	Art. 1º A letra de câmbio é uma ordem de pagamento e deve conter estes requisitos, lançados por extenso, no contexto.
D. n. 19.473/30, com as alterações introduzidas pelos D. ns. 19.754/31, 20.454/31 e 21.736/32 ² .	Conhecimento de transporte	Art. 1º O conhecimento de frete original, emitido por empresas de transporte por água, terra ou ar, prova o recebimento da mercadoria e a obrigação de entregá-la no lugar do destino. Reputa-se não escrita qualquer cláusula restritiva, ou modificativa, dessa prova, ou obrigação. É título à ordem; salvo cláusula ao portador, lançada no contexto.

Lei n. 4.830, de 21 de agosto de 1964.	Letra imobiliária	Art. 44. § 1º A letra imobiliária é promessa de pagamento e quando emitida pelo Banco Nacional da Habitação será garantida pela União Federal.
Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965 (art. 30).	Certificado de depósito bancário	Art. 30. § 1º O certificado de depósito bancário é promessa de pagamento à ordem da importância do depósito, acrescida do valor da correção e dos juros convencionados.
Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965 (art. 31).	Certificado de depósito em garantia	Art. 31. Os bancos referidos no art. 29, quando previamente autorizados pelo Banco Central e nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderão emitir “certificados de depósitos em garantia”, relativos a ações preferenciais, obrigações, debêntures ou títulos cambiais emitidos por sociedades interessadas em negociá-las em mercados externos, ou no País.
D. n. 57.595, de 7 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme), e Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985.	Cheque	Lei n. 7.357/85 Art. 1º O cheque contém: I – a denominação “cheque” inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido; II – a ordem incondicional de pagar quantia determinada; III – o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado); IV – a indicação do lugar de pagamento; V – a indicação da data e do lugar de emissão; VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.
DL n. 70, de 21 de novembro de 1966, e		Art. 10. É instituída a cédula hipotecária para hipotecas inscritas no Registro Geral de Imóveis, como instrumento hábil para a representação dos respectivos créditos hipotecários, a qual poderá ser emitida pelo credor hipotecário nos casos de:

Resolução n. 228, de 4 de julho de 1972, do Bacen.	Cédula hipotecária	I – operações compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação; II – hipotecas de que sejam credores instituições financeiras em geral, e companhias de seguro; III – hipotecas entre outras partes, desde que a cédula hipotecária seja originariamente emitida em favor das pessoas jurídicas a que se refere o inciso II <i>supra</i> .
DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.	Cédula rural hipotecária	Art. 9º A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: I – Cédula Rural Pignoratícia (art. 14). II – Cédula Rural Hipotecária (art. 20). III – Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (art. 25). IV – Nota de Crédito Rural (art. 27).
DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.	Cédula rural pignoratícia	Arts. 9º, I, e 14.
DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.	Cédula rural pignoratícia e hipotecária	Arts. 9º, I, e 25.
DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.	Duplicata rural	Art. 46. Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, poderá ser utilizada também, como título do crédito, a duplicata rural, nos termos deste Decreto-lei.
DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.	Nota de crédito rural	Arts. 9º, IV, e 27.
		Art. 43. A nota promissória rural conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto: I – Denominação “Nota Promissória Rural”. II – Data do pagamento. III – Nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega os bens e

DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.	Nota promissória rural	a qual deve ser paga, seguido da cláusula à ordem. IV – Praça do pagamento. V – Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adquiridos ou recebidos ou no adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para venda. VI – Indicação dos produtos objeto da compra e venda ou da entrega. VII – Data e lugar da emissão. VIII – Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.
Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo DL n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.	Duplicata mercantil	Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.
Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo DL n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.	Duplicata de prestação de serviços	Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata. § 1º A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados. § 2º A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados.
Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações		Art. 22. Equiparam-se às entidades constantes do art. 20, para os efeitos da presente Lei, ressalvado o disposto no Capítulo VI, os profissionais liberais e os que prestam serviço de natureza eventual

introduzidas pelo DL n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.	Fatura ou conta de serviços	desde que o valor do serviço ultrapasse a NCr\$ 100,00 (cem cruzeiros novos). § 1º Nos casos deste artigo, o credor enviará ao devedor fatura ou conta que mencione a natureza e valor dos serviços prestados, data e local do pagamento e o vínculo contratual que deu origem aos serviços executados.
DL n. 413, de 9 de janeiro de 1969.	Cédula de Crédito Industrial	Art. 9º A cédula de crédito industrial e promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real, cedularmente constituída. Art. 10. A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.
DL n. 413, de 9 de janeiro de 1969.	Nota de Crédito Industrial	Art. 15. A nota de crédito industrial é promessa de pagamento em dinheiro, sem garantia real.
Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	Conhecimento de depósito de cooperativa	Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá registrar-se como armazém-geral, podendo também desenvolver as atividades previstas na Lei n. 9.973, de 29 de maio de 2000, e nessa condição expedir Conhecimento de Depósito, <i>Warrant</i> , Certificado de Depósito Agropecuário – CDA e <i>Warrant</i> Agropecuário – WA para os produtos de seus associados conservados em seus armazéns, próprios ou arrendados, sem prejuízo da emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades normais, aplicando-se, no que couber, a legislação específica.
Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	Certificado de Depósito Agropecuário de Cooperativa – CDA	Idem.
Lei n. 5.764, de		

16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	<i>Warrants</i> cooperativa de	Idem.
Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	<i>Warrants</i> agropecuário de cooperativa	Idem.
Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e Circular Bacen n. 7.586, de 25 de outubro de 1977.	Cédula de Crédito à Exportação	Art. 1º As operações de financiamento à exportação ou à produção de bens para exportação, bem como às atividades de apoio e complementação integrantes e fundamentais da exportação, realizadas por instituições financeiras, poderão ser representadas por Cédula de Crédito à Exportação e por Nota de Crédito à Exportação com características idênticas, respectivamente, à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial, instituídas pelo Decreto-lei n. 413, de 9 de janeiro de 1969. Parágrafo único. A Cédula de Crédito à Exportação e a Nota de Crédito à Exportação poderão ser emitidas por pessoas físicas e jurídicas, que se dediquem a qualquer das atividades referidas neste artigo.
Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e Circular Bacen n. 7.586, de 25 de outubro de 1977.	Nota de Crédito à Exportação	Idem.
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro		Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens

de 1976.	Ações	que confirmam a seus titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição.
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.	Bônus de subscrição	Art. 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no estatuto (artigo 168), títulos negociáveis denominados “Bônus de Subscrição”. Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações.
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.	Cédula pignoratícia de debêntures	Art. 72. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil a efetuar esse tipo de operação poderão emitir cédulas garantidas pelo penhor de debêntures, que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra o emitente, pelo valor nominal e os juros nelas estipulados.
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.	Certificado de depósito de ações	Art. 43. A instituição financeira autorizada a funcionar como agente emissor de certificados (artigo 27) poderá emitir título representativo das ações endossáveis ou ao portador que receber em depósito, do qual constarão:
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.	Certificado de depósito de partes beneficiárias	Art. 50. As partes beneficiárias podem ser nominativas, endossáveis e ao portador, e a elas se aplica, no que couber, o disposto nas Seções V a VII do Capítulo III. § 1º As partes beneficiárias nominativas e endossáveis serão registradas em livros próprios, mantidos pela companhia. § 2º As partes beneficiárias podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43.
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.	Debêntures	Art. 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado.
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.	Partes beneficiárias	Art. 46. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados “partes beneficiárias”. § 1º As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de

		crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais (artigo 190).
Lei n. 6.840, de 3 de novembro de 1980.	Cédula de crédito comercial	Art. 1º As operações de empréstimo concedidas por instituições financeiras a pessoa física ou jurídica que se dedique a atividade comercial ou de prestação de serviços poderão ser representadas por Cédula de Crédito Comercial e por Nota de Crédito Comercial.
Lei n. 6.840, de 3 de novembro de 1980.	Nota de crédito comercial	Idem.
Lei n. 7.684, de 2 de dezembro de 1988.	Letra hipotecária	Art. 1º As instituições financeiras, autorizadas a conceder créditos hipotecários, poderão sacar, independentemente de tradição efetiva, letras da mesma espécie, garantidas por créditos hipotecários, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, atualização monetária e juros nelas estipulados.
Lei n. 8.929, de 22 de agosto de 1994.	Cédula de Produto Rural – CPR	Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural – CPR, representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída. Art. 2º Têm legitimação para emitir CPR o produtor rural e suas associações, inclusive cooperativas.
Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.	Cédula de Crédito Bancário	Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.	Cédula de Crédito Imobiliário	Art. 18. É instituída a Cédula de Crédito Imobiliário – CCI para representar créditos imobiliários. § 1º A CCI será emitida pelo credor do crédito imobiliário e poderá ser integral, quando representar a totalidade do crédito, ou fracionária, quando representar parte dele, não podendo a soma das CCI fracionárias emitidas em relação a cada crédito exceder o valor total do crédito que elas representam.
		Art. 12. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de

Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.	Letra de Crédito Imobiliário – LCI	crédito imobiliário, a Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e demais espécies de instituições que, para as operações a que se refere este artigo, venham a ser expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, poderão emitir, independentemente de tradição efetiva, Letra de Crédito Imobiliário – LCI, lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nelas estipulados.
Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004, com redação dada pela Lei n. 11.524, de 2007.	Certificado de Depósito Agropecuário – CDA	Art. 1º Ficam instituídos o Certificado de Depósito Agropecuário – CDA e o <i>Warrant</i> Agropecuário – WA. § 1º O CDA é título de crédito representativo de promessa de entrega de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, depositados em conformidade com a Lei n. 9.973, de 29 de maio de 2000. § 2º O WA é título de crédito representativo de promessa de pagamento em dinheiro que confere direito de penhor sobre o CDA correspondente, assim como sobre o produto nele descrito. § 3º O CDA e o WA são títulos unidos, emitidos simultaneamente pelo depositário, a pedido do depositante, podendo ser transmitidos unidos ou separadamente, mediante endosso. § 4º O CDA e o WA são títulos executivos extrajudiciais.
Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	<i>Warrant</i> agropecuário	Idem.
Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA	Art. 24. O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA é título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial.
Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	Letra de Crédito do Agronegócio – LCA	Art. 26. A Letra de Crédito do Agronegócio – LCA é título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. Parágrafo único. A LCA é de emissão exclusiva de instituições financeiras públicas ou privadas.

Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.	Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA	Art. 36. O Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA é título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial.
Lei n. 11.882, de 23 de dezembro de 2008.	Letra de Arrendamento Mercantil – LAM	Art. 2º As sociedades de arrendamento mercantil poderão emitir título de crédito representativo de promessa de pagamento em dinheiro, denominado Letra de Arrendamento Mercantil – LAM.
Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018.	Duplicata escritural	Art. 2º A duplicata de que trata a Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, pode ser emitida sob a forma escritural, para circulação como efeito comercial, observadas as disposições desta Lei.
Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018.	Extrato de registro eletrônico de duplicata escritural	Art. 7º A duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato de que trata o art. 6º desta Lei são títulos executivos extrajudiciais, devendo-se observar, para sua cobrança judicial, o disposto no art. 15 da Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968.

Ordenando por denominação do título de crédito, indicando apenas a legislação aplicável, teremos:

DENOMINAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Ações	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Bilhete de mercadoria	Lei n. 165-A, de 17 de janeiro de 1890 (art. 4º). Lei n. 4.829, de 5 de novembro de 1965 (art. 25, V). Observação: no Dec. s/n, de 25 de abril de 1991, que trata de reconhecimento de cursos superiores, foi introduzido o art. 4º, que declarou revogados milhares de decretos relacionados em seu anexo, incluindo a Lei n. 165-A. Contudo, não há menção da revogação da Lei n. 4.829/65.
Bônus de subscrição	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Cédula de Crédito à Exportação	Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975, e Circular Bacen n. 7.586, de 25 de outubro de 1977.

Cédula de Crédito Bancário	Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.
Cédula de Crédito Comercial	Lei n. 6.840, de 3 de novembro de 1980.
Cédula de Crédito Imobiliário – CCI	Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.
Cédula de Crédito Industrial	DL n. 413, de 9 de janeiro de 1969.
Cédula de Produto Rural – CPR	Lei n. 8.929, de 22 de agosto de 1994.
Cédula hipotecária	DL n. 70, de 21 de novembro de 1966, e Resolução n. 228, de 4 de julho de 1972, do Bacen.
Cédula pignoratória de debêntures	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Cédula rural hipotecária	DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Cédula rural pignoratória	DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Cédula rural pignoratória e hipotecária	DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Certificado de Depósito Agropecuário – CDA	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Certificado de Depósito Agropecuário de	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.

Cooperativa – CDA	
Certificado de depósito bancário	Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965 (art. 30).
Certificado de depósito de ações	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Certificado de depósito de partes beneficiárias	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Certificado de depósito em garantia	Lei n. 4.728, de 14 de julho de 1965 (art. 31).
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Certificado de Recebíveis do Agronegócio – CRA	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Cheque	D. n. 57.595, de 7 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme), e Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985.
Conhecimento de depósito	D. n. 1.102, de 21 de novembro de 1903 (art. 15).
Conhecimento de depósito cooperativa	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Conhecimento de transporte	D. n. 19.473/30, com as alterações introduzidas pelos D. n. 19.754/31, 20.454/31 e 21.736/32.
Debêntures	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Duplicata de prestação de serviços	Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo DL n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.
Duplicata escritural	Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018.
Duplicata mercantil	Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo DL n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.
Duplicata rural	DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Extrato de registro eletrônico de duplicata escritural	Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018.
Fatura ou conta de serviços	Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com alterações introduzidas pelo DL n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.
Letra de arrendamento mercantil	Lei n. 11.882, de 23 de dezembro de 2008.
Letra de câmbio	D. n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 (art. 1º), alterado pelo D. 57.663, de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme).
Letra de Crédito do Agronegócio – LCA	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
Letra de Crédito Imobiliário – LCI	Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.
Letra hipotecária	Lei n. 7.684, de 2 de dezembro de 1988.
Letra imobiliária	Lei n. 4.830, de 21 de agosto de 1964.
Nota de crédito rural	DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.

Nota de Crédito à Exportação	Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975 e Circular Bacen n. 7.586, de 25 de outubro de 1977.
Nota de Crédito Comercial	Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975 e Circular Bacen n. 7.586, de 25 de outubro de 1977, e Lei n. 6.840, de 3 de novembro de 1980.
Nota de Crédito Industrial	DL n. 413, de 9 de janeiro de 1969.
Nota promissória	D. n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 (arts. 54-56), alterado pelo D. 57.663, de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme, arts.75-78).
Nota promissória rural	DL n. 167, de 14 de fevereiro de 1967.
Partes beneficiárias	Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
<i>Warrant</i>	D. n. 1.102, de 21 de novembro de 1903 (art. 15).
<i>Warrant</i> agropecuário	Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
<i>Warrant</i> de cooperativa	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.
<i>Warrant</i> agropecuário de cooperativa	Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, com a alteração dada pelo art. 47 da Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004.

1.4. Princípios que regem os títulos de crédito

A clássica definição de título de crédito de Cesare Vivante (“É o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado”) foi emprestada pelo legislador brasileiro no art. 887 do Código Civil: “O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei”.

Do conceito e da definição jurídica são extraídas as três características essenciais

dos títulos de crédito: a cartularidade ou incorporação (documento necessário), a autonomia (direito autônomo nele contido) e a literalidade (direito literal nele contido).

1.4.1. Cartularidade

A cartularidade ou incorporação invoca a *necessidade* ou *indispensabilidade*, isto é, sem o documento não se exerce o direito de crédito nele mencionado. A pessoa detentora do título – de boa-fé – é reconhecida como credora da prestação nele incorporada e, inversamente, sem a apresentação do título, não há como obrigar o devedor a cumprir a obrigação inscrita no título.

Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. (2007:65-66) prefere a expressão *incorporação* e justifica com muita propriedade essa escolha: “Entendemos que a incorporação explica melhor esse fenômeno do direito cambiário, uma vez que sem ela não há que se falar em cartularidade porque se o portador necessita apresentar o título para exercer o direito cambiário (cartularidade), é porque este (direito cambiário) materializa-se, incorpora-se no título (incorporação)”.

1.4.2. Autonomia

A autonomia é o princípio que melhor garante a plena negociabilidade dos títulos de crédito, concedendo-lhe agilidade, dada a segurança jurídica com que reveste o escrito cartular. Carvalho de Mendonça (1955:52) assim se expressa, ao referir-se ao direito do possuidor: “(...) se investe de direito próprio, originário, ficando imune das exceções oponíveis aos precedentes possuidores. Os seus traços predominantes são a negociabilidade e a força que adquirem com a boa-fé do possuidor”.

A autonomia é a característica dos títulos de crédito que garante a independência obrigacional das relações jurídicas subjacentes, simultâneas ou sobrejacentes à sua criação e circulação e impede que eventual vício em uma relação se comunique às demais ou invalide a obrigação literal inscrita na cártula.

Para se compreender este princípio e seus principais efeitos, convém lembrarmos que sempre existe uma causa – um fato jurídico – que dá origem à criação do título,

como, por exemplo, um mútuo que contratamos com um banco. Recebemos o dinheiro emprestado e emitimos uma nota promissória com vencimento marcado para uma data futura.

Esta primeira causa é chamada de *causa subjacente ou simultânea ao nascimento*, isto é, originária do título e só interessa ao mutuário e ao banco com o qual contratamos.

Circulação é o ato em que o banco endossa o título, transmitindo o direito de crédito, a outra pessoa (natural ou jurídica). Neste momento emerge uma das consequências³ da autonomia – a abstração – isto é, o título se liberta da causa subjacente, ganha independência do negócio jurídico inicial. Pode haver aqui outra causa, outra relação jurídica. Por exemplo: o banco *A* com quem contratei o mútuo, pela transmissão do crédito, com o endosso do título, está quitando uma dívida com fornecedores de móveis *B* para a agência situada na cidade de Bauru.

Esta segunda causa – sobrejacente ou causa posterior à emissão – interessa apenas ao banco e ao fornecedor de móveis *B*.

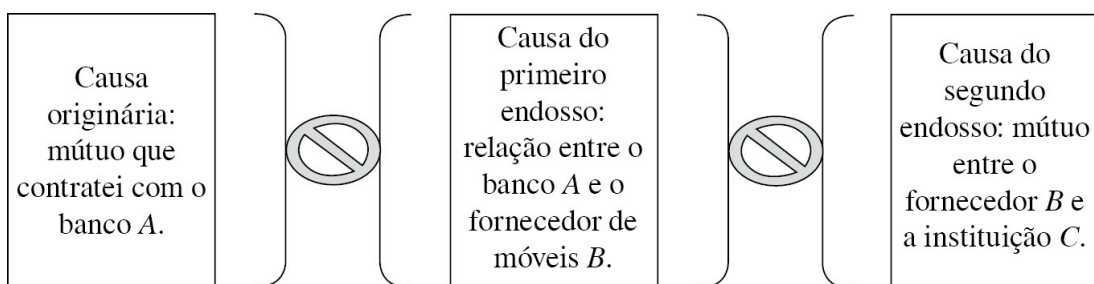
Ao fornecedor de móveis, por sua vez, pode interessar o desconto do título junto a outra instituição financeira que lhe adiantará o numerário, mediante a entrega do título por novo endosso. Este terceiro negócio tem a natureza de mútuo e interessa somente ao fornecedor de móveis e à instituição financeira *C*.

Como se vê, as causas (mútuo, fornecimento de móveis e novo mútuo) de emissão e de circulação são distintas e as relações decorrentes são independentes umas das outras.

Pupo Correia (1999:159-160) trata da abstração em dois sentidos porque: (a) “não tem uma causa-típica, antes pode prosseguir uma multiplicidade de causas-funções, inerentes a diversos negócios jurídicos que podem estar na origem da relação subjacente: compra e venda, mútuo etc.”; (b) “a obrigação cambiária é independente da causa e, por consequência, não sofre as consequências dos vícios da sua causa, isto é, são inoponíveis ao portador mediato e de boa-fé as chamadas exceções causais, ou sejam as resultantes de possíveis vícios da relação subjacente ou

fundamental”.

Uma segunda consequência deriva da independência das relações jurídicas e da abstração⁴ das obrigações umas das outras: a inoponibilidade das exceções pessoais contra o portador de boa-fé, ou, nas palavras do legislador da Lei Uniforme: “as pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor” (LUG, art. 17).



Por força da **ABSTRAÇÃO**, as obrigações mantêm-se independentes umas das outras, e, por decorrência da **INOPONIBILIDADE** das exceções pessoais, os devedores não podem alegar vícios e defeitos de suas relações jurídicas contra o portador de boa-fé que não participou do negócio jurídico do qual resultou a dívida que lhes é exigida.

Considerando o exemplo do texto e utilizando os indicadores encontrados na notação de Rubens Requião (1995:317) – O (para permitir a discussão da causa) e Ø (para não permitir a discussão da causa) –, podemos chegar à seguinte expressão:

EU O banco A
EU (“A”) Ø fornecedor B
EU (“A”) Ø instituição financeira C

Ou seja: posso opor exceções ao banco A, relativas à causa que deu nascimento a nossa relação cambial, mas não posso invocar minha relação com A opondo-me a B ou a C. Esta consequência do princípio da autonomia (não oposição ou

inoponibilidade) alcança todas as relações que se formarem durante o período de circulação dos títulos e que envolvam as partes originárias, endossantes e avalistas.

1.4.3. Literalidade

A literalidade, na linguagem de Carvalho de Mendonça (1955:52), “determina o seu conteúdo e a sua extensão”; é, portanto, medida do direito inscrito no título. O que está escrito é exatamente a quantidade do crédito do portador e a extensão da obrigação do devedor. Nem o primeiro pode exigir mais nem o segundo deverá pagar além do que está escrito. Eunápio Borges (1975:13) completa a noção funcional do princípio da literalidade com o seguinte entendimento: “para a expressão da existência, conteúdo, extensão e modalidades do direito, é decisivo exclusivamente o teor do título”.

Por este princípio implica dizer que vale o que está escrito e que, se algo diverso tiver sido contratado, não estando escrito no título, não pode ser alegado pelas pessoas intervenientes em defesa de seus direitos.

Consequências práticas encontram-se nas legislações que regulam os títulos de crédito ao exigir estrita obediência à formalidade de sua criação e, ainda, a determinar que as obrigações subsequentes sejam lançadas na própria cártula, como, por exemplo, o endosso “deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta – anexo” (LUG, art. 13) e “transmite todos os direitos emergentes da letra” (LUG, art. 14); “o aceite é escrito na própria letra” (LUG, art. 25); o aval é “escrito na própria letra ou numa folha anexa” (LUG, art. 30); o pagamento parcial deve ser mencionado no título (LUG, art. 39); o coobrigado que pagar a letra pode riscar o seu endosso os dos endossantes subsequentes (LUG, art. 50); “o aceite por intervenção será mencionado na letra” (LUG, art. 57).

Em todos esses casos a lei exige a inscrição da operação cambial na própria cártula porque desse ato é que se extraem o crédito, sua modalidade e tratamento jurídico, o *quantum* exigível, quem está obrigado a pagar e, ainda, a existência ou não de direito de crédito de uns contra os outros, conforme ordem de intervenção lançada no título.

1.5. Os arts. 887-926 do Código Civil e os títulos anteriormente regulamentados

O Título VIII do Código Civil de 2002, que trata dos Títulos de Crédito, sofre uma avalanche de críticas da doutrina, sobretudo em função de sua quase total prescindibilidade por não reger os títulos de crédito – próprios ou impróprios – submetidos à regência própria em lei especial, isto é, todos os existentes quando da entrada em vigor do Código Civil.

É o que decorre do art. 903 do Código Civil: “Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código”, expressão que recebeu correta interpretação do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal no enunciado n. 52: “por força da regra do art. 903 do Código Civil as disposições relativas aos títulos de crédito não se aplicam aos já existentes”. Mais recentemente, o Enunciado n. 462, em revisão ao anterior, dispôs: “as disposições relativas aos títulos de crédito do Código Civil aplicam-se àqueles regulados por leis especiais no caso de omissão ou lacuna”.

O regramento oferecido pelo legislador civilista, portanto, seria restrito aos títulos que forem criados após a entrada em vigor do Código Civil, se outra regência não lhes for determinada pela lei especial que os modelar.

Wille Duarte da Costa (2004:541) evoca duas situações aplicáveis aos títulos existentes à época da entrada em vigor do Código Civil: “1) o aval de pessoa casada não poderá ser dado sem o consentimento de outro cônjuge, exceto quando o regime do casamento for o de separação absoluta de bens (inciso III do art. 1.647 do novo Código Civil); 2) alteração do prazo de prescrição da ação de enriquecimento com base em título cambial e fixação de prazo geral para a pretensão de recebimento de títulos de crédito, ressalvadas as disposições de lei especial”.

Ambas as exceções, contudo, não encontram fundamento no Título VIII do Livro da Parte Especial do Código Civil, mas, quanto ao aval de pessoa casada, no Título I do Livro IV da Parte Especial (Direito de Família, art. 1.647) e, no que se refere aos prazos prescricionais mencionados, no Título IV da Parte Geral (art. 206, § 3º, IV e VIII).

O Código Civil incidiria tão somente quanto às disposições do Direito de Família acerca do aval dado por pessoa casada sem o consentimento do outro cônjuge.

O novo prazo prescricional para as ações de enriquecimento sem causa, de três anos (CC, art. 206, § 3º, IV), não se aplica aos títulos existentes, em virtude da ressalva do art. 903, exceto na hipótese de omissão da lei disciplinadora. E, quanto ao prazo geral para a cobrança de recebimento de títulos de crédito, a remessa às disposições da lei especial encontra-se no próprio art. 206, § 3º, VIII.

Qual seria, então, a razão da inserção de uma rubrica específica a regular, no Código Civil, os títulos de crédito? Seriam meras diretivas ao legislador à criação de novos títulos? A resposta a esta segunda indagação nos parece afirmativa, devendo ser lembrado o pensamento da doutrina que aponta para outros fundamentos que apenas reforçam essa conclusão:

“A intenção do Anteprojeto não foi reunir simplesmente o que é comum aos diversos títulos regulados em leis especiais...; foi fixar os requisitos mínimos para todos os títulos de crédito, inclusive para os títulos inominados, que a prática venha a criar, deixando assim aberta a porta às necessidades econômicas e jurídicas do futuro”⁵.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:390) afirma que “são normas de aplicação supletiva, que se destinam a suprir lacunas em regramentos jurídicos específicos”, completando: “apenas quando a lei cria um novo título de crédito e não o disciplina exhaustivamente, nem eleger outra legislação cambial como fonte supletiva de regência da matéria, tem aplicação o previsto pelo Código Civil”.

Wille Duarte da Costa (2004:553) é mais contundente: “Não entendemos mesmo por qual razão foram introduzidas normas sobre título de crédito, criando disposições em tudo supérfluas para não dizer desnecessárias, que não melhoraram tais títulos, na medida em que foram mantidas as atuais e vigentes disposições sobre os títulos típicos, cambiais e cambiariformes”.

1.6. Títulos de crédito virtuais ou eletrônicos

Críticas à parte, o Código Civil traz importante novidade no art. 889, § 3º, que transcende à questão do conflito entre a lei especial e as novas disposições previstas no Código Civil. É a permissão de emissão de títulos “a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo”.

Chamado de título desmaterializado, virtual ou eletrônico, o novo formato documental traz como exigências: (a) lançamento na escrituração do emitente e (b) obediência aos requisitos mínimos previstos no dispositivo, isto é, presença da data da emissão, da indicação precisa dos direitos que confere, da assinatura do emitente (CC, art. 889, *caput*) e do domicílio do emitente (CC, art. 889, § 2º).

1.6.1. Títulos virtuais e princípios cambiais

Algumas dificuldades ainda objeto de primeiros estudos são suscitadas pela doutrina, como a subsunção desta nova modalidade de emissão aos princípios que regem os títulos de crédito.

Enfrentando a questão, Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:392) conclui que somente o postulado da autonomia deixa de ser ferido com a adoção dos títulos virtuais, compreendendo que não havendo emissão de papel, tanto a posse do título por parte do credor (cartularidade) como a extensão dos atos nele lançados (literalidade) são limitações à perfeita adequação aos princípios clássicos da doutrina.

1.6.2. Duplicata virtual

Ressalva o mesmo doutrinador paulista a possibilidade de emissão de duplicata por meio magnético, sem qualquer alteração legislativa, diante do disposto no art. 15, § 2º, da Lei n. 5.474/68 que, no seu entender, dispensaria a apresentação do título para a propositura da ação de execução, bastando ao credor, para tanto, apresentar o instrumento de protesto por indicação (encaminhado por meio magnético) e o comprovante de entrega de mercadoria. Propõe, ainda, a completa desmaterialização deste segundo documento, adotando-se a assinatura eletrônica, o que possibilitaria ao vendedor exibir em juízo “dois papéis: o instrumento de protesto por indicações e o

comprovante da entrega das mercadorias” (Coelho, 2016, 1:468).

Esse é o entendimento contido nos Enunciados n. 461 e 462 das Jornadas de Direito Civil:

“461 – Art. 889: As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços”.

“462 – Art. 889, § 3º: Os títulos de crédito podem ser emitidos, aceitos, endossados ou avalizados eletronicamente, mediante assinatura com certificação digital, respeitadas as exceções previstas em lei.”

Observamos, contudo, que no meio judiciário não é plena a aceitação do documento protestado (em geral, *boleto*), contendo as indicações feitas pelo credor, em substituição à duplicata ou triplicata, isto é, há os que entendem que a lei exige, além da prova de protesto e documento de entrega da mercadoria, a apresentação da cártula – duplicata ou triplicata – dada a literalidade da expressão legal (LD, art. 15, § 2º), com nosso grifo: “Processar-se-á também da mesma maneira *a execução da duplicata ou triplicata* não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo”.

Veja-se, como exemplo, o acórdão no REsp n. 827.856-SC, j. 28-8-2007 pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (v.u.): “Direito Comercial. Duplicata Mercantil. Protesto por indicação de boletos bancários. Inadmissibilidade. I – A retenção da duplicata remetida para aceite é *conditio sine qua non* exigida pelo art. 13, § 1º, da Lei n. 5.474/68 a fim de que haja protesto por indicação, não sendo admissível protesto por indicação de boletos bancários. II – Recurso não provido” (Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro).

A Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018, contudo, ao dispor sobre a emissão de duplicata sob a forma escritural, autorizou o lançamento e regulamentou a circulação desse título em sistema eletrônico de escrituração, determinando, ainda, a

aplicação subsidiária das disposições da Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474/68). As características desse título são objeto de melhor estudo no Capítulo 5, relativo às duplicatas.

1.6.3. Avanço tecnológico e diplomas legislativos

Embora se reconheçam os avanços tecnológicos e legislativos neste particular aspecto do Direito Empresarial, contribuindo para a celeridade dos negócios realizados por meio eletrônico, há passos a serem dados para a plena conquista da segurança jurídica na emissão e circulação de títulos de crédito por meio desmaterializado.

Medidas que conduzem à plena adoção e aceitação no meio jurídico, em especial nos meios forenses, dos títulos virtuais podem ser estudadas em quatro categorias: segurança dos dados, assinaturas digitais, prova da operação e efeitos jurídicos.

Quanto à segurança dos dados, a MP n. 2.200, de 28 de junho de 2001, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil – visando “garantir : autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. A medida possibilitou importante alteração na comunicação documental perante os tribunais, conforme dispôs o parágrafo único do art. 154 do Código de Processo Civil de 1973⁶, com a redação que lhe deu a Lei n. 11.280, de 16 de fevereiro de 2006: “Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos da autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil”⁷.

Francisco Eduardo Loureiro (2004:367) assinala, com propriedade: “a assinatura digital, ou criptográfica, com o sistema de chaves assimétricas, reúne as características: a) autentica o documento e prova ao destinatário que o subscritor assinou-o; b) impede a falsificação, pois somente o subscritor tem a chave privada que permite assiná-lo; c) impede nova utilização da mesma assinatura, porque ela se

amolda ao documento na sua essência; d) impede que o documento seja modificado por qualquer de suas características depois de assinado pelo autor”.

No tocante à admissão jurídica de assinaturas digitais ou reconhecimento de fatos representados nos títulos, de anotar que o art. 225 do Código Civil erigiu à categoria de prova plena “as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas”.

Em relação à prova da realização de compra e venda mercantil, houve a assinatura do Convênio SINIEF n. 7, de 30 de setembro de 2005, entre os membros do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ e o Secretário-Geral da Receita Federal do Brasil, na 119ª reunião ordinária daquele conselho, ocasião em que se instituiu a “Nota Fiscal Eletrônica – NF-e que poderá ser utilizada em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal de Comunicação – ICMS” (art. 1º do Convênio). O parágrafo único do art. 1º conceitua nota fiscal eletrônica como “o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador”.

Quanto aos conceitos, regulamentação, efeitos jurídicos e obrigações decorrentes de contratos firmados eletronicamente, registre-se a iniciativa de dois projetos de lei nas casas do Congresso Nacional: a) Na Câmara dos Deputados – PL n. 1.483, de 1999, que “institui a fatura eletrônica e a assinatura digital nas transações de comércio eletrônico”, apensado a outros doze projetos, sendo o último apresentado em 2016 (PL n. 4.511); b) no Senado Federal – PLS n. 672, de 1999, apresentado pelo Senador Lúcio Alcântara, com base no modelo Uncitral/ONU, apensado ao primeiro, na Câmara dos Deputados.

Os avanços legislativos apontam para a regulamentação dos atos voltados ao

comércio eletrônico, modalidade em que a emissão dos títulos *causais* seria amplamente beneficiada. A circulação, contudo, que na maior parte dos casos obedece aos rigores da Lei Uniforme de Genebra, não está contemplada em toda a sua extensão, pois implicaria alterações em diversos dispositivos do tratado.

Proposta nesse sentido foi apresentada por Orival Grahal, em dissertação de mestrado apresentada na Universidade de Brasília (2003:150), que nos lembrou, na oportunidade, da necessidade de alterações legislativas para a circulação de títulos de crédito por meio eletrônico – endossos e avais – e para a emissão daqueles que exijam assinatura de *punho próprio*, quais sejam: letra de câmbio, cédula rural pignoratícia, cédula de crédito à exportação, nota de crédito à exportação, cédula de crédito comercial e nota de crédito comercial.

Com o domínio tecnológico, superamos essas dificuldades. Prova disso é o modelo concebido pela Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018, que dispôs sobre a emissão de duplicata escritural, objeto de nossos estudos no Capítulo 5 desta obra (v. 5.10).

Capítulo 2

LETRA DE CÂMBIO

Sumário: 2.1. Origens. 2.2. Direito aplicável. 2.3. Conceito e requisitos formais. 2.3.1. A denominação letra de câmbio. 2.3.2. Mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada. 2.3.3. O nome do sacado. 2.3.4. A época do pagamento. 2.3.5. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento. 2.3.6. O nome do tomador. 2.3.7. A data da emissão. 2.3.8. O lugar da emissão. 2.3.9. A assinatura do sacador. 2.4. Reservas do Estado brasileiro. 2.5. Institutos cambiários. 2.5.1. Saque. 2.5.2. Aceite. 2.5.3. Endosso. 2.5.4. Aval. 2.6. Pagamento. 2.7. A apresentação. 2.8. Protesto. 2.9. Ação cambial.

2.1. Origens

A doutrina situa o desenvolvimento da letra de câmbio em três períodos históricos: italiano, francês e germânico. Procuram-se estabelecer os seguintes marcos para cada um deles (cf. Fran Martins, 2010:28-31), o primeiro no início da Idade Média; o segundo, a partir das *Ordonnance sur le Commerce de Terre*, de 1673, o chamado Código Savary, de Jacques Savary, também conhecido como *Ordonnance des Merchands et Negociants*; e o último, a partir de 1848, com a aprovação da Ordenança Geral Cambiária Alemã, aprovada para entrar em vigor em todo o território nacional em 1º de maio de 1849.

No primeiro período a emissão da letra servia à função de representar e facilitar a troca de diferentes moedas utilizadas no vasto comércio internacional, formado por cidades autônomas que cunhavam sua própria moeda. É corrente que seu nascimento se dá graças à necessidade de um meio prático para resolver o problema do transporte de numerário e, ao mesmo tempo, servir como instrumento de crédito internacional e de câmbio.

Conforme descrevem Edwin S. Hunt e James M. Murray (2000:108): “A mais importante inovação financeira da Alta Idade Média foi a letra de câmbio, a qual

combinava três atributos de grande valor para os mercadores internacionais que exerciam atividades comerciais na Europa ocidental. Evitava os custos do transporte de moeda, oferecia um mecanismo prático para o crédito internacional e para o câmbio de moedas, além de servir a proibição da Igreja contra a usura (...). Além disso, facilitava o tráfico singular tais como a do têxteis”.

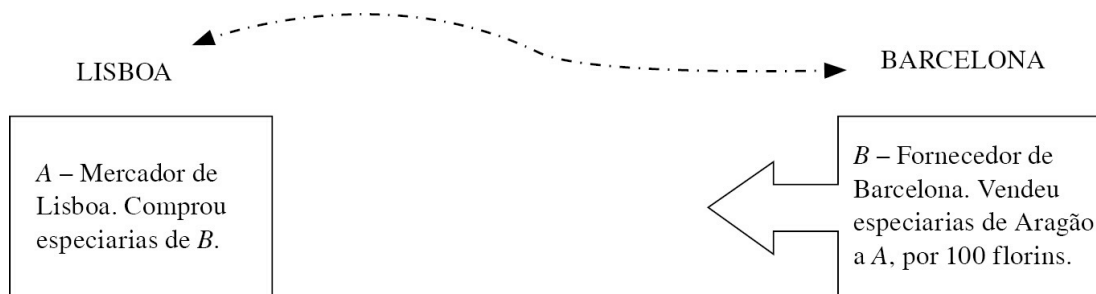
O comércio realizado entre regiões diferentes exigia constante operação de troca de moedas, o que poderia ocorrer na presença do banqueiro e simultaneamente à entrega do valor a ser convertido – câmbio manual – ou em lugares distintos. Neste último caso a conversão era diferida para outro local (*distancia loci*), na moeda que ali tivesse curso legal; era o chamado câmbio *trajecticum*.

O custo do transporte era altíssimo. Hunt e Murray (2000:106) narram que mover moedas de Nápoles para Roma podia alcançar cifra entre 8% e 12% do total conduzido. A difusão do crédito internacional era facilitada pelo mecanismo prático da emissão, envolvendo quatro figuras: o que transfere (dador), o tomador, o sacador e o sacado.

Uma narrativa desse mecanismo é resgatada por Filipe Themudo Barata (1998:378): “um mercador de Lisboa, *A*, tendo importado especiarias de Aragão, deve a *B*, o fornecedor de Barcelona, 100 florins. Para adquirir florins para pagar, procura na ‘capital’ quem seja credor de florins sobre um devedor da praça de Barcelona, ou seja, alguém que tenha florins a receber ou dispunha desta moeda em Barcelona. Supondo que era o caso de *C*, também de Lisboa, credor de *D*, mercador de Barcelona, a quem vendera uma partida de pescado no valor de 100 florins, *A*, entregando a *C* o contravalor em moeda portuguesa de 100 florins, recebe dele uma letra sacada sobre *D*, na qual *B* será indicado como tomador”.

Por este exemplo verifica-se que *A*, estando em Lisboa e necessitando providenciar o pagamento de sua dívida, estaria obrigado a providenciar o câmbio do valor correspondente e encaminhar a Barcelona, para entregar a *B*, o valor já transformado em florins. Para isso pagaria o transporte da moeda, acrescentando custo em seu débito. Em outra ponta estava *D*, em Barcelona, que devia a *C*, estabelecido em Lisboa. *D* teria a mesma despesa de transporte para efetuar esse

pagamento na capital portuguesa. Com a emissão da letra era possível a *A* pagar a dívida de *D*, a *C*, o que facilitava porque *A* e *C* encontravam-se em Lisboa. *C*, ao receber os cem florins, emitia uma letra com a ordem escrita de que *D*, seu devedor em Barcelona, pagasse diretamente a *B*, também estabelecido em Barcelona, o valor correspondente ao que recebeu de *A*, então devedor de *B*. *A* recebia essa letra e encaminhava a *B*, quitando sua dívida. Veja-se o esquema gráfico:



OPERAÇÕES SUBJACENTES:

- (1) *A* (em Lisboa) DEVE 100 florins a *B* (em Barcelona)
- (2) *D* (em Barcelona) DEVE 100 florins a *C* (em Lisboa).

SOLUÇÃO CAMBIAL:

- (3) *A* entrega 100 florins, em moeda portuguesa a *C* (A operação é realizada entre os presentes em Lisboa e a dívida de *D* em relação a *C* está paga)
- (4) *C* entrega uma letra de câmbio a *A*, em florins contra *D* (sacado), tendo *B* como tomador (A remete a letra a *B*; *D* pagará a *B* a dívida de *A*).



É desse mesmo autor (BARATA, 1998:377) a narrativa do “primeiro vestígio de uma letra emitida e paga numa atividade comercial ‘privada’. Num recibo de 2 de março de 1395 emitido em Barcelona, um mercador do Porto, João Peres, reconhece ter recebido 125 florins em moeda de ouro aragonesa de Jacob Axenderi, em razão do pagamento correspondente ao câmbio feito ao cidadão valenciano de nome Michael”.

Ao primeiro período, ainda, estaria reservado o nascimento do aval, garantia que terceiro assumia em reforço à operação.

Nesse período, como também descrevem Hunt e Murray (2000:333), as letras servem como “meio essencial para transferência de capital, sendo o seu papel como instrumento de crédito meramente secundário, de forma que a preponderância dos pagamentos continuava a ser efetuada por transferência bancária”.

O desenvolvimento do título se dá graças ao lucro que as grandes companhias e os bancos obtinham na conversão das moedas, conforme explica Filipe Barata (1998:381): “Eles dispunham dos capitais necessários e podiam-nos disponibilizar; eram eles que melhor conheciam, e tantas vezes influenciavam, os mecanismos financeiros e os vários mercados e eram ainda eles que dispunham de agentes espalhados um pouco por todo o lado, facilitando assim a obtenção e pagamento dos créditos, ou, posta a questão doutro modo, tinham dimensão internacional suficiente”.

No período francês seu uso ganha impulso para documentar contrato de compra e venda nascido por ordem de terceiro, mandante, que o delegava. Pontes de Miranda (2000, 1:51-52) explica a principal característica diferenciadora desse período: “A emissão de cambial demonstraria, sempre, a existência de contrato, contrato de promessa da cambial, o que pode ser comercial ou civil, se bem que a cambial seja sempre comercial. A própria cláusula à ordem há de aparecer no endosso e com ela os elementos principais do contrato originário e câmbio. Deve esse ter a sua causa, que se documenta literalmente como a própria obrigação do sacador”.

Um contrato inicial e a delegação ou mandato caracterizavam a emissão da letra que, com a adoção da cláusula “à ordem”, torna-se instrumento de pagamento, de ampla difusão. Por essa cláusula, o simples lançamento de assinatura no verso do título – endosso – transfere ao novo possuidor os poderes que o antigo titular dispunha.

É no período germânico que emerge a feição moderna da letra de câmbio: título abstrato não vinculado à causa de sua criação, conforme concepção de Karl Einert (cf. Pontes de Miranda, 2000, 1:52): “a cambial é o papel-moeda dos comerciantes”. Pontes de Miranda (2000, 1:52) elucida essa renovação conceitual: “Emitida a promessa ao público, cria-se, nesse, a fé no pagamento, de acordo com as cláusulas apostas ao título, e assim se explica a existência do direito autônomo. O tomador não

pode dar a outrem mais do que tem, de modo que são idênticos os direitos de quaisquer possuidores sucessivos. Se existisse contrato entre o subscritor e o tomador, não se poderia conceber a autonomia do direito. Por isso, a cambial ao portador e o endosso em branco constituem a forma mais perfeita do papel cambiário”.

O quadro a seguir resume e ilustra as funções e características de cada período:

PERÍODO	FUNÇÃO/CONCEITO	CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO
Italiano	Instrumento de câmbio e de remessa de moedas entre localidades distintas.	Surge o aval.
Francês	Instrumento de pagamento, nascido de um contrato, de fácil circulação.	A cláusula à ordem pode integrar o título. Regulamenta-se o endosso.
Alemão	Título de crédito formal, literal e abstrato. Vale pelo escrito, independentemente de causa inicial.	A cláusula à ordem é implícita.

2.2. Direito aplicável

Dois são os diplomas legais que regulam a letra de câmbio: a chamada Lei Saraiva – Decreto n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 – e a Lei Uniforme – Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966, também chamada genebrina, por ter sido promulgada a partir da adoção no Brasil das convenções internacionais que ocorreram na cidade de Genebra, na Suíça.

Os dois sistemas coexistem, acarretando certa dificuldade para o aplicador do Direito quanto à solução de conflitos em matéria cambial.

A dificuldade mostra-se presente já no primeiro artigo de ambos os diplomas legais, na apresentação dos requisitos exigidos para o saque da letra de câmbio, conforme se pode observar no seguinte quadro:

LEI SARAIVA (LS)	LEI UNIFORME (LUG)	DISTINÇÕES
------------------	--------------------	------------

I – A denominação “letra de câmbio” ou a denominação equivalente na língua em que for emitida;	1. A palavra “letra” inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;	• Letra de câmbio (LS) e Letra (LUG) • Inserta no próprio texto (LUG)
II – A soma de dinheiro a pagar e a espécie de moeda;	2. O mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada;	• A palavra mandato (LUG)
III – O nome da pessoa que deve pagá-la. Esta indicação pode ser inserida abaixo do contexto;	3. Nome daquele que deve pagar (sacado)	• Pode ser inserida abaixo do contexto (LS)
	4. A época do pagamento;	• Sem correspondência na LS
	5. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;	• Sem correspondência na LS
IV – O nome da pessoa a quem deve ser paga. A letra pode ser ao portador e também pode ser emitida por ordem e conta de terceiro. O sacador pode designar-se como tomador;	6. O nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; + (A letra pode ser à ordem do próprio sacador. Pode ser sacada sobre o próprio sacador. Pode ser sacada por ordem e conta de terceiro – art. 3 da LUG).	• Admite ao portador (LS)
	7a. A indicação da data em que, e (7.b) do lugar onde a letra é passada.	• Sem correspondência na LS
V – A assinatura de próprio punho do sacador ou do mandatário especial. A assinatura deve ser firmada abaixo do contexto.	8. A assinatura de quem passa a letra (sacador);	• Deve ser firmada abaixo do contexto (LS)

Emergem do quadro quatro indicações obrigatórias na Lei Uniforme: época e (4) lugar de pagamento (5), data (7a) e lugar (7b) onde é passada, que não foram contempladas pela Lei Saraiva.

Haveria, ainda, certas discrepâncias quanto ao nome do título (I e 1), ao texto (II e 2 e 3), permissão de modalidade ao portador (IV e 6) e forma de lançamento da assinatura do sacador (V e 8), que serão objeto de apreciação no exame detalhado de cada requisito.

2.3. Conceito e requisitos formais

A letra de câmbio é ordem de pagamento, à vista ou a prazo. Essa concisa afirmação é suficiente para diferenciá-la de outros títulos de crédito, como, por exemplo, do cheque que somente é emitido à vista e da nota promissória que não é ordem, mas promessa de pagamento. Contudo se há precisão no conceito, a brevidade lhe retira a compreensão de suas principais características e funções.

A Lei Uniforme relativa às letras de câmbio e notas promissórias – Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966 – acrescenta ao “mandato puro e simples de pagar uma determinada quantia” outros oito requisitos, três dos quais considerados como não essenciais⁸, conforme excetua o art. 2º, ao dispor que, se não houver indicação de época, de lugar de pagamento ou onde foi passada, entende-se, respectivamente, pagável à vista, no lugar ao lado do nome do sacado e ao lado do nome do sacador.

Esse tratamento legal à formalidade de época e lugar de pagamento e localidade de saque é chamado de Teoria dos Equivalentes, atribuída a Lagarde (cf. Requião, 1995, 2:325), porque a lei provê formas de suprir a ausência desses elementos.

Um resumo dos equivalentes pode ser apreciado no seguinte quadro:

REQUISITO AUSENTE	EQUIVALENTE
Época do pagamento	Vence-se à vista

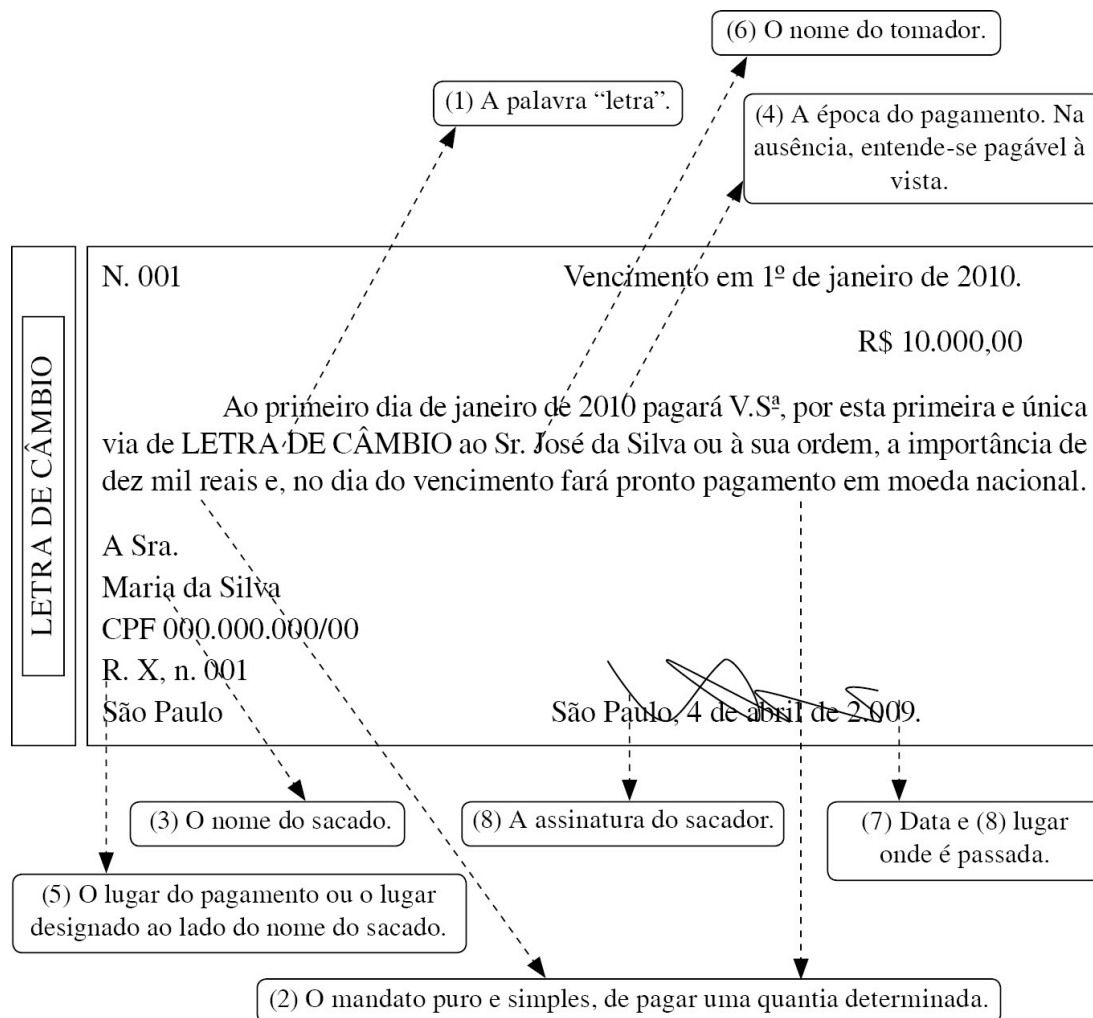
Lugar do pagamento	Lugar ao lado do nome do sacado
Lugar de saque	Lugar ao lado do nome do sacador

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:402) rebela-se com a solução que a doutrina dá aos requisitos equivalentes ao classificá-los como não essenciais, preferindo considerar não essencial tão somente a época do pagamento porque sua ausência não conduz à inexistência do documento, como ocorreria com a indicação do lugar de pagamento e de saque, na ausência de qualquer outra indicação equivalente.

A posição do professor paulista é correta, permitindo elaborar uma melhor classificação.

Seis são os requisitos formais essenciais, previstos nas alíneas 1, 2, 3, 6, 7 (parcial) e 8, do art. 1º da Lei Uniforme: (1) a palavra letra inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; (2) o mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada; (3) o nome daquele que deve pagar (sacado); (6) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; (7a) a indicação da data em que a letra é passada e (8) a assinatura de quem passa a letra (sacador).

São essenciais, dependentes de complementação por equivalentes, as indicações (5) do lugar em que se deve efetuar o pagamento e (7b) do lugar onde a letra é passada. E é accidental a (4) época do pagamento.



2.3.1. A denominação letra de câmbio

A cláusula cambiária consiste em que a denominação “letra de câmbio” seja incorporada ao texto da ordem, conforme a Lei Uniforme determina: “inserta no próprio texto do título”. Não basta, portanto, que a expressão intitule o documento, devendo denunciar inequivocamente o pleno conhecimento dos participantes quanto à natureza da obrigação a que se vinculam com o lançamento de suas assinaturas na qualidade de sacadores, avalistas, aceitantes e endossantes.

Os doutrinadores debatem-se em torno da obrigatoriedade de constar a expressão “letra de câmbio” ou simplesmente “letra”, uma vez que a forma simplificada foi a escolhida pelo legislador da convenção uniforme e a mais extensa é encontrada em nosso sistema jurídico desde 1908, com a promulgação do Decreto n. 2.044, de 31 de

dezembro, ainda em vigor.

A explicação para a coexistência de ambas as denominações estaria na adoção, pelo Brasil, da tradução realizada em Portugal, gerando inúmeras dificuldades, não apenas porque o tratamento de algumas expressões distingue-se entre os lusófonos como também porque o texto trazido e adotado na Europa recebeu inúmeras críticas dos mestres portugueses (1995, 1:78).

Fran Martins (1995, 1:108) explica que, em Portugal, “o termo legal para exprimir uma letra de câmbio é simplesmente *letra*”, o que decorreria do fato de o Código Comercial daquele país ter reduzido a expressão para a forma abreviada, em 1888. No Brasil a abreviação não se justificaria: “obedecendo o título a um formalismo rigoroso, a substituição de um requisito essencial quebra essa regra, de grande importância para a segurança do título”, no que parece ser acompanhado por Pontes de Miranda (2000, 1:234) quando afirma: “Ainda que todos os outros requisitos existam e se aluda à lei cambiária, empregando-se termos inequívocos, como “por este título cambiário regido pelo art. 1º da Lei n. 2.044”, “por esta cambial”, “por esta letra”, não é letra de câmbio aquela em que, redigida em português, não se diga ser *letra de câmbio*, ou redigida noutra língua, não se empregue, nessa língua, o termo equivalente. É, pois, o requisito principal, inabreviável, não podendo os Estados, onde duas línguas ou mais sejam usadas, permitir, nas letras de câmbio internacionais, que, redigida numa delas, a expressão denominadora seja de outra”.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:400) diverge desse entendimento e, orientando-se pela denominação legal da Convenção, admite tanto uma como outra expressão, “desde que o restante do título esteja em português”.

O assunto merece algumas ponderações.

Em primeiro lugar, atente-se que o rigor cambiário é justificado, o que se verifica pelo fato de as legislações cambiais – convenção e lei brasileira, ambas em seus arts. 2º – desqualificarem como letras de câmbio os escritos em que faltar algum dos requisitos formais.

Em segundo lugar, não há tradição legislativa no Brasil que justifique a adoção da

forma reduzida, não tendo ocorrido, ainda, expressa revogação da lei brasileira de 1908, que preferiu a expressão mais longa, de uso corrente no País. Esse uso contempla o próprio texto preambular de ambas as leis que promulgaram as convenções para adoção de lei uniforme em matéria cambial (Decreto n. 3.756, de 27 de agosto de 1919, e Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966).

Em terceiro lugar, o termo reduzido “letra” conduz a inúmeros equívocos, uma vez que o legislador nacional o aplica para diversos títulos distintos: letra hipotecária (Decreto n. 5.443, de 13 de janeiro de 1928; Decreto-lei n. 1.002, de 29 de dezembro de 1938; Decreto-lei n. 1.230, de 29 de abril de 1939), letra de exportação (Decreto n. 20.451, de 28 de setembro de 1931; Decreto-lei n. 97, de 23 de dezembro de 1937; Decreto-lei n. 1.201, de 8 de abril de 1939), letras e obrigações do tesouro (Lei n. 4.069, de 11 de junho de 1962), letra imobiliária (Lei n. 5.049, de 29 de junho de 1966; Decreto-lei n. 1.338, de 23 de julho de 1974) etc. Ao passo que, quando a lei quer mencionar a “letra de câmbio” faz uso da expressão completa, como ocorre, por exemplo, no art. 4º do Decreto n. 4.315, de 28 de agosto de 1921; no art. 1º do Decreto-lei n. 4.759, de 29 de setembro de 1942; no art. 1º do Decreto n. 22.870, de 28 de junho de 1933; no art. 1º do Decreto n. 24.534, de 3 de julho de 1934; na Lei n. 4.069, de 11 de junho de 1962; no art. 2º do Decreto-lei n. 1.338, de 23 de julho de 1974; no art. 1º do Decreto-lei n. 1.700, de 18 de outubro de 1979 etc.

2.3.2. Mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada

O requisito relativo ao mandato puro e simples de pagar uma quantia determinada impõe algumas outras considerações no que diz respeito à não sujeição a qualquer condição e quanto à moeda de emissão e à cláusula de acréscimos a título de juros. A expressão “mandato”, contida na Lei Uniforme, é passível de críticas por permitir equívocos. Não há “mandato”, mas simples comando que manifesta a vontade do sacador. Nesse ponto a lei brasileira é mais precisa ao limitar-se a exigir o lançamento de “soma de dinheiro a pagar e a espécie de moeda”.

a) Ausência de condição

Ao estabelecer “mandato puro e simples” a lei veda implicitamente a aposição de

condição que altere a determinação da quantia estipulada no título.

Pontes de Miranda (2000, 1:239) nos lembra que “o direito cambiário conheceu condições que podiam ser apostas ao saque cambiário; com o tempo, desapareceram. No ato de criação não é possível a inserção de condições. A lei comprime, a esse respeito, a vontade privada”.

b) Emissão em moeda estrangeira

Para as letras emitidas no Brasil, para pagamento no território nacional, exige-se a expressão do valor em reais, vedada, como regra geral, a estipulação em ouro ou moeda estrangeira.

A legislação brasileira (art. 2º do Decreto-lei n. 857, de 11 de setembro de 1969, e art. 1º da Lei n. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001), contudo, admite sejam firmados em moeda estrangeira: (I) contratos e títulos referentes à importação ou exportação de mercadorias e a empréstimos; (II) contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior; (III) contratos de compra e venda de câmbio em geral; (IV) empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; (V) contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações anteriores, ainda que as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil.

Se a emissão em moeda estrangeira se der regularmente, nos casos em que a legislação permite, na data do vencimento se fará a conversão do valor estipulado, pagando-se em moeda nacional. Havendo atraso no pagamento, o credor pode escolher que a conversão se dê na data do vencimento ou na data do pagamento, evitando que a oscilação beneficie o devedor inadimplente.

c) Cláusula de pagamento efetivo em moeda estrangeira

A Lei Uniforme, no art. 41, traz cláusula de pagamento efetivo em moeda

estrangeira que, contudo, foi objeto de reserva pelas autoridades brasileiras, nos seguintes termos: “Pelo que se refere às letras pagáveis no seu território, qualquer das Altas Partes Contratantes tem a faculdade de sustar, se o julgar necessário, em circunstâncias excepcionais relacionadas com a taxa de câmbio da moeda nacional, os efeitos da cláusula prevista no art. 41 relativa ao pagamento efetivo em moeda estrangeira. A mesma regra se aplica no que respeita à emissão no território nacional de letras em moedas estrangeiras” (art. 7º, Anexo II, do Decreto n. 57.663/66).

A reserva, portanto, impede a estipulação e eficácia de cláusula de pagamento tão somente em moeda estrangeira que, se permitida, tornaria inócua a previsão quanto à forma de conversão cambial no dia do vencimento e/ou pagamento em atraso.

d) Cláusula de estipulação de juros

O sacador pode estipular, com a emissão e no próprio título, o rendimento de juros, presumindo-se, salvo indicação diversa, contados da data da emissão da letra. Essa faculdade encontra-se tão somente na criação de letras pagáveis à vista ou a um certo tempo da vista, considerando-se não escrita sua inscrição em outra espécie de letra.

A regra, prevista no art. 5º da Lei Uniforme, manda, ainda, indicar a taxa de juros, sob pena de se considerar não escrita a cláusula de rendimento.

Algumas observações devem ser atendidas quanto ao limite na contratação de juros e sua forma de cobrança: (a) em primeiro lugar, quanto ao limite, vige o teto previsto no art. 1º do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, que estipula a vedação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal prevista no art. 1.062 do Código Civil de 1916, estabelecida em 6% ao ano; (b) em segundo, deve-se lembrar que aos bancos e instituições financeiras não se aplica qualquer restrição quanto aos limites de juros (Súmula 596 do STF), mas a eles também se veda contar juros sobre juros – capitalização de juros, também chamada anatocismo – salvo anualmente (art. 4º do Decreto n. 22.626/33 e Súmula 121 do STF) ou em casos em que houver expressa autorização legal, como ocorre, por exemplo, em títulos de crédito rural, industrial e comercial; (c) em terceiro lugar, a partir da vigência do Código Civil de 2002,

aplica-se, quanto aos juros legais, o limite relativo à “taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406) que é a prevista no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional – 1% ao mês⁹.

2.3.3. O nome do sacado

O nome daquele que deve pagar (sacado). A vinculação cambial somente ocorre se e quando o sacado aceitar o título, devendo ser indicado seu nome e meios de identificá-lo. Convém insistir para esse ponto: antes do aceite, a pessoa mencionada como sacada não se vincula à obrigação cambial. Imagine-se a seguinte situação: após a circulação do título, por endosso do tomador e de vários endossantes depois dele e do lançamento de inúmeras assinaturas de avalistas ao sacador, tomador e endossantes, o título é remetido ao sacado para aceite e este é recusado.

As obrigações cambiárias existiram entre todos aqueles que lançaram assinaturas: sacador, seu avalista, tomador, seu avalista, endossantes e seus avalistas, mas nenhum deles terá direito sobre o sacado que, deixando de aceitar o título, não se vinculou à obrigação cambiária.

Ao aceitar, contudo, o sacado obriga-se a pagar a letra na data de seu vencimento a quem se apresentar como portador do título (art. 28 da Lei Uniforme).

a) Identificação do sacado

Embora a Lei Uniforme mencione tão somente a inscrição do *nome* do sacado, a Lei n. 6.268, de 24 de novembro de 1975, impôs, para efeito de registro de protesto, “a identificação do devedor pelo número de sua cédula de identidade, de inscrição no cadastro de pessoa física, do título eleitoral ou da carteira profissional” (art. 3º).

Vê-se, portanto, que não se trata de formalidade essencial para a validade do título, mas indispensável para a correta inclusão do ato registrário: a letra pode circular sem os elementos de identificação, mencionando tão somente o nome do sacado, devendo, entretanto, ser completada para que o oficial público possa realizar o protesto.

b) Identidade entre sacador e sacado e entre tomador e sacado

A Lei Uniforme admite que se faça a indicação do sacado na pessoa do próprio sacador (art. 3º, 2ª alínea), não vedando, ainda, outras duas situações: (a) que o tomador e o sacado sejam a mesma pessoa e (b) que se identifique a mesma pessoa como sacado, sacador e tomador.

A primeira situação (sacador = sacado) é de saque sobre si mesmo. Rubens Requião (1995, 2:322) lembra que a letra emitida sobre si mesmo (sacador = sacado) terá efeitos de nota promissória. Mesmo não ocorrendo aceite, o sacado – não em razão desta condição, mas por ser também sacador – estará obrigado perante o portador.

Pontes de Miranda (2000, 1:250) relata, para o segundo caso (tomador = sacado), a preocupação de certo segmento da doutrina alemã porque “o tomador poderia, como sacado, não aceitar e, no entanto, dar circulação à letra de câmbio, sem qualquer responsabilidade sua, se fosse ao portador o título”. Resistindo à vedação, Pontes de Miranda assevera que, embora seja correto o raciocínio, o portador terá direito contra o sacador que se obriga pela emissão.

O último caso (sacador = tomador = sacado), letra de câmbio sobre si mesmo e à própria ordem (cf. Requião, 1995, 2:322), traz a variante de que o sacador é tomador e, ao mesmo tempo, sacado. Se ele não aceitar o título, ainda assim, terá responsabilidade como sacador, pouco importando a posição que ocupa como tomador endossante, porque, ao fazer circular o título, traz para si, na qualidade de sacador, obrigação a favor de terceiro que se apresentar como portador.

2.3.4. A época do pagamento

O sacador pode indicar a época de vencimento de quatro modos: (a) à vista; (b) a um certo termo da vista; (c) a um certo termo da data; (d) pagável num dia determinado, sendo-lhe vedado sacá-la com vencimentos diferentes ou com vencimentos sucessivos, sob pena de nulidade (art. 33 da Lei Uniforme).

a) Diferentes indicações – modalidades de vencimento

A distinção entre as diferentes indicações de épocas de vencimento do título pode ser visualizada no seguinte quadro:

ÉPOCA DE VENCIMENTO	TERMOS TEMPORAIS	EXEMPLOS DE EXPRESSÃO CONTIDA NO TÍTULO
À vista ou à apresentação	APRESENTAÇÃO PARA ACEITE O vencimento se dá com a apresentação do título ao sacado, o que deve ocorrer até um ano da data da emissão, se outro termo não for estabelecido.	“À vista desta única via de Letra de Câmbio V.Sª pagará a quantia de...” “À apresentação desta única via de Letra de Câmbio V.Sª pagará a quantia de...” “Com a vista desta única via de Letra de Câmbio V.Sª pagará a quantia de...” “Depois da vista desta única via de Letra de Câmbio V.Sª pagará a quantia de...” “Ao ser-lhe apresentada esta única via de Letra de Câmbio V.Sª pagará a quantia de...”
	É possível que o sacador estipule que a apresentação não ocorra antes de certa data. O prazo para apresentação, neste caso, deve ser contado a partir dessa data (art. 34 da Lei Uniforme).	“À vista desta única via de Letra de Câmbio, em época posterior ao Natal de 2005, V.Sª pagará a quantia de...”
A certo termo da vista	DE CERTO PRAZO APÓS O ACEITE O vencimento ocorre com o decurso de prazo após o lançamento do aceite pelo sacado ou, na sua recusa, a partir da data do protesto (art. 35 da Lei Uniforme). Se o aceite não estiver datado e não houve protesto, considera-se o último dia do prazo para apresentação ao aceite, que é de um ano da data de saque (art. 23 da Lei Uniforme).	“Sessenta e cinco dias da data da vista (ou após o aceite) pagará V.Sª, por esta única via de Letra de Câmbio...”

A um certo termo da data ou com prazo da data	DE CERTO PRAZO APÓS O SAQUE O vencimento ocorre quando decorrer o prazo fixado pelo sacador, contado da data do saque.	“Sessenta e cinco dias desta data pagará V.S ^a , por esta única via de Letra de Câmbio...”
Pagável em dia determinado ou a dia certo	NO DIA ESTABELECIDO O vencimento ocorrerá no dia do calendário indicado no título (art. 37 da Lei Uniforme).	“Aos trinta dias do mês de março pagará V.S ^a , por esta única via de Letra de Câmbio, a quantia...”

b) Vencimentos não convencionais ou legais

Além dessas quatro modalidades de vencimento, o título pode sofrer duas outras formas de vencimento não convencionais, também chamadas de formas legais de vencimento, previstas nos arts. 19 da Lei brasileira e 43 da Lei Uniforme: (a) quando protestada pela falta ou recusa do aceite; (b) pela falência do aceitante; (c) pela falência do sacador nos casos de letra não aceitável. Este último caso, por reserva (anexo II, art. 10) e falta de regulamentação brasileira, somente se aplica às letras pagáveis fora do País (cf. Fran Martins, 1995, 1:71).

Se o título é aceito, o vencimento se dará na data convencionada, constante do título, segundo uma das modalidades já estudadas. Mas, na hipótese de recusa ao aceite, o vencimento é antecipado, autorizando, a partir de então, o portador a voltar-se contra os coobrigados do título, exigindo o cumprimento da obrigação.

A falência do aceitante – isto é, o sacado que lançou sua assinatura no título, confirmando o saque, total ou parcialmente – acarreta o vencimento antecipado do título, conforme também decorre do art. 77 da Lei Falimentar (Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), podendo o portador executar individualmente os coobrigados e, concomitantemente, habilitar o crédito na falência do aceitante.

Se o portador regularmente habilitado receber o valor correspondente de um coobrigado solvente, deve comunicar ao Juízo falimentar; nessa circunstância, o coobrigado pode habilitar seu crédito na massa falida, pelo valor que pagou.

Uma inovação trazida pelo novo diploma falimentar (LREF, art. 128) tutela o interesse de coobrigado antes mesmo do desembolso do valor correspondente ao título que se obrigou, se o portador permanecer inerte no prazo legal de habilitação.

Neste caso, mesmo que o coobrigado não tenha efetuado, até então, o pagamento do título e verificar que não houve habilitação desse crédito na massa falida (o prazo legal é de quinze dias contados da publicação do edital previsto no art. 99, parágrafo único, da Lei de Falências) poderá requerer sua habilitação na massa falida pelo valor que *lhe for devido*. Até solver o crédito o coobrigado não poderá levantar o numerário que corresponda à sua habilitação e venha a ocorrer no rateio.

c) Contagem dos prazos

A contagem do prazo segue algumas regras simples, previstas na lei brasileira (LS, art. 17) e na Convenção (LUG, art. 36):

- O prazo é contínuo e não se interrompe em domingos ou feriados;
- Se o vencimento cair num domingo ou feriado, o prazo prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte;
- O prazo fixado em um ou mais meses de um termo vencerá no dia correspondente a esse termo, decorridos os meses mencionados. Por exemplo, a expressão “A dois meses da data da vista pagará V.S^ª” indica que a data do aceite será considerada como a data do vencimento, dois meses depois. Se o aceite ocorreu em 15 de janeiro, o vencimento será em 15 de março;
- O prazo que consignar princípio, meado ou fim do mês, será considerado pelos dias 1º, 15 e 30 daquele mês;
- O dia do saque e o dia do aceite não são contados para contagem do vencimento dos títulos “a certo termo”.

A época do pagamento, contudo, não é requisito essencial; sua ausência não acarreta nenhuma invalidade ou restrição à circulação do título porque, nesse caso, a letra de câmbio entende-se pagável à vista, conforme dispõe o art. 2º, segunda alínea, da Lei Uniforme.

2.3.5. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento

O quinto requisito pertence à categoria dos essenciais supríveis: a lei determina que, “na falta de indicação especial, o lugar designado ao lado do nome do sacado

considera-se como sendo o lugar do pagamento, e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do sacado” (art. 2º, segunda alínea, da Lei Uniforme).

Chama-se letra domiciliada a pagável no domicílio de terceiro – uma agência bancária, por exemplo – situado tanto na localidade onde o sacado tem seu domicílio como em outra localidade.

A letra somente será nula se ambas as inscrições estiverem ausentes, isto é, tanto a indicação pessoal como a de localidade ao lado do nome do sacado.

2.3.6. O nome do tomador

Tomador é o beneficiário original do título; é pessoa a quem, ou à ordem de quem, a letra deve ser paga. Seu nome deve constar obrigatoriamente no título, conforme dispõe a Lei Uniforme (art. 2º), em regramento diametralmente oposto ao estabelecido na Lei Brasileira (LS, art. 1º, IV), que admitia o saque ao portador. Com a adoção pelo Brasil, sem reservas quanto à matéria, prevalece a Lei Uniforme, não se admitindo o saque de letra de câmbio ao portador.

Convém lembrar, contudo, que o título *depois de emitido* pode circular ao portador, na hipótese de lançamento de endosso sem a indicação do nome do novo portador, endossatário do título.

Se o sacador indica seu próprio nome como tomador do título, a letra de câmbio é denominada “letra à própria ordem”. Se o sacado aceitar, será ele o responsável pelo pagamento ao portador; caso contrário, o próprio sacador terá a obrigação de resgatar o título que, como tomador, fez circular.

2.3.7. A data da emissão

A data do saque vem prevista unicamente na Lei Uniforme. Composta de dia, mês e ano, ostenta caráter de essencialidade por razões que podem ser facilmente compreendidas: (a) a partir da data inserta no título o sacador obriga-se cambialmente; (b) é o dado que permite verificar tanto a capacidade do sacador no momento da emissão do título, como também do mandato e, para as letras emitidas por pessoas jurídicas, a regularidade da representação; (c) disciplina o regime

jurídico aplicável, na ocorrência de mudanças legislativas que impliquem alterações em aspectos formais do título; (d) a data do saque por sociedade em que há sócios com responsabilidade ilimitada e solidária – como ocorre nas sociedades em nome coletivo e em comandita (simples e por ações) – permite saber se a dívida foi constituída antes ou depois da retirada do sócio para efeito de sua responsabilização, nos termos do art. 81 da Lei de Falências¹⁰; (e) possibilita documentar fatos que possam ter relevância em eventual oposição a portador, como, por exemplo, os que impedem a compensação de créditos em massa falida.

Em relação ao último caso propomos o seguinte exemplo: cambial emitida por empresário individual (Antônio Silva) que, tempos depois, vem a ter sua falência decretada. Entre os créditos arrecadados pela massa encontra-se considerável importância devida por “ACME Importadora Ltda.”, representada por títulos não pagos (por exemplo: cheques sem fundos emitidos pela importadora). “ACME”, por sua vez, é tomadora de letra de câmbio não aceita, tendo como sacador Antônio Silva em valor superior à sua dívida. ACME, que é devedora pelos cheques sem fundos que emitiu e credora pela letra de câmbio sacada por Antônio Silva, requer, no Juízo falimentar, a compensação dos créditos.

Em tese, a compensação é admissível, salvo se a emissão ocorrer em três circunstâncias: (a) *após* a decretação da falência; (b) *quando já conhecido de crise econômico-financeira do devedor*; ou, ainda, (c) se a operação se deu com fraude ou dolo (LREF, art. 122).

“ACME” demonstra ter recebido o título *antes* da decretação da falência e a massa não dispõe de outros elementos para contestar a boa-fé da emissão, mas, com fundamento na data do saque, pode opor-se à compensação, demonstrando que a crise econômico-financeira já era conhecida.

O saque, a favor de devedor, estabelecido em período de crise econômico-financeira, é suspeito, podendo servir para acobertar operação prejudicial aos credores. É o argumento suficiente para a massa opor-se à compensação, e a arguição se mostra possível com o conhecimento da data de saque.

2.3.8. O lugar da emissão

Trata-se de requisito somente previsto na Lei Uniforme. Aplica-se ao lugar da emissão, como também ocorre com a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento e a data em que deve fazê-lo, a Teoria dos Equivalentes, acima exposta.

Fran Martins (1995, 1:129) lembra que o requisito tem relevância em razão do direito internacional aplicável. Por força do art. 4º da “Convenção¹¹ destinada a regular certos conflitos de leis em matéria das letras de câmbio e notas promissórias e protocolo”, “os efeitos provenientes das assinaturas dos outros coobrigados por letra ou nota promissória são determinados pela lei do país em cujo território foram apostas”. Assim, a lei do lugar do saque regula os efeitos decorrentes da obrigação do sacador.

Se ausentes tanto o lugar de emissão como o seu equivalente – o lugar indicado ao lado do nome do sacador –, a letra é nula.

2.3.9. A assinatura do sacador

O título nasce com ordem do sacador que é manifestada por sua assinatura na letra de câmbio. Tratando-se de documentar a manifestação de vontade na criação do título, a assinatura torna-se indispensável, podendo ser lançada por mandatário.

O sacador garante, com sua assinatura, tanto a aceitação do título como seu pagamento, podendo exonerar-se, por cláusula no texto da letra de câmbio, quanto à primeira obrigação, mas nunca em relação à garantia de pagamento (art. 9º da Lei Uniforme).

A lei brasileira exige que a assinatura seja lançada “abaixo do contexto” (art. 1º, V), exigência que não foi amparada pela Lei Uniforme, daí por que Fran Martins (1995, 1:123) entende que o sacador pode lançar a assinatura “no contexto ou fora dele”. Reflita-se, contudo, que, por ser a letra de câmbio expressão de um comando (“Pagará V.Sª...”), a assinatura deve posicionar-se em limite espacial que indique o arremate, desfecho, desse comando e, portanto, logo após a redação cambial.

2.4. Reservas do Estado brasileiro

Ao promulgar a Convenção de Genebra para a uniformização das letras de câmbio e notas promissórias, o Brasil fez expressa reserva aos arts. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 do Anexo II, que se referem expressamente às seguintes matérias:

ART.	MATÉRIA	SOLUÇÃO BRASILEIRA
2º	SUPRIMENTO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA Permite ser suprida a falta de assinatura, desde que por uma declaração autêntica escrita na letra se possa constatar a vontade daquele que deveria ter assinado.	A simples assinatura, de próprio punho ou por mandatário especial, é suficiente para obrigar no título, conforme decorre da lei brasileira (arts. 1º, V; 8º; 11 e 14 da LS).
3º	LETRA INCOMPLETA Faculdade de a lei nacional inserir o art. 10, que, por sua vez, não admite a possibilidade de o devedor opor-se ao portador em razão de a letra ter sido completada contrariamente aos acordos realizados, salvo se o portador a adquiriu de má-fé ou tenha cometido falta grave nessa aquisição.	A lei brasileira considera que os requisitos foram lançados no tempo de sua emissão, podendo o devedor fazer prova de má-fé do portador (art. 3º da LS).
5º	EFEITOS DA NÃO APRESENTAÇÃO DA LETRA NO DIA DE VENCIMENTO O art. 38 determina que a letra pagável em dia fixo ou a certo termo da data ou de vista deve ser apresentada no dia do vencimento ou num dos dois dias úteis seguintes. O art. 5º do Anexo II acrescenta: “a inobservância da obrigação de apresentar o título na data de vencimento ‘só acarreta responsabilidade por perdas e danos’”.	O art. 20 da lei brasileira determina que se faça a apresentação da letra no dia do vencimento, salvo se cair em feriado, quando então deverá ser apresentada no primeiro dia útil imediato, <i>sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas.</i> Os efeitos, portanto, entre o que dispõe a LUG (art.

		38) e a LS (art. 20), são distintos, prevalecendo, em razão da reserva, este último, salvo se o pagamento deve ser realizado no exterior, ocasião em que se impõe a regra da lei uniforme.
6º	CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO O art. 6º remete a cada legislação nacional a definição das instituições que devam ser consideradas câmaras de compensação, para cumprimento do art. 38, parte final: “a apresentação da letra a uma câmara de compensação equivale à apresentação a pagamento”.	Cabe ao Brasil determinar quais as instituições devem funcionar como câmaras de compensação.
7º	CLÁUSULA RELATIVA À EMISSÃO E AO PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA O art. 41 permite a inclusão de cláusula de conversão cambiária na letra e, ainda, cláusula de pagamento efetivo numa moeda estrangeira.	A legislação brasileira veda a estipulação em moeda estrangeira, salvo em alguns casos, e não permite a inclusão de cláusula de pagamento efetivo nessa moeda (v. acima item 2.3.2, b e c).
9º	MOMENTO DO PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO O art. 44 regula o prazo e o modo que o protesto deve ser tirado, determinando nas suas alíneas que (1) é o ato que comprova a recusa de aceite ou de pagamento; (2) o protesto por recusa de aceite e de pagamento de título vencível à vista deve ocorrer nos prazos fixados para a apresentação; (3) se por falta de pagamento pode ser feito nos dois dias úteis seguintes; (4) o protesto por falta de aceite dispensa tanto a apresentação a pagamento como também a prova de protesto por falta de pagamento; (5) é necessária a apresentação do título ao sacado para pagamento, depois de feito o protesto; (6) a falência do sacado ou do aceitante promove o vencimento do título e dá ao portador do título o direito de exercer o direito de ação. A reserva do art. 9º permite à lei nacional fixar que o protesto por falta de pagamento se faça no dia do vencimento ou num dos dois dias úteis seguintes.	A reserva brasileira permite a apresentação para protesto da letra no mesmo dia de vencimento, embora esta pareça não ter sido a pretensão brasileira que mantinha, por tradição (art. 28 da LS), proibição nesse sentido (cf. Fran Martins, 2010:47-48).

10	EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO EM ALGUMAS SITUAÇÕES A reserva do art. 10 permite à lei nacional determinar as situações das alíneas 5 e 6 do art. 44: (5) se é necessária a apresentação do título ao sacado para pagamento, depois de feito o protesto; (6) se a falência do sacado ou do aceitante promove o vencimento do título e dá ao portador do título o direito de exercer o direito de ação.	A lei brasileira regula os casos de falência do aceitante (LS, art. 19, II). A reserva, contudo, menciona direito de regresso contra os coobrigados em outras hipóteses no art. 43, 2ª e 3ª alíneas: • Falência do sacado (aceitante ou não); • Suspensão de pagamentos do sacado; • Execução frustrada do sacado; • Falência do sacador de uma letra não aceitável (art. 43, alínea 3ª).
----	--	--

	Além disso, permite que legisle sobre a matéria do art. 43, alíneas 2 e 3, isto é, quanto ao exercício do direito de ação contra os coobrigados nos casos de suspensão de pagamentos, falência ou execução frustrada de sacado (aceitante ou não) e nos casos de falência de sacador de letra não aceitável.	O direito brasileiro desconhece o critério de suspensão de pagamentos, moldando a insolvência por outros critérios, todos dependentes de decisão judicial – declaração de insolvência civil ou falência do empresário. Só há relevância para o D. Brasileiro a falência do sacado, quando este aceita o título, daí a norma contida no art. 19, II, da Lei Saraiva. O fato de o sacado que não aceitou ou o sacador serem declarados falidos em nada altera os prazos contidos no título que se regerão pelas regras ordinárias de vencimento. No que se refere à letra não aceitável, isto é, a proibição de remeter a letra para o sacado aceitar, há de se discutir, no item próprio do aceite, a vigência ou não proibição contida no art. 44, III, da lei brasileira que considera não escrita a cláusula proibitiva da apresentação da letra.
	TAXA DE JUROS	No Brasil o teto está previsto no art. 1º do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, que estipula a vedação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal prevista no art. 1.062 do Código

13	Os arts. 48 e 49 fixam a taxa de juros de 6% ao ano. A reserva permite que a lei nacional estabeleça o montante.	Civil de 1916, estabelecida em 6% ao ano. A partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se, quanto aos juros legais, o limite relativo à “taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (CC, art. 406) que é a prevista no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional – 1% ao mês.
15	AÇÃO POR LUCROS ILEGÍTIMOS A reserva do art. 15 remete aos Estados subscritores da Convenção o direito de regular ação por enriquecimento indevido, no caso de perda do direito de ação ou ocorrência de prescrição, contra sacador, endossantes ou aceitante.	A ação ordinária para esse fim está prevista no art. 48 da lei brasileira.

12

16	OBRIGAÇÃO DE PROVISÃO DO SACADOR As questões quanto à necessidade de provisão pelo sacador à data do vencimento e sobre as relações jurídicas que serviram de base para a emissão da letra.	A lei brasileira é omissa quanto à necessidade de provisão pelo sacador, mas o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais está patente no art. 51.
17	CAUSAS DE INTERRUPTÃO OU DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO A reserva devolve à lei nacional sua regulamentação.	A quase totalidade dos autores⁵ entende que o prazo prescricional é totalmente regido pelo art. 70 da Lei Uniforme, isto é: • a ação contra o aceitante prescreve em 3 anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea 1); • a ação contra o endossador e seu avalista, em um ano da data do protesto feito em tempo útil ou da data do vencimento (LUG, art. 70, alínea 2); • a ação entre os endossantes e contra o sacador prescreve em seis meses do dia em que o endossante pagou a letra ou do dia em que foi acionado (LUG, art. 70, alínea 3). Para Fran Martins (1995, 1:75-76), com a reserva, o

		quadro do art. 70 da LUG se modifica: • a ação contra o aceitante prescreve em 5 anos (LS, art. 52) da data em que a ação pode ser proposta e não em 3 anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea 1);
--	--	--

		• a ação contra o endossador e seu avalista, em 12 meses do dia do pagamento (LS, art. 52) e não em um ano da data do protesto feito em tempo útil ou da data do vencimento (LUG, art. 70, alínea 2); • a ação entre os endossantes e contra o sacador prescreve em seis meses do dia em que o endossante pagou a letra ou do dia em que foi acionado, mantendo a redação do art. 70 da LUG, por falta de dispositivo na lei brasileira.
19	DENOMINAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA Reservada à lei nacional.	Dispositivo sem relevância, porque a denominação da nota promissória foi mantida no Direito Brasileiro.
20	EXTENSÃO DAS RESERVAS DO ANEXO II – arts. 1 a 18 – ÀS NOTAS PROMISSÓRIAS.	Aplicam-se, no que couber, as reservas às notas promissórias.

2.5. Institutos cambiários

2.5.1. Saque

O saque é a operação de emissão da letra de câmbio. Pontes de Miranda (2000, 1:227) distingue as palavras “criação” e “emissão”, entendendo que a primeira designa o fazimento até a subscrição, e, a segunda, seu lançamento à circulação.

Contudo, interessa ao direito o título criado e pronto à circulação, gerando efeitos jurídicos entre aqueles que apuserem suas assinaturas na cártula.

Para a validade do título é indispensável obediência aos requisitos formais extrínsecos exigidos pela legislação em vigor, objeto de estudo nos tópicos precedentes. Há, ainda, que se respeitarem, além da forma prevista em lei, os

requisitos intrínsecos, comuns a todos os demais negócios jurídicos: a capacidade e o objeto lícito.

Agregam-se a esta matéria outras questões: a letra incompleta ou em branco, a permissão de inclusão de certas cláusulas concomitantemente à emissão e a pluralidade de exemplares:

a) Letra incompleta ou em branco

É possível que a letra de câmbio circule de forma incompleta, isto é, sem atender a todos os requisitos exigidos pela lei, transferindo-se por endosso e sendo garantia por avais até chegar às mãos do portador. Assim emitida e assinada pelo sacador, aceita ou não pelo sacado, pode ser completada pelo credor de boa-fé, desde que o faça *antes* da cobrança ou do protesto, conforme entendimento jurisprudencial (Súmula 387 do STF).

O direito de “preencher” decorre da posse legítima de boa-fé, não podendo, porém, o possuidor fazê-lo abusivamente, isto é, além do que foi objeto do endosso, conforme decorre do art. 10 da Lei Uniforme: “Se uma letra incompleta no momento de ser passada tiver sido completada contrariamente aos acordos realizados, não pode a inobservância desses acordos ser motivo de oposição ao portador, salvo se este tiver adquirido de má-fé ou, adquirindo-a, tenha cometido falta grave”.

Em outras palavras, o acordo sobre o “preenchimento” tem efeito entre as partes – endossante e endossatário. Se entre os endossos precedentes à posse do portador houver quem tenha preenchido abusivamente e transferido o título com valor não acordado, as relações posteriores, se de boa-fé, não ficam afetadas, podendo, contudo, o subscritor – aceitante e/ou sacador – ir contra aquele que deixou de observar o quanto estabelecido.

Miguel Pupo Correia (1999:150) expressa-se de forma didática a respeito: “c pacto de preenchimento, como convenção extracartular que é, não é oponível a um portador *mediato*, isto é, a um portador que não tenha sido parte naquela convenção. Isto a menos que o portador *mediato* tenha adquirido a letra de má-fé ou cometendo uma falta grave (...)”. A respeito do que seria falta grave, o mesmo autor (1999:159)

completa: “correspondente à falta daquele mínimo de diligência com que deve agir um homem médio”.

Eis um exemplo: (α) saca uma letra de câmbio a favor de (β), tendo como sacado (γ). A letra está incompleta quanto ao valor acertado entre as partes originárias, no montante de R\$ 1.000,00. (β), tomador do título, a transfere de forma incompleta a (δ) que, abusivamente, preenche o título em valor superior, R\$ 2.000,00, e a transfere para (ε), endossatário que desconhece os fatos anteriores. (ε), por sua vez, a transfere para (η), portador que cobra do aceitante (γ) o valor de R\$ 2.000,00. (γ) não pode opor-se ao pagamento alegando abuso, em razão do acordo que tinha com (α), porque (η) é portador de boa-fé.

Nessa linha de circulação do título, as relações pessoais são assim definidas:

$\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \eta$ Sacador $\alpha \rightarrow$ Tomador $\beta \rightarrow \delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow$ Portador η				
OPOSIÇÕES ENTRE OS OBRIGADOS				
γ (aceitante) somente pode opor-se ao sacador α , em razão de exceções pessoais que tenha contra ele. Não pode, contudo, alegá-las contra os demais figurantes do título, porque as relações são autônomas:	α (sacador) somente pode opor-se ao tomador β em razão de exceções pessoais que tenha contra ele. Não pode, contudo, alegá-las contra os demais figurantes do título, porque as relações são autônomas:	β (tomador) somente pode opor-se ao coobrigado δ , em razão de exceções pessoais que tenha contra ele. Não pode, contudo, alegá-las contra os demais figurantes do título, porque as relações são autônomas:	δ (endossatário do título e endossante a ε) somente pode opor-se a ε em razão de exceções pessoais que tenha contra ele. Não pode, contudo, alegá-las contra o atual portador do título (η) porque as relações são autônomas:	ε (endossatário do título e endossante a η) somente pode opor-se a η , em razão de exceções pessoais que tenha contra ele.
γ O α γ (α) Ø β γ (α) Ø δ γ (α) Ø ε γ (α) Ø η	α O β α (β) Ø δ α (β) Ø ε α (β) Ø η	β O δ β (δ) Ø ε β (δ) Ø η	δ O ε δ (ε) Ø η	ε O η

No exemplo acima, fazendo uso da notação de Rubens Requião (1995, 2:316-317), “O” representa a possibilidade de exceção pessoal e “Ø” a impossibilidade (inoponibilidade da exceção de defesa contra portador de boa-fé).

b) Cláusulas adicionais

Algumas expressões lançadas no título permitem tornar mais maleável a genérica estrutura cambial, adaptando sua emissão a determinadas situações pessoais. A esse respeito devem ser lembradas algumas cláusulas mais comuns:

- Cláusula não à ordem: em regra as cambiais presumem-se emitidas à ordem, isto é, por sua natureza de circularidade, o título permite a transmissão por endosso, independentemente de estipulação expressa. É possível, entretanto, ao sacador inscrever “não à ordem” ou frase equivalente (não circulável, não transferível, não cedível), impondo a transferibilidade tão somente sob a forma e efeito de cessão de crédito, instituto tipicamente civil (art. 11 da LUG), objeto de maior aprofundamento no capítulo correspondente ao cheque (4.6). Além do sacador, qualquer endossante pode impor a cláusula não à ordem e, neste caso, sua eficácia restringe-se às assinaturas posteriores à inscrição.

- Cláusula sem protesto: é a que isenta o portador de promover o protesto, na falta de aceite ou de pagamento. Pode ser expressa por frases equivalentes: “sem despesas”, “protesto desnecessário” etc. A regra geral estabelece a necessidade de o portador promover o protesto para comprovar a falta de aceite ou de pagamento (LUG, art. 44, 1ª alínea).

Da ausência de protesto no prazo legal decorrem inúmeras consequências, sendo a mais importante a perda do direito de ação contra os coobrigados, à exceção do aceitante e seu avalista (LUG, art. 53, alínea 2ª). Inscrita a cláusula “sem protesto”, o portador se vê desobrigado de promover o ato em cartório, mantendo inalterado seu direito de ação, bastando apresentar a letra para aceite ou pagamento e expedir os avisos correspondentes ao endossante e ao sacador do título (LUG, arts. 45 e 46).

Além do sacador, os endossantes e os avalistas podem inscrever a cláusula sem

protesto no título, mas os efeitos serão distintos: no primeiro caso (inscrita pelo sacador) produzirá efeitos em relação a todos os signatários da letra e, nos demais, somente em relação ao endossante ou avalista que a escreveu no título.

- Cláusula de juros: já vimos (v. item 2.3.2, *d*) que, na criação de letras pagáveis à vista ou a certo tempo da vista, o sacador pode estipular a cobrança de juros, que se presumem contados da data da emissão da letra, salvo indicação diversa.

- Cláusula de pagamento em moeda estrangeira: é permitida nos casos especificados pelo legislador, nos termos já estudados (v. item 2.3.2, *b*), vedando-se, contudo, a que imponha pagamento efetivo em moeda estrangeira (v. item 2.3.2, *c*).

- Cláusula de proibição de aceite: o sacador pode inserir cláusula de proibição de apresentação para aceite salvo em três casos, nos quais é vedada a proibição: (1) na hipótese de letra vencível a certo termo da vista, em que a apresentação é obrigatória (v. item 2.5.2, *b*); (2) na letra domiciliada (v. item 2.3.5); e (3) na letra pagável em localidade diversa da de domicílio do devedor.

A vantagem de o sacador emitir título inaceitável reside em evitar o vencimento antecipado do título pela recusa do aceite, fato que acarretaria o protesto e a possibilidade de o possuidor valer-se do direito de ação contra os coobrigados, inclusive o sacador.

A inserção de proibição, contudo, não é possível na letra vencível a certo termo de vista porque essa expressão (“vista”) significa apresentação para aceite, decorrendo daí sua indeclinabilidade. O prazo de vencimento começa a fluir da apresentação, o que justifica a vedação legal (LUG, art. 22).

A letra pagável em localidade diversa da do domicílio do sacado e a letra domiciliada – a pagável em domicílio de terceiro – (LUG, art. 4º) igualmente não comportam “cláusula de não aceite”. A razão legal está em que o sacado deve, antes do vencimento, assentir não somente quanto à sua vinculação cambial, mas também quanto ao fato de a obrigação lhe ser exigida em *local diverso* do seu domicílio. Com a apresentação segue-se a concordância do sacado ao deslocamento do lugar de pagamento para localidade diversa da regra geral, que é seu domicílio. Trata-se de

verdadeira declinação de foro, sobre a qual cabe-lhe consentir ou recusar.

- Cláusula de proibição de aceite antes de determinada data: o sacador pode preferir não proibir o aceite, mas, por outro lado, pode lhe parecer interessante estipular que a apresentação ao aceite não se efetue antes de determinada data (LUG, art. 22, 3ª alínea), em momento aquém ao de vencimento do título.

- Cláusula sem garantia: outra maneira de o sacador não sofrer os efeitos da falta de aceite sem, contudo, chegar ao extremo de proibir a apresentação do título ao sacado é a possibilidade de eximir-se expressamente da garantia da aceitação da letra (LUG, art. 9º).

A proibição de aceite, a proibição de aceite antes de determinada data e a exoneração de garantia referem-se, portanto, a espécies de cláusulas que têm por escopo proteger a posição do sacador quanto aos efeitos da apresentação do título ao sacado e sua recusa em aceitá-lo.

c) Pluralidade de exemplares

No século XV, a partir da Itália, o uso das letras de câmbio popularizou-se, adotado que foi pela “maior parte dos mercadores de toda a Europa, incluindo mesmo os mercadores da Hansa Alemã” (cf. Hunt e Murray, 2000:332). Por uma questão de segurança os títulos eram emitidos em mais de uma via, como bem descreve Filipe Barata (1998:383-384): “Uma boa medida da forma como as letras de câmbio foram rapidamente incorporadas nas práticas comerciais do reino, é-nos dada por uma carta de 11 de junho de 1428 em que Rafael Fogaça, vivendo em Bruges, escreve a Afonso Eanes, então na Itália, dando-lhe conta de que recebera dele uma missiva e, dentro, vinha uma ‘letra de caybo segunda’ para receber de um certo Galião Boramym 800 florins. Esta era a prática habitual dos mercadores da região: por uma questão de segurança, eram emitidas para cada negócio 3 letras de câmbio, esperando-se que uma delas pudesse chegar ao destino. Neste caso, só se perdera a primeira, mas a ‘segunda letra’ atingira o destinatário”.

A duplicata da letra de câmbio, isto é, a emissão em mais de uma via, manteve-se no direito moderno. O evidente risco da multiplicidade de exemplares é minimizado

pela exigência de figurar a ordem de numeração no contexto do título – ao invés de escrever “por esta única via pagará V.S^a”, dá-se outra redação: “por esta primeira via...”, “por esta segunda via...” etc.

O controle que deve ser exercido sobre cada uma das vias e a complexidade do mecanismo de circularidade, aliados ao quase nenhum benefício de sua adoção nos dias atuais, em razão da rapidez e eficiência dos meios de remessa, tornam despiciendo o aprofundamento de estudos acerca do infrequente uso.

De fato, além da numeração de cada via, indicando a existência de múltiplos exemplares, há ainda: (a) o direito de o portador exigir a entrega de todas as demais vias em circulação, dirigindo-se, para tanto, ao endossante imediato e este ao anterior, até chegar ao sacador (LUG, art. 64); (b) os endossantes são obrigados a reproduzir os endossos nas novas vias (LUG, art. 64, *in fine*); (c) o endossante pode ter transferido vias da mesma letra a várias pessoas, acarretando sua obrigação pessoal e a dos posteriores endossantes (LUG, art. 65); (d) ao enviar uma via para aceite, o portador deve indicar nas demais vias o nome da pessoa em cujas mãos aquela se encontra. A recusa da devolução dessa via impõe ao portador a obrigação de protestar a via para comprovar que foi enviada para aceite e não lhe foi restituída e que não lhe foi possível conseguir o aceite ou o pagamento de outra via (LUG, art. 66).

Além da duplicação da letra de câmbio, a Lei Uniforme permite ao portador o direito de copiar o título – reprodução exata, com todos os endossos e todas as menções que nela figurem – mencionando tratar-se de cópia, indicando onde termina a reprodução e o nome da pessoa em cuja posse se encontra o título original.

Essa cópia pode ser endossada e avalizada, produzindo os mesmos efeitos do título original, mas o exercício do direito de ação depende: (a) da remessa do original ao portador da cópia; (b) em caso de recusa, a comprovação por protesto neste sentido (LUG, art. 68).

A coexistência do original e de sua cópia pode dar margem à transferência a pessoas distintas, razão pela qual o legislador permite ao portador inscrever no título original cláusula “daqui em diante só é válido o endosso na cópia” ou fórmula

equivalente, increpando de nulidade todo e qualquer endosso posterior lançado no título original.

2.5.2. Aceite

Aceite é o ato de vontade materializado pela aposição de assinatura no título, mediante a qual o sacado concorda com a ordem do sacador, tornando-se o principal responsável pelo pagamento da quantia expressa na letra de câmbio na data de seu vencimento.

a) Natureza do aceite

A emissão do título não obriga o sacado; tem ele a faculdade de vincular-se àquela obrigação, mediante o simples lançamento de sua assinatura no anverso do título ou, se no verso, precedida de expressão que traduza sua concordância (aceito, concordo, acolho, sim, pagarei etc.). Mesmo depois de o título ter circulado, contendo várias manifestações de pessoas que aderiram às obrigações, por avais e endossos, o sacado pode recusar sua adesão, devolvendo o título ao portador.

b) Apresentação obrigatória e facultativa

Nas letras de câmbio emitidas sem data de vencimento ou com a expressão “à vista”, a apresentação da letra ao sacado é feita para pagamento porque a simples vista da letra significa seu vencimento. Rigorosamente, não há, neste caso, apresentação para aceite.

A apresentação para aceite tem sentido nos títulos emitidos para pagamento a prazo, isto é, os que contêm vencimento a certo termo da vista, em dia certo, ou a certo termo de prazo, sendo obrigatória no primeiro caso e facultativa nos dois últimos.

A facultatividade emerge do fato de que, nos dois últimos casos, as datas de vencimento são conhecidas: na letra vencível em dia certo, este é o dia de vencimento e para se saber o dia de vencimento na emitida a certo termo de prazo, basta somar à data do saque o termo correspondente (trinta dias, dois meses, um ano etc.). Mesmo

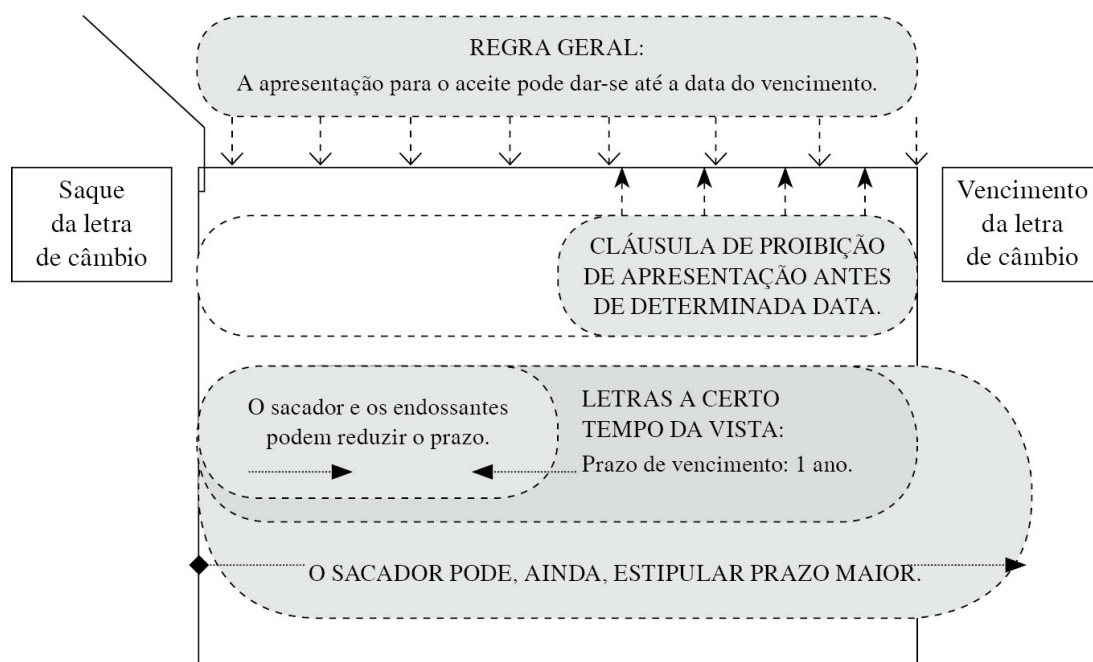
não sendo obrigatória a apresentação para o aceite, o portador pode providenciá-lo visando dar maior confiabilidade ao título.

c) Momento para o aceite

Como regra geral o portador do título ou pessoa incumbida por ele deve apresentar o título ao sacado para o aceite em qualquer momento antes da data do vencimento. O portador não é obrigado a deixar o título nas mãos do sacado, mas ao sacado é permitido pedir que a letra lhe seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação.

Há, ainda, outros momentos a se considerar, dependendo de cláusulas insertas no título ou de circunstâncias extraordinárias:

- Cláusula de proibição de aceite antes de determinada data: o sacador pode estipular que a apresentação ao aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data (LUG, art. 22, 3ª alínea).
- Obrigação de apresentação ao aceite por endossante, fixando ou não prazo (LUG art. 22, 4ª alínea). Esta e a hipótese anterior podem ocorrer em qualquer modalidade de vencimento de letra.
- Nas letras de câmbio a certo termo de vista o prazo se estende até um ano após a apresentação, permitindo-se ao sacador reduzir ou ampliar esse prazo e, aos endossantes, somente reduzi-lo (LUG, art. 23). Como já visto, somente nessa modalidade de letra a apresentação é obrigatória, porque o vencimento da letra somente ocorrerá a partir da data da vista, isto é, apresentação para aceite.



d) Recusa do aceite

A recusa de aceite pode ser tácita, pela simples devolução do título ao portador, ou expressa por manifestação escrita do sacado lançada no título e acarreta alguns efeitos: (1) a necessidade de o portador protestar o título no prazo legal para comprovar a falta de aceite (LUG, art. 44), sem o que perderá o direito de ação contra os endossantes e outros coobrigados (LUG, art. 53); (2) o vencimento antecipado do título, permitindo ao portador exercer seus direitos de ação antes do vencimento ordinário do título, mesmo se a recusa for apenas parcial (LUG, art. 43).

Esses efeitos ocorrem mesmo nos casos de recusa parcial, seja ela de cunho limitativo – isto é, quanto ao valor – ou de cunho modificativo – quanto às condições de pagamento. A limitação (LUG, arts. 26 e 43) ou a modificação (LUG, art. 26) do aceite equivalem à recusa total e geram os mesmos efeitos acima mencionados.

Aceite limitado é, pois, a anuência do sacado em pagar tão só parcialmente a quantia mencionada na cambial, vinculando-se, nesses limites, à obrigação cambial. Fran Martins (1995, 1:196) define o aceite modificativo como sendo “aquele em que o aceitante, em vez de acatar a ordem nos termos em que ela foi emitida, altera algum requisito da mesma, como, por exemplo, a data do vencimento, o lugar de pagamento

ou, mesmo, a espécie da moeda em que a importância deve ser paga, além de outra diversidade qualquer do que está escrito no título”. Semelhantemente ao que ocorre na limitação de valor, o sacado vincula-se nos termos de seu aceite modificativo.

e) Efeitos da não apresentação para o aceite

Se o portador perder o prazo para a apresentação para o aceite do título na modalidade em que ele é obrigatório – vencimento a certo termo da vista –, perderá o direito de regresso contra todos os coobrigados ao título, salvo se comprovar a existência de motivo suficiente à prorrogação (LUG, arts. 53 e 54).

Motivo insuperável é o decorrente de força maior, diverso de causa ligada ao interesse puramente pessoal do portador ou da pessoa encarregada da apresentação. O portador deve apresentar o título sem demora tão logo cesse a força maior. Se a circunstância impeditiva prolongar-se por mais de trinta dias, ocorrerá vencimento antecipado, dispensando-se tanto a apresentação como o protesto.

f) Letra não aceitável

É a que traz cláusula de proibição de aceite (v. item 2.5.1, *b*). Pode ocorrer tão somente nas modalidades de apresentação facultativa, uma vez que a apresentação é indisputável nos casos de letra vencível a certo termo da vista. Há, ainda, vedação para sua inscrição nas letras pagáveis em localidade diversa do domicílio do sacado, por razões que são objeto do estudo acima indicado.

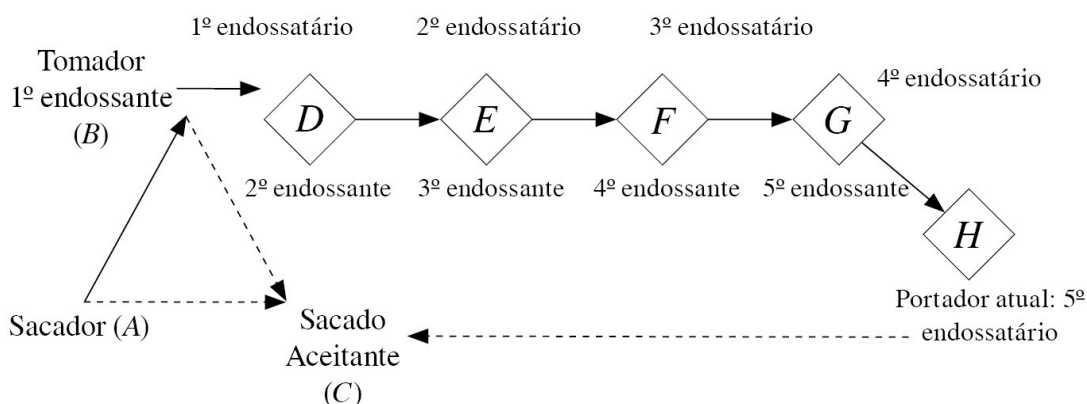
2.5.3. Endosso

Pontes de Miranda (2000, 1:315) desvenda a origem da palavra endosso: “*quia dorso inscribi solet*” (“porque geralmente inscrito na parte de trás”).

No seu nascimento a letra de câmbio comporta três figuras: o sacador – emitente da ordem; o sacado – pessoa indicada a realizar o pagamento; e o tomador, beneficiário do título, portador originário que o recebe das mãos do sacador.

Cabe ao tomador dar início à circulação do título, tornando-se o primeiro endossante, fazendo surgir uma quarta figura cambial: o endossatário, pessoa que

passa a ser o beneficiário do título, seu portador. A sequência pode estender-se com a transmutação desse primeiro endossatário em segundo endossante e assim sucessivamente.



A letra de câmbio é essencialmente emitida à ordem, independentemente de cláusula expressa. É possível, entretanto, a inserção de cláusula não à ordem, tornando o título intransmissível por endosso (v. item 2.5.1, *b*).

a) Modalidades de endosso

O endossador pode transmitir o título pela simples aposição de sua assinatura, seguida ou não da expressão “ao portador” – neste caso faz endosso em branco que, para não se confundir com o aval, só pode ser lançado no verso do título, permitindo ao endossatário: (a) preencher o espaço em branco, com o seu nome ou o de outra pessoa; (b) endossar de novo a letra; (c) remetê-la a um terceiro, sem endosso.

É possível, ainda, endossar em preto, bastando especificar o nome do novo beneficiário, endossatário do título.

Em nenhum caso há necessidade de indicar a data da operação: na omissão presume-se ter sido lançada em data anterior ao prazo fixado para se fazer o protesto (LUG, art. 20).

b) Endosso parcial e endosso sem garantia

Diversamente ao que ocorre com o aceite, que pode ser limitado ou modificado pelo sacado, a lei não admite o endosso parcial, exigindo que se o faça de forma

“pura” e “simples” (LUG, art. 12). Ao lançar sua assinatura o endossante transmite os direitos da letra, tornando-se, em contrapartida, solidariamente responsável pelo aceite e pelo pagamento, obrigando-se ao montante total indicado no título, nas condições nele expressas quanto ao vencimento, juros, espécie de moeda etc.

É possível, entretanto, lançar endosso acompanhado de expressões como “*sem garantia* ou *sem obrigação*”, ambas restritivas da obrigação do endossante (LUG, art. 15) isentando-o de garantir tanto a aceitação como o pagamento da letra. O endossante pode, contudo, limitar a exclusão das obrigações a uma das isenções (sem obrigação de aceitação; sem obrigação de pagamento).

A cláusula sem garantia não é exclusiva do endosso, podendo ser lançada pelo sacador no momento da criação do título, limitada, neste caso, tão somente à aceitação do título (v. item 2.5.1, *b*).

c) Proibição de novo endosso

O endossante pode proibir um novo endosso. Apesar da expressão “proibir”, utilizada pelo legislador genebrino, ao expressar sua vontade nesse sentido, o endossante apenas isenta-se do pagamento do título a qualquer pessoa a quem o título vier a ser posteriormente endossado (LUG, art. 15, final). A proibição não impede a circulação do título, mas retira a garantia quanto ao pagamento do endossante que clausulou relativamente a outros figurantes que não o seu endossatário.

d) Endossos impróprios: mandato e caução

Quanto à extensão de vínculos do endossante com o endossatário e demais integrantes posteriores, admite-se o lançamento de endosso não traslativo de direito de propriedade, como ocorre no endosso-mandato (endosso-procuração), a partir do qual somente admitirá outros endossos-mandatos.

A previsão dessa modalidade encontra-se no art. 18 da Lei Uniforme. Neste caso a assinatura do endossante contém a expressão “valor em cobrança”, “para cobrança”, “por procuração” ou equivalentes e, com ela, o endossante vincula-se aos endossatários tão somente com relação ao mandato ou ao serviço de cobrança que

contratou. Os coobrigados podem invocar contra o portador do título as mesmas exceções que dispõem contra o endossante porque não houve, no endosso, transmissão de crédito, mas somente ordem para os endossatários realizarem a cobrança do crédito pertencente ao endossante.

Para dar maior segurança à operação, o endosso-mandato não se extingue com a morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade (LUG, art. 18, 3ª alínea), ao contrário do que sucede no mandato civil (CC, art. 682, II).

Permite-se, ainda, o endosso com indicação de penhor ou em garantia. Neste caso o endossante cede, em garantia real, os direitos que possui no título. O endossatário do título – credor pignoratício do endossante – não pode endossar o título com efeitos de transmissão de direitos de propriedade, porque não os possui. A cláusula “em penhor” transfere ao endossatário a posse do título em garantia de um débito, outorgando-lhe o direito de cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível. Com a posse deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado, como, por exemplo, apresentar o título ao sacado para aceite e pagamento, protestar, exercer as ações cambiais etc.

O endossatário que recebe o título a partir de endosso impróprio – em decorrência de mandato ou com a cláusula “em penhor”, “caução” ou equivalente – ao lançar sua assinatura no título o faz com efeitos de mandato ao novo endossatário, o que é simples de entender: não possuindo direitos de dispor, compete-lhe exercer todos os direitos atribuídos ao endossante anterior, à exceção do direito de transferir titularidade.

No endosso-mandato os coobrigados podem opor ao endossatário as mesmas exceções pessoais que eram oponíveis ao endossante (LUG, art. 18, 2ª alínea), o que não ocorre no endosso-caução (LUG, art. 19, 2ª alínea). É que, no primeiro caso – endosso-mandato –, a relação entre o endossante e os coobrigados não se altera pelo fato de o título ter sido entregue para cobrança, mas, no segundo caso – endosso-caução –, o endossatário é titular de uma garantia real sobre o título de crédito, negócio jurídico autônomo que mantém com o endossante, não lhe podendo ser opostas exceções por outras relações jurídicas que o endossante firmou com terceiros.

2.5.4. Aval

À falta de outro termo, denomina-se aval tanto o instituto jurídico como o ato de vontade, a obrigação (perante o credor) e a garantia (a favor de um dos devedores) resultantes dessa declaração. Daí por que a doutrina procura apresentar distintos conceitos, exaltando certas particularidades expressivas do instituto.

Fran Martins (1995, 1:205) prefere a visão obrigacional: “obrigação cambiária assumida por alguém no intuito de garantir o pagamento de letra de câmbio nas mesmas condições de outro obrigado”. Rubens Requião (1995, 2:431) enfatiza a finalidade garantidora: “garantia de pagamento de letra de câmbio, dada por um terceiro ou mesmo por um dos signatários”. Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:415) elege a declaração de vontade: “ato cambiário pelo qual uma pessoa (*avalista*) se compromete a pagar título de crédito nas mesmas condições que um devedor deste título (*avalizado*). Pontes de Miranda (2000, 1:361) celebra as características do instituto: “vinculação típica, que é literal e expressa”.

Para nós, aval é instituto jurídico tipicamente cambiário por meio do qual alguém, signatário ou não da letra, promete o cumprimento de obrigação de pagamento de importância em dinheiro, no todo ou em parte e de forma autônoma, em posição equivalente à obrigação de um ou mais devedores integrantes do título de crédito.

Vejamos as questões mais importantes, salientando, ainda, cada aspecto desse conceito:

a) Tipicidade cambiária

O aval é obrigação cambial própria e distinta de outras que são lançadas no título. Diversamente do que ocorre com as obrigações assumidas pelo sacador, aceitante e endossante do título, independentes umas das outras, a obrigação do avalista vincula-se à obrigação assumida pelo avalizado. Em outras palavras, liberado o avalizado, libera-se o avalista. Esta estreita ligação com a obrigação garantida confere ao aval natureza e características únicas, não presentes em outros direitos que o portador possui em relação aos demais devedores do título.

b) Declaração de vontade expressa

Aval é declaração unilateral de vontade e, meramente por esta característica, torna-se possível distingui-lo de outro instituto garantidor de obrigação: a fiança, que se define “*contrato* pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor” (CC, art. 818). Há entre aval e fiança outras distinções, mas, para os propósitos deste estudo, basta confrontar a natureza jurídica dos institutos: declaração unilateral de vontade e contrato.

Para distinguir de outros institutos cambiários, a assinatura para o aval deve ser acompanhada de expressões “bom para aval” ou fórmula equivalente, salvo se a assinatura for lançada no anverso do título, que dispensa qualquer qualificação. Desse modo, identificadas as assinaturas do sacador e do aceitante, todas as demais lançadas no anverso, sem expressão qualificadora, serão necessariamente de avalistas.

Havendo outras assinaturas, o avalista deve indicar o nome do signatário da letra a quem o aval é produzido (avalizado); se não o fizer, presume-se tenha sido oferecido ao sacador.

No verso do título, para não confundir com o endosso em branco, o aval deve ser sempre precedido da fórmula “bom para aval” ou equivalente. Como ocorre com o lançamento no anverso, a assinatura deve identificar o nome do avalizado – aval em preto, sob pena de ser considerada atribuída ao sacador do título.

Um quadro-resumo permite retratar os tipos, a posição e as expressões obrigatórias do aval:

MODO	LUGAR DE LANÇAMENTO	
	LANÇADO NO ANVERSO	LANÇADO NO VERSO
Aval em	Com ou sem a expressão “por aval” ou equivalente. É sempre assinatura do avalista do sacador.	É avalista do sacador, mas para essa conclusão é necessário que a assinatura esteja acompanhada da expressão “por aval” para não confundir-se com os

branco	Se houver várias assinaturas, excluídas as do aceitante e do sacador, todas as demais, em branco, são de avalistas do sacador.	endossos em branco. Havendo várias assinaturas “por aval” no verso, presumem-se dadas ao sacador.
Aval em preto	O avalista identifica a quem dá o aval. Exige a expressão “por aval” ou equivalente, para não confundir com o endosso que, “em preto” também pode ser lançado tanto no verso como no anverso.	

Conclusões: (1) o aval em branco, lançado no anverso ou no verso – necessariamente qualificado com a expressão “por aval”, quando lançado no verso –, presume-se atribuído ao sacador; (2) o aval em preto deve ser sempre qualificado com a expressão “por aval”.

c) Garantia cartular

O aval, por ser obrigação exclusivamente cambial, deve ser sempre lançado sobre a cártula ou em folha anexa. É dessa natureza cartular que decorrem seus principais efeitos, regendo-se por regras cambiais que lhe são distintas. De outra natureza são as garantias oferecidas em contratos ou em documentos diversos do cambial que, embora popularmente sejam denominadas avais, não o são.

Não é raro confundir-se aval com fiança, institutos que, como anotado nas linhas anteriores, guardam entre si não poucas distinções, podendo ser salientadas algumas delas:

- A fiança é negócio jurídico bilateral e, como tal, ligado a uma causa contratual; o aval é declaração de vontade cambial, abstrata;
- O aval é sempre prestado no título cambiário e se declarado fora dele não se presta à sua função, nem “goza das prerrogativas, quer de direito material, quer de direito formal, criadas pela legislação cambiária” (Pontes de Miranda, 2000, 1:363);
- O fiador dispõe de benefício de ordem, como devedor subsidiário, isto é, pode exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor para depois serem executados seus próprios bens (CC, art. 827); o avalista ostenta, na linha de

devedores do título, posição igual à do avalizado e, como tal, o portador pode empregar contra ele o mesmo direito que detém em relação ao avalizado, acionando-o em conjunto com aquele ou separadamente, independentemente de obediência a qualquer ordem ou excussão prioritária de bens. É o princípio do art. 47 da Lei Uniforme: “O portador tem o direito de acionar todas estas pessoas individualmente, sem estar adstrito a observar a ordem por que elas se obrigaram”;

- O fiador que paga integralmente a dívida pode demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota (CC, art. 831); no aval esta situação somente ocorre em avais simultâneos, isto é, na hipótese de um mesmo devedor estar garantido por mais de um avalista.

d) Obrigação autônoma

O princípio da autonomia das obrigações cambiárias permeia todo o sistema cambial, não sendo exclusividade do instituto do aval. Sua expressão legal encontra-se tanto na Lei Brasileira (“As obrigações cambiais são autônomas e independentes umas das outras”, art. 43) como na Lei Uniforme. Nesta, o art. 7º após dispor sobre assinaturas inválidas (de pessoas incapazes, falsas, de pessoas fictícias ou que não poderiam obrigar as pessoas que assinaram a letra, ou em nome das quais ela foi assinada) arremata: “as obrigações dos outros signatários nem por isso deixam de ser válidas”.

Além do princípio geral, a autonomia do aval é assegurada no art. 32, alínea 2ª, da Lei Uniforme, que mantém a obrigação do avalista “mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma” (LUG, art. 32, 2ª alínea).

e) Equivalência obrigacional

Da expressão “da mesma maneira” utilizada pelo legislador da Convenção (LUG art. 32: “O dador de aval é responsável *da mesma maneira* que a pessoa por ele afiançada”) decorrem, como bem salienta Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:416), “unicamente definições de anterioridade ou posteridade, na cadeia de regresso, e

nunca efeitos incompatíveis com o princípio da autonomia das obrigações cambiais”.

Todas as ações que o portador dispõe contra o avalizado são permitidas ao avalista. Todos os direitos que o avalizado possui em relação aos devedores de regresso são sub-rogados ao avalista que paga o título.

É de atentar que o avalista, por aderir autonomamente, pode limitar quantitativamente a obrigação, garantindo menos do que se vinculou o avalizado. Sua vinculação é autônoma e cabe a ele deliberar o quanto se obriga, até o valor total. É vedado ao avalista, contudo, impor condições qualitativas porque estas implicam alterações que descaracterizarão o próprio título (outra data, até tal data, quando ocorrer tal situação etc.).

Em outras palavras: o aval garante o pagamento da letra, em sua totalidade ou parcialmente, mas não se permite ao avalista submeter a garantia a circunstâncias alheias às cláusulas de criação.

f) Momento em que se dá o aval

O aval deve ser lançado *antes do vencimento do título* e, ordinariamente, depois do lançamento da assinatura do avalizado, não sendo proibido, entretanto, que se faça antes. Neste último caso – aval lançado antes da assinatura do avalizado – é denominado “aval antecipado”. Sobre os efeitos do aval tardio – após o vencimento – v. o item 5.8.2, no capítulo das Duplicatas.

Surge então uma questão que envolve a aplicação de ambos os princípios anteriormente estudados (autonomia e equivalência obrigacional): a eficácia do aval dado ao sacado, personagem que, até o momento do aceite, não figura na cadeia obrigacional. Para uma das correntes doutrinárias, se o avalista se obriga “da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada”, como decorre da deficiente redação do art. 32 da Lei Uniforme, essa “maneira”, na hipótese de o sacado não aceitar, conduz à não vinculação do avalista. É a opinião de Fran Martins (1995, 1:222) e J. X Carvalho de Mendonça, aos quais se contrapõe o entendimento de João Eunápic Borges e Rubens Requião (1995, 2:344), com fundamento no princípio da autonomia obrigacional, conforme lição deste último: “sendo independentes as assinaturas, e

sendo conforme expressa a Lei Uniforme, o dado do aval responsável da mesma maneira que a pessoa por ele avalizada, subsiste o aval, pagando o avalista pelo sacado que não aceitou a letra”.

Fran Martins (1995, 1:223), no nosso entender acertadamente, afasta a aplicação da autonomia das obrigações cambiárias sob o fundamento de que “só haverá obrigação se o sacado aceitar a letra”.

g) Avais simultâneos e avais sucessivos

Dois conceitos finalizam o estudo do aval: o que decorre da possibilidade de existir múltiplos avais para garantir uma mesma obrigação – avais simultâneos – e o que surge da ideia de um aval garantir outro aval – avais sucessivos.

São simultâneos os avais prestados por várias pessoas à obrigação assumida por devedor ou devedores que se encontram na mesma posição. Por exemplo: *A, B, C* avalizam a obrigação do endossante *D*; *A, B* e *C* avalizam a obrigação dos aceitantes *D* e *E*; *A, B* e *C* avalizam a obrigação dos sacadores *D, E* e *F*.

Avalistas simultâneos são devedores solidários. O pagamento feito por um dos avalistas exonera a obrigação dos outros, mas se um deles pagar a totalidade do débito avalizado terá direito de exigir dos demais coavalistas o correspondente ao valor pago, subtraída a parte que, como avalista, lhe competia. Se um dos avalistas for declarado falido ou insolvente, cada um dos avalistas solventes acrescentará parte de seu quinhão à obrigação que já detém.

O aval simultâneo é regido pela regra comum da solidariedade passiva (CC, arts. 275-285), nada dizendo a legislação cambiária sobre as relações jurídicas entre coavalistas. Pontes de Miranda (2000, 1:371) é enfático neste ponto, ao afirmar que “as relações jurídicas que possam existir entre coavalistas são, necessariamente, extracambiárias, com referência ao título em que apuseram os seu avales”.

São sucessivos os avais dados ao avalista do título – aval de aval. Neste caso, a relação é tipicamente cambial e rege-se pelo direito cambiário: se o avalista do avalista pagar o título terá direito de regresso contra o avalizado (avalista do endossante, por exemplo), endossante, endossantes anteriores, tomador, sacador e

aceitante. A norma de regência é cambial; o avalista sucessivo possui, como qualquer outro signatário de uma letra quando a tenha pago, o direito de acionar todas as pessoas que lhe precedem sem estar adstrito a observar a ordem por que elas se obrigaram (LUG, art. 47).

2.6. Pagamento

“Pagamento é a execução voluntária da obrigação” (cf. Beviláqua, 1975, 2:66); é também o modo direto de extinção das obrigações. Na cambial o portador, último endossatário do título, é o credor do título, podendo exercer seu direito contra qualquer pessoa que figure na sequência de devedores que se inicia com o aceitante, segue ao sacador e ao tomador e, a partir de então, pela cadeia de endossantes e seus avalistas.

Haverá pagamento extintivo quando o aceitante pagar o título, assim denominado por desobrigar todos os demais signatários. Chama-se recuperatório (cf. Bulgarelli, 1996:186) o pagamento feito por um dos coobrigados, libera tão somente os coobrigados posteriores.

a) Noções

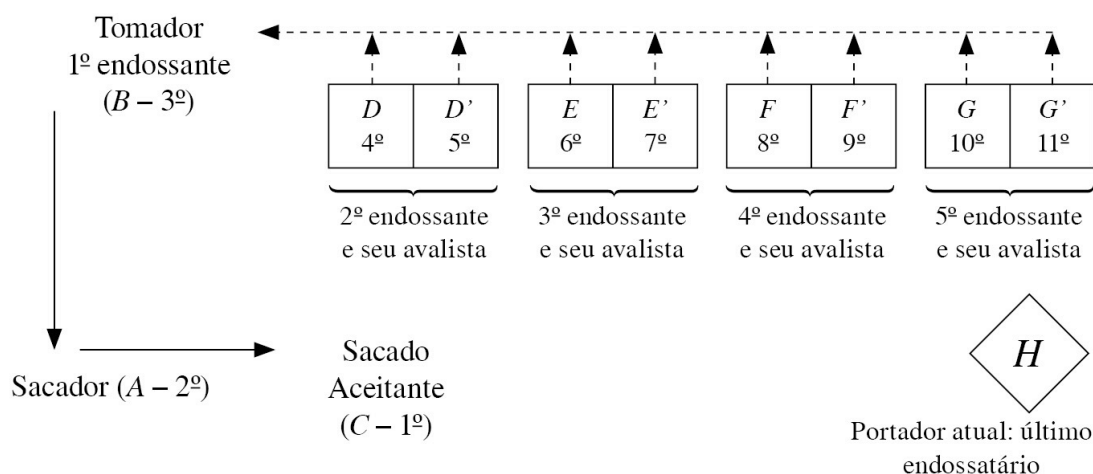
Algumas noções são necessárias para se compreender com exatidão os direitos a serem exercidos no vencimento da letra (v. item 2.3.4): (a) o primeiro ato é a apresentação: o título deve ser apresentado para pagamento ao primeiro devedor, pessoa designada como sacado, mesmo que não tenha lançado seu aceite; (b) o segundo ato é o protesto, ato cartorial que comprova a recusa de pagamento; (c) o terceiro é o exercício da ação: o portador tem o direito de acionar todos os signatários do título, sem estar adstrito a qualquer ordem por que elas se obrigaram; (d) qualquer pessoa que pagar o título, à exceção do devedor principal ou primeiro devedor, passa a ter o direito de acionar os devedores que lhe precedem na sequência de devedores; (e) para esse fim, segue-se a ordem cronológica de assinação; os avalistas seguem logo após os avalizados, conforme se pode observar no quadro ilustrativo logo abaixo; (e) quando efetuado pelo devedor principal extingue todas as obrigações cambiais porque não há outros devedores de regresso; (f) devedor

principal é o sacado aceitante ou, se não aceito o título, o sacador.

A sequência é assim considerada:

• portador → • avalista do último endossante → • último endossante → • avalista do antepenúltimo endossante → • antepenúltimo endossante → • avalista do endossante que o precede → • endossante que o precede → • avalista do endossatário do tomador → • endossatário do tomador → • tomador → • sacador → • aceitante.

Aproveitando o exemplo gráfico anterior (v. item 2.5.3), teremos onze devedores na sequência:



b) Pagamento por intervenção

Intervenção cambial é ato “pelo qual uma pessoa, estranha ou não à letra de câmbio, nela intervém, espontaneamente ou por força de indicação feita pelo sacador, endossante ou avalista, para aceitá-la ou pagá-la por honra de um dos devedores indiretos e de regresso” (Rosa Jr., 2007:206).

As regras para o pagamento por intervenção são simples:

• **Casos:** pode ocorrer nos casos em que o portador tem direito de ação: (a) na data do vencimento se o pagamento não foi efetuado; (b) antes da data de vencimento, nas hipóteses em que a lei admite o vencimento antecipado, isto é, quando houver recusa de aceite ou falência do aceitante¹³.

• **Extensão do pagamento:** deve abranger a totalidade da importância que teria de

pagar aquele por honra de quem a intervenção se realiza.

- **Liberação:** o pagamento libera todos os endossantes e os avalistas posteriores ao signatário por honra de quem se fez o pagamento.

- **Momento:** deve ser feito no dia seguinte ao último dia em que é permitido levar o título a protesto.

- **Pluralidade de intervenientes:** se várias pessoas se apresentam para pagar por intervenção terá preferência a que liberar, por seu pagamento, maior número de obrigados.

- **Omissão de indicação:** se não for indicado em honra de quem se faz o pagamento, presume-se que tenha sido feito ao sacador.

Por outro lado, os efeitos do pagamento ou da recusa são:

- **Recusa do pagamento por intervenção:** acarreta a perda do direito de ação contra as pessoas que ficariam exoneradas pelo pagamento, isto é, os coobrigados posteriores àquele por quem se intervém.

- **Direito de regresso:** o interveniente fica sub-rogado nos direitos contra aquele por quem pagou e contra os coobrigados anteriores a ele.

- **Proibição de endosso:** àquele que intervém, pagando a letra em nome de outrem, não se permite endossar a letra, vedando-se a circulação do título a partir de sua assinatura.

c) Ressaque

É o direito atribuído ao signatário do título de emitir uma nova letra de câmbio à vista, sacada sobre um dos coobrigados de regresso anteriores, pagável no domicílio deste, visando ressarcir-se do valor do pagamento efetuado, acrescido de juros e despesas realizadas. Uma letra de ressaque pode suscitar outros ressaques porque quem paga adquire o mesmo direito em relação aos coobrigados que lhe antecedem.

Para permitir o ressaque o título deve apresentar as seguintes situações: (a) esteja vencido; (b) foi protestado; (c) não se encontre prescrito.

De pouco uso, o ressaque é substituído com vantagem pela ação de regresso,

mediante a qual o signatário que paga o título pode acionar, em execução, os devedores coobrigados, com a apresentação do título e memória de cálculo com os valores de ressarcimento e os decorrentes da mora.

2.7. A apresentação

Dois dispositivos legais tratam da apresentação:

- Art. 38 da Lei Uniforme: “o portador de uma letra pagável em dia fixo ou a certo termo da data ou de vista deve apresentá-la a pagamento no dia em que ela é pagável ou num dos 2 (dois) dias seguintes”;
- Art. 20 da lei brasileira: “a letra deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento ou, sendo este dia feriado por lei, no primeiro dia útil imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossante e avalistas”.

A leitura permite duas soluções distintas: a letra deve ser apresentada até um dia seguinte ao vencimento (LS) ou nos dois dias subsequentes (LUG). No quadro constante do item 2.4., acima, ao tratarmos da reserva brasileira à Convenção (art. 5º do Anexo II) anotamos a prevalência da Lei Uniforme, em conformidade com o entendimento de Fran Martins (1995, 1:65). Consigna-se, agora, a divergência apontada por Fábio Ulhoa Coelho que sustenta a aplicação do art. 20 da lei brasileira, salvo se o pagamento deva se realizar no exterior, situação que exigiria a aplicação do art. 39 da Lei Uniforme.

O efeito da não apresentação do título para pagamento no prazo legal é a perda das ações contra os devedores à exceção do aceitante (LUG, art. 53, 2ª alínea), mas tão somente para as letras com cláusula “sem despesas”, isto é, a que dispensa o protesto para o exercício da ação. Nas demais letras, o protesto comprovará a falta de pagamento, suprimindo a formalidade legal de apresentação.

Na prática usual a apresentação é feita ao devedor principal na data do vencimento por boleto bancário e, se não é pago, o título é remetido a protesto, municiando o portador para o exercício da ação cambial contra os coobrigados.

Nas letras com a cláusula “sem despesas”, “sem protesto” ou “protesto

desnecessário” o portador se vê desobrigado de promover o ato em cartório, mantendo inalterado seu direito de ação, tornando imprescindível, em contrapartida, a apresentação da letra para aceite ou pagamento e a expedição de avisos correspondentes ao endossante e ao sacador do título (LUG, arts. 45 e 46), o que torna mais custoso para o portador que o simples protesto em cartório.

2.8. Protesto

No direito cambial protesto é o ato jurídico a cargo de tabelião de protesto de títulos, de natureza formal e solene, pelo qual se comprova o descumprimento de fatos de interesse cambiário: a recusa ou falta de aceite, a recusa ou falta de pagamento e a ausência de data de aceite.

a) Protesto por falta de aceite

A apresentação para aceite e, conseqüentemente, o protesto por falta de aceite somente são obrigatórios nas letras com vencimento a certo termo da vista, exigindo que o portador apresente o título para protesto (LUG, art. 44), sem o que perderá o direito de ação contra os endossantes e outros coobrigados (LUG, art. 53). Do protesto segue o vencimento antecipado do título, permitindo ao portador exercer seus direitos de ação antes do vencimento ordinário do título, mesmo se a recusa for apenas parcial (LUG, art. 43).

b) Protesto por falta de data de aceite

Igualmente, o protesto por falta de data de aceite só tem relevância nas letras com vencimento a certo termo da vista, porque é da apresentação (*vista*) que se conta o prazo para o pagamento do título. Se o título foi apresentado e acolhido pelo devedor, mas não foi datado, deve o portador conservar seus direitos contra os endossantes e sacador, levando o título a protesto (LUG, art. 25, *in fine*).

c) Protesto por falta de pagamento

O protesto por falta de pagamento deve ser tirado num dos dois dias seguintes àquele em que a letra é pagável (LUG, art. 44, alínea 3ª) na hipótese de a letra não ser

vencível à vista. Para esta deve-se observar que a lei prevê que o prazo de apresentação se estende até um ano da data de saque (LUG, art. 34), seguindo-se, com a recusa, a necessidade de protesto no prazo legal.

2.9. Ação cambial

Duas são as ações cambiais: a ação direta, que pode ser intentada contra aceitante e seus avalistas, e a ação de regresso, assim chamada por se dirigir contra todos os demais coobrigados: sacador, endossantes e seus avalistas.

A primeira delas – ação direta – pode ser promovida pela via executiva com a simples exibição da letra de câmbio e do demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, nos termos dos arts. 784, I, 798, I e II, do Código de Processo Civil de 2015.

A segunda – ação de regresso – exige, além dos requisitos mencionados, a juntada de certidão de protesto tirado no prazo legal, isto é, num dos dois dias úteis seguintes à apresentação do título para pagamento.

A única exceção ocorre nos títulos em que se inscreveu a cláusula “sem protesto”, em que o portador terá de demonstrar a recusa e o fato de ter dado aviso da falta de pagamento a todos os signatários da letra atingidos pela cláusula. A extensão dos efeitos da cláusula “sem protesto”, “sem despesas” ou equivalente varia de acordo com a autoria de sua inscrição no título: se o ato emana do sacador, abrange todos os signatários; se quem clausulou foi outro signatário, só produzirá efeito em relação a ele, ou seja, o ato de protesto para o exercício da ação somente é dispensado em relação a este avalista ou endossante (LUG, art. 46).

A exigência de juntar o instrumento de protesto visa cumprir a regra cambial segundo a qual depois de expirados os prazos para a apresentação: (a) de uma letra à vista ou a certo termo da vista, (b) para tirar o protesto por falta de aceite ou de pagamento ou, ainda, (c) para a apresentação a pagamento nos títulos com cláusula “sem protesto”, o portador perde o direito de ação contra todos os signatários, à exceção do aceitante e seus avalistas (LUG, art. 53). Como se percebe, todas as hipóteses de perda de prazo acima mencionadas, à exceção da última (perda do prazo

para apresentação de título com cláusula sem protesto) somente se comprovam pelo ato de protesto.

Nestes casos, portanto, a juntada do instrumento de protesto é requisito indispensável à propositura da ação contra os signatários da letra.

O autor da ação cambial pode, num mesmo processo, pretender a execução de um, alguns ou todos os signatários da letra que, nessa condição, respondem solidariamente pela dívida toda. Pode pretender agir diretamente contra o aceitante e outros endossantes devedores de regresso; cuidará, então, de apresentar a certidão de protesto, sempre que necessário, isto é, se um dos executados não for o aceitante, nem tenha dispensado o protesto.

a) Defesas

A principal característica da ação cambial é a limitação das defesas a três matérias, conforme decorre do art. 51 da Lei Saraiva:

- Direito pessoal do executado contra o exequente.
- Defeito de forma do título.
- Ausência de requisito necessário ao exercício da ação.

A primeira forma de defesa pode exigir a dilação probatória, isto é, a realização de prova em Juízo, requerida pelo devedor em sua defesa, verdadeira ação denominada embargos do devedor, oferecida no prazo de até quinze dias da juntada aos autos de execução do mandado de citação.

b) Direito pessoal e princípio da inoponibilidade das exceções pessoais contra portador de boa-fé

Alegando a existência de direito pessoal contra o exequente, o devedor embargante deverá demonstrar a ocorrência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva das obrigações, como pagamento, novação, compensação com execução aparelhada, transação ou prescrição. Exemplo de causa extintiva das obrigações é o desfazimento de compra e venda que deu origem ao título ou, de causa modificativa, o pagamento ou compensação parcial, alterando o valor original do título. Qualquer causa que

implique esse reconhecimento deve decorrer de vínculo jurídico entre o executado e o exequente.

Oposições do devedor com outro signatário não podem ser objeto de defesa em relação ao portador de boa-fé. Isto decorre da aplicação da regra cambial básica, prevista no art. 17 da Lei Uniforme: “As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor”.

c) Defeito de forma do título e ausência de requisito necessário ao exercício da ação e exceção de pré-executividade

As duas outras alegações permitidas – defeito de forma do título e ausência de requisito necessário ao exercício da ação – ensejam, muitas vezes, soluções unicamente de direito e, nesses casos, o devedor pode valer-se de procedimento menos complexo que os embargos de devedor: a exceção de pré-executividade, também conhecida por objeção de não executividade. Consiste em suscitar em Juízo, mesmo sem a garantia pela penhora ou do depósito, o exame de matéria que o magistrado deva conhecer de ofício, isto é, a que o Judiciário é obrigado a indagar mesmo quando uma das partes litigantes não as apresente em suas petições. São questões relacionadas, entre outras, à nulidade do título, por falta de liquidez ou de exigibilidade.

Note-se que, para exercer a ação executiva, o credor deve apresentar o título original, somente se admitindo a cópia quando tirada na forma do art. 67 da Lei Uniforme, o que é de rara ocorrência. Em segundo lugar, a letra deve ostentar todos os requisitos extrínsecos ligados à validade da forma, bem como estar livre de defeitos – requisitos intrínsecos – que comprometam a constituição do crédito e a circulação do título, como, por exemplo, a falsidade da assinatura do executado e a ausência de poderes para obrigar o executado. E, finalmente, deve ser exigível, ou seja, não estar prescrito, nem ter ocorrido a perda do direito contra o executado, por falta de apresentação ou protesto no prazo devido.

As questões relacionadas aos defeitos da cártula, seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, e à sua exequibilidade são defesas que independem de causa pessoal que vincule os litigantes.

É possível encontrar na jurisprudência exemplos de acolhimento de alegações de exceção de pré-executividade: ausência de título (p. ex., TJSP, Apel. 1007009-52.2013.8.26.0127, rel. Des. Paulo Pastore Filho, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 1º-9-2017) e falta de higidez do título ou de eficácia executiva entre outros. Em todos esses casos entendeu-se possível o exame por simples petição nos autos, sem a necessidade de propositura de embargos de devedor, por se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz.

Nem sempre, contudo, o defeito de forma e a ausência de requisito necessário ao exercício de ação permitirão o exercício dessa objeção de não executividade porque podem depender de realização de prova, impedindo ao magistrado o conhecimento desde logo. Nesses casos, a oposição do devedor somente poderá ser apreciada em embargos do devedor.

d) Prescrição

Prescrição, segundo Clóvis (1975, 1:435), é “a perda da ação atribuída a um direito, de toda a sua capacidade defensiva em consequência do não uso delas, durante um determinado espaço de tempo”. A ação cambial prescreve em períodos distintos em relação aos diferentes signatários da letra:

CREDOR	DEVEDOR	PRAZO	FUNDAMENTO LEGAL
Qualquer signatário: portador, endossantes e avalistas, sacador e avalistas	Aceitante e seus avalistas	3 anos a contar do vencimento	LUG, art. 70, § 1ª
Portador	Endossantes e seus avalistas	1 ano a contar do protesto feito em tempo útil 1 ano a contar da data de vencimento	LUG, art. 70, § 2ª

	Sacador e seus avalistas	quando houver cláusula “sem protesto”, “sem despesa” ou equivalente	alínea
Endossantes	Endossantes Sacador	6 meses do dia em que pagou a letra ou 6 meses do dia em que foi acionado	LUG, art. 70, 3ª alínea

e) Ações causais

Além da ação cambial, de cunho executivo, com defesa limitada às matérias acima mencionadas, o portador poderá fazer uso de outra ação, de rito ordinário, em que buscará a condenação do devedor a restituir, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à sua custa. Trata-se da ação de locupletamento injusto, também conhecida por enriquecimento indevido ou ilícito, prevista no art. 48 da Lei Saraiva que foi preservada por força do art. 15 do Anexo II da Convenção de Genebra:

“Qualquer das Altas Partes Contratantes tem a liberdade de decidir que, no caso de perda de direitos ou de prescrição, no seu território subsistirá o direito de proceder contra o sacador que não constituir provisão ou contra um sacador ou endossante que tenha feito lucros ilegítimos. A mesma faculdade existe, em caso de prescrição, pelo que respeita ao aceitante que recebeu provisão ou tenha realizado lucros ilegítimos”.

Pontes de Miranda (2000, 1:572) elucida a razão jurídica de sua criação: “A ação de enriquecimento injustificado cambiária foi criada principalmente para o caso de prescrição da ação cambiária específica, que é a executiva [...]”.

Neste caso há uma amplitude tanto nas alegações do autor como na defesa porque o que se alega é a existência de uma situação que tenha causado prejuízo ao portador. Os pressupostos são: a existência de dano e o enriquecimento do devedor, que se consumam pela prescrição da ação executiva, sem pagamento do título.

A doutrina discute o prazo de prescrição, entendendo alguns (p. ex., Emygdio Rosa Jr., 2007:470) que a ação de locupletamento injusto prescreve em 3 (três) anos a partir da data em que se consumou a perda do direito à ação de execução e se rege pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Outros (p. ex., Pontes de Miranda, 2000 1:573), aos quais nos incluímos, perfilam o entendimento de que sua previsão

encontra-se na Lei Saraiva e, como tal, rege-se pelo art. 52 desse diploma e no prazo de cinco anos, contados da data em que prescreveu a ação de execução cambiária.

A ação deve ser movida exclusivamente contra o aceitante ou, se não aceito o título, contra o sacador. Os avalistas de um e de outro não estão legitimados passivamente porque, como explica Pontes de Miranda (2000, 1:577), sua posição jurídica “é estranha ao saque, ainda quando se trate do avalista do sacador”.

f) Ação monitória

Se houve perda do direito de ação – por ocorrência da prescrição, por exemplo –, o portador pode valer-se, ainda, de outro procedimento de ampla utilização: a ação monitória, preferida por ser mais célere que a ação ordinária. O credor deve apresentar com a inicial o título que perdeu a eficácia executiva ou qualquer documento escrito, público ou privado que justifique o direito à satisfação de uma determinada soma em dinheiro (CPC15, arts. 700 e seguintes).

Define-se ação monitória como instrumento processual que tem por fim obter a expedição de mandado executivo a favor de quem, dispondo de prova escrita, sem eficácia de título executivo, pretende pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é de cinco anos o prazo de prescrição para a ação monitória fundada em título de crédito. Esse prazo inicia-se no dia seguinte ao do vencimento do título.

Veja-se nesse sentido o entendimento do STJ: a) Súmula 503: “O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula”; b) Súmula 504: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.

Capítulo 3

NOTA PROMISSÓRIA

Sumário: 3.1. Origens. 3.2. Conceito. 3.3. Requisitos da nota promissória. 3.3.1. Requisitos essenciais. 3.3.2. Preenchimento de nota incompleta. 3.3.3. Requisitos não essenciais. 3.3.4. Rigor formal. 3.4. Direito aplicável - regras compatíveis. 3.5. Ação cambial e vinculação a contrato.

3.1. Origens

A nota promissória é tratada pelas legislações brasileira e uniforme de forma secundária à letra de câmbio. Tratam dela os arts. 54-56 do Decreto n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908 (Lei Saraiva – LS) e os arts. 75-78 do Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966 (Lei Uniforme – LUG). Significa dizer que o legislador pátrio e o unionista regulamentaram extensamente a letra de câmbio (arts. 1º a 55 da LS e arts. 1º a 74 da LUG) para, ao final, em breve capítulo contendo três artigos, discorrerem sobre sua distinta criação e remessa à aplicação de um regime comum na maior parte das matérias.

Aplicam-se, pois, para as notas promissórias o regime comum das letras de câmbio, salvo no que se refere à criação do título e outras poucas alterações, em razão de incompatibilidade com sua natureza ou porque a legislação provê regramento diverso.

Embora este seja o quadro legislativo, as origens dos títulos diferem. Hunt e Murray (2001:333-334) informam que a nota promissória nasceu como instrumento de crédito mais eficiente para as operações a curto prazo e seu desenvolvimento e aperfeiçoamento se deram no eixo comercial Londres-Antuérpia, independentemente da evolução da letra de câmbio:

“Este estratagema era uma promessa escrita de pagamento de uma certa soma em

determinada altura, a qual passava de detentor em detentor como forma de pagamento de dívidas. As promissórias já tinham sido utilizadas no comércio de lã desde um período anterior a 1400, mas eram principalmente utilizadas entre mercadores ingleses, os quais podiam contar com tribunais ingleses para garantir seus direitos. Estas promissórias ao portador tornaram-se bastante populares em Antuérpia e obtiveram um reconhecimento oficial em 1507, altura em que os magistrados desta cidade oficializaram explicitamente que os detentores de uma promissória, independentemente do número de vezes que esta tivesse mudado de mãos, detinham os mesmos direitos legais que o detentor original. Este parecer foi confirmado para todas as partes dos Países Baixos através de um decreto imperial em 1537. Na mesma altura, as letras de câmbio começaram, em Antuérpia, a incluir a nota ‘ou ao detentor desta letra’, adquirindo, deste modo, as mesmas características que as promissórias; por volta de 1541 tinham, judicialmente, atingido o mesmo estatuto que as promissórias”.

A evolução de cada um desses dois títulos cambiais igualmente não se deu de forma idêntica. Pontes de Miranda (2000, 2:40-41) afirma que a assimetria evolutiva de uma e outra decorre das condições económicas e dos hábitos: “Em certos povos, aos negócios bastam as notas promissórias, só se recorrendo às letras de câmbio para as relações de comércio exterior. É o caso da Rússia, pré-soviética e soviética. Não é o dos outros estados europeus de intercâmbio interestatal intenso, ou de comércio interno, de praça a praça, de alta monta e principal função na vida económica e financeira. A letra de câmbio passa à frente, sem que a nota promissória perca o seu papel cambiário”.

Há quem veja na praticidade de criação da nota promissória vantagens sobre a letra de câmbio, em razão de dispensar o mecanismo do aceite e, por isso, é amplamente utilizada nos mútuos de dinheiro (cf. Eunápio Borges, citado por Waldirio Bulgarelli (1996:221)).

3.2. Conceito

Mais marcante é a distinção conceitual dos institutos, daí decorrendo as diversas

formas de criação formal de um e de outro título.

Letra de câmbio é ordem de pagamento, à vista ou a prazo. Nota promissória é promessa escrita de pagamento de certa soma em dinheiro. Aquele que emite uma nota promissória afirma que é devedor de outrem e promete pagar-lhe a quantia inserta no título, em determinado tempo.

Nasce, pois, a nota promissória com a assinatura do devedor, razão pela qual não se lhe aplicam as regras relativas ao aceite, instituto típico da letra de câmbio. O aceite, como vimos no Capítulo 2 (item 2.5.2), é o ato de vontade materializado pela aposição de assinatura no título, mediante a qual o sacado concorda com a ordem do sacador, tornando-se o principal responsável da quantia expressa na letra de câmbio na data de seu vencimento.

É desde o saque que os títulos distinguem-se: na letra de câmbio o sacador dá ordem para que outrem pague; na nota promissória o sacador promete pagar a alguém. No primeiro título, o devedor principal é o aceitante, não o sacador; no segundo, o devedor principal é o próprio sacador, também chamado emitente ou subscritor, preferindo a legislação brasileira o primeiro termo (LS, art. 54, IV) e a legislação uniforme, o segundo (LUG, art. 75, 7).

3.3. Requisitos da nota promissória

O estudo dos requisitos formais envolve três questões: a dos requisitos essenciais; a da nota promissória emitida em branco ou de forma incompleta e a das indicações não essenciais.

3.3.1. Requisitos essenciais

São requisitos essenciais da nota promissória:

- a) A denominação¹⁴ “nota promissória”, inserta no próprio texto do título e expressa na língua em que for emitida (LUG, art. 75, 1, e LS, art. 54, I);
- b) A promessa “pura e simples”, isto é, sem nenhuma condição, de pagar uma quantia determinada (LUG, art. 75, 2, e LS, art. 54, II);
- c) O nome da pessoa ou a ordem de quem deve ser paga, isto é, o tomador ou

beneficiário (LUG, art. 75, 5, e LS, art. 54, III);

d) A assinatura do emitente ou seu procurador com poderes especiais (LUG, art. 75, 7, e LS, art. 54, IV). A lei brasileira exige que a assinatura seja lançada “abaixo do contexto” (art. 1º, V), exigência que não foi amparada pela Lei Uniforme, daí por que Fran Martins (2010:85) entende que o sacador pode lançar a assinatura “no contexto ou fora dele”. Reflita-se, contudo, que, por ser a letra de câmbio expressão de um comando (“Pagará V.Sª...”), a assinatura deve posicionar-se em limite espacial que indique o arremate, desfecho, desse comando e, portanto, logo após a redação cambial. Contudo, ao lado de Fran Martins, há jurisprudência entendendo que possa ser lançada no verso ou no anverso do título, sendo mais comum esta segunda modalidade¹⁵. Observe-se, ainda, que a Lei Uniforme não exige mandatário com poderes especiais, mas a jurisprudência firmou-se no sentido de atender à regra da Lei Saraiva e, assim mesmo, de forma mitigada visando abrandar eventuais abusos na contratação:

“Título cambial emitido com fundamento em cláusula de contrato de abertura de crédito. Artigo 115 do Código Civil. A nota promissória pode, em tese, ser emitida por mandatário com poderes especiais. Todavia, por vulneração ao art. 115 do Código Civil, é inválida a cambial emitida com base em mandato de extensão não especificada, outorgado pelo devedor em favor de empresa integrante do mesmo grupo financeiro a que pertence a instituição credora. Conflito efetivo de interesse entre representante e representado. Tema do contrato consigo mesmo, abordado no REsp n. 1.294, acórdão da 3ª Turma deste STJ. Recurso especial conhecido pela alínea c, mas não provido. Votos vencidos” (REsp n. 2.453/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Rel. para o acórdão Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, j. 9-4-1991 *DJ*, 10-6-1991, p. 7851). No mesmo sentido: REsp n. 19.165/MG, Rel. Min. Athos Carneiro, Quarta Turma, j. 1º-9-1992, *DJ*, 21-9-1992, p. 15696.

e) A indicação da data em que é passada (LUG, art. 75, 6). Não é demais lembrar a importância deste requisito e que foi objeto de estudo no Capítulo 2 (item 2.3.7): (1) a partir da data inserta no título o sacador obriga-se cambialmente; (2) é o dado que permite verificar tanto a capacidade do sacador no momento da emissão do título

como também do mandato e, para as emitidas por pessoas jurídicas, a regularidade da representação; (3) disciplina o regime jurídico aplicável, na ocorrência de mudanças legislativas que impliquem alterações em aspectos formais do título; (4) a data do saque por sociedade em que há sócios com responsabilidade ilimitada e solidária – como ocorre naquelas formadas em nome coletivo e em comandita (simples e por ações) – permite saber se a dívida foi constituída antes ou depois da retirada do sócio para efeito de sua responsabilização, nos termos do art. 81 da Lei de Falências¹⁶; (5) possibilita documentar fatos que possam ter relevância em eventual oposição a portador, como, por exemplo, os que impedem a compensação de créditos em massa falida.

f) A indicação do lugar onde é passada¹⁷ (LUG, art. 75, 6). Valerá como equivalente o lugar designado ao lado do nome do subscritor (LUG, art. 76, último parágrafo).

Se iniciada a cobrança sem o preenchimento dos requisitos essenciais ou, quando indicado pelo legislador nos dois últimos casos, do mencionado equivalente, a nota é considerada inexistente, podendo, contudo, valer como princípio de prova. Entretanto, se contiver pelo menos a assinatura do emitente é prova escrita sem eficácia de título executivo, apto a fundamentar pedido monitório nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil de 2015.

Os requisitos essenciais podem ser objeto de decisão de ofício pelo magistrado, porque referem-se à própria condição da ação de execução¹⁸, daí por que, havendo irregularidade formal que comprometa a higidez desses requisitos, não percebida pelo juiz da execução, permite-se ao devedor suscitar objeção de não executividade¹⁹.

3.3.2. Preenchimento de nota incompleta

A lei brasileira (LS) permite que o preenchimento dos dois últimos requisitos possa ser feito pelo portador do título (art. 54, § 1º), solução que a jurisprudência adotou, com a observação de que a complementação de qualquer requisito se faça por credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto do título (Súmula 387 do STF).

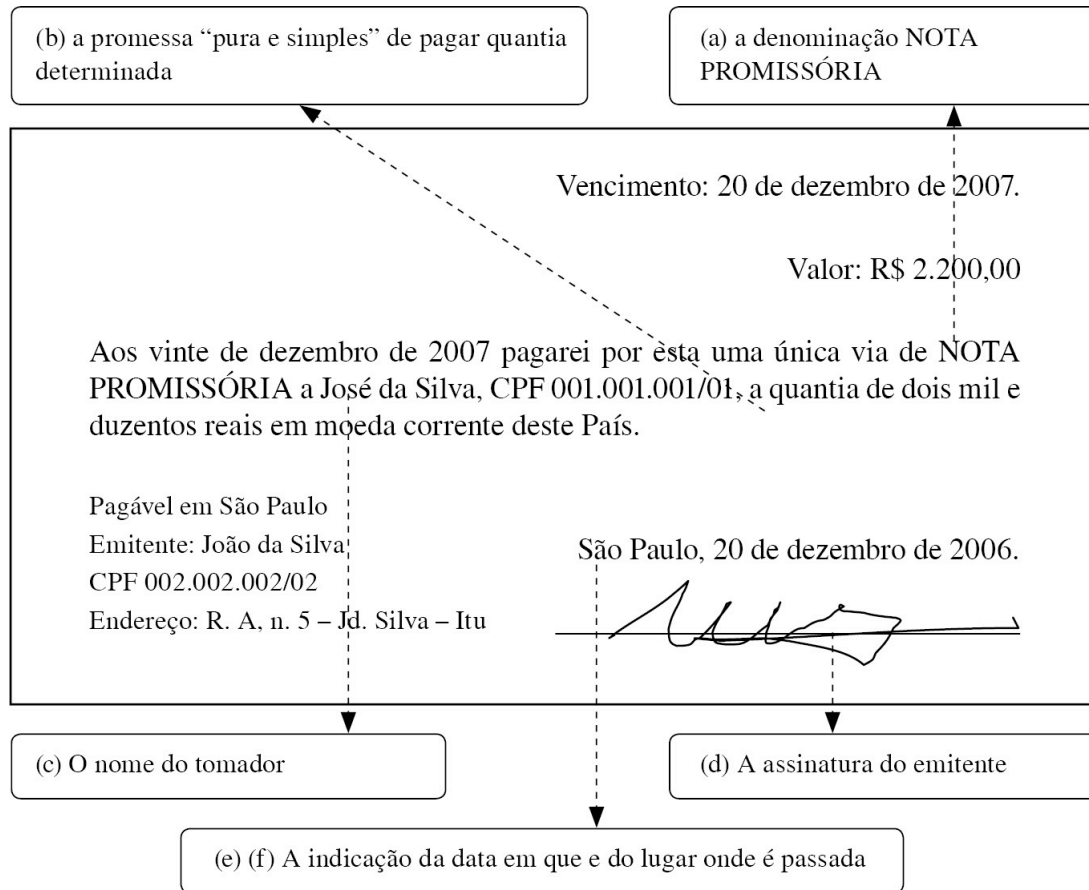
3.3.3. Requisitos não essenciais

A Lei Uniforme acrescenta, ainda, a época do pagamento (LUG, art. 75, 3) e a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento (LUG, art. 75, 4), não impondo pena de ineficácia ao título que omitir tais requisitos. São, portanto, requisitos não essenciais.

Para sanar a ausência da indicação da época de pagamento o legislador preferiu impor à nota promissória a qualidade de vencível à vista (LUG, art. 76, segundo parágrafo, e LS, art. 54, § 2º). À nota que não trouxer o lugar de pagamento a lei determina que se considere o lugar do saque como sendo tanto de pagamento como de domicílio do subscritor (LUG, art. 76, terceiro parágrafo). Nesse aspecto difere a Lei Saraiva que escolheu o domicílio do emitente como lugar de pagamento (art. 54, § 2º).

3.3.4. Rigor formal

A descrição do rigor formal pode ser representada graficamente:



3.4. Direito aplicável – regras compatíveis

Os arts. 77 e 78 da Lei Uniforme traçam as regras de ajuste da nota promissória ao regramento comum às letras de câmbio.

Em primeiro lugar aplicam-se às notas promissórias as disposições relativas às letras que não forem incompatíveis com sua natureza, no tocante:

- (a) às disposições relativas às letras pagáveis no domicílio de terceiro ou numa localidade diversa da do domicílio do sacado (arts. 4º e 27);
- (b) à estipulação de juros (art. 5º);
- (c) às divergências nas indicações da quantia a pagar (art. 6º);
- (d) às consequências da aposição de uma assinatura nas condições indicadas no art. 7º;
- (e) às da assinatura de uma pessoa que age sem poderes ou excedendo os seus poderes (art. 8º);

(f) às da letra em branco (art. 10);

(g) ao endosso (arts. 11 a 20);

(h) ao aval (arts. 30-32), com observação quanto à não indicação da pessoa por quem é dado, entendendo-se que se deu ao subscritor da nota promissória e ajustando a redação do art. 31 para equiparar a posição do sacador da letra de câmbio ao do emitente da nota promissória;

(i) ao vencimento (arts. 33 a 37);

(j) ao pagamento (arts. 38 a 42);

(k) ao direito de ação por falta de pagamento (arts. 43 a 50 e 52 a 54);

(l) ao pagamento por intervenção (arts. 55 e 59 a 63);

(m) às cópias (arts. 67 e 68);

(n) às alterações (art. 69);

(o) à prescrição (arts. 70 e 71);

(p) aos dias feriados, contagem de prazos e interdição de dias de perdão (arts. 72 a 74).

Alguns ajustes vêm expressos no próprio texto legislativo, como ocorre com o aval: “no caso previsto na última alínea do art. 31, se o aval não indicar a pessoa por quem é dado, entender-se-á pelo subscritor da nota promissória” (LUG, art. 77, último parágrafo). Outros decorreram de simples regra de interpretação lógica. No endosso, por exemplo, não há que aplicar a expressão do art. 15 quanto ao “endossante garantir tanto a aceitação como pagamento da letra”, porque na nota promissória não há o mecanismo de aceite. A leitura fica reduzida ao texto que trata do pagamento da letra: “O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante do pagamento da nota promissória”.

Em segundo lugar, a própria lei estipulou em dois casos tratamentos distintos ao regime da letra de câmbio, causando alguma perplexidade. É o que ocorre com o vencimento do título, conforme bem anotam Fábio Ulhoa Coelho (2016:436), Frar Martins (2010:270) e Waldirio Bulgarelli (1996:222-223).

A letra de câmbio pode ser emitida “a certo termo da vista”, o que significa “a certo tempo da apresentação para aceite”. Não existindo aceite, porque o subscritor é o devedor principal e é quem faz a promessa de pagamento, a conclusão lógica *seria* a impropriedade de emissão de nota promissória a certo termo da vista e, ainda, a inaplicabilidade dos arts. 22, 35, 36 e outros que tratam do aceite. Contudo, o art. 78 da Lei Uniforme, em seu segundo parágrafo, inexplicavelmente, traz regra aplicável às notas promissórias com vencimento a certo termo da vista e estabelece forma distinta da consideração dessa expressão, não mais significando “da data de apresentação para o aceite”, mas “da data do visto dado pelo subscritor”, cuja recusa será comprovada por protesto. Da data do protesto conta-se o início do termo fixado para o vencimento.

Com acuidade Fran Martins (2010:270-272) observa: “A estranheza que nos causa essa modalidade de vencimento da nota promissória se deve ao fato de, na letra de câmbio a certo tempo da vista, o *aceite* do sacado englobar o *visto*, dispensando-o. Mas, na realidade, *aceite* e *visto* são dois atos de natureza diversa, o primeiro significando a disposição do sacado de cumprir ordem que lhe é dada pelo sacador, tornando-se, com a sua assinatura, o obrigado principal pelo pagamento do título, e o segundo dizendo respeito ao início do prazo findo o qual a obrigação assumida com o aceite deve ser cumprida, ou seja, esgotado o qual o título deve ser pago. Em resumo: *o aceite* representa a assunção da obrigação de pagar por parte do sacado; *o visto* marca o início do prazo determinado o qual aquela obrigação deve ser cumprida” (...) “Representa o visto, pura e simplesmente, o início do prazo para o vencimento da letra. E se por acaso esse visto, posteriormente, for negado, ou dado sem data, cabe ao portador protestar o título por *falta de visto* ou *de data*, não acarretando esse protesto o vencimento do título, mas marcando o início do prazo findo o qual a promissória será considerada vencida, como ocorre com o protesto por falta do aceite nas letras de câmbio a certo termo da vista”.

O segundo caso de tratamento distinto refere-se à regra do art. 78: “O subscritor de uma nota promissória é responsável da mesma forma que o aceitante de uma letra”.

Neste caso, a falência do emitente da nota promissória produz o vencimento

antecipado (LUG, arts. 43-44), conforme também decorre do art. 77 da Lei Falimentar (Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005), podendo o portador executar individualmente os coobrigados e, concomitantemente, habilitar o crédito na falência do subscritor.

Do mesmo modo, a ação contra o subscritor da nota promissória prescreve em três anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea 1), se considerada a primazia da Lei Uniforme sobre a Lei Brasileira²⁰, ou cinco anos, se adotada a posição de Fran Martins que aplica a regra do art. 52 da Lei Saraiva.

Na letra de câmbio decorrem inúmeras consequências quando ausente o protesto obrigatório no prazo legal, sendo a mais importante a perda do direito de ação contra os coobrigados, à exceção do aceitante e seu avalista (LUG, art. 53, alínea 1ª). Por equiparação determinada pelo art. 78 da Lei Uniforme, esses mesmos efeitos ocorrem em relação ao subscritor da nota promissória e seu avalista, isto é, a falta de protesto não conduz à perda do direito de ação contra ambos²¹.

3.5. Ação cambial e vinculação a contrato

A matéria relativa às ações cambiais foram objeto de estudos no Capítulo 2 (item 2.9). Subsiste, contudo, a análise da nota promissória vinculada a contrato e seus efeitos cambiários.

A jurisprudência tem entendido que as discussões acerca das causas contratuais que deram origem ao título irradiam sobre ele seus efeitos e, assim, a deficiência ou inadimplemento contratual repercute sobre a nota promissória que a ele se vincula.

É possível, portanto, nesses casos, discutir o negócio subjacente em qualquer procedimento judicial, isto é, no curso de ação de execução, de ação de cobrança ou monitória. Há de se atentar que o título acompanhará a mesma sorte do contrato ao qual se encontra vinculado desde o nascedouro. Tornando-se ilíquido o contrato, o título também o será. Por esta razão, os Tribunais têm entendido que a perda da exigibilidade do contrato implica necessariamente perda da exigibilidade pela via executiva²².

Capítulo 4

CHEQUE

Sumário: 4.1. Conceito, natureza jurídica e características. 4.2. Origens do cheque. 4.3. Legislação e regime jurídico do cheque. 4.4. Criação do cheque – requisitos. 4.5. Revogação e oposição. 4.6. Circulação do cheque. 4.7. Pluralidade de exemplares e alterações no texto do cheque. 4.8. Formas de lançamento e modalidades de endosso. 4.9. Aval no cheque. 4.10. Inoponibilidade das exceções pessoais. 4.11. Modalidades de emissão. 4.12. Apresentação, pagamento e prescrição. 4.13. Ações judiciais.

4.1. Conceito, natureza jurídica e características

Cheque é ordem de pagamento à vista, emitida por pessoa física ou jurídica, em favor próprio ou de terceiro, contra instituição bancária ou financeira que lhe seja equiparada, com a qual o emitente mantém contrato que a autorize a dispor de fundos existentes em conta corrente.

Caracteriza-se o cheque por ser título (a) executivo, (b) formal, (c) autônomo, (d) de prestação em dinheiro.

a) Título executivo

É título executivo porque o possuidor pode promover ação de execução visando receber a prestação indicada pelo emitente. Dispõe o art. 47 da Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985, que o portador pode promover a execução do cheque (I) contra o emitente e seu avalista e (II) contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa do pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

De forma harmoniosa com essa disposição, o Código de Processo Civil o qualifica como título executivo extrajudicial, ao lado da letra de câmbio, da nota promissória,

da duplicata, da debênture (art. 784, I) e de outros documentos.

Dizer que um título dispõe de executividade significa afirmar que seu portador possui um meio judicial célere para exigir o cumprimento da obrigação em dinheiro nele representada e que esse título possui liquidez, certeza e exigibilidade.

Líquida, segundo o art. 1.533 do Código Civil de 1916, é a “obrigação certa, quanto à existência, e determinada quanto a seu objeto”.

A certeza da obrigação contida no cheque é apreciada a partir do exame dos pressupostos formais do *título original*, isto é, aqueles que necessariamente devem estar presentes e encontram-se discriminados nos arts. 1º e 2º da Lei n. 7.357 (Lei Uniforme Relativa ao Cheque – LC), de 2 de setembro de 1985:

I – a denominação “cheque” inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;

II – a ordem incondicional de pagar quantia determinada;

III – o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

IV – a indicação do lugar de pagamento;

V – a indicação da data e do lugar da emissão;

VI – a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma da legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.

Art. 2º O título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I – na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II – não indicando o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar

indicado junto ao nome do emitente.

Afirma-se que esse exame quanto à certeza se dá *sobre o título original* porque somente se admite a execução se apresentado o original do cheque, caso contrário haveria dúvida quanto ao detentor de sua posse²³, em razão da sua capacidade de circulação, por endosso ou mera tradição.

A liquidez refere-se à determinação do valor do título que, no caso do cheque, vem expresso no documento. É possível, entretanto, que, em razão do decurso de prazo entre a emissão e a cobrança, se faça necessária realização de cálculo aritmético para a atualização de seu valor, operação que não desfigura sua liquidez, conforme se extrai do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e encontra-se assentado em jurisprudência: “O título executivo não se desnatura quando, para se encontrar o seu valor, se faz necessário simples cálculo aritmético, com a inclusão de encargos previstos no contrato e correção monetária, bem como com o abatimento dos pagamentos parciais” (STJ, REsp n. 78.658/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 5-5-1998). Mais recentemente encontramos: “Em caso de contrato de crédito fixo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de considerá-lo título executivo extrajudicial (art. 585, II, do CPC), na medida em que ele se constitui verdadeiro mútuo de importância determinada. O valor do principal da dívida é demonstrável de plano, sendo sua evolução aferível por simples cálculos aritméticos, diferentemente do que ocorre no contrato de abertura de crédito em conta-corrente” (AgRg no REsp n. 1.233.423/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16-2-2012, DJe 24-2-2012).

A exigibilidade do título implica considerar se o título está presentemente sujeito a condição ou a termo, isto é, se o exercício do direito de execução encontra-se no aguardo da ocorrência de evento futuro e incerto (condição, art. 121 do Código Civil) ou a limite temporal estabelecido no próprio título (termo, art. 131 do Código Civil).

Em regra, não se pode fixar termo ou condição na criação do cheque, porque o cheque é pagável à vista e se considera não escrita qualquer menção em contrário (LC, art. 32), observando-se que mesmo o cheque pós-datado deve ser pago no dia da apresentação (parágrafo único do mesmo art. 32).

b) Título formal

Além da executividade, caracteriza-se o cheque por ser título formal; sua emissão se dá em modelo-padrão, em papel fornecido pela instituição sacada, segundo normas fixadas pelo Banco Central do Brasil. Os requisitos formais da emissão encontram-se nos arts. 1º e 2º da Lei do Cheque, que serão objeto de estudos no tópico “criação do cheque – requisitos” (item 4.4) logo adiante.

O cheque, como outros títulos de crédito, pode conter disposições de vontade sucessivas e, conseqüentemente, de obrigações consecutivas (2000, 4:41). Destarte a emissão a favor de alguém se refere à disposição de vontade distinta da que há entre os endossantes e os endossatários que se sucederem na posse e transmissão do título. Haverá novas e sucessivas obrigações a cada ato de circulação do título.

c) Título autônomo

Por abstração entende-se que o possuidor atual do cheque dispõe de direito próprio, não vinculado à relação jurídica que lhe deu origem, isto é, o título que possui não se corrompe ou se nulifica com as causas anteriores que envolveram as relações jurídicas entre os possuidores precedentes.

Com esse entendimento, admitem-se, em defesa de devedor fundada em direito pessoal, tão somente, as que se reportem à relação que tenha contra o portador, não podendo invocar (ou opor) causas havidas em relações jurídicas de que este não participou. Trata-se do que a doutrina denominou inoponibilidade de exceções pessoais contra terceiros de boa-fé.

A defesa fundada em direito *pessoal* é, como seu nome diz, defesa de *certo* réu contra *um certo* autor e pressupõe que exista, nas relações entre o réu e o autor da ação, motivo suficiente para que a obrigação não seja cumprida, como, por exemplo, ocorre com a compensação. Nesta hipótese, quando “duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” (CC, art. 368). Evidente que não há como invocar essa causa entre o emitente e o primeiro beneficiário do cheque se o título se encontra em mãos de

terceiro, endossatário do título.

Esses dois preceitos – abstração e a inoponibilidade de exceções pessoais contra os terceiros de boa-fé – são classificados por Fábio Ulhoa Coelho (2016:382) como subprincípios de um princípio maior, o da autonomia, conforme explica o docente da PUC-SP: “pelo princípio da autonomia das obrigações cambiais, os vícios que comprometem a validade de uma relação jurídica, documentada em título de crédito, não se estendem às demais relações abrangidas no mesmo documento”. A abstração e a inoponibilidade²⁴ referem-se à libertação da nova relação decorrente do endosso da causa que deu origem ao título e aos limites da possibilidade de defesa por parte do devedor.

Figure-se o seguinte exemplo: Ana adquire produtos em supermercado e paga sua compra com cheque de sua emissão no valor de R\$ 600,00. O gerente do supermercado transmite o cheque, por endosso, ao fornecedor de seus produtos e este, por sua vez, dá em pagamento de matérias-primas que adquiriu de produtor agrícola. Colocado em cobrança, o cheque volta sem fundos e Ana, em ação de execução promovida pelo produtor agrícola, invoca a existência de compensação, decorrente de crédito que possui no supermercado.

Verificam-se, nesse exemplo, as autonomias do título em relação às obrigações precedentes: (a) a primeira obrigação decorre de relação entre a consumidora e o supermercado; (b) a segunda refere-se aos negócios entre o supermercado e seu fornecedor e (c) a terceira, aos negócios deste último com o produtor agrícola.

Em decorrência dessa autonomia segue-se, igualmente, no caso de transmissão do título, sua libertação quanto à relação jurídica que lhe deu origem. É a abstração do título que conduz, necessariamente, à impossibilidade de a emitente do cheque (Ana no caso) invocar contra o terceiro (produtor agrícola) fatos que viciaram sua relação com o supermercado. Ela não se exonera porque o título é autônomo quanto às obrigações dele geradas e se reconhece haver abstração quanto à relação que lhe deu origem.

d) Pagamento em dinheiro

O cheque traz sempre obrigação de prestação em dinheiro, representando quantia certa, não se prestando a contratar pagamento de coisa infungível ou certa coisa.

4.2. Origens do cheque

A origem do cheque coincide com a história da letra de câmbio, sendo incontroverso que ambos fincam raízes em outros documentos de ordens de pagamento que circularam entre os mercadores na Idade Média²⁵.

Não se sabe, contudo, a quem atribuir a primazia pela criação do instituto jurídico tal como o concebemos nos dias de hoje.

Rubens Requião sustenta que a Inglaterra é o berço do cheque, o qual, em sua origem, teria sido concebido como uma variante da letra de câmbio e, assim, definido como letra de câmbio à vista, sacada sobre um banqueiro (1995, 2:386).

Pontes de Miranda (2000, 4:43-44) contesta e afirma que se deve atribuir aos banqueiros holandeses e aos ourives ingleses, na emissão das *goldsmiths notes*, a criação dos livros de cheque, salientando, contudo, que “os títulos que emitiam eram mais bilhetes de banco do que cheques”, completando: “Com a criação do Banco da Inglaterra, em 1694, abriu-se nova era aos negócios jurídicos bancários, mas o cheque, propriamente dito, não nasceu então. A Lei de 1742 dera ao Banco da Inglaterra o monopólio dos bilhetes pagáveis à vista ou ao portador; surgiu o cheque, mediante expediente que fugisse à lei monopolizante: em vez de se emitirem bilhetes pagáveis à vista ou ao portador, os banqueiros de Londres inscreviam o crédito dos clientes e entregavam a esses caderninhos, contendo fórmulas, que os credores enchiam. A diferenciação foi, portanto, entre o bilhete de banco e o cheque, e não entre a cambial e o cheque. A diferenciação entre o título cambiário e o cheque foi solução técnica portuguesa, em 1833”.

É possível, portanto, traçar, em breves palavras, a evolução do instituto jurídico no Velho Continente: de sua origem mais remota na Holanda e nas cidades italianas, toma impulso na Inglaterra, no século XVII, estabelece conceituação mais precisa na legislação portuguesa de 1833 e, finalmente, livra-se das imposições fiscais das letras de câmbio pela lei francesa de 14 de junho de 1865, que lhe comina, ademais,

sanções penais para os abusos, tornando-se título distinto daqueles (cf. Requião, 1995, 2:386, e Pontes de Miranda, 2000, 4:51).

Seja qual for a ascendência jurídica do cheque, importante ressaltar sua identidade com certas características da letra de câmbio: ambos são ordens de pagamento e, no cenário internacional, podem ser emitidos ao portador. Distanciam-se, contudo, em outros aspectos: o cheque é sempre emitido à vista, é prestação em dinheiro e, portanto, pressupõe a existência de provisão de fundos do emitente em poder do sacado, que somente pode ser banco ou instituição financeira. A letra de câmbio pode ser emitida a prazo; é ordem de pagamento e pode ser sacada contra pessoa não integrante do sistema financeiro, empresária ou não empresária.

4.3. Legislação e regime jurídico do cheque

a) Legislação em vigor

São três os diplomas legais que tratam do cheque no Brasil: o Decreto n. 57.595, de 7 de janeiro de 1966, que promulga as convenções para adoção de uma Lei Uniforme de Cheques (LUC); a Lei n. 7.357, de 2 de setembro de 1985, mais conhecida como Lei do Cheque (LC); e o Decreto n. 1.240, de 15 de setembro de 1994 (CIMC), que promulga a Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Cheques, adotada em Montevideu, em 8 de maio de 1979.

Outras leis, regulando matéria diversa, fazem referência a certas particularidades quanto à emissão e/ou circulação dos cheques, como, por exemplo, o Decreto-Lei n. 6.895, de 23 de setembro de 1944, que dispõe sobre o pagamento por cheque à Fazenda Nacional; a Lei n. 9.069, de 29 de junho de 1995, que instituiu o Plano Real e veda a emissão de cheques ao portador em valor superior a R\$ 100,00; a Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, que regula a lavagem de dinheiro; a Lei Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001, que trata do sigilo das operações das instituições financeiras; a Lei n. 10.214, de 27 de março de 2001, que dispõe sobre a atuação das câmaras de compensação e dos prestadores de serviços de compensação e da liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro; o Decreto n. 4.296, de 10 de julho de 2002, que disciplina a não incidência da CPMF nas hipóteses de que trata

o art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Além da legislação ordinária e constitucional, há uma extensa lista de resoluções, instruções normativas, portarias e circulares do Banco Central do Brasil que tratam do mecanismo de circulação dos títulos entre as instituições financeiras, devendo ser lembrados alguns desses documentos, dada sua importância na solução de conflitos mais comuns que envolvem as operações bancárias com cheques:

- Resolução n. 885, de 22 de dezembro de 1983, que institui modelo-padrão de cheque;
- Resolução n. 2.090, de 6 de julho de 1994, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do beneficiário do cheque de valor superior a R\$ 100,00;
- Resolução n. 2.537, de 26 de agosto de 1998, que dispõe sobre procedimentos relativos ao cheque;
- Circular n. 3.226, de 18 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a prestação de serviços por parte de bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito, referentes à compensação de cheques e acesso a sistemas de liquidação de pagamentos e transferências interbancárias.

No que se refere aos motivos de devolução de cheques, várias circulares e resoluções tratam da matéria, conforme se pode verificar no exame do quadro a seguir, elaborado a partir da tabela publicada no *site* do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), com a observação de que os motivos 26, 29, 32, 36, 42, 47 e 64 já não contam dessa tabela oficial, mas são mantidos para efeito histórico:

MOTIVO		FUNDAMENTO LEGAL
11	Insuficiência de fundos – 1ª apresentação	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
12	Insuficiência de fundos – 2ª apresentação	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90

13	Conta encerrada, a ser utilizado na devolução de cheque objeto de conta encerrada, na condição de não ser aplicável a devolução por qualquer outro motivo	Circular n. 3.535/2011
14	Prática espúria	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
20	Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio das folhas de cheque em branco, mediante apresentação de boletim de ocorrência policial e declaração firmada pelo correntista relativos ao roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco	Circular n. 3.535/2011
21	Cheque sustado ou revogado, mediante declaração firmada pelo emitente ou portador legitimado, por qualquer motivo por ele alegado	Circular n. 3.535/2011
22	Divergência ou insuficiência de assinatura	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
23	Cheques de órgãos da administração federal em desacordo com o disposto no art. 74, § 2º, do DL n. 200/67	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
24	Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
25	Cancelamento de talonário pelo sacado	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
26	Inoperância temporária de transporte Obs.: neste caso o documento não pode ser devolvido ao cliente depositante.	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
27	Feriado municipal não previsto Obs.: neste caso o documento não pode ser devolvido ao cliente depositante.	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
28	Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio: na devolução de cheque efetivamente emitido pelo correntista, mediante apresentação de boletim de ocorrência policial e declaração firmada pelo emitente ou beneficiário relativos ao roubo, furto ou extravio	Circular n. 3.535/2011
	Cheque bloqueado por falta de confirmação do recebimento do talonário pelo	Circular n. 2.655/96,

29	correntista Obs.: motivo com nova redação a partir de 16-5-2011, com a Circular n. 3.535.	integralmente alterada pela Circular n. 3.535/2011
30	Furto ou roubo de malotes Obs.: com a instituição da truncagem pela Circular n. 3.532/2011 (retenção do papel pela instituição financeira e remessa por imagem digital ou outros registros eletrônicos), o motivo de devolução passou a ser simplesmente “furto ou roubo de cheques”.	Carta-Circular n. 2.692/96
31	Erro formal de preenchimento (sem data de emissão, com o mês grafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso)	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
32	Ausência ou irregularidade na aplicação do carimbo de compensação	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
33	Divergência de endosso	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
34	Cheque apresentado por estabelecimento que não o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
35	Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento bancário (<i>cheque universal</i>), ou ainda com adulteração da praça sacada, ou ainda rasura no preenchimento	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
36	Cheque emitido com mais um endosso – Lei n. 9.311/96	Carta-Circular n. 2.713/97, integralmente alterada pela Carta-Circular n. 3.173/2005.
37 38 39	Registro inconsistente – compensação eletrônica Assinatura digital ausente ou inválida Imagem fora do padrão Obs.: nesses três casos os documentos não podem ser devolvidos ao cliente depositante.	Circulares n. 2.398/93 (revogada), 3.532/2011, 3.535/2011 e Manual Operacional da Compe.
40	Moeda inválida	Carta-Circular n. 2.608/95 e Circulares n.

		3.532/2011 e 3.535/2011
41	Cheque apresentado a participante que não o destinatário (banco não é o sacado) Obs.: neste caso o documento não pode ser devolvido ao cliente depositante.	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
42	Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado e o recibo bancário trocado em sessão indevida Obs.: neste caso o documento não pode ser devolvido ao cliente depositante.	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
43	Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 34, persistindo o motivo de devolução	Resolução n. 1.682/90 e Circular n. 1.584/90
44	Cheque prescrito	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
45	Cheque emitido por entidade obrigada a emitir ordem bancária	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90
46	CR – Comunicação de Remessa cujo cheque correspondente não for entregue no prazo devido Obs.: este motivo deixou de existir em 28-2-2005, com a Carta-Circular n. 3.173.	Carta-Circular n. 2.376/93
47	CR – Comunicação de Remessa com ausência ou inconsistência de dados obrigatórios Obs.: este motivo deixou de existir em 28-2-2005, com a Carta-Circular n. 3.173.	Carta-Circular n. 2.376/93
48	Cheque de valor superior a R\$ 100,00, sem identificação do beneficiário	Circulares n. 2.444/94, 3.532/2011 e 3.535/2011
49 59 60	Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45 Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de verificação pelo participante remetente e não enquadrada no motivo 31 Instrumento inadequado para a finalidade	Resoluções n. 1.631/89 e 1.682/90

61	Papel não compensável	
64	Arquivo lógico não processado/processado parcialmente Obs.: neste caso (motivo 64) o documento não pode ser devolvido ao cliente depositante.	
70	Sustação ou revogação provisória: na devolução de cheque objeto de sustação ou revogação provisória, cujo prazo de confirmação não tenha expirado e cuja confirmação ainda não tenha sido realizada, nas condições estabelecidas na regulamentação em vigor	Circular n. 3.535/2011
71	Inadimplemento contratual de cooperativa de crédito no acordo de compensação	Circular n. 3.226/2004
72	Contrato de compensação encerrado (cooperativas de crédito)	Circular n. 3.226/2004

b) Conflitos em matéria de cheque

Verifica-se entre a Lei Uniforme (Decreto n. 57.595/66) e a Lei Brasileira (Lei n. 7.357/85) a existência de conflitos quanto à regulamentação do cheque, como, por exemplo, o prazo para sua apresentação. O art. 29 do primeiro diploma indica o prazo de 8, 20 e 70 dias, conforme o local de pagamento: se no mesmo país em que foi emitido; se em país diverso na mesma parte do mundo; e, ainda, se o lugar de emissão e de pagamento se encontrarem em diferentes partes do mundo. A Lei Brasileira (art. 33) dispõe de modo diverso: o prazo é de 30 ou de 60 dias, levando em conta tão somente a identidade ou divergência entre o local de pagamento e o da emissão.

A solução para sanar o conflito entre as normas encontra-se na leitura atenta dos artigos em que ocorreram reservas do governo brasileiro, indicadas no preâmbulo da assinatura da convenção, em que se lê expressamente a não adoção plena do disposto nos arts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29 e 30 do Anexo II.

Apresentamos aqui um resumo do Anexo II, unidade da Lei Uniforme que possibilita os países aderentes a: (1) fixar a aplicação quanto ao requisito da denominação e do lugar onde é passado, seis meses depois de sua entrada em vigor; (2) determinar a maneira de suprir a falta de assinatura do emitente; (3) prescrever

que um cheque sem indicação do lugar de pagamento se pague no lugar onde foi passado; (4) dispor quanto à possibilidade de se sacar cheques sobre pessoas que não sejam banqueiros ou instituição assemelhada; (5) estabelecer em que momento o sacador deve ter fundos disponíveis em poder do sacado; (6) possibilitar a inscrição pelo sacado de menção à certificação, confirmação, visto ou outra declaração equivalente; (7) possibilitar introdução de cláusula de intransmissibilidade; (8) permitir ou não que um cheque possa ser sacado sobre o próprio sacador; (9) proibir emissão ao portador; (10) possibilitar pagamento em domicílio de terceiro não banqueiro; (11) inserir a regra do art. 13 da Convenção que possibilita encher cheque incompleto; (12) não aplicar o art. 21 da Convenção que tutela o direito de portador de boa-fé que tenha recebido cheque extraviado; (13) permitir o lançamento de aval em documento separado; (14) prolongar o prazo para apresentação do cheque, previsto no art. 29 da Convenção; (15) instituir câmaras de compensação; (16) revogação do cheque; (17) sustar os efeitos da cláusula prevista no art. 36 da Convenção, quanto ao valor da moeda estrangeira; (18) adotar cheques para se levar em conta e cheques cruzados e seu regime; (19) dispor sobre direitos especiais do portador do cheque sobre a provisão e seus efeitos; (20) dispor sobre os efeitos do protesto; (21) impor o protesto para o exercício do direito de ação; (22) dispor sobre a comunicação a ser feita pelo oficial do registro de protesto; (23) estabelecer taxa de juros; (24) dispor sobre os direitos do portador em ação de regresso; (25) regular as ações de cobrança na hipótese de prescrição; (26) indicar causas de suspensão e interrupção; (27) estabelecer a contagem do prazo para apresentação em certos dias úteis e feriados; (28) dispor sobre a possibilidade de tomar medidas excepcionais de ordem geral relativas ao adiantamento de pagamento e aos prazos de tempo que dizem respeito aos atos tendentes à conservação de direito; (29) conceituar banco e instituição assemelhada; (30) legislar, de forma especial, acerca de cheques postais e cheques especiais; (31) reconhecer as disposições adotadas por outra parte contratante.

Em relação às reservas expressamente indicadas pelo Brasil, temos:

--	--

MATÉRIA	DISPOSIÇÕES DO ANEXO II E SOLUÇÕES LEGISLATIVAS
Suprimento da assinatura	Art. 2º – quanto à maneira que pode ser suprida a falta de assinatura no cheque: • A LUC (art. 11) e a LC (arts. 13 e 14) dispuseram de forma semelhante, não admitindo a possibilidade de se suprir a ausência de assinatura por “declaração autêntica escrita no cheque para se constar a vontade daquele que deveria ter assinado”.
Cheque sem indicação de lugar de pagamento	Art. 3º – quanto à faculdade de o país signatário prescrever que um cheque sem indicação do lugar de pagamento: • Pela LUC, havendo total omissão, o cheque é pagável no lugar em que o sacado tem o seu estabelecimento principal (art. 2º do Anexo I). • A LC impõe o pagamento no lugar de sua emissão (art. 2º, I).
Cheques sacados contra pessoas que não sejam instituições financeiras	Art. 4º – sobre a validade dos cheques sacados sobre pessoas que não sejam instituições financeiras: • A LUC dispõe que “o cheque é sacado sobre um banqueiro que tenha fundos”, acrescentando que “a validade do título como cheque não fica, todavia, prejudicada no caso de inobservância dessas prescrições” (art. 3º). • A LC é restritiva e estabelece que “o cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque” (art. 3º).
Momento da disponibilidade de fundos	Art. 5º – quanto ao momento em que deve o sacador ter fundos disponíveis em poder do sacado: • A LUC não fixa esse momento. • A LC estabelece que a “existência de fundos é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento” (art. 4º, § 1º).
Possibilidade de vistos ou certificação	Art. 6º – sobre a possibilidade de inscrição de certificação, confirmação, visto ou outra declaração equivalente e de regular os seus efeitos jurídicos: • O art. 7º da LC admite ao “sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar, no verso do cheque não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título”.
Cláusula de intransmissibilidade	Art. 7º – quanto à derrogação dos arts. 5º e 14 da Convenção no que se refere à inscrição de cláusula “não transmissível”, nos cheques pagáveis no seu território: • A cláusula “não transmissível” é aquela que determina que os cheques só podem ser pagos aos portadores que os tenham recebido com essa cláusula

transmissibilidade	pagos aos portadores que os tenham recebido com essa cláusula. • A redação brasileira encontra-se nos arts. 8º e 9º da LC e da circulação à ordem e não à ordem, permitindo a proibição de novo endosso (art. 21, parágrafo único).
Saque sobre o próprio sacador	Arts. 8º e 9º – sobre a faculdade de um cheque ser sacado sobre o próprio sacador: • O art. 6º da LUC traz como regra geral que “o cheque não pode ser passado sobre o próprio sacador, salvo no caso em que se trate de um cheque sacado por um estabelecimento sobre outro estabelecimento, ambos pertencentes ao mesmo sacador”. • A LC permite a emissão “contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador” (art. 9º, III).
Pagamento em domicílio de terceiro	Art. 10 – no tocante à admissibilidade de um cheque ser pago no domicílio de terceiro que não seja banqueiro. • Há restrição na Convenção (art. 8º) que exige que o terceiro seja sempre banqueiro, assim também regulando a LC (art. 11).
Efeitos da inscrição abusiva em cheque incompleto a terceiros de boa-fé	Art. 11 – faculdade de não inserir na sua lei nacional o art. 13 da Lei Uniforme. O art. 13 trata dos efeitos em relação aos portadores de boa-fé, decorrentes do cheque abusivamente completado contrariamente aos acordos realizados com o emitente: • A lei brasileira tratou a matéria no art. 16, confirmando aqueles efeitos: “Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com o emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de má-fé”.
Efeitos do desapossamento sobre terceiros de boa-fé	Art. 12 – faculdade de não aplicar o art. 21 da Convenção que dispõe acerca do desapossamento de cheque ao portador ou endossável e seus efeitos sobre o portador de boa-fé: • O art. 24 da Lei n. 7.357/85 dá idêntica regulação à matéria, acrescentando, contudo, a possibilidade de anulação e substituição de títulos ao portador, por ação própria.
Aval em ato separado	Art. 13 – faculdade de admitir a possibilidade de ser dado um aval por ato separado em que se indique o lugar onde foi feito: • A LUC (art. 26) exige que se lance o aval sobre o cheque ou folha anexa. • A LC regula de forma idêntica a matéria (art. 30).
Prorrogação do prazo de apresentação	Art. 14 – faculdade de prolongar o prazo de apresentação do cheque previsto no art. 29 da Convenção que fixa prazos de 8, 20 e 70 dias, considerando que a apresentação se dá no país onde foi passado ou em país diferente daquele em que é pagável ou, ainda, se o lugar em que foi emitido e o de pagamento situam-se em partes diferentes do mundo. • A lei brasileira fixa apenas dois prazos: 20 dias, quando o cheque é emitido no Brasil e o

apresentação	• A lei brasileira fixa apenas dois prazos: 30 dias, quando o cheque é emitido no lugar onde deve ser pago, e 60 dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior (art. 33).
Câmaras de compensação	Art. 15 – faculdade de determinar as instituições que devem ser consideradas câmaras de compensação, em complemento ao conceito que se encontra no art. 31 da Convenção. • A matéria é regulada pela Lei n. 10.214, de 27 de março de 2001, e por resoluções e circulares do Banco Central, especialmente a Circular n. 3.226, de 18 de fevereiro de 2004.
Revogação de cheque emitido	Art. 16 – quanto a admitir ou proibir a revogação de cheque emitido. • A lei brasileira admite a revogação do cheque pagável no Brasil “mercê de contraordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato” e, contudo, dispõe que a produção de efeitos somente ocorre depois de expirado o prazo de apresentação (art. 35). Neste aspecto há harmonia com o disposto no art. 32 da Lei Uniforme que dispõe que “a revogação do cheque só produz efeito depois de findo o prazo de apresentação”. • A lei brasileira, contudo, distintamente do disposto na LUC, prevê a possibilidade de <i>sustação</i> de pagamento, com efeitos mesmo antes do prazo da apresentação (art. 36).
Pagamento em moeda estrangeira	Art. 17 – sustação dos efeitos da cláusula prevista no art. 36 da Convenção, relativa ao pagamento efetivo em moeda estrangeira. • A lei brasileira determina o pagamento em moeda nacional, pelo câmbio do dia de pagamento, obedecida a legislação especial. Se, entretanto, o cheque não for pago na data da apresentação, o portador pode optar entre o câmbio do dia da apresentação e do dia do pagamento (art. 42).
Cheque cruzado	Art. 18 – faculdade de só admitir os cheques cruzados ou os cheques para levar em conta. • A LUC admite cheques cruzados (art. 37), cruzamento geral e especial (art. 38) e para levar em conta (art. 39). • A LC trata de todas essas modalidades nos arts. 44 e 45.
Direitos do portador sobre a provisão	Art. 19 – a Lei Uniforme não abrange a questão de saber se o portador tem direitos especiais sobre a provisão e quais são as consequências desses direitos. • A lei brasileira prevê no art. 52 a extensão da indenização devida ao portador em ação de cobrança.
	Arts. 20 e 21 – quanto às ações necessárias à preservação dos direitos contra o sacador. • A Convenção trata da matéria no art. 40, indicando como base à verificação da prova

Exigência de protesto ou declaração equivalente	• A Convenção trata da matéria no art. 40, indicando como habéis a verificação de recusa do pagamento o protesto, a declaração do banco sacado ou da câmara de compensação. • A matéria é regulada no art. 47 da lei brasileira que estabelece a suficiência para execução da declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação. Essas declarações dispensam o protesto. • A execução independe do protesto e das declarações do sacado ou da câmara de compensação se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.
Sobre o agente incumbido do protesto	Art. 22 – quanto a introduzir o sistema de aviso de falta de pagamento previsto no art. 42 da LUC por um agente público: • A legislação brasileira trata dos serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida na Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997.
Taxa de juros	Art. 23 – quanto à fixação da taxa de juros: • A Lei Uniforme limita em 6% ao ano (arts. 45 e 46). • A lei brasileira remete à legislação comum – juros legais (arts. 52, II, e 53, II). Atualmente o Código Civil prevê que os juros legais sejam fixados “segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (CC, art. 406), o que conduz à aplicação de juros moratórios de 12% ao ano (REsp n. 970.586, Min. Humberto Martins, j. 21-8-2007, <i>DJ</i>, 3-9-2007 e Enunciado n. 20 do CJP, anotados por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em <i>Código Civil Anotado</i>. 27. ed. 2008).
Cobrança de comissão	Art. 24 – quanto à faculdade de inserir disposição determinando que o portador possa reclamar uma comissão: • A reserva não é expressa (ao assinar, o Brasil não indicou a não adoção plena). O diploma nacional não usa a faculdade de inserir a possibilidade de se reclamar uma “comissão”, dispondo distintamente. • A Lei Uniforme dispõe que “qualquer das Altas Partes Contratantes reserva-se a faculdade de inserir na lei nacional uma disposição determinando que o portador pode reclamar daquele contra o qual exerce o seu direito de ação uma comissão cuja importância será fixada pela mesma lei nacional” e “que a mesma regra é aplicável à pessoa que, tendo pago o cheque, reclama o seu valor aos que para com ele são responsáveis”. • A Lei Brasileira regulou a matéria nos arts. 52 e 53, permitindo ao portador e ao coobrigado exigirem dos demandados a importância do cheque não pago, os juros legais desde a data da apresentação, as despesas que fez e a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.

		nao se trata, pois, de comissão, como prescreve a Lei Uniforme, mas de valores suficientes à recomposição do poder aquisitivo da quantia escrita no cheque.
Ação de enriquecimento sem causa		Art. 25 – quanto à ação por enriquecimento sem causa: • A LC adotou a prescrição em dois anos contados do dia em que se consumou a prescrição do cheque (art. 61).
Causas de suspensão da prescrição		Art. 26 – quanto à determinação das causas de suspensão da prescrição das ações relativas a cheques e início do prazo de prescrição de um dos coobrigados contra os demais: • O art. 52 da Convenção fixa em seis meses a ação do portador contra os endossantes, sacador e demais coobrigados, contados do termo do prazo de apresentação e, também, o mesmo prazo para a ação entre os coobrigados, contados do dia em que o cheque foi pago ou em que o autor tenha sido acionado. • A LC estabelece os mesmos prazos, mas institui que as causas de interrupção somente produzem efeitos em relação ao obrigado contra o qual foi promovido o ato interruptivo e, ainda, prevê ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, em prazo distinto daquele (arts. 59-62).
Dias úteis e prazo de apresentação		Art. 27 – quanto à faculdade de determinar que certos dias úteis sejam assimilados aos dias de feriados legais, pelo que respeita ao prazo de apresentação e a todos os atos relativos a cheques: • Na LC a matéria é regulada pelo art. 64: “A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente só podem ser feitos ou exigidos em dia útil, durante o expediente dos estabelecimento de crédito, câmara de compensação e cartório de protestos. Parágrafo único. O cômputo dos prazos estabelecidos nesta Lei obedece às disposições do direito comum”. Isto equivale a dizer que se aplica o disposto no art. 132 do Código Civil: (a) exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento; (b) caindo o vencimento em feriado considera-se prorrogado o prazo até o seguinte dia útil; (c) meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia; (d) os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência; (e) os prazos fixados por hora contam-se minuto a minuto.
Adiantamento de pagamentos		Art. 28 – faculdade de tomar medidas excepcionais de ordem geral relativas ao adiantamento de pagamento e de prazos de tempo no tocante à conservação de direito: • A LC não prevê casos específicos.
Qualidade de banqueiro		Art. 29 – sobre a determinação das pessoas que devem ser consideradas banqueiras ou instituições equivalentes: • No Brasil a definição e a caracterização da instituição financeira encontram-se no art.

Banqueiro	• NO BRASIL, a definição e a caracterização de instituição financeira encontram-se no art. 17 da Lei n. 4.595/64.
Cheques postais e cheques especiais	Art. 30 – quanto à possibilidade de exclusão, no todo ou em parte, da aplicação da Lei Uniforme aos cheques postais e aos cheques especiais, quer dos bancos emissores, quer das caixas do Tesouro, quer das instituições públicas de crédito, na medida em que os instrumentos sejam submetidos a legislação especial: • A LC remete a matéria (art. 66) a legislação especial.

Voltando ao exemplo que encabeça este subtítulo: verifica-se que o art. 14 do Anexo II permite que os países aderentes prolonguem os prazos para a apresentação do cheque e o Brasil, fazendo uso dessa faculdade, expressamente indicou sua reserva quanto à aplicação do art. 29, introduzindo em sua legislação prazos distintos daqueles.

Há de atentar, finalmente, que o art. 63 da Lei n. 7.357/85 especifica o modo de interação entre as normas, determinando que “os conflitos de leis em matéria de cheques” sejam “resolvidos de acordo com as normas constantes das Convenções aprovadas, promulgadas e mandadas aplicar no Brasil”.

4.4. Criação do cheque – requisitos

Para valer como cheque o título deve conter os requisitos previstos no art. 1º da Lei n. 7.357/85:

(I) A denominação “cheque” inscrita no contexto do título e expressa na língua do lugar da legislação de regência. Trata-se de pressuposto formal de existência do próprio título e pode ser lançado em qualquer parte do papel. Um documento que contenha todos os demais elementos do cheque, mas não contenha essa palavra (“cheque”) não pode ser admitido como tal, não se submetendo ao regime jurídico desse título.

(II) A ordem incondicional de pagar quantia determinada. Essa ordem deve ser expressa em algarismos ou por extenso, sendo que, presentes ambas as expressões e havendo divergência entre elas, a última prevalece sobre a primeira. Se houver mais de uma indicação de valor com identidade gráfica – por extenso ou por algarismos –

prevalece a que representar menor quantia.

(III) O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar. O nome do sacado deve constar do título, podendo haver mais de um banco ou instituição financeira que deva pagá-lo, de forma solidária entre eles.

(IV) A indicação do lugar do pagamento. Ocorrendo a omissão será o do local designado junto ao nome do sacado – banco ou instituição assemelhada. Se houver multiplicidade de locais, como, por exemplo, agências e filiais do estabelecimento bancário ou instituição financeira, considera-se o primeiro deles. Se não houver lugar algum designado, presume-se que se pague no lugar de sua emissão. A lei autoriza que o pagamento se dê tanto no domicílio de terceiro quanto no do sacado (banco ou instituição) ou, ainda, em outra localidade, desde que o terceiro seja banco. A indicação do lugar de pagamento constitui importante dado para verificação do prazo para apresentação do cheque: quando emitido no lugar de pagamento, deve ser apresentado dentro de trinta dias da data da emissão; se emitido em lugar diverso ao de pagamento, esse prazo dilata-se para sessenta dias, conforme dispõe o art. 33 da Lei n. 7.357/85.

(V) A indicação da data e do lugar de emissão. Considera-se lugar de emissão, à falta de estipulação especial, o indicado junto ao nome do emitente. É da data da emissão que se conta o prazo de apresentação do cheque, podendo ocorrer, contudo, na prática comercial, a indicação de data diversa à da emissão (cheque pós-datado). A solução legislativa é considerar que o cheque é pagável no dia da apresentação (art. 32 da Lei n. 7.357/85). Há, neste caso, contudo, que se considerarem as consequências da apresentação antes do dia indicado, podendo dar ensejo a indenização por eventuais prejuízos materiais e morais que decorram da violação de cláusula acordada entre as partes originais.

(VI) A assinatura do emitente ou de seu mandatário com poderes especiais. A assinatura pode ser feita por chancela mecânica, desde que autorizada pelo banco ou instituição financeira sacada.

Uma última questão ainda pode ser enfrentada quanto à emissão: o cheque incompleto, também chamado em branco, isto é, aquele que não preenche todos os

cinco primeiros requisitos acima citados. A complementação pode se dar em momento posterior da emissão, pelo portador que deve observar o convencionado com o emitente. Se o cheque for completado abusivamente, ainda assim não pode ser objeto de oposição contra o portador que não o tiver adquirido de má-fé (LC, art. 16).

Significa dizer que o emitente, quando assina o cheque e o deixa em branco, responde perante eventuais portadores de boa-fé. A matéria de preenchimento abusivo somente pode ser oposta contra aquele que primeiro recebeu o cheque e o preencheu sem observar o convencionado. Contra o terceiro o emitente não pode opor-se ao pagamento, salvo se provar má-fé de sua parte na aquisição.

Imagine-se a seguinte situação: Ricardo emite um cheque para seu irmão e o autoriza a preenchê-lo em valor não superior a R\$ 1.000,00, como presente de aniversário. Seu irmão André entrega o título em compras que realiza em loja de roupas, preenchendo ou entregando para preenchimento no balcão, em valor superior, R\$ 4.000,00. Ricardo não pode alegar preenchimento abusivo para não pagar o título. O proprietário da loja é terceiro de boa-fé e sua relação com André é independente da relação entre Ricardo e André.

4.5. Revogação e oposição

O emitente pode emitir contraordem de pagamento do cheque, devendo manifestar sua intenção por meio idôneo – por correspondência particular, por via judicial ou extrajudicial – conforme decorre do art. 35 da Lei do Cheque.

Os motivos que justificam a revogação são inúmeros, podendo ser lembrados a perda do talonário, o furto ou roubo de que o correntista tenha sido vítima, atos da natureza que impossibilitem conhecer o destino do talão etc. O correntista deve indicar a motivação no momento em que pede a revogação da ordem de emissão do cheque, ficando sujeito à responsabilização por danos civis e criminais decorrentes dessa manifestação.

A lei impede que o banco ingresse no julgamento da relevância da razão invocada pelo oponente (LC, art. 36, § 2º), conforme também deflui do entendimento da mais alta corte em matéria infraconstitucional:

“Comercial – cheque – sustação de pagamento por oposição – matéria de fato – inteligência do art. 36 da Lei do Cheque. I – A seriedade da oposição (sustação do pagamento) está assegurada pela exigência da relevância jurídica da razão invocada pelo oponente, a qual, obviamente, não é deixada ao julgamento do banco sacado, mas ao do juiz. II – Matéria de fato (Súm. 7/STJ). III – Recurso não conhecido (REsp : 101.096/RS, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, j. 24-11-1997, *DJ*, 25-2-1998, p. 69)”.

Dispõe a lei que a contraordem somente produzirá efeitos após o decurso do prazo de apresentação (LC, art. 35, parágrafo único). Veja-se, portanto, que a revogação pode ser definida como “ordem escrita expedida pelo correntista determinando ao banco sacado o não pagamento de cheque uma vez decorrido o prazo para sua apresentação”. Dissemos “correntista” e não “emitente” porque muitas vezes não houve emissão e o fundamento de sua ordem é justamente essa circunstância.

A sustação de pagamento do cheque é outra modalidade de ordem, que pode ser expedida tanto pelo correntista como também pelo portador legitimado visando ao não acolhimento do cheque pela instituição financeira. Neste caso os interessados *opõem-se* ao pagamento, por escrito, por razões fundadas no direito que, semelhantemente à motivação da revogação, não podem ser objeto de perquirição pelo banco sacado, dentro do prazo de apresentação.

O interesse do portador legitimado decorre das mesmas situações cotidianas: desapossamento indevido do título, por ato ilícito, por exemplo, ou simples perda do título, daí por que não pretende ver pago o título ao terceiro a quem imputa atos de má-fé.

Diferenciam-se os institutos da revogação e da oposição no tocante ao momento da eficácia da ordem. A revogação somente será acatada depois do término do prazo de apresentação do cheque e a sustação, mesmo durante esse prazo.

Outra distinção refere-se à pessoa legitimada a determinar o comportamento do banco: somente o correntista (que a lei denomina emitente) no primeiro caso e, no segundo, tanto ele como o portador legitimado poderão fazê-lo (LC, art. 36).

Em um ou em outro caso, ocorrido o pagamento, não há mais possibilidade de se proceder à revogação ou à sustação do título.

Se o banco se recusar a acatar a ordem recebida tempestivamente – isto é, antes do acolhimento do cheque – responderá pelos prejuízos causados ao correntista ou ao portador legitimado.

É bom observar que há distinção entre os dispositivos da Lei Uniforme (art. 32) e o da Lei do Cheque nacional (arts. 35 e 36) quanto à matéria de revogação e sustação, permitindo a primeira tão somente a revogação. Isto é possível porque o Brasil fez reserva ao disposto no art. 16 do Anexo II da Lei Uniforme, como salientado anteriormente (item 4.3, *b*). Por este dispositivo, “qualquer das Altas Partes Contratantes, por derrogação do art. 32 da Lei Uniforme, reserva-se a faculdade de, no que respeita aos cheques pagáveis em seu território: (a) admitir a revogação do cheque mesmo antes de expirado o prazo de apresentação; (b) proibir a revogação do cheque mesmo depois de expirado o prazo de apresentação. Qualquer das Altas Partes Contratantes tem, além disso, a faculdade de determinar as medidas a tomar no caso de perda ou roubo dum cheque e de regular seus efeitos jurídicos”.

Verifica-se, pois, que, fazendo uso de sua faculdade, o Brasil optou por incluir a alternativa “(a)”, admitindo a revogação do cheque antes mesmo de expirado o prazo de apresentação – a qual denominou “sustação”, evitando os percalços da homografia.

4.6. Circulação do cheque

Além dos requisitos de criação, o cheque, no direito brasileiro, por força do art. 69 da Lei n. 9.069/95 – que dispôs sobre o Plano Real –, a partir de 1º de julho de 1994, tornou-se obrigatória a indicação do beneficiário do cheque de valor superior a R\$ 100,00 (cem reais). Com isso, para pagamento e compensação, grande parte dos cheques em circulação é obrigatoriamente emitida na modalidade nominativa.

Posto em circulação, o cheque nominativo pressupõe a cláusula “à ordem”, isto é, admite sempre o endosso, que deve ser lançado de forma pura e simples, incondicionalmente. Se, entretanto, o título estipular que seu pagamento seja feito a pessoa nomeada, com a cláusula “não à ordem”, ou outra equivalente, como, por

exemplo, “sem garantia” ou “sem responsabilidade”, não pode circular de forma cambial, sujeitando sua transmissão exclusivamente mediante cessão de crédito.

Distinguem-se os institutos do endosso e da cessão de crédito.

Endosso é forma implícita de transmissão dos títulos de crédito e, portanto, não necessita estar escrita. É qualidade inerente ao título, seu modo natural de transferir o crédito a outrem.

Cessão de crédito é modo de transmissão de obrigações. Maria Helena Diniz (2007, 2:433) a conceitua como “negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do consentimento do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional”.

Enquanto no título de crédito há presunção de circularidade pelo endosso lançado no próprio título, admitindo-se a inscrição de cláusula em contrário, na cessão, impende perquirir, antes, se a natureza da obrigação, a lei ou convenção com o devedor não se opõem à operação. A cessão, para ser eficaz contra terceiros, deve ser celebrada por instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades previstas no § 1º do art. 654 do Código Civil: (a) indicação do lugar onde foi passado; (b) qualificação do outorgante e do outorgado; (c) data; (d) objeto; e (e) extensão da cessão.

Há também grande distinção entre os efeitos do endosso cambial e da cessão de crédito.

Conforme dispõe a Lei n. 7.357/85, o endossante: (a) garante o pagamento do título, salvo estipulação em contrário (art. 21); (b) pode proibir novo endosso, introduzindo cláusula “não à ordem”, a partir da qual não mais garante o pagamento a quem seja posteriormente endossado (art. 21, parágrafo único); (c) quando de boa-fé está imune às exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores (art. 26); (d) não precisa notificar o devedor – a eficácia do endosso independe de qualquer comunicação ao sacador; (e) ao lançar sua assinatura

no título, transmite a totalidade do crédito, sendo nulo o endosso parcial (art. 18, § 1º).

O cedente segue o regime próprio desse contrato, previsto no Código Civil (arts. 286-298) e (a) em regra, salvo estipulação em contrário, não responde pela solvência do devedor (art. 296); (b) não tem interesse em limitar a transmissão posterior do crédito; (c) contra o cessionário – adquirente do título por cessão – o devedor pode opor exceções que lhe competirem, inclusive as que, no momento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294); (d) a cessão somente opera eficazmente sobre o devedor após sua notificação (art. 290); (e) é possível a cessão parcial do crédito, desde que estipulada (art. 287).

Vale observar, ainda, que todo endosso posterior ao protesto ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação, produz efeitos de cessão, conforme dispõe o art. 27 da Lei n. 7.357/85.

4.7. Pluralidade de exemplares e alterações no texto do cheque

Conquanto incomuns, duas situações aparentemente desconcertantes mostram-se possíveis, desde a emissão do cheque: a duplicação de vias do mesmo título e a alteração de seu texto original.

a) Pluralidade de exemplares

A primeira hipótese é prevista nos arts. 56 e 57 da Lei do Cheque que cerca tal operação de alguns cuidados: (1º) é vedada sua emissão no cheque ao portador; (2º) deve referir-se a cheque emitido em um país e pagável em outro; (3º) as vias devem ser numeradas no próprio texto do título, sob pena de cada exemplar ser considerado cheque distinto; (4º) o pagamento contra a apresentação de um exemplar é liberatório, tornando sem efeito os demais exemplares; (5º) aquele que transferir, mediante endosso, exemplares a diferentes pessoas responde por todos os exemplares que não forem restituídos.

Não é necessária uma análise mais profunda para se antever os perigos de emissão múltipla – em duplicatas – de um mesmo título. Recolher todos os exemplares do

título, tendo ele circulado liberalmente, é tarefa árdua, sobretudo havendo possibilidade de a circulação ter ocorrido em diferentes direções, com endossos a distintos portadores por parte de um dos endossantes, disseminando novas relações jurídicas, com ampliação da relação cambial.

Há, contudo, notável jurista a enaltecer a importância desse instrumento legal. Pontes de Miranda (2000, 1:419-420) afirma que sua abolição “prejudicaria o tráfico dos negócios”, salientando: “É verdade, quer em relação à letra de câmbio, quer a qualquer outro saque, inclusive àquele em que maiores são os perigos deles: o cheque”. A defesa que o jurista faz do instituto é enfática, mesmo quando aponta os perigos do endosso múltiplo: “Em todo o caso, ocorre a circulação anormal, por dois ou mais caminhos, da letra de câmbio, com sérios perigos de dolo. Dir-se-á que é mau instituto; mau, porém necessário. A má-fé é punível, cercável por medidas preventivas e cautelas; ao passo que a perda de letra de câmbio – título com vocação para a metrópole, de uma colônia para outra colônia, de um país para outro, de um continente para outro continente – constitui fato definitivo, com prejuízos totais e dificilmente remediável. Daí ter-se conservado não só o uso das duplicatas como também, o que mais é, o *direito* e a *pretensão a duplicatas*”.

É certo que, no caso do cheque, a exigência de emissão nominativa e a reserva de seu uso exclusivamente para operações internacionais acarretam inexpressiva aplicação no mundo negocial, sobretudo porque a segurança econômica é fator preponderante a inibir a difusão de seu uso.

Ademais, é de fácil compreensão a autorização de pluralidade de exemplares nas letras de câmbio porque, na remessa para o aceite, pode ocorrer recusa de devolução ou a perda do título, surgindo daí a funcionalidade do instituto. Contudo, quanto ao cheque, não há aceite. Seu uso somente seria justificável por receio de perda ou destruição do título, em viagem de grande percurso, bem como para permitir ao beneficiário sua negociação durante esse interregno. Nos dias atuais, a transferência *on-line* e o cheque-viagem cumprem superiormente tais funções, tornando rara, senão inexistente, a emissão de mais de um exemplar de cheque para uma única declaração cambiária.

b) Alterações no texto do cheque

Quanto ao texto original do cheque, o art. 58 da Lei n. 7.357/85 a admite, impondo somente aos signatários posteriores responsabilidade nos termos do texto alterado, mantendo aos anteriores a do texto original.

Se não for possível determinar se o lançamento da assinatura se deu antes ou depois da alteração do texto, a lei faz presumir tenha ocorrido antes (art. 58, parágrafo único).

Pontes de Miranda (2000, 4:151) lembra que o cancelamento de qualquer declaração singular – por exemplo, endosso e aval – precisa ser feito “pelo criador do título, ou por alguém em nome dele, quando *ainda* se acha em posse dele o cheque, ou lhe volve às mãos como sua, ou, achando-se em posse de outro, esse outro não tem direito sobre ela”.

Rubens Requião é veemente quanto à sua oposição à possibilidade de se alterar o texto do cheque, alertando para a insegurança do procedimento (1995, 2:432).

4.8. Formas de lançamento e modalidades de endosso

O endosso pode ser lançado em branco ou em preto, caracterizando o primeiro pela simples assinatura do endossante, seguida ou não da expressão “ao portador”; o segundo – em preto – é aquele que especifica o nome do novo beneficiário, endossatário do título. Não há obrigação de o endossante indicar a data da operação; se omitida, presume-se anterior ao protesto ou declaração equivalente ou, ainda, à expiração do prazo de apresentação (LC, art. 27).

Quanto à extensão de vínculos com os endossatários, admite-se o lançamento de endosso não traslativo de direitos, como ocorre no endosso-mandato (endosso-procuração), a partir do qual somente admitirá outros endossos-mandatos.

A previsão dessa modalidade encontra-se no art. 26 da lei brasileira. Neste caso a assinatura do endossante contém a expressão “valor em cobrança”, “para cobrança”, “por procuração” ou equivalentes e, com ela, o endossante vincula-se aos endossatários tão somente com relação ao mandato ou ao serviço de cobrança que contratou. Os coobrigados podem invocar contra o portador do título as mesmas

exceções que dispõem contra o endossante porque não houve, no endosso, transmissão de crédito, mas somente ordem para os endossatários realizarem a cobrança do crédito pertencente ao endossante.

Para dar maior segurança à operação, o endosso-mandato não se extingue com a morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade (LC, art. 26, parágrafo único), ao contrário do que sucede no mandato civil (CC, art. 682, II).

Exemplo de endosso-procuração pode ser tirado da vida bancária cotidiana. O empresário recebe cheques e constitui com terceiro, em geral instituição financeira, contrato de cobrança, entregando os títulos mediante endosso-mandato. O cobrador seguirá as ordens do endossante quanto ao prazo, tolerância de mora, protesto etc. O sacador do cheque cobrado ou os endossantes anteriores do cheque podem arguir oposições ao cumprimento de suas obrigações em razão de relações que mantiveram com o endossante, levando-as ao conhecimento do endossatário-procurador, portador do título.

4.9. Aval no cheque

Pode-se lançar aval no cheque, a favor do emitente, de qualquer um dos endossantes ou mesmo de outro avalista, apenas não se permitindo ao sacado que, por natureza, não se vincula na relação cambial. Trata-se, pois, de garantia, total ou parcial, prestada por terceiro ou por qualquer signatário do título.

A lei de cheque brasileira admite o aval parcial (art. 29), no que colide com a regra do parágrafo único do art. 897 do Código Civil. Contudo, entende-se que as disposições relativas aos títulos de crédito, introduzidas pelo legislador civilista de 2002, não se aplicam aos títulos então existentes quando de sua promulgação. É o enunciado n. 52 da Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, entre 11 e 13 de setembro de 2002: “Por força da regra do art. 903 do Código Civil, as disposições relativas aos títulos de crédito não se aplicam aos já existentes”.

Em regra, lança-se o aval no verso do cheque ou em folha de alongamento – pedaço de papel que se acrescenta ao título quando necessário, por não haver espaço

suficiente – mediante assinatura com a expressão “por aval” ou equivalente. Qualquer assinatura no anverso do cheque, além da do emitente, é considerada aval e a omissão quanto ao nome do avalizado faz presumir que foi dado a favor do emitente.

O avalista vincula-se no título ao avalizado, equiparando-se obrigacionalmente a ele. Sua responsabilidade é solidária, isto é, obriga-se como se devedor principal fosse. Se houver vários avalistas a favor de um coobrigado, o pagamento realizado por um deles exonera os demais, gerando a seu favor direito de regresso contra o avalizado e demais coobrigados do título. Contudo, não há direito de regresso entre avalistas de um mesmo avalizado porque inexistente, entre eles, qualquer relação cambial.

4.10. Inoponibilidade das exceções pessoais

Estudado o mecanismo de circulação do cheque, convém ampliar os efeitos do princípio da autonomia antes mencionado.

Participam do ato de emissão do cheque três figuras: o sacador, que mantém contrato de conta corrente em instituição financeira; o sacado, que é sempre uma instituição financeira; e o beneficiário, pessoa indicada nominalmente no ato de criação ou posteriormente.

O beneficiário pode transmitir seu crédito a terceiro, mediante endosso, passando a intitular-se endossante e o novo portador, endossatário, pode transmiti-lo a outrem, passando a ser novo endossante e assim sucessivamente. Cada uma dessas relações jurídicas que se formam é independente das outras. Entre o sacador e o beneficiário pode ter existido contrato de venda e compra de um veículo, por exemplo. Entre esse beneficiário e seu endossatário, pagamento de dívida e, entre este e o novo portador, uma doação.

Se o veículo adquirido pelo emitente do cheque não satisfizesse suas expectativas, gerando sua intenção e não cumprir o contrato, esse motivo não pode ser apresentado como defesa em relação ao atual portador do cheque porque “as obrigações contraídas do cheque são autônomas e independentes” (LC, art. 13).

É possível, contudo, que certas situações da vida indiquem a existência de causas

extracambiárias, anteriores, presentes ou posteriores à emissão – subjacentes, simultâneas ou sobrejacentes, na linguagem de Pontes de Miranda – a despeito da autonomia e abstração do cheque. Essas causas podem ser opostas entre os figurantes imediatos das relações que se formaram ao longo do período de circulação do título e podem, ainda, ser apresentadas quando, fora desses limites, houver a demonstração de má-fé do portador do título.

4.11. Modalidades de emissão

As várias modalidades com as quais se reveste o cheque podem ser assim classificadas: (a) quanto ao modo de circulação, os cheques podem ser nominativos, com ou sem cláusula à ordem e ao portador; (b) quanto ao modo e segurança de liquidação, podem ser emitidos: cheque administrativo, cheque cruzado, com cruzamento geral ou especial, cheque para se levar em conta; (c) quanto à reserva de numerário admite-se o cheque visado.

a) Cheques nominativos e ao portador

Nominativos são os cheques emitidos a favor de alguém indicado como beneficiário. Em regra, sempre são cheques à ordem, isto é, permite-se sua circulação mediante simples endosso, sendo possível, entretanto, inscrever-se cláusula “não à ordem”, vedando a circulação por endosso: qualquer transferência a partir de então será havida como cessão de crédito, regida pelo direito comum.

Cheques ao portador tornaram-se limitados a partir do Plano Real, sendo modalidade reservada aos emitidos em valor inferior a R\$ 100,00 (cem reais). Considera-se ao portador o cheque que não indique o beneficiário ou, ainda, aquele que contenha a indicação do beneficiário acrescida da expressão “ou ao portador” ou equivalente.

b) Cheques administrativos

Cheques administrativos, também chamados bancários, de tesouraria ou comprados (Pupo Correia, 1999:119), são os emitidos, sempre de forma nominativa, conforme determina a lei (art. 9º, III), por instituições financeiras que, assim, figuram

simultaneamente como emitentes e sacadas. Fábio Ulhoa Coelho (2016:444) nos lembra que, se fosse permitido ao banco emitir cheque administrativo ao portador, tal documento poderia vir a substituir o curso da moeda, em razão da idoneidade financeira do sacador.

A função do cheque administrativo é desvendada por Pupo Correia (1999:119): “em vez de se munir de numerário ou outro meio de pagamento, uma pessoa que pretenda remeter ou levar fundos para outra praça compra o cheque ao banco, que o emite a favor da pessoa indicada pelo comprador”. Este mesmo autor admite que os cheques de viagens “mais não são do que uma variante do cheque comprado, caracterizada por conter a assinatura do tomador, lançada no cheque no momento da compra, devendo o tomador nele lançar uma segunda assinatura, para evitar fraudes, quando pretender receber o seu montante do banco, ou transmiti-lo”.

O uso do cheque administrativo não é recente e era prática corrente no Brasil, antes mesmo de o Decreto n. 24.777, de 14 de julho de 1934, reconhecendo o costume, regulamentar suas operações e dispor que os bancos e as *firmas comerciais* estavam autorizados a emitir cheques contra as próprias caixas, vedada, contudo, sua emissão ao portador. A evolução desde então se refere à proibição de os empresários não banqueiros emitirem esses títulos.

c) Cheque cruzado

O cheque cruzado caracteriza-se pela inscrição de duas linhas paralelas no anverso, com o fim de restringir sua circulação porque os traços indicam que seu pagamento somente pode ser a um banco (LC, arts. 44-45).

Se o cruzamento é geral, ou em branco, significa que não há indicação de instituição financeira entre os traços paralelos, e, neste caso, o banco pode pagá-lo a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. Se o cruzamento é especial, ou em preto, existirá entre os traços a indicação do nome do banco, e o pagamento somente deverá ser feito àquele banco indicado ou, se este for o próprio sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta.

O cruzamento não pode ser cancelado, mas a lei permite a conversão do

cruzamento geral em especial, mas nunca o inverso.

d) Cheque para se levar em conta

Cheque para se levar em conta, previsto no art. 46 da Lei de Cheque, é aquele que indica, por inscrição transversal, no anverso do título, cláusula limitativa da circulação que impede seu pagamento em dinheiro. Sua criação se faz mediante inscrição “para se levar em conta” ou equivalente pela qual se entende que o banco sacado somente poderá proceder a lançamento contábil (crédito em conta, transferência ou compensação), com força de pagamento. Não há como inutilizar a limitação; o depósito na conta do beneficiário dispensa o endosso.

e) Cheque visado

Cheque visado é espécie prevista no art. 7º da Lei n. 7.357/85 que se define como aquele em que se inscreveu “visto, certificação ou outra declaração equivalente”, a pedido do emitente, pela qual o sacado se obriga a debitar na conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la em benefício do beneficiário durante o prazo de apresentação.

Pontes de Miranda (2000, 4:318) indica a tríplice função do cheque visado: “a) atestar que a assinatura do passador do cheque é autêntica; b) declarar que havia, no momento do visto, provisão suficiente e não ter o sacado, no momento do visto, o que opor ao pagamento; c) reservar-se a provisão”.

Além desses, o Brasil conheceu o *cheque marcado*, hoje já não existente. Previsto no art. 11 da Lei n. 2.591, de 1912, assemelhava-se à novação de dívida: “Se o portador consentir que o sacado marque o cheque para certo dia, exonera todos os outros responsáveis”. Apesar de não mais figurar na Lei Uniforme e, tampouco, na lei brasileira, nada impede, como nos lembra Rubens Requião (1995, 2:421), que o portador do cheque admita dilação do prazo para apresentação do cheque, sem assumir, contudo, os efeitos e as consequências jurídicas que a lei anterior outorgava ao instituto.

4.12. Apresentação, pagamento e prescrição

A perfeita compreensão dos mecanismos de apresentação e liquidação do cheque exige a análise de poucos dispositivos da Lei n. 7.357/85: (a) o prazo para a apresentação, previsto no art. 33; (b) os efeitos indenizatórios da pós-datação; (c) os efeitos da não apresentação no prazo certo: (c1) em relação aos endossantes e seus avalistas (art. 47, II); (c2) em relação ao emitente e seus avalistas (art. 47, § 3º); (c3) no prazo de prescrição, depois de expirado o prazo para a apresentação (art. 59); (c4) o curso da prescrição para a promoção de ação de regresso de um coobrigado em relação a outro (art. 59, parágrafo único).

a) Prazo para a apresentação

Dispõe o art. 33 que “o cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior”.

Quanto ao lugar de pagamento, a lei determina que, na ausência de sua indicação, deve ser pago no lugar designado junto ao nome do sacado; se houver vários lugares designados, no primeiro deles e, na ausência completa de indicação, no lugar de sua emissão.

Em regra, toma-se o lugar da emissão aquele que o emitente preenche ao inscrever a data.

A atenção e o cuidado dispensado ao preenchimento resultarão na ampliação ou redução do prazo para a apresentação, conforme o seguinte exemplo: Ricardo possui conta corrente em agência situada na cidade de São Paulo – lugar de pagamento – e emitiu cheque na cidade de São Luís do Maranhão: o prazo para apresentação é de sessenta dias. Contudo, se deixa de observar a localidade em que se encontra e completa a emissão do cheque com a indicação da cidade de São Paulo, o prazo se reduz para trinta dias.

Quanto ao tempo, presume-se verdadeira a data inscrita como a de emissão do cheque, devendo ser considerada, para esse efeito, a data lançada, abreviadamente²⁶ ou por extenso, pelo emitente ou por terceiro que a tenha completado posteriormente.

Neste último caso, deve-se observar o disposto no art. 16 da Lei de Cheque quanto à inobservância do convencionado com o emitente. A matéria está sujeita aos meios de prova e aos efeitos que o descumprimento do acordado tem em relação a quem deu causa ao preenchimento abusivo, tão somente, não podendo ser oposta a terceiro de boa-fé.

Figure-se o seguinte exemplo: André emite um cheque incompleto para pagamento de compra feita em loja de móveis e acerta com o vendedor que a data da emissão do cheque deverá ser marcada para somente após o recebimento da mercadoria, estimado em até quinze dias. A entrega atrasa e, contudo, o cheque é completado pelo vendedor e apresentado para cobrança, retornando com o carimbo de insuficiência de fundos. Em execução, André demonstra a existência desse acordo e o descumprimento por parte do vendedor da cláusula negocial, obtendo indenização por danos morais pelos prejuízos causados. Entretanto, se o cheque tivesse sido completado abusivamente e transferido a terceiro de boa-fé, não ciente dos acordos comerciais entre as partes originárias, não haveria motivo para André opor-se ao pagamento do cheque, impedindo-o de valer-se daquele fundamento contra o portador atual.

Muitas vezes o cheque é preenchido com anotação de duas datas: uma de emissão e outra “pós-data”, relativa à marcação de outro dia para apresentação. É o chamado cheque pós-datado.

Da mesma forma que o exemplo anterior, a existência de tratativas entre as partes que importem em alteração do tempo em que o cheque deve ser apresentado tem interesse extracambiário, podendo ser objeto de questionamento entre o emitente e o beneficiário que acordou em apresentar o cheque em data diversa da lançada na emissão do título, não podendo ser objeto de oposição em relação ao portador de boa-fé.

A prática regular de emissão de cheques pós-datados é realidade que não pode ser desprezada pelo Direito. Reconhece-se tratar de instrumento de crédito eficaz e, também, sua sujeição à tutela de proteção por danos que possam advir ao emitente em razão do descumprimento por parte do beneficiário que, desrespeitando o acordado, apresenta o título antes do prazo estipulado.

Contudo, em relação ao art. 33 da Lei do Cheque, qual é o termo a ser considerado para efeito de verificar se a apresentação se deu dentro do prazo de 30 ou de 60 dias? A data de emissão ou a pós-data escrita no anverso (geralmente com a inscrição “bom para”)?

Apontando para a primeira assertiva, Fábio Ulhoa Coelho (2016:446) lembra que o art. 32 da Lei do Cheque “fulmina com a ineficácia absoluta a inserção, no título, de qualquer menção contrária ao seu pagamento à vista”.

Nesse mesmo sentido Pontes de Miranda (2000, 4:111) apresenta três soluções possíveis quanto ao prazo de apresentação: “(a) alegado e provado ter havido a pós-data, descontam-se ao prazo de apresentação os dias aumentados à data da criação, porém somente se poderia opor essa exceção aos possuidores de má-fé; (b) torna-se o cheque pós-datado como qualquer outro cheque, e é pagável à vista, a despeito da alegação e prova da pós-data e, até, da apresentação antes da data inserta” (...); “(c) o cheque pós-datado somente pode ser apresentado para pagamento a partir do dia da data falsa. A solução, no sistema brasileiro (Lei n. 7.357, art. 32), é a solução b), que também prevaleceu no direito uniforme; porém a solução c) não seria, de *iure condendo*, descabida: a pós-data foi tolerada pela lei, que não considerou inexistente, nem nulo, nem ineficaz, o cheque pós-datado; a aparência é a da pós-data, de modo que a solução nenhum óbice ofereceria à tutela dos possuidores de boa-fé”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, entende que o prazo de apresentação é ampliado, contando-se seu curso a partir da data consignada como de cobrança:

“Comercial. Falência. Cheque pré-datado. Executividade. Precedentes. Instrução de pedido de falência. Possibilidade. Recurso desprovido. I – A circunstância de haver sido aposta no cheque data futura traz como única consequência prática, no âmbito do direito privado, a ampliação real do prazo de apresentação. II – A aposição de data futura, por si só, não desnatura o cheque como título hábil a instruir o pedido de falência” (REsp n. 195748/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira Quarta Turma, j. 15-6-1999, *DJ*, 16-8-1999, p. 75).

“Cheque ‘pré-datado’. Apresentação antecipada. Responsabilidade civil. Precedentes da Corte. 1. Como já decidiu a Corte, a ‘prática comercial de emissão de cheque com data futura de apresentação, popularmente conhecido como cheque ‘pré-datado’, não desnatura a sua qualidade cambiariforme, representando garantia de dívida com a consequência de ampliar o prazo de apresentação’. A empresa que não cumpre o ajustado deve responder pelos danos causados ao emitente. 2. Recurso especial não conhecido” (REsp n. 237376/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 25-5-2000, *DJ*, 1-8-2000, p. 270).

“Comercial e processual civil. Cheque pré-datado. Prescrição. O cheque emitido com data futura, popularmente conhecido como cheque ‘pré-datado’, não se sujeita à prescrição com base na data de emissão. O prazo prescricional deve ser contado, se não houve apresentação anterior, a partir de trinta dias da data nele consignada como sendo a da cobrança. Recurso não conhecido” (REsp n. 620.218/GO, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 7-6-2005, *DJ*, 27-6-2005, p. 376). Ao fundamentar seu voto, o Ministro Relator escreveu: “Ora, a toda evidência, se se exige que o portador do cheque pré-datado aguarde, no mínimo, o prazo consignado no cheque como de apresentação, é curial que o prazo prescricional só terá sua contagem iniciada após findo o lapso de trinta dias, não da data da emissão, mas daquela avançada para a apresentação”.

Porém, em demanda de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que se deva contar o prazo da apresentação a data consignada no espaço destinado a data da emissão:

“Recurso especial representativo de controvérsia, direito cambiário e protesto extrajudicial. Cheque. Ordem de pagamento à vista. Cártula estampando, no campo específico, data de emissão diversa da pactuada para sua apresentação. Considera-se, para contagem do prazo de apresentação, aquela constante no espaço próprio. Protesto, com indicação do emitente do cheque como devedor, ainda que após o prazo de apresentação, mas dentro do período para ajuizamento de ação cambial de execução. Possibilidade. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: a) a pactuação da pós-datação

de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula; b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido” (REsp n. 1.423.464/SC, Rel. Min Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27-4-2016, *DJe* 27-5-2016).

b) Efeitos indenizatórios da pós-datação

Em outro campo de discussão, não mais quanto à prorrogação ou não do prazo de apresentação, mas quanto aos efeitos do descumprimento de cláusula nesse sentido, encontra-se a obrigação de indenizar por parte do apresentante que o faz de má-fé, em desobediência ao acordado com o emitente, conforme iterativa jurisprudência de nossos tribunais, representada pela Súmula n. 370, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: “Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado”.

c) Efeitos da não apresentação no prazo certo

De posse do cheque, o portador pode apresentá-lo ao banco para seu pagamento, devendo fazê-lo dentro do prazo da lei (art. 33) – trinta ou sessenta dias, conforme o caso. Se, entretanto, deixar transcorrer esse tempo, poderá ainda colocá-lo em cobrança bancária dentro do prazo de prescrição, que é de seis meses contados da data em que expirou o prazo para apresentação (art. 59). Havendo saldo, o banco não pode recusar o pagamento, conforme decorre do texto legal, em interpretação extensiva do art. 35, parágrafo único: “A revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do art. 59”. Significa dizer que não havendo revogação do cheque este pode ser pago até a data da ocorrência de sua prescrição.

Dentro desses dois intervalos – no prazo de apresentação e antes da ocorrência da prescrição – haverá distintas consequências na hipótese de recusa de pagamento:

(a) se a apresentação se der dentro do prazo legal (art. 33) o portador poderá

executar todas as pessoas que figuraram no título como coobrigados: emitente, avalista do emitente, endossantes anteriores e seus avalistas;

(b) se um dos coobrigados pagar o título, poderá reaver esse valor dos coobrigados anteriores, devendo promover ação de execução até seis meses contados do dia em que pagou o cheque ou, se o fez em Juízo, do dia em que foi demandado (art. 59, parágrafo único);

(c) se a apresentação ocorrer após o prazo previsto, somente poderá promover a execução do cheque em relação ao emitente e seus avalistas, perdendo o direito no tocante aos endossantes e seus avalistas (art. 47, II);

(d) contudo, também perderá o direito de executar o emitente se, nessa última hipótese (apresentação fora do prazo do art. 33) o emitente comprovar ter mantido saldo à disposição do portador, no valor da emissão do cheque, durante o período de apresentação, deixando de tê-lo posteriormente em razão de fato que não lhe seja imputável (art. 47, § 3º).

Em outras palavras, a execução do cheque contra os endossantes e avalistas somente é possível se o portador apresentou o cheque dentro do prazo previsto no art. 33 – trinta ou sessenta dias –, exigindo-se, ainda, a comprovação de que houve recusa do pagamento.

Em relação ao emitente e seus avalistas, a execução é possível desde que o cheque tenha sido apresentado dentro do prazo de prescrição – até seis meses depois do decurso do prazo para a apresentação e o emitente não tinha fundos suficientes no prazo de apresentação, conforme § 3º do art. 47.

A seguir, veremos que, expirado o prazo de apresentação em banco, por ocorrência da prescrição, ainda é possível sua cobrança em Juízo, por ações distintas à executória.

4.13. Ações judiciais

O direito brasileiro permite que o portador do título faça uso de vários instrumentos processuais visando receber o valor representado pelo cheque em seu poder.

A execução e o enriquecimento indevido são ações denominadas cambiais porque fundadas exclusivamente na relação cartular, que, dada a sua autonomia, restringem as defesas às hipóteses previstas na legislação do cheque. As duas ações cambiais estão previstas na Lei do Cheque, a primeira nos arts. 47 e 51-54 e a segunda, no art. 62. Podem participar das ações cambiais todas as pessoas que figuram no título, à exceção do sacado, que não se obriga, em momento algum, no título.

Além dessas duas, o portador pode valer-se de outras ações, denominadas causais, tais como a ação monitória, prevista nos arts. 700-702 do CPC15, *a* até *c*, na hipótese de o cheque que possui já não dispuser de eficácia executiva, por ter sido atingido pela prescrição ou, ainda, a cobrança judicial pelo rito ordinário, fundada em causa que deu origem à relação cambial.

As ações cambiais, portanto, pressupõem a higidez do cheque como título executivo, sendo accidental o ingresso na relação originária e as causais ingressam, necessariamente, na causa subjacente à relação jurídica entre o credor e o devedor.

É, ainda, possível ao próprio emitente ingressar com ações visando à nulidade do título, por inexistência de relação jurídica com o portador, ou a qualquer figurante do título promover ação visando indenização por falta ou deficiência do sacado no serviço bancário. Veja-se, neste caso, que o sacado pode ser acionado porque, embora não tenha se obrigado no título, responde por atos praticados no exercício de sua atividade bancária.

Capítulo 5

DUPLICATA

Sumário: 5.1. Origens. 5.2. Nota fiscal, fatura e duplicata – distinções, conceitos, natureza e espécies. 5.2.1. Nota fiscal. 5.2.2. Fatura. 5.2.3. Nota fiscal-fatura. 5.2.4. Duplicata. 5.2.5. Espécies de duplicatas. 5.3. Criação e requisitos. 5.4. Aceite. 5.4.1. Remessa. 5.4.2. Falta de aceite. 5.4.3. Não devolução da duplicata e protesto por indicação. 5.4.4. Motivos para a recusa. 5.5. Triplicata. 5.6. Fatura, conta e duplicata de prestação de serviços. 5.7. Endosso. 5.8. Aval. 5.8.1. Aval em branco, antes do aceite. 5.8.2. Aval posterior ao vencimento do título. 5.8.3. Aval e ação monitória. 5.9. Pagamento da duplicata. 5.9.1. Protesto. 5.9.2. Prazo para pagamento. 5.9.3. Pagamento antecipado. 5.9.4. Prorrogação de vencimento. 5.10. Duplicata escritural. 5.11. Ações fundadas na duplicata – incidência de juros e correção monetária. 5.12. Aspectos penais relacionados à duplicata.

5.1. Origens

As duplicatas em seus primórdios eram também chamadas, por força de sua definição legal, “contas assinadas”, expressão que evitava a homografia com a cópia de título de crédito (duplicata de letra de câmbio, duplicata de nota promissória, duplicata de cheque etc.), lembrando que a expressão “Das duplicatas” é o título da seção única do Capítulo V do Decreto n. 2.044/08, que trata das cópias das letras.

Sua origem, genuinamente brasileira²⁷, encontra-se no *art. 219 do Código Comercial Brasileiro*, em que se destaca a expressão pela qual ficou inicialmente conhecida: “Nas vendas em grosso ou por atacado entre comerciantes, o vendedor é obrigado a apresentar ao comprador por duplicado, no ato da entrega das mercadorias, a fatura ou *conta dos gêneros vendidos*, as quais serão por *ambos assinadas*, uma para ficar na mão do vendedor, e outra na do comprador. Não se declarando na fatura o prazo do pagamento, presume-se que a compra foi à vista. As faturas sobreditas, não sendo reclamadas pelo vendedor ou comprador, dentro de 10 (dez) dias subsequentes à entrega e recebimento, presumem-se contas líquidas”.

O art. 427 do *Código Comercial*²⁸ equiparava a conta assinada às letras de câmbio, provendo-lhe tratamento jurídico idêntico, permitindo sua cobrança judicial, o que se dava por meio de ação decendiária, assim chamada porque, no plano processual, o Regulamento n. 735 estabelecia em seu art. 249: “Na audiência seguinte à da citação do réu lhe serão assinados dez dias para pagar, ou para dentro deles alegar, por via de embargos, as exceções e defesa que lhe assistirem”.

Em 31 de dezembro de 1908, ao ser publicado, o Decreto n. 2.044 – a Lei Saraiva – revogou o Título XVI do *Código Comercial* (LS, art. 57), relativo às letras de câmbio, notas promissórias e créditos mercantis, em que constavam os arts. 354 a 427 e, assim, deixaram as contas assinadas de ter proteção da ação cambiária, mas, como se verá, não totalmente.

Pontes de Miranda (2000, 3:39-40) nos lembra que permanecia em vigor a Lei de Falências de então, o Decreto n. 917, de 24 de outubro de 1890, que no art. 2º arrolava, dentre as dívidas líquidas e certas que ensejavam pedido falimentar, “as contas, mercantilmente extraídas de livros de comerciante com as formalidades legais intrínsecas e extrínsecas, e verificadas judicialmente por peritos nomeados pelo juiz comercial em petição do credor” (alínea *h* do mencionado artigo). Trata-se da ação de verificação judicial de contas que permitia ao credor constituir título de crédito para fins falimentares e que persistiu em nosso sistema falimentar até a entrada em vigor da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Entretanto, o uso da verificação judicial restrito à lide falimentar não bastava para atender à necessidade do comércio, segundo bem relata Rubens Requião (1995:436): “Encontravam-se, assim, os comerciantes nacionais em face de um sério problema. As faturas ou contas assinadas perderam o efeito cambiário, sendo repelidas pelos bancos, que passaram a exigir, normalmente, para as operações de desconto, letras de câmbio ou notas promissórias com rigor cambiário do Decreto n. 2.044. O comércio, porém, não afeito à nova prática do título formal e abstrato, oferecia resistência às letras de câmbio e notas promissórias, dados seus rígidos efeitos jurídicos”.

Eunápio Borges (1975:205-206), também citado por Bulgarelli (1996:400-401),

resgata a história subsequente e registra que a reação das associações comerciais motivou o ressurgimento do vigor cambiário às contas assinadas, mediante a inserção na Lei Orçamentária n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, de dispositivo que autoriza o governo a equiparar as contas assinadas às letras de câmbio e notas promissórias²⁹. Com este primeiro passo, o movimento das associações comerciais finalmente, em 22 de maio de 1923, alcançou a criação da duplicata ou conta assinada, com a expedição do Decreto n. 16.041, que aprovou o “regulamento para a fiscalização e cobrança do imposto do selo proporcional sobre as vendas mercantis, a prazo ou à vista, efetuadas dentro do país”.

O art. 1º repete, com redação melhorada, o quanto consignava o revogado *art. 427 do Código Comercial*: “Nas vendas mercantis a prazo, efetuadas entre vendedor e comprador, domiciliados no território brasileiro, é obrigatória, no ato da entrega da mercadoria, a emissão da fatura ou conta, em duplicata, ficando o comprador com a fatura e o vendedor com a duplicata, depois de assinada por aquele”. No art. 14 o mencionado regulamento assegurava à duplicata os mesmos direitos cambiários previstos para a letra de câmbio e a nota promissória:

Art. 14. A duplicata pode ser protestada:

- a) obrigatoriamente – por falta de assinatura ou de devolução;
- b) facultativamente – por falta de pagamento.

§ 1º Nos casos da letra *a* deste artigo o protesto terá lugar dentro do prazo de 15 dias, subsequentes aos marcados nos arts. 6º e 7º, parágrafo único, garantidos ao credor, aos avalistas e aos endossatários os mesmos direitos e vantagens, assegurados pela Lei n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908.

O ressurgimento do renovado título recebeu duras críticas de Carvalho de Mendonça (1953, 6:it. 1461):

“Afluem, atualmente, ao desconto dos bancos as chamadas *duplicatas* ou *contas assinadas*, que mataram as letras de câmbio e as notas promissórias nas operações de compra e venda mercantil celebradas na República.

Deu-se-lhes para esse efeito o caráter cambial, submetendo-as às disposições da

Lei n. 2.044, de 1908, no que lhes fossem aplicáveis.

A confusão que se vai estabelecendo entre as *duplicatas* (que continuaremos a chamar *faturas* fiscais, originalidade brasileira, solicitada pelos *gros bonnets* do comércio, para enforcarem os compradores do interior, estando, porém, a servir de guilhotina para muitos deles) e as *letras de câmbio* é de tal ordem que passa como expressão corrente o *aceite* da *duplicata*, para significar a assinatura aposta no reconhecimento da exatidão do seu saldo!

Como se isso não bastasse, aí veio o abuso... Estamos vendo no giro comercial e bancário *duplicatas fictícias*, criadas especialmente para o desconto”.

Seguiram-se as alterações pelo Decreto n. 16.265, de 22 de dezembro de 1924, a Lei n. 187, de 15 de janeiro de 1936, e, finalmente, a que se encontra em vigor, Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968, com as modificações introduzidas pelo Decreto n. 436, de 27 de janeiro de 1969, e pela Lei n. 6.458, de 3 de novembro de 1977.

A luta vencida pelos comerciantes e associações comerciais, introduzindo proteção legal às contas assinadas, apesar da resistência de juristas do peso de Carvalho de Mendonça, encontra explicação no interesse de governo no peso que as vendas mercantis representavam na arrecadação fiscal. Rubens Requião (1995, 2:439) anota que: “O motivo real da implantação da duplicata de fatura foi o interesse tributário do Governo, como já se acentuou. A princípio, a arrecadação do imposto sobre vendas mercantis cabia à União, mas, com a discriminação de rendas da Constituição de 1934, passou à competência tributária dos Estados, com a denominação *imposto sobre vendas e consignações*. E a duplicata permaneceu como título de emissão obrigatória, pois era ela o veículo da arrecadação e fiscalização do imposto”.

Sérgio Shimura (2005:400) revela como convergiram os objetivos dos comerciantes e do fisco: “Procuravam os comerciantes do Rio de Janeiro e de São Paulo achar um documento com o qual pudessem movimentar o capital congelado em mãos do comprador, quando a venda fosse a prazo. Pretenderam e conseguiram um documento que, tendo como provisão a venda, transformava uma transação a prazo em recebimento à vista. Para alcançar este objetivo o comércio buscou o Estado e o

interessou na operação, oferecendo-lhe nova fonte de renda de que ele não cogitara. Acedeu o Estado. Acedendo, tornou obrigatória a emissão da duplicata e, correspondentemente, sua aceitação expressa, pela fatalidade da inutilização das estampilhas por via das quais o imposto se arrecadava”.

Com genialidade, Waldirio Bulgarelli (1996:400-402) classifica os períodos da evolução da duplicata em três fases, de acordo com a natureza que lhe foi comunicada pelas diversas legislações históricas: (1) como *título mercantil*, do *Código Comercial de 1850* até a promulgação do Decreto n. 2.044/08; (2) como *título fiscal*, da Lei Orçamentária n. 2.919, de 1914, até a Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968; e (3) *título bancário*, implantado pela Lei n. 5.474, que inclusive concedeu ao Conselho Monetário poderes para regulá-la e padronizá-la.

A primazia brasileira na criação da duplicata é registrada de forma unânime pela doutrina. Fran Martins (2010:425-431) salienta a influência da duplicata brasileira no surgimento de outros títulos assemelhados no direito estrangeiro: *stabilito di compravendita* (Itália), *trade acceptance* (Estados Unidos), extrato de fatura (Portugal), *conforme obligatorio* (Uruguai), *fatura conformada* (Argentina), fatura protestável (França) e fatura cambiária (Colômbia).

Com qualidades e natureza próprias, a duplicata é classificada como título cambial impróprio ou cambiariforme, como prefere Pontes de Miranda (2000, 3:37): “Razões de método levaram-nos a chamar títulos cambiariformes àqueles a que a lei atribui certa circulabilidade ao jeito das cambiais, tornando comuns alguns dos princípios comuns”.

5.2. Nota fiscal, fatura e duplicata – distinções, conceitos, natureza e espécies

Convém distinguir nota fiscal, fatura e duplicata, afastando toda e qualquer confusão que possa advir da linguagem comum desses termos por força do uso cotidiano.

5.2.1. Nota fiscal

Nota fiscal é o documento que comprova a entrada ou saída de mercadorias de

estabelecimento empresarial e acompanha sua entrega ao destinatário, contendo dados que identifiquem, para fins fiscais, a operação realizada, tais como nome e identificação fiscal do emissor e do destinatário da mercadoria, data de realização do negócio, base de cálculo, valor, alíquota, valor tributável etc. É documento comprobatório de realização de um fato sujeito à fiscalização tributária, relativo a coisas móveis ou semoventes.

Vê-se, pois, que a nota fiscal é documento de interesse dos órgãos de arrecadação tributária que comprova a ocorrência de fato sujeito a recolhimento de imposto.

5.2.2. Fatura

Fatura é “o documento representativo da venda já consumada ou concluída, mostrando-se o meio pelo qual o vendedor vai exigir do comprador o pagamento correspondente, se já não foi paga e leva o correspondente recibo de quitação” (cf. De Plácido e Silva, 1998:349).

Ampliando esse conceito, há de se acrescentar que a fatura, denominada também “conta de venda”(cf. Lei n. 187/36, art. 1º), refere-se a contratos de compra e venda mercantil e de prestação de serviços entre partes domiciliadas no território nacional e sua emissão, obrigatória para operações com prazo não inferior a trinta dias, destina-se à apresentação ao comprador da relação de mercadorias entregues ou despachadas ou, ainda, dos serviços prestados, contendo os valores que lhe são cobrados e as condições de pagamento.

Fran Martins (2010:433) prefere definir a fatura mercantil como “documento comprobatório de uma venda a prazo de mercadoria devendo, por isso, ser presente ao comprador, para a necessária conferência com as mercadorias remetidas”. Diga-se, entretanto, não de *uma* venda, mas, simplesmente, “de venda” porque a fatura pode incluir mais de uma “nota parcial”, conforme se lê do § 1º do art. 1º da Lei de Duplicatas.

Observe-se que as mercadorias podem ter seguido ao comprador em distintos momentos, acompanhadas individualmente do respectivo documento fiscal (nota ou cupom fiscal). A fatura discriminará “os números e valores parciais expedidos por

ocasião das vendas, despachos ou entregas de mercadorias” (LD, art. 1º, § 1º).

Nem sempre uma nota fiscal gerará uma fatura, como ocorre, por exemplo, em operações à vista ou com prazo inferior a trinta dias ou, ainda, em operações fiscais que não representam contratos de venda e compra ou de prestação de serviços.

Contudo, se o contrato se refere à compra e venda mercantil ou à prestação de serviços e o pagamento foi convencionado em prazo não inferior a trinta dias, a emissão da fatura é obrigatória. É possível, ainda, que uma fatura contenha várias operações fiscais (e notas) já realizadas.

5.2.3. Nota fiscal-fatura

É possível a emissão de nota fiscal simultânea com a fatura, o que é mais comum, sobretudo nos grandes centros e estabelecimentos de médio e grande portes.

É o que nos lembra Rubens Requião (1995, 2:441) ao mencionar convênio assinado entre o Ministério da Fazenda e as Secretarias Estaduais da Fazenda de 14 de dezembro de 1970. Adotando padrões para a emissão de documentos fiscais, o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF) deliberou emissão em documento único que recebe a denominação “nota fiscal-fatura”³⁰.

5.2.4. Duplicata

Duplicata é título de crédito causal que representa saque relativo a crédito oriundo de contrato de compra e venda mercantil, firmado entre pessoas domiciliadas no território nacional, a partir de discriminação de operações constantes de fatura expedida pelo emitente.

5.2.5. Espécies de duplicatas

Desse conceito é possível extrair as duas modalidades de duplicatas: a mercantil – oriunda de contrato de venda mercantil – e a de prestação de serviços, relativa a operações dessa natureza realizadas por empresários individuais, sociedades simples ou empresárias e fundações.

5.3. Criação e requisitos

São quatorze as indicações, em nove incisos, que devem ser inseridas na cártula (LD, art. 2º, § 1º) a qual se impõe, ainda, obedecer a normas de padronização formal fixadas pelo Conselho Monetário Nacional³¹:

DESCRIÇÃO	INCISO	REQUISITO
Identificação da duplicata	I	A denominação “duplicata”
		A data de emissão
		O número de ordem
Identificação da fatura	II	O número da fatura
Vencimento do título	III	A data certa do vencimento ou a declaração de ser duplicata à vista
Identificação dos contratantes	IV	O nome do vendedor
		O domicílio do vendedor
		O nome do comprador
		O domicílio do comprador
Valor	V	A importância a pagar, em algarismos e por extenso
Lugar de pagamento	VI	A praça de pagamento
Endossabilidade	VII	Cláusula à ordem
Aceite	VIII	A declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite cambial

Assinatura do sacador	IX	A assinatura do emitente
-----------------------	----	--------------------------

Os elementos de identificação da duplicata e da fatura (incisos I e II) destinam-se a distinguir o título de outras espécies cambiais (denominação duplicata), identificando-o (número de ordem) e relacionando-o com a respectiva fatura, em atenção ao que determina o art. 2º da Lei de Duplicatas (“No ato de emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial...”) e seu § 2º (“Uma só duplicata não poderá corresponder a mais de uma fatura”). A data da emissão é essencial para conferir a capacidade e poderes do emitente, verificar a regularidade sequencial que pode ser conferida com os livros do empresário, em especial o diário e o de registro de duplicatas e, ainda, analisar o andamento dos negócios, servindo, em especial, para os levantamentos das causas e demonstrações contábeis quando se fizer necessário, como ocorre, por exemplo, no pedido de recuperação judicial (LREF, art. 51, I e II).

O inciso III estabelece as modalidades possíveis de vencimento do título. Ao permitir que o vencimento se dê somente em data certa e à vista, o legislador excluiu a possibilidade de títulos a tempo certo da data ou de vista.

Aos dados de identificação das partes contratantes, previstos no inciso IV, acresce-se a exigência de documento de identificação fiscal (CPF ou CNPJ), prevista na Lei n. 6.268, de 24 de novembro de 1975, que impôs “a identificação do devedor pelo número de sua cédula de identidade, de inscrição no cadastro de pessoa física, do título eleitoral ou da carteira profissional” (art. 3º).

A importância a pagar (inciso V) é a que consta da fatura que deve considerar eventuais “abatimentos de preços das mercadorias feitos pelo vendedor até o ato de faturamento” (LD, art. 3º, § 1º).

O lugar de pagamento (inciso VI) é o convencionado pelas partes. O consumidor, contudo, pode alegar em Juízo, na discussão sobre o pagamento do título, a prevalência do lugar de seu domicílio, invocando o princípio de facilitação da defesa de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII), sobretudo se o título resulta de contrato de

adesão ou refere-se à duplicata não aceita. Há, contudo, de assentar que o legislador exige a determinação do lugar do pagamento no título; o fato de outro local resultar na discussão sobre a causa não acarreta sua nulidade, mas tão somente modificação de competência judicial.

A inserção da cláusula à ordem (inciso VII) reflete a finalidade da duplicata: “para circulação como efeito comercial” (LD, art. 2º). A menção à transmissibilidade por endosso evita dúvidas que poderiam ser suscitadas durante a circulação do título, sobretudo porque a vinculação do título à causa entre as figuras de criação – emitente e sacado – poderia afugentar eventuais interessados em sua circulação. A menção, ao lado da regra de identidade legislativa, à emissão, circulação e pagamento das letras de câmbio (LD, art. 25) oferece segurança jurídica aos endossatários, resguardados que ficam quanto à autonomia cambial.

Em relação ao inciso VIII, devemos observar que o aceite é obrigatório, contudo nem sempre estará lançado por escrito na cártula; sua inscrição gráfica não é indispensável para a formalização do título, bastando que a duplicata tenha sido protestada e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, conforme dispõe o inciso II do art. 15 da Lei de Duplicatas, encontrando-se esta solução assentada em pacífico e reiterado entendimento jurisprudencial: “1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução” (AgInt no AREsp n. 921.529/RS, Rel Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27-9-2016, *DJe* 30-9-2016).

Finalmente, a assinatura do emitente (inciso IX) identifica a responsabilidade do sacador, que passa a figurar como principal obrigado, na hipótese de o título não ser legitimamente aceito pelo sacado.

Os modelos regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, em número de seis, três pares³² referentes às duas espécies de duplicatas, obedecem a rígido regramento quanto à forma e dimensões (altura entre 148 e 152mm; largura entre 203 e 210mm). A LD (art. 24), contudo, permite constem outras indicações, não essenciais, desde que não alterem suas feições características. É o caso, por exemplo,

de identificações visuais, aplicação de marca, número de registro no Livro de Duplicatas, lugar de saque etc.

5.4. Aceite

Aceite é o ato de vontade materializado pela aposição de assinatura no título, mediante a qual o sacado concorda com a ordem do emitente da duplicata, tornando-se o principal responsável pelo pagamento da quantia nela expressa na data de seu vencimento.

5.4.1. Remessa

Emitida a duplicata, o sacador deve remetê-la ao sacado no prazo de trinta dias (LD, art. 6º, § 1º). Se o vendedor preferir fazer a remessa por intermédio de representantes ou instituições financeiras, estes terão o prazo de dez dias para apresentar o título ao sacado (LD, art. 6º, § 2º).

Recebida a duplicata, o comprador pode aceitá-la, lançando sua assinatura na cártula, ou recusá-la, fazendo declaração escrita das razões da falta de aceite, devolvendo, em qualquer caso, no prazo de dez dias (LD, art. 7º).

Com a concordância expressa da instituição financeira apresentante do título, o sacado pode reter o título em seu poder até o vencimento e, para tanto, deverá expedir comunicação por escrito notificando o aceite e a retenção (LD, art. 7º, § 1º). Isto é necessário porque, retido o título, a notificação o substitui na formalização do protesto ou na execução judicial (LD, art. 6º, § 2º).

5.4.2. Falta de aceite

Distintamente do que ocorre na letra de câmbio, em que a emissão do título não obriga o sacado que poderá deixar de lançar seu aceite e, conseqüentemente, não se vincular ao pagamento do título, na duplicata a obrigação pode estar comprovada pela assinatura do devedor ou de seu preposto, lançada no canhoto de entrega de mercadorias ou de recebimento do serviço. Neste caso, mesmo sem aceitar o título, o sacado obriga-se pelo valor expresso na duplicata. É o chamado aceite presumido.

O aceite na duplicata é sempre obrigatório, contrariamente ao que ocorre na letra de câmbio, em que é facultativo. Significa dizer que a recusa em aceitar a duplicata – deixando de assiná-lo ou de devolvê-lo – não gera efeitos liberatórios, como ocorre na letra de câmbio em razão da natureza causal do título e, assim, respaldado na realização de negócio de compra e venda mercantil ou em contrato de prestação de serviços. Demonstrada a realização do negócio, pela assinatura no canhoto da fatura, a recusa do sacado não altera a exigibilidade do título.

Verifica-se, pois, que o aceite na duplicata é ato com força de obrigatoriedade. À recusa injustificada do sacado a legislação provê o aceite presumido quando presentes os elementos comprobatórios da formação da causa da emissão (negócio subjacente).

5.4.3. Não devolução da duplicata e protesto por indicação

Se o sacado não devolve o título, nem tampouco comunica seu aceite e retenção, o título pode ser protestado por simples indicações fornecidas pelo emitente ou apresentante ao oficial do cartório de protestos (LD, art. 13, § 1º), acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço prestado.

A exigência de que a prova da entrega da mercadoria ou do serviço seja apresentada ao serviço de protestos decorre da dicção do art. 15, § 2º, da Lei n. 5.474/68, que permite a execução de duplicata não aceita e não devolvida, “desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo”, isto é, “(b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório de entrega e recebimento da mercadoria; e (c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º, desta Lei”.

Não é por outro motivo que, no Estado de São Paulo, a apresentação de duplicata sem aceite a protesto impõe que o credor e/ou o seu procurador apresentem ao oficial de protestos “os documentos que comprovam a venda e compra mercantil ou a efetiva prestação do serviço e o vínculo contratual que a autorizou, respectivamente, bem

como, no caso de duplicata mercantil, do comprovante da efetiva entrega e do recebimento da mercadoria que deu origem ao saque da duplicata” (Provimento n. 30, de 19 de dezembro de 1997, da E. Corregedoria-Geral da Justiça, alínea 11).

No tocante à duplicata de prestação de serviços, o Oficial de Registro de Protestos deve exigir prova do vínculo contratual e da efetiva prestação de serviços, como bem decidiu o Ministro Barros Monteiro: “Duplicata oriunda de prestação de serviços. Títulos desprovidos de Aceite. Protesto. Desatendimento dos requisitos legais. Nulidade da Execução. Indispensabilidade do protesto para aforar-se a execução, devendo do mesmo constar qualquer documento comprobatório do vínculo contratual e da efetiva prestação de serviços. Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 68.735/AM, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 25-10-1999, *DJ*, 17-12-1999, p. 370).

Esse entendimento persiste em julgados mais recentes: “1. A duplicata de prestação de serviços é, por sua natureza, título de crédito eminentemente causal, estando sua emissão subordinada à efetiva prestação do serviço que representa. 2. No caso, a retirada de parte dos materiais que compõem, junto com a mão-de-obra, o objeto do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, retira não apenas o substrato causal da duplicata, como também a sua liquidez, na medida em que o valor estampado na cártula não mais corresponde ao que foi efetivamente entregue ou empregado na obra, tornando o título inexigível. 3. Recurso especial improvido” (REsp n. 1169764/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, j. 24-10-2017, *DJe* 30-10-2017).

5.4.4. Motivos para a recusa

A recusa formal do sacado impede sua vinculação ao título, desde que legitimada nas hipóteses previstas na lei. Neste caso, o protesto não pode se efetivar, respondendo por danos tanto o emitente como o endossatário.

O legislador restringiu as hipóteses de recusa de aceite a três casos previstos no art. 8º da Lei de Duplicatas: (a) avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco; (b) vícios, defeitos e diferenças

na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados; (c) divergência no prazo e nos preços ajustados.

As alegações do comprador-sacado podem ser demonstradas por inúmeros meios de prova: laudos técnicos, notificação escrita com registro de seu recebimento, confronto da nota de pedido de encomenda com o documento fiscal de remessa etc.

A recusa de o vendedor aceitar o fundamento legal indicado pelo comprador pode dar margem a algumas soluções jurídicas: o emitente pode insistir no protesto do título e iniciar a execução judicial, cabendo ao sacado acautelar-se com medidas judiciais adequadas, sendo a mais comum ação de sustação de protesto, seguida por outras que busquem provimento judicial de inexistência de relação jurídica ou, ainda, o reconhecimento de danos a serem ressarcidos em razão da emissão irregular do título e seu protesto. Em se tratando de relação de consumo, o sacado que demonstrar a existência de vícios de quantidade e de qualidade pode valer-se das medidas previstas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, buscando, se preferir, o desfazimento do negócio e o ressarcimento dos prejuízos que sofreu.

5.5. Triplicata

Estudamos o escrito do emitente ou do apresentante contendo as indicações necessárias ao protesto do título (item 5.4.3). Contudo, para prover-se de instrumento adequado à execução judicial, o emitente deve extrair triplicata que, diz o art. 23 da Lei n. 5.474/68, “terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades” da duplicata extraviada ou perdida.

Fábio Ulhoa Coelho (2016:465) entende que, “a rigor, a lei autoriza o saque da triplicata apenas nas hipóteses de perda ou extravio”, considerando, contudo, lícita a emissão de triplicata para essa situação: “Em outros termos, na medida em que o credor pode remeter ao cartório de protesto o boleto com as indicações que individualizam a duplicata retida, também se admite que a triplicata veicule tais informações, tendo em conta inclusive que a fonte é a mesma: a escrituração mercantil do vendedor”.

Esse tem sido o entendimento da jurisprudência que classifica os casos do art. 23

como obrigatórios e os demais, como facultativos: “2. É pacífico na jurisprudência que se admitem triplicatas emitidas em razão da não devolução das duplicatas originalmente enviadas ao devedor. Interpretação extensiva do art. 23 da Lei n. 5.474/1968 (Lei das Duplicatas). [...] 4. A retenção das duplicatas deve ser presumida em face da entrega da mercadoria, cabendo ao devedor a prova da devolução” (REsp n. 1307016/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24-2-2015, *DJe*, 9-3-2015).

Com esse entendimento – obrigatoriedade nos casos do art. 23 e facultatividade nas demais hipóteses – consagrou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça outra consequência de natureza prático-processual: a desnecessidade de juntar triplicata para o exercício da ação de execução, entendendo-se que o credor possa valer-se tão só do instrumento de indicação, alçando o boleto bancário à posição de título executivo. Veja-se, por exemplo: AgRg no AREsp n. 218937/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28-2-2014, *DJe*, 28-2-2014.

Divergimos desse entendimento. O boleto bancário ou qualquer outro instrumento de indicação emitido para efeitos de protestos não é título executivo. Somente às duplicatas e às triplicatas se aplicam “os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das Letras de Câmbio” (LD, art. 25), não tendo o legislador conferido a mesma qualidade a outros documentos.

Quanto ao argumento de ser facultativa a extração de triplicata e, conseqüentemente, dispensável sua emissão para fins de execução, há de se atentar para a possibilidade de a facultatividade nos conduzir a outra conclusão. Embora a lei não determine a obrigatoriedade de emissão de triplicata nos casos que não correspondam à perda ou extravio de duplicata, conforme dispôs o art. 23 da Lei de Duplicatas, se o credor pretender proceder à execução de seu crédito, somente poderá fazê-lo se extrair novo título – a triplicata – porque a lei não admite outra forma.

Explica-se. O legislador restringiu o processamento de execução a tão somente duas modalidades de títulos: “duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida” (art. 15, § 2º), conforme deflui do texto legal: “Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido

protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo”. Verifica-se que a menção às “indicações do credor” é respeitante ao protesto, não permitindo entender que substituem o título na ação judicial. A lei não lhes dá tal extensão.

Ou seja, para efeito de protesto é de admitir tanto a triplicata – documento com maior rigor formal – como também o escrito contendo as indicações do crédito, em geral sob forma de “boletos bancários” ou papel equivalente. Para a execução, contudo, desaparece a identidade entre ambos porque somente a triplicata é título executivo.

Enfim, boleto bancário não é título executivo extrajudicial, conquanto na prática comercial faça-se passar por triplicata, emissão que, a satisfazer o rigor formal, exigiria a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 2º da Lei n. 5.474/68, substituindo-se a denominação duplicata por triplicata e, assim, atendendo à forma legal.

5.6. Fatura, conta e duplicata de prestação de serviços

Algumas particularidades marcam a distinção entre o regime da duplicata mercantil e o da prestação de serviços. Contudo, não há nenhuma dificuldade em proceder às adaptações das disposições relativas à fatura e à duplicata mercantil, como determina o art. 20, § 3º, da Lei de Duplicatas. São poucas as observações a serem consideradas.

Em primeiro lugar há de se entender a abrangência subjetiva da autorização para emitir faturas e duplicatas de prestação de serviços. O legislador facultou a emissão às empresas individuais, às sociedades simples e às empresárias que prestam serviços de qualquer natureza, bem como às fundações (LD, art. 20).

As empresas, individuais e coletivas, as sociedades simples e as fundações expedirão fatura dos serviços prestados e, sobre ela, a duplicata, tal como ocorre com a duplicata mercantil.

Os profissionais liberais e prestadores de serviços ocasionais, mesmo sem o registro de empresa individual, podem emitir fatura ou conta de serviços, mas não

duplicata de prestação de serviços (LD, art. 22). Estes profissionais devem extrair conta de serviços que contenha dados da natureza e do valor dos serviços prestados, data e local do pagamento e o vínculo contratual que deu origem aos serviços executados (LD, art. 22, § 1º), levando-a para registro no Cartório de Títulos e Documentos para posterior remessa ao devedor (LD, art. 22, § 2º). Não há, neste caso, emissão de duplicata, mas tão somente de conta de serviços que representa o vínculo obrigacional, a efetiva prestação e é título executivo, desde que acompanhado do instrumento de protesto (LD, art. 22, § 3º).

A duplicata de prestação de serviços e a conta de serviços equiparam-se à duplicata mercantil para todos os efeitos, inclusive para requerer a falência do devedor. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir pedido de falência” (Súmula 248).

Enquanto na duplicata mercantil se exige comprovante de entrega de mercadoria, o que em regra se faz pela apresentação do canhoto ligado à nota fiscal ou fatura, no regime da duplicata de prestação de serviços qualquer documento que comprove a efetiva prestação dos serviços e o vínculo obrigacional que a autorizou é apto para transcrição do instrumento no registro de protesto (LD, art. 20, § 3º).

Os fundamentos da recusa ao aceite à semelhança das causas admitidas para a duplicata mercantil são três, previstos no art. 21, a saber: (1) não correspondência com os serviços efetivamente prestados; (2) vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, devidamente comprovados; e (3) divergências nos prazos e nos preços ajustados. Resumem-se, pois, em: ausência de causa, vícios ou defeitos e divergências de preço e prazo.

5.7. Endosso

A duplicata é, ao mesmo tempo, título causal e à ordem, isto é, liga-se, na origem, a um negócio de compra e venda mercantil e mantém a mais importante característica das cambiais: é endossável e apto à circulação de crédito. Navegaria, pois, entre a causa que lhe deu origem e a ausência (abstração) dessa causa durante seu percurso

circulatório.

Por esta razão, muito lucidamente, Pontes de Miranda (2000, 3:91) afirma que “o título faz-se abstrato com o endosso, ou com o aceite. Com o endosso, que pode ser antes do aceite, o endossatário providencia para que seja apresentado para aceite, ou, se à vista, para aceite-pagamento. Antes do aceite, não há ação cambiária – executiva ou não – contra o comprador, pela duplicata mercantil”.

Surge, então, a questão relativa ao endosso de duplicata não aceita e, em especial, à posição dilemática do endossatário, portador do título que, para fazer valer seu direito contra os endossantes e respectivos avalistas, terá que tirar o protesto dentro do prazo de trinta dias, contado da data de seu vencimento (LD, art. 13, § 4º), mas, ao protestar, poderá ser responsabilizado por danos causados ao sacado não aceitante do título (v. item 5.4.4, em especial jurisprudência mencionada) e, ainda, recentemente:

“Ação de indenização. Duplicata. Protesto de título pago. Instituição financeira. Legitimidade. Precedentes do STJ. Danos morais. Valor. Alteração. I – A instituição financeira que desconta duplicata e a leva a protesto por falta de aceite ou de pagamento está legitimada passivamente à ação do sacado. Precedentes do STJ. II – O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser alterado quando irrisório ou muito elevado, o que não acontece no caso. Agravo improvido” (AgRg no Ag 585.849/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, j. 15-2-2005, *DJ*, 7-3-2005, p. 243).

Se o protesto é necessário – para garantia do direito do portador contra o sacador, endossantes e seus avalistas – e se há que cuidar para que o sacado não aceitante não seja prejudicado, a solução jurisprudencial encontrada no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, no sentido de omitir o nome do sacado, é adequada e foi reiteradamente aplicada (Processo: 842378-9. Relator: Oséas Davi Viana. Órgão Julgador: 4ª Câmara. Data do julgamento: 12-3-2003; Processo: 402098-6. Relator: Marcondes Machado. Órgão Julgador: 3ª Câmara. Data do julgamento: 10-5-1989; Processo: 410846-7. Relator: Alexandre Germano. Órgão Julgador: 8ª Câmara. Data do julgamento: 26-4-1989; Processo: 407066-4. Relator: Carlos Roberto Gonçalves. Órgão Julgador: 6ª Câmara. Data do julgamento: 15-8-1989). Sérgio Shimura

(2005:407) chega à mesma conclusão, ao analisar situação em que um banco se encontrava na posição de endossatário de duplicata não aceita: “Significa dizer que o banco tem de levar o nome do endossante-sacador, com a omissão do nome do sacado, sob pena de a instituição financeira responder pelos danos causados ao último”.

A solução apresentada é jurídica e evita confundir causa subjacente – entre sacado e sacador e a consequente natureza causal do título – com a subsequente abstração, mantendo plena a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções contra o portador de boa-fé. Por outro lado, omitindo o nome do sacado, o portador de boa-fé vê-se resguardado contra possíveis ações de ressarcimento pelo prejuízo causado à imagem do devedor não aceitante.

O valor jurídico é, sobretudo, apreciado porque garante os efeitos cambiais da duplicata simulada, em benefício dos portadores de boa-fé, respondendo adequadamente à perplexidade que se levanta contra os que, sustentando a causalidade absoluta da duplicata, optam por entender que se assim emitida não pode ser admitida como título de crédito. Resposta que Waldirio Bulgarelli (1996:405) replica em tom questionador: “Convém não esquecer, a tal propósito, que emitida uma duplicata simulada e endossada pelo emitente, se viesse a não ser considerada duplicata, e, portanto, título de crédito, o endossatário, terceiro de boa-fé, perderia então o seu direito de receber o valor do título do endossador e eventuais avalistas?”.

5.8. Aval

Quanto ao aval, aplicam-se à duplicata as mesmas regras relativas à letra de câmbio (v. item 2.5.4), observando-se que pode ser lançado, em preto, com a indicação da pessoa a quem se dá a garantia ou, ainda, em branco, assegurando obrigação, neste caso, da pessoa que se encontra acima de sua assinatura ou, na falta desta, da pessoa do comprador (LD, art. 12).

5.8.1. Aval em branco, antes do aceite

Em regra o aval é dado depois do lançamento da assinatura do avalizado, não

sendo proibido, entretanto, que se faça antes, como expressamente permite o art. 14 da Lei n. 2.044, de 1908. Neste último caso – aval lançado antes da assinatura do avalizado – é denominado “aval antecipado”. É o que acontece, no mencionado dispositivo da Lei de Duplicatas, com a expressão “ao comprador”.

Atente-se que o comprador – sacado – pode não ter aceitado o título quando do lançamento de assinatura de terceiro que não é sacador ou endossante.

Aqui repousa diferença de tratamento entre a letra de câmbio e a duplicata. Na primeira a assinatura lançada sem indicação por quem se dá somente pode ser considerada como sendo a do avalista do sacador, como decorre do art. 30 da Lei Uniforme. A lei brasileira que antecedeu a Lei Uniforme deu tratamento diferente. O art. 15 da Lei n. 2.044, de 1908 (Lei Saraiva), distingue duas situações: (a) se o título estivesse aceito, o aval seria considerado dado ao aceitante, e (b) se não aceito, ao sacador: “O avalista é equiparado àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, àquele abaixo de cuja assinatura lançar a sua; fora desses casos, ao aceitante e, não estando aceita a letra, ao sacador”.

A lógica da Lei Saraiva, omitida pela Lei Uniforme (art. 31) e pela Lei de Duplicatas (art. 12), envolve a vinculação do sacado que, se ainda não se obrigou, também não obrigará terceiro por seu inexistente inadimplemento obrigacional.

Desse entendimento, contudo, afastou-se o legislador da Lei de Duplicatas e ac mencionar “ao comprador”, no art. 12, quis indicar que o aval é dado àquele que figura na fatura como destinatário da mercadoria ou do serviço prestado, mesmo que ainda não tenha aceitado o título emitido, quando então se torna “aceitante”. Evita-se com a omissão das expressões “sacado” ou “aceitante” qualquer menção à vinculação ao título e, assim, não havendo indicação a quem se dá o aval e tampouco assinatura acima do aval lançado, presume-se que foi dado ao *comprador*, aceitante ou não da duplicata.

Pontes de Miranda (2000, 3:277) elucida a questão: “Se a duplicata mercantil, ainda não aceita, tem assinatura acima, ou ao lado da assinatura do vendedor-subscritor, entende-se avalizado o comprador. Se esse vier a aceitar, torna-se eficaz o aval, que existia, valia e apenas não era eficaz”.

5.8.2. Aval posterior ao vencimento do título

Quanto ao momento de sua inscrição, ainda, deve-se observar, como regra geral para os títulos de crédito, o lançamento *antes do vencimento do título*, pois, segundo alguns doutrinadores entendem, o aval, por definição, refere-se à garantia de pagamento de uma letra, durante seu ciclo cambial.

É a opinião de Carvalho de Mendonça (1953, 5:329-330):

“O aval pode ser dado desde o momento da emissão até o dia do vencimento da letra de câmbio; nunca depois deste dia, porque, visando garantir o pagamento no vencimento, perderia a sua função única. Diferente é o caso do endosso, com a sua dupla função, indicada no n. 676, *supra*.

O aval posterior ao vencimento supõe-se não escrito. Que garantiria ele?

Nem se objete que o título se extingue com o pagamento e não com o vencimento. Certamente assim é, mas a superveniência do vencimento sem o pagamento altera-lhe profundamente o caráter (Sorani, *Della cambiale*, 2. ed., v. 2, § 309).

‘Saraiva entende que o aval, prestado depois do vencimento, se não produz efeitos cambiais, vale como fiança, civil ou comercial, conforme a hipótese’³³. Esta interpretação não nos parece aceitável. A Lei n. 2.044, de 1908, a repele, porque não considera o aval como fiança. Além disso, seria impossível, porque a fiança civil ou comercial não se constitui por essa forma”.

Modernamente, filia-se a esta posição Waldirio Bulgarelli (1996:174): “O aval pode ser dado *antes do vencimento*, pois se for posterior ao vencimento – já que o título cessou seu ciclo cambial – não valerá como aval, podendo ser considerado, quando muito, fiança (se tiver as condições exigidas pela Lei Civil ou Comercial para isso)”.

Há, contudo, divergência doutrinária, não menos importante.

É o magistério de Pontes de Miranda (2000, 1:374), para quem haveria grande confusão nesse entendimento: “(...) os direitos cambiários e as dívidas cambiárias ainda estão de pé, ainda há ação cambiária a ser proposta; se está encerrada a vida

circulatória do título cambiário, razão por que o endosso após o vencimento não vale *cambiariamente*, e só tem efeitos civis, não se pôs termo à sua vida jurídica. Demais, não se pode tratar o aval como se trata o endosso: o aval só exige que exista a obrigação cambiária; do contrário teríamos obrigação cambiária não suscetível de segurança cambiária (...)

E prossegue Pontes de Miranda (2000, 1:375), distinguindo o momento em que se dá o aval tardio: (a) é eficaz se dado após o vencimento e antes da apresentação, porque ainda não surgiu a obrigação; (b) se não houve protesto no tempo certo, perdeu-se o direito de regresso contra os codevedores e, assim, não haveria sentido falar-se em aval de dívida preclusa; (c) se o aval é dado ao aceitante ou avalista deste, mesmo posterior ao vencimento, o aval é eficaz porque ainda não se exerceu a pretensão cambiária; (d) se, entretanto, já proposta a ação cambial, o aval deixa de ter qualquer eficácia cambiária.

Para espancar qualquer dúvida a respeito do aval lançado posteriormente ao vencimento da duplicata, o legislador introduziu parágrafo único no art. 12 da Lei n. 5.474/68: “O aval dado posteriormente ao vencimento do título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência”. Cujas redações se completam: salvo se o aval for dado a favor de devedores de regresso que foram desonerados por falta de protesto tempestivo (art. 13, § 4º) ou posteriormente à proposição de ação de cobrança ou de execução relativa ao título porque será outra espécie de garantia, prestada no curso de processo.

5.8.3. Aval e ação monitória

Ampla discussão foi travada nos Tribunais no que respeita à figura do avalista na reconstituição da obrigação por força de tutela jurisdicional concedida em ação monitória, vindo a ser proferidos julgados em ambos os sentidos no 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: alguns entendiam que o avalista podia ser sujeito passivo de ação monitória (Processo: 1.308.174-4. Relator: Gomes Corrêa. Órgão Julgador 4ª Câmara; Processo: 0844108-5. Recurso: Apelação. Origem: Santo Anastácio Julgador: 8ª Câmara. Julgamento: 21-5-2003. Relator: Juiz Carlos Alberto Bondioli)

e outros, em sentido oposto (Processo: 0818000-1. Recurso: Apelação. Origem: Jacareí. Julgador: 4ª Câmara. Julgamento: 9-5-2001. Relator: Rizzatto Nunes Processo: 1142709-1. Recurso: Agravo de Instrumento. Origem: São Paulo. Julgador: 6ª Câmara. Julgamento: 4-2-2003), sob o fundamento de que, prescrita a execução do título, desaparece a garantia cambial.

O STJ, em recente decisão, reconheceu a legitimidade do avalista para responder a ação monitória, sob o fundamento de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o credor exija o crédito tanto do devedor principal como do coobrigado (no caso avalistas)”. A ementa encontra-se assim redigida: “Agravo interno no agravo em recurso especial. Processual civil (CPC/73). Ação monitória. Nota promissória. Legitimidade passiva. Reconhecida. Avalista como devedor solidário. Súmula 26/STJ. Prescrição. Prazo quinquenal. Precedentes. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 948.348/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 5-6-2018, *DJe*, 8-6-2018).

5.9. Pagamento da duplicata

5.9.1. Protesto

Na criação da duplicata o sacador é obrigado a indicar uma data certa de vencimento, como, por exemplo, 18 de dezembro de 2007, ou declarar que se trata de vencimento à vista (LD, art. 2º, III). Na primeira hipótese, o título é remetido para aceite, nos prazos já indicados *supra*, e deve ser devolvido em até dez dias contados da data da apresentação, salvo concordância em sentido contrário do apresentante, no sentido de retê-lo até a data do vencimento; na segunda hipótese – vencimento à vista – o título é remetido para pagamento, sendo desnecessária a apresentação para aceite.

O mecanismo da duplicata permite realizar protesto em três circunstâncias, sempre no lugar designado para pagamento, conforme o direito que o titular do crédito pretenda ver preservado (LD, art. 13): (a) se a duplicata não for devolvida, é possível, ao sacador, extrair triplicata ou apresentar ao oficial do cartório indicações que permitam o protesto por falta de devolução; (b) se o título for devolvido sem aceite, cabe-lhe interpor o protesto por falta de aceite; e, finalmente, (c) vencido o

título, sem que ocorra o pagamento, cabe ao portador tirar o protesto, devendo fazê-lo em até trinta dias da data de seu vencimento, sob pena de perder o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas.

O protesto por falta de aceite e o protesto por falta de pagamento dispensam a apresentação da duplicata ao pagamento. É o que sustentam Fran Martins (2010:453) e Rubens Requião (1995, 2:453), invocando a regra da quarta alínea do art. 44 da Lei Uniforme de Genebra.

Para esses autores, o dispositivo da Lei Uniforme (Decreto n. 57.663, de 24 de janeiro de 1966) não contrasta com a regra do art. 13, § 2º, da Lei de Duplicatas – “O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento”.

Fran Martins assim justifica sua posição: “Estando em vigor a Lei n. 5.474 com normas especiais regulando a duplicata, mas dispondo o art. 25 dessa lei que a tal título são aplicados os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das letras de câmbio, não tem mais vigência, segundo nos parece, o disposto neste § 2º do art. 13, pois o protesto está ligado diretamente, no caso, ao pagamento do título, sendo de aplicar-se, assim, o contido no art. 44 da Lei Uniforme e não mais o que expressamente reza o citado parágrafo 2º do art. 13 da Lei n. 5.474”.

Rubens Requião, invocando o Decreto-lei n. 436, de 27 de janeiro de 1969, que alterou o § 2º da Lei de Duplicatas, entende que é o caso de aplicação subsidiária da Lei Uniforme: “Desfaz o Decreto n. 436 dúvida antiga, se a falta de protesto de título por falta de aceite ou devolução obstaculiza o protesto por falta de pagamento, dispondo que o fato de não ter sido protestado o título por aqueles motivos não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Mas ao revés, invocando subsidiariamente a lei cambial uniforme, devemos lembrar que o protesto por falta de aceite *dispensa* a apresentação ao pagamento e o protesto por falta de pagamento (art. 44 da Lei Uniforme)”.

Os fundamentos do jurista paranaense convencem. Não há contradição entre os dispositivos mencionados. De um lado, a Lei de Duplicatas tutela o titular de crédito

que detém título não devolvido ou não aceito: a não realização de protesto por falta de aceite ou de devolução não afasta a possibilidade de, até trinta dias do vencimento, esse mesmo título ser protestado por falta de pagamento, permitindo ao portador conservar o direito contra os coobrigados solidários – endossantes e respectivos avalistas. De outro, realizado o protesto por falta de aceite, dispensa-se o protesto por falta de pagamento, isto é, o portador, vencido o título, mesmo sem novo protesto, conserva o direito contra os devedores de regresso.

Parece-nos claro que o protesto é sempre indispensável em duas hipóteses: (a) para prover o portador de condição necessária à execução do título, no caso de o título não ter sido aceito (LD, art. 15, II), e (b) para evitar a perda do direito de regresso em relação aos endossantes e respectivos avalistas (LD, art. 13, § 4º). Para tais fins torna-se suficiente a promoção de um só protesto – um ou outro – realizado até trinta dias da data de vencimento.

5.9.2. Prazo para pagamento

O pagamento da duplicata à vista deve ser feito no momento de sua apresentação; quanto à duplicata com vencimento em data certa, o pagamento deverá ser realizado na data indicada.

A lei indica três formas de se provar o pagamento: (a) recibo lançado no próprio título; (b) documento de recebimento em separado, com referência expressa à duplicata; e (c) liquidação de cheque no qual conste, no verso, que seu valor se destina à amortização ou liquidação da duplicata nele caracterizada (LD, art. 9º, §§ 1º e 2º). Com tais delineamentos, contudo, a lei não esgota a matéria relativa à prova quanto à extinção da obrigação cambial que pode ser demonstrada por inúmeros outros meios, como novação, dação em pagamento, compensação, confusão, remissão etc.

5.9.3. Pagamento antecipado

Permite o art. 9º da Lei de Duplicatas alterarem-se os momentos de pagamento, autorizando ao comprador resgatar a duplicata “antes de aceitá-la ou antes da data do

vencimento”.

Pontes de Miranda (2000, 3:310) adverte que, no tocante às duplicatas, o pagamento antecipado somente tem validade se realizado antes do aceite, incidindo, depois dele, a regra geral das cambiais, prevista na Lei Uniforme de Genebra (art. 40) e na lei brasileira (LS, art. 22).

Os mencionados dispositivos declaram que o portador não é obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra. Pontes de Miranda (2000, 1:476-477) explica a *ratio legis*: “O fundamento disso está em que toda antecipação de pagamento é contra os hábitos; e pode ser nociva a direitos de outrem, principalmente do que se venha evidenciar como legítimo possuidor do título. Em relação ao possuidor de boa-fé, que recebeu o pagamento antecipado, é sempre existente e eficaz esse. Não assim em relação a outros possuidores, ou a outros titulares de direitos cambiários, devendo renovar-se, eventualmente, *e.g.*, se o que tinha a posse não era o legítimo possuidor, se se pagou ao incapaz, se a letra de câmbio fora emitida em branco e enchida abusivamente. Como se vê, é bem perigoso antecipar o pagamento de títulos cambiários, pois não se pode alegar, sequer, a boa-fé. O sacado, ainda que não aceitante, pode ter motivos para não querer pagar antes do vencimento. É provável que aguarde ordens do sacador, até o momento de vencer-se a letra de câmbio. Chegado o vencimento, já o sacador não lhe pode mais dar instruções. Se aceitou a letra, obrigou-se por si”.

Veja-se que até o vencimento do título algumas situações podem dar margem à legítima oposição ao pagamento, como, por exemplo, o extravio – desapossamento violento ou por erro, dolo etc. – que, então, se encontra em poder de portador de má-fé ou de terceiro a quem foi repassado. A antecipação de pagamento retira do verdadeiro credor oportunidade para municiar-se com instrumentos legais necessários à anulação do título.

Outros exemplos: a pessoa a quem se pagou antecipadamente tem sua falência decretada e a massa é a legítima titular do crédito e pretende receber o pagamento na data do vencimento; o devedor é empresário que vem a ser declarado falido; o pagamento antecipado dentro do termo legal é ineficaz em relação à massa (LREF,

art. 129, I).

O art. 36 da Lei Uniforme possibilita ao legítimo titular da letra o direito de “requerer ao juiz competente do lugar do pagamento, na hipótese de extravio, a intimação do sacado ou do aceitante e dos coobrigados, para não pagarem a aludida letra, e a citação do detentor para apresentá-la em Juízo, dentro do prazo de três meses”.

Não é por outra razão que as mencionadas leis cambiais advertem quanto aos riscos decorrentes de pagamento de letra não vencida: “Se o sacado paga a cambial antecipadamente o faz sob sua responsabilidade”.

5.9.4. Prorrogação de vencimento

Por declaração em separado ou escrita na duplicata, o endossatário, o vendedor ou seus mandatários com poderes especiais podem reformar ou prorrogar o prazo de vencimento (LD, art. 11). Para validade contra os devedores de regresso deve obter anuência expressa de todos os endossantes e avalistas que intervieram no título. Se algum deles não declara sua concordância fica desobrigado, retirando-se da cadeia obrigacional.

5.10. Duplicata escritural

A Lei n. 13.775, de 20 de dezembro de 2018, dispôs sobre a emissão da duplicata sob a forma escritural, o que ocorre pelo simples lançamento em sistema eletrônico.

O lançamento deve ser feito por entidades autorizadas pelo Poder Público quando não o for por órgão ou entidade da administração federal. A escrituração do título abrange a apresentação, o aceite, a devolução e a formalização da forma de pagamento, o controle de transferência de titularidade, a prática de atos cambiais sob a forma escritural (como, por exemplo, aval e endosso), a inclusão de indicações, informações ou de declarações referentes à operação com base na qual a duplicata foi emitida ou ao próprio título e de informações a respeito dos ônus e gravames constituídos sobre as duplicatas.

A legislação autoriza expressamente a Central Nacional de Registro de Títulos e

Documentos a exercer essa atividade. Trata-se de plataforma criada pelos diversos serviços registraes, com fundamento no que dispõem os arts. 37 a 39 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009.

Realizado o registro escritural da duplicata, qualquer solicitante pode requerer aos gestores do sistema a expedição do extrato, em forma física ou eletrônica, desse registro, contendo os dados previstos no art. 6º, § 1º, do diploma regulamentador:

“I – a data da emissão e as informações referentes ao sistema eletrônico de escrituração no âmbito do qual a duplicata foi emitida;

II – os elementos necessários à identificação da duplicata, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968;

III – a cláusula de inegociabilidade; e

IV – as informações acerca dos ônus e gravames”.

Ambos – a duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato dela emitido – são títulos executivos extrajudiciais, devendo o portador demonstrar, na execução, o que dispõe o art. 15 da LD, conforme acima exposto (v. 5.4.3), aplicando-se, ainda, no que couber, a legislação de regência comum às duplicatas, inclusive no que se refere ao protesto do título.

Consequência do sistema registral é a simplificação da prova de entrega de mercadoria e a de pagamento do título. Para tanto, a Lei n. 13.775/18 estabelece que o sistema eletrônico “disporá de mecanismos que permitam ao sacador e ao sacado comprovarem, por quaisquer meios de prova admitidos em direito, a entrega e o recebimento das mercadorias ou a prestação do serviço, devendo a apresentação das provas ser efetuada em meio eletrônico” (art. 4º, § 3º) e, ainda, que a prova de pagamento, total ou parcial, pode ser feita por “qualquer meio de pagamento existente no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro” (art. 5º).

A previsão traz economia ao processo judicial, nas ações relativas às cobranças e nas defesas relacionadas à emissão e à circulação de duplicatas.

5.11. Ações fundadas na duplicata – incidência de juros e correção monetária

As ações cambiais foram estudadas no capítulo relativo às letras de câmbio, restando tão somente analisar a questão relativa à fluência de juros de mora que para Fábio Ulhoa Coelho (2016:466-467) devem incidir a partir do protesto do título e não de seu vencimento, como ocorre com as cambiais próprias.

O fundamento do insigne professor paulista invoca o art. 40 da Lei n. 9.492/97 (Lei de Protestos), que dispõe: “Não havendo prazo assinado, a data do registro de protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida”. As notas promissórias e as letras de câmbio estariam regidas por outra regra (juros de 6% desde a data do vencimento, LUG, art. 48, 2º), bem como os cheques (desde a data da apresentação, LC, art. 52, II).

No tocante à forma de incidência da correção monetária aplicável aos títulos executivos – classificação em que a duplicata se inclui –, não há tratamento distinto porque a regência estaria em outra legislação, Lei n. 6.899/91, abrangendo as duplicatas.

No entanto, quanto aos juros, sustenta Fábio Ulhoa que a omissão da Lei de Duplicatas de disposição semelhante à encontrada nos mencionados diplomas legais conduz à aplicação da regra geral, prevista na Lei de Protestos: a data de protesto é o seu termo inicial.

Lembramos, entretanto, que o art. 25 da Lei de Duplicatas determina a aplicação dos dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das letras de câmbio, devendo-se observar que a regra do art. 48 a respeito dos juros encontra-se no Capítulo VII, que trata “da ação por falta de aceite e falta de pagamento” expressão que, a nosso ver, submete-se ao gênero “pagamento” e, portanto, aplicável às duplicatas.

A jurisprudência reflete este último entendimento:

“Duplicata. Pagamento em cartório. Juros moratórios. Fluência desde o vencimento do título. Ação de cobrança. Pago o título em cartório de protesto, sem correção e juros moratórios, o credor pode propor ação de cobrança para haver essas duas

parcelas, sendo que tanto a atualização monetária (REsp n. 117.704/SE, REsp 30.104/SP) como os juros devem ser contados desde a data do vencimento do título líquido e certo (arts. 48 da Lei Uniforme e 25 da Lei n. 5.474/68) até o dia do pagamento em cartório. A quantia assim apurada será passível de nova atualização, até o final pagamento, a que se somam os juros moratórios, estes contados da citação para a ação de cobrança (art. 219 do CPC). Recurso conhecido e provido (REsp n 197.294/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 23-2-1999, *DJ*, 29-3-1999, p. 190)”.

“Duplicatas pagas em cartório. Incidência de correção monetária e juros devidos pelo credor, desde a data do vencimento até a quitação. Dissídio. Aplicação da súmula 83 do STJ. 1. Tendo os devedores efetuado o pagamento dos títulos em cartório, a quitação dada pelo oficial de protestos não impede a cobrança pelo credor das parcelas correspondentes à correção monetária e juros, devidos desde os vencimentos respectivos. 2. Pacificada a matéria no âmbito das duas turmas que compõem a 2ª seção deste Tribunal Superior, a divergência não há de ser conhecida. Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido” (REsp n 204.253/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21-8-2008, *DJe*, 1-9-2008).

5.12. Aspectos penais relacionados à duplicata

A emissão de duplicata simulada é crime previsto no art. 172 do Código Penal e, em se tratando de empresário falido – individual ou sociedade empresarial –, poderá sujeitar-se às penas do art. 168 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 – fraude a credores.

O art. 172 do Código Penal dispõe, na redação que lhe deu a Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990: “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena – detenção, de dois a quatro anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do Livro de Registros de Duplicatas”.

Na redação anterior, não havia punição para a emissão da fatura ou da nota de venda simulada, mas tão somente à duplicata: “Expedir ou aceitar duplicata que não corresponda, juntamente com a fatura respectiva, a uma venda efetiva de bens ou a uma real prestação de serviços”.

Fábio Ulhoa (2016:460) concluiu que “a mudança na redação do tipo do art. 172, operada pela Lei n. 8.137/90, porém, substituiu o bem jurídico protegido. A partir dela, crime passou a ser expedir duplicata *em desacordo com a mercadoria vendida*. Desse modo redirecionou-se, para amparar não mais o crédito, e sim os consumidores. Emitir duplicata sem causa, desde então, não é mais conduta típica”.

Celso Delmanto, Roberto Delmanto e Roberto Delmanto Junior (1998:354-355) rejeitam esse entendimento:

“(…) A nosso ver, embora o novo texto não seja um primor de redação, ele abrange tanto a duplicata que não corresponde a uma venda efetivamente feita quanto aquela que distorce a quantidade ou a qualidade da realmente realizada. O atual *caput* ampliou a incidência do art. 172 que, ao tempo da redação dada pela Lei n. 5.474/68, se referia apenas à expedição de duplicata que não correspondesse a uma venda efetiva de bens. Com efeito, seria *ilógico* que o novo dispositivo tipificasse como crime uma conduta evidentemente *menos* grave (emissão de fatura, duplicata ou nota de venda com quantidade ou qualidade do produto alterada) e deixasse de punir, igualmente, uma conduta indubitavelmente *mais* grave (emissão de fatura, duplicata ou nota de venda sem qualquer venda efetuada). Por outro lado, o atual *caput*, em sua parte final, tipifica como crime a emissão dos mesmos documentos quando não correspondam ‘ao serviço prestado’. Ora, seria um *contrassenso* que a lei punisse como crime a emissão de fatura, *duplicata* ou nota de venda referente a um serviço que jamais foi prestado e não o fizesse quanto a uma venda que nunca existiu, dando tratamento *desigual* a duas situações de *idêntica* potencialidade lesiva. A outra conclusão não leva, em nosso entendimento, a interpretação do novo *caput* do art. 172 em conjunto com o seu parágrafo único que, como vimos, teve a antiga redação mantida (…)

A jurisprudência do STF conduziu-se nesta última direção, conforme HC

72538/RS – Rio Grande do Sul. *Habeas corpus*. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento: 27-6-1995. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: *DJ*, 18-8-1995, p. 24898. Vol. 01796-02, p. 00417: “Duplicata simulada – Venda inexistente – Artigo 172 do Código Penal – Alcance. A Lei n. 8.137, de 28 de dezembro de 1990, não expungiu do cenário jurídico, como fato glosado no campo penal, a emissão de fatura, duplicata ou nota que não corresponda a uma venda ou prestação de serviços efetivamente realizados, conduta que se mostra tão punível quanto aquelas que encerrem simulação relativamente à qualidade ou quantidade dos produtos comercializados”.

Na Lei Falimentar, o crime é punido com pena de reclusão de três a seis anos e multa, e se insere na prática de ato fraudulento “de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem” (LREF, art. 168). Se o vendedor, além da emissão fraudulenta, elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, nos termos do § 1º, I.

Capítulo 6

CÉDULAS DE CRÉDITO

Sumário: 6.1. Origem. 6.2. Definição legal, espécies e conceitos. 6.3. Características e requisitos essenciais. 6.4 Encargos moratórios.

6.1. Origem

As cédulas de crédito concebidas no Brasil foram inspiradas no modelo proposto pelo direito italiano que, em 1927, disciplinou o crédito agrário instituindo a “Cambiale Agrária”³⁴. São títulos de crédito que conservam uma unidade própria, especial, de tratamento legislativo, destinados a servir como instrumentos de financiamento a inúmeras atividades econômicas.

Distinguem-se dos títulos estudados nos capítulos anteriores, porque nelas não é possível determinar previamente o valor do débito assumido pelo devedor, faltando-lhe obediência ao princípio da literalidade. As cédulas de crédito pressupõem a concessão de crédito na modalidade rotativa, em que o valor inicialmente financiado é posto à disposição do emitente em conta vinculada, por um determinado período, ao final do qual o devedor obriga-se a pagar o quanto resultar dos saldos parciais existentes, sobre os quais se cumularão os encargos contratados.

A semelhança dessas operações com outras operações de concessão de crédito rotativo, entre as quais a dos chamados cheques especiais, limita-se, tão somente, à abertura da conta, movimentação e apuração do saldo final porque às cédulas de crédito deu-se uma estrutura jurídica, com requisitos próprios, suficiente a dotá-las de executividade, isto é, o saldo apurado ao final é líquido e certo, podendo ser exigido em ação de execução.

No extinto Primeiro Tribunal de Alçada Cível de São Paulo entendeu-se que os extratos de contas correntes, indicando os saldos apurados nos contratos de cheque especial, dispunham de plena executividade³⁵. Esse entendimento, contudo, foi superado pela superveniência da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça que, em seu enunciado, dispôs em sentido diverso: “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extratos de conta corrente, não é título executivo”.

Essa divergência jurisprudencial, que se fez sentir também em outros tribunais estaduais, foi o principal motivador da estrutura legal da cédula de crédito bancário, instituída pelo governo federal por medida provisória³⁶ em 14 de outubro de 1999.

6.2. Definição legal, espécies e conceitos

O direito positivo brasileiro disciplina as cédulas de crédito em cinco diplomas legislativos: (a) Decreto-lei n. 167, de 14 de fevereiro de 1967; (b) Decreto-lei n. 413, de 9 de janeiro de 1969; (c) Lei n. 6.313, de 16 de dezembro de 1975; (d) Lei n. 6.840, de 3 de novembro de 1980; e (e) Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004.

Decorrem dessa legislação doze distintos títulos de crédito, genericamente denominados cédulas de crédito, subdivididos em duas subcategorias: cédulas de crédito *stricto sensu* e notas de crédito. Nos primeiros quatro diplomas legais o legislador distingue as primeiras das segundas em razão da garantia real que aquelas ostentam, enquanto as notas de crédito, não dispondo de garantia real, detêm privilégio geral sobre os bens do devedor. A Lei n. 10.931/2004 abandonou a distinção e manteve um único nome jurídico – cédula de crédito – não mais utilizando a expressão nota de crédito para a emissão sem garantia.

**CÉDULAS DE
CRÉDITO**

Decreto-lei n. 167/67	- Cédula Rural Pignoratícia - Cédula Rural Hipotecária - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária - Nota de Crédito Rural
Decreto-lei n. 413/69	- Cédula de Crédito Industrial - Nota de Crédito Industrial
Lei n. 6.313/75	- Cédula de Crédito à Exportação - Nota de Crédito à Exportação
Lei n. 6.840/80	- Cédula de Crédito Comercial - Nota de Crédito Comercial
Lei n. 10.931/2004	- Cédula de Crédito Imobiliário - Cédula de Crédito Bancário

Cédula de crédito é, portanto, título executivo que contém promessa de pagamento de soma de dinheiro e cuja liquidez somente se apura no vencimento, mediante operação de subtração de eventuais amortizações periódicas e de adição de encargos contratados. Nos financiamentos rurais, industriais, comerciais e de exportação admite-se sua constituição com ou sem garantia real, denominando-se, no primeiro caso, cédula de crédito *stricto sensu* e, no segundo, nota de crédito. Nos contratos de crédito imobiliário e bancário a garantia pode ser real sobre bens móveis ou imóveis ou, ainda, fidejussória. Na definição desses dois últimos títulos, o legislador manteve um único *nomen juris* – *cédula de crédito* – mesmo quando a constituição se dá sem garantia.

Os conceitos de cada espécie decorrentes das definições legais de cada um desses títulos são aqui reproduzidos:

DIPLOMA LEGAL	DISPOSITIVO	CONCEITO QUE DECORRE DA DEFINIÇÃO LEGAL
	Art. 9º c/c o art.	Cédula Rural Pignoratícia é promessa de pagamento em dinheiro, com

Decreto-lei n. 167/67	14, V	garantia real constituída por penhor cedular, do emitente ou de terceiro.
	Art. 9º c/c o art. 20, V	Cédula Rural Hipotecária é promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real constituída mediante hipoteca de bem imóvel.
	Art. 9º c/c o art. 25, V e VI	Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária é promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real constituída por penhor cedular, do emitente ou de terceiro e, ainda, mediante hipoteca de bem imóvel.
	Arts. 9º e 28	Nota de Crédito Rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem garantia real, que ostenta privilégio especial sobre determinados bens.
Decreto-lei n. 413/69	Art. 9º	Cédula de Crédito Industrial é promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real constituída por penhor cedular, do emitente ou de terceiro, por alienação fiduciária de bens ou, ainda, mediante hipoteca de bem imóvel.
	Art. 15	Nota de Crédito Industrial é promessa de pagamento em dinheiro, sem garantia real, que ostenta privilégio especial sobre determinados bens.
Lei n. 6.313/75	Art. 5º c/c o art. 9º do Decreto- lei n. 413/69	Cédula de Crédito à Exportação é promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real constituída por penhor cedular, do emitente ou de terceiro, por alienação fiduciária de bens ou mediante hipoteca de bem imóvel.
	Art. 5º c/c o art. 15 do Decreto- lei n. 413/69	Nota de Crédito à Exportação é promessa de pagamento em dinheiro, sem garantia real, que ostenta privilégio especial sobre determinados bens.
Lei n. 6.840/80	Art. 5º c/c o art. 9º do Decreto- lei n. 413/69	Cédula de Crédito Comercial é promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real constituída por penhor cedular, do emitente ou de terceiro, por alienação fiduciária de bens ou mediante hipoteca de bem imóvel.
	Art. 5º c/c o art. 15 do Decreto- lei n. 413/69	Nota de Crédito Comercial é promessa de pagamento em dinheiro, sem garantia real, que ostenta privilégio especial sobre determinados bens.
Lei n. 10.931/2004	Arts. 18-20	Cédula de Crédito Imobiliário é título representativo da totalidade ou de parte do financiamento imobiliário, emitido pelo credor imobiliário, com ou sem garantia, real ou fidejussória, sob a forma escritural ou cartular.

Lei n. 10.931/2004	Arts. 26-27	Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, com ou sem garantia, fidejussória ou real, de bem móvel ou imóvel, cedularmente constituída.
-----------------------	-------------	--

6.3. Características e requisitos essenciais

As diversas leis que instituíram as cédulas de crédito definiram certas características próprias comuns a todas elas e estabeleceram um conjunto de elementos essenciais necessários à constituição do título.

Caracterizam-nas³⁷: (a) a definição jurídica de título extrajudicial dotado de liquidez e certeza³⁸; (b) a vinculação a contratos de financiamentos conferidos por instituições financeiras a pessoas que exerçam atividades econômicas (rural, industrial, de exportação ou comercial) ou para a cédula de crédito bancária, a operação de crédito de qualquer modalidade. Observa-se, entretanto, que a Cédula de Crédito Imobiliário vincula-se a contrato de crédito imobiliário e pode ser emitida por credor desse crédito, não necessariamente instituição financeira; (c) a exigibilidade pelo saldo do débito, valor apurado segundo as condições pactuadas pelos contratantes. A apuração se faz pela soma constante da cédula ou “do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório” (art. 10 do Decreto-lei n. 167/67 e do Decreto-lei n. 413/69), mediante planilha de cálculo ou extratos de conta corrente (art. 28 da Lei n. 10.931/2004); (d) a possibilidade de constituição de garantia, em diversas modalidades; (e) a submissão às regras do direito cambial comum, admitindo aval e endosso, sendo dispensado o protesto para assegurar o direito de regresso³⁹.

São requisitos essenciais à emissão das cédulas de crédito: (a) a denominação do título; (b) a data e condições de pagamento; (c) o nome do credor; (d) o valor do crédito e, se diferido, a forma de sua utilização; (e) os encargos contratados ou os critérios para sua identificação; (f) a praça de pagamento; (g) a data e o lugar da

Além desses requisitos, se emitida com garantia, há necessidade de descrever os bens objeto da cláusula assecuratória. A cláusula à ordem é obrigatória em todas as cédulas, mas, na imobiliária, somente se, no momento de sua emissão, permitir-se o endosso.

[illegible][illegible]

[illegible]

Praça de pagamento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Assinatura do emitente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autenticação pelo Oficial de Registro de Imóveis												
SIGLAS CRP = Cédula Rural Pignoratória; CRH = Cédula Rural Hipotecária; CRPH = Cédula Rural Hipotecária; NCR = Nota de Crédito Rural; CCId = Cédula de Crédito Industrial; NCId = Nota de Crédito Industrial; CCE = Cédula de Crédito à Exportação; NCE = Nota de Crédito à Exportação; CCC = Cédula de Crédito Comercial; CCId = Cédula de Crédito Comercial; CCI = Cédula de Crédito Imobiliário; CCB = Cédula de Crédito Bancário.												

Na linha “finalidade do crédito” observa-se a exigência de inscrição, na cartula, do tipo de negócio subjacente à emissão de alguns tipos de cédulas de crédito, circunstância que levou Waldirio Bulgarelli (1996:471) a pôr em dúvida a abstração e a literalidade desses títulos, o que, entretanto, não desqualificaria sua natureza cambial, uma vez que “o legislador não levou em maior consideração a circulação; daí os abalos na abstração e na própria literalidade” (1996:469).

De fato, ao indicar a causa de seu nascimento, o título prende-se a esse fato de origem, que repercute sobre as transmissões posteriores, abrindo séria ruptura no princípio da autonomia das relações subsequentes (v. a respeito o item 1.4.2).

O objetivo das cédulas rurais, industriais, comerciais e à exportação é, no dizer de Fábio Ulhoa Coelho (2016:483), “vocacioná-los ao atendimento, de um lado, das necessidades e garantias das instituições financiadoras [...], e, de outro, das peculiaridades do empreendimento [...] fomentado”. Nesse contexto a circulação dos títulos é matéria relegada ao segundo plano pelo legislador, como bem afirma Waldirio Bulgarelli.

6.4. Encargos moratórios

Três questões são enfrentadas no que se refere aos encargos moratórios: o limite da taxa de juros, a possibilidade ou não de capitalização de juros e a cumulação de juros com outros encargos.

a) Do limite da taxa de juros

Para as cédulas rurais, comerciais, industriais e à exportação as taxas de juros podem ser fixadas até o limite permitido pelo Conselho Monetário Nacional, conforme decorre do Decreto-lei n. 167/67 e do Decreto-lei n. 413/69, no disposto no art. 5º de ambos os diplomas legais.

Verifica-se, entretanto, que o Conselho Monetário Nacional jamais fixou o índice permissivo, gerando discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Entendeu-se, então, que, para os créditos regulados pelos diplomas de 1967, 1969, 1975 e 1980, respectivamente rural, industrial, à exportação e comercial, na falta de regulamentação, aplica-se o limite imposto pela legislação comum, qual seja, de 12% ao ano, podendo ser elevada em até 1%, em caso de mora, por expressa previsão legal (parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei n. 167/67 e do Decreto-lei n. 413/69).

Para as cédulas de crédito bancário, distinto é o entendimento. Não há, na legislação que as regulamenta, dispositivo que remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação das taxas de juros⁴⁹, daí por que se entende que as instituições financeiras, neste caso, não encontram limites na estipulação de taxas de juros nos contratos de abertura de crédito ou em financiamentos de natureza diversa daquelas sujeitas ao regime da legislação de 1967 e 1969. V. decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “Civil e processual. Ação revisional. Cédulas de crédito bancário. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Juros remuneratórios Limitação. Impossibilidade. Súmula n. 296-STJ. Comissão de permanência Inacumulabilidade com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. Capitalização dos juros. Anualidade. Art. 591 do Código Civil de 2002. Inaplicabilidade. Art. 5º da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (2.170-36/2001). Lei especial. Preponderância. I. Não padece de nulidade acórdão estadual que enfrenta as questões essenciais ao julgamento da demanda, apenas com conclusão

desfavorável à parte. II. Não se aplica a limitação de juros remuneratórios de 12% a.a., prevista na Lei de Usura, aos contratos bancários não normatizados em leis especiais, sequer considerada excessivamente onerosa a taxa média do mercado. Precedente uniformizador da 2ª Seção do STJ. III. Segundo o entendimento pacificado neste Colegiado (AgR-REsp n. 706.368/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, unânime *DJ*, de 8-8-2005), a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela. IV. Não é aplicável aos contratos de mútuo bancário a periodicidade da capitalização prevista no art. 591 do novo Código Civil, prevalecente a regra especial do art. 5º, *caput*, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (2.170-36/2001), que admite a incidência mensal. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido” (REsp n. 906.054/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 7-2-2008, *DJ*, 10-3-2008, p. 1).

Em orientação firmada em recurso repetitivo concluiu-se que “nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, *DJe* 10-3-2009).

b) Da capitalização de juros

Por outro lado, o Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, conhecido como Lei da Usura, veda, em seu art. 4º, a cobrança de juros capitalizados, isto é, juros sobre juros, em período inferior a um ano. Entretanto, o Decreto-lei n. 167/67, que instituiu as cédulas de crédito rurais, autorizou expressamente a capitalização⁵⁰, mas não foi seguida pela legislação que dispõe sobre o crédito industrial, o comercial e o destinado à exportação. O Decreto-lei n. 413/69, que regulamenta as mencionadas cédulas, é omissa quanto à permissão à capitalização em período inferior a um ano. Para a cédula de crédito bancária, a permissão decorre do que dispõe o art. 3º da Medida Provisória n. 2.170/2001.

Dirimindo a matéria, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a permissão legal

para a capitalização de juros em período inferior a um ano, desde que constante de cláusulas firmadas pelas partes. Veja-se, nesse sentido, a Súmula 93: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”.

Reconhecida a expressa autorização legislativa, entende-se necessária pactuação escrita, consoante reiterada jurisprudência:

- **Para as cédulas de crédito rural:** Ação rescisória. Violação literal de lei. Cédula de crédito rural. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Pactuação. 1 – Não há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente na cédula de crédito rural se acordado entre as partes, a embasar ação rescisória com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2 – Ação rescisória julgada improcedente (AR 3.510/SC, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Segunda Seção, j. 28-11-2007, *DJ*, 17-12-2007, p. 123). Em recurso repetitivo, essa tese prevaleceu, ficando assentado que “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (REsp n. 1.333.977/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26-2-2014, *DJe* 12-3-2014).

- **Para as cédulas de crédito industrial, comercial e à exportação,** cuja aplicação estendida se dá por força do disposto no art. 5º das Leis n. 6.313/75 e 6.840/80: Agravo regimental. Civil. Cédula de crédito comercial. Juros. Limitação. 12% ao ano. Capitalização mensal. Ausência de pactuação. Súmula 5/STJ. 1 – Omitindo-se o Conselho Monetário Nacional em fixar as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito comercial (Decreto-Lei n. 413/69 c/c o art. 5º da Lei n. 6.840/80), prevalece o art. 1º, *caput*, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano, ficando afastada a Súmula 596 do STF, porquanto se dirige à Lei n. 4.595/64, derogada pelo diploma legal de 1980. 2 – Admissível a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, o que não ocorre no caso dos autos, ao teor da Súmula 93 desta Corte. Rever o posicionamento adotado esbarraria no óbice contido na Súmula 5/STJ. 3 – Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 719.065/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 6-3-2008, *DJ*, 17-

3-2008, p. 1);

• **Para as cédulas de crédito bancário**, v. item IV da ementa jurisprudencial na nota n. 19 deste Capítulo.

c) Da cumulação de encargos moratórios

Na pactuação de encargos veda-se a cumulação de encargos com a mesma finalidade, isto é, em caso de inadimplência, não se pode onerar o devedor com o acréscimo de juros moratórios, multa moratória, correção monetária e comissão de permanência, como ocorre com certa frequência. Esses encargos são estipulados com o objetivo de remunerar o credor pelo atraso do mutuário no cumprimento de suas obrigações.

Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o pacífico entendimento exposto no AgR-REsp n. 706.368/RS, de lavra da Ministra Nancy Andrighi, que, por decisão unânime (*DJ*, 8-8-2005), afastou a cobrança desses encargos de forma cumulada: “Direito econômico. Agravo no recurso especial. Ação revisional de contrato bancário. Comissão de permanência. Cumulação com outros encargos moratórios. Impossibilidade. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Agravo no recurso especial não provido” (AgRg no REsp n. 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27-4-2005, *DJ*, 8-8-2005, p. 179).

É entendimento pacificado da 2ª Seção do STJ que “**a comissão de permanência** não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios” (REsp n. 973.827/RS).

Capítulo 7

TÍTULOS DE CRÉDITO REPRESENTATIVOS

Sumário: 7.1. Títulos representativos. 7.2. Conhecimento de depósito e *warrants*. 7.2.1. Armazém-geral. 7.2.2. Direitos e deveres dos contratantes. 7.2.3. Devolução em mercadoria do mesmo gênero. 7.2.4. Conhecimento de depósito e *warrant* – noções. 7.2.5. Natureza jurídica. 7.2.6. Requisitos legais de emissão. 7.2.7. Circulação dos títulos. 7.2.8. Responsabilidade dos endossantes do *warrant*. 7.2.9. Responsabilidade dos endossantes do conhecimento de depósito. 7.2.10. *Warrants* de produtores rurais. 7.2.11. Certificado de depósito e *warrants* agropecuários. 7.2.12. Títulos de cooperativa. 7.3. Conhecimento de transporte. 7.3.1. Origem, definição e conceito. 7.3.2. Características. 7.3.3. Espécies. 7.3.4. Requisitos. 7.3.5. Circulação.

7.1. Títulos representativos

Mencionamos anteriormente (item 1.2.4) o conceito de Pupo Correia (1999:107) para títulos representativos: os que “incorporam direitos sobre determinadas coisas, em geral mercadorias”. Expandindo esse pensamento, anotamos com Fábio Ulhoa Coelho (2017:294) que esses títulos exercem, ao lado da função documental, “a de título de crédito, por instrumentalizarem a mais fácil negociação da mercadoria custodiada por seu proprietário”.

São dessa natureza o conhecimento de depósito, o *warrant* e o conhecimento de frete, que, por sua vez, encontram-se regulados em distintas legislações, conforme o regulamento da obrigação originária.

Temos, assim, no direito brasileiro, algumas espécies de conhecimentos de depósito, segundo a origem do contrato: (a) os emitidos pelos armazéns-gerais e regulados pelo Decreto n. 1.102, de 21 de novembro de 1903; (b) os emitidos pelos armazéns agropecuários e pelas cooperativas, objeto das Leis n. 5.762/71,

9.973/2000 e 11.076/2004. Todos são acompanhados dos respectivos *warrants*.

Os documentos de conhecimentos de transporte, ou de frete, que representam a existência de um contrato de mercadoria transportada, referem-se a contratos aéreo, marítimo ou terrestre, dando origem aos títulos adjetivados segundo o meio utilizado (conhecimento aéreo, conhecimento marítimo etc.).

7.2. Conhecimento de depósito e *warrants*

A exata compreensão do conhecimento de depósito e dos *warrants* exige o prévio estudo da função e definição dos armazéns-gerais, estabelecimentos emitentes desses títulos.

7.2.1. Armazém-geral

Armazém-geral é o estabelecimento explorado por empresário individual ou sociedade empresária que tem como objeto de sua atividade o recebimento, para guarda e conservação, de mercadorias ou coisas alheias, por um determinado período de tempo estipulado pelos proprietários desses bens.

Para oferecer o serviço de modo universal e, ainda, evitar a prática desleal de concorrência com os usuários empresários da indústria e do comércio é vedado ao armazém: (a) estabelecer preferência entre os depositantes. Observa-se que o armazém-geral que se especializar em produtos agropecuários e for certificado como tal pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento deve trazer em seu regulamento os critérios de preferência para a admissão de produtos (art. 5º da Lei n. 9.973/2000); (b) recusar depósito previsto em seu regulamento interno, somente podendo fazê-lo se não houver espaço suficiente para a acomodação da mercadoria e, ainda, se esta, em razão de sua particular condição, for passível de danificar as já depositadas; (c) exercer o comércio de mercadorias idênticas às que se propõem receber em depósito, salvo quando se tratar de produto agropecuário, conforme o art. 8º da Lei n. 9.973/2000. (V. item 7.2.10e.); (d) adquirir mercadorias expostas à venda em seus estabelecimentos, ainda que a pretexto de consumo particular; (e) emprestar ou negociar títulos de sua emissão.

A Lei de Registro de Empresa (Lei n. 8.934/94) impõe, no inc. I do art. 32, a matrícula dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais, todos pertencentes à categoria para a qual a doutrina cunhou a expressão “colaboradores independentes da empresa”, também conhecidos como “auxiliares do comércio”. São pessoas que, ao lado dos corretores e representantes comerciais, sem vínculo empregatício ou hierárquico, prestam serviços às empresas na aproximação de clientela e na intermediação de seus negócios.

Interessa-nos a normatização dos trapicheiros e dos administradores de armazéns-gerais. Denominam-se trapicheiros os administradores de armazéns que abrigam mercadorias destinadas à importação e exportação.

A disciplina de matrícula é a mesma para ambos porque, de fato, a função é única e a especialização se dá em razão da destinação da mercadoria depositada. Antes de entrar em exercício na atividade, a empresa que as contrata – armazéns-gerais e companhia de docas – deve proceder à matrícula na Junta Comercial da sede do armazém para o qual trabalham, submetendo-se às regras do Departamento Registro Empresarial e Integração, em especial da Instrução Normativa n. 17, de 5 de dezembro de 2013. Para tanto, deverão juntar declaração contendo o nome empresarial, domicílio e capital, o título do estabelecimento, a localização, a capacidade, a comodidade, a segurança e a descrição minuciosa dos equipamentos dos armazéns, a natureza e discriminação das mercadorias a serem recebidas em depósito, as operações e os serviços a que se propõe oferecer.

A segurança, a ordem e a obediência às normas que disciplinam os armazéns-gerais devem ser demonstradas pela empresa, com a juntada dos seguintes documentos: a) regulamento interno do armazém-geral e da sala de vendas públicas; b) laudo técnico de vistoria firmado por profissional competente ou empresa especializada, aprovando as instalações do armazém-geral; c) tabela contendo a tarifa remuneratória de depósito de mercadoria e dos demais serviços; d) em se tratando de empresa que recebe mercadorias de importação e exportação, ou concessionário de entreposto e trapiche alfandegado, a empresa interessada deve juntar comprovante de

autorização do governo federal para emitir os títulos representativos (conhecimento de depósito e *warrant*).

Exige-se do administrador: certidão negativa de condenação pelos crimes falimentares, estelionato, abuso de confiança, falsidade, roubo ou furto, expedida pelo cartório distribuidor da comarca onde residir.

Feito o registro e publicada a tabela contendo a tarifa de serviços, a empresa interessada dará início a suas atividades, devendo, para isso, registrar o ato de nomeação do administrador ou do trapicheiro e providenciar sua assinatura no termo de responsabilidade como fiel depositário dos gêneros e mercadorias que receber, lavrado pela Junta Comercial e publicado por edital.

Abrindo filiais em outros Estados da Federação, os armazéns são obrigados a arquivar, na Junta Comercial da jurisdição, termo de responsabilidade de seu fiel depositário.

7.2.2. Direitos e deveres dos contratantes

Imagine-se a seguinte situação: o produtor obteve um bom resultado na colheita ou fabricação de determinada mercadoria e pretende estocá-la por um determinado período para, posteriormente, vendê-la no mercado interno ou externo, a um bom preço. Ao entregá-la aos cuidados da empresa de armazém, receberá um recibo descritivo de sua operação, indicando a realização de um contrato típico de depósito, contendo a natureza, a quantidade, o número e as marcas das mercadorias depositadas.

Decorrem desse contrato obrigações de ambas as partes que se obrigam a respeitar as instruções oficiais, o regulamento interno e as tarifas praticadas indicadas em local visível na porta principal do estabelecimento. O armazém depositário deve guardar e conservar as mercadorias sob seus cuidados e o proprietário depositante o de pagar o preço dos serviços que lhe são prestados.

a) Obrigações e direitos do armazém-geral

Em especial, o armazém obriga-se a guardar, a conservar e a entregar, pronta e

fielmente, as mercadorias que tiver recebido, respondendo por culpa, fraude ou dolo de seus empregados e prepostos e por subtração ocorrida dentro do estabelecimento. Salvo convenção entre as partes e pagamento de taxa complementar, o armazém exime-se de responsabilidade no caso de força maior, de avaria ou vícios provenientes da natureza e acondicionamento das mercadorias.

Nesses casos, a ação de indenização prescreve em três meses contados do dia em que a mercadoria devia ser entregue.

Os direitos da empresa de armazenamento podem ser resumidos em quatro esferas de proteção: (a) direito à contraprestação pelos serviços; (b) direito de retenção; (c) direito à indenização; (d) direito de preferência.

No tocante à **contraprestação pelos serviços oferecidos**, de guarda e conservação das mercadorias, os armazenadores têm direito à percepção de tarifa remuneratória de depósito de mercadoria e de outros serviços que disponibilizar à sua clientela, como, por exemplo: cobrança pela emissão dos títulos (conhecimento de depósito e *warrant*), a pedido dos depositantes das mercadorias; serviço de pesagem de veículos, carretas e outros meios de transporte de mercadorias; serviços realizados fora do horário normal de atividade; etc.

Direito de retenção: para garantia do pagamento das despesas e pelos serviços prestados ao depositante, o armazém tem o direito de retenção sobre as mercadorias. O Decreto n. 1.102/1903 estabelece que o direito de retenção pode ser oposto à massa falida do devedor (art. 14), o que, no atual regime falimentar, não mais ocorre. O inciso I do art. 116 da Lei n. 11.101/2005 suspende o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação.

Direito de indenização: decorre do contrato de armazenagem o direito de a empresa de armazenagem ser indenizada pelos prejuízos que lhe foram causados por culpa ou dolo do depositante. Isso ocorre, por exemplo, quando as declarações prestadas pelo depositante omitirem, culposa ou dolosamente, circunstância que deveria ser conhecida no momento do depósito, relativamente à mercadoria entregue. João Luiz Alves (1926:910), ao comentar o art. 1.278 do Código Civil revogado anotou acerca dos prejuízos indenizáveis pelo depositante: “Esses prejuízos são os

que provêm da própria coisa, ou de fato que a ela se prende necessária e diretamente, ainda que oriundos de vícios ocultos, ignorados pelo próprio depositante, como se o animal depositado sofria de moléstia que contagiou os animais do depositário [...]”.

Direito de preferência, pelas despesas “com a conservação e com as operações, benefícios e serviços prestados às mercadorias, a pedido do dono, dos adiantamentos feitos com fretes e seguros, e das comissões e juros, quando as mercadorias lhes tenham sido remetidas em consignação” (Decreto n. 1.102/1903, arts. 14 e 26, inc. 3º).

O direito de preferência deve ser exercido no momento da venda da mercadoria pelo credor titular do *warrant*. Recebido o preço apurado no leilão extrajudicial, o leiloeiro expede a conta de venda ao armazém-geral, entregando-lhe o valor apurado. Cabe ao armazém deduzir os valores de tributos devidos, pagar a comissão do leiloeiro e despesas do leilão, reembolsar-se do montante totalizado na conta das despesas que lhe são devidas, entregando o saldo ao credor, portador do *warrant*.

No caso de falência do depositante, cabe ao armazém-geral promover sua habilitação no quadro geral de credores da massa falida, classificando seu crédito na classe dos créditos com direito especial de garantia (LREF, art. 83, IV). Semelhantemente, os credores fiscais perdem a preferência absoluta e recebem na classe de privilegiados tributários (LREF, art. 83, III).

b) Obrigações e direitos do depositante

O depositante, em regra, obriga-se a pagar o preço do serviço contratado e a indenizar o armazém pelos prejuízos que causar ao estabelecimento, de forma culposa ou dolosamente.

É evidente que a responsabilidade do depositante deve ser apurada antes de qualquer quantia vir a ser cobrada pelo armazém-geral, não bastando a notificação unilateral do prestador do serviço. Não raras vezes se estabelece um juízo contraditório visando apurar a quem cabe a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos no interior desses estabelecimentos.

Por outro lado, o depositante tem ação contra o armazém-geral pelos prejuízos que

sofrer em razão do depósito, tais como aqueles decorrentes de subtração de gêneros, fraude ou má conservação. O prazo prescricional previsto no diploma de 1903 é reduzido: três meses contados do dia em que a mercadoria devia ser devolvida pelo armazém (art. 11, § 1º).

Durante o período contratado, o depositante tem o direito a examinar e verificar as mercadorias depositadas e a conferir as amostras, obedecendo, contudo, ao que dispuser o regulamento quanto ao modo e tempo de exercer esse direito.

7.2.3. Devolução em mercadoria do mesmo gênero

As empresas de armazenagem que se especializarem em determinados gêneros podem misturar as mercadorias de diversos donos, desde que tenham a mesma natureza e qualidade, o que, por conseguinte, nesse tipo de depósito, equivale a dizer que não se obriga a restituir a própria mercadoria, mas está autorizada a entregar mercadoria da mesma qualidade.

Pressupõe esse tipo de depósito a adequação da mercadoria para a armazenagem mista e o aparelhamento da empresa para o recebimento desse produto. A esse respeito escreveu Carvalho de Mendonça (1955, 5:570-571): “Está subentendido que a confusão e mistura não podem ser feitas no armazém-geral sem expresso consentimento ou pedido do depositante e sem que a empresa se ache aparelhada para esse fim. Na Itália, denominam-se esses depósitos *alla rinfusa*, e na Alemanha, *Menglagenschaft* (O Cód. Federal suíço das obrigações, no art. 484, dispõe que ‘o entrepositário não pode misturar coisas fungíveis com outras da mesma espécie e qualidade, se esta faculdade lhe não for expressamente conferida’). [...] Na Exposição de motivos do projeto da Lei n. 1.102, de 1903, escrevemos o seguinte: ‘O projeto ocupa-se também da guarda das mercadorias *in genere*, isto é, mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos depositantes e que são misturadas, perdendo a sua individualidade própria’. Nos armazéns-gerais da Escócia, ensaiou-se com bons resultados esta prática no comércio do ferro e logo depois a Inglaterra e a Holanda a adotaram para os produtos coloniais (café, chá, tabaco, açúcar bruto, peles curtidas, guano e metais). Essas mercadorias armazenadas a granel nas docas são

vendidas em lotes e sobre elas emitidos *warrants*. A França adotou-a no comércio dos óleos e farinhas; a América do Norte para os cereais. Para mercadorias da mesma qualidade, esta prática economiza espaço e trabalho na sua guarda e nos transbordos dos navios para os armazéns e vice-versa. Esse depósito nos armazéns-gerais tem caráter excepcional. A propriedade da mercadoria depositada permanece *pro indiviso* com os depositantes”.

7.2.4. Conhecimento de depósito e *warrant* – noções

Quando se trata de guarda e conservação de mercadorias (e não de qualquer outra coisa) o armazém está autorizado a emitir, a pedido do depositante, em vez de um simples recibo de depósito, dois outros documentos: o título representativo do contrato de depósito (denominado conhecimento de depósito) e, outro, representativo do valor das mercadorias depositadas, destinado a facilitar operações de crédito de seu portador (chamado *warrant*).

Com a emissão dos títulos a mercadoria depositada não pode ser arrestada, penhorada, embargada ou sofrer “qualquer outro embaraço que prejudique a sua livre e plena disposição” (Decreto n. 1.102/1903, art. 17). Essa blindagem, contudo, não alcança os títulos emitidos que, estes sim, podem sofrer toda espécie de constrição por dívidas de seu portador.

Esses dois documentos são emitidos unidos, extraídos de talão de uso do armazém depositante, mas “separáveis à vontade”, conforme redação do art. 15 do Decreto n. 1.102/1903, e, embora unidos na criação, distintas são as funções econômicas que desempenham, como bem afirma Carvalho de Mendonça: “o *warrant* serve de instrumento de crédito sobre mercadorias, o conhecimento de depósito, de meio de circulação de mercadorias” (1955, 5:628).

O conhecimento de depósito confere titularidade sobre as mercadorias depositadas e o *warrant* a disponibilidade sobre essas mesmas mercadorias, porque, uma vez circulando, este título outorga ao portador direito real sobre a coisa depositada, circunstância que limita a livre disposição do detentor daquele outro – o conhecimento de depósito. Em outras palavras: o portador do conhecimento de

depósito é o titular da coisa depositada, mas tem o exercício de seu direito de propriedade limitado pelo direito do titular do *warrant*, que recebe a mesma coisa depositada em garantia real de seu direito de crédito.

Tullio Ascarelli (1999:95, nota 423) sintetiza essa limitação: “o conhecimento de depósito que circula sem o *warrant* transfere, por consequência, somente o direito à entrega da mercadoria, mas onerada com penhor”.

Ou, ainda, na expressão legal (art. 18 do Decreto n. 1.102/1903): o *warrant* separado do conhecimento de depósito dá ao portador o direito de penhor sobre a mercadoria depositada. O conhecimento de depósito confere a faculdade de disposição da mercadoria, ressalvado o direito do credor, portador do *warrant*.

Quando os títulos encontram-se unidos, seu portador possui o direito de: (a) pedir a divisão da mercadoria em tantos lotes quantos lhe convier e o de exigir a emissão de títulos correspondentes a cada um desses lotes; (b) retirar as mercadorias depositadas, com a apresentação de ambos os títulos ao armazém depositante.

Quanto à limitação do direito de propriedade, observa-se que essa circunstância deixa de existir se o portador do conhecimento de depósito disponibilizar o valor correspondente à quitação do *warrant*. É a hipótese prevista no art. 22 do Decreto n. 1.102/1903, em que a circulação dos títulos se dá separadamente: o portador do conhecimento de depósito pode retirar a mercadoria antes do vencimento da dívida expressa no *warrant*, desde que consigne no armazém-geral o valor correspondente ao principal e juros até o vencimento, mais as despesas de armazenagem e tributos incidentes.

Spencer Vampré (1922, 3:113) conceitua ambos os títulos, preferindo para o direito de crédito a forma abasileirada não dicionarizada por Aurélio Buarque de Almeida: “Várrante é o instrumento de penhor, que dá ao seu portador direito real sobre a mercadoria, até a concorrência da importância, que representa, importância que é enunciada por ocasião do primeiro endosso”.

Para o conhecimento de depósito Vampré apresenta conceito que o confunde com mero recibo: “é o recibo do depósito, passado pelo empresário, companhia, ou

sociedade de armazéns-gerais, e que prova a propriedade, ou a livre disposição da mercadoria, por parte do depositante”. À expressão “recibo do depósito” prefere-se “documento” ou “título” para distingui-lo do “recibo” previsto no art. 6º do Decreto n. 1.102/1903, que contém a discriminação das mercadorias, sem, contudo, contar com todos os requisitos exigidos para a formalização do conhecimento de depósito. Atualizando, pois, o conceito de Spencer Vampré teremos: “é o título passado pelo empresário, companhia, ou sociedade de armazéns-gerais, emitido a pedido do depositante, simultaneamente ao *warrant*, e que prova a propriedade, ou a livre disposição da mercadoria, por parte do depositante”.

7.2.5. Natureza jurídica

a) Natureza e classificação do conhecimento de depósito

Classifica-se o conhecimento de depósito como título representativo⁵¹, isto é, fundado em contrato de depósito em armazém-geral e que importa em entrega de certa mercadoria, especificada na cártula. Por ser representativo é também título causal porque se prende ao depósito realizado no armazém-geral que lhe regula a obrigação de guarda, de custódia e de devolução da mercadoria mencionada no título. É, ainda, título de legitimação porque dá a seu portador o direito de exercer a titularidade sobre a coisa depositada.

b) Natureza e classificação do warrant

O *warrant* é considerado por Rubens Requião (1995, 2:466) título causal, classificação que Tullio Ascarelli (1999:194-195) expande: “O *warrant* incorpora um direito real; o titular do *warrant* tem um direito real de penhor sobre a mercadoria, não se podendo, portanto, a propósito desse direito, falar em causalidade e abstração, como se não pode falar, em geral, de causalidade e abstração para os direitos reais. O *warrant*, como se observou, serve justamente para dar em penhor a mercadoria depositada e, sucessivamente, transferir o direito de penhor. A constituição do penhor tem, portanto, origem num negócio de transmissão do título por parte do titular do conhecimento de depósito; as suas cláusulas valem, quanto ao

terceiro portador de boa-fé do título, tais quais ressaltam do título, de conformidade com as regras gerais várias vezes enunciadas [...]”.

Podemos concluir que a representação e a causalidade do *warrant* somente podem ser admitidas em sua origem. Uma vez separado do conhecimento de depósito, melhor defini-lo como promessa de pagamento, pois cumpre, com a circulação independente, o papel abstrato da nota promissória, com a peculiaridade de conceder garantia real sobre a mercadoria depositada a seu possuidor.

7.2.6. Requisitos legais de emissão

São requisitos essenciais à emissão de conhecimento de depósito e do respectivo *warrant*, encontrados no § 1º do art. 15 do Decreto n. 1.102/1903:

a) *À ordem*

A expressão legal determina que “cada um destes títulos deve ter a ordem”⁵² (§ 1º do art. 15). Significa dizer que ambos são títulos que indicam o nome da pessoa a quem se deve entregar a coisa depositada e que circulam necessariamente por meio de endosso, não bastando a mera tradição da cártula. O endosso é, assim, requisito necessário para a transferência do título (cf. Ascarelli, 1999:279).

b) *Designação particular*

Cada um dos títulos deve trazer o *nomen juris* a que correspondem: “conhecimento de depósito” e “*warrant*”. A indicação do título é requisito de ordem formal que delimita com exatidão os direitos conferidos aos portadores. Observa-se que o nome adotado pelo legislador brasileiro para o *warrant* apareceu primeiramente na Lei n. 1.746, de 13 de outubro de 1869, conforme anota Carvalho de Mendonça. Seu significado na origem (do inglês *warrant*, “autorização, ordem, permissão, recibo de depósito”) não é adequado à função que exerce, motivo da justificativa apresentada por Carvalho de Mendonça⁵³.

c) *Denominação da empresa do armazém-geral e sua sede*

O emitente do título deve ser identificado por figurar no contrato originário. É ele

quem se obriga civil e criminalmente à fiel observação do cumprimento da legislação, em especial pela emissão dos títulos, respondendo penalmente pela não observância das normas estabelecidas nos arts. 1º a 4º do Decreto n. 1.102/1903; pela falsidade das declarações neles lançadas; por entrar em negociação com esses mesmos títulos; por desviarem ou fraudarem mercadorias e pela retenção indevida dos valores consignados pelos devedores (Decreto n. 1.102/1903, art. 35).

d) Identificação do depositante ou de terceiro por este indicado

Trata-se de títulos nominativos, à ordem, devendo, portanto, se conhecer o nome do beneficiário original dos direitos conferidos nas cédulas. O depositante, a quem a seu pedido se emitiram os títulos à sua ordem ou à ordem de terceiro por ele designado, é a pessoa que dará início à circulação cambiária, de forma unificada ou separadamente, mediante simples endosso.

e) Lugar e prazo de depósito

O local e o prazo do depósito devem ser desde logo conhecidos pela simples razão de que somente assim poderá o titular das mercadorias exercer efetivamente seu direito à retirada ou mesmo à fiscalização das condições de armazenamento. Para essa finalidade os traslados posteriores, acordados entre as partes, também devem constar das cédulas, exigindo o legislador que sejam anotados o local para onde se transferirá a mercadoria em depósito e o valor das despesas decorrentes da transferência e do seguro por todos os riscos (art. 15, § 1º, inc. 3º, alínea b).

O art. 10 do Decreto n. 1.102/1903 fixa o prazo de depósito em seis meses, contado a partir da entrada da mercadoria no estabelecimento contratado, podendo ser prorrogado livremente pelas partes. Decorrido esse prazo, sem que tenha ocorrido a prorrogação, a mercadoria será considerada abandonada, impondo-se ao armazém a expedição de aviso, por via postal, para sua retirada no prazo de até 8 dias, sob pena de sua venda em leilão público.

f) Discriminação da mercadoria

É de claro entendimento a exigência de se indicar a natureza e a quantidade das

mercadorias em depósito. Para facilitar sua precificação em futura alienação (com o endosso do conhecimento de depósito) ou avaliação para a obtenção de crédito (com o endosso do *warrant*), exigiu o legislador que as mercadorias sejam designadas “pelos nomes mais usados no comércio”, indicando “seu peso, o estado dos envoltórios e todas as marcas e indicações próprias para estabelecerem sua identidade, ressalvada a peculiaridade das mercadorias depositadas a granel”. Se a mercadoria for aquela que pode ser guardada misturada com outras da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos donos, deve-se indicar essa circunstância.

g) Identificação do segurador

As mercadorias que servirem de base à emissão dos títulos devem ser seguradas, evitando sua perda por incêndio⁵⁴ (art. 16 do Decreto n. 1.102/1903), devendo ser indicados nas cédulas o valor do seguro e a indicação da companhia seguradora. Esses elementos conferem segurança à circulação dos títulos e, especialmente, o valor segurado é indicativo confiável do valor da garantia, permitindo-se a fixação da importância do crédito no primeiro endosso. Em se tratando de mercadorias misturáveis (v. item 7.2.3) o seguro deve ser feito em nome do armazém-geral, que é quem se responsabiliza pela indenização em caso de sinistro (Decreto n. 1.102/1903, art. 16, parágrafo único).

h) Declaração fiscal e de encargos

Os encargos e os tributos preferem o direito de crédito do portador do *warrant* pelo produto da venda da mercadoria (Decreto n. 1.102/1903, art. 26) e, assim, a indicação dos valores correspondentes a essas despesas permite tornar transparente a negociação dos títulos com futuros endossatários.

i) Data da emissão

O tempo em que o contrato se estabelece não apenas serve para contagem do período de armazenamento como também é elemento indispensável para se verificar a ocorrência de fraudes contra credores ou ineficácia e revogação de atos na ocorrência

de falência do depositante ou do estabelecimento armazeneiro.

j) Assinatura do emitente

A autenticidade dos títulos e a certificação de que as mercadorias ou os gêneros encontram-se em depósito, nas quantidades, qualidades, peso e estado neles consignados, são assumidas com o lançamento de assinatura do empresário armazeneiro ou de quem for por ele habilitado.

7.2.7. Circulação dos títulos

Os títulos são emitidos unidos pelo armazém depositário mas podem ser livremente separados pelos seus possuidores durante sua vida circulatória.

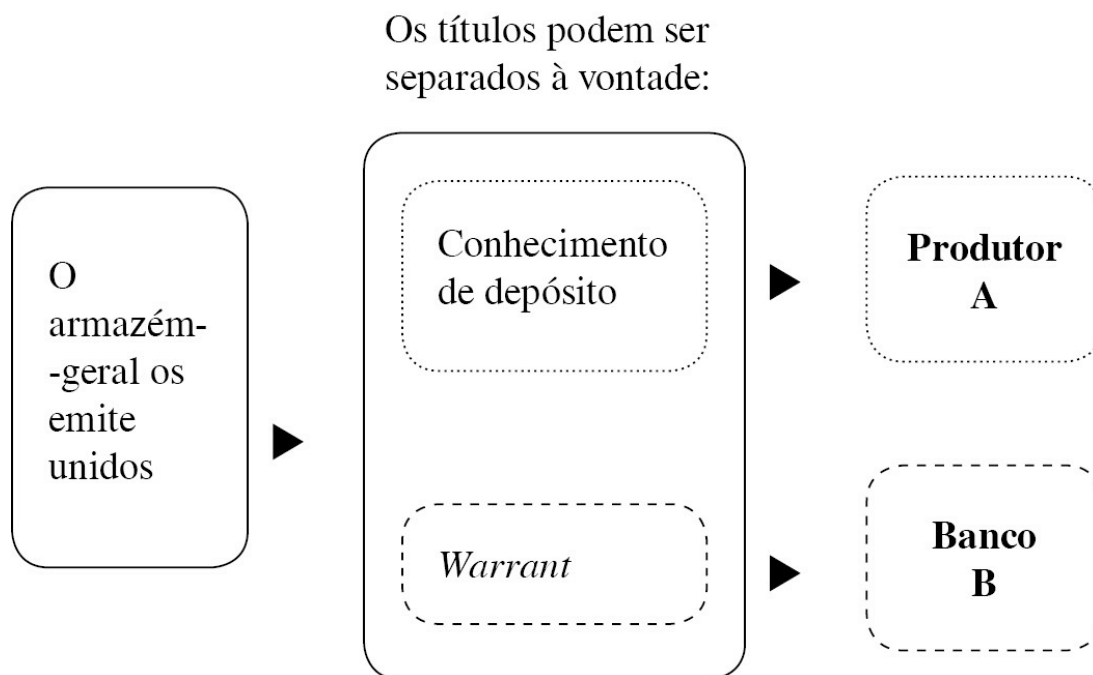
De observar que, necessariamente, primeiro se dá a separação do *warrant*, com a anotação de seu valor no conhecimento de depósito, para, então, se permitir a circulação do conhecimento de depósito. Isso se mostra consentâneo com a transparência dos negócios de alienação que se seguirem com a transferência desse título que obrigatoriamente conterà a declaração do valor, lançado no *warrant*, pelo qual se deu em garantia real as mercadorias. Aquele que recebe o conhecimento de depósito isoladamente está ciente de que alguém é detentor de um direito de crédito, no valor mencionado, a respeito do qual detém o penhor das mesmas mercadorias representadas no conhecimento de depósito do qual se tornou endossatário.

Por se tratar de títulos à ordem, a circulação se faz por endosso sobre os títulos, em branco ou em preto.

Percebe-se que, entre os requisitos de criação, não consta a discriminação da importância de sua emissão, como ocorre com o cheque, a nota promissória, a letra de câmbio. Os únicos valores constantes dos títulos correspondem ao seguro, aos tributos, aos encargos e às despesas de depósito. Esses valores servirão para se chegar ao montante da negociação dos títulos, cabendo à primeira pessoa que realizar o endosso do *warrant* declarar “a importância do crédito garantido pelo penhor da mercadoria, a taxa de juros e a data de vencimento” (Decreto n. 1.102/1903, art. 19), transcrevendo-as no conhecimento de depósito. O endossatário – pessoa que recebe o

warrant – assina o conhecimento de depósito.

Por exemplo: o depositante das mercadorias, ao recebê-los do armazém, endossa o *warrant* a um estabelecimento bancário para obter financiamento de sua produção. O preço ajustado será aquele que convier ao banco que, para tanto, considerará o valor das mercadorias, por avaliação *in loco* ou pelo valor assegurado, subtraídos os mencionados montantes para pagamento do fisco e demais encargos. Em seguida, esse mesmo depositante transfere, também por endosso, o conhecimento de depósito em alienação das mercadorias a outro produtor:



Nesse exemplo, o produtor que recebeu o conhecimento de depósito, ciente que o recebeu separadamente do *warrant*, sabe que seu direito à livre disposição das mercadorias está limitado pelo direito do portador do *warrant*, o banco financiador. Este, por seu turno, dispõe do direito ao crédito – a promessa de pagamento da importância declarada no *warrant* – garantida pelo penhor das mercadorias que estão depositadas no armazém. Seu direito, em relação a essas mercadorias, é de credor pignoratício, isto é, a mercadoria vincula-se ao pagamento de seu crédito, conferindo a seu portador o direito de vir a recebê-lo pelo produto da venda da mercadoria.

O armazém somente entregará a mercadoria a quem apresentar os dois títulos ou ao portador do conhecimento de depósito se este consignar importância suficiente para pagamento do *warrant* (principal e juros até o vencimento), dos tributos, do custo de armazenagem vencida e demais despesas eventualmente contadas.

7.2.8. Responsabilidade dos endossantes do *warrant*

Se no vencimento o *warrant* não for pago, por ato espontâneo dos devedores (endossantes e avalistas do *warrant*) ou pela consignação de pagamento comunicada pelo armazém-geral ao primeiro endossante do *warrant*, o portador desse título deve protestá-lo por falta de pagamento, seguindo a regra aplicável às letras de câmbio.

Realizado o protesto, o credor dispõe do prazo de dez dias, contados da realização do protesto, para dar início à venda das mercadorias, em leilão extrajudicial. Decorridos os prazos sem protesto e sem que se dê início à venda extrajudicial, o portador do *warrant* perde o direito de ação contra os devedores de regresso do *warrant*, permanecendo, contudo, com o direito de acionar o primeiro endossante desse título e todos os endossantes do conhecimento de depósito.

7.2.9. Responsabilidade dos endossantes do conhecimento de depósito

Distinto o tratamento dos endossantes nos títulos estudados e, ainda, distinta é a solução jurídica quando se tratar dos efeitos do endosso em relação aos endossantes anteriores no conhecimento de depósito e para com o portador do *warrant*, objeto dos dois estudos que se seguem.

a) Responsabilidade entre endossantes do conhecimento de depósito

A obrigação dos endossantes no conhecimento de depósito refere-se tão somente aos limites do direito que lhes foi outorgado ao figurarem na cadeia de endossos: o de se responsabilizarem pela *existência das mercadorias*, uma vez que seu título é o de titular da mercadoria depositada.

Seguindo a lógica dos títulos de crédito, o portador do conhecimento de depósito teria ação contra os endossantes anteriores pela existência da mercadoria transferida

pelo endosso sobre o título.

Contudo, a mercadoria foi depositada e, assim, se existe, satisfeita está a obrigação. A possível ocorrência de perda das mercadorias depositadas por sinistro ou furto ocorrido no interior do armazém acarreta responsabilidade à administração do depósito ou à companhia seguradora e nunca aos endossantes anteriores. Resulta desse entendimento a inexistência de ação de regresso entre o endossatário e os endossantes anteriores.

Em razão desse mecanismo peculiar, distinto daquele que reveste o *warrant*, o portador do conhecimento de depósito não precisa protestar o título porque a lei não lhe reserva ação de regresso contra os anteriores endossantes.

b) Responsabilidade para com o portador do warrant

Outra, entretanto, é a responsabilidade dos endossantes do conhecimento de depósito para com o portador do *warrant*, pois, ao adquirir, por endosso, o conhecimento de depósito, o faz com a ciência quanto ao montante que onera as mercadorias que lhe foram transferidas. O portador do conhecimento de depósito sabe que é proprietário das mercadorias depositadas, mas está ciente, igualmente, da limitação de seu direito à livre disposição desses bens em razão do penhor imposto no *warrant* e transcrito no conhecimento de depósito.

Por que seu direito de crédito incide sobre as mercadorias depositadas, o portador do *warrant* pode acionar os endossantes do conhecimento de depósito, conforme decorre do § 7º do art. 23 do Decreto n. 1.102/1903: “O portador do *warrant* que, em tempo útil, não interpuser o protesto por falta de pagamento, ou que, dentro de dez dias, contados da data do instrumento de protesto, não promover a venda da mercadoria, conservará tão somente ação contra o primeiro endossador do *warrant* e contra os *endossadores do conhecimento de depósito*” (grifo nosso).

Vale dizer (v. item 7.2.8) que, se houve protesto tempestivamente interposto e, em seguida, venda extrajudicial das mercadorias, duas soluções são possíveis: (a) satisfação integral do crédito pelo produto da venda; (b) não satisfação integral do crédito e direito ao portador do *warrant* de acionar os endossantes anteriores do

warrant (e não os do conhecimento de depósito) a lhe pagar o que faltar (Decreto n. 1.102/1903, art. 25). O endossante que pagar tem ação de regresso contra o primeiro endossante do *warrant*.

Mas, se não houve protesto e, tampouco, venda extrajudicial, nos prazos fixados pelo legislador, o portador do *warrant* ainda dispõe de ação *judicial* – não mais de venda extrajudicial – contra o primeiro endossante desse título e contra *todos* os endossantes do conhecimento de depósito. Em relação ao primeiro, por ser o devedor principal, pelo total do crédito; no tocante aos demais (endossantes do conhecimento de depósito), a obrigação se firma no limite do valor das mercadorias depositadas e não na totalidade da dívida.

De observar que a ação que o portador do *warrant* detém não é ação para entrega das mercadorias, mas execução de crédito que onera essas mercadorias. O endossante do conhecimento de depósito que, acionado, pagar a dívida, tem ação de regresso contra o devedor principal, o primeiro endossante do *warrant*.

7.2.10. Warrants de produtores rurais

As regras gerais da armazenagem e da emissão dos títulos de crédito ora estudados encontram-se no Decreto n. 1.102/1903. Contudo, a Lei n. 9.973, de 29 de maio de 2000, dispôs distintamente sobre a armazenagem de “produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico”.

Portanto, quando a armazenagem referir-se a esses produtos, o contrato de depósito obedecerá às inovações introduzidas nos seguintes aspectos contratuais: (a) o preço dos serviços é fixado por livre acordo entre as partes (art. 3º, § 1º); (b) responsabilidade solidária do titular da empresa individual, do presidente, do diretor e do sócio-gerente da sociedade empresarial ou do equivalente no caso de cooperativas pelas mercadorias recebidas em depósito (art. 6º, § 2º); (c) indenização devida pelo armazém nos casos de furto, roubo e sinistros, definida na norma regulamentadora (art. 6º, § 4º); (d) isenção de responsabilidade do armazém depositário pela natureza, tipo, qualidade e “estado de conservação dos produtos contidos em invólucros que impossibilitem sua inspeção” (art. 6º, § 5º); (e)

obrigatoriedade de celebração de contrato de seguro por parte do depositário “contra incêndio, inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriore” (art. 6º, § 6º); (e) permissão de prática, pelo armazém, de comércio de produtos da mesma espécie daqueles usualmente recebidos em depósito (art. 8º); (f) obrigação acessória de o armazém prestar informações sobre a emissão de títulos e de débitos que oneram os produtos depositados e de encaminhar informações ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, órgão ao qual se faculta o direito de “livre acesso aos armazéns para verificação da existência do produto e suas condições de armazenagem” (arts. 10 e 11).

7.2.11. Certificado de depósito e *warrants* agropecuários

Complementando o regramento da Lei n. 9.973/2000, que tratou especificamente sobre as regras de armazenamento do produto agropecuário, seguiu-se a Lei n. 11.076, de 30 de dezembro de 2004, que dispôs sobre os títulos que podem ser emitidos pelos armazéns e cooperativas que mantêm em depósito esses produtos, instituindo dois novos títulos, similares em regime jurídico ao conhecimento de depósito e ao *warrant*, qualificados pelo acréscimo do vocábulo *agropecuário*.

As definições legais vêm previstas no art. 1º: Certificado de Depósito Agropecuário – CDA “é título de crédito representativo de promessa de entrega de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, depositados em conformidade com a Lei n. 9.973, de 29 de maio de 2000” e *Warrant* Agropecuário – WA “é título de crédito representativo de promessa de pagamento em dinheiro que confere direito de penhor sobre o CDA correspondente, assim como sobre o produto nele descrito”.

Distinguem-se esses títulos daqueles outros previstos no Decreto n. 1.102/1903 na exigência de endosso completo, isto é, em preto e na dispensa de protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra endossantes e avalistas, bem como na possibilidade de emissão escritural ou eletrônica, modalidade inexistente no início do século XX, época da promulgação da legislação concebida por Carvalho de Mendonça.

De forma mais precisa, no tocante à descrição e identificação da mercadoria, o art. 5º da Lei n. 11.076/2004 exige para a emissão dos títulos os seguintes requisitos, objeto de nossas considerações no item 7.2.6:

- I – denominação do título;
- II – número de controle, que deve ser idêntico para cada conjunto de CDA e WA;
- III – menção de que o depósito do produto sujeita-se à Lei n. 9.973, de 29 de maio de 2000, a esta Lei e, no caso de cooperativas, à Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971;
- IV – identificação, qualificação e endereços do depositante e do depositário;
- V – identificação comercial do depositário;
- VI – cláusula à ordem;
- VII – endereço completo do local do armazenamento;
- VIII – descrição e especificação do produto;
- IX – peso bruto e líquido;
- X – forma de acondicionamento;
- XI – número de volumes, quando cabível;
- XII – valor dos serviços de armazenagem, conservação e expedição, a periodicidade de sua cobrança e a indicação do responsável pelo seu pagamento;
- XIII – identificação do segurador do produto e do valor do seguro;
- XIV – qualificação da garantia oferecida pelo depositário, quando for o caso;
- XV – data do recebimento do produto e prazo do depósito;
- XVI – data de emissão do título;
- XVII – identificação, qualificação e assinatura dos representantes legais do depositário;
- XVIII – identificação precisa dos direitos que conferem.

Entre outras alterações que o distinguem do sistema de 1903, encontra-se a obrigatoriedade de registro do Certificado de Depósito Agropecuário e do *Warrant*

Agropecuário no sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central, no prazo de trinta dias, contado da data da emissão dos títulos. Com o registro faz-se a entrega dos títulos em custódia de instituição financeira, mediante endosso-mandato. Objetivou-se, com isso, a utilização desses títulos como “lastro em operações no mercado financeiro e de capitais”, como bem lembra Fábio Ulhoa Coelho (2017:295).

7.2.12. Títulos de cooperativa

Alterada pela Lei n. 11.076/2004, a lei das cooperativas (Lei n. 5.764/1971, art. 82) permitiu que essas sociedades, quando se dedicarem à venda em comum, pudessem registrar-se como armazém-geral e expedir todos os quatro títulos ora estudados, desde que autorizada pelo seu objeto social: conhecimento de depósito, *warrant*, certificado de depósito agropecuário, *warrant* agropecuário.

7.3. Conhecimento de transporte

7.3.1. Origem, definição e conceito

Retroagindo a 10 de maio de 1293, Filipe Themudo Barata (1998:279) inicia a história dos fretes, resgatando o primeiro acordo relacionado a transportes marítimos, assinado pelo rei de Portugal: “Segundo essa carta, os navios de mais de 100 tonéis, quer fossem para o Norte da Europa, quer se dirigissem ao Mediterrâneo, pagariam 2 soldos de estrelins, por cada frete, enquanto as embarcações com uma tonelagem inferior só pagariam a metade”.

As cidades litorâneas portuguesas conheceram, desde cedo, regras e acordos visando regular o mercado de transporte marítimo. Filipe Barata (1998:280) assinala que, em 1324, “a cidade do Porto, por acordo entre o Concelho⁵⁵ e os homens-bons, o que provavelmente significaria a posição comum dos mercadores e dos proprietários e mestres de navios, definiu um primeiro conjunto de regras: corretagem obrigatória dos fretes, através da eleição anual de 4 fretadores, os quais receberiam salário, estando estes ainda obrigados a realizarem uma distribuição equitativa dos fretes pelos diferentes navios. Para que não houvesse problemas de última hora, os

mercadores seriam avisados, com antecedência, do número de embarcações disponíveis e da época do ano em que poderiam ser fretadas, embora o frete fosse negociado com os mestres dos navios. Estabeleciam-se ainda as regras básicas da estiva, incluindo o salário dos carregadores, excluindo dessa função os mercadores”.

Essas e outras regras serviram para que as Ordenações Afonsinas regulassem os fretes marítimos no Título V do Livro IV, sob a rubrica “Das Cartas dos Fretamentos dos Navios” tomando como base as práticas extraídas dos contratos de afretamento e a Lei das Sete Partidas. Afirma Filipe Barata (1998:283) que, “segundo ela, entre as partes deveria ficar ajustado o preço e as condições de pagamento, bem como os portos que a embarcação deveria escalar, dependendo disso da vontade do mercador. Este deveria comprometer-se a carregar o navio, dentro de certo prazo, com as mercadorias que pretendia transportar. Ao mestre ou proprietário competiria zelar pela segurança geral do navio e da navegação e assegurar que o equipamento e a tripulação corresponderiam às necessidades da viagem. Por fim, acertavam-se as penas e o foro judicial a que uma eventual violação do contrato deveria ser submetida [...]”.

Nesse período a normatividade restringia-se a questões relacionadas aos direitos de partilha e de concorrência entre os proprietários de navios, cabendo aos contratos estipular os direitos e as obrigações entre o transportador e o dono da mercadoria transportada.

Esse conjunto de práticas veio consolidado nas legislações modernas, cabendo aos arts. 99, 100 e 566 do *Código Comercial de 1850* estabelecer, respectivamente, os princípios que regiam os contratos de transporte terrestre e marítimo, respectivamente. O primeiro estabelece o direito a uma comissão, frete ou aluguel pelo serviço de transporte e impõe a obrigação de os “barqueiros, tropeiros e quaisquer outros condutores de gênero, ou comissários” a empregar toda diligência para que o produto transportado não se deteriore, respondendo por perdas e danos. O segundo determina a expedição de uma *cautela* ou *recibo*, contendo a descrição do contrato firmado. O terceiro exige que o fretamento se prove por escrito, por *carta-partida* ou *carta de fretamento* e, ainda, por *conhecimento*, respectivamente, nos

casos de fretamento da totalidade e de parte da embarcação.

Até a promulgação do Decreto n. 19.473, de 10 de dezembro de 1930, os documentos expedidos serviam à única função de comprovar um contrato de transporte. Coube ao art. 1º desse diploma legal dar dupla finalidade ao documento expedido pelo transportador, reiterando, na primeira parte, sua vocação original: “O conhecimento de frete original, emitido por empresas de transporte por água, terra ou ar, prova o recebimento da mercadoria e a obrigação de entregá-la no lugar do destino. Reputa-se não escrita qualquer cláusula restritiva, ou modificativa, dessa prova, ou obrigação”; e na parte final, a tipologia jurídica: “É título à ordem; salvo cláusula ao portador, lançada no contexto”.

Partindo dessa definição legal podemos conceituar conhecimento de transporte como título representativo, emitido à ordem – salvo cláusula expressa ao portador – por empresa de transporte aéreo, terrestre ou marítimo que concede a seu titular o direito ao transporte e de entrega do produto nele descrito.

7.3.2. Características

Distingue-se o conhecimento de transporte dos títulos de crédito próprios pelo fato de ser título representativo da mercadoria transportada e, nesse aspecto, classifica-se ao lado do conhecimento de depósito e do *warrant*. Assemelha-se a estes dois títulos, ainda, pelo fato de ser título causal, não abstrato⁵⁶, nascido de contrato de transporte de mercadoria.

Entretanto, uma terceira característica que lhe é própria – a não executividade por quantia certa – o afasta daqueles. De fato, o Código de Processo Civil⁵⁷ não o arrola entre os títulos executivos extrajudiciais, conduzindo James Siano⁵⁸ à inafastável conclusão: “[...] o conhecimento de transporte é título de crédito, mas não possui executividade, pois ausentes os requisitos objetivos, da certeza e da exigibilidade, legitimando, quando muito, ação de execução para entrega de coisa certa (art. 621, CPC73), mas não execução por quantia certa”.

7.3.3. Espécies

Dependendo do meio utilizado, o conhecimento de transporte pode receber o qualificativo correspondente. Há, assim: (a) **conhecimento de transporte terrestre**, rodoviário ou ferroviário, regidos pelo Decreto n. 19.473/30, com as alterações introduzidas pelos Decretos n. 19.754/31, 20.454/31 e 21.736/32 e, ainda, se ferroviário, pela definição dada pelo art. 20 do Decreto n. 1.832, de 4 de março de 1996; (b) **conhecimento de transporte marítimo**, regido pelo art. 575 do Código Comercial, por força do § 1º do art. 2º do Decreto n. 19.473/30; (c) **conhecimento de transporte aéreo**, regulado pelo art. 235 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986); (d) **conhecimento de transporte multimodal**, relativo ao transporte de cargas definido no art. 2º da Lei n. 9.611, de 19 de fevereiro de 1998, como “aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal”⁵⁹.

7.3.4. Requisitos

São requisitos das várias espécies de conhecimento de transporte:

REQUISITOS	TERRESTRE	MARÍTIMO	AÉREO	MULTIMODAL
Legislação aplicável	Art. 2º do Decreto n. 19.473/30	Art. 575 do Código Comercial	Art. 235 da Lei n. 7.565/86	Art. 10 da Lei n. 9.611/98
Identificação das partes:	O nome ou denominação da empresa emissora. Os nomes do remetente e do consignatário, por extenso, e, na falta deste, será ao portador.	O nome do capitão e o do carregador consignatário (podendo omitir-se o nome deste se for à ordem), e o nome e porte do navio.	O nome e endereço do expedidor, do transportador e do destinatário.	O nome, a razão ou denominação social e o endereço do emitente, do expedidor, bem como do destinatário da carga ou daquele que deva ser notificado, quando não nominal.

N. de identificação	N. de ordem		O número das vias de conhecimento.	
Lugar e data	Com indicação de dia, mês e ano. Havendo lugar de partida, considera-se este o da emissão.		Lugar e data da emissão.	Data e local da emissão.
Percurso	Lugar de partida e o destino.	Lugar de partida e o do destino, com declaração de escalas, havendo-as.	Os pontos de partida e destino.	Os locais de origem e destino.
Descrição dos bens	A espécie e a quantidade ou peso da mercadoria, bem como as marcas, os sinais exteriores dos volumes de embalagem.	A qualidade e a quantidade dos objetos da carga, suas marcas e números, anotados à margem.	A natureza da carga. O número, acondicionamento, marcas e numeração dos volumes. O peso, a quantidade e o volume ou dimensão. O valor declarado, se houver.	A descrição da natureza da carga, seu acondicionamento, marcas particulares e números de identificação da embalagem ou a própria carga, quando não embalada. A quantidade de volumes ou de peças e o seu peso bruto.
Preço	Valor do frete, lugar e forma de pagamento.	O preço do frete e primagem ¹⁰ , se esta for estipulada, e o lugar e forma de pagamento.	O preço da mercadoria, quando a carga for expedida contra pagamento no ato de entrega, e, eventualmente, a importância das	Valor do frete, com indicação “pago na origem” ou “a pagar no destino”.

			despesas.	
Assinaturas	Do emitente ou de seu representante, abaixo do contexto.	Do capitão, e a do carregador ¹¹ .		
Prazo			O prazo de transporte, dentro do qual deverá o transportador entregar a carga no lugar do destino, e o destinatário ou expedidor retirá-la.	
Outras cláusulas			Os documentos entregues ao transportador para acompanhar o conhecimento.	A indicação “negociável” ou “não negociável” na via original, podendo ser emitidas outras vias, não negociáveis.

60,61

7.3.5. Circulação

O conhecimento de transporte circula por simples tradição, se ao portador ou por endosso, em preto ou em branco, atestando-se, neste caso, com o lançamento da assinatura do endossante a titularidade, do portador ou do endossatário nominado, das mercadorias descritas.

Este endosso é chamado pignoratício, introduzido no Brasil pelo Decreto n. 19.473/31, segundo nos lembra Waldemar Ferreira, citado por Waldirio Bulgarelli (1996:452), pois “confere ao endossatário o penhor ou garantia, dando-lhe assim poderes para retirar a mercadoria etc.”.

O art. 1º do Decreto n. 20.454/31 acrescentou a possibilidade de emissão de

conhecimento não à ordem, proibindo, com essa cláusula expressa no título nominativo, sua circulação.

LIVRO II

CONTRATOS EMPRESARIAIS

Capítulo 8

TEORIA GERAL DOS CONTRATOS

Sumário: 8.1. Fontes de obrigações. 8.2. Conceito. 8.3. Contratos empresariais. 8.4. Princípios informadores. 8.5. Classificação dos contratos.

8.1. Fontes de obrigações

As obrigações assumidas por qualquer pessoa – natural ou jurídica, empresário ou não – têm origem na lei, nas declarações unilaterais de vontade, nos contratos e em atos ilícitos. Por esta razão, essas manifestações são denominadas fontes de obrigações.

A lei. Quando a lei tributária, por exemplo, impõe que o proprietário de veículo automotor pague anualmente o imposto sobre a propriedade desse bem (IPVA), estamos diante de uma relação obrigacional decorrente de lei. O Estado descreve uma situação hipotética (se proprietário de veículo automotor) que incide sobre um determinado número de pessoas (os proprietários de veículos automotores), fazendo nascer a obrigação tributária (dever de pagar o IPVA anualmente).

Declarações de vontade. As declarações de vontade podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Os negócios unilaterais decorrem das primeiras e são assim chamados porque possuem uma só parte, o que não deve ser confundido com o número de pessoas que os manifestam. Uma ou mais pessoas podem agir numa mesma direção, visando ao mesmo objetivo; esse ato de vontade é unilateral. Por exemplo, a emissão de um cheque ao portador pelo titular ou titulares da conta bancária não depende de manifestação em sentido contrário para que produza obrigações. É uma declaração unilateral de vontade que gera a obrigação de pagar a quantia nele inserida. Outro exemplo: o anúncio público de recompensa ou de gratificação a quem

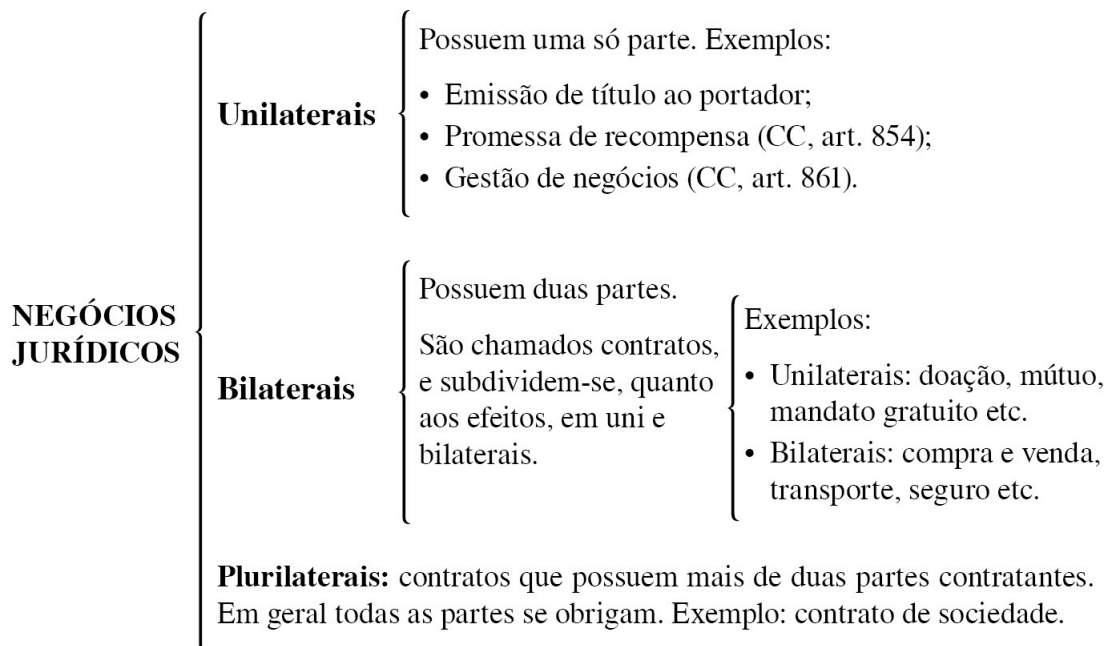
preencha certa condição ou desempenhe certo serviço obriga o anunciante (ou anunciantes), independentemente de qualquer outra manifestação de vontade por parte de terceiros.

Contrato. É o negócio jurídico que envolve duas ou mais partes contratantes que, por essas características, é classificado como contratos bilaterais e contratos plurilaterais. No contrato, as partes (sempre mais de uma) manifestam, de forma convergente, sua vontade visando à realização de um determinado negócio jurídico.

Os contratos podem ser *de efeitos unilaterais* ou *de efeitos bilaterais*. Será chamado unilateral se obrigar apenas uma das partes contratantes e bilateral se ambos os contratantes obrigam-se.

De uma forma resumida temos: (a) quanto ao número de declarações de vontades e partes envolvidas, os *negócios jurídicos* são unilaterais, bilaterais ou plurilaterais – estes dois últimos denominam-se contratos; (b) quanto às obrigações que geram os *contratos* podem obrigar uma só parte ou todas elas, sendo assim chamados, quanto aos efeitos que produzem em relação às partes, unilaterais ou bilaterais.

Os conceitos de unilateralidade e de bilateralidade são, portanto, ambíguos, servem tanto para indicar o número de partes *num negócio jurídico* como, igualmente, para distinguir, *nos contratos* (que são sempre negócios jurídicos bilaterais ou plurilaterais), o número das que nele se obrigam.



Atos ilícitos. Atos ilícitos são ações ou omissões voluntárias, negligentes ou imprudentes que violam direito e causam dano a outrem. São igualmente fonte obrigacional porque deles resulta o dever jurídico de ressarcir a lesão causada ao ofendido, em toda a sua extensão.

8.2. Conceito

Os doutrinadores enfatizam, a seu modo, aspectos que consideram mais relevantes à conceituação de contrato.

Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:22) salienta a natureza jurídica e o caráter obrigacional dos contratos:

“Contrato é o negócio jurídico bilateral ou plurilateral gerador de obrigações para uma ou todas as partes, às quais correspondem direitos titulados por elas ou por terceiros”.

Maria Helena Diniz (2007, 3:14), a obediência à ordem jurídica, a finalidade e o caráter patrimonial:

“[...] *contrato* é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza

patrimonial”.

Orlando Gomes (2008:11) prefere indicar a conduta e os interesses das partes:

“*Contrato* é, assim, o negócio jurídico bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses que regulam”.

O Código Civil de 2002 impôs aos contratos a obediência a duas cláusulas gerais, relativas aos princípios da boa-fé e probidade (art. 422) e ao cumprimento da função social (art. 421), razão pela qual entendemos que essas características são relevantes e os distinguem de outras ações humanas, devendo ser incluídas no conceito. Correto também indicar a natureza jurídica e o objeto da manifestação de vontade. Um conceito com esses elementos, baseado na doutrina exposta, poderia ser assim formulado:

Contrato é, pois, o negócio jurídico em que duas ou mais partes contratantes concorrem para criar, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial, sujeitando-se, durante a conclusão e execução, aos princípios da boa-fé objetiva e da função social.

8.3. Contratos empresariais

No sistema do Código Civil de 1916, considerava-se contrato comercial os que decorriam de negócios mercantis, como afirma Fran Martins (1993:77): “uma diferença que se pode estabelecer entre contratos civis e comerciais é que estes serão sempre os praticados pelos comerciantes no exercício de sua profissão, enquanto aqueles são os que qualquer pessoa capaz poderá praticar”.

Com a unificação do direito obrigacional, a matéria contratual, à exceção do contrato de transporte marítimo e dos previstos em leis extravagantes, passou a ser regida pelo Código Civil de 2002, tornando necessário justificar o emprego da expressão “contratos empresariais”. Em que sentido se emprega esta locução, uma vez que as regras são comuns e a doutrina a trata indistintamente nos compêndios de direito civil e de direito empresarial?

Para o currículo universitário, há de se traçar uma linha divisória, pois bem se

sabe que a experiência do professor, numa ou noutra disciplina académica, é limitada, bem como o tempo para o tratamento da matéria nos escassos anos de duração do currículo de bacharelado em Direito, ou no desenvolvimento da matéria para os cursos de Administração, Economia e Ciências Contábeis. Interessa-lhes a aplicação dirigida aos negócios empresariais e, nisto, reside também a limitação do conteúdo – algumas espécies contratuais previstas no Código Civil não se integram no campo empresarial.

Como abordar os temas e selecionar as espécies contratuais dentro do universo do direito obrigacional unificado? Justifica-se, pois, ainda hoje a dicotomia como método de estudo no âmbito do direito contratual.

Outra razão, de cunho prático-jurídico, é a constatação de que a unificação obrigacional não milita em desfavor da manutenção da autonomia do Direito Empresarial, pois, como bem afirma Paula Castello Miguel (2006:67), “não há com tratar de forma idêntica os contratos firmados por pessoas comuns, a fim de regular uma ou outra relação obrigacional, com os contratos firmados entre empresários no exercício de sua atividade econômica”.

Fábio Ulhoa Coelho (2016, 3:22) optou por estudar os *contratos entre empresários* em seu *Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa*, asseverando que “esse é o campo de interesse da tecnologia comercialista. Quando a relação contratual se estabelece entre o empresário e um sujeito de direito não dedicado à exploração de atividade empresarial (empregado, profissional liberal, estado etc.), seu estudo deve ser feito por outros ramos da tecnologia jurídica”.

De nossa parte, entendemos que muitos contratos têm sua origem no desenvolvimento histórico do Direito Comercial e não poderiam ser dispensados no processo de seleção dentre as diversas modalidades de contratos e outros são, necessariamente, contratos entre empresários, podendo, entretanto, gerar efeitos a pessoas não empresárias. Nesse processo algumas dificuldades surgem ao se verificar que o conceito precede ao uso – empresarial ou não empresarial – e, neste caso, a abordagem unificada é recomendável.

No estudo dos contratos empresariais, portanto, reconhecendo que somente podem

ser assim qualificados os realizados entre empresários, estenderemos nosso estudo a alguns efeitos não empresariais quando necessários à compreensão da matéria e ao estudo das origens comerciais dos institutos.

Entre as espécies contratuais, o estudioso pode notar, neste volume, a ausência dos contratos de propriedade industrial, de locação empresarial e de sociedade, o que se faz em razão de esses estudos terem sido tratados no 1º volume deste *Curso*, objeto dos capítulos 7 (Ponto Empresarial), 8, 9, 10 (Propriedade Industrial, incluindo as patentes de invenção e de modelos de utilidade, o registro de desenho industrial e o registro de marcas e indicações geográficas e, em especial, o tratamento das licenças, nos itens 8.8, 8.9, 9.8, 10.8 e 10.9) e 17 (Da Constituição das Sociedades em Geral).

Justifica-se, também, com essas considerações, a não abordagem de toda a matéria do Título V (Dos Contratos em Geral) da Parte Especial do Código Civil, por se comum a todos os contratos – empresariais e não empresariais –, delas mencionando somente em casos pontuais pertinentes aos contratos entre empresários ou essenciais à compreensão do estudo das espécies contratuais.

8.4. Princípios informadores

A doutrina não adota uma uniformização na exposição dos princípios informadores do contrato.

Há, entretanto, unanimidade quanto a serem fundamentais os princípios da autonomia da vontade, do consensualismo, os da força obrigatória e da relatividade dos efeitos do contrato, fundados na teoria histórica e reproduzidos ao longo de séculos de sedimentação da tecnologia dos contratos.

Mais modernamente, sobretudo após a promulgação do Código Civil de 2002, outros três princípios passaram a ser compreendidos como essenciais à relação contratual: a boa-fé e probidade, na sua conclusão e execução; o equilíbrio econômico, a permitir a revisão contratual se constatada onerosidade excessiva; e a função social do contrato.

Vejamos cada um desses princípios, obedecendo, na exposição, à sequência lógica de inter-relacionamento entre eles:

a) Princípio da autonomia da vontade

Fruto de construção histórica⁶², o princípio da autonomia da vontade, isto é, o poder de a pessoa “suscitar, mediante declaração de vontade, efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica” (Gomes, 2008:25), tem sua origem na expressão de Kant sobre a vontade individual que, segundo assinala Fábio Ulhoa Coelho (2007:3:6), “guia-se exclusivamente por si mesma, pautando suas escolhas pelas máximas que quer como leis universalmente válidas”.

No Direito essa vontade não tem a mesma extensão de autonomia que lhe é reservada pela Moral. Se neste campo valoram-se as escolhas – furtar e não furtar, mentir ou não mentir, danificar ou não danificar a propriedade de alguém – pautadas naquilo que queremos, sem sermos incomodados pelo Estado, no Direito sofremos a coerção das normas que, postas pelos legisladores, somos obrigados a obedecer. A Moral é assim autônoma, “por ter como fonte a própria natureza humana, por regular a vida interior, compelindo o homem, se ele quiser, à objetivação do bem individual; logo o sujeito é autolegislator” (Diniz, 2000:375) e o Direito é heterônomo, no sentido de “ser posto por terceiros aquilo que juridicamente somos obrigados a cumprir” (Reale, 2006:49).

Diante disso, no Direito, a livre manifestação de vontade da pessoa natural ou jurídica, ao criar, modificar e extinguir direitos, encontra fundamento na não proibição legal e, portanto, no reconhecimento jurídico de seus efeitos.

O Código Civil de 2002 apresenta dois dispositivos que expressam a liberdade de contratar: o primeiro, limitando essa liberdade à função social do contrato (art. 421) e o segundo, declarando lícita a estipulação de contratos atípicos, isto é, os que não foram regulados pela lei, desde que observadas as normas gerais nele estabelecidas (art. 425).

Essas formulações legais restringem a liberdade dos contratantes e se somam aos casos de proibição de contratar por violação da *ordem pública* e dos *bons costumes*, como, por exemplo, a fixação de juros usurários (Decreto n. 22.626/33) e a exploração de casa de prostituição.

Franz Wieacker (1967:633-634) acentua que a liberdade de contratar é um princípio funcional mutável, atrelado às necessidades que se apresentam no desenvolvimento do direito social:

“[...] No domínio da economia da empresa estas limitações restringem-se ao controle, do ponto de vista da economia de mercado, dos cartéis e dos preços de monopólio inadmissíveis. Por outro lado, no domínio global das empresas de abastecimento, de transporte (incluindo o transporte de mercadorias de longo curso), de seguros e das profissões liberais, a restrição de serviços está geralmente sujeita ao tabelamento pelos poderes públicos. No domínio do comércio de produtos alimentares agrícolas, domina – tanto no interesse dos produtores agrícolas como da fixação pública dos preços – uma organização dirigida do mercado, apesar de uma progressiva liberalização. As condições de crédito das instituições bancárias estão sujeitas, como meio essencial de direção das necessidades de capital do conjunto da economia, à regulamentação pública das condições de crédito e a sua inspeção. A partir daqui, a jurisprudência reserva-se, em crescente medida, a correção dos abusos da liberdade contratual através de cláusulas contratuais obrigatórias”.

Limitada a disposições dessa textura, a liberdade de contratar estende-se a todos os aspectos do negócio jurídico, isto é, ao querer ou não contratar, com quem contratar e em que termos contratar.

Gozamos, assim, em primeiro lugar, de liberdade para contratar ou de não contratar e, nesse contexto, temos a faculdade de *rescindir o que foi acordado*.

Há, entretanto, mitigações aqui e acolá. Digno de nota é o art. 39, II, do Código de Defesa do Consumidor que veda ao fornecedor de produtos ou serviços “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes”. Esse dispositivo não significa literalmente a obrigação de o fornecedor contratar (Marques e Benjamin, 2006:562), mas impede, entre outras práticas, a discriminação e a recusa de cumprimento à oferta, mesmo quando contida informação ou publicidade veiculada a público (CDC, arts. 30 e 35).

Em segundo lugar, cabe aos contratantes a escolha da outra parte, o que implica considerar se autorizam ou não a cessão ou a sub-rogação do contrato, isto é, a modificação do polo contratual por outra pessoa que não a primeira com quem contrataram. Essa autorização decorre do contrato ou da regência legal sobre o contrato. No contrato de sociedade, por exemplo, quando o vínculo é pessoal, o ingresso de novo sócio (novo contratante) depende do consentimento dos demais sócios (CC, art. 1.003).

Observa-se que nem sempre é possível a livre escolha da outra parte no contrato ou de seus termos. Cláudia Lima Marques (1999:119) lembra que “a concentração das empresas e os monopólios, estatais e privados, reduziram a liberdade de escolha do parceiro. Em casos de serviços imprescindíveis, como água, luz, transporte, fala-se mesmo em obrigação de contratar, assim também no caso de seguros tornados obrigatórios, pois permanece a liberdade de escolha do parceiro, mas não a de redigir ou não o contrato. O dirigismo contratual passa a dominar”.

Em terceiro lugar, segue-se a liberdade sobre os termos do contrato. Nesse campo, as imposições da economia e vida modernas conduziram à formulação contratual sob a modalidade de adesão, na grande maioria dos contratos, sobretudo nos destinados a consumo. Essa prática implicou alterações sobre o próprio conceito de contrato, sobre a qual Orlando Gomes (2008:31) acentua:

“Falou-se, então, na *decadência do contrato*, porque as cláusulas de alguns deixaram de ser livremente determinadas pelas partes. Afirmou-se que a noção clássica deixara de corresponder à realidade. Relações jurídicas, oriundas tradicionalmente de contrato, passaram a ser explicitadas com efeito de causa diversa, admitida, como foi, por certas correntes doutrinárias, a natureza unilateral do ato de formação”.

b) Princípio da função social do contrato

Modernamente, a liberdade de contratar sofre limitações que acentuam o caráter de mutação a que o direito contratual encontra-se exposto em seu desenvolvimento.

O art. 421 do Código Civil expressamente dispõe um sobreprincípio ao princípio

clássico da autonomia da vontade: “a *liberdade de contratar* será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Acresce-se ao contrato, pois, uma nova *função limitadora* a ser observada, somando-se à função econômica perseguida pelas partes contratantes.

Teresa Ancona Lopez (2007:64-65), corretamente, afirma que “a função social não é o objetivo do contrato”, porque essa compreensão afrontaria a ordem econômica e a livre-iniciativa. Para a doutrinadora, função social é “limite da autonomia privada”, mas não objetivo do contrato. Nessa limitação a função social do contrato impõe aos contratantes deveres de duas naturezas: o primeiro, de “realizar sua função *econômica* dentro da sociedade, fazendo circular as riquezas e, assim, impulsionando o seu progresso material e conseqüentemente instalando o bem-estar social” e o segundo, de não prejudicar “os interesses extracontratuais, de terceiros ou da coletividade, quando da regulação de seus próprios interesses”.

A I Jornada de Direito Civil realizada em Brasília, nos dias 12 e 13 de setembro de 2002, pelo Conselho da Justiça Federal, apresentou três conclusões a respeito da função social do contrato, no que tange aos terceiros, à efetividade do pacto entre as partes contratantes e os casos de mitigação do princípio da autonomia contratual:

21 – Art. 421: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito.

22 – Art. 421: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas.

23 – Art. 421: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.

Posteriormente, na IV Jornada, realizada entre 25 e 27 de outubro de 2006, ficou explicitada a extensão de seus efeitos sobre as partes contratantes:

360 – Art. 421: O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes.

Os enunciados remetem a aplicação prática do princípio da função social a interesses internos (conservação do contrato, trocas úteis e justas) e a interesses externos (metaindividuais ou individual relativo à dignidade da pessoa humana).

Ao definir função social como cláusula geral, os enunciados refletem o entendimento uniforme da doutrina. Significa que, ao contrário da redação das cláusulas escritas nos contratos firmados pelos particulares, sua formulação não é precisa, seu conteúdo é aberto, possibilitando a graduação, pelo Poder Judiciário, quanto à extensão e aos efeitos de sua inobservância caso a caso (cf. Rosenvald, 2008:410).

Por ser princípio de ordem pública, cabe ao magistrado, nos casos submetidos a seu exame, verificar, na apreciação das cláusulas formuladas pelas partes contratantes e na execução do contrato, a incidência da limitação prevista no art. 421 do Código Civil, reordenando o contrato para possibilitar que atinja o objetivo preconizado pela norma.

Veja-se, por exemplo (REsp n. 1641131/SP, Rel. Min. Nancy Andrichi, Terceira Turma, j. 16-2-2017, *DJe* 23-02-2017):

“1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta.

2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora.

3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem

harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio *pacta sunt servanda*.

4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.

5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas – não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes –, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso.

6. Recurso especial provido.”

Ainda como exemplo, pode o magistrado declarar que “negócios jurídicos nulos produzam efeitos a serem preservados quando justificados por interesses merecedores de tutela” (CJF, Enunciado n. 537).

c) Princípio da probidade e boa-fé objetiva

O estudo do princípio da boa-fé objetiva, na sequência da exposição do princípio da função social, deve-se ao fato de que ambas trazem traço comum: são cláusulas gerais, de conteúdo vago, impreciso e aberto que remetem sua apreciação ao caso concreto, pelo juiz da causa.

A qualificação “objetiva” à boa-fé serve para distinguir a virtude interna dos indivíduos (boa-fé subjetiva) das condutas esperadas das pessoas que contratam (boa-fé objetiva). Pretendeu o legislador tornar claro que a imprecisão da expressão não se encontra na dificuldade de se constatar o *estado psicológico* de um indivíduo, mas em conhecer sua *obediência a uma regra de conduta* esperada na concretização de

negócio jurídico.

Orlando Gomes (2008:44-45) propõe a classificação do princípio da boa-fé objetiva segundo suas três funções: (a) **interpretativa**, conforme previsto no art. 113 do Código Civil: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Exemplo da função interpretativa: “1. O Tribunal *a quo* decidiu a questão com base nas provas dos autos, por isso a análise do recurso foge à mera interpretação da Lei de Condomínios, eis que a circunstância fática influi na solução do litígio. Incidência da Súmula 07/STJ. 2. O alcance da regra do art. 3º, da Lei n. 4.591/64, que em sua parte final dispõe que ‘as áreas de uso comum são insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino’, esbarra na determinação da própria lei de que a convenção de condomínio deve estabelecer o ‘modo de usar as coisas e serviços comuns’, art. 3º, § 3º, c, da mencionada Lei. Obedecido o *quorum* prescrito no art. 9º, § 2º da Lei de Condomínio, não há falar em nulidade da convenção. 3. Consoante precedentes desta Casa: ‘o princípio da boa-fé objetiva tempera a regra do art. 3º da Lei n. 4.591/64’ e recomenda a manutenção das situações consolidadas há vários anos (REsp n. 214.680/SP e 356.821/RJ, dentre outros). Recurso especial não conhecido” (REsp n. 281.290/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2-10-2008, *DJe*, 13-10-2008); (b) **supletiva**, quando se refere aos deveres inerentes ao contrato, mesmo quando não expressos em cláusula contratual, como, por exemplo, no contrato de mútuo bancário; o sigilo é inerente, como também ocorre nos negócios empresariais; a colaboração nos contratos assim chamados, v. g., o contrato de franquia. Exemplo jurisprudencial da função supletiva: “Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita em imprevisão” (AgRg no REsp n. 884.066/GO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. em 6-12-2007, *DJ*, 18-12-2007, p. 270); (c) **corretiva**, isto é, como diretriz na revisão de cláusulas abusivas. Exemplo jurisprudencial da função corretiva: “A comissão de concessão de crédito, cobrada pela instituição financeira para fornecer crédito ao mutuário, incide apenas uma vez, no início do contrato. Qualquer outra cobrança do referido encargo é ilícita. A cobrança mensal do referido encargo viola preceitos de boa-fé objetiva, razão pela

qual não deve ser admitida. Recurso Especial provido” (REsp n. 908.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 27-5-2008, *DJe*, 20-6-2008).

Um exemplo prático da função corretiva do princípio da boa-fé é a proibição de comportamento contraditório – *venire contra factum proprium*. O contratante não pode agir de forma contrastante àquela contratada. Sua atitude deve ser sempre a de coparticipação, conduzindo-se de forma a executar o cumprimento do contrato. Se age em sentido inverso, incorre em abuso, abrindo caminho à revisão contratual ou, se sua atitude é omissiva, ao suprimento judicial de sua vontade.

Veja-se o exemplo tirado da jurisprudência:

“Promessa de compra e venda. Consentimento da mulher. Atos posteriores. *Venire contra factum proprium*. Boa-fé. Preparo. [...] 2. A mulher que deixa de assinar o contrato de promessa de compra e venda juntamente com o marido, mas depois disso, em juízo, expressamente admite a existência e validade do contrato, fundamento para a denúncia de outra lide, e nada impugna contra a execução do contrato durante mais de 17 anos, tempo em que os promissários compradores exerceram pacificamente a posse sobre o imóvel, não pode depois se opor ao pedido de fornecimento de escritura definitiva. Doutrina dos atos próprios. Art. 132 do CC. 3. Recurso conhecido e provido”. (REsp n. 95.539/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 3-9-1996, *DJ*, 14-10-1996, p. 39015.)

Outra classificação doutrinária⁶³ pauta-se nos três dispositivos ordenados pelo legislador civil e propõe que a boa-fé objetiva seja aplicada: (a) como regra de conduta obrigatória (CC, art. 422); (b) como função interpretativa (CC, art. 113); e (c) para evitar abusos (CC, art. 187).

No tocante ao momento em que se deve apurar a conduta do contratante, o Código Civil não deixa dúvidas ao dispor que a obrigação de guardar os princípios de probidade e boa-fé opera tanto na *conclusão* do contrato, isto é, na formação e aperfeiçoamento, como na sua *execução*, cobrindo todo o período de negociação até a total execução do contrato, podendo estender mesmo após esta última fase, se a natureza do contrato assim o exigir.

Como ocorre com o princípio da função social, por ser princípio de ordem pública, cabe ao magistrado, nos casos submetidos a seu exame, verificar, na apreciação das cláusulas formuladas pelas partes contratantes e na execução do contrato, a incidência da limitação prevista no art. 422 do Código Civil, reordenando o contrato para possibilitar que atinja o objetivo preconizado pela norma. A obrigação da parte é tão somente demonstrar a existência da violação, conforme Conclusão n. 363 da IV Jornada de Direito Civil: “Art. 422: Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, sendo obrigação da parte lesada apenas demonstrar a existência da violação”; cabe ao juiz sua aplicação, mesmo de ofício.

d) Princípio do consensualismo

O formalismo contratual era acentuado na antiguidade. Lemos, por exemplo, nos escritos bíblicos, o ritual exigido para a compra de um imóvel por direito de preferência⁶⁴. Em regra, os contratos impunham alguma formalidade, com a presença de testemunhas ou a prática de uma determinada solenidade, com a pronúncia de uma fórmula, simbolizando a concretização de um negócio jurídico entre os celebrantes.

De Roma recebemos a distinção jurídica entre consensualidade e formalidade, a partir dos conceitos de *nexum*, *sponsio* e *stipulatio*. O primeiro – *nexum*, de *nectere*, ligar, criar laços – constituía-se em ato solene para o empréstimo em dinheiro, conforme ensinam Alexandre Correia e Gaetano Sciascia (187-188):

“Quando ainda a moeda não era cunhada, o *nexum* se fazia assim: deviam estar presentes as duas partes (futuro credor e futuro devedor), perante cinco testemunhas e um libripense ou porta-balança (*libripens*), pessoa encarregada de pesar o metal. Quem realiza o empréstimo (*tradens*) fazia uma pergunta àquele que o recebia (*accipiens*). Conhecemos só o teor da resposta do *accipiens*: “Reconheço que acabo de receber esta importância para pagar num tempo determinado”. Assim o vínculo era constituído.

Mas quando a moeda veio a ser o *aes signatum*, i. e., cunhada, não houve já

necessidade de pesar o metal. Contudo, continuou a fazer-se a pesagem simbólica, sendo suficiente o *accipiens* tocar na balança com a moeda.

Quando o credor ia receber o dinheiro devido, comparecia com o devedor perante cinco testemunhas e o libripende pesava o metal; assim, com a mesma solenidade contrária era solvida a obrigação (*solutio per aes et libram, contrariu actus*)”.

Ainda segundo os mesmos autores, o *sponsio*, apesar da formação da palavra *sponte* – espontaneamente –, era um ato ainda formal, do qual surgiam vínculos de natureza religiosa. Foi substituído pelo instituto *stipulatio*, “contrato verbal unilateral em que a obrigação de dar ou de fazer nasce de uma resposta que o futuro devedor dá a uma pergunta do futuro credor. O que vai ser credor se chama *reus stipulandi*, e o que vai ser devedor se chama *reus promittendi*”.

Conforme Correia e Sciascia (s/ data:186 e 198), o Direito Romano conheceu outras formas contratuais, fruto do desenvolvimento do direito obrigacional: *contractus re, verbis, literis, consensu*, conforme a natureza do objeto de contratação ou da forma exigida (real, verbal, literal – escrita e consensual). Esta última compreende “todos os atos obrigacionais que se perfazem por força do simples consentimento dos contratantes independentemente de qualquer forma verbal ou escrita e da tradição da coisa”.

O direito moderno afastou-se dessa concepção solene e formal, abraçando-a somente como exceção, expressa em lei, como ocorre com contratos que exigem forma solene ou especial e os reais, que exigem a entrega da *res*. Em regra, os contratos modernos são consensuais, isto é, a simples concordância das partes é suficiente para aperfeiçoá-los.

Lembremos, entretanto, que *todos os contratos* exigem o consentimento das partes contratantes; quando esse for capaz de estabelecer o contrato, sem outra formalidade, diz-se consensual.

e) Princípio da força obrigatória

A expressão latina *pacta sunt servanda* resume o princípio da força obrigatória, também chamado de vinculação das partes, obrigatoriedade da convenção,

intangibilidade ou da conservação dos contratos. O contrato faz lei entre as partes, obrigando-as pelo que contrataram.

Fundado na segurança jurídica, o princípio da força obrigatória destaca a intangibilidade do conteúdo do contrato e sua irretratabilidade, significando dizer que, uma vez aperfeiçoado e obediente ao que dispõe a lei, não se possibilita a alteração de suas cláusulas ou a rescisão por uma das partes sem o consentimento da outra.

Há, entretanto, situações que não podem ser evitadas ou inibidas e que justificam o não cumprimento do contrato pelos contratantes. São os chamados casos fortuitos ou de força maior, circunstâncias que demonstradas pelo contratante o isentam de responder pelos prejuízos deles resultantes e que o impediram de cumprir o contrato (CC, art. 393).

Além desses, o sistema jurídico prevê atenuações à rigidez do princípio. São as modernas construções fundadas na teoria da imprevisão e adotadas pelo legislador brasileiro nos arts. 317 (revisão de prestação excessiva por fatos supervenientes) e 478-480 (resolução por onerosidade excessiva), do Código Civil.

Sobre a imprevisão de pagamento, dispõe o art. 317 do Código Civil: “Quando por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Esse dispositivo limita-se à revisão da prestação e não da cláusula contratual, como ocorre na resolução por onerosidade excessiva.

A expressão “motivos imprevisíveis” aqui utilizada pelo legislador “deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis” (Aguiar Jr., 2007:18).

Nos contratos de execução continuada ou diferida, o art. 478 autoriza ao devedor pedir a rescisão contratual se a prestação se tornar excessivamente onerosa para ele, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. O art. 479 permite ao credor evitar a medida drástica, facultando-lhe oferecer modificações nas condições

contratuais, e o art. 480 concede essa mesma faculdade ao autor do pedido no contrato de efeitos unilaterais, permitindo-lhe que pleiteie a redução da prestação ou seu modo de executá-la, ao invés de rescindir o contrato.

Deve-se evitar, sempre que possível, a rescisão, é o que preconiza o Enunciado n. 176 da III Jornada de Direito Civil: “Art. 478: Em atenção ao princípio de conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual”.

Esses dispositivos limitam a austeridade da força obrigatória do contrato e sucedem à construção jurisprudencial que, adotando a teoria *rebus sic stantibus*, isto é, “estando assim as coisas”, permitia a revisão contratual se a situação no momento em que o contrato foi firmado sofresse alteração ou, em outras palavras, na forma direta: “estando assim as coisas a obrigação permanece”. Vislumbrava-se a existência de cláusula não escrita, implícita nos contratos de prestação sucessiva, condicionante à continuidade do dever anteriormente contratado.

Na obra *A Regra Moral nas Obrigações Civis*, Georges Ripert (2000:154) explica com acentuada clareza a função prática dessa teoria, comparando-a ao texto do art. 1.156 do Código Civil francês⁶⁵, reproduzida no art. 85 do Código Civil brasileiro de 1916 e no atual art. 112: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”:

“Os tribunais poderiam ter corrigido o cumprimento do contrato servindo-se do próprio contrato; têm o direito de interpretar e devem fiar mais na intenção das partes que no sentido literal dos termos (art. 1.156 do Código Civil). As partes não previram as modificações posteriores ao contrato que tornariam a sua execução tão onerosa que seria desastrosa para o devedor: neste caso, desligar o devedor é respeitar a vontade de ambas as partes”.

“É esta uma velha ideia que os glosadores tinham exposto tomando como pretexto um fragmento de Nératius no *Digesto* (XII, 4, 8). Bartolo dizia que era necessário supor em todos os contratos a cláusula *rebus sic stantibus*, isto é, supor que as partes

não combinaram manter o contrato senão no caso das circunstâncias não mudarem. A regra dada por Balde e por Tiraquellus, combatida no princípio pela escola do direito natural como contrária ao valor do contrato, foi afirmada nos séculos XVII e XVIII por certos autores (de Cocceji, de Leyser), e veio terminar no Código Prussiano de 1794”.

“Ainda que o Código Civil não vise esta cláusula, parece que a jurisprudência no princípio do século teve tendência para a acolher. No acórdão de 11 de abril de 1821, a Corte de Cassação declara que essa cláusula se não pode aplicar num contrato que não comportava prestações sucessivas, mas, num acórdão de 20 de agosto de 1838, rejeita o recurso contra a sentença do Tribunal de Paris, de 7 de agosto de 1837, que tinha declarado a quebra dum contrato que continha a obrigação de entregas sucessivas, porque a situação não era a mesma em virtude do falecimento de uma das partes. [...]”.

No Brasil, dois exemplos jurisprudenciais da aplicação da cláusula *rebus sic stantibus* ajudam à compreensão dessa construção doutrinária:

“Responsabilidade Civil. Locação – Revisional – acordo das partes – O princípio *pacta sunt servanda* deve ser interpretado de acordo com a realidade socioeconômica. A interpretação literal da lei cede espaço à realização do justo. O magistrado deve ser o crítico da lei e do fato social. A cláusula *rebus sic stantibus* cumpre ser considerada para o preço não acarretar prejuízo para um dos contratantes. A Lei de Locação fixou o prazo para a revisão do valor do aluguel. Todavia, se o período, mercê da instabilidade econômica, provocar dano a uma das partes, deve ser desconsiderado. No caso dos autos, restara comprovado que o último reajuste do preço ficara bem abaixo do valor real. Cabível, por isso, revisá-lo judicialmente” (RMS 7.399/MS, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, j. 25-11-1996, DJ, 7-4-1997, p. 11172.)

“Responsabilidade Comercial – Contrato – A prestação contratual, em havendo expressão econômica, deve mantê-la durante a avença. Caso contrário, haverá enriquecimento ilícito para uma das partes. Leis subsequentes à avença, visando a conservar o valor, devem ser levadas em consideração. O *pacta sunt servanda* deve

ser compatibilizado com a cláusula *rebus sic stantibus*”. (REsp n. 93.143/RJ, Rel Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, j. 17-6-1996, *DJ*, 22-4-1997, p. 14460.)

f) Princípio do equilíbrio econômico

Vimos que a força obrigatória do contrato encontra limitação nos novos institutos de revisão do contrato, sucedâneos da cláusula *rebus sic stantibus*, implícita nos contratos de prestação continuada.

Há, além da onerosidade excessiva, outro fator a contribuir para o equilíbrio econômico entre as partes contratantes: o instituto da lesão, previsto em nosso ordenamento civil no art. 157: “ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”. Os §§ 1º e 2º desse dispositivo informam que se considera a desproporção das prestações segundo os valores em que foi celebrado o negócio jurídico e autorizam a revisão do contrato, em vez da resolução se houver suplemento suficiente ou se “a parte favorecida concordar com a redução do proveito”.

Por esses dois instrumentos – revisão e revogação em casos de lesão e de onerosidade excessiva – alcança-se o equilíbrio contratual, quando demonstrados casos de *premente necessidade ou inexperiência* (CC, art. 157) ou a ocorrência de *acontecimentos extraordinários e imprevisíveis* (CC, art. 478). É o que afirma Orlando Gomes (2008:48): “o princípio do equilíbrio econômico do contrato, ou do *sinallagma*, encontra-se presente no Código Civil primordialmente como fundamento de duas figuras, a lesão e a revisão ou resolução do contrato por excessiva onerosidade superveniente. Em ambos os casos, desempenha papel de limite à rigidez do princípio da força obrigatória do contrato”.

Outro método de abordagem dessa matéria considera o instituto da revisão (ou revogação) por onerosidade excessiva como moderador do princípio da força obrigatória e o da lesão, subproduto do princípio da boa-fé objetiva. Esse método despreza o equilíbrio econômico como princípio fundamental dos contratos, incluindo

sua compreensão nos dois outros – o da força obrigatória e o da boa-fé objetiva.

g) Princípio da relatividade dos efeitos do contrato

Em regra, os contratos geram efeitos somente entre as partes contratantes. Terceiro alheio ao negócio jurídico não é atingido, não pode ser credor ou devedor de obrigações nele estipuladas. Esta é a formulação, em termos gerais, do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, conhecida entre os romanos pela expressão *alteri stipulari nemo potest* – ninguém pode obrigar por outro.

Vislumbra-se, entretanto, uma gradação na aplicação desse princípio, levando-se em conta a natureza dos interesses de terceiros que podem estar envolvidos no contrato. Sua incidência é plena nas obrigações personalíssimas, como ocorre na cláusula de preferência ou preempção (v. item 9.10.4) prevista no art. 520 do Código Civil.

No pavimento intermediário de incidência, vemos que as cláusulas gerais incidem sobre os contratos e, entre elas, a da função social. Dentro desse contexto, podendo existir interesses da coletividade, há uma mitigação no princípio da relatividade dos efeitos, sendo incorreto afirmar de forma absoluta que o contrato não irradia efeitos sobre terceiros estranhos ao contrato. Relativiza-se o conceito de que o contrato cria, modifica e extingue direitos e obrigações somente no círculo interno dos contratantes.

No último degrau da escala a que nos referimos, há os contratos que são firmados *em favor de terceiros* e, portanto, nascem para gerar efeitos a pessoas que dele não participaram. A estipulação em favor de terceiro (CC, arts. 436-438) é exemplo desse contrato; por meio dele, estipulante e promitente convencionam vantagens a terceiros não participantes do negócio jurídico. Ocorre com frequência nos contratos de seguro (v. item 17.7.2). Clóvis (1975, 2:214) vê na estipulação em favor de terceiro “um poderoso instrumento jurídico. O seu campo de aplicação é muito extenso. Vemo-la, particularmente, na *constituição de renda*, quando há um terceiro beneficiado; nos *seguros de vida*; nas *fundações*; nas *doações modais*; e em certos contratos celebrados com a administração pública, nos quais, muitas vezes, se encontram cláusulas em favor dos habitantes de um lugar, ou dos operários da companhia

empresária”.

Por fim, relevante anotar o ensino de Orlando Gomes (2008:47) que estende a compreensão do princípio da relatividade das convenções ao objeto do contrato. Assim, não apenas pessoas estranhas ao contrato deixariam de ser atingidas por seus efeitos, como também “o contrato tem efeito apenas a respeito das coisas que caracterizam a prestação”. Teríamos, assim, que o princípio da relatividade tem feições subjetivas e objetivas.

8.5. Classificação dos contratos

Muitas são as possíveis classificações dos contratos, podendo ser encontrados distintos critérios para esse fim. A doutrina, em geral, apresenta diversas categorias. Há classificações quanto: (a) aos efeitos; (b) à formação; (c) à forma; (d) aos sujeitos que contratam; (e) ao objeto; (f) ao tempo de execução; (g) ao modo; (h) à designação; (i) à estrutura; (j) à regência jurídica; (k) à liberdade de contratar etc.

Advertimos quanto à falta de uma unidade terminológica, Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:39-40), por exemplo, apresenta seis critérios (estrutura, forma de constituição, execução, tipicidade, liberdade de contratar e ramo jurídico de regência); Maria Helena Diniz (2007:77) também faz seis escolhas, que, no conjunto, se distinguem das primeiras (natureza da obrigação, forma, designação, objeto, tempo de execução e pessoa do contratante); Orlando Gomes (2008:83-84) prefere usar doze critérios, sem agrupá-los (bilaterais e unilaterais, onerosos e gratuitos, solenes e não solenes, principais e acessórios, instantâneos e de duração, de execução imediata e de execução diferida, típicos e atípicos, pessoais e impessoais, civis e mercantis, individuais e coletivos, causais e abstratos).

Interessa-nos traçar, dentro desses critérios, um método que nos permita visualizar claramente, seguindo uma certa lógica na sequência dos acontecimentos, a previsão ou regência legal, as pessoas que contratam, a formação do contrato, suas possíveis estruturas, o modo de contratar e o tempo de sua execução.

Os consecutivos momentos da conclusão e execução do contrato facilitam a compreensão e memorização do estudante da matéria e mostram a importância prática

dos critérios selecionados:

PREVISÃO LEGAL	PESSOAS	FORMAÇÃO	ESTRUTURAS	MODO	EXECUÇÃO
há uma lei regulando parcial ou totalmente esse contrato?	a determinação da pessoa é essencial à formação; o contratante deve ostentar certa qualidade pessoal e, se afirmativo, qual a consequência quanto ao regime legal?	como saber se o contrato se aperfeiçoou e as partes efetivamente se obrigaram?	quais as obrigações e custos assumidos e quais as vantagens pretendidas?	os contratantes podem modificar as cláusulas antes de aderirem?	como se dá, no tempo, a execução do contrato?

a) Quanto à *previsão legal*, os contratos podem ser típicos, atípicos e mistos. A tipicidade ou atipicidade de um contrato ou sua aproximação com um modelo existente é fator a ser considerado na interpretação de cláusula contratual. Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:54) expõe essa situação nestes termos: “Só há tipicidade se os direitos e obrigações dos contratantes estão, ainda que parcialmente, disciplinados pela lei”.

PREVISÃO LEGAL	Típicos: são contratos sujeitos à disciplina da lei que os regula e lhes dá denominação própria. O Código Civil define vinte e três contratos típicos, havendo outros tantos em leis extravagantes. Adverte-se, porém, que há contratos que aparentemente possuem as duas características acima – <i>nomen juris</i> e definição legal –, mas não típicos, como é o caso do contrato de franquia, previsto na Lei n. 8.955/94, que não o regulou completamente deixando de definir direitos e deveres dos contratantes.
	Atípicos: são os celebrados com cláusulas definidas pelos contratantes, conforme a necessidade negocial, sem obediência a um regramento legal específico, inexistente para o caso concreto. A permissão para esses contratos decorre da aplicação do princípio da autonomia da vontade, encontrando fundamento legal no art. 425 do Código Civil.
	Mistos: são os contratos atípicos “inspirados, total ou parcialmente, em contratos típicos”, como ocorre com os que regem as locações em <i>shopping center</i> (2007, 3:59).

b) Quanto à *formação*, os contratos podem ser consensuais, formais (ou solenes) e reais. A distinção marca a validade do negócio jurídico e o momento em que as partes se obrigam.

FORMAÇÃO	Consensuais: a formação dos contratos consensuais depende tão somente da convergência da vontade dos contratantes que, uma vez expressa pelos contratantes, conclui o negócio jurídico sem nenhuma outra exigência, nem mesmo de forma escrita.
	Formais ou solenes: nesses contratos a forma escrita é essencial, podendo a lei exigir, ainda, solenidades complementares, como ocorre com o contrato de compra e venda de imóvel de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo (CC, art. 108).
	Reais: exigem esses contratos a entrega da coisa objeto do negócio jurídico firmado entre os contratantes, sem o que o contrato não se considera formalizado.

c) Quanto às *pessoas que contratam* vislumbram-se duas subdivisões relacionadas à: (c1) importância do caráter pessoal – *intuitu personae* e impessoais; e (c2) qualidade dos contratantes – os contratos seriam empresariais, de consumo, laborais, administrativos e simplesmente privados. A importância dessas duas classificações repousa, de um lado, “nas consequências lógicas e intuitivas que decorrem da natureza personalíssima da obrigação característica dos contratos pertencentes” (Gomes, 2008:98) à categoria dos contratos pessoais e, de outro, na regência legal a que se subordinam esses contratos. Nas relações de consumo, por exemplo, o tratamento legal é de tal forma distinto que implica soluções processuais diversas da encontrada em outras lides.

Entre os contratos empresariais, outra classificação pode ser sugerida, segundo sua função econômica. Haveria, assim, contratos associativos ou de organização; de prevenção de riscos, como o contrato de seguro; de crédito, cujos exemplos mais marcantes são os contratos bancários, o contrato de *leasing* e outros; de cooperação ou colaboração empresarial, nos quais se incluem os contratos de distribuição-intermediação e de concessão (cf. classificação de Coelho, 2016:109); contratos de

colaboração por aproximação, sendo que estes três últimos podem ser agrupados sob a rubrica de contratos de atividade, conforme entende Orlando Gomes (2008:106): “Há negócios destinados a estabelecer a *cooperação* entre as partes, sem que, entretanto, estas se associem, isto é, assumam os riscos do empreendimento. Nesses negócios, as pessoas não se associam, como nos *associativos*, ao exercício comum de atividade econômica com o ânimo de repartir os lucros ou suportar as perdas. Mas atuam, independentemente, sem vínculos associativos, pelo concurso de atividades. Tais são, entre outros, os contratos de *mandato*, de *edição*, de *representação* e de *agência*”.

Paula Castello Miguel (2006:180 e 126), em sua tese de doutorado, sustenta a classificação dos contratos empresariais (contratos interempresariais, como denomina) em contratos entre iguais e entre desiguais, sustentando para estes últimos “a possibilidade de aplicação extensiva das regras de proteção contratual previstas no Código de Defesa do Consumidor”, justificando sua postura na constatação de “que a desigualdade das partes revela a possibilidade de ameaça aos valores sociais (como dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e busca pela igualdade), é necessário que exista intervenção para a preservação dos interesses do contratante mais fraco”.

Preferimos essa abordagem à tradicional, que divide os contratos em civis e comerciais (ou empresariais) porque entendemos que o tratamento legal a partir do Código Civil de 2002 não permite mais essa distinção. Não há, no nosso entendimento, contratos civis e mercantis, mas contratos empresariais e não empresariais.

IMPORTÂNCIA DO CARÁTER PESSOAL	<i>Intuitu personae:</i> o caráter pessoal é essencial à formação do contrato. Exemplo mais comum é o contrato de constituição de sociedade de pessoas (CC, arts. 1.002-1.003).
	Impessoais: é indiferente, nesses contratos, a consideração acerca da pessoa com quem se contrata.
	Empresariais: são contratos firmados entre empresários, isto é, entre pessoas que

QUALIDADE DOS CONTRATANTES	exercem profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, diversa da profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística.
	Simplesmente privados: contratos entre pessoas não empresárias, não sujeitas à regência do Código de Defesa do Consumidor, a vínculo trabalhista ou com a administração pública.
	Consumeristas: são os contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, nos quais uma das partes contratantes é consumidor, “pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (CDC, art. 2º) e a outra fornecedor, “pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”(CDC, art. 3º).
	Laborais: contratos oriundos da relação de trabalho.
	Administrativos: contratos em que um dos contratantes é pessoa jurídica de direito público interno.

d) Quanto às *possíveis estruturas* que adotam, os contratos podem ser subdivididos em outras classificações, entre as quais:

(d1) Em relação aos efeitos – unilaterais e bilaterais. Decorre dessa classificação a incidência de certas regras, em especial: (i) a exceção de contrato não cumprido (*exceptio non adimpleti contractus*), prevista no art. 476 do Código Civil: “nos *contratos bilaterais*, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”; (ii) à condição resolutiva tácita, presente nos *contratos bilaterais*, significando que, se uma das partes não cumprir a obrigação contratada, a outra poderá rescindir o contrato, com justa causa (CC, art. 474); (iii) à resolução do contrato *bilateral* por insolvência de uma das partes (CC, art. 477); (iv) os efeitos da rescisão judicial do contrato bilateral são *ex tunc*, desde o dia em que foi celebrado; (v) à distinção de tratamento em caso de falência (LREF, arts. 117 e 118 – v. também item 22.2.6 do 3º volume desta obra).

(d2) Em relação à onerosidade – gratuitos e onerosos. A distinção é importante do ponto de vista prático porque “se manifesta a respeito da capacidade dos contraentes, do objeto do contrato e da responsabilidade do devedor” (cf. Gomes, 2008:88). O Código Civil os regula distintamente, quanto à interpretação (art. 114) e responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação (art. 392).

(d3) Quanto à vantagem econômica – comutativos e aleatórios. Essa distinção procede da anterior. Os contratos *onerosos* podem ser comutativos e aleatórios, isto é, pode ou não haver incerteza dos contratantes sobre a vantagem econômica esperada. No contrato comutativo a incidência do princípio do equilíbrio econômico mostra-se evidente, o que não ocorre nos contratos aleatórios, no que diz respeito à lesão (CC, art. 157), instituto que pressupõe a existência de prestações desproporcionais entre os contratantes (cf. Gomes, 2008:90).

EFEITOS	Unilaterais: nestes contratos somente uma das partes contratantes se obriga.
	Bilaterais: todas as partes contratantes obrigam-se.
ONEROSIDADE	Gratuitos ou benéficos: a vantagem é atribuída somente a uma das partes; a outra pratica o ato por liberalidade.
	Onerosos: ambas as partes visam obter uma vantagem.
VANTAGEM ECONÔMICA	Comutativos: o contrato pressupõe uma prestação à qual se opõe uma contraprestação correspondente.
	Aleatórios: sempre bilaterais, os contratos aleatórios têm por objeto coisa sujeita a acontecimento desconhecido e incerto.

e) Quanto ao *modo de contratar*, os contratos são paritários ou de adesão. A importância dessa classificação decorre principalmente das regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor, relativas à transparência contratual, uma vez que o consumidor adere a cláusulas preestabelecidas pelo fornecedor, gerando, em caso de

dúvida na sua interpretação, compreensão a favor do consumidor.

MODO DE CONTRATAR	Paritários: assim chamados em razão da paridade, isto é, a igualdade entre as partes que contratam, cabendo a cada uma delas impor as condições e cláusulas que julgar necessárias.
	De adesão: os contratos em que, na redação das cláusulas contratuais, um dos contratantes impõe sua vontade, não deixando espaço à outra parte para fazê-lo, tolhendo sua liberdade quanto a alterações que entenda pertinentes. A aceitação ou rejeição pelo contratante que não o redigiu dá-se pela unidade contratual, não podendo aceitar ou rejeitar apenas parcialmente.

f) Quanto ao *tempo de execução*, há três rubricas de classificação: de execução imediata, deferida ou sucessiva. Nestes últimos, como vimos anteriormente, incide a teoria da imprevisão (v., acima, item 8.4, e). No caso de nulidade do contrato cumpre distinguir os efeitos: nos de execução imediata a nulidade atinge os atos realizados e, se a prestação for sucessiva, a declaração judicial somente incide sobre os efeitos futuros e não os já produzidos.

TEMPO DE EXECUÇÃO	Execução imediata ou instantânea: os contratos executados de uma só vez, em um só ato.
	Execução diferida: identicamente ao de execução instantânea, a execução se dá em um só ato, mas em momento futuro, em termos acertados pelas partes.
	Execução sucessiva ou continuada: reiteram-se no tempo os atos de execução, em prestações cujo modo e prazo são objeto de consenso entre as partes.

Capítulo 9

COMPRA E VENDA EMPRESARIAL

Sumário: 9.1. Conceitos e distinções. 9.2. Características. 9.3. Elementos formadores. 9.4. Forma e prova do contrato. 9.5. Execução do contrato de compra e venda. 9.6. Direitos dos contratantes. 9.7. Obrigações do vendedor. 9.7.1. Entrega da coisa. 9.7.2. Vícios. 9.7.3. Evicção. 9.8. Obrigações do comprador. 9.9. Modalidades especiais de compra e venda. 9.9.1. Venda de coisa móvel à vista de amostras. 9.9.2. Venda de imóvel *ad mensuram* e *ad corpus*. 9.10. Cláusulas especiais. 9.10.1. Pacto de melhor comprador e pacto comissório. 9.10.2. Retrovenda. 9.10.3. Venda a contento e venda sujeita a prova. 9.10.4. Preempção ou preferência. 9.10.5. Venda com reserva de domínio. 9.10.6. Venda sobre documentos. 9.10.7. Crédito documentário. 9.11. Cláusulas de custos em contratos internacionais – *incoterms*. 9.12. Outros contratos relacionados à compra e venda. 9.12.1. Contrato estimatório. 9.12.2. *Hedging*. 9.13. Resumo gráfico.

9.1. Conceitos e distinções

Contrato de compra e venda é aquele em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro (CC, art. 481). O contrato será empresarial quando as partes forem empresárias ou sociedades empresariais e o objeto se destinar à atividade negocial.

A expressão “compra e venda mercantil”, consagrada a partir de sua regulamentação no *Código Comercial*, já não mais se justifica tendo em vista a adoção da Teoria da Empresa, assumindo o legislador brasileiro, no Livro II do Código Civil, a expressão “Direito de Empresa”.

Com a revogação de extensa porção do *Código Comercial*, desaparece a figura especial do contrato de venda mercantil, previsto naquele diploma legal (Título VIII arts. 191-220), que se distinguia do contrato de venda civil nos seguintes aspectos: (a) quanto ao *objeto*: era considerada mercantil a compra e venda de “efeitos móveis e

semoventes”, expressões que compreendiam “a moeda metálica e o papel-moeda, títulos de fundos públicos, ações de companhias e papéis de créditos comerciais”; (b) quanto à *finalidade*: a operação envolvendo essa espécie de bens tinha por escopo “os revender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar seu uso”; (c) quanto ao *sujeito*: a especialidade se expressava pela redação final do art. 191 – “contanto que nas referidas transações o comprador ou vendedor seja comerciante”.

Tradicionalmente, a expressão mercadoria limitava-se a designar certas coisas móveis e semoventes que serviam às operações mercantis. O Código Civil de 2002 ampliou esse universo, com a adoção do Direito de Empresa, não mais distinguindo, no conceito de atividade empresarial, os bens destinados à circulação (art. 966). Não há nem mesmo limitação a bens, uma vez que os serviços são também qualificados de empresariais. Qualquer atividade econômica organizada destinada à produção ou à circulação de bens ou de serviços passa a ter o cunho empresarial, desde que não corresponda a profissões intelectuais, científicas, literárias ou artísticas.

Desde o advento do Código Civil de 2002, com a unificação do direito das obrigações, a regulamentação do contrato de compra e venda é uma só (arts. 481-532).

Então por que adjetivar o contrato de compra e venda “empresarial”? Que distinções haveria para insistir em uma modalidade especial?

A distinção deixa o foco da dicotomia “comercial-civil” e passa a concentrar-se em outras relações: *empresarial* (relação entre um empresário e outro empresário) relativamente a coisas destinadas à organização econômica, isto é, à produção ou circulação de bens ou de serviços; *consumerista* (fornecedor-consumidor), regida por legislação própria (Código de Defesa do Consumidor), tuteladora dos consumidores em suas relações com pessoas ou entes despersonalizados, “que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços” (CDC, art. 3º) e *comum* (entre pessoas não empresárias, nem fornecedoras de bens, serviços ou produtos).

Alguns doutrinadores preferem manter as expressões “mercantil” e “civil” que, segundo justifico, devem ser evitadas por terem sido, durante mais de um século, utilizadas para indicar coisas opostas. O Professor Fábio Ulhoa Coelho, por exemplo entende que “a compra e venda pode ser cível ou ao consumidor. Entre os da primeira espécie, encontra-se a compra e venda mercantil” (2016:70).

Esta é a razão pela qual adotamos a expressão “empresarial”: para indicar que este capítulo limita-se ao estudo da compra e venda operada entre empresários ou sociedades empresárias.

9.2. Características

A compra e venda é contrato consensual, bilateral e oneroso, isto é, opera-se, em regra, a partir do simples consentimento das partes (consensualidade) quanto ao objeto e ao preço (onerosidade), resultando para ambas as partes direitos e obrigações (bilateralidade): o vendedor obriga-se a transferir o domínio de certa coisa e o comprador, a pagar certo preço em dinheiro.

O contrato pode, ainda, exigir mais do que a simples anuência (consensualidade) e impor certa solenidade, como ocorre com a obrigatoriedade de escritura pública na venda e compra de imóveis (CC, art. 108).

Em geral o contrato é comutativo, isto é, refere-se a coisas certas e determinadas, podendo, entretanto, estabelecer-se como aleatório, voltado a transferir o domínio de coisa desconhecida e incerta. O contrato aleatório envolve riscos assumidos conscientemente pelas partes que, sujeitando-se a fato desconhecido (álea, sorte, incerteza), ignoram, quando de sua celebração, os contornos da coisa a ser transferida ou paga.

9.3. Elementos formadores

Em geral a doutrina apresenta três elementos essenciais à formação do contrato de compra e venda: a coisa, o preço e o consentimento.

Há, contudo, quem entenda que o contrato se forma quando comprador e vendedor acordam quanto à coisa, preço e condições. Nessa linha, o consentimento não é

específico ao contrato de compra e venda, mas é comum a todos os contratos, surgindo um terceiro elemento essencial em seu lugar: as condições.

É o magistério de Fábio Ulhoa Coelho (2016:74): “comprador e vendedor devem acertar quanto às condições do contrato, isto é, os fatos que postergam a exigibilidade das obrigações (condição suspensiva) ou as desconstituem (resolutiva)”.

Em oposição a esse entendimento encontra-se Carvalho de Mendonça (1955, 6:18), na vigência do *Código Comercial*, para quem “o contrato de compra e venda mercantil torna-se definitivo e obrigatório entre as partes, eis que ajustem sobre a *coisa* e o *preço*”. Waldirio Bulgarelli (1997:178), na vigência do Código Civil de 1916, lecionava: “Tem-se entendido que a referência às condições é dispensável, pois que elas não integram propriamente o contrato, mas são modalidades contratuais, tanto que o Código Civil, no art. 1.126, não se refere a elas, estatuinto que, se a venda é pura, será desde logo perfeita e obrigatória, bastando que o comprador e o vendedor se acordem sobre o objeto e o preço”.

Essa posição foi adotada pelo art. 482 do Código Civil de 2002: “A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço”.

Seriam, portanto, essenciais ao contrato de compra e venda o ajuste sobre o preço e a coisa.

Vejamos mais de perto esses dois elementos.

a) Coisa

A *coisa* como objeto do contrato de compra e venda encontrava limitação no sistema da comercialidade. Somente os “efeitos móveis e semoventes” serviam à circulação econômica qualificada de *mercantil*; ficavam fora desse conceito os imóveis. Durante a vigência do Código de 1850, foram cunhados termos próprios (cf. Bulgarelli, 1997:171) para designar a coisa destinada à mercancia, como, por exemplo, mercadorias (CCom, art. 200, coisas corpóreas), gêneros (CCom, art. 87, coisas depositadas em armazéns, em geral produtos da terra), fazendas (CCom, art. 101, coisas para revenda, a bordo de um navio), efeitos (CCom, art. 100, n. 2, coisas

com ênfase a valor).

A Teoria da Empresa alterou substancialmente esse quadro. A coisa objeto do contrato de compra e venda empresarial é todo bem móvel, semovente ou imóvel utilizado pelo empresário – ou sociedade empresária – no exercício de sua atividade, para servir diretamente à revenda ou, indiretamente, para compor os atos empresariais.

Maria Helena Diniz (2007:177-178) especifica os requisitos da coisa: (a) *existência corpórea ou incorpórea*, que pode ser potencial no momento da celebração do contrato, mas deverá ser efetiva na data de sua entrega ao comprador; (b) *individualidade*, isto é, objeto determinado ou determinável; (c) *disponibilidade* no comércio; (d) *possibilidade de ser transferida* ao comprador.

Desses requisitos entendemos que os três primeiros são essenciais à completa definição do objeto do contrato de compra e venda, uma vez que a transferência de domínio da coisa e seus efeitos interessam ao estudo das obrigações da parte, no caso, do vendedor. O contrato se aperfeiçoa *pela obrigação* de o vendedor transferir o domínio de certa coisa (CC, art. 481), não exigindo sua imediata transferência para torná-la obrigatória e perfeita. Em razão dessa disposição, nosso direito admite o contrato de venda de coisa alheia, isto é, permite que o vendedor comprometa-se a adquirir certa coisa e entregá-la ao comprador. Carvalho de Mendonça (1955, 6:19) assim se expressa sobre a distinção entre formação e execução do contrato: “Este contrato é, na frase de Dernburg, o primeiro degrau para a aquisição da coisa por parte do comprador (*Pandette*, trad. Cicala, v. 2, § 94). Por meio dele, o vendedor *obriga-se a transferir* a coisa vendida; resta executá-lo. Se, efetivamente, não entrega esta coisa, não a tem transferido, não existe a alienação. Em tais condições, o comprador não se reputa proprietário por força do simples consentimento das partes; tem somente o *jus ad rem obtinendam*”.

Existência e individualidade

Podem ser objeto do contrato de compra e venda empresarial bens que tenham existência, realidade que inclui tanto os bens corpóreos, móveis, imóveis ou semoventes, como igualmente os bens incorpóreos, entre os quais a marca, o direito

de patente, valores mobiliários e outros tantos objetos que integram o estabelecimento empresarial do empresário individual ou o patrimônio da sociedade empresária⁶⁶. É possível que os contratantes acordem sobre a entrega de produtos ainda não existentes, sujeitos à colheita futura, como os frutos agrícolas, ou à fabricação, quando se tratar de produção industrial, ou, ainda, à manufatura. Se a coisa não chegar a existir, o contrato é declarado sem efeito, salvo se as partes tinham intenção de concluir um contrato aleatório (CC, art. 483).

Denomina-se aleatório o contrato que tenha por objeto coisa sujeita a uma *álea*, isto é, a um acontecimento desconhecido e incerto. O contrato aleatório não se confunde com contrato sujeito a condição porque neste o contrato não se forma enquanto não ocorrer o fato futuro nele estipulado. O contrato aleatório, como bem explica Clóvis Beviláqua (1975, 2:231), “está formado e perfeito; a incerteza recai sobre a extensão dos lucros e das perdas dos contratantes, e não é essencial que o acontecimento, que termina a incerteza dos lucros e das perdas, seja futuro, basta que seja ignorado das partes”.

São exemplos de contratos de compra e venda aleatórios, conforme Carvalho de Mendonça (1955, 6.1:271, e 6.2:30-31), tanto as coisas que têm possibilidade de existir (*emptio rei speratae*), como, por exemplo, determinada colheita (sujeita a não existir em razão de intempéries), quanto as que são totalmente incertas de existir algum dia (*emptio spei*), como ocorre com a compra de um bilhete de loteria, o produto de uma rede de pesca jogada no mar, a subscrição de ações que ainda não estão no mercado etc.

Verifica-se que o que se vende num contrato aleatório não são os frutos da colheita, ou o prêmio da extração, nem o peixe ou as ações, mas sim, como afirma Carvalho de Mendonça, *as pes*, isto é, a esperança, coisa incorpórea, a possível fortuna advinda desse acontecimento incerto e desconhecido. São os feijões que o personagem comprou no clássico da literatura infantil “João e o Pé de Feijão”, do folclore inglês.

Se a venda e compra não for aleatória, podendo se extrair de suas cláusulas a

individualização de coisa determinada e esta nunca existir (em outras palavras, se não tem por finalidade vender *spes*), o contrato é declarado inválido.

Disponibilidade no comércio

A disponibilidade no comércio refere-se à possibilidade de aquisição em oposição às coisas fora de comércio, como ocorre com os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial (CC, art. 100) e outros por força legal ou declaração de vontade (como os bens com cláusula de inalienabilidade).

b) Preço

As partes devem estabelecer um preço *em dinheiro*, característica que distingue o contrato de compra e venda do contrato de troca ou permuta. Em regra, o preço é fixado após tratativas individuais entre os empresários ou fixadas em contrato anterior ou convenção, como ocorre com a concessão mercantil (distribuição para revenda). O *consenso* é essencial, sendo nulo o contrato que deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço (CC, art. 489).

Ao estabelecerem o montante a ser pago pelo comprador, os contratantes deverão utilizar valores em moeda nacional, podendo, contudo, valer-se de moedas estrangeiras em alguns contratos.

A legislação brasileira (art. 2º do Decreto-lei n. 857, de 11 de setembro de 1969, e art. 1º da Lei n. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001) admite sejam firmados em moeda estrangeira: (I) contratos e títulos referentes à importação ou exportação de mercadorias e a empréstimos; (II) contratos de financiamento ou de prestação de garantias relativos às operações de exportação de bens de produção nacional, vendidos a crédito para o exterior; (III) contratos de compra e venda de câmbio em geral; (IV) empréstimos e quaisquer outras obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional; (V) contratos que tenham por objeto a cessão, transferência, delegação, assunção ou modificação das obrigações anteriores, ainda que as partes contratantes sejam pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil.

Deve-se atentar, contudo, que o pagamento se faz após a conversão, em moeda

nacional, na data do vencimento.

O preço, contudo, pode não estar determinado desde a formação do contrato, acordando as partes que se estabeleça posteriormente, por um árbitro, por critérios objetivos ou, ainda, que se sujeite ao regramento legal a respeito da matéria. Portanto, embora não determinado, o preço será *sempre determinável*, por cláusula contratual que fixe critérios objetivos (arbitral, mercado, bolsa, índices ou parâmetros objetivos) ou por sujeição dos contratantes aos critérios fixados pelo legislador (tabelamento ou preço corrente).

Contrato com critério arbitral para determinação do preço. Não afasta o requisito da determinação do preço o fato de os contratantes designarem ou prometerem designar terceiro para o encargo de arbitrar a fixação do preço (CC, art. 485), em geral pessoa a quem ambos confiam e reputam qualificada para o mister. Entretanto, se o terceiro recusar e não houver acordo dos contratantes no sentido de designar o substituto para a tarefa, a venda é declarada sem efeito.

Contrato com critério futuro para determinação do preço. Além do critério arbitral, a determinação do preço pode vir a se estabelecer em data futura, como ocorre se o contrato: (a) prevê sua fixação pela taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar (CC, art. 486); (b) submete-se a índices ou parâmetros suscetíveis de objetiva determinação (CC, art. 487).

Contrato sem critério convencional para determinação do preço. Se os contratantes convencionarem a venda sem fixação de preço, não estabelecendo, ainda, critérios para sua determinação (árbitro, taxa de mercado, de bolsa, índice ou parâmetro de determinação), nem existir, para a coisa objeto do contrato, tabelamento oficial, “entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente das vendas habituais do vendedor” (CC, art. 488). Vale dizer que, no caso de convenção sem fixação de preço por parte dos contratantes, a determinação se fará pelo valor de tabelamento oficial e, na sua falta, pelo preço corrente do vendedor.

9.4. Forma e prova do contrato

A compra e venda não exige forma especial, salvo exceções previstas em diversos

dispositivos encontrados nos códigos e nas legislações extravagantes. São exemplos a compra e venda de imóveis, de valores mobiliários, de cotas de sociedades, entre outros.

Quando a venda se referir a bens imóveis a escritura pública é essencial à validade (CC, art. 108). Entretanto, se o imóvel servir à composição do capital social, a certidão da Junta Comercial referente aos atos de constituição ou de alteração societária é documento hábil para sua transferência, por transcrição no registro imobiliário (Lei n. 8.934/94).

Na alienação de valores mobiliários nominativos, a transferência se dá por termo lavrado no livro respectivo, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário. Os títulos escriturais, mantidos em depósito em instituição financeira designada pela companhia emissora, somente são transferidos mediante ordem escrita do alienante ou judicial.

A cessão de cotas sociais deve ser feita por escrito e, para ter efeitos perante terceiros, averbada no Registro Público, isto é, no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas ou Juntas Comerciais, dependendo da natureza da atividade econômica desenvolvida pela sociedade, simples no primeiro caso e empresária, no segundo.

Os títulos e licenças de propriedade industrial – marcas, patentes e registro de desenho industrial – e os contratos que impliquem transferência de tecnologia, franquia e similares serão sempre escritos e, para produzirem efeitos em relação a terceiros, deverão ser levados a registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (CPI, arts. 62, 121, 136, I, e 211).

Para a compra e venda de bens móveis e semoventes, não regulada pelo legislador, inexiste forma especial, revelando-se a conclusão do negócio por vários meios de prova existentes: uso de cartão de crédito pelo comprador, no valor do contrato; troca de mensagens eletrônicas e de correspondência negocial; emissão de fatura por parte do vendedor, acompanhada de canhoto de entrega da mercadoria; apresentação de conhecimento de transporte; comprovante de entrega pelos correios; apresentação de títulos de crédito emitidos pelo comprador, cujos valores correspondam ao valor do pedido ou da nota fiscal expedida pelo vendedor etc.

De um modo geral, pode-se afirmar que, em juízo, os contratantes não podem pretender realizar prova *exclusivamente testemunhal* para demonstrar a existência de *compra e venda empresarial* porque são obrigados não somente a manter o registro contábil de seus atos (CC, art. 1.179) como também a escriturar operações segundo normas fiscais de apuração e recolhimento de tributos.

É igualmente verdade que os registros extraídos dos livros e fichas empresariais sempre provam contra seu autor, valendo como confissão, podendo, entretanto, ser elididos por prova de falsidade ou inexatidão de lançamento (CC, art. 226).

Nos contratos empresariais a ausência de *algum* documento escrito, portanto, é exceção. O exercício regular da atividade empresarial exige, cada vez mais, a forma escrita ou passível de ser documentada fisicamente, como ocorre com os contratos firmados eletronicamente, mediante uso de senha ou assinatura digital.

Embora o contrato de compra e venda empresarial não possa ser demonstrado em juízo por prova exclusivamente testemunhal, aspectos relacionados às condições do negócio podem ser objeto de demonstração pelo testemunho de pessoas que participaram do negócio, quando subsidiários ou complementares da prova escrita apresentada pelos contratantes (CC, art. 227, parágrafo único).

Nesses contratos é comum, quando não obrigatória, a intermediação de corretores, representantes autônomos, procuradores negociais, comissários etc., profissionais que podem ser convocados para trazer elementos que elucidem as condições em que o contrato se efetivou.

Na venda de ações em bolsa e nas vendas públicas exige-se a presença de pessoas qualificadas para o ato, respectivamente corretores e leiloeiros.

9.5. Execução do contrato de compra e venda

Concluído o contrato pelo consenso sobre a coisa e o preço, os contratantes passam à execução que consiste no recebimento do preço e na entrega da coisa, o que pode ocorrer de modo imediato ou em data futura. Se por escolha das partes estabelecer-se prazo para pagamento ou para entrega, teremos a chamada *venda a*

termo, que, por sua vez, comporta outra noção: a *venda complexa*.

Venda complexa é a venda a termo que se caracteriza pelo desdobramento do contrato inicial em vários outros que lhe são dependentes. Fran Martins (1993:186) dá como exemplos de venda complexa os contratos de fornecimento e os de assinatura, sobre os quais afirma: “caracterizam-se esses contratos pelo fato de convencionarem as partes uma negociação, sendo a fase executiva do contrato desdobrada em várias operações parciais, todas autônomas quanto à prestação, mas dependentes do consentimento inicial. Podem as vendas complexas tomar várias formas, variando de contrato para contrato. Em cada uma delas, contudo, haverá um acordo de vontades sobre coisa e preço dando origem às prestações parciais em que as vendas se desdobram”.

9.6. Direitos dos contratantes

Fixado o preço, os contratantes podem ajustar o modo em que se dará seu pagamento: adiantado, à vista ou a prazo. Resulta disso o direito do vendedor ao recebimento do preço no modo pelo qual se firmou o contrato. Se estabelecido pagamento adiantado ou à vista, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço, conforme dispõe o art. 491 do Código Civil.

A contrario sensu, se contratada venda a crédito, o comprador tem o direito de receber a coisa mesmo antes de pagar o preço. Esse direito, contudo, encontra limitação na hipótese prevista no art. 495 do Código Civil: “se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado”.

Para o contrato de compra e venda empresarial, essa disposição encontra regramento específico no diploma falimentar. Decretada a falência, situação que corresponde no campo empresarial à expressão “cair em insolvência”, prevista no art. 495 do Código Civil, o “vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos de transportes, entregues ou remetidos pelo vendedor” (LREF, art. 119, I).

Vale dizer que, na venda a prazo e estando a coisa em trânsito para ser entregue, a decretação da falência do comprador permite ao vendedor interromper a entrega, reavendo seu conteúdo. Esse direito, denominado *right of stoppage in transitu*, não é absoluto: se o comprador as tiver revendido *antes* da decretação de sua falência, não há como o vendedor impedir a entrega. Nesse caso o único direito do vendedor é o de restituição, não da própria coisa (porque já revendida pelo comprador), mas de seu valor de avaliação (LREF, art. 86, I).

Correlatamente aos direitos do vendedor, ao comprador é atribuído o de receber a coisa no lugar e modo contratados, inclusive o de reter o preço no caso de mudança do estado econômico-financeiro do vendedor que ainda não lhe entregou a coisa contratada. Esse direito decorre do princípio geral da exceção de contrato não cumprido pelo qual, “depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete e dê garantia bastante de satisfazê-la” (CC, art. 477).

9.7. Obrigações do vendedor

Basicamente três são as principais obrigações do vendedor: (a) entregar a coisa e transferir o domínio da coisa vendida; (b) garantir o uso e gozo pleno da coisa vendida, obrigando-se pelos vícios ocultos; e (c) responder por evicção.

9.7.1. Entrega da coisa

No que respeita à obrigação de entregar a coisa, impõem-se algumas considerações acerca do lugar de entrega, das despesas de entrega, dos riscos e débitos existentes. Os contratantes podem, entretanto, dispor livremente a respeito. Poucas são as diretivas quanto ao *lugar de entrega*, quanto às *despesas da tradição* e responsabilidade quanto aos *débitos existentes*. Na omissão do contrato aplicam-se as seguintes regras:

a) **Lugar de entrega:** deve ocorrer onde a coisa se encontrava ao tempo da venda

(CC, art. 493);

b) **Despesas da tradição:** são devidas pelo vendedor. Se, entretanto, for exigida escritura e registro, as despesas correm a cargo do comprador (CC, art. 490);

c) **Débitos que gravam a coisa:** são devidos pelo vendedor até o momento da tradição (CC, art. 502).

Quanto aos riscos é mais extenso o regramento legal que dispõe de modo *supletivo* à vontade dos contratantes.

Dá-se a transferência do imóvel pela transcrição imobiliária. De modo geral, a entrega de coisa móvel ou semovente ocorre por tradição, termo jurídico que significa a transferência da coisa ao comprador, que pode ser real ou simbólica (também chamada *alegórica* ou *ficta*). Os dois modos mais comuns são, portanto, a entrega em mãos do comprador (tradição real) ou posta à sua disposição, nos casos em que a lei presume (tradição simbólica).

Há, ainda, dois outros modos que serão tratados como cláusulas especiais, previstos no art. 529 do Código Civil: a entrega do título representativo e de documentos exigidos no contrato e, no silêncio deste, pelos usos, objeto de estudos nos itens 9.10.6 e 9.10.7.

São assim *quatro* os modos pelo quais se opera a transferência da coisa pelo vendedor ao comprador: (1) entrega real; (2) entrega simbólica; (3) transferência dos títulos que representam a coisa vendida; (4) pelos usos, isto é, pelo modo que se costuma fazer no local do contrato, quando a venda for sobre documentos e o contrato silenciar a respeito dos documentos que devem ser apresentados.

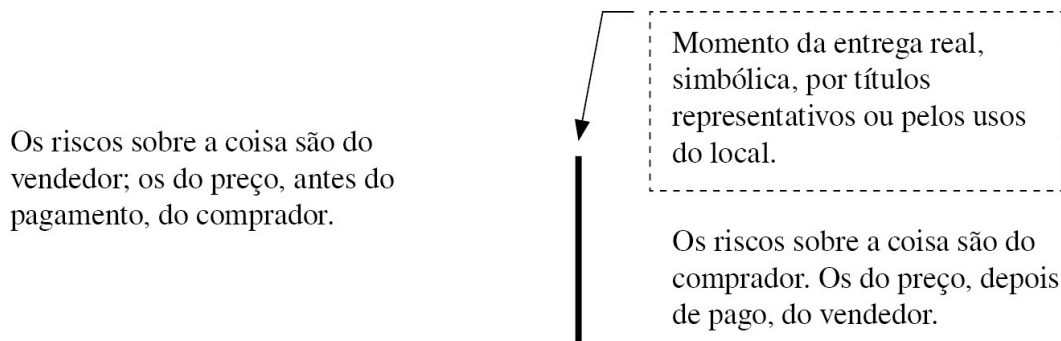
É de suma importância saber como se opera a entrega da coisa vendida, porque até esse momento os riscos sobre a coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador (CC, art. 492). Risco é, utilizando a expressão de Clóvis Beviláqua (1975, 2:240), “o perigo, a que está sujeita a coisa, de perecer ou se deteriorar por caso fortuito ou força maior”.

Por exemplo: tendo sido contratada a transferência por títulos representativos e tendo esses sido entregues, cabe ao comprador arcar com os prejuízos decorrentes de

inundação, incêndio, acidente de trânsito ou outra circunstância imprevisível e irresistível que venham a atingir a coisa comprada, mesmo que esta ainda não esteja efetivamente em suas mãos.

O termo que separa a mudança do ônus pelos riscos sobre a coisa e preço é, portanto, a entrega (real, simbólica, por títulos representativos ou pelo uso local). Feliz a expressão utilizada por Clóvis Beviláqua (1975, 2:240): “cada um suporta as perdas e degradações daquilo que lhe pertence”. E, de fato, a coisa pertence ao vendedor e o preço (o valor não pago ao vendedor), ao comprador.

A regra comum pode ser representada pela seguinte figura:



Com estas considerações fácil é concluir que se a coisa vendida perecer em consequência de caso fortuito, antes da tradição, os prejuízos decorrentes oneram o vendedor que não poderá cobrar o preço e, se este já foi pago, deve devolvê-lo ao comprador. Se, entretanto, a coisa pereceu depois de operada a tradição, compete-lhe pagar o preço, mesmo sem a ter recebido.

A situação é diversa nos casos de culpa. Perecendo a coisa em consequência de fatos culposos ou dolosos, atribuídos ao comprador ou ao vendedor, a responsabilidade rege-se segundo o ordenamento próprio da indenização civil.

As três situações descritas nos dois parágrafos do art. 492 e no art. 494 estão entre os de entrega simbólica, pois impõem riscos ao *comprador*, mesmo quando ainda não ocorreu a entrega *real*: (1) os “casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido *postas à disposição do comprador*” (CC, art. 492,

§ 1º); (2) se houver mora do comprador de recebê-las, “quando *postas à sua disposição* no tempo, lugar e pelo modo ajustados” (CC, art. 492, § 2º); e (3) se, por ordem do comprador, o objeto do contrato tiver que ser expedido para lugar diverso do local onde se encontrava no tempo da venda, tendo o vendedor cumprido as instruções e entregue a coisa ao transportador (CC, art. 494).

Nesses três casos – *postas à conferência*, mora em receber e expedição para lugar diverso – a lei entende que a tradição *simbólica* operou-se no momento em que a coisa foi posta à disposição do comprador para a determinação da quantidade, peso e características; simplesmente entregue no local combinado; ou, ainda, remetida a local diverso a pedido do comprador. O vendedor exime-se de riscos supervenientes.

Como afirmado no início, as regras legais sobre os riscos são supletivas e, como tais, os contratantes podem preferir outras soluções, acordando diversamente.

9.7.2. Vícios

Vícios são falhas ou defeitos ocultos, graves a ponto de tornar a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou, ainda, diminuir-lhe o valor (CC, art. 441). Os defeitos que permitem rejeitar (ação redibitória) ou reclamar abatimento de preço (ação estimatória, *quantum minoris*) são qualificados de *redibitórios*. Redibir traz a ideia de enjeitar.

A obrigação de garantir a coisa contra defeitos ocultos está presente em todo contrato *comutativo*, isto é, aquele em que as “prestações são equivalentes e insuscetíveis de variação”(cf. Beviláqua, 1975, 2:216), característica que o distingue do contrato *aleatório*, em que, na dicção de Monteiro (1973, 2ª:70) “intervindo o risco, subordinam-se as prestações à *álea* de acontecimento desconhecido e incerto, de que pode resultar para um e outro contratante perda ou vantagem e cuja extensão é ignorada”.

O adquirente pode escolher entre as ações previstas no Código Civil – redibitória, prevista no art. 441, ou estimatória (*quantum minoris*), regulada pelo art. 442 –, não podendo, contudo, depois de ingressar com uma delas em juízo, valer-se da outra.

Ampliando o prazo decadencial de dez dias previsto no *art. 211 do Código*

Comercial, contados do recebimento da coisa, o Código Civil estabelece que o direito à redibição ou abatimento do preço decai em trinta dias se a coisa for móvel e de um ano se for imóvel, contados da entrega efetiva. Esses prazos são reduzidos à metade se a coisa vendida já se encontrava na posse do comprador quando da alienação.

O comprador deve demonstrar em juízo: (a) **o prejuízo:** que o vício ou defeito tornam imprópria a coisa para o uso que é destinada ou lhe diminuem o valor a preexistência do vício; (b) **a preexistência:** é necessário demonstrar que os defeitos *preexistiam* no momento da celebração da compra e venda e não poderiam ter sido ordinariamente percebidos pelo comprador; (c) **o elemento subjetivo:** refere-se ao comportamento do vendedor, sua boa ou má-fé quanto ao conhecimento do vício. A lei trata de modo mais severo o vendedor que age com culpa, impondo àquele que conhecia o defeito a restituição do que recebeu (o preço), mais o pagamento de perdas e danos. Para o vendedor que ignorava, quando da venda, o defeito, basta a restituição do que recebeu acrescido das despesas do contrato (CC, art. 443).

Nas coisas vendidas em conjunto, o defeito de uma não autoriza a rejeição de todas (CC, art. 503). Disso decorre que, na compra e venda a termo, as reclamações sobre os vícios devem ser apresentadas à medida que as entregas ocorrem.

9.7.3. Evicção

A evicção é *garantia inerente* a todo contrato oneroso. Refere-se à perda – total ou parcial – da coisa vendida ou de sua posse, por força de decisão judicial proferida em virtude de reivindicação de terceiro ou, ainda, de apreensão por autoridade policial (Cf. STJ-4ª T., REsp n. 51.875-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 12-5-1997, deram provimento, v.u., *DJU*, 23-6-97, p. 29134, citado por Theotonio Negrão, 2009:208).

A garantia de evicção pode ser ampliada, reduzida ou excluída pelas partes, em cláusula expressa no contrato.

Diz-se *inerente* porque, mesmo nos contratos em que conste a expressa exclusão dessa garantia, ela subsistirá se o evicto desconhecia o risco da evicção ou, tendo

sido informado, não o assumiu. Assim, se a leitura do contrato não revelar que o comprador tinha conhecimento dos riscos e concordou em assumi-los, cabe-lhe o direito de receber o preço que pagou pela coisa.

Obriga-se o vendedor a restituir o preço que o comprador lhe pagou e, salvo expressa estipulação em contrário, a indenizar-lhe pelos frutos que foram entregues ao terceiro reivindicante, despesas do contrato, prejuízos resultantes da evicção, custas judiciais e honorários advocatícios despendidos (CC, art. 450). Para tanto, o comprador deve acionar o vendedor na ação movida pelo reivindicante da coisa, fazendo uso do instituto da denunciação da lide, previsto no art. 125, I, do Código de Processo Civil de 2015⁶⁷.

A denunciação da lide é “ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal. Haverá, na verdade, duas lides, que serão processadas em *simultaneus processus* e julgadas na mesma sentença (CPC15, art. 129); duas relações processuais, mas um só processo” (Nery, 2015:546).

Se a relação envolver mais de um alienante, o primeiro acionado poderá denunciar o alienante imediato ou qualquer um dos anteriores. Esse mesmo direito cabe a qualquer um dos acionados, em sucessão. Pode, entretanto, preferir acionar todos os anteriores, denunciando-os à lide. Nos dois primeiros casos ocorre o chamamento sucessivo e chamamento *per saltum*, no último, chamamento coletivo.

Exemplo: supondo que um empresário adquira uma máquina de outro empresário para seu parque industrial; pago o preço, instalado o equipamento em sua fábrica e em plena produção, o comprador é surpreendido com mandado de citação em ação promovida por terceiro que reivindica a máquina dizendo integrar seu estabelecimento empresarial. Afirmar essa terceira empresa ter contratado o trespasse de seu estabelecimento que, entretanto, fora rescindido em data anterior à venda realizada à compradora. Cabe à compradora denunciar à lide a vendedora para resguardar-se e obter, nesse mesmo processo, seu direito de evicto. O magistrado, julgando procedente o pedido de reintegração do terceiro e entendendo caber direito do comprador pela evicção, condenará o vendedor (denunciado à lide) pelas verbas previstas em lei (CC, art. 450): a restituição do preço que pagou pela máquina, dos

eventuais frutos que tiver sido obrigado a restituir ao reivindicante, das despesas do contrato, inclusive transporte e montagem do equipamento em seu parque fabril, bem como pelos prejuízos decorrentes da desmontagem, paralisação da linha de montagem etc., das custas processuais (perícias, condução de oficial de justiça, despesas processuais etc.) e honorários aos advogados constituídos.

9.8. Obrigações do comprador

O comprador deve, essencialmente, pagar o preço. Não o fazendo, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa objeto do contrato (CC, art. 491), salvo se celebrado para pagamento a prazo.

Como vimos (item 9.7.1), no tocante às despesas de transferência, cumpre distinguir: as de escritura e de registro são ônus do comprador e as de *tradição*, do vendedor, o que nos remete ao bem objeto do contrato – quando se tratar de imóvel, as despesas serão sempre do comprador porque nessa modalidade a transferência se dá obrigatoriamente pela transcrição da escritura no registro imobiliário e, se móvel, em regra do vendedor. Em ambos os casos, as partes podem estabelecer diversamente.

Há, ainda, outros deveres que são inerentes ao comprador: suportar os riscos do preço (CC, art. 492) e das situações referidas no exame da entrega da coisa, previstas no Código Civil (arts. 492 e 494), matéria objeto de exame acima (item 9.7.1).

9.9. Modalidades especiais de compra e venda

O Código Civil traz três regras especiais, uma exclusivamente para a compra e venda de coisas móveis e outras duas para operação com imóveis. A primeira regula a compra e venda de coisa móvel à vista de amostras (CC, art. 484) e as duas outras, a venda de imóvel *ad mensuram* e *ad corpus* (CC, arts. 500-501).

9.9.1. Venda de coisa móvel à vista de amostras

Dispõe o art. 484 do Código Civil: “Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as

qualidades que a elas correspondem”. O dispositivo reproduz integralmente o que dispunha o art. 1.135 do Código Civil de 1916, acrescentando logo após “amostras” os termos “protótipos ou modelos”, ampliando o objeto da contratação.

As inovações tecnológicas impuseram esses dois novos *termos de comparação*, cuja inclusão mostrou-se necessária em decorrência da limitação da palavra “amostra” que não se estende a novos processos, frutos da engenharia da informatização e da produção industrial em série.

Amostra é coisa móvel remetida pelo vendedor, em pequena quantidade, suficiente para permitir ao comprador verificar sua integral correspondência com a qualidade da coisa objeto de contrato de compra e venda. Pode ser um retalho de tecido, um punhado de sementes, um vidro pequeno de perfume, uma lâmina de pedra etc.

Protótipo, na delimitação jurídica de proveito empresarial, é o primeiro tipo ou exemplar de qualquer coisa móvel, corpórea ou incorpórea, suscetível de produção ou circulação econômica. Incluem-se, por exemplo, nesse conceito os programas e sistemas de computador e um exemplar de determinado produto, contendo todas as especificações para produção em escala industrial (um *software*, um carro, uma motocicleta, um computador etc.).

A palavra “modelo” pode ser utilizada em inúmeras acepções, conforme anota Aurélio (2010:1409): “objeto destinado a ser reproduzido por imitação; representação em pequena escala de algo que se pretende executar em grande; molde; impresso; réplica tridimensional de objeto, artefato, cenário, pessoa, etc., construído em escala normal, reduzida ou ampliada para fins didáticos, filmagem de efeitos especiais, teste de segurança, etc.”. Considerando, contudo, que o legislador quis diferenciá-la das duas primeiras – amostra e protótipo –, deve-se entender que se pretendeu limitar seu uso à representação gráfica contendo minuciosa descrição integral do produto objeto da compra e venda. Conclusão também sustentada por Maria Helena Diniz (2008:402): “Se a coisa foi vendida mediante amostra (reprodução integral da coisa com suas qualidades e características), protótipo (primeiro exemplar do objeto criado) ou modelo (desenho, ou imagem, acompanhado de informações), por não ter sido entregue nas condições prometidas, o comprador

poderá recusá-la no ato do recebimento, pois se entende que o vendedor garante que possui as qualidades correspondentes ao modelo, amostra ou protótipo apresentado [...]”.

Temos assim, resumidamente:

Amostra – a própria coisa em pequena quantidade.

Protótipo – o primeiro exemplar de uma coisa que se quer produzir em série.

Modelo – a reprodução gráfica de coisa objeto do contrato de compra e venda, contendo sua descrição integral.

Na compra e venda concluída à vista de amostras, protótipos e modelos, o vendedor garante que as coisas objeto do contrato possuem as qualidades desses exemplares apresentados ao comprador, os quais prevalecem sobre outros elementos descritivos, mesmo se constatada contradição com eventual descrição constante do contrato.

Esses princípios adotados pelo legislador de 2002 são fruto de doutrina antiga. Carvalho de Mendonça (1955, 6.2:127) explica sua importância na vigência do *Código Comercial de 1850*: “O Código, no art. 201, exige *correspondência perfeita* entre a amostra e a coisa a entregar. Se o vendedor entrega a mercadoria de qualidade superior ou inferior à amostra, o comprador pode recusá-la. Este, também, não é obrigado a suportar a tolerância, que se observa nas entregas ordinárias, nem a aceitar mercadorias que se aproximam da amostra. A qualidade de amostra, escreve Pipia (*La compra-vendita commerciale*, n. 410), exerce decisiva influência na estipulação do contrato, e, portanto, o comprador tem o direito de exigir mercadorias idênticas e conformes”.

9.9.2. Venda de imóvel *ad mensuram* e *ad corpus*

Venda *ad mensuram*, ou venda por metragem, é aquela em que o preço é implícita ou explicitamente determinado pela área do imóvel, o que ocorre em duas situações descritas no art. 500 do Código Civil: (a) se o preço é estipulado por medida de extensão, como, por exemplo, o contrato em que se estipula a venda de um terreno de 1.230 metros quadrados a R\$ 500,00 por metro quadrado; (b) se no contrato a

determinação da área é precisa e essencial à fixação do preço, como ocorre na venda de 2 alqueires de terra no município de São Gabriel pelo preço de R\$ 2.000.000,00. Diz Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:152), com propriedade, que, “na venda *ad mensuram* o objeto do contrato é uma determinada extensão de terra”.

Nessas situações o comprador tem direito ao complemento da área (ação de entrega de coisa vendida – *ex empto*) e, se isso não for possível, o direito de resolver o contrato (ação redibitória – *redhibitoria*) ou pedir o abatimento proporcional ao preço (ação estimatória – *quantum minoris*), salvo se a diferença encontrada não exceder a um vigésimo da área enunciada, isto é, a 5% de sua extensão.

A primeira ação (de complementação – *ex empto*) persegue a própria coisa que deixou de ser entregue e, portanto, é uma ação de cunho real. As duas outras são de natureza pessoal, distinção que se mostra importante na fixação da competência, uma vez que, quanto ao prazo “decadencial”, o legislador disponibilizou um único prazo (cf. Nery 2007:530).

Todas as ações decaem no prazo de um ano, contado do registro do título ou a partir da imissão de posse, quando houver atraso atribuível ao alienante (CC, art. 501). Embora o Código Civil mencione o verbo “decair”, não há na doutrina entendimento uniforme. Barbosa Moreira, no artigo publicado RF 364/186 (*O novo Código Civil e o direito processual*), entende que na ação *ex empto* e na ação *quantum minoris* o prazo é de prescrição, e na ação *redhibitoria* o prazo é de decadência (cf. citação em Nery 2007:533).

Se a área encontrada é superior à da área vendida e o vendedor ignorava a medida exata, o comprador pode, a sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

Considera-se, contudo, meramente enunciativa a menção à extensão do imóvel quando vendido como *coisa* certa (sítio Tal) e discriminada (limitando com A e B), isto é, indicando suas confrontações e limites: “vendo sítio Jardim das Oliveiras, com 2 alqueires, no melhor ponto de Campinas, confrontando de um lado com Sítio Dominique e, de outro, com a Quinta do Sebastião, margeando por dois lados pelo ric

das Trutas. O imóvel contém pomar com uma variedade de árvores frutíferas”. Aqui o que o comprador busca é o Sítio Jardim das Oliveiras, sua extensão não é essencial na fixação do preço, mas meramente enunciativa.

Neste caso se diz que a venda é feita *ad corpus* e a falta de correspondência com as dimensões indicadas não acarreta direito de resolução, complementação ou abatimento de preço ao comprador.

Sumariando a matéria: a venda é *ad mensuram* se as medidas são precisas e determinantes para a fixação do preço; será *ad corpus* se forem imprecisas e meramente enunciativas e a venda se dá sobre imóvel certo e discriminado.

9.10. Cláusulas especiais

Além das três modalidades especiais estudadas no tópico anterior – venda por amostras, venda *ad mensuram* e venda *ad corpus* –, o Código Civil regula cinco pactos adjetos, cláusulas especiais à compra e venda, em cinco subseções, a saber: a retrovenda (Subseção I, arts. 505-508); venda sujeita a contento e venda sujeita a prova (Subseção II, arts. 509 a 512); preempção ou preferência (Subseção III, arts 513 a 520); venda com reserva de domínio (Subseção IV, arts. 521 a 528); e venda sobre documentos (arts. 529 a 532).

Abandonou o Código Civil de 2002 a estrutura anterior, deixando de regulamentar o pacto de *melhor comprador* e o *pacto comissório*, objeto de previsão nos arts. 1.158 a 1.162 e art. 1.163, respectivamente, do Código Civil de 1916.

Essas cláusulas, contudo, não desapareceram da ordem jurídica porque não encontram proibição no novo ordenamento, podendo ser objeto de estipulação entre os contratantes.

9.10.1. Pacto de melhor comprador e pacto comissório

No pacto de melhor comprador os contratantes acordam o desfazimento de contrato de *compra e venda de imóveis*, se, em certo prazo, aparecer quem ofereça melhor preço:

“Art. 1.158. O contrato de compra e venda pode ser feito com a cláusula de se

desfazer, se, dentro em certo prazo, aparecer quem ofereça maior vantagem”.

Clóvis Beviláqua (1975, 2:262) esclarece a exata extensão da expressão “maior vantagem”: “entende-se preço mais elevado ou algum elemento, que traga benefício ao vendedor, como sejam garantias maiores, pagamento imediato e semelhantes. Essas vantagens, porém, devem ser reais. Não basta que o vendedor lhe afirme a existência, cumpre que, efetivamente, existam, para que as denuncie ao comprador”.

A segunda modalidade omitida pelo legislador de 2002 – o pacto comissório – é cláusula que prevê a resolução do contrato no caso de não pagamento do preço até determinada data: “Art. 1.163. Ajustado que se desfça a venda, não se pagando o preço até certo dia, poderá o vendedor, não pago, desfazer o contrato, ou pedir o preço. Parágrafo único. Se em 10 (dez) dias de vencido o prazo, o vendedor, em tal caso, não reclamar o preço, ficará de pleno direito desfeita a venda”.

9.10.2. Retrovenda

Retrovenda é modalidade de cláusula especial, permitida nos contratos de compra e venda de coisa imóvel, mediante a qual o vendedor reserva para si o direito de recobrá-la no prazo *decadencial* máximo de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador.

A legislação brasileira veda o resgate parcial de imóvel indivisível – relativamente à fração do imóvel por um dos condôminos – exigindo que o depósito seja integral, mesmo quando duas ou mais pessoas detenham o direito de retrato.

Pode ocorrer que *todos* concordem em exercer esse direito em ação conjunta e, neste caso, não haverá nenhuma dificuldade, cada um deles receberá o quinhão correspondente à sua fração ideal. Entretanto, se o pedido for feito por um ou mais condôminos individualmente, caberá ao comprador intimar todos os demais titulares para, querendo, acordarem, e se não o fizerem (ou apresentarem divergências), prevalecerá o direito em favor daquele que efetuar depósito integral (CC, art. 508).

Entre as despesas incluem-se “as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita ou, para a realização de benfeitorias necessárias” (CC, art. 505).

Clóvis Beviláqua (1975, 2:251), com fundamento no art. 1.140 do Código Civil de 1916, reproduzido quase integralmente pelo art. 505 do Código Civil de 2002, apresenta quatro características do resgate convencional: “1ª, que é uma venda sob condição resolutória, como no direito romano; 2ª, que somente se aplica aos imóveis, cujas alienações, sujeitas ao registro predial, tornam conhecido de todos o pacto adjeto de *retroemendo*; 3ª, que o imóvel é restituído com os seus acréscimos e melhoramentos; 4ª, que o vendedor, exercendo o seu direito de resgate, devolve ao comprador o preço recebido, reembolsando-lhe as despesas feitas com o contrato, e com os melhoramentos úteis e necessários”.

São legitimados ativamente os cessionários por ato *inter vivos* e, em virtude de *causa mortis*, herdeiros e legatários do vendedor e, passivamente, terceiros adquirentes.

Maria Helena Diniz (2007:205-206) assinala que o direito de retrato – de resgate – não é cessível a terceiros por ato *inter vivos*, por ser personalíssimo do vendedor. Posição distinta é adotada por Orlando Gomes (2008:308), Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:157), Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (2012:702); estes últimos assinalam: “diferentemente do que ocorre com o direito de preferência (CC, art. 520), o direito ao exercício da retrovenda é cessível e transmissível por ato *inter vivos*”.

A expressão legal (“O direito de retrato, que é *cessível* e transmissível a herdeiros e legatários [...]”, CC, art. 507) nos permite concordar com a última posição, observando que o legislador distinguiu os atos de *cessão* dos atos de *transmissão*, legitimando a conclusão de que se trata de atos *inter vivos*.

A recusa em devolver o bem permite ao vendedor depositar a quantia em juízo (CC, art. 506), sob a forma de consignação, segundo o disposto nos arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, depositando em dinheiro o valor correspondente “em estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, em conta com correção monetária, cientificando-se o credor por carta com aviso de recepção, assinado o prazo de dez dias para a manifestação da recusa”.

Em caso de recusa do comprador, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, o vendedor (e, eventualmente, o cessionário, o herdeiro ou legatário daquele) deverá ingressar com o pedido (ação de consignação) em juízo, no prazo de trinta dias; se não o fizer nesse prazo, o depósito fica sem efeito, podendo o depositante levantá-lo.

9.10.3. Venda a contento e venda sujeita a prova

Venda a contento é aquela sujeita a condição (suspensiva) de o adquirente manifestar seu agrado (CC, art. 509). Considera-se perfeita a venda somente depois da exteriorização favorável do comprador.

A condição *potestativa*, inerente ao contrato, submete seu aperfeiçoamento ao arbítrio do comprador, impedindo sua contestação pelo vendedor. Clóvis (1975, 2:255) assim se expressa: “O vendedor não tem direito de apelar para o parecer de perito, porque não se trata de determinar a boa qualidade da coisa vendida, mas de saber se *agrada* ao comprador. A opinião pessoal deste último é decisiva”.

Venda sujeita a prova é a contratada sob condição suspensiva de o comprador experimentá-la para o fim de comprovar que a coisa tem as qualidades asseguradas pelo vendedor e é idônea para o fim ao qual se destina (CC, art. 510).

Em que momento deve o comprador manifestar-se?

O contrato pode estipular o prazo para a declaração do comprador e, no silêncio, ao vendedor cabe o direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para esse fim, em prazo improrrogável (CC, art. 512).

Em ambos os contratos, enquanto não se realizar a condição, a venda e compra, o contrato não se aperfeiçoa. Qual é, então, a situação jurídica do comprador em relação à coisa que detém?

É a de mero comodatário (CC, art. 511), isto é, detém a coisa em empréstimo gratuito, obrigando-se a conservá-la, como se sua própria fora (CC, art. 582), devendo restituí-la quando vencido o prazo convencionado (CC, art. 581) ou, se não previsto, pelo tempo razoável para o fim contratado.

9.10.4. Preempção ou preferência

Preempção é modalidade de cláusula especial, permitida em contrato de compra e venda de coisa móvel ou imóvel, mediante a qual o comprador, na eventualidade de venda ou dação em pagamento da coisa, obriga-se, por certo prazo, a notificar o vendedor a exercer direito de prelação (ou preferência) na aquisição do bem, em igualdade de condições com terceiro.

As obrigações dos contratantes resumem-se essencialmente a duas: a primeira refere-se ao *comprador*, de oferecer a coisa comprada ao vendedor, no caso de pretender vendê-la ou dá-la em pagamento e, a segunda, imposta ao *vendedor*, em aceitando exercer a preferência, a de pagar o preço encontrado ou ajustado.

O Código Civil regulamenta vários aspectos do pacto adjeto de preferência: (a) **Prazo para o exercício do direito:** o prazo máximo para exercício da preempção é de cento e oitenta dias para móveis e de dois anos para imóveis (CC, art. 513, parágrafo único); (b) **Notificação pelo vendedor:** se o comprador não notificar o vendedor, este pode intimá-lo para que cumpra a avença (CC, art. 514); (c) **Prazo de decadência:** decai o direito das ações decorrentes da preempção sobre coisa móvel e imóvel, em três e em sessenta dias após o recebimento da notificação, respectivamente (CC, art. 516); (d) **Direito entre condôminos:** se o direito couber a mais de uma pessoa, qualquer uma delas pode exercer o direito sobre o todo e, recusando ou decaindo uma delas, remanesce o direito da outra (CC, art. 517); (e) **Cominação:** a falta de cumprimento por parte do comprador, deixando de dar ciência sobre o preço e vantagens oferecidas por terceiro, resolve-se em perdas e danos, respondendo solidariamente o terceiro adquirente que agir de má-fé (CC, art. 518); (f) **Natureza pessoal do direito:** trata-se de direito personalíssimo que não se transmite por ato *inter vivos* ou *causa mortis* (CC, art. 520).

Temos, assim, as seguintes situações:

a) o comprador notifica o vendedor e este deixa fluir o prazo legal (3 dias se móvel ou 60 dias, se imóvel). O vendedor decaiu de seu direito e a venda pode ser realizada a terceiro, sem que o vendedor tenha direito à manifestação intempestiva de

sua preferência ou de pleitear perdas e danos, caso a venda ocorra;

b) o comprador notifica o vendedor e este manifesta, no prazo legal, o interesse em recomprar a coisa. Deverá pagar, em condições iguais, o preço de mercado (preço encontrado) ou o preço previamente ajustado contratualmente. O direito de prelação é exercido pela manifestação tempestiva e pelo pagamento do preço;

c) o comprador não notifica o vendedor sobre o preço e vantagens e o vendedor toma ciência, por outra via, da intenção de venda. Cabe-lhe notificar o comprador, exercendo, assim, o direito de preempção. Deverá então pagar o preço (encontrado ou ajustado), sob pena de perder a preferência;

d) o comprador não notifica o vendedor sobre o preço e vantagens e aliena a coisa. O vendedor pode acionar o comprador por perdas e danos. Se o terceiro agiu de má-fé responderá com o comprador, de forma solidária.

Ao lado do direito de preempção *contratual*, há a figura especial, também denominada *retrocessão* (ou preempção *legal*), decorrente de decreto de desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Consiste na faculdade de o expropriado exercer a preferência na aquisição da coisa expropriada, pelo preço atual, quando o Poder Público não utilizar a coisa em obras ou serviços públicos indicados no ato administrativo. Prevista no art. 519 do Código Civil, distingue-se da preempção contratual porque não ocorre uma nova venda, nem há obrigação de o poder expropriante notificar o expropriado, inexistindo, na ausência de qualquer dever, imposição indenizatória por perdas e danos.

9.10.5. Venda com reserva de domínio

Venda com reserva de domínio é aquela em que o vendedor, por cláusula contratual escrita, reserva para si a propriedade de *coisa móvel infungível* objeto da alienação, até que o preço esteja inteiramente pago.

Uma das dificuldades do pacto situa-se em desvendar sua natureza jurídica. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (2012:706) assinalam “que a reserva de domínio tem sido tratada como condição do contrato por alguns e garantia real por outros”. Orlando Gomes (2008:318), mesmo considerando inexistir outra explicação

mais clara para a natureza da venda e compra, salienta as dificuldades em se aceitar o pacto de reserva de domínio como condição do contrato: “inclina-se a doutrina para a doutrina da *venda sob condição suspensiva*, conquanto censurável por atribuir a um dos elementos essenciais do contrato, precisamente o preço, a natureza de *condição*. O pagamento do *preço* é a principal obrigação do *comprador*, a contraprestação devida ao vendedor, não sendo possível considerá-lo acontecimento *incerto*, pois o devedor tem a necessidade jurídica de satisfazê-lo. Por outro lado, se *condição* fora, no sentido técnico do vocábulo, seria *meramente potestativa*, porque o cumprimento da obrigação ficaria ao arbítrio exclusivo do devedor. A objeção não tem, contudo, a consistência da outra, pois o pagamento do preço não é indiferente ao comprador, e, nessa hipótese, a condição não seria arbitrária”.

À falta de solução uniforme, consideraremos o pacto de reserva de domínio condição suspensiva, como também sustenta respeitável parte da doutrina moderna (v. Maria Helena Diniz, 2007:214; Washington de Barros Monteiro, 1973:110).

Para validade contra terceiros, o contrato contendo a cláusula de reserva deve ser levado a registro no cartório de títulos e documentos e o objeto deve ser infungível, suscetível de caracterização perfeita, distinta de outros congêneres, isto é, infungível (CC, arts. 522-523).

O comprador detém a posse direta, respondendo pelos riscos desde que a coisa lhe foi entregue. O vendedor, na qualidade de proprietário e possuidor indireto, pode cobrar o preço das prestações vencidas e vincendas ou recuperar a própria coisa, por meio de ação de reintegração de posse.

Em síntese, são características do contrato de venda e compra com cláusula de reserva de domínio: (a) estipulação por escrito (CC, art. 522); (b) transcrição do documento no Registro de Títulos e Documentos situado no domicílio do comprador para validade contra terceiros (CC, art. 522); (c) a coisa vendida deve ser móvel e infungível (CC, arts. 521 e 523); (d) a transferência da propriedade somente ocorre no momento em que o preço estiver integralmente pago (CC, art. 524); (e) ao contrário do que ocorre nos contratos de venda e compra em geral, em que os riscos correm por conta do vendedor até o momento da tradição (CC, art. 492), na reserva de domínio, o

comprador responde pelos riscos da coisa *desde a entrega do bem* (que ainda não é tradição – transferência de propriedade, CC, art. 524); (f) para executar a cláusula, o credor deve, antes, interpelar judicialmente ou protestar o título, constituindo o devedor em mora (CC, art. 525); (g) o credor tem duas opções: cobrar as prestações vencidas ou recuperar a posse da coisa (CC, art. 526).

No direito falimentar, algumas regras próprias trazem regulamentação complementar ao direito decorrente do contrato de venda e compra com reserva de domínio.

Desde o processamento do pedido de recuperação judicial ficam suspensas as ações de cobrança ou de recuperação da coisa dada com reserva de domínio, pelo prazo de 180 dias, contados da publicação do despacho de deferimento (LREF, arts. 6º e 52). Nesse prazo os bens essenciais à atividade do devedor não podem ser objeto de venda ou de retirada do estabelecimento empresarial do comprador. Decorrido esse prazo, o vendedor pode exercer livremente seu direito, escolhendo a via que melhor lhe atender, sem necessidade de habilitar-se no concurso de credores (LREF, art. 49, § 3º).

Somos críticos dessa solução e tivemos oportunidade de escrever a respeito do assunto no trabalho “A Eficiência do Processo Judicial na Recuperação de Empresa” (Negrão, 2010:179).

“Posto assim o real cenário dos protagonistas da recuperação, indaga-se: a perspectiva de *manter o nível do spread* bancário nos contratos afastados do plano de recuperação e, ainda, de *preservar* a expansão do crédito e a não majoração de seu custo no Brasil é, de fato, fator de eficiência no processo de recuperação⁶⁸?

A resposta a esta indagação é negativa. Submeter os credores arrolados no art. 49, §§ 3º e 4º, ao plano de recuperação é, antes de tudo, fator positivo no que se refere à eficiência do processo de recuperação e resulta em melhor garantia de tratamento igualitário entre os credores de um mesmo devedor, portadores dos títulos indicados no dispositivo.

Esta vantagem está condicionada a que a cláusula de titularidade do bem

contratado não venha a sofrer, por força de plano recuperatório, qualquer modificação. Exemplificando: ao devedor haveria de se permitir propor a credores titulares desses direitos alterações com vistas ao alongamento do contrato e à *equalização dos encargos financeiros*⁶⁹ praticados sem promover alterações no direito de reivindicar o bem no caso de inadimplemento.

Essa solução traria resultados mais eficientes por quatro razões: maximização do ativo, fortalecimento do ambiente de negociação, melhor coordenação de divergências e redução de disputas judiciais sobre contratos.

Em primeiro lugar, evita a retirada de bem necessário à continuação da empresa, decorrido o período de *stay*, isto é, o período de suspensão das ações, previsto no Brasil no art. 6º da LREF. Isto permite não fracionar a empresa, mantendo-a para a venda como unidade produtiva em caso de liquidação, solução que, em termos eficientes, é superior à desagregação de bens oriundos de contratos de arrendamento, alienação fiduciária ou com cláusula de reserva de domínio.

Em segundo lugar, não prioriza direitos dos credores em ambiente de negociação. Observe-se, neste ponto, que não se propõe qualquer desrespeito ao direito de preferência concursal, mas, sim, possibilitar que a empresa em crise amplie a possibilidade de sua recuperação, abrangendo todo o universo contratual.

Em terceiro lugar, amplia o nível de coordenação dos interesses entre os credores, fornecendo à massa subjetiva maior segurança na apreciação das propostas do plano, produzindo um encadeamento afirmativo quanto à transparência e viabilidade do projeto. As classes, nas sucessões de deliberações, ponderariam os argumentos apresentados em debates quanto à aceitação ou rejeição do plano por um segmento da universalidade. As negociações fluiriam ao se perceber que determinada categoria (por exemplo, fiscais ou titulares de direito de propriedade) estaria disposta a aceitar o alongamento e a redução dos encargos incidentes etc.

Em quarto lugar, evita disputas judiciais quanto à regularidade do contrato (as chamadas ações de revisão de contrato), instrumento jurídico amplamente utilizado e que pode atingir o objetivo de impedir a pronta execução do contrato original. Neste

caso, a situação do credor, na ação individual, seria menos favorável do que aquela decorrente de negociação na recuperação judicial, dada a plena efetividade do título judicial (LREF, art. 59, § 1º), com margens mínimas de futura revisão por parte do devedor. Removido o obstáculo da discussão judicial em processo autônomo, reduz-se o custo”.

Na falência, o contrato de venda e compra com reserva de domínio não se resolve, competindo ao administrador judicial, ouvido o Comitê de Credores, decidir pelo prosseguimento ou pela entrega do bem ao vendedor (LREF, art. 119, IV). No silêncio do administrador, depois de notificado pelo credor, cabe, ainda, a favor deste, ação de restituição, cumulada com indenização, com curso no juízo falimentar (LREF, arts. 85 e 117, § 2º).

9.10.6. Venda sobre documentos

Venda sobre documentos é aquela em que a tradição da coisa vendida é “substituída pela entrega de seu título representativo e de outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos” (CC, art. 529).

Trata-se de modalidade de tradição simbólica da coisa que dá ao vendedor o direito de cobrar o preço da venda, na data e no local da entrega dos documentos (CC, art. 530), salvo se outro momento e lugar forem pactuados.

A circulação de documentos é, nos tempos atuais, mais célere que o transporte da própria coisa. Nos contratos internacionais ou mesmo dentro de regiões nacionais, sobretudo em países com grande extensão territorial, o objeto a ser entregue pode estar em lugar diverso daquele em que se celebra o contrato de compra e venda. Feita a entrega dos títulos representativos e da documentação exigida contratualmente, considera-se efetivada a tradição da própria coisa e, assim, os riscos passam a correr por conta do comprador. É por esta razão que o art. 531 do Código Civil prevê que cabem a este os custos da apólice de seguros que, eventualmente, acompanhar a documentação, com vistas à cobertura dos riscos do transporte.

Em contratos com venda sobre documentos é comum a intervenção de instituição financeira, sobretudo em operações mercantis internacionais, nas quais o banco efetua

o pagamento ao exportador mediante a entrega da documentação correspondente. Dispõe a lei que a causa subjacente à importação, suas falhas, irregularidades e ilícitos praticados por terceiros não podem ser imputados ao banco concedente do crédito porque é terceiro em relação ao negócio jurídico celebrado entre comprador e vendedor (CC, art. 532). O banco responde tão somente pela má prestação de seus serviços, como, por exemplo, a demora na liberação de valores, extravio de documentação em seu caixa, pagamento não previsto ou não conforme a ordem recebida etc.

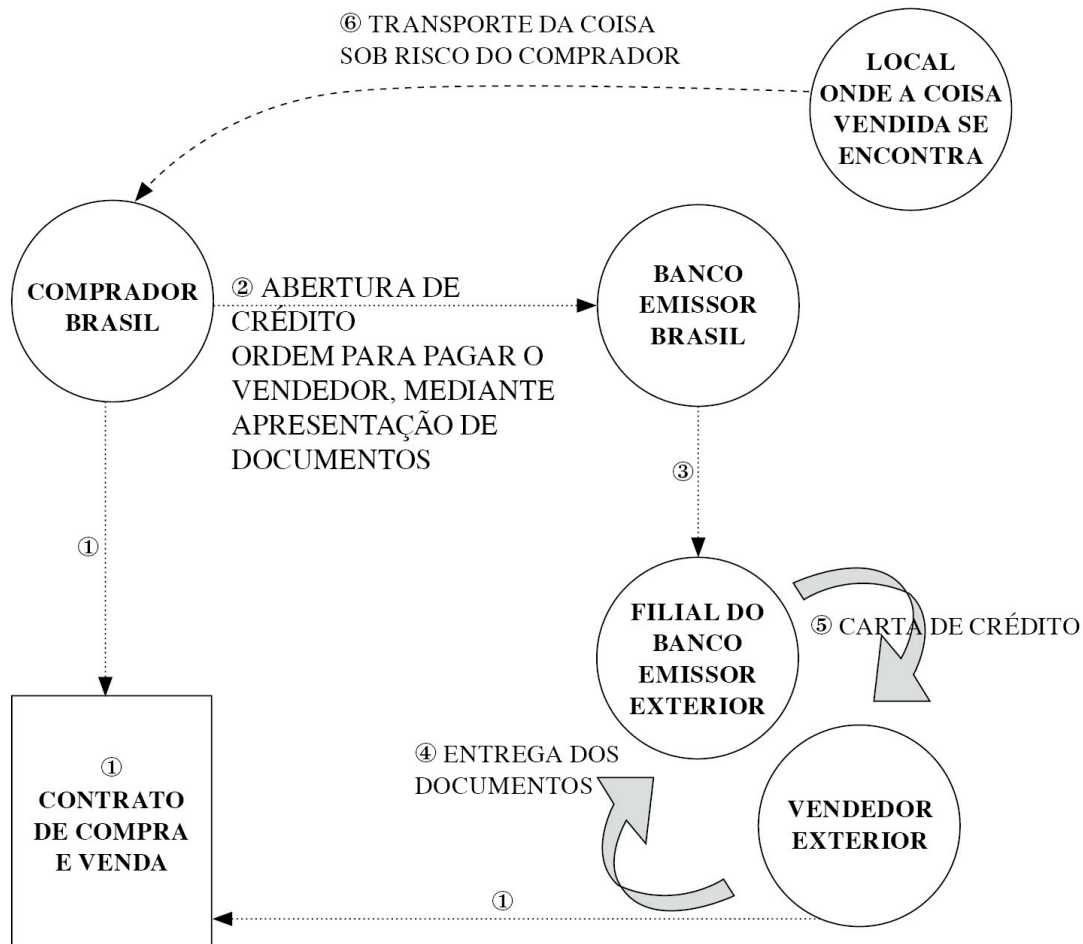
O parágrafo único do art. 532 do Código Civil figura sobre a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, estabelecendo que, neste caso, o vendedor poderá pretendê-lo diretamente do comprador. Essa recusa pode ser justificada por negócios entre o comprador e o banco ou decorrer de má prestação de serviços, cabendo ao comprador valer-se de ações próprias à recuperação do dinheiro por ele endereçado ao vendedor e à indenização por eventuais perdas e danos, inclusive os de natureza moral.

Para perfeita compreensão do tema, estudaremos, na sequência, o uso mais comum da venda sobre documentos no comércio internacional – o crédito documentário.

9.10.7. Crédito documentário

Crédito documentário é operação de crédito realizada por bancos que intermedeiam operações comerciais internacionais, geralmente efetivadas sobre documentos.

O mecanismo de atuação mostra-se complexo quanto ao número de operações envolvidas, mas o conjunto é de fácil compreensão, conforme anota Waldirio Bulgarelli⁷⁰. Numa compra e venda sob documentos, entre dois empresários estabelecidos em países distintos, podemos exemplificar, em seis operações, o uso de crédito documentário:



Neste exemplo, figuramos a importação feita por um empresário brasileiro no exterior e, ao lado do contrato de compra e venda sobre documento realizado pelas empresas envolvidas, outros contratos foram firmados, como, por exemplo, o do importador brasileiro com o banco escolhido, na abertura da conta de crédito, no contrato de câmbio e na outorga de poderes para que o banco pagasse o exportador e recebesse o título representativo e os documentos relativos ao negócio.

Há vantagens no uso dessa modalidade de mecanismo facilitador de negócios internacionais. Para os empresários contratantes da compra e venda, Fábio Ulhoa Coelho (2016, 3:141) destaca o crédito e a segurança: “Para o ordenante, o crédito documentário representa o financiamento da operação, já que pode restituir ao banco o valor pago ao beneficiário através de sucessivas amortizações. E configura para o beneficiário a garantia de recebimento de seu crédito, em vista da obrigação assumida pela instituição financeira de pagar o devido pelo seu cliente”.

Há regras para o comércio internacional com o uso do crédito documentário fixadas pela *International Chamber of Commerce* (Câmara de Comércio Internacional), também conhecida por *World Business Organization*, adota a sigla ICC e possui entre seus associados organizações representativas de negócios, empresas e outras entidades jurídicas, além de pessoas individuais com atividades voltadas a negócios internacionais.

É uma organização privada fundada em 1919, com sede em Paris, que adota, entre seus objetivos, o de promover o comércio internacional, a economia de mercado e o crescimento das economias dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, buscando a melhor forma de integrá-los na economia internacional.

No sítio eletrônico da organização (<http://www.iccwbo.org>) é possível encontrar o extenso leque de objetivos do ICC, aqui livremente traduzidos⁷¹: “As atividades do ICC cobrem um amplo espectro, que inclui desde a arbitragem e a solução de conflitos, até a defesa do livre-comércio e do sistema de economia de mercado, a autorregulação de empresas, a luta contra a corrupção ou a luta contra o crime comercial”.

Com esses objetivos o ICC elaborou a partir de 1933 regras visando uniformizar o uso dos créditos documentários, denominando esse documento UCP (*Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits*), que nada mais são do que “usos e costumes” regulamentados para facilitar sua utilização pelos bancos ao redor do mundo. Desde então sete versões foram aprovadas, sendo a última numerada como UCP 600, em vigor desde 1º de julho de 2007.

9.11. Cláusulas de custos em contratos internacionais – *incoterms*

Para facilitar a administração de conflitos em matéria de comércio internacional, a mesma ICC (Câmara de Comércio Internacional – CCI) criou em 1936 os *incoterms* (*International Commercial Terms*) que, na data de hoje, somam treze siglas que representam, de forma abreviada, os usos frequentes das cláusulas de custos da entrega da mercadoria, adotadas no mercado internacional.

Divididos em quatro grupos, os *incoterms* permitem conhecer, desde logo, as cláusulas convencionadas pelas partes, entre o mínimo de responsabilidade do vendedor pela Saída (*E, de exit*) até o máximo de obrigações pela entrega ao comprador (*D, de delivery*). No meio-termo estão os casos de incumbência ou não pelo transporte principal (*F, de free* – sem custo ou *C, de cost*, com custo).

GRUPO	SIGLA	SIGNIFICADO	DESPESAS E RISCOS
E	EXW	<i>Ex works</i> – a mercadoria é retirada do estabelecimento do vendedor. Neste momento ocorre a tradição ao comprador, que passa a correr os riscos até o local de produção.	Desde a retirada, as despesas e riscos são do comprador.
F	FCA	<i>Free carrier</i> – o vendedor deve desembaraçar a mercadoria para a exportação.	O vendedor é responsável até o momento em que a mercadoria é levada à saída do País, inclusive pelo desembaraço alfandegário. Elemento comum: o transporte principal não é pago pelo vendedor.
	FAS	<i>Free Alongside Ship</i> – o vendedor deve colocar a mercadoria ao lado do navio, no cais do porto. Este é o momento da tradição da mercadoria, correndo riscos pelo comprador a partir daí.	
	FOB	<i>Free On Board</i> – o vendedor deve colocar a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador. A tradição da mercadoria se dá no navio, a partir do que os riscos são do comprador.	
C	CFR	<i>Cost and Freight</i> – os custos de embarque e de frete são de responsabilidade do vendedor. Os riscos da mercadoria a bordo são do comprador. É exclusivo para transporte marítimo ou fluvial doméstico.	O vendedor é responsável até o porto de destino. Elemento comum: o transporte principal é pago pelo vendedor.
	CIF	<i>Cost, Insurance and Freight</i> – amplia-se a obrigação do vendedor para incluir o seguro marítimo até a chegada. A tradição é feita no navio e, assim, os riscos da mercadoria a bordo são do comprador. É exclusivo para transporte marítimo ou fluvial doméstico.	

	CPT	<i>Carriage Paid To</i> – o vendedor é obrigado ao frete até o local do destino e o comprador assume o ônus dos riscos, a partir do momento em que a transportadora, no país de destino, assume a custódia das mercadorias.	
C	CIP	<i>Carriage and Insurance Paid To</i> – idêntico ao CPT, salvo quanto ao custo do seguro que deve ser pago pelo vendedor.	
D	DAF	<i>Delivered At Frontier</i> – a entrega é feita em ponto anterior ao da alfândega e desembaraçada para exportação. Cabem ao comprador as providências até seu estabelecimento.	Elemento comum: a responsabilidade do vendedor estende-se até a chegada.
	DES	<i>Delivered Ex-Ship</i> – o vendedor deve colocar, à sua custa, a mercadoria no porto de destino. Somente para transporte marítimo.	
	DEQ	<i>Delivered Ex-Quay</i> – as despesas até o desembarque são do vendedor, inclusive direitos de exportação e taxas, à disposição do comprador.	
	DDU	<i>Delivered Duty Unpaid</i> – a mercadoria é entregue dentro do país do comprador, obrigando-se pelas despesas o vendedor, exceto os impostos e encargos de importação.	
	DDP	<i>Delivered Duty Paid</i> – a mercadoria é entregue livre ao comprador. O vendedor assume todos os riscos e custos até a entrega.	

Há notícia de atualização dessa lista para incluir um novo *incoterm* (CNI), excluir outros (EXW, DDP e FAS) e desdobrar os *incoterms* FCA (em marítimo e terrestre) e DDP (em DTP e DPP), a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020.

9.12. Outros contratos relacionados à compra e venda

No direito empresarial algumas modalidades de contratos interessam no exame do

contrato de compra e venda, em razão de pressupor sua celebração. Destacaremos o contrato estimatório e o *hedging*.

9.12.1. Contrato estimatório

Contrato estimatório ou venda em consignação é aquele em que alguém (consignatário) recebe *bem móvel* de terceiro (consignante) para efetuar sua venda, obrigando-se a pagar o preço previamente ajustado se deixar de restituir a coisa consignada em sua integridade, no prazo contratado.

A I Jornada do Conselho da Justiça Federal, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários entre 12 e 13 de setembro de 2002, sob a Coordenação-Geral do Ministro Milton Pereira, com a participação de 130 juristas, aprovou a seguinte interpretação para o conceito de contrato estimatório previsto no art. 534 do Código Civil: “Enunciado n. 32: no contrato estimatório, o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder de alienação da coisa consignada com opção de pagamento do preço de estima ou sua restituição ao final do prazo ajustado”.

A expressão *estimatório* decorre do ajuste prévio de preço (valor estimado). É implícita, também, a temporária suspensão, por parte do consignante, do poder de disposição da coisa, agora exercido em nome próprio pelo consignatário (CC, art. 537). Contudo, o consignante conserva a propriedade do bem consignado que, assim, não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço (CC, art. 536).

9.12.2. Hedging

No mundo dos negócios empresariais há um constante avanço da tecnologia contratual, surgindo a cada momento mecanismos que somente serão objeto de regulamentação anos ou décadas depois de seu uso pelos empresários em diversos ramos de atuação.

Como exemplo dessas novas técnicas aplicáveis sobre o contrato de compra e venda empresarial encontramos o *hedging* ou *hedge*, literalmente barreira/proteção, trava/cobertura. Incide em operação de compra e venda, com vistas à cobertura de

riscos de oscilações de preços. São operações realizadas pelo investidor na comercialização de produtos no mercado futuro (derivativos – *commodities*, *juros*, *câmbio*, *ações*, *dívidas*), visando à proteção de seu investimento contra riscos de variações, e se resumem a contra-ações em sentido contrário ao do investimento.

O *Vocabulário do Mercado de Capitais*, publicado pela Comissão Nacional de Bolsas de Valores (1990:34), apresenta o seguinte conceito: “É a operação que consiste na tomada de uma posição no mercado futuro aproximadamente igual – mas em sentido contrário – àquela que se detém ou que se pretende vir a tomar no mercado à vista. É uma forma de o investidor se proteger contra os efeitos das oscilações de preço”.

Nos contratos dessa natureza, envolvendo riscos consideráveis, o investidor é orientado a realizar no mercado futuro operações que lhe permitam minimizar as perdas no mercado à vista.

Para entender o mecanismo, figure-se como exemplo o produtor rural que, pretendendo colher sua safra em outubro e calculando um custo de R\$ 60,00 a saca, vende em fevereiro do mesmo ano *contratos futuros* (a termo) de sua produção para a data da colheita, pelo preço de R\$ 100,00 a saca. Esse valor lhe é garantido qualquer que seja a variação do preço de seu produto na data da colheita (podendo variar para mais ou para menos nessa data). Imaginando que ele tenha vendido sua produção (mil sacas), seu resultado no mercado futuro é R\$ 100.000,00, para um custo de R\$ 60.000,00. Em agosto, ao verificar que o preço de mercado de seu produto é de R\$ 60,00 a saca, obteria o resultado de R\$ 60.000,00, empatando com os custos da produção. A operação no mercado futuro compensa as perdas do mercado à vista.

Esse mecanismo se repete no mercado de ações, na compra a termo e na venda a termo e em outros mercados financeiros. Ao realizar essas operações, o investidor realiza mais de um contrato de compra e venda, figurando ora como comprador, ora como vendedor, tudo com vistas a proteger-se de prejuízos decorrentes da variação de preços.

9.13. Resumo gráfico

Conceito e distinções Características Elementos formadores	É aquele em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. O contrato será empresarial quando as partes forem empresárias ou sociedades empresárias e o objeto se destinar à revenda ou circulação. Consensualidade Bilateralidade Onerosidade Coisa Existência Individualidade Disponibilidade Preço Critério arbitral Critério futuro (mercado, bolsa, índices) Sem critério convencional
	Em regra é simplesmente consensual (sem forma específica), salvo para imóveis, que exige solenidade. Imediata A termo Complexa

Forma e prova do contrato	- Entrega da coisa e recebimento do preço - A coisa em trânsito e a insolvência do comprador - Efeitos falimentares
Execução do contrato	- Entrega da coisa - Vícios - Evicção
Direitos dos contratantes	
Obrigações do vendedor	
Obrigações do comprador	- Pagar o preço e suportar seus riscos - Coisas imóveis: as despesas de transferência - Casos fortuitos na contagem e remessa para lugar diverso
Modalidades especiais de venda e compra	- Venda de coisa móvel à vista de amostras - Venda de imóvel <i>ad mensuram</i> e <i>ad corpus</i>
Cláusulas especiais	- Pacto de melhor comprador - Pacto comissório - Retrovenda - Venda a contento - Venda sujeita a prova - Preempção ou preferência - Venda com reserva de domínio - Venda sobre documentos - Crédito documentário
Cláusulas de custos em contratos internacionais	<i>Incoterms</i>
Outros contratos relacionados	- Contrato estimatório <i>Hedging</i>

Capítulo 10

CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO AGÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONCESSÃO MERCANTIL

Sumário: 10.1. Distinções doutrinárias. 10.2. Agência e distribuição. 10.2.1. Conceito. 10.2.2. Representação empresarial autônoma. 10.2.3. Natureza. 10.2.4. Forma contratual. 10.2.5. Contratantes: natureza e classificação. 10.2.6. Elementos essenciais do contrato. 10.2.7. Elementos acessórios do contrato. 10.2.8. Qualificação jurídica e distinções. 10.2.9. Distinções com o mandato e a comissão. 10.2.10. Retribuição. 10.2.11. Extinção do contrato. 10.3. Distribuição por conta própria (revenda ou concessão comercial). 10.3.1. Objeto e características. 10.3.2. Revenda de automóveis. 10.3.3. Objeto de concessão. 10.3.4. Zona de atuação. 10.3.5. Principais deveres e direitos. 10.3.6. Convenções. 10.3.7. Formalidade contratual. 10.3.8. Resolução de contrato. 10.3.9. Indenizações nas resoluções de contrato.

10.1. Distinções doutrinárias

O vocábulo “distribuição” traz dificuldades à correta classificação do contrato, em razão de seu caráter jurídico polissêmico. Utilizando o mesmo termo para realidades jurídicas distintas, ora como gênero e ora como “subespécie de uma de suas espécies”⁷², o legislador civil instalou séria controvérsia no meio jurídico.

Humberto Theodoro Junior (2003:111) explica que “a palavra ‘distribuição’ é daquelas que o direito utiliza com vários sentidos. Há uma ideia genérica de distribuição como processo de colocação dos produtos no mercado. Aí se pensa em *contratos de distribuição* como um gênero a que pertencem os mais variados negócios jurídicos, todos voltados para o objetivo final de alcançar e ampliar a

clientela (comissão mercantil, mandato mercantil, representação comercial, fornecimento, revenda ou concessão comercial, franquia comercial etc.). Há, porém, um sentido mais restrito, que é aquele com que a lei qualifica o contrato de agência. No teor do art. 710 do CC, a distribuição não é a revenda pelo agente. Este nunca compra a mercadoria do preponente. É ele sempre um prestador de serviços, cuja função econômica e jurídica se localiza no terreno da captação de clientela. (...)”.

Com essa mesma preocupação, Fábio Ulhoa Coelho apresenta classificação que distingue os contratos de distribuição-aproximação dos contratos de distribuição-intermediação, ensinando que os primeiros, contratos típicos, regulam-se pelos arts. 710-721 do Código Civil e, os segundos, atípicos (não disciplinados em lei) caracterizam-se pelo *ato de comprar para revender*: “um empresário assume (distribuidor)” a obrigação, “perante o outro (distribuído), de criar, consolidar ou ampliar o mercado dos produtos deste último, comprando-os para revender” (2016:415).

Essas noções – aproximação e intermediação – são essenciais para a perfeita compreensão conceitual. Na aproximação o que se faz é promover negócios para outrem, com ou sem obrigação de concluí-los; na intermediação há revenda de produtos, por conta própria.

Maria Helena Diniz (2007:424-435) vê o contrato de distribuição como sinônimo de concessão mercantil *lato sensu*, expressão adotada pela Lei n. 6.729/79, antes da regulação pelo Código Civil (arts. 710-721), que, a partir de sua vigência, abrangeria aquele contrato e os de agência. A renomada professora paulista, contudo, distingue a distribuição do “contrato de agência ou representação comercial” porque na distribuição sempre ocorre a revenda.

Adotamos aqui a distinção entre “contrato de agência e distribuição”, sucedâneo do contrato de representação comercial e “contrato de distribuição por conta própria” (revenda), também conhecido como concessão comercial. Entendemos que os primeiros regem-se pelo Código Civil (agência-distribuição) e pela Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de 1965 – LRCA (Lei que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos – agência-representação), e os últimos são, em geral, contratos

atípicos.

CONTRATOS DE DISTRIBUIÇÃO (<i>nomen juris</i> genérico)	POR CONTA DO PROPONENTE (aproximação) POR CONTA PRÓPRIA (intermediação)	AGÊNCIA – CC, arts. 710-721. O agente não dispõe da coisa. AGÊNCIA-REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL – CC, art. 710, e Lei n. 4.886/65. Tem cunho empresarial. AGÊNCIA-DISTRIBUIÇÃO – CC, art. 710, final, e ss. O agente dispõe da coisa negociada. Chamados de REVENDA ou de CONCESSÃO. Contratos em geral atípicos. São exemplos: revenda de automóveis, distribuição de combustíveis e de bebidas etc. A revenda ou concessão de automóveis foge à regra da atipicidade e foi regulamentada pela Lei n. 6.729/79.
--	---	---

No contrato de agência, a aproximação se faz sem que o agente disponha da coisa à sua disposição para ser negociada. Por exemplo: agente que oferece mercadorias por catálogos fornecidos pelo fabricante, sem dispor dos produtos.

Se a agência é de cunho empresarial, temos a figura do representante comercial autônomo que se define como pessoa física ou jurídica “que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios *mercantis*, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios” (Lei n. 4.886/65, art. 1º).

Na distribuição, o agente tem a sua disposição a coisa a ser negociada, mas a oferta à clientela é realizada à conta do proponente. Disso difere da concessão, porque nesta há revenda de produtos, por conta do agente. É o caso, por exemplo, de revenda de automóveis: o revendedor os compra do fabricante e os revende em sua concessionária. Essa venda se faz por conta da concessionária e não do concedente (a montadora). Há aqui uma intermediação de mercadorias, uma revenda de produtos.

Enfatizamos que o primeiro (contrato de agência e a modalidade distribuição, bem como a subespécie representação empresarial autônoma) é regido pelos arts. 710-721 do Código Civil, pela Lei n. 4.886/65 (quando o agente mediar negócios empresariais, agenciando propostas e pedidos) e pelas regras concernentes ao mandato e à comissão quando houver cláusula de concessão de poderes para o agente concluir contratos (CC, arts. 710, parágrafo único, e 721). O segundo (contrato de

distribuição por conta própria) é, em geral, contrato atípico, não disciplinado legalmente, a não ser quando envolver revenda de automóveis, regendo-se, então, pela Lei n. 6.729/79.

10.2. Agência e distribuição

10.2.1. Conceito

Agência é o contrato oneroso, em que alguém assume, em caráter profissional, não eventual, e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outrem, a realização de certos negócios, em determinado território ou zona de mercado.

A obrigação do agente é *promover a realização de negócios*, isto é, o objeto se cumpre na simples aproximação de clientes ao representando, sem a obrigação de concluir acordos. O contrato pode prever, contudo, ampliação desse objeto – promover e concluir acordos –, concedendo ao agenciado poderes para também finalizá-los.

A expressão *promover a realização de certos negócios* utilizada pelo legislador civil (CC, art. 710) ampliou outra mais restrita inserida no art. 1º da LRCA: *desempenhar a mediação para a realização de negócios mercantis*, adequando-se ao fenômeno evolutivo já realizado em legislações estrangeiras⁷³.

António Pinto Monteiro (2004:45) ressalta a superioridade desse termo: “Para esse efeito, o termo ‘promover’, além de ser já familiar da doutrina e da jurisprudência portuguesas, é o que se afigura mais adequado às funções do agente (apresenta vantagens, designadamente, sobre o termo ‘negociar’, desde logo porque aquele coenvolve o *incentivo* à negociação) [...]”.

Segundo Monteiro (2004:44) promover implica, no meio econômico, “toda uma complexa e multifacetada *atividade material*, de prospecção do mercado, de angariação de clientes, de difusão dos produtos e serviços, de negociação, etc., que antecede e prepara a conclusão dos contratos [...]”.

Veja-se que o verbo “promover (a realização de certos negócios)” tem maior

extensão do que aquele utilizado pela Lei n. 4.886/65 – “agenciar (propostas ou pedidos)” – existindo uma relação “continente-conteúdo” entre ambos. Promover negócios abrange, entre outras, a ação de agenciar pedidos e propostas.

10.2.2. Representação empresarial autônoma

Substituímos, neste capítulo, a denominação legal “representante comercial autônomo” por “representante empresarial autônomo”, por entendermos que a expressão “comercial”, que distinguia atos civis e comerciais, não tem mais razão de existir, diante da adoção da Teoria da Empresa pelo ordenamento jurídico brasileiro.

No direito brasileiro, se o contrato de agência versar sobre negócios empresariais voltados ao agenciamento de propostas, surgirá a figura da representação empresarial autônoma. Representante empresarial autônomo é, portanto, o agente contratado para promover a realização de certos negócios empresariais, agenciando pedidos ou propostas para transmiti-los ao proponente.

Confere com essa conclusão o magistério de Alfredo de Assis Gonçalves Neto (2006:216) quando afirma: “o contrato de representação comercial, dadas suas particularidades, não corresponde exatamente ao contrato típico de agência descrito e regulado nos arts. 710 a 712 do Código Civil, mas é, sem dúvida, uma de suas espécies. Em razão disso, essas normas codificadas são-lhe aplicáveis, mas o contrato e o agente representante continuam sujeitos à lei especial, ou seja, à Lei n. 4.886, de 1965, que rege a atividade de representação comercial”.

No mesmo sentido, completa Humberto Theodoro Júnior (2003:116): “Harmonizando-se, de tal sorte, a disciplina do contrato de agência instituído pelo NCC com a do representante comercial, constante das Leis ns. 4.886/65 e 8.420/92 ter-se-á um negócio jurídico vocacionado naturalmente para as atividades mercantis”.

É também a lição de Orlando Gomes (2008:450) quando proclama: “Em primeiro lugar, da análise comparativa dos dois textos legais parece não haver dúvida de que se trata do mesmo tipo contratual. Com efeito, a função econômico-social do contrato descrito no art. 710 do Código Civil é idêntica à do contrato regido pela Lei n. 4.886/65, a saber, a realização de determinada atividade (promoção de negócios

em certa área, à conta e, eventualmente, também em nome de outrem) contra uma retribuição. A distinção entre eles cinge-se apenas ao fato de que o art. 1º da Lei n. 4.886/65 limita a atividade do agente à promoção de ‘negócios mercantis’, ao passo que o art. 710 do Código Civil de 2002 refere-se, de modo mais amplo, à promoção de ‘certos negócios’. A mudança deve-se à unificação do direito das obrigações operadas pelo novo Código”.

Afastamos, portanto, da porção doutrinária que sustenta que o contrato de representação empresarial previsto na Lei n. 4.886/65 é instituto diverso do contrato de agência e distribuição. Trata-se de modalidade específica, contida no gênero “agência-distribuição” aplicável a negócios empresariais específicos, aos quais incidem as regras previstas no Código Civil, desde que não incompatíveis com o regime próprio instituído por aquele diploma legal.

A especificidade mostra-se presente na finalidade contratual – o contrato de representação empresarial está voltado a negócios mercantis (LRCA, art. 1º), hoje denominados “empresariais”, particularmente o de “agendar propostas ou pedidos, para transmiti-los ao representado” – e no regramento legislativo próprio (ao qual se aplica em primeiro plano à Lei n. 4.886/65).

Certa parte da doutrina vê no parágrafo único do art. 710 a distinção entre “agência-distribuição” e “agência-distribuição representação comercial”, como disserta Carlos Roberto Gonçalves (2008, 3:436) ao sustentar: “quando ocorre a situação prevista no parágrafo único supratranscrito, em que o proponente confere poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos, *configura-se* o contrato de *representação comercial autônoma*, regido pela Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de 1965, com as alterações feitas pela Lei n. 8.420, de 8 de maio de 1992. Neste as partes necessariamente serão empresárias. No contrato de agência, regulado pelo novo Código Civil, não é necessário que o agente ou o proponente sejam empresários, como sucede, por exemplo, com o agente de um atleta profissional ou de renomado ator ou cantor”.

Divergimos desse entendimento porque a concessão de poderes ao agente para que este “o represente na conclusão dos contratos”, implícito no agenciamento de

propostas que o representante empresarial autônomo realiza, pode ocorrer nas outras duas modalidades contratuais, isto é, na agência (em que o proponente não disponibiliza a coisa negociada) e na distribuição (em que o proponente disponibiliza ao agente a coisa negociada).

10.2.3. Natureza

A natureza contratual do contrato de agência (aqui no seu sentido genérico, que abrange as três subcategorias – agência, distribuição e representação empresarial autônoma) – emerge de seu conceito: (a) onerosidade porque a intermediação do agente se faz mediante retribuição pecuniária; (b) intransferibilidade (“alguém assume”), em razão de se exigir exercício pelo agente ou distribuidor; (c) bilateralidade que decorre do fato de ambos os contratantes assumirem obrigações.

Trata-se, assim, de contrato oneroso, intransferível e bilateral.

Além dessas características gerais, há, ainda, outras três bem específicas: (a) a aproximação *inter alios*, porque o agente age no interesse de outrem; (b) a autonomia, em razão de atuar sem subordinação ou vínculo de dependência com o agenciado. Leia-se independência quanto à subordinação de caráter funcional, mas não quanto ao aspecto jurídico, uma vez que o agente age por conta do proponente, submetendo-se, neste ponto, às instruções recebidas deste (CC, art. 712); (c) a estabilidade contratual, ou intuito duradouro, que decorre da expressão “não eventual” (CC, art. 710), indicando haver, entre os contratantes, uma relação que se estende a certo período, não se caracterizando por uma operação negocial isolada.

10.2.4. Forma contratual

Antes do advento do Código Civil de 2002, no regime da Lei n. 4.886/65, a doutrina indagava acerca da obrigatoriedade de contratação por escrito. Entendiam alguns que a redação do art. 27 introduzida pela Lei n. 8.420/92, suprimindo a expressão “quando celebrado por escrito”, fizera desaparecer a possibilidade de contratação verbal, não reduzida a termo.

Marco Antonio Rocha Calábria (2000:49) corretamente rebate os adeptos dessa

corrente, argumentando que “a lei apenas deixou de mencionar as expressões *quando celebrado por escrito* ou *contrato escrito* – nada mais, não prevendo, em qualquer das suas passagens, a obrigatoriedade de que o contrato seja reduzido à forma escrita. Simplesmente não existe no texto legal qualquer dispositivo que conduza a esse entendimento. Ao contrário, quando não faz ela menção a uma ou outra forma de contratação, a conclusão mais razoável é de que ambas (escrita ou verbal) são igualmente possíveis e válidas”.

Esse raciocínio mantém-se sob o regime do Código Civil que, nos arts. 710-721, não restringiu a contratação a uma única forma. Evidentemente, se o contrato se firmar verbalmente, toda sorte de dificuldades existirá no campo probatório, inviabilizando, muitas vezes, a delimitação precisa que o legislador buscou ordenar.

10.2.5. Contratantes: natureza e classificação

Duas questões são suscitadas quanto às pessoas contratantes: sua natureza e qualificação jurídica. Podem figurar no contrato pessoas naturais e pessoas jurídicas? E a qual classe de agentes econômicos pertencem? A atividade que exercem é reputada empresarial?

No que se refere à primeira pergunta, dúvida não há quanto aos agentes que exercem a representação autônoma: as pessoas naturais e as pessoas jurídicas podem desempenhar a profissão (LRCA, art. 1º).

E os agentes-distribuidores de negócios não empresariais, sujeitos à previsão única do Código Civil (arts. 710-721)?

Rubens Edmundo Requião (2006:189), com fundamento em interpretação que dá ao art. 719 do Código Civil, sustenta que o agente será sempre pessoa natural. Parece-nos, contudo, que essa interpretação é ampliativa e não resulta da redação legal. Ao afirmar caber aos herdeiros o direito à remuneração correspondente aos serviços realizados pelo agente, já falecido, que não concluiu o trabalho por motivo de força maior, o legislador tratou de uma situação específica ao contrato firmado por agente pessoa natural, não se podendo concluir que, em razão disso, excluiu a possibilidade de uma pessoa jurídica exercer a atividade de agente. Como assinala Carlos Alberto

Hauer de Oliveira (2006:233): “trata-se, é claro, de um dispositivo que só tem pertinência quando o agente for pessoa natural, mas daí concluir que somente as pessoas naturais podem ser a parte ativa deste contrato é uma demasia”.

No que se refere à classificação dos agentes-distribuidores, anotamos com Fábio Ulhoa Coelho (2006:115-122) que, não obstante desenvolverem atividade com caráter econômico, esta nem sempre será reputada empresarial.

No contrato de agência (agência e agência-distribuição) o *proponente* poderá ou não subsumir-se ao conceito de empresário. No contrato de agência-representação, essa qualidade é implícita, decorre da definição legal que, embora desatualizada (realização de negócios *mercantis* pela lei de 1965, LRCA, art. 1º), aponta para o exercício de uma “atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens” (CC, art. 966). É de se presumir que, mesmo antes de se introduzir o conceito moderno de empresa no Código Civil, aquele que contratava um representante para realização duradoura de negócios relativamente a seus produtos, o fazia porque mantinha negócio estruturado de cunho *mercantil* (como exigia a LRCA).

O *agente*, entretanto, em todas as modalidades contratuais, pode ou não exercer essa atividade econômica de forma organizada porque nada há que o impeça de prestar o serviço “pessoalmente, sem contratação de mão de obra, investimento de capital significativo, desenvolvimento ou aquisição de tecnologias com alguma sofisticação (Coelho, 2006:121)”.

Em resumo, respondendo à indagação: os contratantes serão sempre empresários?

CONTRATO	PROPONENTE	AGENTE
Agência	Não	Não
Agência-distribuição	Não	Não
Agência-representação	Sim	Não

10.2.6. Elementos essenciais do contrato

É da essência do contrato de agência e de distribuição:

a) *Definição do objeto contratual*: com indicação genérica ou específica dos produtos, artigos e serviços a que o agente se obriga a promover a realização. O Código Civil utiliza-se da expressão “certos negócios”, indicando a necessidade de determinação, seja no alcance funcional desses negócios (promover, executar e/ou concluir), seja na indicação da coisa a ser negociada (produto, artigo, serviço). A Lei n. 4.886/65 exige a “indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação” (art. 27, alínea b). O que se tem em mente é definir o âmbito da agência, lembrando que o agente desenvolve atividade de aproximação de clientela, mediante a promoção de realização de negócios – em geral vendas ou serviços – para o representado;

b) *Profissionalidade do agente*. É a exigência que decorre do caráter não eventual do contrato, de sua natureza duradoura. O agente é profissional qualificado ao fomento de contratos entre proponente e interessados, futuros clientes daquele. Decorre dessa profissionalização a exigência de o agente de negócios empresariais registrar-se no Conselho Regional de Representantes Comerciais (LRCA, art. 2º);

c) *Determinação de uma zona de atividade*, que pode ser exclusiva ou não. Tanto o Código Civil quanto a Lei do Representante Autônomo exigem a determinação contratual da zona de atuação do agente (CC, art. 710, e LRCA, art. 27,d). No que se refere à exclusividade, as legislações oferecem para o caso de omissão de regra contratual, em distintas redações, o mesmo resultado: no Código Civil, nada estipulando o contrato, incide a vedação prevista no art. 711: “Salvo ajuste, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na mesma zona, com idêntica incumbência [...]”; na LRCA obriga-se a estipulação da “garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona” (art. 27, e) e, entretanto, prevê, para a omissão, o direito de o agente receber “comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros” (LRCA, art. 31).

d) *Retribuição pelos serviços prestados*. Como regra geral, o agente tem direito à remuneração que corresponder aos negócios realizados em sua zona, ainda que sem a

sua interferência (CC, art. 713). As partes, contudo, podem contratar diversamente, limitando a zona de atuação ou propondo condições diversas. Em geral fixam percentagens sobre o produto ou serviço objeto da negociação. Na representação empresarial, incidem regras específicas previstas nos arts. 32 e 33, estipulando a LRCA, entre outras, o prazo para pagamento (até o dia 15 do mês subsequente ao da liquidação da fatura, sob pena de incidir atualização monetária), a forma de cobrança (possibilidade de emissão de títulos de crédito) e o método para obtenção do valor devido (cálculo sobre o valor total das mercadorias). O Código Civil é omissivo, permitindo que as partes, em contratos de natureza não empresarial, cheguem ao consenso que entenderem mais adequado.

10.2.7. Elementos acessórios do contrato

Quanto ao prazo, as partes são livres para a sua fixação. No caso de firmado por prazo indeterminado, o contrato resolve-se a qualquer tempo, mediante aviso prévio de noventa dias, observado, porém, o transcurso de prazo razoável tendo em vista a natureza e o vulto do investimento exigido pelo agente (CC, art. 720).

Essa disposição não se aplica ao contrato de representação empresarial autônoma que possui regra própria, prevista no art. 34 da LRCA: “a denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por prazo indeterminado e que haja vigorado por mais de 6 (seis) meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante, nos 3 (três) meses anteriores”.

Em razão da livre disposição das partes, não se alinha, entre os requisitos essenciais do contrato, a possibilidade de: (a) assunção das despesas a cargo do agente (CC, art. 713); (b) dúplice exclusividade ou exclusividade recíproca: em regra o proponente garante ao agente a exclusividade quanto à zona de negócio que for delimitada no contrato (CC, art. 711) e este se obriga a não tratar de negócios do mesmo gênero, à conta de outros proponentes (CC, art. 711). Contudo, podem dispor de modo distinto. São assim cláusulas facultativas.

10.2.8. Qualificação jurídica e distinções

O contrato de agência qualifica-se de distribuição se o agente tem à sua disposição a coisa a ser negociada (CC, art. 710, *in fine*): “Eventualmente, o representado pode confiar ao agente os bens a serem colocados junto à clientela, caso que o Código trata como *distribuição*, mas não como revenda, visto que os atos de negociação se realizam em nome e por conta do comitente” (Theodoro Jr., 2003:115).

Vemos, portanto, a distinção entre **agência** (promoção de negócios à conta de outrem *sem* que o agente disponha da coisa), **distribuição** (promoção de negócios à conta de outrem *com* a disposição da coisa pelo agente) e **revenda** (os atos negociais se realizam em nome e por conta do revendedor).

E a representação “comercial”? É o contrato de agência-distribuição em que o agente realiza negócios empresariais de forma específica, mediante concretização de propostas ou de pedidos que são encaminhados ao proponente. Esta modalidade, conforme vimos, rege-se pela definição do parágrafo único do art. 710 do Código Civil e pela Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de 1965, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei n. 8.420, de 8 de maio de 1992.

10.2.9. Distinções com o mandato e a comissão

Devemos observar que, não obstante aplicarem-se ao contrato de agência e distribuição as regras concernentes ao mandato e à comissão, no que couber (CC, art. 721), esses contratos não se confundem. Cada um deles possui conceitos e características próprios.

No contrato de mandato, o mandatário recebe poderes de outrem, para, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses (CC, art. 653). A distinção entre mandato e agência é facilmente percebida: na agência o contrato envolve relacionamento duradouro, sem a necessidade de poderes inerentes ao mandato, visando à aproximação indeterminada de clientes ao representado. No contrato de mandato, há determinação de certos atos no instrumento de procuração, a serem praticados pelo mandatário.

É certo que o parágrafo único do art. 710 estipula que “o proponente *pode* conferir

poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos”. Contudo, o mandato neste caso é contrato acessório, complementar, ao contrato de agência e distribuição, caráter que acentua a distinção entre ambos.

Na comissão mercantil, o comissário adquire ou vende bens em seu próprio nome, à conta do comitente (CC, art. 693). O comissário não atua em nome do comitente, mas *por conta* do comitente e, assim, somente ele, comissário, é que se obriga perante a pessoa com quem contrata (CC, art. 694), não respondendo, contudo, por sua solvência perante o comitente (CC, art. 697), salvo se agir com culpa ou o contrato estipular cláusula *del credere* (CC, art. 698).

CONTRATO	FUNÇÃO DO CONTRATO	CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO	PREVISÃO LEGAL
Agência	Promoção de certos negócios em zona determinada.	A aproximação é feita pelo agente, mas o negócio é concretizado entre cliente e proponente.	CC, arts. 710-721 Soma-se a elas a modalidade especial de agência “representação empresarial autônoma”, prevista na Lei n. 4.886/65
Distribuição (sem revenda)	Promoção de certos negócios em zona determinada, mas o agente tem a sua disposição a coisa negociada.	A aproximação é feita pelo agente, mas o negócio é concretizado entre cliente e proponente.	
Mandato	Prática de atos ou administração de interesses alheios.	O mandatário delibera e realiza o negócio em nome do mandante.	CC, arts. 653-691
Comissão	Aquisição ou venda de bens, em nome do comissário, à conta do comitente.	Somente o comissário aparece no negócio. Ele fica diretamente obrigado com as pessoas com quem contratar.	CC, arts. 693-709

10.2.10. Retribuição

Quanto à retribuição, tanto o Código Civil como a lei especial traçaram extenso regramento. Além da remuneração relativa aos negócios que efetivamente concluir, o agente tem direito à percepção dos valores correspondentes aos negócios: (a) *concluídos* dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência (CC, art. 714, e LRCA, art. 31); (b) *não realizados* por fato imputável ao proponente (CC, art. 716); (c) *pendentes*, na hipótese de dispensa sem culpa (CC, art. 718, e LRCA, art. 32 § 5º).

10.2.11. Extinção do contrato

Ocorrendo causa que acarrete a extinção do contrato, devem-se distinguir algumas situações previstas em lei:

- **Dispensa por justa causa alegada pelo representado:** o agente tem direito à remuneração pelos serviços úteis. O proponente pode exigir perdas e danos por prejuízos que sofrer (CC, art. 717). O Código Civil não articula causas que considere justas, podendo o intérprete valer-se do elenco previsto na legislação especial para proceder à integração da norma. São motivos justos para a rescisão pelo proponente as causas previstas no art. 35 da Lei n. 4.886/65: (a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; (b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; (c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial; (d) a condenação definitiva por crime considerado infamante; (e) força maior.

- **Dispensa por justa causa alegada pelo agente:** são os casos em que o agente terá direito à indenização, porque a dispensa ocorre sem culpa sua, equiparando-se sua situação à dispensa imotivada por parte do proponente, descrita a seguir. O art. 716 refere-se à não realização do negócio por fato imputável ao proponente. A LRCA é mais específica e, no art. 36, indica os motivos legais para que o representante empresarial autônomo fundamente seu pedido de rescisão: (a) redução da esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato; (b) quebra, direta ou indireta, da exclusividade; (c) fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação

regular; (d) não pagamento de sua retribuição na época devida; (e) força maior.

- **Dispensa sem justa causa:** o art. 718 do Código Civil trata genericamente da hipótese, estipulando que o agente terá “direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial”. Neste caso o agente tem direito à remuneração sobre os negócios pendentes e às indenizações constantes da Lei n. 4.886/65, cujo valor deverá estar previsto em contrato, não podendo ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, j). No contrato firmado com prazo determinado, a indenização corresponde à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual (art. 27, § 1º).

- **Cessação do trabalho pelo agente, por motivo de força maior:** o agente ou, em caso de morte, seus herdeiros terão direito à percepção correspondente aos serviços realizados.

10.3. Distribuição por conta própria (revenda ou concessão comercial)

10.3.1. Objeto e características

O contrato de distribuição por conta própria (revenda) utilizado ordinariamente para distribuição de diversos produtos, entre os quais revenda de bebidas e de combustível, é contrato atípico e, como tal, não se reveste de características próprias, comuns, aplicáveis a todos os contratos. Entretanto, pode ser citada como essencial a cláusula de exclusividade recíproca na distribuição e de definição de territorialidade, em maior ou menor amplitude.

Em geral, nesses contratos são, ainda, previstas cláusulas que estabelecem regras sobre: (a) a indenização ao concessionário em caso de resolução contratual para cobrir prejuízos decorrentes de assistência técnica *pós-venda* e estoques de peças (cf. Bulgarelli, 1997:450); (b) os casos de resolução e prazos de notificação; (c) as quotas de fornecimento e de aquisição; (d) as condições especiais de pagamento do produto adquirido; (e) a concessão de uso limitado de direitos de propriedade

industrial, assistência, conhecimento e treinamento técnicos etc., conforme grau de sofisticação contratual.

Na falta de regramento específico, como se opera a solução judicial para as divergências que surgirem entre os contratantes? O Superior Tribunal de Justiça, analisando a necessidade de operar a interpretação dos contratos atípicos, decidiu que sua apreciação não se faça única e exclusivamente pela disciplina dos contratos afins, mas inicialmente pela analogia, aplicando-se em seguida os princípios gerais do direito obrigacional e contratual e, por fim, pela livre apreciação do magistrado. (REsp n. 5.680/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 13-11 1990, *DJ*, 10-12-1990, p. 14812).

Aplicam-se, portanto, na lacuna legislativa as regras gerais de integração, previstas no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942): “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

10.3.2. Revenda de automóveis

A revenda de automóveis, exceção ao caráter de atipicidade destes contratos, traz regramento específico (Lei n. 6.729/79, com as alterações introduzidas pela Lei n. 8.132/90).

Vários aspectos contratuais foram exaustivamente regulamentados pelo legislador, tais como o objeto de concessão (art. 3º); a zona de atuação (art. 5º); os direitos e deveres das partes (arts. 6º até 15) e as vedações contratuais (art. 16); o regramento das convenções (art. 17) entre categorias econômicas de produtores e distribuidores, denominadas convenções de categorias econômicas (art. 18), e entre produtor e rede de distribuição, denominadas convenções de marca (art. 19); a formalidade contratual (arts. 20 e 21) e sua resolução (arts. 22-27); a contratação de prestação de assistência técnica e comercialização de componentes fora da rede de distribuição de veículos (art. 28).

10.3.3. Objeto de concessão

Inclui-se no contrato de concessão não somente a revenda de veículos mas igualmente a comercialização de implementos e componentes fabricados ou fornecidos pelo produtor e, ainda, a prestação de assistência técnica a todos os produtos objeto do contrato.

10.3.4. Zona de atuação

É inerente ao contrato de concessão a demarcação de área operacional para o exercício das atividades do concessionário, que não poderá operar além dos seus limites. Se o fizer, vendendo, diretamente ou por intermédio de preposto, produtos a comprador domiciliado em outra área demarcada, o concessionário deverá destinar parte da margem de comercialização aos concessionários da área do domicílio do adquirente. Este, consumidor dos produtos e serviços distribuídos, pode livremente escolher o estabelecimento que melhor lhe convier, não podendo ter limitado esse direito de livre escolha por contrato ou convenções entre o fabricante e a sua rede concessionária.

A área demarcada poderá conter mais de um concessionário da mesma rede, devendo ser observadas distâncias mínimas entre eles, fixadas segundo critérios de potencial de mercado. O concedente poderá, ainda, realizar novas concessões se a área delimitada apresentar condições previamente ajustadas com sua rede de distribuição ou, ainda, para substituir concessionário que teve seu contrato extinto. Em ambos os casos as condições dessa nova contratação não poderão acarretar prejuízo aos concessionários da marca que terão direito de concorrer, em igualdade de condições, ao preenchimento da nova vaga.

10.3.5. Principais deveres e direitos

São direitos do concedente: (a) exigir fidelidade na compra pelo concessionário de seus produtos, obrigando-o, por força de convenções, a adquirir percentuais de componentes de veículos. Nesse índice de fidelidade não se incluem os acessórios para veículos automotores, nem os implementos para máquinas agrícolas; (b) fixar o preço de venda de seus produtos aos concessionários; (c) exigir do concessionário a

manutenção de estoque proporcional à rotatividade dos produtos novos; (d) vender veículos diretamente à administração pública, direta ou indireta, ou ao corpo diplomático e, ainda, nos limites ajustados com a rede de distribuição, a compradores especiais.

São direitos do distribuidor: (a) receber quota de produtos para revenda, correspondente a uma parte da produção estimada pela montadora e ajustada anualmente, segundo sua capacidade empresarial, desempenho de comercialização e conforme capacidade do mercado da área que lhe foi demarcada; (b) fixar o preço de venda, ao consumidor, dos bens e serviços objeto da concessão, acrescendo no preço do produto ao consumidor sua margem de comercialização; (c) receber os produtos por preço e condições de pagamento uniformes praticados para a rede de distribuição; (d) limitar seu estoque de veículos, tratores, implementos e componentes⁷⁴ a índices fixados em lei; (e) realizar o pagamento dos produtos adquiridos somente após o faturamento, salvo ajuste diverso entre o concedente e a rede de distribuição.

É vedado ao concedente: (a) vincular o concessionário a condições de subordinação (econômica, jurídica ou administrativa); (b) interferir na gestão dos negócios do concessionário; (c) impor aos concessionários encargos financeiros e prazos diferenciados daqueles que pessoalmente assumir perante esses mesmos contratantes.

O concessionário tem o dever de resguardar a integridade da marca e os interesses do concedente e da rede distribuidora, sendo-lhe vedado comercializar para revenda. O contrato o limita a realizar negócios tão somente com consumidores, salvo em vendas ao mercado externo e em operações entre concessionárias, nos limites de 15% e de 10% de sua quota, respectivamente, de caminhões e de veículos.

10.3.6. Convenções

Convenções são acordos com força de lei, celebrados por escrito, pelos quais se explicitam, declaram e disciplinam certas questões de interesse entre categorias econômicas de produtores e de distribuidores e entre um determinado produtor e sua rede de distribuidores.

Prevê a Lei n. 6.729/79 duas classes de convenções: (a) a de **categoria econômica**, firmada pelas entidades civis representativas dos interesses das categorias econômicas dos produtores e dos distribuidores de veículos, ou de entidade competente de âmbito nacional, para o fim de explicitar princípios e normas de seu interesse; declarar a entidade civil representativa da rede de distribuição; resolver questões por decisão arbitral e disciplinar assuntos pertinentes às convenções de marca; (b) a **de marca**, celebrada por cada um dos produtores com sua rede de distribuição, visando estabelecer normas e procedimentos relativos a diversos aspectos contratuais, entre os quais: o atendimento de veículos; o uso gratuito da marca; a inclusão de produtos lançados na vigência da concessão e de modalidades auxiliares de venda; a comercialização de outros bens e à prestação de outros serviços; fixação de área demarcada e distâncias mínimas; vendas de componentes em área demarcada diversa etc., previstos no art. 19 da Lei n. 6.729/79.

10.3.7. Formalidade contratual

O contrato de concessão exige forma escrita e deve ser padronizado para cada marca, devendo constar obrigatoriamente: produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, condições financeiras, organização administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão de obra especializada do concessionário.

O primeiro contrato pode ser celebrado por prazo indeterminado ou determinado. Esta última modalidade deverá ser contratada uma única vez, por período não inferior a cinco anos, sem prorrogações. Findo o período contratado, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado.

Quanto à motivação pela não prorrogação contratual, o legislador deu distintas soluções: se a iniciativa partir do distribuidor, o contrato extingue-se pelo decurso do prazo; nenhuma indenização é devida ao concedente. Diversamente, se a decisão for do concedente, cumpre-lhe: (a) readquirir do concessionário o estoque de veículos e os componentes novos, ainda acomodados em sua embalagem original, pelo preço de venda à rede de distribuição vigente na data da reaquisição; (b) comprar os bens

móveis dos estabelecimentos empresariais do distribuidor (equipamentos, máquinas, ferramental e instalações) pelo preço de mercado.

Observa-se, neste ponto, que, embora o art. 23, II, indique especificamente “os equipamentos, máquinas, ferramental e instalações à concessão”, o que se verifica é que o ressarcimento deve circunscrever-se a todos os bens móveis do estabelecimento empresarial, em razão da expressão inclusiva: “cuja aquisição o concedente determinara ou dela tivera ciência por escrito sem lhe fazer oposição imediata e documentada” e, ainda, de excluir tão somente “os imóveis do concessionário”.

10.3.8. Resolução de contrato

Além da expiração do prazo determinado, o contrato de concessão resolve-se por acordo das partes ou força maior e, ainda, por iniciativa da parte inocente, em razão de cessação de atividades, infração ao contrato, ao disposto em convenções e/ou a dispositivo previsto na Lei n. 6.729/79.

Nos casos em que se atribui culpa a um dos contratantes, a rescisão não ocorre imediatamente à constatação de uma simples ocorrência, exigindo o legislador que o contrato preveja a aplicação de penalidades gradativas que precedam à pena de resolução contratual. Como num regimento escolar em que as penas de advertência, repreensão e suspensão precedem à expulsão do aluno, nos contratos de concessão mercantil a resolução do contrato é medida derradeira, imposta somente depois que outras mais brandas (advertência, multa, redução de quotas etc.), previstas contratualmente, forem previamente aplicadas.

10.3.9. Indenizações nas resoluções de contrato

A rescisão contratual obriga a parte que deu causa a pagar indenização ao outro contratante, no prazo de sessenta dias contados da data da extinção da concessão, sujeitando-se, após o decurso desse período, ao pagamento de correção monetária e de juros legais desde o vencimento do débito.

Se o **concessionário** é culpado pela resolução do contrato deverá pagar ao concedente uma indenização correspondente a 5% do valor total das mercadorias

adquiridas desse mesmo concedente nos últimos quatro meses de contrato. Não há, neste caso, distinção quanto ao prazo contratual – determinado ou indeterminado.

Entretanto, se a culpa é atribuída ao **concedente**, cumpre distinguir.

Nos contratos com prazo *indeterminado*, o ressarcimento devido ao concessionário deve incluir os mencionados itens antes descritos para a hipótese de não prorrogação de contrato por prazo determinado (i.e., a reaquisição do estoque de veículos, implementos e componentes e a compra dos bens móveis constantes dos estabelecimentos empresariais do distribuidor), mais o valor correspondente a perdas e danos à razão de 4% do faturamento projetado para um período calculado caso a caso (dezoito meses fixos a que se somam mais três meses por quinquênio de vigência da concessão). Essa projeção tomará por base o valor corrigido monetariamente do faturamento de bens e serviços concernentes a concessão, que o concessionário tiver realizado nos dois anos anteriores à rescisão.

Essas indenizações não excluem outras que forem ajustadas entre o produtor e a sua rede de distribuição.

Nos contratos com prazo *determinado*, em regra a indenização será calculada sobre o faturamento projetado até o final do contrato, observando-se, contudo, a proporcionalidade para os contratos que não alcançaram dois anos de vigência: neste caso a projeção tomará por base o faturamento até então realizado.

Se outras reparações foram ajustadas pelas partes, o concedente deverá satisfazer as vincendas até o termo final do contrato rescindido.

Capítulo 11

FRANQUIA (FRANCHISING)

Sumário: 11.1. Origens e evolução. 11.2. Função e classificação. 11.3. Definição legal, noções e modalidades. 11.4. Natureza do contrato de franquia. 11.5. Formação e elementos do contrato. 11.6. Pré-contrato e contrato de *pilotage*. 11.7. Circular de oferta de franquia. 11.8. Extinção do contrato.

11.1. Origens e evolução

A doutrina é unânime quanto à origem norte-americana do contrato de franquia, indicando, contudo, distintas datas para seu nascimento. Maria de Fátima Ribeiro, docente da Faculdade de Direito da UCP (Porto), em Portugal, cita o período de reconstrução da economia dos Estados Unidos como sendo o de seu provável aparecimento e, mais especificamente, por volta de 1892, pela indústria *Singer Sewing Machine Company* (2001:12):

“Terá surgido em consequência da impossibilidade de os industriais nortistas expandirem as suas atividades para o oeste e o sul do país mediante atuação direta e capitais próprios. Então, os comerciantes locais terão arriscado os seus parcos capitais na venda de produtos que ostentavam marcas prestigiadas e reconhecidas pelos consumidores”.

A falta de capital inicial para o investimento, a pouca experiência dos candidatos dispostos a se estabelecer no ramo de vendas e a possibilidade de se montar rapidamente uma rede comercial foram os impulsionadores dessa nova modalidade de sistema de distribuição de um produto de prestígio entre os consumidores.

Concordam com essa afirmação as exposições que fazem Esperanza Gallego Sánchez, citada por Maria de Fátima Ribeiro, e, entre nós, Fran Martins, ao revelarem o grande período de desenvolvimento da atividade.

Afirma Gallego Sánchez, citado por Fátima Ribeiro (2001:13), que “a verdadeira expansão parece ter-se produzido após a II Guerra Mundial, pois este sistema converteu-se em alternativa eficaz para os soldados desmobilizados que, se bem que carecessem de formação técnica necessária para iniciar uma atividade empresarial, dispunham de um pequeno capital desejosos de investir; e também para as pequenas e médias empresas já estabelecidas cuja expansão comercial, ante o perigo de absorção por parte das grandes *ententes*, estava tolhida pela escassez de recursos financeiros”.

Fran Martins (1993:577) relata que “depois da Segunda Guerra Mundial, quando inúmeras pessoas, desmobilizadas de suas atividades ou nos campos de batalha ou nas indústrias de guerra, procuravam novas oportunidades para firmar-se economicamente. Para aproveitar esse material humano na expansão dos seus negócios, várias empresas descobriram um modo de ligar esses elementos aos seus empreendimentos, passando a oferecer *franquia* (*franchising*) aos que desejam dedicar-se a esse ramo de atividades”.

Inicialmente, portanto, o incentivo para o novel empreendedor era o *prestígio da marca* de um determinado produto, cujo uso lhe era facultado por contrato pelo fabricante, abrindo largo campo de distribuição junto a uma clientela já satisfeita com a qualidade dos produtos que ostentam aquela identificação.

A complexidade da vida moderna e os desafios de um mercado globalizado contribuíram para o aprimoramento e sofisticação desse contrato, capaz de atrair cada vez mais um grande número de pessoas interessadas em atuar nesse segmento, como franqueador ou como franqueado.

Fátima Ribeiro (2001:18-24) destaca os pontos de interesse: (a) o franqueador transfere o custo de pesados investimentos ao franqueado, na medida em que este fica responsável pela montagem e manutenção do ponto de venda e, além disso, é beneficiado pela difusão de sua marca que o crescimento da rede de franqueados possibilita; (b) o franqueado, por sua vez, vê a perspectiva de fazer crescer sua empresa pelo uso de uma marca de prestígio, integrando uma rede com produtos conhecidos e bem aceitos pelo mercado e desfrutando de “uma clientela preexistente ou potencialmente existente para aquela marca” (2001:22).

O consumidor (Fátima Ribeiro, 2001:25-26) é igualmente beneficiado pelos resultados de uma boa parceria entre franqueador e franqueado porque estes lhe dão acesso a inúmeros pontos de venda, propiciam aumento da qualidade de bens ou serviços prestados e reduzem preços. Basta, por exemplo, conhecer uma loja de uma rede de comércio de roupas ou de alimentos para saber o que esperar quanto ao atendimento, qualidade e variedade de determinado produto que estamos acostumados a vestir ou comer.

António Menezes Cordeiro (2003:516) atribui o êxito econômico da franquía a três fatores: “possibilidades abertas pela publicidade, no tocante à divulgação de marcas e de estilo de vida; mobilidade crescente dos consumidores, que facilita uma oferta uniforme de bens; aumento de seus rendimentos”.

Há, é claro, pontos amplamente desfavoráveis, não sendo necessários maiores esforços intelectuais para deduzir a extensão dos estragos na imagem de uma marca pelo gerenciamento desastroso do franqueador ou mesmo de um integrante de sua rede. Numa rede de alimentos, a falta de higiene num dos restaurantes pode contaminar a imagem de todos os outros franqueados; a falência do franqueador opera desastre financeiro como por efeito dominó; uma notícia desabonadora sobre um produto afeta interesses de inúmeros empresários autorizados a distribuí-lo etc.

11.2. Função e classificação

Quanto à função econômica que desempenham, em qual categoria jurídica se insere o contrato de franquía?

Fábio Ulhoa Coelho (2016:104) denomina os contratos que instrumentalizam o escoamento de mercadorias pela rubrica “contratos de colaboração” e distingue, entre os assim classificados, duas outras subespécies: (a) os contratos de **distribuição-intermediação**, caracterizados pela operação de compra de mercadorias por parte de um empresário em condições especiais de outro empresário, denominado distribuidor; (b) os contratos de **distribuição-aproximação**, nos quais um dos empresários contratantes tem a tarefa de buscar outros empresários interessados no produto distribuído pelo fornecedor.

A franquia seria, nesse modelo classificatório, um contrato de colaboração, na modalidade “distribuição-intermediação”.

A dificuldade, contudo, dessa classificação estaria no fato de que nem sempre o franqueado adquire mercadorias do franqueador, podendo revelar-se simplesmente pela obrigação de cumprir certos requisitos instituídos pelo franqueador. Veja-se, por exemplo, contrato em que as mercadorias podem ser adquiridas de fornecedores diversos (a franquia de um sistema de supermercados), obrigando-se o franqueado a respeitar certas regras de organização interna das gôndolas, visualização dos produtos, variedade de marcas oferecidas, limitações quanto ao número de artigos disponibilizados etc. O que o franqueador disponibiliza, neste caso, é sua concepção de como se deve dar a oferta de venda ao consumidor.

Maria de Fátima Ribeiro elucida assim essa questão (2001:46): “[...] embora o contrato de franquia possa prever a venda de produtos pelo franqueador ao franqueado, para que este os coloque no mercado (situação em que o contrato cumprirá uma função distributiva específica), esse não é um elemento essencial do contrato de franquia – nem aí ele será ‘um mero contrato de distribuição’. De uma forma mais genérica, o que está em causa no contrato de franquia é não a distribuição de produtos/serviços do franqueador para o consumidor através do franqueado, mas, antes, o recurso a esse franqueado para que coloque no mercado esses produtos/serviços *concebidos* pelo franqueador, da forma por este indicada (ou seja, tal como foi concebido pelo franqueador)”.

A função econômica do contrato de franquia, neste caso, encontra-se centrada em um modelo de *distribuição* de produtos ou de serviços, concebido pelo franqueador, no qual se incluem, necessariamente, conhecimento técnico e treinamento. Este modelo é facilmente reconhecido pelo consumidor pelos sinais distintivos licenciados pelo franqueador.

11.3. Definição legal, noções e modalidades

A Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia Empresarial – LFE) dispôs sobre o contrato de franquia e o definiu em seu art. 2º: “sistema pelo qual um

franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.

Pela definição, o contrato de franquia envolve distribuição de produtos ou serviços, cessão de uso de marcas, registros e/ou patentes, bem como prestação sucessiva e continuada desses recursos, cumulada ou não com o direito de uso de tecnologias relacionadas à administração do negócio e de sistema operacional. Cabe ao franqueado pagar o franqueador pelo uso desses recursos.

De forma resumida, teríamos, assim, o seguinte quadro:

FRANQUEADOR	FRANQUEADO
Oferece, de forma continuada e sucessiva: – licença de uso de direitos de propriedade industrial; – distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços. Cumulativamente ou não, com serviços de: – tecnologia na implantação; – tecnologia na administração da empresa; – sistema operacional adequado à organização da atividade empresarial.	⇒ Recebe, para expansão de sua empresa, esses recursos.
Recebe remuneração (<i>royalties</i>) do franqueado.	⇐ Paga remuneração (<i>royalties</i>) ao franqueador. Obriga-se a respeitar certas regras fixadas pelo franqueador, durante o período de franquia.

Na expressão direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio encontram-se os serviços de organização empresarial que, por sua vez, podem ser divididos em áreas distintas, conforme identificadas pela Ciência da

Administração, tais como recursos humanos, recursos materiais e patrimoniais, logística, mercadologia etc.

A definição legal brasileira, embora não seja perfeita por não distinguir as modalidades contratuais concebidas pelo mercado, permite compreender a realidade desse mercado.

A classificação aceita pelo Tribunal das Comunidades Europeias, no acórdão de 28 de janeiro de 1986, assim distingue as espécies de franquia (2003, 1:517):

- *a franquia de serviços*, pela qual o franqueado oferece um serviço sob a insígnia, o nome comercial ou mesmo a marca do franqueador, conformando-se com as diretrizes deste último;

- *a franquia de produção*, pela qual o próprio franqueado fabrica, segundo as indicações do franqueador, produtos que ele vende sob a marca deste;

- *a franquia de distribuição*, pela qual o franqueado se limita a vender certos produtos num armazém que usa a insígnia do franqueador.

Outra classificação, utilizada pela IFA (Beshell, 2000:2), distingue dois tipos de franquia: a de distribuição de produtos (*product franchises*) e a de formato negocial (*business format franchise* ou *package franchise*), identificando a primeira como a que o franqueador disponibiliza suas licenças de propriedade industrial e a segunda, franquia de negócio, aquela em que o uso inclui um método completo de condução da atividade empresarial. Exemplos da primeira seriam a Pepsi, a Exxon e a Ford Motor Company e, da segunda, uma variedade de empresas de restaurantes, *fast food*, locadoras de automóveis etc. Essa classificação, sobretudo quanto à primeira modalidade, conforme adverte Maria de Fátima Ribeiro (2001:228), traz a “dificuldade em demarcar este eventual tipo de franquia de outros contratos, como o de concessão comercial”.

Paulo Sérgio Restiffe (2006:330), explorando as relações entre as partes contratantes, concebe quatro modalidades: (a) **franquia de marca**, em que os produtos do fornecedor somente são encontrados nos estabelecimentos franqueados; (b) **franquia de produto**, utilizada como instrumentos de distribuição pelo franqueado

a outras revendas; (c) **franquia de conversão**, caracterizada pela “transformação de negócios já existentes em franquias de determinada marca”; (d) **franquia de negócio** ou empresarial, a acima descrita (de formato comercial) na classificação da IFA.

Atentamos para a realidade dos negócios de franquia: nem sempre haverá distribuição de produtos ou de serviços *do franqueador*, podendo revelar-se na assessoria técnica e imposição ao franqueado na distribuição de produtos e/ou serviços previstos no contrato, sob a diretriz do franqueador.

11.4. Natureza do contrato de franquia

O contrato de franquia é de natureza bilateral: um dos contratantes obriga-se a fornecer, entre outros recursos, produtos, uso de tecnologia, uso de marcas e patentes, prestação de serviços etc., dependendo da modalidade; cabe ao outro contratante pagar remuneração por esses direitos, cessões e serviços, obedecendo a certas regras rígidas no exercício de sua atividade.

É, também, contrato oneroso, de execução continuada, atípico e, para obter efeito em relação a terceiros, exige forma escrita e registro especial.

A atipicidade, não obstante sua previsão legal, decorre do fato de a Lei n. 8.955/94 não ter definido direitos e deveres das partes contratantes, conforme anota Fábio Ulhoa Coelho (2016, 1:160): “A lei brasileira sobre franquias não confere tipicidade ao contrato: prevalecem entre franqueador e franqueado as condições, termos, encargos, garantias e obrigações exclusivamente previstos no instrumento contratual entre eles firmado. Procura, apenas, a lei assegurar ao franqueado o amplo acesso às informações indispensáveis à ponderação das vantagens e desvantagens relacionadas ao ingresso em determinada rede de franquia”.

A validade das cláusulas entre as partes celebrantes é decorrência da exigência de ser sempre escrito e assinado na presença de duas testemunhas (LFE, art. 6º). Em outras palavras, para surtir efeito entre os contratantes, não há necessidade de seu registro em cartório ou em órgão administrativo. Contudo, no tocante à produção de efeitos em relação a terceiros, exige a Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96 art. 211) o registro do contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

11.5. Formação e elementos do contrato

Para a formação do contrato de franquia exige-se:

a) Quanto às partes

A presença de dois contratantes, de um lado o franqueador, ou concedente, empresário que detém a fabricação, distribuição ou licenciamento do produto, *know-how*, tecnologia, serviço ou marca, e, de outro, o franqueado, empresário que se dispõe a pagar pelo direito de usar esses recursos.

b) Quanto ao dever de informação

Obrigações de o franqueador fornecer uma Circular de Oferta de Franquia ao interessado em tornar-se franqueado, por escrito e em linguagem clara e acessível, dez dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa, contendo as informações previstas no art. 3º da LFE, fazendo acompanhar modelo de contrato-padrão (item XV);

c) Quanto à forma

A celebração por escrito⁷⁵, assinado na presença de duas testemunhas (LFE, art. 6º).

É comum incluir cláusulas que obrigue o franqueador a disponibilizar, entre outros serviços e produtos:

- licença de uso da marca e de sinais distintivos;
- *know-how*;
- assistência técnica;
- limitação territorial, para evitar a concorrência entre franqueados;
- tecnologia na administração do negócio nas áreas de administração contábil, financeira, recursos humanos, recursos patrimoniais e materiais etc.;
- reaquisição de estoque, quando a distribuição envolver produtos do franqueador;
- treinamento de funcionários do franqueado;

- assessoria na instalação do estabelecimento empresarial do franqueado;
- assistência na logística de distribuição;
- divulgação publicitária da rede e marcas.

Para o franqueado, em regra impõem-se, além do pagamento de remuneração, outras tantas obrigações, entre as quais destacam-se:

- a obrigação de usar a marca, os sinais distintivos e o conhecimento técnico transmitido pelo franqueador;
- permitir a fiscalização do andamento das atividades pelo franqueador;
- limitação territorial;
- uso de determinados padrões arquitetônicos na fachada e na decoração do estabelecimento;
- pessoal uniformizado segundo padrões identificadores da marca ou rede;
- fixação de estoques mínimos;
- cláusula de sigilo sobre os métodos e segredos do negócio;
- participação nas despesas publicitárias;
- tabelamento de preços dos produtos e serviços comercializados;
- cláusula de não concorrência (veja no v. 1 desta obra o item 6.9);
- cláusula de eleição de foro;
- restrição à atividade no período subsequente à extinção do contrato;
- adesão a estatuto próprio quanto à ética negocial, higienização do ambiente, relacionamento com a clientela etc.

11.6. Pré-contrato e contrato de *pilotage*

Temendo os riscos do negócio ou procurando inteirar-se quanto ao funcionamento da franquia, as partes podem optar pela convenção de um pré-contrato ou, ainda, de um contrato de *pilotage*.

Consiste o pré-contrato no acordo entre o franqueador e o interessado, em que se estabelece certo prazo de experiência, em que o candidato a franqueado exercerá

plena ou parcialmente as atividades oferecidas, pagando certa prestação pecuniária ao franqueador e comprometendo-se a, finda a relação, optar pela celebração do contrato definitivo ou dar por encerrada a relação, obrigando-se, neste caso, a conservar sigilo a respeito das informações recebidas e a não se utilizar da tecnologia adquirida em sua atividade empresarial.

Contrato de *pilotage*, literalmente pilotagem, conforme define Maria de Fátima Ribeiro (2001:238), “é a convenção pela qual o hipotético futuro franqueador vai confiar a um terceiro a tarefa de experimentar o projeto de franquia, em vez de o fazer diretamente, através de unidades-piloto detidas pela sua própria empresa. Aquele que vai ser o responsável pela experimentação prática, nos planos técnico, comercial e financeiro, do objeto da franquia, suportando os riscos dessa experiência em troca de uma contrapartida financeira que lhe atribui o candidato a franqueador. Aqui o terceiro vai ser um ‘laboratório de ensaio’”.

11.7. Circular de oferta de franquia

Entre as exigências para a formação do contrato encontra-se a obrigação de o franqueador fornecer uma Circular de Oferta de Franquia (COF) dez dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato, acompanhada do modelo do contrato-padrão ou, quando for oferecida a modalidade, do pré-contrato-padrão.

Universalmente exigida, a Circular de Oferta de Franquia adota em outros países procedimentos distintos sob rubricas e exigências semelhantes.

Nos Estados Unidos, lei federal determina que o franqueador deve dar conhecimento ao interessado desde o primeiro encontro, mediante entrega de um documento preliminar (*basic disclosure document*). A circular completa é denominada UFOC – *Uniform Franchise Offering Circular*.

Na França, a Lei n. 89-1008, de 31 de dezembro de 1989, conhecida por “Loi Doubin”, e o Decreto n. 91-337, de 4 de abril de 1991, que a regulamenta, exigem que o franqueador redija e entregue ao interessado, até vinte dias antes da celebração do contrato, “un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause”, isto é, “um documento contendo informações

sinceras que permitam seu ingresso (no sistema de franquia) com conhecimento de causa”.

Se o franqueador não demonstrar ter entregue a circular de oferta ao interessado, no prazo determinado pelo legislador brasileiro, o franqueado pode requerer a anulabilidade do contrato assinado pelas partes, exigindo a devolução das quantias pagas a título de taxa de filiação e de *royalties*, devidamente atualizadas, acrescidas de indenização pelos danos sofridos.

O COF pode ser apreciado sob cinco aspectos: (a) dever de informação sobre o franqueador e sua rede, relativa à imagem e realidade financeira da franquadora; (b) dever de identificação integral do objeto contratado; (c) dever de informação sobre a qualificação exigida do franqueado: características e comportamentos esperados do franqueado; (d) dever de informação sobre os encargos contratuais; e (e) dever de explicitar a extensão territorial e o regime de exclusividade.

ITEM	INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS INDICADAS NO ART. 3º DA LEI N. 8.955/94
Imagem e realidade financeira da franquadora: diz respeito à franquadora, sua rede e higidez financeira.	DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE O FRANQUEADOR E SUA REDE Os incisos I, II, III e IX do art. 3º da Lei n. 8.955/94 dizem respeito à segurança financeira do contrato de franquia. A exigência de informações completas sobre a higidez da rede e da franquadora pode ser agrupada sob a denominação comum dever de adequada informação simétrica e completa sobre o franqueador e sua rede e inclui: • histórico resumido, forma societária e nome completo ou empresarial do franqueador e de todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e endereço (art. 3º, I); • balanços de demonstrações financeiras da franquadora relativos aos dois últimos exercícios (art. 3º, II); • indicação das pendências judiciais envolvendo franqueador, empresas controladoras e titulares das marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia (art. 3º, III); • relação da rede (franqueados, subfranqueados e subfranqueadores) contendo os nomes completos dos atuais e daqueles que se retiraram nos últimos 12 meses (art. 3º, IX).

Quanto ao objeto (ou produto) contratado.	DEVER DE IDENTIFICAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO CONTRATADO Os incisos IV, XII e XIII referem-se ao objeto da contratação. Não há um padrão de cláusulas possíveis de ser contratadas, diferenciando-se os contratos pela diversidade de recursos oferecidos aos franqueados, uns mais extensos, outros mais restritivos, cabendo ao franqueador descrever honestamente o quanto propõe a sua rede de franqueados, possibilitando uma avaliação correta por parte dos interessados, permitindo-lhe equacionar os riscos e as possibilidades de lucros: • descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado (art. 3º, IV); • indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se refere à supervisão da rede, serviços de orientação e outros prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento de funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e <i>layout</i> e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (art. 3º, XII); • situação das marcas ou patentes perante o órgão de registro (INPI) (art. 3º, XIII).
Quanto às características e comportamento esperado do franqueado, durante e depois da extinção do contrato.	DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIFICAÇÃO EXIGIDA FRANQUEADO O sucesso da franquia não depende isoladamente de aspectos subjetivos do franqueador (sua higidez financeira e solidez de seu negócio) ou unicamente de aspectos objetivos do produto oferecido, sendo indispensável que o franqueado “se encaixe” no perfil exigido para o empreendimento. As regras dos incisos V, VI e XIV dizem respeito a essas exigências: • perfil do que se convencionou “franqueado ideal”, isto é, as qualidades e requisitos obrigatórios ou desejados para o exercício da atividade, bem como quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio (art. 3º, V e VII); • situação do franqueado após a expiração do contrato, quanto ao segredo de indústria e restrições concorrenciais (art. 3º, XIV).
Encargos: diz respeito ao custo efetivo do contrato.	DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE OS ENCARGOS • especificação de valores a ser disponibilizados, inclusive sobre as taxas periódicas, remunerações, instalações, aluguéis etc. (art. 3º, VII e VIII); • informações sobre a obrigação de o franqueado adquirir bens, produtos ou insumos (art. 3º, XI).
Quanto à extensão	DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO À EXCLUSIVIDADE TERRITÓRIO

territorial e exclusividade.	• especificação da zona de atendimento, da exclusividade ou não do franqueado (art. 3º, X).
-------------------------------------	---

As informações integrantes do COF podem, ainda, ser agrupadas segundo a Teoria da Empresa, o que facilita sua compreensão, por dizerem respeito ao perfil subjetivo, ao perfil objetivo e ao perfil funcional, isto é, a certas qualidades exigidas ou esperadas das partes envolvidas (aspecto subjetivo); o objeto do contrato (aspecto objetivo) e o dia a dia da empresa, a atividade empresarial propriamente dita (aspecto funcional):

Perfil subjetivo	Quanto à pessoa do franqueador: dever de informação sobre o franqueador e sua rede (incisos I, II, III e IX); Quanto à pessoa do franqueado: dever de informação sobre a qualificação exigida do franqueado (incisos V, VII e XIV).
Perfil objetivo	Quanto ao objeto do contrato (incisos IV, XII e XIII).
Perfil funcional	Quanto aos encargos contratuais: obrigações sucessivas durante o exercício da atividade (incisos VII, VIII e IX); Quanto à limitação territorial e exclusividade do exercício empresarial (inciso X).

11.8. Extinção do contrato

O contrato de franquia extingue-se pelos seguintes motivos:

a) em razão do **decurso do prazo convencionado**, quando se tratar de contrato com cláusula de prazo determinado;

b) em razão de **distrato**, isto é, pelo acordo de vontade entre as partes contratantes estabelecendo sua extinção. As partes resolvem extinguir a parceria contratual, podendo assumir ou eximir-se reciprocamente de encargos e obrigações adicionais;

c) por **justa causa**, alegada por uma das partes contratantes: aquele que alegar justa causa para rescisão assume os riscos de sua iniciativa, isto é, deverá demonstrá-la em juízo, sob pena de sofrer as consequências contratuais, em geral consistentes no pagamento de pesadas multas e na indenização da parte;

d) por vontade unilateral, **sem justa causa**, quando o contrato assim o permitir⁷⁶ (em geral com a seguinte redação: “este contrato poderá ser denunciado, sem ônus, a qualquer tempo pela parte que não mais se interessar com o seu prosseguimento, bastando a notificação à parte contrária mediante carta registrada, com antecedência de trinta dias”). Os riscos dessa cláusula situam-se no campo dos investimentos realizados pelas partes para a efetivação da franquia: adequação do estabelecimento empresarial, locação de equipamentos, contratação de pessoal etc., motivos que sugerem certos cuidados na previsão de rescisão sem justa causa, sem imposição de encargos à parte que deu causa;

e) em virtude de **declaração judicial de anulabilidade**, como ocorre no caso de não demonstração de entrega da COF e de constatação de falsidade nas declarações nela contidas, conforme dispõem o parágrafo único do art. 4º e o art. 7º da LFE.

Capítulo 12

MANDATO

Sumário: 12.1. Definição legal. 12.2. Características do mandato. 12.3. Requisitos subjetivos do contrato. 12.4. Requisitos objetivos do contrato. 12.5. Requisitos formais do contrato. 12.6. Substabelecimento. 12.7. Direitos e obrigações dos contratantes. 12.8. Efeitos do mandato em relação a terceiros – excesso e aparência. 12.9. Extinção do contrato.

12.1. Definição legal

No contrato de mandato, o mandatário recebe poderes de outrem para, em seu nome, praticar atos ou administrar seus interesses. Completa essa definição legal a expressão final do art. 653 do Código Civil: “A procuração é instrumento do mandato”. Observação necessária porque, desde logo, se separam duas realidades jurídicas distintas: mandato e procuração. A primeira identifica a relação contratual e a segunda, o instrumento do ato jurídico praticado pelo representado ao conceder poderes a seu representante.

Verificamos, assim, tecnicamente, o mecanismo do contrato de mandato: (1) alguém outorga poderes, (2) instrumentalizando-os em uma procuração, (3) dando origem a um contrato entre elas denominado mandato com representação.

Antes, portanto, de se produzir o contrato, há outros dois atos que o antecedem: o primeiro é um ato jurídico unilateral praticado pelo mandante ou representado, não há um nome jurídico próprio para esse ato e, erroneamente, se convencionou chamar *mandato*, criando confusão com o contrato ora em estudo⁷⁷; o segundo é instrumento do ato jurídico unilateral e o terceiro é contrato que se firma entre mandante (credor) e mandatário (devedor).

O mandato pressupõe *representação*, mas essas duas figuras são distintas⁷⁸:

mandato, o contrato e *representação*, instituto mais amplo que abrange a representação legal, a judicial e a voluntária (CC, arts. 115-120). O contrato de mandato é uma das formas da representação, mas não é a única, pois há pessoas que representam alguém por força de lei ou ato judicial.

12.2. Características do mandato

O contrato de mandato é sempre consensual, pessoal, preparatório de outros negócios jurídicos e pode classificar-se como unilateral, bilateral ou bilateral imperfeito. É gratuito em regra, podendo também celebrar-se de forma onerosa.

Consensual. Para a celebração do mandato exige-se a manifestação de vontades do mandante e do mandatário. Ao praticar o ato unilateral de mandato, o mandante aguarda a aceitação por parte do mandatário que, recusando, não se vincula, não se estabelecendo o contrato. O mandatário manifesta sua aceitação de forma expressa ou tácita, revelando-se esta segunda modalidade pelo começo da execução do contrato (CC, art. 659).

Pessoal. Alguém recebe de outrem poderes. Forma-se no contrato de mandato uma relação entre pessoas, *intuitu personae*. A substituição do mandatário somente pode ocorrer com a autorização do mandante. Presume-se que a escolha se dá em razão das qualidades pessoais do mandatário: idoneidade, moral ou financeira, capacidade técnica, preparo especial para a tarefa, confiabilidade, enfim atributos próprios da personalidade da pessoa a quem o mandante atribui poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

Preparatório. É de Clóvis Beviláqua (1975, 2:400) a observação: “o mandato é um contrato preparatório; habilita o mandatário a praticar certos atos jurídicos que não estão contidos nele. No mandato para vender, para pleitear, para representar o herdeiro, os atos de venda, da demanda, do inventário não estão contidos no mandato, são-lhe externos. O mandato confere poderes para executá-los”.

Unilateral, bilateral, bilateral imperfeito. A doutrina em geral diverge quanto a esse aspecto. Grande parte da doutrina prefere classificar o contrato de mútuo como sendo unilateral e bilateral imperfeito⁷⁹. Outra parte o classifica como contrato

bilateral ou bilateral imperfeito⁸⁰.

Serpa Lopes (1993:280) prefere concluir pela natureza biforme do mandato, declarando tratar-se de um “contrato unilateral, se convencionado gratuitamente, e bilateral, se estabelecida uma remuneração para o mandatário”, conclusão que Orlando Gomes (2008:426) não aceita em sua totalidade, sob o lúcido argumento de que o contrato é unilateral, “mas pode converter-se em contrato *bilateral*, conservando-se *gratuito*, se no curso de sua execução nascer, para o mandatário, um direito de crédito contra o mandante. Será, então, *contrato bilateral imperfeito*”. E, completa: “em algumas legislações admite-se, ademais, que seja *bilateral perfeito* desde a formação. Sê-lo-á se não *for gratuito*, pois também do lado do mandante haverá obrigações”.

Maria Helena Diniz (2007, 3:370) é peremptória e entende que o mandato é sempre *bilateral*, “por gerar deveres tanto para o mandatário (CC, art. 667) quanto para o mandante (CC, art. 675) accidental e posteriormente à execução do mandato”.

Há, portanto, séria divergência, que emerge de um simples exame de posições doutrinárias.

A razão de tão grande elasticidade na classificação é de fácil entendimento e repousa na perspectiva do objeto de estudo pelo doutrinador.

Nos contratos bilaterais ou sinalagmáticos, “nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (CC, art. 476).

Neste sentido, o mandato gratuito é unilateral porque não há na gênese do contrato obrigações por parte do mandante, somente do mandatário, isto é, o mandante não pode opor-se a cumprir sua parte (porque nada deve) enquanto o mandatário não cumprir a sua.

Contudo, há outra noção, doutrinária, de contrato bilateral sobre as quais Orlando Gomes (2008:85) assim se expressa: “Não é pacífica a noção de *contrato bilateral*. Para alguns, assim deve qualificar-se todo contrato que produz obrigações para as duas partes, enquanto para outros a sua característica é o *sinalagma*, isto é, a dependência recíproca das obrigações, razão por que preferem chamá-los

sinalagmáticos ou de *prestações correlatas*. Realmente, nesses contratos, uma obrigação é a causa, a razão de ser, o pressuposto da outra, verificando-se interdependência essencial entre as relações”.

Para Maria Helena Diniz (2007, 3:78) contrato bilateral é aquele “em que cada um dos contraentes é simultânea e reciprocamente credor e devedor do outro, pois produz direitos e obrigações para ambos [...]”.

Se a contraprestação simultânea for essencial à classificação do contrato como bilateral, então o *mandato oneroso* é bilateral e o *gratuito*, unilateral. Neste último caso, a transmutação para bilateral somente ocorre se, no curso da execução do contrato gratuito, surgir causa suficiente a tornar o mandante devedor do mandatário. Se, entretanto, a simples existência de direitos e obrigações para ambos os contratantes, sem a exigência de que guardem dependência recíproca, então o mandato será sempre contrato bilateral, pouco importando se gratuito ou oneroso.

Uma indagação pertinente a esta altura: o contrato de mandato para a realização de negócios empresariais é unilateral ou bilateral? Importa, neste caso, para a resposta, a posição doutrinária quanto à classificação à bilateralidade?

O estudioso atento encontrará a resposta após a leitura do próximo tópico.

Gratuito ou oneroso. A regra geral é a gratuidade, que se presume “quando não houver sido estipulada retribuição”, conforme redação do art. 658 do Código Civil que, entretanto, completa o raciocínio jurídico abrindo exceção à presunção: “exceto se o seu objeto corresponder ao daquele que o mandatário trata por ofício ou profissional lucrativa”.

Há, nesse dispositivo, presunção com duas frentes: uma aplicável na ausência de identidade entre o objeto do contrato e a profissão ou o ofício do mandatário e outra quando presente essa identidade.

É o caso, por exemplo, do mandato judicial outorgado a advogado que, em razão de sua profissão, aceita ser mandatário de seus clientes. Presume-se que o faça em razão de seu grau e, portanto, visando obter os frutos de seu trabalho. Neste caso a onerosidade é presumida, salvo se coisa diversa for estipulada.

Se o mandatário não tem por ofício ou profissão a prática do objeto contratual – por exemplo, peço ao vizinho agrônomo que, em sua viagem a São Paulo, faça a minha matrícula no curso de Direito, outorgando-lhe poderes para esse ato –, presume-se, na falta de estipulação, que o contrato é gratuito.

Refletindo sobre a expressão legal “ofício ou profissão”, podemos concluir que o mandato empresarial, isto é, o que tem por objeto negócio empresarial, é, em decorrência de sua natureza, sempre oneroso, salvo se os contratantes expressamente acordaram a gratuidade.

12.3. Requisitos subjetivos do contrato

Como todo contrato, para que a manifestação das partes seja válida, há necessidade da presença dos requisitos *subjetivos*, relativos às pessoas que o praticam, *objetivos* – objeto lícito e possível – e *formais* concernentes à forma utilizada pelos contratantes. São estes requisitos básicos.

Quanto ao primeiro requisito – de natureza subjetiva –, cinco questões devem ser enfrentadas no estudo dos contratos empresariais: a capacidade dos contratantes, os impedimentos em razão de outras condições subjetivas, a outorga por empresário falido, os efeitos do mandato plural, conferido a mais de um mandatário, e, ainda, sua distinção com o mandato coletivo.

a) Capacidade

Os incapazes são representados pelos pais ou responsáveis legais, em todos os atos legais, e, portanto, não participam pessoalmente dos atos jurídicos e, assim, lhes é vedado outorgar procuração ou figurar como mandatários.

Os relativamente incapazes participam pessoalmente do ato, mas, quando mandantes, são assistidos por seus pais ou responsáveis, exigindo-se, ainda, *contrario sensu* do disposto no art. 654 do Código Civil (“Todas as pessoas *capazes* são aptas para dar procuração mediante *instrumento particular* [...]”), que o instrumento se faça por escritura pública. Exceção feita à outorga de procuração judicial que, por força do disposto no art. 692 do Código Civil, é regida pelo art. 105

do Código de Processo Civil de 2015, que não faz a distinção, sobrevivendo o entendimento jurisprudencial no sentido de dar validade à procuração *ad judicium* por instrumento particular outorgada por menor púbere, devidamente assistido por seu representante legal⁸¹.

A assistência desaparece se os relativamente incapazes figuram no ato como *mandatários*, respondendo, contudo, pessoalmente o mandante pelos atos praticados pelo menor em relação ao terceiro. Aplica-se aqui o princípio geral dos negócios jurídicos (CC, art. 105), segundo o qual “a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio [...]”.

b) Impedimentos em razão de outras condições subjetivas

Maria Helena Diniz apresenta dois casos de *incapacidade* para o exercício do mandato, um dos quais de interesse empresarial. Refere-se à proibição contida no art. 199 do Decreto-lei n. 2.063, de 7 de março de 1940, que regulamenta sob novos moldes as operações de seguros privados e sua fiscalização. Dispõe esse artigo que “os acionistas brasileiros não poderão fazer-se representar nas reuniões de assembleia geral por mandatários estrangeiros”.

Trata-se de impedimento (e não incapacidade), restrito às sociedades por ações que tenham por objeto operações de seguros privados.

c) Empresários falidos

Em relação aos empresários falidos, algumas observações devem ser feitas: a) não cessam os poderes *outorgados* para realização de atos *não negociais* e os *recebidos* para execução de atos estranhos à matéria estranha à atividade empresarial, em datas anteriores à decretação da falência (LREF, art. 120, *caput* e § 2º); b) não cessam, tampouco, os *poderes ad judicium conferidos*, ainda não expressamente revogados pelo administrador judicial (LREF, art. 120, § 1º); c) a partir da decretação de sua falência, o devedor somente pode outorgar poderes, inclusive para ser representado no juízo falimentar, e para outros atos *pessoais*, desde que infensos aos efeitos falimentares (o que não ocorre com atos que tenham por objeto seu patrimônio).

d) Mandato plural

O instrumento de mandato pode ser plural e designar dois ou mais mandatários para o ato, indicando que cada um deles pode agir sozinho. Presume o legislador neste caso a existência de cláusula disjuntiva, isto é, que qualquer um dos mandatários poderá exercer os poderes outorgados (CC, art. 672). O mandato é denominado *solidário* ou *in solidum*.

O mandante, entretanto, pode delimitar a atuação dos mandatários, incluindo no instrumento instruções especiais:

(1) Cláusula conjuntiva: indica que os mandatários atuam em conjunto – o mandato será considerado *conjunto* ou *simultâneo*. O ato somente terá eficácia se todos os designados intervierem no momento de sua realização ou mesmo posteriormente, retroagindo os efeitos dessa ratificação àquela data;

(2) Cláusula distributiva singular: os atos que cada um deverá realizar são expressamente discriminados pelo mandante. O mandato contendo essa cláusula é denominado *fracionário*, *separado* ou *distributivo*;

(3) Cláusula distributiva sucessiva: competirá a cada um dos designados atuar na ordem da designação, substituindo o precedente na recusa ou na impossibilidade de o antecessor realizar o ato. Se não for estabelecida uma ordem pelo mandante, os designados atuarão na sequência em que seus nomes foram designados no instrumento. O mandato é conhecido como *sucessivo* ou *substitutivo*.

O estudo dos poderes conferidos a vários mandatários em instrumento único mostra sua importância em razão dos limites impostos à responsabilidade do mandatário perante o terceiro com quem contratar. Preceitua o art. 673 do Código Civil que “o terceiro, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário”, o que implica dizer que o terceiro deva esforçar-se em compreender com exatidão a extensão dos poderes conferidos pelo mandante à pessoa que se apresenta para, em seu nome, celebrar negócio. Embora o legislador tenha excetuado duas situações – *se* o mandatário prometeu ratificação do mandante ou *se* responsabilizou pessoalmente –,

haverá grande dificuldade de sua demonstração em juízo.

Em resumo:

ESPÉCIE	SUBESPÉCIE	CARACTERÍSTICA
Plural	Solidária (in <i>solidum</i>)	Na ausência de outra declaração expressa, qualquer mandatário poderá exercer individualmente os poderes outorgados.
	Conjunta simultânea ou	Para validade do ato todos os mandatários devem intervir ou, se não o fizerem, ratificar posteriormente o ato.
	Separada, fracionária distributiva ou	Atos diferentes são designados para cada um dos mandatários.
	Sucessiva substitutiva ou	O mandante estabelece uma ordem de substituição na recusa ou impedimento dos mandatários que, assim, atuarão sucessivamente.

e) Mandato coletivo

O termo “coletivo” refere-se à pluralidade de mandantes que outorgam poderes para a realização de negócio que lhes é comum. Pode existir, portanto, mandato coletivo e plural, referindo-se à pluralidade de mandantes e de mandatários.

No mandato coletivo os mandantes são solidariamente responsáveis para com o mandatário (ou mandatários) por “todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo direito regressivo, pelas quantias que pagar, contra os outros mandantes” (CC, art. 680).

12.4. Requisitos objetivos do contrato

Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. A noção de licitude, possibilidade e determinação foi estudada no capítulo “Da Constituição das Sociedades em Geral – Aspectos Comuns” (v. v. 1 desta obra, itens 17.6 e 17.7), devendo ser lembrado que “lícito é tudo aquilo que não contraria a lei e está conforme o ordenamento jurídico”; impossível é a prestação “irrealizável por

qualquer pessoa, ou insusceptível de determinação” (cf. Pereira, 1997, 1:311).

Em regra, todos os negócios jurídicos podem ser praticados por mandatário, com ou sem poderes especiais, conforme dispuser a lei. Há exceções e, por escolha do legislador, alguns atos exigem a intervenção pessoal do agente, como, por exemplo, o exercício do voto em eleições da organização política do País, mas não em organizações privadas, que, entretanto, podem vedar seu uso para certos atos internos. Não há um critério único para a vedação, permitindo a lei a celebração do mandato para a prática de atos pessoais e solenes como o casamento (CC, arts. 1.525 e 1.542), mas não para certos atos patrimoniais perante o instituto de previdência social, como, por exemplo, a autorização de desbloqueio de valores para registro ou a averbação de contratos de empréstimo consignados em folha (Instrução Normativa n. 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008).

12.5. Requisitos formais do contrato

Forma não solene: como regra geral, não há forma especial nem solenidade na contratação. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito (CC, art. 656).

Como então conciliar a parte final do art. 653 (“A procuração é instrumento do mandato”) com a forma não escrita? A redação legal do art. 653 refere-se unicamente aos contratos escritos e introduz os dois artigos subsequentes que tratam especificamente da procuração. Esse regramento introdutório acerca da procuração tem caráter pedagógico e pretende distinguir, desde logo, o contrato de seu instrumento escrito. Superadas as distinções, o legislador a partir do art. 656 volta a tratar exclusivamente do contrato de mandato, não mais se referindo à procuração.

a) Forma especial

Embora ampla a liberdade formal de contratar, o mandante deve respeitar a forma especial quando esta for exigida. São exemplos, de interesse aos negócios empresariais:

- a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, em

que se exige mandato por *escrito público* (CC, art. 108).

- a exigência do art. 657 do Código Civil: o contrato de mandato será sempre escrito para a prática de *atos que só podem ser celebrados por escrito*, como a prestação de garantia pessoal ou o lançamento de assinatura em cambial (endosso, aceite, emissão de título de crédito, aval).

b) Conteúdo da procuração

Outro aspecto a não ser desconsiderado refere-se ao conteúdo dos instrumentos de mandato – particular e público. São essenciais ao particular (CC, art. 654, § 1º):

- a indicação do lugar onde foi passado;
- a qualificação dos contratantes – outorgante e outorgado;
- a data;
- o objetivo da outorga;
- a designação e a extensão dos poderes.

Para o instrumento público devem ser obedecidos os requisitos do art. 215 do Código Civil que se assemelham aos exigidos para o instrumento particular, respeitado o caráter genérico da redação utilizada pelo legislador civil em razão da multiplicidade de situações de seu emprego:

- a data e o lugar de sua realização;
- reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas;
- nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;
- manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes;
- referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;
- declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram;

- assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto, legal, encerrado o ato.

O idioma da redação de ambos os instrumentos é o nacional. Se originalmente a procuração foi escrita em outra língua, caberá ao interessado, que pretender fazer prova em juízo, providenciar sua versão por tradutor juramentado, devidamente inscrito na Junta Comercial do Estado. O instrumento público deve ser lavrado originalmente no vernáculo e se algum dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, o tradutor público ou, na sua falta, pessoa capacitada deverá ser chamado para servir de intérprete.

A importância da exigência quanto ao *objetivo* da outorga, traduzido pelo art. 215 do Código Civil por “manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes”, repousa no fato de o mandato firmado em termos gerais, isto é, sem discriminação de atos especiais, só conferir poderes de administração ordinária (CC, art. 661). São dessa natureza os que autorizam a gestão e a gerência de negócios, inclusive a conservação e proteção da coisa objeto do contrato.

Os atos de alienação ou imposição de ônus sobre a coisa ou, ainda, os relativos à transação exigem autorização específica.

Se a prática de atos em que deva figurar o mandatário exigir o de *firmar compromisso* em nome do mandante deverão constar do instrumento de mandato poderes específicos nesse sentido. A expressão “poder de firmar compromisso” significa que o mandatário está autorizado pelo mandante a aceitar, em acordo (judicial ou extrajudicial) ou em contrato em que deva intervir, a inclusão de cláusula que estipule sejam as controvérsias de cunho patrimonial submetidas à decisão de um árbitro (CC, arts. 851-853). Em outras palavras: sem que conste expressa disposição no instrumento de mandato o mandatário não pode firmar compromisso, conforme estabelece o art. 661, § 1º, do Código Civil: “o poder de transigir não importa o de firmar compromisso”. O texto legal é necessário porque inadvertidamente o mandatário poderia falsamente deduzir que entre os poderes gerais recebidos para transigir estariam incluídos os de concordar que eventuais litígios ou divergências viessem a ser resolvidos por terceiro (árbitro). O mesmo raciocínio vale para

qualquer outro contrato em que o mandatário deva intervir, o poder de *firmar compromisso* não está implícito no poder geral de contratar.

Quanto aos poderes conferidos – gerais ou especiais –, destacam-se que alguns aspectos relativos à atividade negocial são apresentados na legislação empresarial:

- **Poderes especiais:** permite-se às companhias abertas a emissão dos certificados de ações assinados por dois mandatários, desde que portadores de *poderes especiais* (LSA, art. 24, § 2º);

- **Representação sem mandato:** na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado, *independentemente de instrumento de procuração*, pela sociedade corretora ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores (LSA, art. 31, § 3º). Temos aqui um caso legal de *representação sem mandato*;

- **Poderes especiais presumidos:** o acionista residente ou domiciliado no exterior deve manter representante com poderes para receber citação, para os litígios relativos à sua condição de acionista. Dispõe o parágrafo único do art. 119 da LSA que “o exercício, no Brasil, de qualquer dos direitos de acionista, confere ao mandatário ou representante legal qualidade para receber citação judicial”, significando que o ato (de receber citação) é presumido e não precisa estar expresso no instrumento de mandato;

- **Poderes especiais exigidos:** exigência semelhante é feita no art. 217 do Código da Propriedade Industrial: “a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”. Aqui não há presunção e a falta de procurador acarreta perda de direitos do detentor de patente (CPI, art. 78, V), registro de desenho industrial (CPI, art. 119, IV) ou marca (CPI, art. 142, IV);

- **Qualidade do procurador e prazo de validade do instrumento:** na assembleia geral das sociedades por ações, o acionista pode ser representado por procurador, desde que constituído há menos de um ano e ostente uma das seguintes qualidades:

acionista, administrador da companhia ou advogado. Se a companhia for aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira. Nos fundos de investimento, os condôminos são representados pelo administrador de fundos (LSA, art. 126, § 1º);

• **Conteúdo da procuração para exercício de funções na sociedade por ações:** os administradores das companhias podem, se o estatuto não proibir, constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado (LSA, art. 146).

c) Reconhecimento de firma

Por fim, não integra o rol dos requisitos formais do instrumento, mas encontra-se no campo da faculdade do terceiro, com que o mandatário deverá tratar, a exigência do reconhecimento de firma.

12.6. Substabelecimento

Os poderes recebidos pelo mandatário podem ser substabelecidos a outros mandatários. Substabelecimento é, portanto, o ato jurídico pelo qual o mandatário transfere, em todo ou em parte, os poderes recebidos do mandante, reservando ou não iguais poderes para si.

As procurações em geral omitem qualquer indicação quanto ao substabelecimento e, podem, ainda, declarar expressamente que a permitem. Temos assim três situações, duas em que a vontade do mandante é expressa – proibir e permitir – e uma em que ele silenciou. Se há permissão ou silêncio o substabelecimento pode ser realizado pelo mandatário, sem que este incorra em qualquer falta.

O legislador traçou com minúcias a responsabilidade do mandatário pelos atos praticados nessas três situações.

Se a procuração contiver proibição expressa, o mandatário responde pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituído, mesmo quando provenientes de caso fortuito. Sua única defesa é demonstrar que “o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido substabelecimento” (CC, art. 667, § 1º).

Na outra extremidade encontra-se a situação de autorização expressa: o mandatário somente responde “se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele” (CC, art. 667, § 2º).

Na posição intermediária encontra-se a omissão de substabelecimento pelo mandante. Neste caso, o mandatário somente responde se o substabelecido proceder culposamente (CC, art. 667, § 4º).

Dessas situações, o mandante somente não se obriga perante terceiros, na primeira hipótese, isto é, se o instrumento de mandato contiver expressa proibição de substabelecimento e os atos forem praticados pelo substabelecido. Poderá, entretanto, se quiser, ratificar os atos, expressa ou tacitamente, quando praticar ato inequívoco nesse sentido.

Temos, assim, os graus de responsabilidade:

CLÁUSULA DE SUBSTABELECIMENTO	RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO PERANTE O MANDANTE	OBRIGAÇÕES DO MANDANTE PERANTE TERCEIRO
Proibição expressa	Responde pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituído, mesmo se provenientes de caso fortuito.	O mandante não se obriga.
Permissão expressa	Responde em dois casos: (a) se tiver agido com culpa na escolha (<i>in eligendo</i>); (b) se não seguiu as instruções recebidas.	O mandante se obriga perante terceiro com que o substabelecido contratar.
Omitida	Só responde se o substabelecido agiu com culpa.	O mandante se obriga perante terceiro com que o substabelecido contratar.

Quanto à forma do substabelecimento, o Código Civil é liberal: permite que se proceda mediante instrumento particular, mesmo nos casos em que a outorga de poderes ao mandatário ocorreu mediante instrumento público (CC, art. 655).

Por fim, cumpre anotar as formas de substabelecimento: *com* ou *sem reservas de*

poderes, indicando, no primeiro caso, que o mandatário pode, a qualquer tempo, reassumir os poderes que lhe foram conferidos pelo mandante e, no segundo, sua exoneração dos encargos recebidos.

12.7. Direitos e obrigações dos contratantes

Para efeito didático, é possível agrupar em *quatro*, como faz Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:316-320), as obrigações do mandante (satisfazer, adiantar, remunerar e ressarcir) e, em três, o número das do mandatário (aplicar – toda sua diligência, indenizar e dar contas).

O mandante deve *satisfazer* as obrigações assumidas em seu nome, *adiantar* as despesas de execução do mandato, *remunerar* o mandatário (quando o contrato for oneroso, como é a regra geral para os negócios empresariais) e *ressarcir* o mandatário pelas perdas e despesas havidas.

O mandatário deve *aplicar* toda diligência no cumprimento do mandato, *obedecendo* às instruções recebidas, *indenizar* o mandante pelos prejuízos causados e *dar contas* dos atos praticados.

Para melhor eficiência em sua compreensão, a matéria pode ser resumida em quadros:

OBRIGAÇÕES DO MANDANTE		
VERBO-- CHAVE	OBRIGAÇÕES	DISPOSITIVO
Satisfazer	Todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido. Essa obrigação inclui todos aqueles com quem o mandatário contratou, mesmo que este tenha contrariado suas instruções, sem, entretanto, exceder os limites do contrato.	CC, arts. 675 e 679.
Adiantar	A importância das despesas necessárias à execução do mandato, quando o mandatário lho pedir.	CC, art. 675.

Remunerar	No contrato oneroso, o quanto foi ajustado.	CC, art. 676.
Ressarcir	As despesas da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o efeito esperado, salvo se o mandatário agiu com culpa.	CC, art. 676.

OBRIGAÇÕES DO MANDATÁRIO		
VERBO- -CHAVE	OBRIGAÇÕES	DISPOSITIVO
Aplicar	Toda sua diligência habitual na execução do mandato, gênero de dever que inclui, entre outros, os seguintes: • Respeitar os limites do mandato; • Obedecer às instruções recebidas do mandante;	CC, art. 667.
	• Conservar e bem administrar a coisa objeto do contrato, até entrega ao mandante; • Zelar pelos fundos recebidos. Clóvis Beviláqua (1975, 2:416) assim se expressa acerca desta obrigação: “A primeira obrigação do mandatário é cumprir fielmente o mandato, seguindo as instruções do mandante e, sendo possível, mais vantajosamente ainda. Desta obrigação resulta a sua responsabilidade pelos prejuízos provenientes de sua culpa. O Código exige do mandatário que empregue na execução do mandato a sua diligência habitual, isto é, que trate do negócio, que lhe foi confiado, como se fosse seu, desde que seja um homem zeloso dos seus próprios interesses”.	
Indenizar	Qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer (ver quadro no item 12.6).	CC, art. 667.
Dar contas	O mandatário é obrigado a prestar contas de sua gerência, dever imposto a todo homem probo incumbido de administrar interesses alheios, que inclui: • Transferir as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja, sem compensar os prejuízos que causou com os proveitos que granjeou; • Pagar juros das somas que devia entregar ao mandante e, entretanto, empregou em proveito próprio. O termo inicial da fluência dos juros conta-se da data do desvio praticado;	CC, arts. 668, 669, 670, e LREF, art. 120.

• Em caso de falência do mandante, a prestação de contas de mandato para realização de negócios deverá ser feita no juízo falimentar, tão logo o mandatário tome conhecimento da decisão de quebra.	
---	--

Quanto aos direitos, esses emergem dos deveres impostos a cada um dos contratantes, v. g., se o mandante está obrigado a remunerar, então o mandatário tem direito de ser remunerado. Há, entretanto, um que se soma à prestação de reembolso devida pelo mandante: o direito de retenção sobre a coisa de que tenha posse em virtude do mandato, até se reembolsar de *tudo* o que for devido em consequência do mandato, isto é, a soma dos custos do encargo e da remuneração ajustada.

Se o mandante vier a ter sua falência decretada, cessa esse direito de retenção, devendo o mandatário entregar a coisa retida ao administrador judicial (LREF, art. 116, I), habilitando seu crédito no quadro geral, na classe dos créditos com privilégio especial (LREF, art. 83, IV, c).

12.8. Efeitos do mandato em relação a terceiros – excesso e aparência

Duas questões em relação aos terceiros com quem o mandatário contrata devem ser objeto de maior aprofundamento: a primeira refere-se ao excesso praticado pelo mandatário, de conhecimento do terceiro e, a segunda, a excesso ignorado pelo terceiro de boa-fé.

a) Excesso de mandato conhecido pelo terceiro

A regra geral, quanto às obrigações perante terceiros, é a que determina que o “mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário” (CC, art. 675), expressão legal qualificada pela oração subsequente “na conformidade do mandato conferido”.

Significa dizer que se a obrigação contraída não se encontra na conformidade do mandato, o mandante não responde pelo ato praticado, cabendo ao terceiro buscar junto ao mandatário a satisfação de seu direito ou convencer o mandante a ratificar o ato praticado.

A ratificação pelo mandante se dá de forma expressa ou resulta de ato inequívoco

(CC, art. 662, parágrafo único).

Há, entretanto, sério obstáculo legal para que o terceiro obtenha o cumprimento pelo mandatário: o art. 673 estipula que, se “depois de conhecer os poderes”, o terceiro “celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário”. Deste modo, não há como responsabilizar o mandante porque este não outorgou poderes para a prática do ato, isto é, não consentiu, não expressou sua vontade e, assim, não pode ser obrigado a satisfazer a obrigação. E, igualmente, não há, por força do art. 673, como responsabilizar o mandatário.

E agora? O terceiro está privado de qualquer outra ação, salvo nas seguintes situações que excetua a regra: (a) a primeira consiste em demonstrar que o mandatário prometeu ratificação pelo mandante. É a especialização da regra geral que se encontra no art. 439 do Código Civil: “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar”. Clóvis (1975, 2:422) esclarece que o mandatário, assim agindo, “assegura ato de outrem, e responde pela eficiência de sua promessa”, mero desdobramento do princípio da boa-fé contratual. Se o terceiro não tiver êxito nessa demonstração, resta-lhe o conselho de Carvalho de Mendonça (1956, 6.2:246): “Queixe-se o terceiro de si próprio, se ficar privado de intentar qualquer ação contra o mandante e o mandatário, porque sabia perfeitamente que este agia além dos limites do mandato”; (b) a segunda exceção volta-se novamente à pessoa do mandatário: deverá ficar provado que ele se responsabilizou pessoalmente.

Vê-se, portanto, que o terceiro ficará na dependência de demonstrar que o mandatário *prometeu ato de terceiro* ou *responsabilizou-se pessoalmente*, situações probatórias desconfortáveis que remetem à importância de uma leitura atenta, e anterior a qualquer celebração contratual, dos termos em que foi lavrado o instrumento de mandato apresentado pelo mandatário.

b) Excesso de mandato desconhecido pelo terceiro

Vimos que havendo *excesso de poderes* o mandante não se vincula à obrigação perante terceiro e, tampouco, o mandatário, salvo duas exceções legais, acima

estudadas. Isto ocorre porque o terceiro contrata apesar de conhecer os poderes do mandatário e, portanto, ciente de seus limites.

Há, entretanto, uma situação específica de excesso de poderes que não se refere à *extensão do objeto* do contrato, mas sim à *extensão de sua eficácia*. É a hipótese contemplada no art. 686 do Código Civil que trata dos efeitos da revogação notificada pelo mandante unicamente ao mandatário, da qual os terceiros de boa-fé não tiveram ciência.

É o caso em que o mandatário, no curso da execução do mandato, após ser notificado pelo mandante da revogação de seus poderes, prossegue com as tratativas sem alertar o terceiro e com ele conclui as negociações, celebrando contrato. O mandante, deixando de notificar o terceiro, está obrigado a satisfazer a obrigação assumida pelo mandatário e, este, pelo excesso praticado, responde perante o mandante.

12.9. Extinção do contrato

Seguindo a estrutura proposta por Serpa Lopes (1993:322), além de causas comuns a todos os contratos (impossibilidade de execução, nulidade contratual, resolução por inadimplemento faltoso e superveniência de condição resolutiva), o contrato de mandato extingue-se por seis causas próprias, cinco previstas no Código Civil e uma na Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Dessas duas são causas *normais* e as demais são chamadas *excepcionais*.

São *causas próprias normais*: (1) *Decurso do prazo* (CC, art. 682, IV) e (2) *Conclusão do negócio* (CC, art. 682, IV). São *causas próprias excepcionais*: (1) *Manifestação da vontade das partes*: pela revogação do mandante ou pela renúncia do mandatário (CC, art. 682, I); (2) *Morte* (CC, art. 682, II); (3) *Mudança de estado (civil)*: a interdição de uma das partes (CC, art. 682, II) ou alteração que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer (CC, art. 682, III) (4) *Falência*: do mandante ou do mandatário, com relação ao mandato outorgado para realização de negócios ou para a atividade empresarial (LREF, art. 120 e § 2º).

CAUSAS DE EXTINÇÃO	CAUSAS COMUNS	• Impossibilidade da execução. • Nulidade do contrato. • Resolução por inadimplemento faltoso. • Superveniência de condição resolutiva.	
	CAUSAS PRÓPRIAS	NORMAIS	• Expiração do prazo. • Cumprimento do contrato.
		EXCEPCIONAIS	• Manifestação de vontade das partes: revogação e renúncia. • Morte. • Mudança de estado e inabilitação. • Falência.

Vejamos individualmente cada uma dessas situações:

Impossibilidade de execução

A impossibilidade que atinge o objeto do mandato é superveniente à celebração do contrato. Não se trata aqui de um dos requisitos de validade – objeto lícito, possível, determinado ou determinável – acima estudado (v. item 12.4) mas de não ser mais possível a execução do negócio porque a coisa já não mais existe ou se encontra em lugar inacessível (como ocorre em casos de naufrágio ou perecimento em desastres naturais).

Nulidade do contrato

Serpa Lopes (1993:322) arrola, entre as causas terminativas do mandato, a nulidade do contrato que, entretanto, é, antes, condição de celebração e atinge a validade do ato (CC, art. 166).

Resolução por inadimplemento faltoso

É a forma comum de resolução contratual. As partes divergem e deixam de cumprir as obrigações que assumiram, resolvendo o contrato.

Superveniência de condição resolutiva

Estipulada condição resolutiva, a relação jurídica se mantém enquanto aquela não se realizar ou, em outras palavras, ocorrendo a condição o contrato se resolve. Por exemplo, o mandato de comprar ações de determinada companhia em nome do mandante deve ser cumprido pelo mandatário enquanto a empresa permanecer sob controle de outra sociedade por ações ou em mãos de acionistas brasileiros.

Expiração do prazo previsto no contrato

O instrumento de mandato pode limitar o prazo em que os poderes podem ser exercidos pelo mandatário ou essa limitação decorrer de imposição legal, como ocorre com a procuração outorgada por acionista para ser representado em assembleia geral (LSA, art. 126, § 1º), que prevê a validade por um ano. Cessa o mandato com o decurso do prazo legal ou convencionado pelas partes.

Cumprimento do contrato

O cumprimento do negócio para o qual o mandatário se obrigou dá fim a seus poderes de representação, extinguindo-se o mandato. São exemplos que indicam outorga para a prática de atos ou negócios determinados: o comparecimento em cartório para lavratura de escritura de venda e compra; recebimento de doze prestações mensais de contrato de *leasing*; retirada de mercadorias de depósito alfandegário etc.

Manifestação de vontade das partes: revogação e renúncia

A revogação do mandato pelo mandante e a renúncia manifestada pelo mandatário têm em comum duas qualidades: independem da anuência da outra parte e de justa causa. O mandante e o mandatário podem decidir não prosseguir o contrato, comunicando a outra parte sua intenção de exonerar-se do vínculo contratual.

A lei, entretanto, traça alguns cuidados que, desrespeitados, geram ao manifestante a obrigação de indenizar a outra parte. O mandatário deve evitar situações que possam prejudicar o mandante, o que poderá ocorrer se não obedecer ao tríplice dever que lhe é imposto pelo art. 688: comunicação/oportunidade/tempestividade.

A comunicação pode ser feita por qualquer meio admitido pelo direito.

No quesito *oportunidade* o mandatário ponderará os efeitos da renúncia sobre o

negócio na etapa em que este se encontre. João Luiz Alves (1926:947) lucidamente ensina que “tempo oportuno entende-se aquele em que o mandatário não faça perigar ou piorar as condições do negócio, ou melhor, aquele em que sua renúncia não torne impossível a realização do negócio pelo próprio mandante, ou por outro mandatário. É uma questão de fato que envolve a outra, a do tempo para que o mandante providencie [...]”.

Tempestividade sugere claramente a conveniência do mandante em providenciar a substituição. Deve o tempo da renúncia possibilitar que o outorgante encontre substituto para tanto ou se prepare para assumir o encargo. Há prazos *peremptórios*, como, por exemplo, o de interpor recursos: se o procurador judicial manifesta interesse em deixar o encargo na véspera do vencimento do prazo recursal, é certo que poderá causar prejuízo ao seu cliente; outro exemplo: se o procurador tinha por incumbência apresentar proposta em certame público e renuncia no dia anterior ao encerramento do prazo fixado em edital, está ciente de que seu ato tolhe qualquer iniciativa do mandante, que, diante das circunstâncias, não terá tempo para agir proveitosamente.

Abre o legislador uma única exceção: o mandatário poderá abdicar do encargo, mesmo inoportunamente, se provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável⁸², abrindo um leque de causas justas: viagem inesperada, convocação para prestação de serviço público, enfermidade pessoal ou de familiar, mudança de domicílio que torne penoso o cumprimento do encargo etc.

A revogação pelo mandante pode ser, quanto à extensão dos efeitos, total ou parcial e, no que se refere à extensão subjetiva, coletiva ou individual. Washington de Barros Monteiro (1973, 2ª parte:266) esclarece, no que se refere à extensão no polo ativo, que “a revogação efetuada por um deles não se estende aos demais, restringindo seus efeitos ao próprio revogante”.

Quanto à forma, pode ser, ainda, expressa ou tácita, e, em ambos os casos, *haverá necessidade de notificação ao mandatário*. O exemplo legal de revogação tácita encontra-se no art. 687 do Código Civil: nomeação de outro para o mesmo negócio. Assim, se o mandante comunicar ter designado outra pessoa para o mesmo encargo,

mesmo omitindo a palavra “revogação”, deve o mandatário entender implícita sua destituição, salvo se expressamente ficar consignado que o nomeado atuará em conjunto com o mandatário ou com poderes específicos.

Surge no contexto da *revogação* a figura do mandato irrevogável, objeto da disciplina do art. 683 do Código Civil que impõe o *pagamento de perdas e danos* a cargo do mandante que revogar o mandato que contiver cláusula de irrevogabilidade.

São os casos previstos nos arts. 684-686. O primeiro dispositivo declara *ineficaz* a revogação em três situações: se a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário (art. 684). O segundo prevê a mesma pena de *ineficácia* se o mandato contiver a cláusula “em causa própria” (art. 685). O último qualifica de *irrevogável* o mandato que contenha “poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado” (art. 686, parágrafo único).

O primeiro caso – condição de um negócio bilateral – contempla, na verdade, não a irrevogabilidade do mandato, mas a do contrato para o qual a procuração foi outorgada como condição. Figure-se, como exemplo, acordo pelo qual acionistas de uma companhia concordam em nomear um único procurador para votar em determinada matéria em assembleia geral ou especial (LSA, art. 118, § 7º), transmitindo-lhe a orientação objeto de seu acordo. A procuração outorgada é condição desse contrato bilateral (acordo de acionistas); não há como revogá-la porque é mero meio de cumprimento da obrigação que esses acionistas contrataram.

O segundo caso – cláusula estipulada no exclusivo interesse do mandatário – considera a existência de negócio prévio entre mandante e mandatário que o mandato vem tão somente dar efetividade: o procurador age em nome do outorgante na defesa de seus próprios interesses, objeto de contrato anteriormente firmado. Exemplo comum é a venda e compra realizada pelo mandante ao mandatário que, titular da coisa (que lhe foi vendida), recebe poderes do vendedor para aliená-la a quem desejar. Observe-se que, de fato, a coisa pertence ao mandatário e, por razões de cunho negocial, prefere mantê-la em nome do vendedor para, logo mais, transmiti-la a terceiro, novo comprador.

O terceiro caso – em causa própria, também conhecido como mandato *in rem suam* – é mera derivação do segundo. Sua origem, no Direito Romano, era a de permitir a cessão de obrigações, sem fazer uso da novação: “inventou-se um meio indireto de chegar a esse resultado, fugindo do rigor do direito, que preceituava a intransmissibilidade do vínculo obrigatório, a imutabilidade dos sujeitos da relação creditória, sem se recorrer à *novatio obligationis*” (Beviláqua, 1975, 2:436). Entretanto, como bem salienta Serpa Lopes (1993:335), “a despeito de desaparecida a sua função histórica, prossegue dotado da mesma função, que constitui seu efeito principal, qual o de atribuir ao mandatário a *qualidade de dono da coisa ou do negócio* e até mesmo, se revestido dos requisitos indispensáveis, como título suficiente de alienação da propriedade imóvel, susceptível de transcrição”.

O último caso – poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado – visa à proteção de terceiros com que o mandatário contratou em nome do mandante. Prevê o parágrafo único do art. 686 a existência de “negócios encetados”, isto é, iniciados, e o mandato contém poderes para dar cumprimento ou confirmar o quanto acordado pelas partes contratantes. Revogar o mandato implica tornar ineficazes os efeitos já produzidos pelo negócio ao qual o mandato se acha vinculado. Identicamente ao primeiro caso, a irrevogabilidade atinge não o mandato, mas os termos do negócio que a procuração visa tão somente dar cumprimento ou confirmação.

Morte

A morte de um dos contratantes dá fim ao mandato. A simplicidade dessa afirmação esconde algumas dificuldades: o evento morte não opera a extinção do mandato que contenha a cláusula “por conta própria” (*in rem suam*) e, ainda, vindo a falecer o mandatário (CC, art. 690), seus herdeiros devem praticar medidas conservatórias ou continuar os negócios pendentes, avisando o mandante para que este cumpra o que as circunstâncias exigirem (por exemplo: outorgar escritura da venda e compra de imóvel já realizada; entregar a coisa alienada etc.).

A primeira hipótese de não resolução por força do evento morte no mandato *in rem*

suam tem por fim garantir que o mandatário receba o que lhe é devido em decorrência de negócio jurídico que precede ou é subjacente à outorga de poderes. A lei garante ao mandatário transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato (CC, art. 685).

A segunda hipótese classifica-se como obrigação legal imposta aos herdeiros do mandatário, isto é, o contrato de mandato extingue-se, mas os atos conservatórios e conclusivos do negócio devem ser praticados por esses terceiros – herdeiros do mandatário – em razão de serem urgentes e indispensáveis.

Mudança de estado e inabilitação

Entende-se por mudança de estado a relativa ao *status* civil dos contratantes, que “inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer”. É o caso de pessoa casada que, para vender imóvel ou conceder fiança, precisa da anuência do cônjuge. É também a situação do interditado que não pode mais exercer os atos da vida civil, a superveniência de enfermidade ou deficiência mental que retire o discernimento para a prática desses atos ou, ainda, a daqueles que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Falência

A falência não implica alteração do *status* civil. O falido pode outorgar procuração e recebê-la para praticar atos de interesse de outrem. Pode também prosseguir os mandatos recebidos e outorgados, limitados seus poderes, entretanto, aos atos pessoais que não guardem relação com os atos negociais ou com a atividade empresarial, para os quais o falido está impedido de praticar até o encerramento da falência e extinção de suas obrigações. Os mandatos para fins judiciais não se encerram até que sejam expressamente revogados pelo administrador judicial da falência.

Capítulo 13

COMISSÃO EMPRESARIAL

Sumário: 13.1. Definição legal. 13.2. Origens. 13.3. Características. 13.4. Distinções com outros contratos. 13.5. Direitos e obrigações dos contratantes. 13.5.1. Relação entre comissário e terceiro. 13.5.2. Relação entre comissário e comitente. 13.6. Da remuneração do comissário. 13.7. Efeitos da falência sobre o contrato. 13.8. Cláusula *del credere*.

13.1. Definição legal

Diz o art. 693 do Código Civil que “o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente”.

Há, assim, nesse contrato, a prática de alienação ou de venda de bens, realizada entre terceiro e comissário, a favor e sob as ordens e instruções do comitente. Apesar dessa finalidade específica – por conta do comitente –, o negócio é feito em nome do comissário e não de quem o encarregou de realizá-lo, que, para o terceiro, permanece oculto.

O contrato de comissão difere do mandato na *extensão* (o mandato abrange a prática de quaisquer atos jurídicos lícitos e não apenas a aquisição e venda de bens), no *vínculo obrigacional* (os atos são praticados, no mandato, em nome de quem confere poderes para sua prática – o mandante – e, na comissão, em nome daquele que o realiza – o comissário); e, finalmente, na *representação* (o comissário não representa o comitente nem ostenta instrumento de representação, como ocorre no mandato, em que a procuração é seu instrumento) (CC, art. 653, *in fine*).

A comissão será empresarial (ou mercantil, na linguagem anterior ao Código Civil de 2002) se uma das partes contratantes exercer atividade empresarial e o contrato

voltar-se ao exercício dessa atividade.

Aqui reside séria controvérsia doutrinária. A doutrina comercialista sempre entendeu que o contrato de comissão possui natureza essencialmente mercantil: o art. 165 do Código Comercial reputa comerciante o comissário.

O Código Civil de 1916, contudo, alicerçava a possibilidade de existir contrato de comissão civil, ao dispor, no art. 1.307, sobre situação jurídica no contrato de mandato em que o mandatário ficava “diretamente obrigado, como se seu fora o negócio, para com a pessoa, com que contratou”.

Esse dispositivo, mantido no art. 663 do Código Civil de 2002, assinala a possibilidade de o mandatário agir em seu próprio nome e não em nome do mandante.

Essas questões, a nosso ver, estão superadas pela unificação do direito obrigacional e resolvem-se pela integração dessas normas contratuais com as do Direito de Empresa, em especial com a definição legal de empresário. Se a finalidade do contrato de comissão é a colaboração voltada a uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, estaremos diante de um contrato de comissão empresarial.

É contrato oneroso, bilateral e não solene, isto é, sem forma especial, podendo ser firmado por escrito ou verbalmente, provando-se por qualquer meio admitido em direito.

13.2. Origens

Remonta o contrato de comissão ao contrato de *commenda*, conhecido na Idade Média, conforme descreve Waldirio Bulgarelli (1997:483): “na intensificação do comércio, a manutenção em outras praças de um comissário poupava despesas, frustrava a proibição do comércio por estrangeiros e ensejava o aproveitamento do crédito do comissário”.

Fernand Braudel (1996:127) afirma que a intensificação desse contrato se deu a partir do século XVII: “Com o fim do século XVI tende a generalizar-se a comissão, sistema maleável, menos dispendioso e mais expedito. Todos os mercadores – tanto na Itália como em Amsterdam – dão comissão a outros mercadores que lhes pagam na

mesma moeda. Das operações alheias que assumem retiram uma pequena porcentagem e, no caso inverso, concedem a mesma retirada de suas contas. Não se trata, evidentemente, de sociedades, mas de serviços recíprocos”.

No seu nascimento, o contrato de comissão destinou-se a facilitar as relações mercantis, função que o mandato não cumpria adequadamente, razão pela qual Carvalho de Mendonça afirma que “a comissão aperfeiçoou o mandato”:

“O contrato de comissão teve a sua fase brilhante na história do comércio à medida que este se desenvolveu e os comerciantes de praças diversas, nacionais e estrangeiras, entraram em relações diretas. O mandato não oferecia as facilidades exigidas pelo comércio. A dispensa de exhibir documento formal necessário para habilitar o mandatário perante as pessoas com quem tratasse, o afastamento do risco do excesso de poderes do mandatário, o segredo das operações do mandante em regra necessário para não revelar aos rivais a marcha dos seus negócios, a garantia proporcionada a terceiros que, conhecendo a solvência e a probidade do mandatário com quem se correspondiam, ignoravam as do mandante, a possibilidade de aproveitar o crédito e o capital do comissário, a facilidade das informações, das remessas e da guarda das mercadorias em praças distantes, a antecipação das somas sobre elas foram vantagens que concorreram para o aparecimento dos comissários, pessoas que se encarregavam profissionalmente de operações comerciais por conta de outrem, mas agindo no *próprio nome*”.

“A *comissão* é o contrato entre eles e as pessoas que lhes dão o encargo⁸³.”

“Pode-se dizer que a comissão aperfeiçoou o mandato.”

Waldirio Bulgarelli (1997:483) resume as vantagens do contrato de comissão sobre o mandato:

- “1. a dispensa de exhibir o comissário documento formal para habilitar o mandatário perante as pessoas com que trata;
2. o afastamento do risco pelo excesso de poderes do mandatário;
3. o segredo das operações do mandante, para evitar conheçam os concorrentes a marcha dos seus negócios;

4. a utilizado do crédito e do capital do comissário, na praça onde se encontra estabelecido;

5. as facilidades de informações, das remessas e da guarda de mercadorias, em praças distantes”.

Bem verdade que, atualmente, os modernos contratos de distribuição substituem com eficiência os contratos de comissão.

13.3. Características

Dissecando a expressão legal, encontramos no contrato de comissão três elementos que merecem nossa atenção: (1) aquisição ou a venda de bens pelo comissário; (2) em seu próprio nome; (3) à conta do comitente.

O primeiro elemento trata do *objeto* do contrato entre comitente e comissário: a aquisição ou a venda de bens que o comissário deve realizar. Pode envolver bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos.

O segundo elemento refere-se ao *vínculo* obrigacional: entre comitente e o terceiro não há vínculo jurídico. O comitente não se obriga com o terceiro – vendedor – ou com o comprador que tratou com o comissário; o comissário não é representante do comitente, pois age em seu *próprio nome*. Formam-se dois vínculos distintos: um entre comissário e terceiro, decorrente da aquisição ou venda do bem, e outro entre comissário e comitente, relativo ao contrato de comissão.

O terceiro elemento – à conta do comitente – reforça a *função do contrato*. Observe-se que a afirmação de ausência de vínculo obrigacional do comitente para com terceiros não leva à consideração de que o bem adquirido pelo comissário não pertença ao comitente. A compra ou a alienação se dá para o comitente, que é o fornecedor ou o destinatário do objeto contratado com terceiro.

13.4. Distinções com outros contratos

A distinção entre comissão e mandato não traz dificuldades: embora tenham afinidades na origem – a comissão deriva do mandato –, a natureza de cada um deles se estabelece por peculiaridades próprias e tipicidade bem definidas pelo

ordenamento jurídico.

O Código Civil estabelece certas identidades entre comissão e outros contratos, não somente por descrevê-los sequencialmente, nos capítulos X (mandato), XI (comissão) e XII (agência e distribuição) do Título VI do Livro I da Parte Especial Do Direito das Obrigações, como também por determinar que se apliquem à comissão as regras sobre mandato (CC, art. 709) e aos contratos de agência e de distribuição as concernentes ao mandato e à comissão (CC, art. 721), no que couber.

Admite, portanto, o legislador civil semelhanças no que se refere ao comum papel de colaboração que esses contratos promovem nas relações econômicas que estabelecem entre os contratantes.

Para fixar as distinções entre os contratos de mandato, comissão e agência e distribuição oferecemos uma visão agrupada de suas características:

CONTRATO	FUNÇÃO DO CONTRATO	CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO	CLÁUSULAS GERAIS E ESPECIAIS	PREVISÃO LEGAL
Agência	Promoção de certos negócios em zona determinada.	A aproximação é feita pelo agente, mas o negócio é concretizado entre cliente e proponente.	Salvo ajuste, há reciprocidade de exclusividades.	CC, arts. 710-721 L. 4.886/65
Distribuição (sem revenda)	Promoção de certos negócios em zona determinada, mas o agente tem a sua disposição a coisa negociada.	A aproximação é feita pelo agente, mas o negócio é concretizado entre cliente e proponente.	Aplicam-se as regras relativas ao mandato e à comissão, no que couber.	CC, arts. 710-721 L. 4.886/65
Mandato	Prática de atos ou administração de interesses alheios.	O mandatário delibera e realiza o negócio em nome do mandante.	Só confere poderes de administração. Para alienar, hipotecar, transigir ou atos que exorbitem a mera administração, exige-se cláusula expressa.	CC, arts. 653-691

Comissão	Aquisição ou venda de bens, em nome do comissário, à conta do comitente.	Somente o comissário aparece no negócio. Ele fica diretamente obrigado com as pessoas com quem contratar.	Normalmente não responde pela solvência da pessoa com que contratar, salvo se agir com culpa ou, ainda, se o contrato de comissão prever cláusula <i>del credere</i> .	CC, arts. 693-709
----------	--	---	--	-------------------

13.5. Direitos e obrigações dos contratantes

Vamos tratar dos deveres e das obrigações dos contratantes considerando os dois distintos círculos de relacionamento jurídico que resultam da atividade desenvolvida pelo comissário: as relações com terceiros e as que mantém com o comitente.

13.5.1. Relação entre comissário e terceiro

Na relação com terceiros, que surge pela aquisição ou venda de bens feita pelo comissário, somente este fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contrata; o comitente não figura no contrato, nem se obriga perante terceiros, não é representado pelo comissário; este age sempre em nome próprio. Temos assim que, em contrato de compra e venda que o comissário vier a firmar com alguém, as discussões jurídicas, eventuais pendências e litígios seguirão as regras desse contrato, objeto de nossos estudos no Capítulo 9. Nada há de se arguir quanto ao comitente e à existência de um contrato de comissão antecedente à compra e venda.

O terceiro terá, entretanto, ação contra o comitente na hipótese de tornar-se cessionário dos direitos do comissário. Essa disposição, prevista no art. 694 do Código Civil, é absolutamente desnecessária porque as relações entre cessionário e devedor, nos créditos decorrentes de obrigações que permitam a cessão, regem-se pelas disposições próprias dessa modalidade de transmissão de obrigações (CC, arts. 286-298).

13.5.2. Relação entre comissário e comitente

O comissário age *por conta do comitente*, isto é, recebe ordens e instruções deste. O comitente pode alterar as instruções anteriormente transmitidas, a qualquer tempo,

desde que não haja estipulação contratual em contrário. Neste caso, o comissário deve aplicar as novas ordens e instruções recebidas aos negócios ainda pendentes.

No caso de o contrato de comissão não especificar todos os detalhes do negócio que o comissário deve realizar, a lei fixa cuidados a serem seguidos por ele: dispondo de tempo para consulta, deve pedir instruções ao comitente e, caso contrário, proceder segundo os usos em casos semelhantes (CC, art. 695).

Algumas regras adotadas pelo legislador ajudam a solucionar eventuais pendências entre comitente e comissário, aplicáveis à diligência esperada do comissário, aos prejuízos, ao prazo para pagamento, à cobrança de juros e ao direito de retenção.

a) Primeiro, quanto à diligência

O comissário deve agir com especial cautela, não somente para evitar prejuízo como também para proporcionar “o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio” (CC, art. 696).

Trata-se aqui de um *plus* em relação à administração de negócios alheios porque se espera que o comissário tenha a exata percepção profissional do conteúdo econômico da alienação ou compra a que se propôs realizar ao comitente.

Entre os cuidados que o comissário deve tomar há os de “boa guarda e conservação dos efeitos⁸⁴ de seus comitentes” e o de “fazer aviso ao comitente, na primeira ocasião oportuna que se lhe oferecer, de qualquer dano que sofrerem os efeitos deste existentes em seu poder, e a verificar, em forma legal, a verdadeira origem donde proveio o dano”, ambas previstas no Código Comercial (arts. 170 e 171, respectivamente) que, embora revogados, servem aos propósitos de interpretação, dada a formulação genérica do legislador civilista ao referir-se à obrigação de o comissário “agir com cuidado e diligência” (CC, art. 696).

b) Segundo, quanto aos prejuízos

O comissário é responsável pela higidez do negócio realizado, obrigando-se, salvo força maior, a ressarcir eventuais prejuízos que causar ao comitente por seus atos e omissões. Contudo, não responde pela solvência da pessoa com quem tratar, salvo se

agir com culpa ou dolo. Haverá culpa, por exemplo, se não considerar evidentes sinais reveladores de insolvência, omitindo-se do dever de buscar certidões cartorárias, de protesto ou se desprezar apontamentos em cadastros restritivos de crédito. Para as pessoas habituadas aos negócios empresariais, alguns sinais evidentes de insolvência relacionados pelo legislador falencista (LREF, art. 94) não podem ser ignorados.

O art. 175 do Código Comercial tratava a matéria sob a ótica profissional do comissário e sua obrigação de diligenciar sobre a idoneidade das pessoas com quem contratasse, afastando sua responsabilidade “se ao tempo do contrato eram reputadas idôneas”.

c) Terceiro, quanto à forma de pagamento

Presume-se que, na ausência de estipulação, o comissário esteja autorizado a conceder dilação do prazo para pagamento “na conformidade dos usos do lugar onde se realizar o negócio” (CC, art. 699). A contrário senso, o comissário responderá pessoalmente com o pagamento ao comitente ou pelas consequências da dilação oferecida ao terceiro, nos seguintes casos previstos no art. 700 do Código Civil: (I) se havia estipulação de proibição de prorrogação de prazos; (II) se a prorrogação deu-se em termos não conforme os usos locais; (III) se o comissário não cientificou o comitente dos prazos concedidos e de quem foi beneficiário da dilação.

d) Quarto, quanto à cobrança de juros

O legislador considerou o contrato de comissão sempre oneroso, impondo a obrigação de pagamento de juros de parte a parte. O comissário receberá juros pelos valores adiantados para o cumprimento das ordens do comitente e este os receberá pela mora na entrega de fundos que lhe pertenciam, retidos pelo comissário (CC, art. 706).

e) Quinto, quanto ao direito de retenção

O comissário tem direito de retenção sobre os bens e valores em seu poder no tocante ao reembolso das despesas que realizar e das comissões a que faz jus (CC,

art. 708). Direito de retenção, como conceituamos no terceiro volume desta obra (v. v.3, item 19.6), “consiste na guarda de coisa alheia em garantia enquanto não satisfeita, a favor daquele que a retém, obrigação lícita prevista na lei ou em contrato”.

13.6. Da remuneração do comissário

O contrato de comissão presume-se oneroso; o comissário deve ser remunerado. Se o contrato não prever a forma de arbitramento, este se dará segundo os costumes do local (CC, art. 701).

Além dessas regras previstas para a normalidade de conclusão do contrato, outras três situações foram contempladas pelo legislador civil: a morte do comissário, a dispensa motivada e a imotivada do comissário, sem conclusão do negócio. Para todos esses casos, a regra aplicável é uma só: o comitente deve remunerar o comissário com valores proporcionais ao trabalho realizado até o falecimento ou a dispensa.

Nos casos de dispensa com motivação, a regra geral da proporcionalidade é ponderada: somente serão remunerados os serviços prestados que forem *úteis* ao comitente, cabendo a este exigir os prejuízos sofridos (CC, art. 703).

Se a dispensa se der sem motivação, o comissário fará jus, ainda, às perdas e aos danos resultantes de sua dispensa (CC, art. 705).

13.7. Efeitos da falência sobre o contrato

O contrato de comissão é bilateral e, em caso de falência, sujeita-se a regramento especial: (a) se o falido figurar como comissário: cessa o contrato que verse sobre matéria empresarial, mas não outros que tenham como objeto relações não empresariais (LREF, art. 120, § 2º); (b) se o falido é o comitente: cessam os efeitos do contrato desde a data do decreto judicial, devendo o comissário prestar contas de sua gestão e habilitar seu crédito, relativo a comissões e despesas feitas, no quadro geral, na classe dos detentores de privilégio geral (LREF, art. 83, V, c, e CC, art. 707).

13.8. Cláusula *del credere*

Cláusula *del credere* é pacto acessório, permitido nos contratos de comissão pela qual o comissário assume o ônus de responder solidariamente com as pessoas com quem tratar em nome do comitente. Salvo disposição em contrário, o comissário *del credere* tem direito a remuneração mais elevada (CC, art. 698), que a doutrina denomina *compensação pecuniária particular*(cf. Carvalho de Mendonça, 1956, 6:309).

Carvalho de Mendonça (1955, 8:292) conceitua *del credere* como “cláusula acessória, tendo por fim e efeito fortificar os direitos do comitente; não modifica a natureza do contrato principal a que se justapõe; não o altera, nem o inova; não transfere ao comissário a propriedade das mercadorias e, conseqüentemente, não tira ao comitente a qualidade de reivindicante”.

A cláusula *del credere* deve ser expressa e pode ser enunciada por outras expressões equivalentes, como bem expressa Carvalho de Mendonça (1956, 6:310): “fazer bom”, “tomando tudo sobre nós, garantimos a execução do contrato”, “assumimos a garantia”. Em outras palavras impõe a responsabilidade de o comissário pagar o preço da mercadoria que vendeu, em solidariedade com as pessoas com quem tratou. Para compensar esse ônus, sua remuneração será mais elevada (CC, art. 698).

Orlando Gomes explica a função da cláusula *del credere* (2008:448): “servir de estímulo à criteriosa seleção dos negócios, evitando que o comissário, atraído pela comissão, possa concluir para o comitente negócios prejudiciais”. Maria Helena Diniz (2007, 3:406) comunga dessa mesma opinião quando afirma: “Esta cláusula constituirá um estímulo à seleção dos negócios, evitando que o comissário efetive atos prejudiciais ao comitente”.

Capítulo 14

CONTRATOS BANCÁRIOS

Sumário: 14.1. Origem e conceito da atividade bancária. 14.2. Contratos bancários históricos. 14.3. Depósito bancário. 14.3.1. Conceito e natureza jurídica. 14.3.2. Classificações. 14.3.3. Contas conjuntas. 14.4. Desconto e redesconto. 14.5. Mútuo bancário e outras formas de operação ativa. 14.5.1. Espécies contratuais. 14.5.2. Limitações contratuais. 14.6. Crédito documentário.

14.1. Origem e conceito da atividade bancária

É impossível precisar a exata época do surgimento das primeiras instituições bancárias. Contudo, sabemos que a história nos remete às operações de câmbio realizadas principalmente nas feiras medievais. Surgiu como necessidade de se verificar, valorar e transportar moeda e metais preciosos dentro de uma cidade ou além-fronteiras.

Entre os mercadores havia aqueles que se especializaram na arte de conhecer o valor dos metais e das moedas utilizadas em diferentes territórios em que exerciam a atividade mercantil. O banqueiro, nesta primeira fase, era o mercador que, entre outras operações mercantis, exercia a atividade de câmbio e de custódia de valores.

Hunt e Murray (2000:106-107) descrevem a evolução de certa classe de mercadores à condição de banqueiros mercantes:

“É geralmente aceite pelos historiadores que a banca medieval deveu suas origens não aos prestamistas nem aos penhoristas, mas aos cambistas. Além de que este grande volume de câmbio de dinheiro era de fato levado a cabo por certos mercadores como uma subespecialidade natural da sua linha direta de comércio. Estes homens possuíam não só o equipamento como a capacidade de avaliação do peso e da proporção do material principal da liga e, conseqüentemente, do valor de uma

assustadora variedade de moeda de qualidade diferente. Respeitada a sua arte, desenvolviam a muito útil tarefa de impor uma certa ordem numa economia dominada pelo dinheiro em moeda. Providenciavam também um serviço de incalculável lucro aos governos como principais emissores de lingotes às casas de cunhagem de moeda. O seu saber superior e apto do valor do ouro e da prata e do valor do câmbio com outras moedas estrangeiras deu-lhes uma vantagem comercial sobre os outros negociantes, impondo-lhes por sua vez que agissem de forma justa. Os cambistas que foram adquirindo a reputação adequada começaram a atrair depósitos de moeda para guardar sob sua custódia, anotando nos seus livros o valor calculado deste nos termos de uma unidade padrão de cálculo. Conforme o número de contas aumentava, os depositantes começaram a usá-las para fazer pagamentos”.

É do incremento dessas operações que surge a letra de câmbio (v. item 2.1), invenção que suprimiu os custos do transporte de moeda e de metais, uma vez que o valor expresso no papel convertia-se em moeda circulante no território de destino ao ser apresentada ao sacador ou ao seu representante.

Nos primórdios os “banqueiros-mercantes” (cf. Hunt e Murray, 2000:107) não criavam créditos ao transferir valores para as contas dos clientes, como resultado das transações em dinheiro que realizavam. Foi somente pela custódia de valores de terceiros que esses mercadores perceberam a possibilidade de concederem crédito com o dinheiro que lhes era confiado. Nesse passo, houve um crescente uso das reservas transformando esses banqueiros em instrumentos de realização de crédito a público, em larga escala.

Hunt e Murray (2000:107) explicam essa evolução: “A natureza pessoal do negócio e o fato de os bancos também aceitarem a custódia de depósitos levaram inevitavelmente à extensão de créditos sob a forma de saque a descoberto. Este tipo de criação de crédito, ou seja, o banco fazer uso das reservas fracionárias, parece ter sido limitado aos associados mais íntimos do banco. As reservas fracionárias eram ilegais na maior parte das cidades, sendo consideradas como um abuso de confiança pública”.

Carvalho de Mendonça (2000, 1:555-556) destaca o papel dos bancos no fomento

creditício: “Os bancos representam, na sociedade contemporânea, o mais poderoso elemento do crédito, formando ‘o centro a que afluem as ofertas e as procuras de capital, em razão das relações e dos meios de que dispõem e da sua reconhecida capacidade e solvência’”.

Modernamente, as legislações nacionais salientam, nas definições legais, as operações de intermediação relativas a dinheiro e ao câmbio.

É o caso do Código Comercial de Portugal, que, em seu art. 362, dispõe: “São comerciais todas as operações de bancos tendentes a realizar lucros sobre numerário, fundos públicos ou títulos negociáveis, e em especial as de câmbio, os arbítrios, empréstimos, descontos, cobranças, aberturas de créditos, emissão e circulação de notas ou títulos fiduciários pagáveis à vista e ao portador”.

No Brasil, o art. 17 da Lei n. 4.595/64 define instituição financeira como pessoa jurídica, pública ou privada, que tenha “como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”.

Os bancos são, por excelência, instituições financeiras, mas não são as únicas. As sociedades de crédito, financiamento e investimentos, as caixas econômicas, as cooperativas de crédito e as seções de crédito das cooperativas são também consideradas instituições financeiras.

Para efeito da aplicação da Lei n. 4.595/64 subordinam-se à regência legal das instituições financeiras “as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadoria ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando, nos mercados financeiros e de capitais, operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras”.

Equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades típicas daquelas, de forma permanente ou eventual, isto é, que colem,

intermedeiem ou apliquem recursos financeiros, próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros.

O dispositivo (Lei n. 4.595/64, art. 17, parágrafo único) que contempla essa equiparação parece conter uma contradição porque somente as instituições financeiras podem legalmente exercer a atividade que implique *intermediação* de recursos financeiros. De fato, a autorização e o funcionamento de instituição financeira no País são precedidos de autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil ou, se estrangeira, de decreto do Poder Executivo, depois de submetida à análise rígida das condições de funcionamento e da idoneidade de seus administradores. E essa autorização para funcionamento de instituições financeiras exige a constituição sob a forma de sociedade anônima⁸⁵.

A operação de instituição financeira sem ou com autorização obtida mediante declaração falsa é crime punido com pena de reclusão de um a quatro anos (Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986, art. 16).

Assim, a expressão “pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual” deve ser compreendida como aquele que exerce *isoladamente* uma das operações de coleta, intermediação, aplicação ou custódia. A estes, a legislação submete suas operações aos mesmos rigores a que são subordinadas as instituições financeiras. Para exercer conjuntamente todas essas atividades, de forma legal, deverá submeter-se à autorização federal, sob pena de praticar a figura típica de operação irregular de instituição financeira.

A *intermediação* representa a operação típica do comércio, de servir como mediador, de intervir em operações que envolvam recursos financeiros – isto é, dinheiro, ações, títulos de crédito etc. A *aplicação* significa investimentos de recursos, visando à obtenção de lucros em operação de venda e compra e juros pagos por sua utilização. A *custódia* é semelhante à mera coleta, pois envolve a administração de coisa dada em depósito.

Maria Helena Diniz (2007, 3:689) concentra o conceito dos bancos e instituições financeiras na expressão econômica de sua principal atividade: “empresa que tem por

fim realizar a mobilização do crédito, mediante o recebimento, em depósito, de capitais de terceiros, e o empréstimo de importância, em seu próprio nome, aos que necessitam de capital”, sem, contudo, esquecer das atividades acessórias consistentes na “prestação de serviços que pode executar com maior segurança do que o particular, facilitando a vida da clientela, como a custódia de valores e o aluguel de cofres”.

É este também o magistério de Carvalho de Mendonça (2000, 1:556): “Sob o ponto de vista econômico, são verdadeiros intermediários de crédito, recebendo, em seu nome e por conta própria e como devedores, capitais de uns para, ainda em seu nome e por sua conta, e como credores diretos, darem a outros”.

Ressaltamos, para efeitos didáticos, as quatro ações próprias das instituições financeiras: (1) *coleta*, (2) *intermediação* ou (3) *aplicação* de recursos financeiros (próprios ou de terceiros; em moeda nacional ou estrangeira) e (4) *custódia* de valor de propriedade de terceiros.

14.2. Contratos bancários históricos

Inúmeros são os contratos em que uma instituição bancária pode figurar como uma das partes contratantes. Além dos contratos a que se submete como qualquer outra empresa: locação de imóveis, compra de móveis e equipamentos, contratação de funcionários, fornecimento de energia elétrica e de consumo de água etc., há aqueles em que realiza uma das operações exclusivas de instituição financeira. São os contratos bancários próprios, dos quais se destacam o depósito bancário, o desconto e o redesconto, a abertura de crédito em conta corrente, o empréstimo, o crédito documentário e as operações de câmbio.

Fábio Ulhoa Coelho (2016:133) propõe duas categorias de contratos bancários: típicas ou exclusivas “que dizem respeito à atividade bancária, tal como legalmente definida” e atípicas ou acessórias “pertinentes à prestação de serviços correlatos”, esclarecendo que, quanto às primeiras, somente os bancos estão licitamente autorizados a explorar e as demais podem ser exercidas por qualquer sociedade empresária.

A questão é complexa, inexistindo um consenso doutrinário e jurisprudencial a respeito. Adotamos neste *Curso* outra classificação, obediente ao avanço doutrinário da matéria: chamaremos de contratos bancários históricos aqueles tradicionalmente pactuados pelos banqueiros e contratos modernos de crédito e de fomento os criados pela tecnologia de crédito mais recente.

14.3. Depósito bancário

Os depósitos bancários têm sua origem na gênese da própria atividade bancária. No fim da Idade Média eram conhecidos dois tipos de depósitos admitidos pelos “banqueiros-mercantes”, os cambistas que intermediavam a troca e a remessa de valores representados por moeda e metais de um território para outro. Havia o “depósito temporário a longo prazo, confiado ao banqueiro por um determinado período de tempo e que produzia juros” e “depósito sem reservas, reembolsável em qualquer altura, não comportando o pagamento de qualquer taxa de juros”⁸⁶.

Nessas duas operações situava-se o campo da atividade bancária. Conforme registram Hunt e Murray (2000:328), se o depósito era feito a longo prazo o banqueiro necessitava realizar algum investimento com o numerário que lhe fora confiado para devolver ao depositante os juros esperados na data do vencimento e obter algum lucro de sua atividade. Os depósitos confiados “sem reserva”, ou à vista, deviam necessariamente estar à disposição de seus titulares no momento em que o reembolso fosse exigido, sob pena de *bancarrota*, palavra de origem italiana que bem expressa o destino da “banca” do cambista. No primeiro caso é investidor de dinheiro alheio e, no segundo, fiel depositário.

14.3.1. Conceito e natureza jurídica

Maria Helena Diniz (2007, 3:690) aproxima o conceito ao de depósito regular: “depósito bancário é a operação bancária em que uma pessoa física ou jurídica entrega determinada importância em dinheiro, com curso legal no país, a um banco, que se obrigará a guardá-la e restituí-la quando for exigida, no prazo e nas condições ajustadas”.

Há de distingui-lo, contudo, do depósito regular porque no contrato de depósito bancário o banco adquire o gozo do dinheiro que lhe foi confiado pelo depositante. Nisso difere do contrato de depósito regular, em que “recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame” (CC, art. 627). A finalidade do depósito *regular* é sempre a custódia da coisa (*custodia rei*); se o bem é entregue para uso e fruição do depositante, há de se encontrar outra finalidade e outra figura jurídica a informar a natureza jurídica do contrato.

Por essa razão a doutrina tende a aproximá-lo do contrato de depósito *irregular* em que, devidamente autorizado, o depositário pode “servir-se da coisa depositada ou dar em depósito a outrem” (CC, art. 640).

Entretanto, apesar da semelhança com o depósito irregular, neste o depositário não se torna titular do bem, distintamente do que ocorre quando entregamos nosso dinheiro a depósito em agência bancária: o banco passa a ser seu titular e pode usá-lo segundo as normas que regem o sistema financeiro nacional⁸⁷.

No contrato de depósito bancário o depositante transfere a titularidade da importância depositada e assume a qualidade de credor da instituição financeira; no contrato de depósito o depositante não perde a propriedade da coisa.

Embora credor, o depositante não se transmuda em mutuante. O depósito bancário difere do contrato de mútuo. Não há no contrato de depósito vontade do depositante em emprestar, tampouco, da instituição financeira em tomar empréstimo de dinheiro, pagando juros pela remuneração do capital. Esse caráter econômico (pagar juros) pode estar presente no depósito bancário, como ocorre com as contas remuneradas, mas o liame contratual que converge os interesses das partes contratantes é a de relação de confiança. No contrato de depósito bancário, se à vista, o depositante tem a livre disponibilidade do dinheiro depositado, podendo receber ou não remuneração pelo período em que os recursos ficaram à disposição do depositário.

Trata-se, pois, de contrato de natureza especial – nem mútuo, nem depósito regular ou irregular.

14.3.2. Classificações

Quanto à movimentação, os depósitos podem ser: (a) contratos à vista, em que se permite a livre movimentação pelo depositante, isto é, seu saque parcial ou total a qualquer tempo; (b) depósito de pré-aviso ou de aviso prévio: aquele que, para seu levantamento, exige anterior comunicação ao banco sacado; (c) de prazo fixo: são aqueles em que as retiradas se submetem a termos certos.

Os depósitos bancários são instrumentalizados em contratos de conta corrente. Abre-se uma conta em estabelecimento autorizado de instituição financeira e passa-se a realizar operações de depósito, de aplicações financeiras, retiradas, transferências bancárias, débitos em conta etc.

Os contratos de contas correntes podem ser celebrados em contas remuneradas, sendo as mais conhecidas as contas de poupança, nas quais o depositante tem direito a perceber juros e atualização monetária a cada período de trinta dias.

Podem, ainda, ser celebrados com empréstimos rotativos, conhecidos como “cheques especiais” ou, sob a forma de “cédula de crédito bancário”, ambos sujeitos à cobrança de juros mensais e até diários, por índices variáveis, segundo a prática do mercado. Há contratos que cumulam comissão de permanência, juros remuneratórios, juros moratórios, multa por inadimplência e encargos de cobrança, elevando em muito a quantia utilizada pelo correntista.

No intuito de corrigir alguns abusos cometidos no sistema financeiro nacional, os tribunais vêm estabelecendo certos limites aos contratos em conta corrente: (a) quanto à forma de retribuição; (b) quanto aos limites das taxas remuneratórias; e (c) quanto à cumulação de encargos, matéria que será desenvolvida no tópico “mútuo bancário”, neste capítulo.

14.3.3. Contas conjuntas

Quanto à titularidade das contas, o depositante pode contratá-las sob a forma individual, em que se torna o único correntista, titular do direito às retiradas dos depósitos e dos eventuais frutos, como também responsável perante o banco sacado e terceiros pelas operações que com eles realizar. Os bancos viabilizam, ainda, contas conjuntas, solidárias e não solidárias, celebradas por mais de um depositante.

Distinguem-se as contas não solidárias porque nestas ordens ao banco devem ser expressas por todos os correntistas. Na conta conjunta solidária todos os contratantes têm o direito de, isoladamente ou em conjunto com um ou mais cotitulares, movimentar a conta, realizando operações de saque, transferências, emissões de cheques etc. A solidariedade diz respeito ao direito de cada um exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelo banco no contrato de conta corrente. Trata-se de solidariedade ativa entre os cocorrentistas oposta à instituição financeira contratada.

Em razão dessa característica – solidariedade ativa entre eles e perante o banco –, o credor de um deles não pode querer exigir dos outros cotitulares o pagamento de eventuais dívidas oriundas de cheques sem provisão de fundos que um dos titulares isoladamente tenha emitido. Veja neste sentido, entre muitos outros: “I – a existência de conta conjunta entre cônjuges configura autorização recíproca entre ambos, essa autorização, porém, tem o limite dos fundos existentes em conta bancária, sobre os quais tem simples poder de disposição e não se trata de poder ilimitado, geral, para todos e quaisquer atos, entendendo-se mais que se trata de uma hipótese de solidariedade ativa” (STJ, Terceira Turma, REsp n. 3.507/ES, Rel. Min. Waldemir Zveiter, j. em 14-8-1990).

Por esta mesma razão, o banco não pode disponibilizar o nome de todos os correntistas titulares da conta conjunta solidária no cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos, pela emissão de cheques sem fundos por apenas um deles. Se o banco o fizer, responde pelos danos causados ao correntista não emitente do cheque. Não são poucas as lições de nossos tribunais a respeito dessa matéria.

A solidariedade não acarreta efeito cambiário perante os beneficiários dos cheques emitidos, no tocante a eventual saldo insuficiente para o pagamento. Se somente um deles emitiu o título, apenas este estará obrigado, afastando-se a legitimidade passiva à execução, em relação aos demais.

14.4. Desconto e redesconto

As operações de desconto e de redesconto referem-se a títulos de crédito.

No desconto, o cliente transfere ao banco título, de sua emissão ou de terceiro,

ainda não exigível, recebendo determinada quantia que corresponde à antecipação de seu crédito, deduzidos juros e comissões remuneratórios da operação. Obriga-se o descontante pela solvabilidade dos títulos cedidos.

A modalidade denominada desconto é, em geral, constituída das seguintes operações: (a) compra e venda: o empresário realiza venda de produtos ou serviços a seus clientes a prazo e emite duplicatas; (b) transferência: de posse dos títulos, o vendedor comparece ao banco e os oferece em contrato de desconto, recebendo em contrapartida o valor do crédito correspondente aos títulos transferidos à instituição financeira. Essa transferência pode se realizar mediante endosso no próprio título, endosso-mandato ou, ainda, por cessão do crédito, com cláusula *pro solvendo*⁸⁸; (c) pagamento de encargos: ao disponibilizar o numerário o banco retém encargos que correspondem ao valor dos juros incidentes ao período compreendido entre o adiantamento e o vencimento dos títulos e as despesas de cobrança; (d) cobrança: no vencimento das duplicatas, o banco procura os devedores dos títulos (sacados) e contabiliza a favor do cliente empresário a amortização do valor recebido; (e) direito de regresso: o título que não for pago pelo sacado dá ao banco o direito de voltar-se contra o empresário que o descontou.

Exemplificamos o desconto com o título mais comum do comércio: a duplicata. Contudo, outros títulos de emissão do empresário ou de terceiros poderão ser utilizados na operação de desconto.

Alguns cuidados devem ser tomados pelo banco descontador quando se tratar de duplicata não aceita porque o empresário inescrupuloso poderá emitir títulos sem causa – as denominadas duplicatas “frias”. A responsabilidade do banco no protesto desses títulos pode obrigá-lo ao pagamento de dano moral ao sacado que se sentir lesado (v. item 5).

Redesconto nada mais é que a operação realizada por instituição bancária que, recebendo títulos de seus clientes, em operações de desconto, realiza nova circulação em outros bancos, antecipando disponibilidades financeiras.

14.5. Mútuo bancário e outras formas de operação ativa

Mútuo bancário é o empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir ao banco mutuante a quantia recebida, no prazo contratado, acrescida de juros e encargos pactuados.

O mútuo bancário não difere do mútuo comum, regendo-se por regulamentação própria e disposições do Código Civil, arts. 586-592. Na prática bancária, o mutuário emite, no momento da assinatura do contrato, uma nota promissória que será a garantia do banco e poderá ser executada se, no vencimento, a prestação não for adimplida.

A expressão “empréstimo bancário”, em seu sentido lato, contempla, ainda, outras diversas formas quanto ao instrumento de pactuação: contratos de financiamento, consignações em folha de pagamento, contratos de conta corrente garantida, também denominadas “cheque rotativo”, “especial”, “cheque ouro” ou denominação equivalente, abertura de crédito, cédula de crédito bancário etc.

14.5.1. Espécies contratuais

Os distintos instrumentos, chamados *produtos* pelas instituições financeiras, contemplam mecanismos, garantias, prazos e encargos diferenciadores. As características mais importantes podem ser assim resumidas:

ESPÉCIE	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Abertura de crédito	A instituição financeira obriga-se a disponibilizar determinado limite de crédito ao contratante, em determinado prazo, facultando-lhe o saque imediato ou fracionado de valores que deverão ser restituídos no vencimento, acrescidos dos encargos convencionados. É chamado contrato de abertura de crédito <i>simples</i> na modalidade em que se permite o saque, mas não a recomposição, e <i>em conta corrente</i>, a que o permite. Em outras palavras, o contrato de abertura de crédito é contrato gênero do qual os contratos de cheques garantidos são espécie. Revestirá desta modalidade (cheque especial, garantido, ouro, azul etc.) quando o contrato prever a disponibilidade em conta corrente e a possibilidade de o cliente reembolsar, por depósitos supervenientes, os valores utilizados, renovando-se o limite disponibilizado a cada movimentação de crédito ou débito em conta corrente.
	Os contratos de abertura de crédito podem ser instrumentalizados em Cédulas de Crédito Bancário, que são títulos executivos que contêm promessa de pagamento de soma de dinheiro e cuja liquidez somente se apura no vencimento, mediante operação de subtração de eventuais

Cédula de crédito bancário	amortizações periódicas e de adição de encargos contratados. A distinção mais marcante entre as contas garantidas e a cédula de crédito bancário encontra-se no título que representa a dívida assumida pelo cliente. As cédulas podem ser executadas pelo banco credor, pois são títulos executivos, e os contratos de contas garantidas somente admitem ação de cobrança ou ação monitória, conforme reiterada jurisprudência ²⁰ . Por esta razão, os contratos de cédula de crédito em geral contemplam encargos menos onerosos.
Consignação em folha de pagamento	Os contratos de empréstimo consignado são modalidades de mútuo em que as parcelas devidas pelo mutuário são lançadas diretamente na fonte de pagamento de clientes assalariados ou pensionistas. Essa garantia adicional de adimplência confere ao contrato juros menores que aqueles que poderiam ser obtidos em outras operações de crédito.
Financiamento	Também chamado crédito direto ao consumidor (CDC) ou adiantamento, define-se como contrato pelo qual a instituição financeira entrega determinada quantia em dinheiro para ser utilizada pelo mutuário no pagamento de determinado bem ou empregada para execução de empreendimento previamente contratado. O contrato pode prever a alienação do bem em garantia do financiamento, resultando, com isso, taxas menores que as que seriam devidas no mútuo bancário comum. Essa modalidade é frequentemente utilizada em políticas de crédito em linhas de crédito subsidiadas pelos governos.

14.5.2. Limitações contratuais

Não vige nessas operações ativas bancárias a limitação imposta aos contratos regulados exclusivamente pelo Código Civil no tocante à taxa de juros que não pode ultrapassar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos à Fazenda Nacional, ou seja, 12% ao ano (CC, art. 406).

Em regra, os juros bancários não encontram limitação legal, podendo ser pactuados livremente pelas partes. Os abusos, contudo, na cobrança desse e de outros encargos vêm sofrendo limitações por força de iterativo entendimento jurisprudencial, quanto: (a) à forma de cálculo; (b) aos limites das taxas remuneratórias; e (c) à cumulação de encargos.

a) Limitação quanto à forma de cálculo

Quanto à *forma de cálculo*, a Súmula 121 do STF veda sua capitalização mensal mesmo se contratada essa forma de retribuição. Tenha-se em mente o seguinte

exemplo: o contrato celebrado dispõe que a cobrança de juros se fará mensalmente, somando-se ao débito já existente na conta do correntista e sobre esse resultado incidirão juros no próximo período de trinta dias. É o chamado juro capitalizado mensalmente ou simplesmente “anatocismo” que já encontrava vedação no art. 4º do Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933⁸⁹.

A Medida Provisória n. 2.170, publicada pela primeira vez em 31 de março de 2000 (sua última edição deu-se em 23 de agosto de 2001, sob o n. 2.170-36), em seu art. 5º, dispôs de forma diversa, admitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Assim, os contratos celebrados antes da data da promulgação daquele diploma legal que contemplem a cobrança de juros capitalizados em período inferior a um ano sujeitam-se à revisão judicial para expurgarem-se os excessos resultantes da vedada forma de cálculo.

Nos contratos posteriores àquela data, os juros capitalizados em período inferior a um ano podem ser exigidos pelas instituições financeiras desde que expressamente contratados. O Superior Tribunal de Justiça confirmou esse entendimento dos Tribunais na Súmula 539:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

O que se entende por “expressa contratação”? Em recurso repetitivo (REsp n 973.827/RS, *DJe* 24-9-2012, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti), definiu-se que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

b) Limitação quanto à taxa remuneratória

No tocante à *limitação das taxas remuneratórias* dos encargos exigidos pelos bancos, o entendimento sumular é no sentido de inexistir a limitação de 12% (Súmula 648 – A norma do § 3º, do art. 192, da Constituição, revogada pela emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua

aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar).

O STF, na Súmula 596, já entendia inexistir limitação de juros às instituições financeiras, sendo inaplicável, *quanto às taxas de juros e aos outros encargos por elas cobrados* a limitação do Decreto n. 22.626/33 (que estipula o limite de juros superiores ao dobro da taxa legal).

O STJ firmou entendimento de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382).

Há, contudo, decisões que enfrentam a questão do abuso do poder econômico e impõem limitações às taxas contratadas quando discrepantes os juros pactuados em relação à taxa média do mercado, conforme se lê na ementa do julgado REsp n. 148.562/RS, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25-11-2014:

“A cláusula referente à taxa de juros só pode ser alterada se reconhecida sua abusividade em cada caso concreto, mediante dilação probatória específica, não tendo influência para tal propósito a estabilidade econômica do período nem o percentual de 12% ao ano, já que taxa compatível com a média de mercado não é considerada excessiva para efeitos de validade do contrato (Súmula 382/STJ)”.

c) Limitação quanto à cumulação de encargos

Por fim, quanto à cumulação de encargos, dois são os mais importantes entendimentos jurisprudenciais a respeito da matéria: (a) é vedada a cumulação de correção monetária com comissão de permanência (STJ, Súmula 30); (b) não podem ser cumulados encargos moratórios e comissão de permanência (Súmula 296):

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

14.6. Crédito documentário

A definição e o mecanismo de atuação dos bancos no mercado de crédito documentário encontram-se no desenvolvimento do contrato de compra e venda empresarial no Capítulo 9, item 9.10.7.

Há autores que identificam o crédito documentário como subespécie do contrato de abertura de crédito. Neste sentido, Maria Helena Diniz (2007:696): “Haverá portanto, por ser uma operação bancária, um ajuste em que o banco convencionou com o cliente a disponibilidade do numerário, em favor do próprio cliente ou de terceiro por ele indicado, podendo o crédito, neste último caso, ser confirmado pelo banco se a soma creditada comportar saque mediante a apresentação de documentos comprovantes de operação comercial realizada entre o cliente e terceiro. Nesta hipótese, ter-se-á crédito documentado, muito comum no comércio exportador e importador”.

Capítulo 15

CONTRATOS MODERNOS DE CRÉDITO E DE FOMENTO

Sumário: 15.1. Contratos modernos de crédito e de fomento. 15.2. Da classificação. 15.3. Cartões de crédito 15.3.1. Conceito. 15.3.2. Espécies. 15.3.3. Características contratuais. 15.3.4. Natureza das empresas emissoras 15.3.5. Outras obrigações. 15.4. Faturização (*factoring* ou fomento mercantil). 15.4.1. Conceito. 15.4.2. Sujeitos da relação. 15.4.3. Cláusulas essenciais. 15.4.4. Direito de regresso. 15.4.5. Garantias. 15.5. Arrendamento mercantil (*leasing*). 15.5.1. Definição legal. 15.5.2. Objeto. 15.5.3. Modalidades. 15.5.4. Obrigações dos contratantes. 15.6. Alienação fiduciária em garantia. 15.6.1. Conceito. 15.6.2. Objeto. 15.6.3. Modalidades. 15.6.4. Elementos do contrato. 15.6.5. Proteção processual.

15.1. Contratos modernos de crédito e de fomento

Inúmeras técnicas contratuais surgem no processo de desenvolvimento do crédito, permitindo a participação de um grande número de pessoas no mercado global de produção e circulação de bens, produtos e serviços. A máquina produzida em Manaus por *A*, vendida a lojista *B* em São Paulo, pode gerar a emissão de uma duplicata descontada na instituição financeira *C*, que, por sua vez, a redesconta na instituição *D*. Esse mesmo fabricante *A* vende outra máquina para um importador argentino *E*, que solicita ao banco *F* a expedição de uma carta de crédito a favor de *A*. O banco *F* abre a favor de *A* um crédito documentário que poderá ser utilizado mediante a apresentação dos documentos de embarque da mercadoria ao comprador *E*. *A*, por sua vez, desconta o crédito documentário no banco *G*, que o redesconta ao banco *H*. O consumidor *I* pretende adquirir o produto do lojista paulista e passa a pesquisar o custo bancário de uma linha de crédito na instituição *J*. O gerente dessa instituição oferece um *portfólio* de produtos diferentes, indicando-lhe o custo e as garantias exigidas em cada um deles: mútuo simples, abertura de crédito em conta,

financiamento direto com alienação fiduciária, *leasing*, consignação em folha de pagamento etc. Esta realidade espelha a atividade bancária moderna: um armazém de produtos de crédito, ao sabor das necessidades, condições e objetivos dos distintos perfis da clientela.

Os códigos não acompanham as rápidas transformações e evoluções do mercado que se rege pelos humores da economia: instrumentos eficazes em tempos de estabilidade podem não servir em épocas recessivas. Por outro lado, o aumento da demanda num mundo globalizado impõe, de um lado, a adoção de instrumentos ágeis de disponibilização de crédito e, de outro, meios que tornem segura a concretização do contrato de fornecimento desse crédito.

Surgem, então, novas técnicas contratuais, objeto do presente capítulo. Concomitantemente, os fornecedores impõem novas exigências quanto à segurança dos negócios, em especial no que se refere à idoneidade dos destinatários finais do crédito.

15.2. Da classificação

Agrupamos neste capítulo as novas técnicas contratuais, surgidas de forma extravagante à legislação codificada. Este foi o único critério que usamos para justificar o tratamento desses contratos num único capítulo.

Observamos, porém, a existência de outros parâmetros para a classificação desses mesmos contratos, merecendo, essa diversidade, a atenção do leitor:

AUTOR	CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO	OBRA MENCIONADA
Carlos Roberto Gonçalves	Cartões de Crédito	Contrato bancário	Direito Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
	Factoring	Contratos especiais	
	Leasing		
	Alienação		

	fiduciária em garantia	[...]	
Fábio Ulhoa Coelho	Cartões de Crédito	[...]	Contratos bancários impróprios
	Factoring		
	Leasing		
	Alienação fiduciária em garantia		
Maria Helena Diniz	Cartões de Crédito	[...]	Novas técnicas contratuais
	Factoring		
	Leasing		
	Alienação fiduciária em garantia	[...]	
Orlando Gomes	Cartões de Crédito	Novas figuras contratuais	Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
	Factoring		
	Leasing		
	Alienação fiduciária em garantia		
	Cartões de Crédito	Contrato bancário	

Paulo Sérgio Restiffe	Factoring	Contrato de colaboração	Manual do Novo Direito Comercial. São Paulo: Dialética, 2006.
	Leasing	Contratos de troca	
	Alienação fiduciária em garantia		
Waldirio Bulgarelli	Cartões de Crédito	Negócio jurídico complexo	Contratos Mercantis, 9. ed. São Paulo: Atlas, 1997.
	Factoring	Novas técnicas utilizadas na atividade econômica	
	Leasing	Contrato misto	
	Alienação fiduciária em garantia	[...]	

15.3. Cartões de crédito

15.3.1. Conceito

Contrato de cartão de crédito é o contrato atípico, bilateral e oneroso, pelo qual uma das partes contratantes, sempre sociedade empresária, fica autorizada a emitir, em base física ou não⁹⁰, instrumento de amplo reconhecimento como meio de pagamento, apto a permitir ao outro contratante a aquisição de bens e serviços oferecidos pela emitente ou por fornecedores por ela previamente cadastrados, mediante identificação com código numérico único, complementado ou não com o uso de senha pessoal ou assinatura de seu portador.

Entre as pessoas fornecedoras de bens e de serviços e a emitente forma-se outra relação jurídica contratual, pela qual esta se obriga a pagar o valor total decorrente do uso desses códigos numéricos.

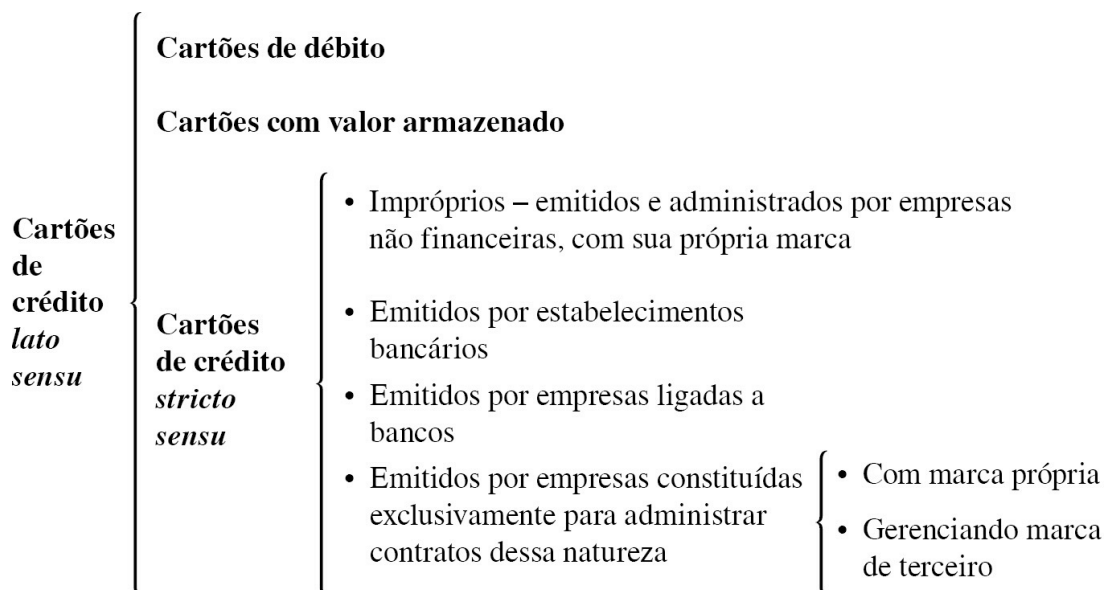
O código do usuário é formado por uma sequência que contém quantidade variável

de algarismos e que se compõe, entre as administradoras mais conhecidas, de 14 a 16 algarismos (Exemplo: American Express: possui 15; Diners Club: 14, Mastercard e Visa: 16 números). Para a segurança das operações, outros três ou quatro algarismos completam a identificação, impressos no verso ou anverso do cartão, para as emissões feitas em base física.

15.3.2. Espécies

Considerada estritamente, a expressão “cartão de crédito” abrange: (a) cartões emitidos e administrados por empresas não financeiras, com sua marca, para uso de seus clientes; (b) cartões emitidos por estabelecimentos bancários; (c) cartões emitidos por empresas ligadas a bancos; (d) cartões emitidos por empresas constituídas exclusivamente para administrar contratos dessa natureza, gerenciando marca própria ou de terceiros. Genericamente considerada, agrupa, ainda, os cartões de débito e os cartões de valores armazenados.

Temos, assim:



15.3.3. Características contratuais

Cartão de débito é “aquele que permite o acesso a determinada conta bancária (comum, de poupança, salário etc.) ensejando a transferência de valores para o

fornecedor da mercadoria ou prestador do serviço. Significa a feitura eletrônica da operação, sendo que o débito acontece automaticamente na conta do titular, ao passo que o crédito se realiza um dia útil depois da transação”⁹¹.

Cartões com valor armazenado, pouco difundidos no Brasil, são os que permitem carregamento prévio de certo valor contratado entre emitente e usuário, servindo como instrumento de pagamento, à guisa de moeda. Distingue-se do cartão de débito porque os lançamentos não ocorrem na conta corrente do titular, mas em dispositivo interno que armazena os créditos de carregamento e os débitos realizados.

Os cartões emitidos por empresas não administradoras de cartões de crédito, com sua própria marca, são também chamados impróprios, “cartões fidelidade”, “cartões de credenciamento” ou, em inglês, “*retail cards*” (literalmente “cartões de venda a varejo”); o contrato firma-se entre o usuário e a empresa, autorizando o portador a realizar compras e serviços exclusivamente nos estabelecimentos integrantes de sua rede. Trata-se de estratégia de aproximação e fidelização de clientela, podendo ou não autorizar a compra a prazo, limitando-se, em alguns casos, ao mero cadastramento de usuários. Por não ser instituição financeira, a emissora não pode exigir encargos próprios das entidades bancárias, sob pena de incidir na vedação da Lei da Usura (Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933) e da Lei do Sistema Financeiro (Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964).

A empresa pode, entretanto, utilizar-se da intermediação de uma administradora de cartões de crédito, à qual outorga a gerência das operações de crédito em seu nome, usando sua logomarca.

Nos contratos firmados com instituição financeira ou empresas ligadas a bancos é comum conceder-se um limite de crédito para que o usuário, além de seu uso corriqueiro de adquirir serviços ou bens, possa contratar a abertura de um limite de crédito, disponível para saque em dinheiro.

O contrato de cartão de crédito propriamente dito pode envolver vários parceiros contratuais, dependendo da finalidade pela qual é realizado.

Nos contratos firmados por empresas constituídas para esse fim, denominadas

“administradoras de cartões de crédito”, formam-se as seguintes relações jurídicas, sendo as duas primeiras também regidas pelo Código de Defesa do Consumidor: (a) **usuário-administradora**: é a relação que envolve o portador do código numérico e a quem se confere o direito de adquirir, respeitados certos limites de crédito, os bens e serviços fornecidos pela emitente ou pelos prestadores credenciados por esta. Ao usuário compete pagar as faturas que forem enviadas pela administradora, no vencimento, incidindo, em caso de mora ou de parcelamento, encargos e remunerações previamente acordadas; (b) **usuário-fornecedor**: a relação que se forma entre o usuário e o fornecedor pode revestir-se de modalidades contratuais distintas: compra e venda; locação de bens ou de serviços; prestação de serviços etc., incidindo nessas operações as regras próprias desses contratos, além daquelas previstas no Código de Defesa do Consumidor; (c) **administradora-fornecedor**: prevalece nesse relacionamento a intermediação realizada pela administradora que, pelos seus serviços ao fornecedor, pode exigir o pagamento de certa remuneração, em geral em porcentagem calculada sobre o valor despendido pelo usuário; (d) **administradora-financiador**: em regra os contratos trazem cláusula autorizando a administradora a valer-se de instituição financeira visando, em nome do usuário, obter recursos para financiar o valor constante da fatura, relativamente aos gastos realizados e às despesas incidentes. É a chamada cláusula-mandato declarada legítima pela jurisprudência dos tribunais.

15.3.4. Natureza das empresas emissoras

As emissoras de cartões são consideradas instituições financeiras se integrantes de um conglomerado bancário ou, ainda, quando, mesmo sem vínculos com instituições dessa natureza, ostentarem em seu objeto social a prestação de serviços de administração de cartões de crédito.

Por assim se qualificarem, as administradoras de cartões de crédito podem cobrar juros e encargos, na mesma proporção que os bancos, não estando limitadas pela Lei de Usura, conforme entendimento da Súmula 283 do STJ (“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros

remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”). E, evidentemente, encontram as mesmas limitações que as instituições financeiras sofrem, inclusive as relativas à forma de cálculo dos encargos, taxas remuneratórias e cumulações vedadas (v. item 14.5.2).

15.3.5. Outras obrigações

As cláusulas contratuais entre administradora-usuário ou entre administradora-fornecedor podem não prever uma diversidade de situações cotidianas ou simplesmente excluir a responsabilidade da administradora para todo e qualquer ato que não tenha sido expressamente previsto.

Em geral os contratos preveem minuciosamente as modalidades de linhas de crédito, fatura, pagamentos, encargos e procedimento em caso de roubo, perda, furto ou extravio do cartão. Situações não descritas geram conflitos entre os contratantes e, com grande frequência, os litígios surgem relativamente às obrigações do usuário e emitente quanto à emissão e remessa do cartão, utilização indevida, cuidados na guarda, responsabilidades em caso de extravio, furto ou roubo, entre outras situações. Em relação ao fornecedor a recusa de reembolso é a mais enfrentada pelos tribunais.

Remessa de cartão. O cartão de crédito somente pode ser encaminhado a quem o tenha solicitado. Constitui prática abusiva prevista no art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor a remessa não solicitada, respondendo a emitente pelos danos morais causados ao destinatário.

Utilização indevida. As fraudes perpetradas com o uso de cartões aumentam na medida em que a tecnologia de segurança não mais consegue criar mecanismos que impeçam o acesso de pessoas inescrupulosas às senhas de acesso dos usuários dos cartões. São muitas as maneiras pelas quais terceiro pode invadir a privacidade dos dados, seja pela feitura de cópia do instrumento físico (clonagem de cartão), seja pela introdução de dispositivo de espionagem nas máquinas disponibilizadas pelas administradoras para operações de saque, pagamento e transferência de valores.

A segurança dos dados cabe a ambos os contratantes, impondo-se, entretanto, no litígio entre a emitente e o usuário, a necessária inversão do ônus da prova (CDC, art.

6º, VIII), sob pena de suportar o consumidor ônus de defesa impossível de ser por ele realizada. Não demonstrado que o usuário deu causa, por sua culpa exclusiva, à utilização de dados por terceiros, impõe-se à administradora a responsabilidade pelos prejuízos causados pelo uso indevido do cartão.

A Recomendação 97/489/CE da Comissão das Comunidades Europeias, assinada em Bruxelas, aos 30 de julho de 1997, acentua, no art. 6º, n. 3, a seguinte diretriz para o uso indevido de cartão: “o detentor não é responsável se o instrumento de pagamento tiver sido utilizado sem presença física ou sem identificação eletrônica (do próprio documento). A simples utilização de um código pessoal ou de qualquer elemento de identificação similar não são suficientes para determinar a responsabilidade do detentor”.

A jurisprudência inclina-se à plena proteção do consumidor, usuário do cartão, não ignorando a diversidade de meios pelos quais se dá o uso indevido desse meio de pagamento, cabendo à emitente demonstrar a regularidade da operação.

Cuidados na guarda. O contratante usuário do cartão é, em regra, responsável pela segurança do instrumento de pagamento e pelos dados que permitem sua utilização. Deve, assim, comunicar à administradora quando ocorrerem erros ou registro indevido de operações não autorizadas. Se não o fizer imediatamente, entretanto, não ficará impossibilitado de fazê-lo na primeira oportunidade após dar conta da irregularidade.

É comum as administradoras estipularem, em cláusula contratual, prazo máximo contado da data de vencimento do extrato para eventuais reclamações sobre divergências, decorrido o qual entendem reconhecido o débito. Essa prática não impede que o usuário busque no Judiciário a satisfação de seu direito.

Responsabilidade em caso de extravio, furto ou roubo. No Brasil, salvo a contratação de cláusula de seguro, não há limite previamente fixado para que o usuário responda pela negligência em comunicar o extravio, furto ou roubo de cartão de sua titularidade. Na Europa, a Recomendação 97/489/CE da Comissão das Comunidades Europeias, em seu art. 6º, assinada em Bruxelas, aos 30 de julho de 1997, estipulava ao detentor suportar as perdas ocorridas no período anterior à

comunicação ao emitente, em até 150 ecus, “salvo se tiver agido com extrema negligência, em contravenção às disposições relevantes previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 5º ou de forma fraudulenta, caso em que o referido limite não é aplicável”.

Não há, entretanto, no Brasil como impor a responsabilidade pelo uso indevido, em caso de subtração do cartão, exclusivamente ao usuário. Cláusula nesse sentido tem sido considerada abusiva. Compete à administradora e ao fornecedor do serviço ou do produto adquirido com o cartão demonstrarem a regularidade de seus atos na concessão do crédito a terceiro que se apresenta como titular do cartão.

Recusa de reembolso. Nas relações entre administradora e fornecedor estabelecem-se regras para o reembolso das compras e serviços realizados com o uso de cartões emitidos. Conflitos podem surgir quanto ao cumprimento pelo fornecedor das regularidades na admissão da operação que, com certa frequência, podem ser realizadas por terceiro que mantém de forma ilegítima a posse do cartão.

Estabelecem-se, para a solução de litígios dessa natureza, alguns princípios básicos: 1º) os riscos por atos de administração, supervisão e controle das operações devem ser suportados pela emitente dos cartões; 2º) a responsabilidade pela identificação do usuário e conferência de sua assinatura é, em regra, do fornecedor; 3º) cabe ao emitente manter em regular funcionamento os terminais e a segurança de instrumentos de pagamentos que dispensam a assinatura do usuário e possibilitam o uso de senha pessoal; 4º) há casos em que se exige autorização da administradora para finalização da operação, assumindo a fornecedora a obrigação de submeter a consulta e, a emitente, a de dar por válido o débito por ela autorizado.

15.4. Faturização (*factoring* ou fomento mercantil)

A Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que alterou a legislação tributária federal, definiu o contrato de faturização na alínea c.4, do § 1º do art. 28, em redação mantida nas duas sucessivas alterações ocorridas no mesmo ano (Leis n. 9.065 e 9.249). Esta última, promulgada em 26 de dezembro, reproduziu o texto original ao regular, em seu art. 15, § 1º, III, *d*, a base de cálculo do imposto de renda de algumas

atividades, entre as quais da “prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (*factoring*)”.

Pela definição legal, a empresa de faturização tem tríplice objetivo: (a) dar assessoria (de crédito e mercadológica); (b) administrar (créditos e riscos e a carteira de contas a pagar e a receber); (c) comprar direitos creditórios resultantes de vendas ou de prestação de serviços.

Embora o objetivo principal seja o último mencionado, o contrato de *factoring* traz as duas outras feições que somadas se traduzem numa só palavra: *trustee*, “gestão financeira de negócios, por intermédio do acompanhamento das contas a receber, das contas a pagar e da cobrança de títulos de crédito” (cf. Rizzardo, 2004:86).

15.4.1. Conceito

Orlando Gomes (2008:580) o conceitua como “contrato por via do qual uma das partes cede a terceiro (o *factor*) créditos provenientes de vendas mercantis, assumindo o cessionário o risco de não recebê-los contra o pagamento de determinada comissão a que o cedente se obriga”.

Semelhantemente, Maria Helena Diniz (2007, 3:739) afirma que “o contrato de faturização de fomento mercantil ou *factoring* é aquele em que um empresário (faturizado) cede a outro (faturizador), no todo ou em parte, os créditos provenientes de suas vendas mercantis a terceiro, mediante o pagamento de uma remuneração, consistente no desconto sobre os respectivos valores, ou seja, conforme o montante de tais créditos”.

Acentuam esses autores tratar-se de *vendas mercantis*. De fato, este é o uso mais comum, devendo-se acrescentar, contudo, que os créditos podem ter como causa subjacente atividade mais ampla, como a *prestação de serviços* e operações não mercantis.

A definição apresentada no Projeto de Lei da Câmara n. 13, de 2007, em tramitação no Senado Federal, é mais completa ao preferir, quanto ao objeto de

cessão, a expressão “direitos creditórios” e, quanto aos destinatários dos serviços, qualquer pessoa que exerça atividade econômica em geral:

“Entende-se por fomento mercantil para os efeitos desta Lei a **prestação contínua** por sociedade de fomento mercantil de um ou mais dos seguintes serviços a sociedades ou firmas que tenham por objetivo o **exercício das atividades mercantis ou de prestação de serviços**, bem como a **peçoas que exerçam atividade econômica em nome próprio e de forma organizada**.

I – acompanhamento de processo produtivo ou mercadológico;

II – acompanhamento de contas a receber e a pagar;

III – seleção e avaliação de clientes, devedores ou fornecedores.

§ 1º O contrato de fomento mercantil poderá prever, conjugadamente com a prestação de serviços, a compra, à vista, total ou parcial, pela sociedade de fomento mercantil de **direitos creditórios no mercado nacional ou internacional**”.

Crítica à parte quanto à redação legislativa, no aspecto de não atualização dos conceitos de empresa (não há mais distinção entre “atividades mercantis e prestação de serviços”), o espectro de direitos creditórios abrange todo e qualquer direito e títulos representativos de crédito originários de operações empresariais e de qualquer outra atividade econômica.

No Senado Federal, o substitutivo apresentado traz outra definição:

“Art. 2º Contrato de fomento empresarial é aquele pelo qual uma parte transmite à outra, total ou parcialmente, a título oneroso, créditos decorrentes de suas atividades empresariais.

Parágrafo único. O contrato de fomento empresarial poderá prever, ainda, a prestação de serviços relacionados à atividade empresarial, tais como:

I – assessoria sobre o processo produtivo ou mercadológico;

II – avaliação e seleção de clientes ou fornecedores;

III – análise e gestão de créditos;

IV – acompanhamento de contas a pagar e a receber”.

Embora o volume expressivo de cessões de créditos decorra de operações envolvendo venda mercantil, o *factoring* pode abranger prestação de serviços e outras atividades econômicas, tais como negócios imobiliários e os decorrentes de agronegócios.

Importante insistir, contudo, que o tríptico objeto do contrato (assessoria, administração e compra de direitos creditórios) afasta o simples consumidor do polo contratual. É indispensável que a operação se destine ao *fomento*, isto é, ao incremento de uma atividade econômica.

Nesse contexto, a qualidade de empresário não é indispensável para caracterizar os contratantes faturizados, basta o exercício de atividade econômica.

Com esses delineamentos, propomos o seguinte conceito: contrato não privativo de instituição financeira pelo qual aquele que exerce atividade econômica de forma organizada cede, em todo ou em parte, a título oneroso, os direitos creditícios decorrentes de sua atividade a empresa regularmente registrada no Conselho Regional de Administração, apta a lhe prestar, de forma cumulativa e contínua, serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos e administração de contas a pagar e a receber.

Desse conceito restam esclarecer dois aspectos: a afirmação de que não se trata de um contrato bancário próprio (não privativo de instituição financeira) e a exigência da regularidade junto ao conselho profissional.

A tradição brasileira é a de não incluir o fomento mercantil entre os contratos exclusivos da atividade bancária. Distintamente, a legislação portuguesa, no Regimento Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-lei n. 298/92, de 31 de dezembro), não somente autoriza os bancos a realizar “operações de crédito, incluindo concessão de garantias e outros compromissos, locação financeira e *factoring*” (art. 4º, n. 1, alínea *b*), como também reservou-lhes a exclusividade (art. 8º, n. 2).

No Brasil, embora o contrato não seja privativo de instituição financeira, nada impede que os bancos ofereçam, em empresas coligadas, essa modalidade de

serviço⁹². Contudo, conforme se verá, as limitações quanto aos encargos, a necessária especialização profissional de seu exercício e a existência de outras operações ativas mais lucrativas (como por exemplo o desconto de títulos) desencorajam a adoção desse segmento pelas instituições financeiras.

No tocante à exigência de registro no Conselho Regional de Administração, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça não deixa margem a dúvidas⁹³. O fundamento do voto do Ministro Castro Meira, reproduzindo a motivação desenvolvida em acórdão de Tribunal gaúcho, funda-se na interpretação da atividade profissional exercida pela empresa de fomento:

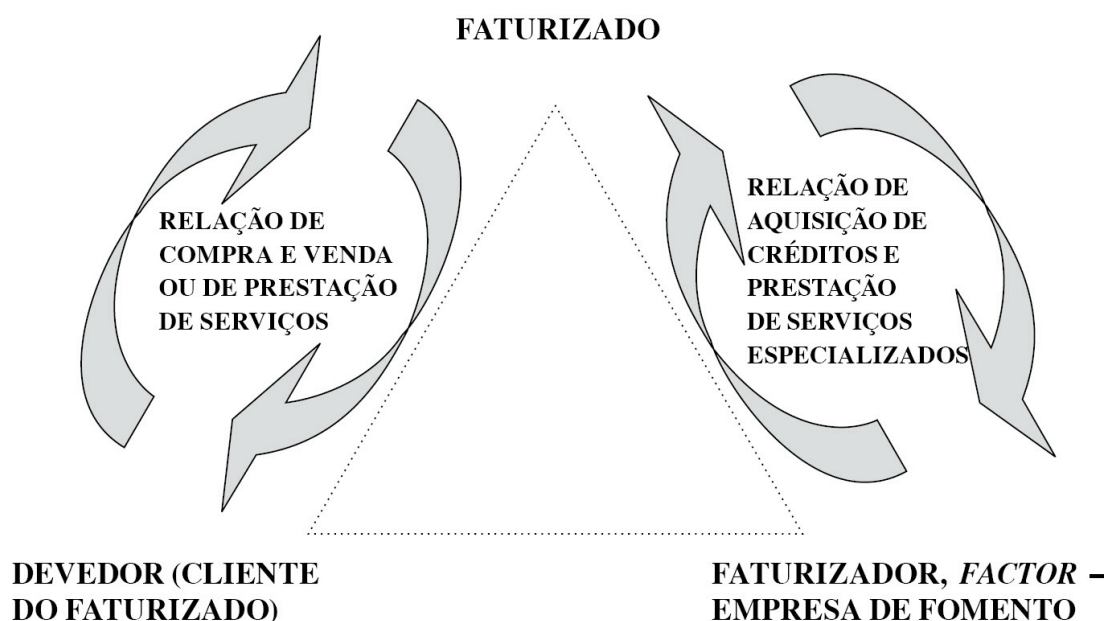
“O STJ, ao analisar o disposto no art. 1º da Lei n. 6.830/80, já firmou o entendimento de que a obrigatoriedade de registro nos conselhos profissionais, bem como a contratação de profissional específico, são determinadas pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados pela empresa”.

“Ademais, conforme bem delineado no voto condutor do julgado, no qual foram interpretados conjuntamente os arts. 3º do Decreto n. 61.934/67 e 2º da Lei n. 4.769/65, a ora recorrente desempenha atividades que necessitam de registro ou de acompanhamento de profissional de administração exigidos pelo Conselho Regional de Administração, porquanto comercializa títulos de crédito, utilizando-se de conhecimentos técnicos específicos na área da administração mercadológica e de gerenciamento, bem como de técnicas administrativas aplicadas ao ramo financeiro e comercial.”

15.4.2. Sujeitos da relação

A operação é triangular, envolvendo o cliente do faturizado, que, por sua vez, é cliente do faturizador. Usam-se, ainda, outros termos para os sujeitos dessa relação: devedor, vendedor e empresa de *factoring* ou, ainda, sacado, faturizado e *factor*. Tais expressões podem não informar completamente a função que cada um exerce na triangulação: o faturizado pode não ser vendedor, mas prestador de um serviço pelo qual seu cliente lhe é devedor; nem sempre o devedor é sacado, pode ser devedor por cheque ou promissória ou outros títulos de sua emissão.

Preferimos, por essas razões, utilizar: (a) **devedor**, para o comprador ou utilizador de serviços objeto da relação subjacente que dá origem ao saque ou emissão do crédito cedido no contrato de faturização; (b) **faturizado**, para o vendedor ou prestador de serviços na relação subjacente; (c) **factor**, **faturizador** ou **empresa de fomento** para a empresa especializada que adquire os créditos do faturizado e lhe presta os serviços administrativos especializados.



15.4.3. Cláusulas essenciais

Segundo Fran Martins (1993:570) são cláusulas essenciais do contrato as relativas à: (a) exclusividade ou totalidade das contas do faturizado; (b) duração do contrato; (c) faculdade de o faturizador escolher as contas que deseja garantir; (d) liquidação dos créditos; (e) cessão dos créditos; (f) assunção de riscos pelo faturizador; (g) remuneração do contrato.

Convém estabelecermos a exata compreensão de cada um desses requisitos:

a) Exclusividade ou totalidade das contas do faturizado

Ao faturizado é vedado ceder seus créditos a distintas empresas de fomento. Ao assinar o contrato estabelece-se uma relação pela qual o faturizador, no prazo de

duração do contrato, poderá eleger as contas do faturizado que deseja garantir. Essa exclusividade, portanto, decorre da essência do contrato por envolver não apenas a compra de créditos mas também assessoria profissional no campo mercadológico, no acompanhamento das contas e na seleção e avaliação dos riscos. Por estas razões a exigência se faz presente.

Se fosse possível ao faturizado valer-se de vários serviços de fomento, o direito à escolha dos créditos recebíveis por partes de um *factor* impediria o pleno exercício do outro.

b) Duração do contrato

O contrato deve estabelecer prazo – determinado ou indeterminado – de duração, período em que o faturizado receberá os serviços da empresa de fomento, pagando os encargos que forem estipulados e colocando à disposição desta as contas para aquisição total ou parcial, mediante seleção a seu arbítrio. Isso não impede que os contratantes estabeleçam, nos contratos com prazo determinado, cláusula de prorrogação.

Nesse período, conforme acentua Maria Helena Diniz (2007, 3:744), ao faturizador é facultado: “a) selecionar os créditos, recusando a aprovação, total ou parcial, das contas que lhe forem remetidas; b) cobrar as faturas pagas; c) deduzir a sua remuneração das importâncias creditadas ao faturizado, conforme o que se ajustou no contrato; d) examinar os livros e papéis do faturizado atinentes às suas transações com certos clientes”.

A falta de um período de duração do contrato daria à empresa faturizadora o poder de exercer odioso controle sobre o exercício da atividade econômica de seu cliente e, por outro lado, a obrigaria a dar continuidade à prestação do serviço que não mais lhe convém. Por esta razão, se o contrato for convencionado por prazo indeterminado, a simples notificação de uma das partes à outra a libera do contrato, liquidando-se as operações já iniciadas.

c) Faculdade de o faturizador escolher as contas

É permitido ao faturizador selecionar os créditos quando da apresentação das faturas pela empresa emitente dos títulos, oportunidade em que assume o risco com a operação, não tendo, contra a faturizada, direito de regresso. Ao aceitar o título apresentado pelo faturizado, assume o *factor*, de forma exclusiva, o risco pela solvência do devedor da prestação originária, não podendo transferir essa obrigação ao cedente, que se obriga tão somente quanto à existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu.

Essa faculdade decorre da necessidade de se manter o equilíbrio contratual: “*Qui sentit onus, sentire debet commodum et contra*”⁹⁴. Em outras palavras, atribuído ao *factor* o risco quanto à solvência do devedor, a ele também deve pertencer, com exclusividade, a decisão de ponderar quanto à conveniência de assumi-lo.

Outra razão para facultar-se à empresa de fomento a escolha dos créditos, tão importante quanto o princípio de equilíbrio contratual, diz respeito à segurança da operação. Evita-se a obrigação de a empresa de fomento adquirir *a totalidade dos créditos* de determinado período e, por consequência, de se tornar refém de operações temerosas ou fraudulentas de seu cliente.

d) Liquidação dos créditos

Cláusula essencial deve dispor quanto à forma de liquidação dos créditos, liberação de valores, prestação de contas contendo informações sobre a movimentação dos títulos entregues ao fomento. Seu conteúdo dependerá da modalidade contratada. Entre as espécies de *factoring* há duas mais utilizadas, denominadas *conventional factoring* (também chamado *old line factoring*) e *maturity factoring* (também conhecido como *factoring de vencimento*): na primeira ocorre a antecipação sobre o valor dos títulos contratados, no momento da cessão; na segunda não há antecipação, o pagamento ao faturizado se dá no vencimento dos títulos ou posteriormente.

Impõe-se sempre a liquidação das operações iniciadas, o que significa dizer que eventual resilição unilateral do contrato não opera a imediata extinção do contrato, devendo os contratantes arcarem com as obrigações assumidas relativamente às

operações já iniciadas.

e) Cessão dos créditos

A compra de créditos no fomento mercantil opera-se pela cessão do direito creditício e por endosso dos títulos a favor do fomentador (faturizador). Porém, esses mecanismos, no fomento mercantil, operam de forma distinta.

Por não se tratar de cessão pura e simples, da qual se diferencia em razão de seu objetivo mais amplo, ao contrato de *factoring* aplicam-se restritivamente regras próprias à transmissão das obrigações previstas nos arts. 286-298 do Código Civil.

Vejam os em que pontos ocorre a subsunção plena do fomento ao instituto da cessão de crédito.

Em primeiro lugar, há identidade quanto à forma: para ter validade em relação a terceiros, o contrato de fomento deve ser celebrado por instrumento público ou particular (CC, art. 288).

Em segundo lugar, o devedor deve ser notificado (CC, art. 289), devendo-se observar que a ausência da notificação não opera *ipso facto* a perda do direito de cobrança. As defesas do devedor são passíveis de ser opostas na execução ou cobrança fundada em título cambial e, entre elas, pode figurar a de pagamento realizado ao sacador, emitente do título na compra e venda a prazo ou na prestação de serviços. Neste caso, a não notificação opera a validade da quitação, em detrimento da empresa de fomento que, com sua inércia, não deu notificação no tempo certo. Em outras palavras, se o devedor pagar ao credor primitivo antes de tomar conhecimento da cessão, fica desobrigado perante o cessionário (CC, art. 292).

Em terceiro lugar, a cessão completa-se com a tradição do documento cedido (CC, art. 291), o que, no contrato de fomento, se dá, ainda, pelo endosso no próprio título.

Nisto reside a complexidade do contrato de fomento que o distingue da simples cessão e do endosso cambial. O *factoring* configura-se contrato aleatório, complexo, atípico, que não se identifica com a simples cessão e, tampouco, com o instituto do endosso, mas reveste-se de ambos, somados ao objeto de financiamento da empresa ou de sua gestão financeira.

A cessão *pura e simples* pode revestir-se de caráter oneroso ou gratuito (CC, art. 295), na operação de *factoring* a cessão é sempre onerosa. Outra distinção encontra-se na natureza do fomento mercantil; por ser contrato de risco, em que se outorga ao faturizador o direito de escolher as contas que lhe interessam (leia-se: os riscos que irá assumir), não há possibilidade de se estipular que o cedente responderá pela solvência do devedor, como ocorre na cessão civil (CC, art. 295). Não é outra a posição de respeitável porção da doutrina⁹⁵ e da jurisprudência⁹⁶, embora haja igualmente respeitável entendimento em contrário⁹⁷.

No endosso, o endossatário titulariza-se do direito de crédito que, contudo, recebe contornos distintos no contrato de faturização. Na compra de créditos pela fomentadora, o endosso, por força do contrato, traz implicitamente cláusula especial “sem garantia”, isto é, o endossante se desobriga de garantir o pagamento do título (LUG, art. 15, 2ª alínea), salvo se agir de má-fé, como, por exemplo, emití-los sem causa (duplicatas frias).

Questão a se contornar neste ponto refere-se ao art. 9º da Lei Uniforme, aplicável por força do art. 25 da Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474/68), *in verbis*: “O sacador é garante tanto da aceitação como do *pagamento da letra*. O sacador pode exonerar-se da garantia da aceitação; toda e qualquer cláusula pela qual ele se exonere da garantia do pagamento considera-se como não escrita”.

A dificuldade está em que, pela redação da lei cambial, a emitente do título (nas vendas a prazo a faturizada é a sacadora da duplicata cedida ao *factor*) obriga-se pelo pagamento do título. Por ser a sacadora ela é, por excelência, garante do pagamento e, portanto, devedora de regresso.

A resposta para essa aparente contradição encontra-se na distinção entre o endosso cambial e o endosso lançado na operação de fomento. As razões pelas quais os princípios da cessão não se aplicam inteiramente ao fomento são as mesmas que lhe negam a plena aplicação dos princípios cambiais ao endosso lançado nos títulos transferidos: o risco e a natureza especial do contrato.

Arnaldo Rizzardo (2004:104-105) assim elucida a questão:

“(…) O Decreto n. 2.044, e assim a Lei n. 5.474, bem como a Lei Uniforme de Genebra sobre letras de câmbio e notas promissórias, disciplina a emissão e circulação de títulos de crédito não ligados ou utilizados em figuras distintas. Surgindo o *factoring* dentro de suas características peculiares, impõe o respeito e a obediência segundo o seu conteúdo. Não é admissível utilizar instrumentos ou princípios de outros institutos dentro do significado com o qual foram criados”.

“Nesta linha, impossível o endosso utilizado para a livre circulação de títulos, e manter seu significado e o tratamento previstos em leis especiais. Já que um mecanismo jurídico diferente apareceu, não se pode vê-lo como uma sombra, uma simbiose, ou remodulação de institutos que possuem a individualidade própria. Novas definições e componentes jurídicos apareceram, com a necessidade de desvinculação dos conceitos de figuras antigas e paralelas. A garantia do pagamento que acompanha a transferência pelo titular do crédito pode deixar de existir em situações diferentes do simples endosso. No *factoring*, há compra de crédito, ou do ativo de uma empresa, e não apenas títulos. Não se opera o simples endosso, mas a negociação do crédito. Há uma individualidade própria, um conteúdo mais extenso que o mero endosso, ou a simples cessão de crédito”.

Trata-se, portanto, de contrato jurídico que não respeita de forma plena os princípios cartulares, sobretudo no que se refere ao emitente-endossante. É princípio cambial a responsabilidade do sacador e do endossante pelo aceite e pelo pagamento do título, o que não ocorre no contrato de faturização.

De forma resumida fica assentado que o faturizado responde pela validade e existência do título (exigibilidade), mas não pela solvência do sacado.

Em quarto lugar, o devedor pode opor ao cessionário exceções que tenha contra o cedente (CC, art. 294).

Distintamente do que ocorre no endosso, em que se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais contra o portador de boa-fé (v. item 1.4.2), na cessão de crédito o devedor pode opor-se ao pagamento do título apresentando defesas que teria em relação à sua primitiva credora (no caso de duplicatas, a

sacadora, faturizadora). Pode, por exemplo, alegar que as mercadorias vendidas não correspondem ao pedido, foram devolvidas ou não entregues no tempo certo etc. Essas defesas, que, em regra, somente poderiam ser opostas àquele com quem realizou a compra ou de quem recebeu os serviços, podem ser apresentadas ao cessionário, empresa de fomento.

É no campo das defesas do devedor que residirá a resposta para se saber se a empresa de *factoring*, deixando de receber o crédito que lhe foi cedido, poderá voltar-se (direito de regresso) contra o faturizado (vendedor ou prestador de serviços na relação com o devedor do título). Se a defesa pautar-se na inexigibilidade do título, teremos, em regra, possibilidade de regresso ao cedente; se a matéria diz respeito à solvência do devedor, em regra nenhuma ação poderá ser movida contra o cedente/endossante, salvo, evidentemente, se a faturizada agir de má-fé (por exemplo, em conluio com o devedor). Expandiremos essa questão no próximo item (15.4.4, “direito de regresso”).

f) Assunção de riscos pelo faturizador

O risco faz parte do contrato de *factoring*, levando Arnaldo Rizzardo a classificá-lo entre os contratos aleatórios⁹⁸, sob o argumento de que “não fica o factor com segurança no recebimento do valor constante do título” (2004:41). Sua natureza explica a não adoção plena dos princípios cambiais quanto ao endosso e responsabilidade do endossante e, igualmente, seu distanciamento do instituto de cessão de crédito no que se refere à cláusula *pro solvendo*.

Entre os norte-americanos essa característica é expressa sem maiores rodeios no conceito jurídico lá adotado: compra de contas a receber, com desconto; o preço é descontado porque o faturizador (quem compra) assume o risco do atraso na cobrança e na perda nos recebíveis⁹⁹.

g) Remuneração do contrato

Factoring não se confunde com mútuo bancário, financiamento ou desconto de títulos, operações privativas das instituições financeiras (v. itens 14.4 e 14.5), não se

aplicando ao contrato a variedade de encargos que o sistema financeiro permite àquelas operações de crédito.

Sobre os valores adiantados na modalidade *conventional* podem incidir juros que, entretanto, se submetem, quando não convencioneados, ao regramento do Código Civil quanto ao mútuo, não podendo exceder “a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (CC, arts. 591 e 406), que corresponde a 1% ao mês (CTN, art. 161, § 1º).

Essa taxa pode ser aumentada até seu dobro por convenção entre as partes, por força de disposição legal (Decreto n. 22.626/33, art. 1º, Lei da Usura).

Paulo Sérgio Restiffe (2006:333) entende que “a empresa de *factoring* não realiza empréstimos, não cobrando, desse modo, juros”. Para este jurista o preço de aquisição – fator de compra – não corresponde à noção de juros. Fábio Ulhoa Coelho (2016, 3:146) apresenta outro entendimento: “A natureza bancária do *convencional factoring* é indiscutível, à vista da antecipação pela faturizadora do crédito concedido pelo faturizado a terceiros, que representa inequívoca operação de intermediação creditícia abrangida pelo art. 17 da LRB” (Lei n. 4.595/64).

De fato, não há tecnicamente mútuo porque o cedente não se obriga a restituir o valor recebido, salvo nos casos em que se constatar a inexistência de crédito ou má-fé do endossante. O valor adiantado é o preço dos serviços e da aquisição dos títulos aceitos pela empresa de fomento.

De rigor, portanto, dar outro nome ao *sobrevalor* exigido pelo faturizador nas operações que pratica. Não há de perder de vista, entretanto, que esse preço corresponderá ao risco e aos termos entre a data de adiantamento e a de vencimento dos títulos. Se o contrato limitar-se à compra de créditos não haverá justificativa para que esse preço supere a taxa legal de juros.

A jurisprudência¹⁰⁰ e grande parte da doutrina¹⁰¹, contudo, admitem a cobrança de juros, sem a distinção técnica de Restiffe. E, desta forma, impõem a limitação prevista pelo legislador: nos contratos em que não há convenção, os juros serão de 1% e, nos que houver, juros até 2% ao mês, sem capitalização, totalizando, no primeiro caso,

12% ao ano e, no segundo, até 24% ao ano.

Questão a se enfrentar é a apresentada por Fábio Ulhoa Coelho (2016, 3:137): “como distinguir juros usurários legalmente proibidos do preço do serviço de fomento?”. E a acertada solução, dada pelo jurista paulista, exigirá demonstração probatória nos processos em que se discutirem eventual revisão contratual: “A solução encontra-se na distinção entre a faturização e a agiotagem, isto é, deve-se pesquisar se os serviços de assessoramento na concessão de crédito são de fato prestados ou não; se entre as partes ocorre a cessão da totalidade das faturas – condição econômica intrínseca da faturização – ou se são pontuais as relações [...]”.

15.4.4. Direito de regresso

Já vimos que o faturizado não responde pela solvência do devedor, mas deve responder pela *existência (exigibilidade) do crédito*. Neste caso obriga-se regressivamente o faturizado que:

a) simular a criação de um crédito, como, por exemplo, emitir duplicatas *sem causa* (duplicatas *frias*);

b) receber o pagamento, total ou parcial, de título, diretamente do devedor, depois de efetivada sua cessão ao *factor*;

c) der causa a justa recusa de pagamento por parte do devedor, como, *por exemplo*, as hipóteses previstas nos arts. 8º, 10 e 21 da Lei n. 5.474/68 (avaria ou não recebimento das mercadorias, vícios, defeitos e diferenças ou devolução de mercadorias, diferenças de preços, enganos verificados, pagamento de outros serviços verificados, não correspondência com os serviços efetivamente contratados; vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados e divergências nos prazos ou nos preços ajustados) e outras *relacionadas ao cumprimento* do negócio subjacente¹⁰².

15.4.5. Garantias

O contrato de *factoring* é contrato de risco, não se reveste da mesma natureza de operações praticadas pelas instituições financeiras, tais como o mútuo bancário ou o

desconto de títulos e nem se faculta ao *factor* direito de regresso contra o faturizado nos casos de simples inadimplemento do devedor dos títulos cedidos. Com essas considerações indaga-se: o *factor* pode exigir, na celebração do contrato, que o faturizado dê garantias (pessoal, real ou fidejussória)?

Ao pretender impor garantias sobre a totalidade dos valores contratados, a empresa de fomento visa afastar o risco negocial, principal característica da operação de *factoring*, e, com isso, munir-se dos mesmos instrumentos de *financiamento de crédito* que os bancos detêm. A operação deixaria de ter a natureza própria de *fomento mercantil*, transmudando-se em concessão de crédito – o retorno do valor dos direitos de crédito adquiridos pelo *factor* é exigido ao final, na hipótese de insucesso na cobrança dos títulos que os representam.

É, portanto, nula a cláusula que imponha ao faturizado a entrega de garantias sobre a totalidade dos títulos cedidos ao *factor*. Entretanto, sobre os valores dos títulos inexigíveis (v. item 15.4.4) perfeitamente válida a cláusula de garantia porque a segurança perseguida neste caso não recai sobre o risco próprio do negócio (a higidez financeira dos devedores consignados nos títulos), mas sobre a solvência do faturizado no que respeita aos valores pelos quais o direito de regresso é possível.

15.5. Arrendamento mercantil (*leasing*)

Arrendamento não é simples locação de bens porque há na execução contratual um entrelaçamento de situações jurídicas que dependem de manifestação da vontade dos contratantes e que, ao final, revelarão seus exatos contornos contratuais.

Ao contratar, o arrendatário dispõe do direito de usar a coisa arrendada e, nesse aspecto, seu ato assemelha-se ao do locatário que recebe temporariamente o direito de gozo sobre a coisa locada. O contrato de *leasing* não se resume a essa faculdade, pois permite ao contratante valer-se do direito de prosseguir com o uso, mediante retribuição, comprar a coisa ou simplesmente resilir, dando por terminado.

Há outras distinções. Imagine-se a situação de um veículo objeto de *leasing* sofrer perda parcial ou total em razão de uma inundação, quem sofrerá o prejuízo? O arrendatário, se não tiver contratado seguro. E na locação? O dono da coisa, que

ainda terá de reduzir proporcionalmente o aluguel ou dar por resolvido o contrato se o veículo não mais servir para o fim a que se destina (CC, art. 597). Conclui-se que os riscos incidem de forma distinta num e noutro contrato.

Há outras distinções, bastando essas duas quanto ao desenvolvimento do contrato e aos riscos para ficar demonstrado que locação e arrendamento, não obstante certas semelhanças, possuem características próprias que não os permite confundir.

15.5.1. Definição legal

O arrendamento mercantil foi inicialmente regulado pela Lei n. 6.099, de 12 de setembro de 1974, que o definiu como “negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta” (art. 1º, § 1º, com a redação que lhe deu a Lei n. 7.132, de 26-10-1983).

Posteriormente, a Resolução n. 2.309, de 28 de agosto de 1996, do Banco Central do Brasil, disciplinou e consolidou suas normas, vindo a ser alterada pela de n. 2.659, de 28 de outubro de 1999, que modificou a redação do art. 7º, e a de n. 3.175, de 20 de fevereiro de 2004, que deu nova redação ao art. 9º.

15.5.2. Objeto

O contrato de arrendamento assegura ao arrendatário tríplice opção (continuar o arrendamento, terminá-lo ou comprar o bem). Para Waldirio Bulgarelli (1997:374), o *leasing* envolve uma operação que se desdobra em cinco fases: (a) a proposta do arrendatário à arrendadora ou vice-versa; (b) o acordo de vontade entre ambas; (c) a aquisição, pela arrendadora, do bem ajustado com o arrendatário; (d) a arrendadora entrega o bem ao arrendatário; e (e) o exercício, pelo arrendatário, de tríplice opção: “continuar o arrendamento, dá-lo por terminado ou adquirir o objeto do arrendamento, compensando as parcelas pagas a título de arrendamento e feita a depreciação”.

No arrendamento mercantil, a coisa está em poder do arrendatário apenas para seu uso, e, contratualmente, pertence ao arrendador.

15.5.3. Modalidades

São conhecidas cinco modalidades de *leasing*, sendo a mais comum a denominada *financial lease* ou arrendamento financeiro ou, ainda, *leasing bancário*, que consiste na operação feita por instituição financeira, que na qualidade de arrendador adquire o bem do fabricante e o entrega, mediante pagamento de parcelas previamente ajustadas, para uso do arrendatário por prazo determinado, ao final do qual este terá o direito de proceder à tríplice escolha. Se o arrendatário rescinde o contrato antecipadamente obriga-se a pagar as prestações vincendas.

A caracterização dessa modalidade encontra-se nos arts. 5º e 8º da Resolução n. 2.309/96: (a) as contraprestações e demais pagamentos devidos pela arrendatária são normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos; (b) a arrendatária responsabiliza-se pelas despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado; (c) o preço para o exercício da opção de compra é livremente pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado; (d) o prazo mínimo de arrendamento deve ser de dois anos entre a data da entrega dos bens e o vencimento da última prestação, para os bens com vida útil igual ou inferior a cinco anos, e de três anos para outros bens.

A segunda modalidade – arrendamento operacional – é definida pelo art. 6º da Resolução n. 2.309/96 e alterações (a Resolução n. 2.465/98 alterou o art. 6º; a de n. 2.659/99, o art. 7º; a de n. 3.175/2004, o art. 9º), e se caracteriza pela ênfase no caráter locatício da operação, tanto que o arrendatário pode rescindir o contrato antecipadamente, sem se obrigar no pagamento das prestações vincendas.

Permite-se, ainda, que a assistência técnica seja de responsabilidade tanto da arrendatária como da arrendadora. Exige-se, entretanto, que as operações desta natureza sejam realizadas privativamente por bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e por sociedades de arrendamento mercantil (art. 6º, § 1º, da Resolução n. 2.465/98).

Por força da Resolução n. 2.309/96, as sociedades de arrendamento mercantil serão sempre sociedades anônimas e deverão ostentar na denominação social a expressão “arrendamento mercantil”. A respeito das operações dessas instituições, o vocabulário do Banco Central do Brasil acrescenta, ainda: “As operações passivas dessas sociedades são emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Suas operações ativas são constituídas por títulos da dívida pública, cessão de direitos creditórios e, principalmente, por operações de arrendamento mercantil de bens móveis, de produção nacional ou estrangeira, e bens imóveis adquiridos pela entidade arrendadora para fins de uso próprio do arrendatário. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil’ (<http://www.bcb.gov.br/pre/compo-sicao/sam.asp>).

As características do arrendamento operacional (arts. 6º e 8º) são: (a) as contraprestações devem contemplar o custo de arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição da arrendatária, não podendo o total dos pagamentos da espécie ultrapassar 90% do custo do bem arrendado; (b) o prazo contratual deve ser inferior a 75% do prazo de vida útil econômica do bem; (c) as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à operacionalidade do bem arrendado ficam a cargo da arrendadora ou da arrendatária; (d) o preço para o exercício da opção de compra é o valor de mercado do bem arrendado; (e) o prazo mínimo de arrendamento deve ser de noventa dias.

A terceira modalidade é o *renting*, que deu origem ao *leasing operacional*. O *renting* é, na realidade, o verdadeiro *leasing operacional*, que, entretanto, ao ser disciplinado pela Resolução n. 2.309, de 28 de agosto de 1996, não foi recepcionado em sua estrutura original.

No *renting* não há intermediários, o arrendamento é feito diretamente do fabricante que se compromete a prestar assistência técnica ao bem arrendado. A Lei n. 6.099/74, embora não proíba sua contratação, a afastou de se beneficiar do tratamento tributário diferenciado instituído a favor das outras modalidades. É o que dispõe o art. 2º: “Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens (...) contratado com o próprio fabricante”.

Lease back ou arrendamento mercantil de retorno é a operação prevista nos arts. 13 e 14 da Resolução n. 2.309/96, sempre de cunho financeiro (não operacional), que envolve, de um lado, compra e venda ou dação em pagamento e, de outro, locação desse mesmo bem, figurando como contratantes o proprietário anterior e o novo adquirente. Nesta modalidade o proprietário, necessariamente pessoa jurídica, vende ou dá em pagamento o bem de sua propriedade e, simultaneamente, o arrenda do adquirente.

Self leasing ou arrendamento consigo mesmo é aquele em que a arrendatária e a arrendadora confundem-se entre pessoas vinculadas de um mesmo grupo econômico. Da mesma forma que o *renting*, a Lei n. 6.099/74 o excluiu do tratamento tributário especial: “Não terá o tratamento previsto nesta Lei o arrendamento de bens contratado *entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas*¹⁰³ *ou interdependentes*, assim como o contratado com o próprio fabricante”.

15.5.4. Obrigações dos contratantes

O arrendatário obriga-se, basicamente, a pagar a prestação contratada e, considerando que o bem permanece no domínio do arrendador, deve, ainda: (a) mantê-lo em bom estado; (b) suportar os riscos e eventuais prejuízos sofridos; (c) pagar os encargos de qualquer natureza como, por exemplo, em relação ao automóvel, quitar o IPVA, as multas de trânsito e quaisquer outras taxas relativas à propriedade e/ou circulação do veículo; (d) restituí-lo ao final do contrato, se não preferir comprá-lo ou prorrogar o prazo de sua utilização.

O arrendatário pode rescindir o contrato antes do prazo consignado, respondendo, contudo, pelo pagamento das parcelas contratadas, salvo se o contrato for de arrendamento operacional, cuja ênfase é dada ao uso locatício do bem (v. item 15.5.3).

Se o contrato estipular cláusula de pagamento adiantado do valor relativo à opção de compra (Valor Residual – VR) e ocorrer a rescisão antes do prazo previsto para a efetivação dessa opção, o valor adiantado deve ser reembolsado ao arrendatário.

Observa-se, entretanto, que o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira distingue, em

didático acórdão (REsp n. 249.340/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira Quarta Turma, j. 18-5-2000, *DJ*, 7-8-2000, p. 116), as expressões “Valor Residual” e “Valor Residual Garantido”, admitindo, ao primeiro, sua restituição em caso de rescisão antecipada:

“I – No contrato de *leasing*, o ‘valor residual’ é o preço contratual estipulado para o exercício da opção de compra, enquanto o ‘valor residual garantido’ é obrigação assumida pelo arrendatário, quando da contratação do arrendamento mercantil, no sentido de garantir que o arrendador receba, ao final do contrato, a quantia mínima final de liquidação do negócio, em caso de o arrendatário optar por não exercer seu direito de compra e, também, não desejar que o contrato seja prorrogado.

II – As parcelas do ‘valor residual’ adiantadas pela arrendatária durante a execução do contrato não podem ser retidas pela arrendante em caso de resolução com base em inadimplemento, com a reintegração do arrendante na posse do bem, somente sendo devida essa verba quando o arrendatário decide adquirir a coisa, exercendo a opção de compra.

III – O descumprimento contratual do arrendatário dá lugar à incidência das cláusulas penais avençadas entre as partes, podendo, em caso de haver demonstração concreta, redundar em ressarcimento de danos ocasionados pelo uso indevido dos bens, não sendo lícito ao arrendante reter o ‘valor residual’ eventualmente adiantado”.

O arrendador, por sua vez, tem o dever de adquirir o bem de terceiro (se não se tratar de *renting*, em que o fabricante se confunde com o arrendador) e entregá-lo ao arrendatário, cumprindo, ao final, a opção manifestada por este (prosseguimento, recebimento do bem em devolução ou outorga do título de domínio na compra e venda).

15.6. Alienação fiduciária em garantia

15.6.1. Conceito

Segundo Orlando Gomes (2008:567), o contrato de alienação fiduciária conceitua-

se como sendo “o negócio jurídico pelo qual o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de um bem, normalmente retendo-lhe a posse direta, sob a condição resolutiva de saldá-la”.

Previsto inicialmente na Lei de Mercado de Capitais (Lei n. 4.728, de 14-7-1965) que lhe reservou tão somente o art. 66, o contrato tinha por escopo dar garantia real aos contratos de abertura de crédito para a aquisição de bens móveis por parte do consumidor.

O regramento legal atual foi determinado pelo Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, que alterou a redação do art. 66 daquele diploma legal, dispondo: “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta de *coisa móvel* alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

Posteriormente, sobre a matéria sobrevieram a Lei n. 9.514, de 20 de novembro de 1997, instituindo a alienação fiduciária de *coisa imóvel*; o Código Civil, que disciplinou a propriedade fiduciária nos arts. 1.361-1.368; e a Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, que regulou o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias.

Este último diploma acentuou a possibilidade de as obrigações assumidas nos contratos de financiamento de imóveis serem garantidas pela alienação fiduciária de coisa imóvel (art. 51) e dispôs que o credor fiduciário não assume “obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e deveres que lhes são imputáveis” (art. 31-A, § 12). Essa disposição, no interesse do credor fiduciário, insere-se nos contratos em que o incorporador submeteu o empreendimento imobiliário ao regime de afetação¹⁰⁴, espécie de universalidade constituída pelo terreno e acessões a ela vinculados, destinada exclusivamente à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.

Alterou, ainda, a Lei n. 10.931/2004, o art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, dispondo procedimento mais célere para a tramitação da ação de busca e apreensão.

15.6.2. Objeto

Pelo mecanismo legal, na alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem. É possível que o bem dado em alienação já integre, no momento do contrato, o patrimônio do devedor, não decorrendo a titularidade, necessariamente, dessa operação (STJ, Súmula 28: “O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor”).

O alienante – devedor – passa a ser possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem. No caso de imóveis, a propriedade fiduciária é constituída mediante registro do contrato no cartório de registro de imóveis.

O domínio definitivo encontra-se sob condição resolutiva, daí por que a lei utiliza a expressão “domínio resolúvel”, visto tratar-se de domínio que jamais será pleno, nem tampouco definitivo. O credor possui uma propriedade restrita e transitória, enquanto não ocorrer a condição resolutiva. A condição resolutiva é uma garantia ao devedor: paga a dívida, readquire o pleno domínio sobre a coisa.

Na condição resolutiva, “enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido” (CC, art. 127) e “sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe; mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé” (CC, art. 128).

Em regra, o credor – também chamado financiador – empresta determinada importância ao devedor – denominado financiado – que, por sua vez, com o dinheiro obtido dessa operação, adquire um bem (pode também tê-lo adquirido anteriormente, v. nota de rodapé n. 39) e, ato contínuo, o transfere, em garantia da primeira operação, a seu financiador. O interesse deste último é receber o que lhe é devido e, quando isto

ocorre, perde ele a propriedade do bem a favor do devedor, também chamado financiador, fiduciante ou alienante.

Aquele que recebe o financiamento – o devedor – aliena a coisa a favor do financiador, em garantia do pagamento da dívida, caracterizando eficientemente o contrato: o bem é garantia do dinheiro entregue ao devedor.

15.6.3. Modalidades

Orlando Gomes (2008:568) entende coexistirem três espécies de contratos de alienação fiduciária em garantia, que podem ser resumidos no seguinte quadro:

Alienação de coisa móvel infungível: prevista no Código Civil (arts. 1.361 a 1.368), firmada entre pessoas não integrantes do sistema financeiro nacional. A propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato, por instrumento público ou particular, no Registro de Títulos e Documentos ou, no caso de veículos no órgão de licenciamento, anotando-se no certificado de registro (CC, art. 1.361, § 1º);

Alienação em que a financiadora é empresa integrante do sistema financeiro: pode recair sobre coisa móvel fungível ou infungível e encontra-se prevista no art. 66 do Decreto-lei n. 911/69;

Alienação fiduciária de imóveis: prevista na Lei n. 9.514/97, definida em seu art. 22 como “negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. O credor pode incidir sobre imóvel construído ou em construção e não é privativo a entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário.

15.6.4. Elementos do contrato

São elementos comuns do contrato de alienação fiduciária em garantia: (a) **forma:** escrita, mediante instrumento público ou privado; (b) **conteúdo:** deve constar do instrumento o valor total da dívida ou sua estimativa; o prazo ou a época de pagamento; a taxa de juros, se contratada; a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação; (c) **eficácia:** necessidade de arquivamento da transferência da propriedade no local de domicílio do devedor para eficácia em relação a terceiros. Sobre isto, o STJ firmou entendimento: “Súmula n. 92 – A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação

fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

O contrato pode, facultativamente, consignar outras cláusulas, por exemplo, as que imponham a incidência penal para o descumprimento (multa, encargos), sendo vedado, contudo, o pacto comissório, isto é, disposição que possibilite ao credor ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento (CC, art. 1.365). Após o vencimento da dívida, entretanto, o devedor pode oferecer em pagamento o bem dado em garantia, com a anuência do credor (CC, art. 1.365, § 1º).

15.6.5. Proteção processual

O credor fiduciário pode valer-se de ações distintas para satisfação de seu crédito, dependendo da situação jurídica em que se encontrar:

a) Tutela provisória – Ação de busca e apreensão

No sistema anterior ao Código de Processo Civil de 2015, se o bem se encontrasse na posse do devedor fiduciário, aplicava-se o remédio jurídico de busca e apreensão da coisa alienada, regida pelo art. 3º do Decreto-lei n. 911/69 e pelos arts. 839 a 843 do Código de Processo Civil de 1973.

O legislador processual simplificou as medidas cautelares – entre as quais a de busca e apreensão –, permitindo ao credor valer-se desde logo da tutela provisória, prevista no art. 294 do CPC15.

Deferida a tutela e realizada a apreensão do bem, a ação segue o rito próprio previsto pelo Decreto-lei n. 911/69, com as alterações da Lei n. 13.043/2014.

b) Ação de execução

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poder requerer a conversão de seu pedido em ação executiva. Em qualquer caso (mesmo que o bem possa ser encontrado), o credor pode preferir valer-se diretamente da ação de execução, porque dispõe de título executivo. Nesse caso, deve optar entre uma e outra ação, uma vez que haverá incompatibilidade de exercício

simultâneo de ambas, consoante a redação do art. 5º do Decreto-lei n. 911/69 e a jurisprudência dominante no regime processual anterior, ainda aplicável.

Capítulo 16

CONTRATO DE TRANSPORTE

Sumário: 16.1. Origens. 16.2. Definição legal e noções. 16.3. Classificação jurídica. 16.4. Espécies e estrutura legislativa. 16.5. Agências reguladoras. 16.5.1. Agência Nacional de Aviação Civil. 16.5.2. Agência Nacional de Transportes Terrestres e Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 16.6. Formação e prova do contrato. 16.6.1. Bilhete de passagem. 16.6.2. Conhecimento de transporte. 16.7. Transporte de pessoas. 16.8. Transporte de bagagem. 16.9. Transporte de coisas. 16.9.1. Contrato de transporte regular e fretamento. 16.9.2. Regras comuns ao contrato de transporte de coisa. 16.9.3. Contrato de transporte multimodal.

16.1. Origens

Ao estudarmos as origens do conhecimento de transporte (v. item 7.3.1) vimos a rápida evolução da empresa de transportes, sobretudo entre as nações com amplos territórios litorâneos e vocação para a navegação marítima. Hunt e Murray (2000:78-79) assinalam que, na Europa Medieval, a empresa transportadora abriu postos de trabalho a uma multidão de operários de distintas qualificações:

“Milhares de pessoas encontravam emprego como carreteiros por terra, tripulantes de embarcações fluviais, carregadores, marinheiros e outros tantos construíam os veículos e as embarcações e encarregavam-se dos serviços ancilares. O transporte de pessoas e de mercadorias era, sem dúvida, uma indústria distinta, pois na maior parte dos casos as entidades que forneciam os serviços eram as proprietárias dos mesmos e alugavam-nos aos consumidores”.

Nesse período, o transporte terrestre e o marítimo desenvolveram-se paralelamente e exerceram parcela importante na expansão do comércio entre as nações europeias. O terrestre, no comércio de longa distância, era o único meio de realizar as rotas interiores na distribuição de inúmeros produtos, mas o marítimo era muito mais econômico¹⁰⁵. Isto devia-se principalmente aos encargos que eram

cobrados dos transportadores ao transporem terras estrangeiras, além dos custos de “aluguel e manutenção de cavalos, de serventes e, quando necessários, de guardas armados” (cf. Hunt e Murray, 2000:79).

Exemplo da importância do transporte terrestre e sua interação com o transporte marítimo é apontado por Hunt e Murray (2000:80) que, em sua obra, ilustram o trajeto desenhado para a remessa de lã de Londres para Florença no limiar do século XIV: despachada na origem, a mercadoria seguia primeiramente de barco até Libourne, na França (Gascogne), ponto em que, de carruagem, chegava até Montpellier, depois, ainda via terrestre, para Aigues-Mortes e, de lá, por barco, até Pisa. Da cidade italiana era conduzida por carroças ou por “bateiras”¹⁰⁶ (dependendo esta operação do nível do rio Arno)”, chegando finalmente a Florença, o destino final.

O transporte mostrou ser importante instrumento de desenvolvimento mercantil regional, o que se deveu, segundo os mesmos historiadores, pelo aperfeiçoamento da tecnologia de transportes terrestres. No período medieval surgem os carros de quatro rodas, com eixo movível, e a carruagem suspensa por correias ou corrente (cf. Hunt e Murray, 2000:302).

A tecnologia jurídica necessariamente evoluiu, fazendo surgir contratos de transportes bem elaborados e legislações de regência para os fretes, como a prevista no Título V do Livro IV das Ordenações Afonsinas, baseada nos usos e costumes dos portos portugueses e espanhóis.

É desse período que surgem as duas formas contratuais que conhecemos para a expedição de mercadorias por via marítima: o contrato de transporte e o afretamento do próprio navio, objeto de nossa exposição logo mais (v. item 16.9.1), que, introduzida no Código Comercial Brasileiro (arts. 566-574), permanecem em nosso sistema jurídico até a presente data. A dualidade contratual bem como o fretamento, por inteiro ou parcial de um barco, são descritos por Filipe Barata (1998:283-284):

“Considerando de uma forma geral, pelo menos para o conjunto do Sul da Europa, um frete podia ser basicamente contratado de duas formas: ou era acordado o transporte de determinada mercadoria, por uma viagem e com escalas mais ou menos

fixas, ou o mestre do navio colocava a sua embarcação ao serviço exclusivo de um afretador interessado, durante um certo tempo, ou para uma viagem específica. É assim que, em 11 de dezembro de 1409, João Martins Camus, de Lisboa e patrão da barca ‘Santa Catarina’, aceitou transportar 30 botas de vinho desde Valência até ao Porto. Ao contrário, pelo contrato de 20 de abril de 1465, Brás Peres, português, dono e mestre da nau ‘Santa Cruz’, contratou com Gaspar Montenamy, mercador de Barcelona, um preço para transportar mercadorias por uma viagem, a qual estava prevista para durar 25 dias”.

“Este último contrato é, aliás, exemplar do tipo de cláusulas que eram estabelecidas. Para que a viagem pudesse ter lugar de forma segura e no prazo acordado, Brás Peres comprometia-se a aprontar sua nau para navegar, equipando-a devidamente. Para que, mais tarde, não surgissem problemas, cada uma das partes nomeava alguém para, de comum acordo, atestar que o navio se encontrava pronto para partir. Qualquer demora na partida, e prejuízos daí derivados, correriam por conta de Brás Peres. Durante a viagem, os lucros dos negócios, bem como eventuais privilégios que a embarcação ou seu mestre tivessem, pertenciam ao afretador. As escalas a fazer seriam de responsabilidade do mercador, o qual, porém, não poderia obrigar o mestre a ir a ‘terra dos mouros’. Entretanto, apesar dos riscos referentes ao navio correrem por conta do seu dono, a Gaspar Montenamy eram conferidos alguns direitos sobre a tripulação. Depois de acordado o preço e jurado o contrato, estabeleciam-se as penalidades da sua violação.”

“Com pequenas alterações e adaptações são estas as cláusulas que figuram na maior parte dos contratos de fretes conhecidos, embora pudessem existir condições especiais para cada viagem, como seja o tempo de escala dos navios em cada porto. Mesmo no fretamento a dois mercadores, um de Santarém e outro de Setúbal, de baixel ‘Santiago’, inscrito na cidade do Porto, do qual era mestre João Ramalho, e datado de 18 de maio de 1386, que transportava trigo do Norte para Lisboa, o conteúdo do contrato não variava muito do referido.”

Sobre essa modalidade contratual quase milenar nos debruçamos neste capítulo.

16.2. Definição legal e noções

“Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas” (CC, art. 730), por meio terrestre, aquaviário ou aéreo.

Extraí-se dessa definição legal a existência de duas espécies contratuais, cuja distinção reside no objeto a ser deslocado: passageiros ou carga. Dentro dessa classificação, encontra-se outra que distingue a via na qual são superadas as distâncias de deslocamento – terrestre, aquaviária, aérea ou mista. Por sua vez, as vias podem ser agrupadas pelo tipo de veículo utilizado e pela distância percorrida dentro dos limites territoriais da nação.

A partir de 2002 os princípios comuns às duas espécies contratuais encontram-se dispostos no Código Civil (arts. 730-756). Trata-se de novidade legislativa porque até então não havia regulamentação acerca de transporte nos códigos brasileiros – civil ou comercial. A inclusão realizada pelo legislador civilista, unificando os princípios aplicáveis ao transporte em geral, decorre da evolução dos meios oferecidos, fruto do desenvolvimento humano e econômico experimentado pelo País nas últimas décadas, a partir de 1960.

O Código Comercial de 1850 é anterior à primeira estrada de ferro no Brasil inaugurada, em 30 de abril de 1854, por D. Pedro II – a Estrada de Ferro Mauá construída por Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá compreendendo 14,5 km de extensão “entre o Porto de Estrela, situado ao fundo da Baía da Guanabara e a localidade de Raiz da Serra, em direção à cidade de Petrópolis”. Era operada pela “Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis” (cf histórico relatado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – <http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp>).

Apresenta-se, assim, o motivo pelo qual o primeiro regulamento sobre transportes ocorre somente em 26 de abril de 1857, pelo Decreto n. 1.930, e refere-se ao transporte ferroviário (cf. Fran Martins, 1993:243).

Antes dessa data o transporte terrestre no Brasil era realizado por animais de carga

e, por esta razão, a Lei Imperial n. 556, de 25 de junho de 1850 – Código Comercial Brasileiro – regulamentava em vinte artigos (arts. 99-118), no Capítulo VI de sua primeira parte, sob o título “Dos Condutores de Gêneros e Comissários de Transportes”, o transporte de carga. Alguns princípios acerca da responsabilidade do condutor e sua duração foram mantidos pelas legislações que se seguiram, apesar de se referirem, entre outros institutos, a tropeiros, bestas e aparelhos, expressões que podem ser atualizadas para condutor, animais de carga e instrumentos necessários ao transporte, respectivamente.

16.3. Classificação jurídica

O contrato de transporte – de pessoas ou de coisas – é contrato *bilateral*, dele resultam obrigações para o transportador e para o passageiro e/ou titular da coisa a ser despachada.

É também contrato *oneroso*. O passageiro paga o preço da passagem e recebe o serviço de deslocamento, na forma estipulada no contrato; durante a execução do contrato tanto ele quanto o condutor devem sujeitar-se às normas do serviço e às indicadas nos diplomas estatais que regulamentam o serviço. De igual modo o expedidor da encomenda paga o frete, pelo qual o transportador se obriga a entregá-la ao destinatário por ele indicado.

Diz-se *consensual*, porque seu aperfeiçoamento ocorre tão logo as partes expressam sua vontade, concordando com seus termos. Dissente, contudo, a doutrina nessa matéria, diante do magistério de Carvalho de Mendonça (1956, 6:465) que classifica o contrato de transporte como contrato *real*. A afirmação do tratadista – “Ele é, também, real. Não se compreende o transporte sem uma pessoa ou coisa a transportar” – é acompanhada do ensinamento de mestres franceses e italianos – Lyon-Caen, Sarrut, Vidari, Vivante e Navarrini, entre outros – e fundamentada, ainda, em dois dispositivos legais que apontam para a natureza real do contrato: o art. 101 do Código Comercial: “A responsabilidade do condutor ou comissário de transportes começa a correr *desde o momento em que recebe as fazendas...*” e o art. 3º da Lei n. 2.681, de 1912: “A responsabilidade (das estradas de ferro) começará *ao ser*

recebida a mercadoria na estação pelos empregados...”.

Fran Martins (1993:245-246) rebate esse ensino afirmando que a entrega do objeto a ser deslocado “se refere à execução do contrato, equivalendo a dizer o Código que a responsabilidade do transportador quanto à guarda e conservação da coisa, guarda e conservação que lhe são impostas pelo art. 99 do Código só tem início *no momento em que a coisa lhe é entregue*”.

Concorda com esse posicionamento Orlando Gomes (2008:375), lembrando que o contrato de pessoas não admite “subordinar a conclusão do contrato a tal condição” (entrega da pessoa), razão que afastaria o contrato de transporte dos contratos reais. Entender o contrário conduziria a uma quebra de unidade quanto à natureza jurídica (seriam reais os contratos de transporte de carga e consensuais os de pessoas). Em um segundo fundamento o mestre invoca o princípio moderno do consensualismo (Gomes, 2008:375-376):

“Ademais, a categoria dos contratos reais é repelida na doutrina moderna por se chocar com o princípio moderno do consensualismo, dominante no direito contratual. Entende-se atualmente que o contrato de transporte, tanto de pessoas como de coisas, é consensual, tornando-se perfeito e acabado quando as partes cruzam suas vontades. No transporte de coisas a carga da mercadoria considera-se ato de execução do contrato, presumindo-se que seja o elemento decisivo do expedidor. As obrigações do transportador não surgem antes do recebimento das mercadorias, mas isso não impede a formação anterior do contrato, até porque ele contrai a obrigação de recebê-las”.

O contrato de transporte, ainda, não exige forma especial, é contrato *não solene*; diríamos, então, que ele é *simplesmente consensual*.

Finalmente, o contrato é *comutativo*, isto é, refere-se a coisas certas e determinadas, não se sujeitando a eventos futuros ou incertos, como ocorre com os contratos aleatórios.

James Siano (2006) completa o quadro da natureza jurídica e relaciona outros atributos ao contrato de transporte:

“O contrato de transporte se classifica como: a) bilateral, b) oneroso, c)

consensual, d) comutativo, e) não solene, f) paritário ou de adesão, g) nominal/típico, h) execução diferida e i) principal”.

Entretanto este autor lembra que, em regra, o contrato de transporte é *paritário* ou *de adesão*, inexistindo proibição de as partes fixarem cláusulas contratuais específicas.

Quanto a ser típico, de execução diferida e principal, James Siano expõe com clareza a matéria:

“O contrato de transporte é classificado atualmente como *nominal ou típico*, porquanto há previsão legal no ordenamento jurídico, no Código Civil, que o disciplinou expressamente, e no Código de Defesa do Consumidor, como de prestação de serviço.

[...]

Pode ser de *execução diferida*, pois nada impede que o cumprimento das obrigações possa ocorrer em momento distinto ao da contratação.

[...]

O contrato de transporte *será sempre principal*, existe por si só, independentemente de outro. Ressalva deve ser feita em relação ao transporte de bagagens de porte, que, no contrato de transportes de pessoas, é considerado como acessório”.

16.4. Espécies e estrutura legislativa

A partir das duas espécies contratuais reguladas no Código Civil – transporte de pessoas e de coisas – e das subespécies que levam em conta o meio, o tipo de veículo utilizado e a distância, podemos visualizar a complexidade da matéria:

Transporte de pessoas	• Terrestre: ferroviário e rodoviário. • Aquaviário: fluvial, marítimo e lacustre. • Aéreo.	Nacional: urbano, intermunicipal ou interestadual Internacional
Transporte de coisas	• Terrestre: ferroviário e rodoviário. • Aquaviário: fluvial, marítimo e lacustre. • Aéreo. • Multimodal.	Nacional Internacional

Para regulamentar a malha formada por tão distintos meios e modalidades de transporte, há, além dos dispositivos encontrados no Código Civil, inúmeros diplomas jurídicos, permanecendo em vigor a segunda parte do Código Comercial de 1850, relativamente ao Comércio Marítimo (arts. 457-796), à exceção do Título IX (arts. 731-739 – Do Naufrágio e Salvados).

A legislação esparsa é aplicável *subsidiariamente* às normas previstas no Código Civil, conforme disposto no art. 732: “Aos contratos de transportes, em geral, são aplicáveis, quando couber, *desde que não contrariem as disposições deste Código*, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais”. Dentro desse contexto, podemos resumir os principais diplomas aplicáveis aos contratos de transporte:

TRANSPORTE DE PESSOAS			
CLASSIFICAÇÃO CONFORME A VIA		DESLOCAMENTO	
ESPÉCIES	SUBESPÉCIES	NACIONAL	INTERNACIONAL
		• CF (art. 21, XII, e). • CF (art. 30, V). • CC (arts. 730-742).	• Decreto n. 5.462, de 9 de junho de 2005. • Decreto n. 2.975, de

Terrestre	Rodoviária	• Lei n. 13.640, de 27 de março de 2018. • Lei n. 13.785, de 27 de dezembro de 2018. • Decreto n. 19.473, de 10 de dezembro de 1930.	1º de março de 1999. • Decreto n. 99.704, de 20 de novembro de 1990.
	Ferroviária	• CF (art. 21, XII, <i>d</i>). • CC (arts. 730-742). • Decreto n. 2.681, de 7 de dezembro de 1912. • Decreto n. 1.832, de 4 de março de 1996.	
Aquaviária	Fluvial, Marítima e Lacustre	• CF (art. 21, XII, <i>d e f</i>). • CC (arts. 730-733 e 743-756) e CCom (arts. 457-796). • Lei n. 7.652, de 3 de fevereiro de 1998, com as alterações da Lei n. 9.774, de 21 de dezembro de 1998. • Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997. • Lei n. 9.537, de 11 de dezembro de 1997. • Lei n. 10.893, de 13 de julho de 2004.	• Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
Aérea		• CF (art. 21, XII, <i>c</i>). • CC (arts. 730-742). • Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986).	• Convenção de Varsóvia.
Mista		• CC (arts. 730-742)	

TRANSPORTE DE COISAS			
CLASSIFICAÇÃO CONFORME A VIA		DESLOCAMENTO	
ESPÉCIES	SUBESPÉCIES	NACIONAL	INTERNACIONAL
			• Decreto n. 5.462, de 9 de junho de 2005. • Decreto n. 1.866, de 16 de

Terrestre	Rodoviária	• CF (art. 21, XII, <i>e</i>). • CC (arts. 730-733 e 743-756). • Lei n. 11.442, de 5 de janeiro de 2007.	abril de 1996. • Decreto n. 2.975, de 1º de março de 1999. • Decreto n. 99.704, de 20 de novembro de 1990.
	Ferrovária	• CF (art. 21, XII, <i>d</i>). • CC (arts. 730-733 e 743-756). • Decreto n. 2.681, de 7 de dezembro de 1912. • Decreto n. 1.832, de 4 de março de 1996.	
Aquaviária	Fluvial, Marítima Lacustre ³ e	• CF (art. 21, XII, <i>d e f</i>). • CC (arts. 730-733 e 743-756) e CCom (arts. 457-796). • Lei n. 7.652, de 3 de fevereiro de 1998, com as alterações da Lei n. 9.774, de 21 de dezembro de 1998. • Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997. • Lei n. 9.537, de 11 de dezembro de 1997. • Lei n. 10.893, de 13 de julho de 2004.	• Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997.
Aérea		• CF (art. 21, XII, <i>c</i>). • CC (arts. 730-733 e 743-756). • Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986).	• Convenção de Varsóvia. • Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986).
Multimodal		• CC (arts. 730-733 e 743-756). • Lei n. 9.611, de 19 de fevereiro de 1998. • Decreto n. 5.276, de 19 de novembro de 2004. • Resolução ANTT n. 794, de 22 de novembro de 2004.	

Submetem-se, portanto, às regras do Código Civil toda a legislação especial brasileira, federal, estadual ou municipal e, ainda, os tratados e convenções internacionais assinados pelo Brasil. Entre estes, relevante é a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, com as modificações introduzidas pelos Protocolos Adicionais n. 1 e 2, assinados em Montreal, em 25 de setembro de 1975, e pelo Protocolo celebrado na Haia, em 28 de setembro de 1955, nos termos e ressalvas constantes no Decreto n. 2.860, de 7 de dezembro de 1998.

Para melhor compreensão, anotamos uma síntese da legislação indicada nos quadros:

a) Legislação Rodoviária:

- Lei n. 11.442, de 5 de janeiro de 2007 – Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei n. 6.813, de 10 de julho de 1980.

- Lei n. 10.561, de 13 de novembro de 2002 – Altera as Leis n. 10.209, de 23 de março de 2001, e 10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras providências.

- Decreto n. 5.462, de 9 de junho de 2005 – Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre, entre os Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina, da República da Bolívia, da República do Chile, da República do Paraguai, da República do Peru e da República Oriental do Uruguai, de 16 de fevereiro de 2005.

- Decreto n. 1.866, de 16 de abril de 1996 – Dispõe sobre a execução do Acordo sobre o Contrato de Transporte e a Responsabilidade Civil do Transportador no Transporte Rodoviário Internacional de Mercadorias, entre Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, de 16-8-65. Publicado no *DOU* de 17-4-96, p. 6.441/45.

- Decreto n. 2.975, de 1º de março de 1999 – Promulga o Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, celebrado entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas em 4 de julho de 1995.

- Decreto n. 99.704, de 20 de novembro de 1990 – Dispõe sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.

- Decreto n. 19.473, de 10 de dezembro de 1930 – alterado pelos Decretos n. 19.754/31, 20.454/31 e 21.736/32 – Regula os conhecimentos de transporte de mercadorias por terra, água ou ar, e dá outras providências.

b) Legislação Ferroviária:

- Decreto n. 2.681, de 7 de dezembro de 1912 – Regula a responsabilidade civil das estradas de ferro.

- Decreto n. 1.832, de 4 de março de 1996 – Aprova o Regulamento dos Transportes Ferroviários.

c) Legislação Marítima:

- Lei n. 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, alterada pela Lei n. 9.774, de 21 de dezembro de 1998 – Dispõe sobre o Registro da Propriedade Marítima e dá outras providências.

- Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997 – Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências.

- Lei n. 9.537, de 11 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional.

- Lei n. 10.893, de 13 de julho de 2004 – Dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante – FMM e dá outras providências.

d) Legislação Multimodal:

- Lei n. 9.611, de 19 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas e dá outras providências.

- Decreto n. 5.276, de 19 de novembro de 2004 – Altera os arts. 2º e 3º do Decreto n. 3.411, de 12 de abril de 2000, que regulamenta o Transporte Multimodal de Cargas, instituído pela Lei n. 9.611, de 19 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.

- Resolução ANTT n. 794, de 22 de novembro de 2004 – Dispõe sobre a habilitação do Operador de Transporte Multimodal, de que tratam a Lei n. 9.611, de 19 de fevereiro de 1998, e o Decreto n. 1.563, de 19 de julho de 1995.

16.5. Agências reguladoras

As agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, que exercem sua atribuição no âmbito de determinada área econômica, de forma independente em relação ao ente da administração direta e, para tanto, dispondo de autonomia financeira e funcional.

Arnoldo Wald e Luiza Rangel de Moraes (1999:146) identificam a dimensão poliédrica característica da agência reguladora: “a independência decisória, a independência de objetivos, a independência de instrumentos e a independência financeira”:

“A independência decisória consiste na capacidade da agência de resistir às pressões de grupos de interesse no curto prazo. Procedimentos para a nomeação e demissão de dirigentes, associados com a fixação de mandatos longos, escalonados e não coincidentes com o ciclo eleitoral são arranjos que procuram isolar a direção da agência de interferências indesejáveis tanto por parte do governo quanto da indústria regulada. A independência de objetivos compreende a escolha de objetivos que não conflitem com a busca prioritária do bem-estar do consumidor. Uma agência com um número pequeno de objetivos bem definidos e não conflitantes tende a ser mais eficiente que uma outra com objetivos numerosos, imprecisos e conflitantes. A independência de instrumentos é a capacidade da agência escolher os instrumentos de regulação – tarifas, por exemplo – de modo a alcançar os seus objetivos da forma mais eficiente possível. Finalmente, a independência financeira refere-se à disponibilidade de recursos materiais e humanos suficientes para a execução das

atividades de regulação”.

As agências têm por diretriz a implementação de políticas públicas em atividades de serviços públicos exploradas economicamente pela iniciativa privada, as quais passa a regular mediante expedição de normas de cunho técnico, exercício fiscalizatório de seu cumprimento e intervenção na busca de solução dos conflitos que surgem no âmbito de sua atribuição.

Este também é o ensino de Cláudio Mastrangelo (2005:67), citando Alexandre Santos de Aragão, ao afirmar que, “a partir da própria noção de regulação, extrai-se que as agências reguladoras devem desempenhar funções básicas, quais sejam, a de estabelecer normas, de fiscalizar, de aplicar sanções e de compor conflitos”.

Trataremos, de forma sucinta, das três agências reguladoras que atuam no âmbito do transporte no Brasil: a ANAC, a ANTT e a ANTAQ.

16.5.1. Agência Nacional de Aviação Civil

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi criada pela Lei n. 11.182, de 27 de setembro de 2005, para exercer função reguladora no âmbito da aviação civil. É pessoa jurídica de direito público, com independência administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato fixo de seus dirigentes. Organizada sob regime autárquico especial, encontra-se sediada no Distrito Federal e vinculada ao Ministério da Defesa.

O art. 3º dispõe sobre sua função primordial: observar, implementar orientações, diretrizes e políticas estabelecidas pelo Conselho de Aviação Civil – CONAC especialmente no que se refere a: I – a representação do Brasil em convenções, acordos, tratados e atos de transporte aéreo internacional com outros países ou organizações internacionais de aviação civil; II – o estabelecimento do modelo de concessão de infraestrutura aeroportuária, a ser submetido ao Presidente da República; III – a outorga de serviços aéreos; IV – a suplementação de recursos para aeroportos de interesse estratégico, econômico ou turístico; e V – a aplicabilidade do instituto da concessão ou da permissão na exploração comercial de serviços aéreos.

Das atribuições previstas no art. 8º da lei de criação, destacam-se as ora

ordenadas:

I – implementar, em sua esfera de atuação, a política de aviação civil;

(...)

IV – realizar estudos, estabelecer normas, promover a implementação das normas e recomendações internacionais de aviação civil, observados os acordos, tratados e convenções internacionais de que seja parte a República Federativa do Brasil;

V – negociar o estabelecimento de acordos e tratados sobre transporte aéreo internacional, observadas as diretrizes do CONAC;

VI – negociar, realizar intercâmbio e articular-se com autoridades aeronáuticas estrangeiras, para validação recíproca de atividades relativas ao sistema de segurança de voo, inclusive quando envolvam certificação de produtos aeronáuticos, de empresas prestadoras de serviços e fabricantes de produtos aeronáuticos, para a aviação civil;

VII – regular e fiscalizar a operação de serviços aéreos prestados, no País, por empresas estrangeiras, observados os acordos, tratados e convenções internacionais de que seja parte a República Federativa do Brasil;

VIII – promover, junto aos órgãos competentes, o cumprimento dos atos internacionais sobre aviação civil ratificados pela República Federativa do Brasil;

IX – regular as condições e a designação de empresa aérea brasileira para operar no exterior;

X – regular e fiscalizar os serviços aéreos, os produtos e processos aeronáuticos, a formação e o treinamento de pessoal especializado, os serviços auxiliares, a segurança da aviação civil, a facilitação do transporte aéreo, a habilitação de tripulantes, as emissões de poluentes e o ruído aeronáutico, os sistemas de reservas, a movimentação de passageiros e carga e as demais atividades de aviação civil;

XI – expedir regras sobre segurança em área aeroportuária e a bordo de aeronaves civis, porte e transporte de cargas perigosas, inclusive o porte ou transporte de armamento, explosivos, material bélico ou de quaisquer outros produtos, substâncias ou objetos que possam pôr em risco os tripulantes ou passageiros, ou a própria

aeronave ou, ainda, que sejam nocivos à saúde;

XII – regular e fiscalizar as medidas a serem adotadas pelas empresas prestadoras de serviços aéreos, e exploradoras de infraestrutura aeroportuária, para prevenção quanto ao uso por seus tripulantes ou pessoal técnico de manutenção e operação que tenha acesso às aeronaves, de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, que possam determinar dependência física ou psíquica, permanente ou transitória;

XIII – regular e fiscalizar a outorga de serviços aéreos;

XIV – conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços aéreos;

XV – promover a apreensão de bens e produtos aeronáuticos de uso civil, que estejam em desacordo com as especificações;

XVI – fiscalizar as aeronaves civis, seus componentes, equipamentos e serviços de manutenção, com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas de segurança de voo;

XVII – proceder à homologação e emitir certificados, atestados, aprovações e autorizações, relativos às atividades de competência do sistema de segurança de voo da aviação civil, bem como licenças de tripulantes e certificados de habilitação técnica e de capacidade física e mental, observados os padrões e normas por ela estabelecidos;

XVIII – administrar o Registro Aeronáutico Brasileiro;

XIX – regular as autorizações de horários de pouso e decolagem de aeronaves civis, observadas as condicionantes do sistema de controle do espaço aéreo e da infraestrutura aeroportuária disponível;

(...)

XXI – regular e fiscalizar a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, com exceção das atividades e procedimentos relacionados com o sistema de controle do espaço aéreo e com o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos;

(...)

XXV – estabelecer o regime tarifário da exploração da infraestrutura aeroportuária, no todo ou em parte.

16.5.2. Agência Nacional de Transportes Terrestres e Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Criadas pela Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) possuem função reguladora no âmbito do transporte terrestre – rodoviário e ferroviário – e no âmbito do transporte aquaviário, respectivamente. Ambas são pessoas jurídicas de direito público, com independência administrativa, autonomia financeira e funcional e mandato fixo de seus dirigentes. Organizadas sob regime autárquico especial, encontram-se sediadas no Distrito Federal e vinculadas ao Ministério dos Transportes.

O art. 20 define os objetivos da ANTAQ e da ANTT:

Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos Transportes Terrestre e Aquaviário:

I – implementar, em suas respectivas esferas de atuação, as políticas formuladas pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, pelo Ministério dos Transportes e pela Secretaria de Portos da Presidência da República, nas respectivas áreas de competência, segundo os princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei;

II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas de atribuições, as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, com vistas a:

a) garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas;

b) harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos usuários, das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, arbitrando conflitos de interesse e impedindo situações que configurem competição imperfeita ou infração da ordem econômica.

São atribuições específicas da ANTT as previstas nos arts. 24 (caráter geral), 25

(transporte ferroviário) e 26 (transporte rodoviário) dessa mesma lei, das quais se destacam os seguintes incisos:

Atribuição geral (art. 24):

I – promover estudos e pesquisas específicos de tráfego e de demanda de serviços de transporte;

II – promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos realizados;

(...)

VI – reunir, sob sua administração, os instrumentos de outorga para exploração de infraestrutura e prestação de serviços de transporte terrestre já celebrados antes da vigência desta Lei, resguardando os direitos das partes e o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos contratos;

(...)

VII – proceder à revisão e ao reajuste das tarifas dos serviços prestados, segundo as disposições contratuais, após prévia comunicação ao Ministério da Fazenda;

(...)

XI – promover estudos sobre a logística do transporte multimodal, ao longo de eixos ou fluxos de produção;

XII – habilitar o Operador do Transporte Multimodal, em articulação com as demais agências reguladoras de transportes;

XIII – promover levantamentos e organizar cadastro relativos ao sistema de dutovias¹⁰⁸ do Brasil e às empresas proprietárias de equipamentos e instalações de transporte dutoviário;

XIV – estabelecer padrões e normas técnicas complementares relativos às operações de transporte terrestre de cargas especiais e perigosas.

Atribuição no âmbito do transporte ferroviário (art. 25):

(...)

II – administrar os contratos de concessão e arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência desta Lei, em consonância com o inciso VI do art. 24;

(...)

V – regular e coordenar a atuação dos concessionários, assegurando neutralidade com relação aos interesses dos usuários, orientando e disciplinando o tráfego mútuo e o direito de passagem de trens de passageiros e cargas e arbitrando as questões não resolvidas pelas partes.

Atribuição no âmbito do transporte rodoviário (art. 26):

(...)

II – autorizar o transporte de passageiros, realizado por empresas de turismo, com a finalidade de turismo;

III – autorizar o transporte de passageiros, sob regime de fretamento;

IV – promover estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões, empresas constituídas e operadores autônomos, bem como organizar e manter um registro nacional de transportadores rodoviários de cargas;

V – habilitar o transportador internacional de carga;

VI – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de concessão de rodovias federais a serem exploradas e administradas por terceiros;

VII – fiscalizar diretamente, com o apoio de suas unidades regionais, ou por meio de convênios de cooperação, o cumprimento das condições de outorga de autorização e das cláusulas contratuais de permissão para prestação de serviços ou de concessão para exploração de infraestrutura.

As atribuições específicas da ANTAQ encontram-se no art. 27 da Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001, dos quais se destacam no interesse de nossos estudos:

I – promover estudos específicos de demanda de transporte aquaviário e de serviços portuários;

II – promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos

investimentos realizados;

(...)

VIII – promover estudos referentes à composição da frota mercante brasileira e à prática de afretamentos de embarcações, para subsidiar as decisões governamentais quanto à política de apoio à indústria de construção naval e de afretamento de embarcações estrangeiras;

(...)

XXI – fiscalizar o funcionamento e a prestação de serviços das empresas de navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário, fluvial e lacustre;

XXII – fiscalizar a execução dos contratos de adesão das autorizações de instalação portuária de que trata o art. 8º da Lei na qual foi convertida a Medida Provisória n. 595, de 6 de dezembro de 2012;

(...)

XXIV – autorizar as empresas brasileiras de navegação de longo curso, de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário, fluvial e lacustre, o afretamento de embarcações estrangeiras para o transporte de carga, conforme disposto na Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997.

16.6. Formação e prova do contrato

De índole consensual, o contrato se aperfeiçoa no momento em que as partes expressam concordância, acordo de vontades. Na prática isto ocorre quando o passageiro adquire a passagem e, no transporte de coisas, quando expedidor e transportador acertam o preço e as condições de remessa do objeto a ser deslocado.

A prova do contrato faz-se, essencialmente, pela apresentação do bilhete de passagem ou do conhecimento de transporte.

É possível a contratação de transporte de pessoas sem a emissão de bilhete de passagem, ou mesmo sua emissão ao portador e, ainda, o recolhimento do bilhete ao final da viagem, por meio manual ou eletrônico. Nesses casos, a demonstração de

existência de contrato ocorrerá por outros meios, podendo o passageiro valer-se de prova testemunhal ou outra que se mostrar disponível durante o trajeto (fotos, gravações ambientais em fitas de segurança etc.).

No contrato de transporte de coisas, realizado o consenso entre expedidor e transportador, este deve emitir o conhecimento de transporte com os requisitos exigidos pelos diplomas legais que tratam da matéria (v. item 7.3.4).

Esta modalidade contratual pode envolver as seguintes figuras: a) o expedidor, também chamado carregador ou remetente, é a pessoa que entrega a coisa ao condutor para ser transportada; b) o condutor ou transportador, pessoa que ocupa o outro polo da relação bilateral e tem a obrigação de levar a coisa até o destino, mediante pagamento realizado pelo primeiro; c) destinatário ou consignatário é a pessoa que deve receber a coisa remetida, podendo ser o próprio expedidor; d) comissário de transporte, quem se encarrega do transporte.

Dizemos que o contrato *pode* envolver todos os quatro mencionados porque basta a convergência de vontades do expedidor e do transportador para que o contrato se aperfeiçoe: o destinatário em regra não figura no contrato, salvo se for o próprio expedidor; o comissário de transporte (figura extinta substituída hodiernamente por agentes de viagens ou de expedição) somente participa da execução do contrato nos casos em que o transportador, não realizando o serviço, o contratar para executá-lo. É, portanto, terceiro a quem o transportador incumbe de executar o deslocamento da coisa contratada.

O *comissário de transporte* aparece como figura distinta da pessoa do *condutor* no art. 115 do Código Comercial: “os condutores e os comissários de transportes são responsáveis pelos danos que resultarem de omissão sua ou dos seus prepostos no cumprimento das formalidades da lei ou regulamentos fiscais em todo o curso da viagem, e na entrada no lugar do destino; ainda que tenham ordem do carregador para obrarem em contravenção das mesmas leis ou regulamentos”. No art. 35, n. 5, do Código Comercial o comissário de transporte aparece sob o título “agentes auxiliares do comércio” ao lado dos corretores, agentes de leilões, administradores de armazéns de depósito e outros.

Carvalho de Mendonça (1956, 6:471) o descreve com a seguinte afirmação: “Não é um comissário comum, e sim verdadeiro e próprio condutor, que assume a obrigação, não de efetuar diretamente o transporte, porém, de fazê-lo realizar por outros”. Verdadeiro intermediário entre o expedidor e o transportador; a função exercida pelo comissário de transporte é hoje realizada por outros profissionais: agentes de navegação, de expedição ou simplesmente agentes de transporte. Na relação com o expedidor é ele quem aparece e contrata; o Código Civil indistintamente denomina tanto o condutor como os que modernamente fazem as vezes de comissário de transporte por um único vocábulo: transportador. Pouco importa saber quem efetivamente fará a entrega: se o comissário que também é condutor ou a empresa transportadora encarregada pelo comissário. Perante o expedidor usuário do serviço a responsabilidade é solidária.

16.6.1. Bilhete de passagem

Bilhete de passagem é, portanto, o documento de emissão facultativa ou obrigatória, nos termos da legislação aplicável a cada espécie, que *legitima* o ingresso do passageiro em veículo de transporte, acompanhado de sua bagagem, em tamanho e peso previstos em regulamento.

Para as viagens aéreas, a emissão é obrigatória, como decorre do art. 227 da Lei n. 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Trata-se de título de crédito impróprio, assim chamado por incorporar certas qualidades cambiais, sem, contudo, ter a função própria de fazer circular riqueza. É, mais precisamente, um *título de legitimação* que confere ao seu portador o direito de ser conduzido pelo transportador, nas condições indicadas, ao destino por eles acordado.

Pupo Correia (1999:103) bem expressa a natureza dos títulos impróprios: “têm por função conferir ao seu possuidor a legitimação (ativa) para o exercício de certos direitos e, conseqüentemente, também conferem à outra parte a correspectiva legitimação passiva. Mas não têm por função própria a circulação, não se destinam a viabilizar e facilitar a transmissão de direitos, e, por isso, não são verdadeiros títulos

de crédito, muito embora não estejam impedidos de circular”.

16.6.2. Conhecimento de transporte

Conhecimento de transporte é *título representativo*, emitido à ordem – salvo cláusula expressa ao portador – por empresa de transporte aéreo, terrestre ou marítimo que concede a seu titular o direito ao transporte e de entrega do produto nele descrito.

Trata-se de título de crédito despidido de executividade por quantia certa (v. item 7.3). É chamado título representativo por ser causal, indicativo da coisa transportada.

16.7. Transporte de pessoas

Por este contrato o transportador obriga-se a conduzir pessoas e suas respectivas bagagens de um ponto a outro ponto geográfico, regendo-se por distintas normas, conforme o meio utilizado e o limite territorial percorrido. Há, assim, além das disposições do Código Civil (arts. 734-742), das leis e tratados internacionais, regulamentos baixados pelas agências reguladoras e, ainda, legislação nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional.

No âmbito municipal compete ao Município “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial” (CF, art. 30, V), resultando que toda a matéria concernente a essa modalidade de transporte deverá ser objeto de regulamentação local, em cada municipalidade.

Aos Estados são reservadas as competências que não lhes forem vedadas pela Constituição Federal, entre as quais se inclui a concessão de exploração de transporte coletivo intermunicipal.

As regras comuns aos contratos de transporte de pessoas estão previstas no Código Civil e podem ser resumidas nos seguintes princípios:

- Responsabilidade objetiva;
- Obrigação de transportar no tempo e modo contratados;
- Dever de obediência aos regulamentos;

- Proibição de recusa;
- Direito de desistência;
- Obrigação de concluir o itinerário;
- Direito de retenção;
- Responsabilidade solidária pelo transporte cumulativo.

Observe-se que esses princípios incidem sobre o contrato oneroso ou àquele do qual resultam vantagens indiretas ao transportador. O transporte gratuito não se subordina às normas do contrato de transporte (CC, art. 735), submetendo-se ao regime da responsabilidade civil subjetiva, conforme Súmula 145 do STJ: “No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave”.

Vejamos cada um desses princípios adotados pelo legislador do Código Civil:

a) Responsabilidade objetiva

O transportador de pessoas responde de forma objetiva pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens (CC, arts. 734-735). Essa responsabilidade somente se elide pela demonstração de motivo de força maior, como, por exemplo, eventos que ocorrem independentemente da supervisão e controle do transportador, como é o caso de roubo no interior de um veículo¹⁰⁹.

Situações prejudiciais aos passageiros, inerentes à atividade profissional do transportador, não podem ser arguidas a afastar o dever de indenizar, sob o pretexto de serem fortuitas. É o caso de um defeito mecânico, problemas técnicos ou de mal súbito sofrido pelo condutor do veículo que se relacionam à atividade empresarial do transportador e, como tal, não podem ser admitidas causas de força maior excludente de responsabilidade¹¹⁰.

A parte final do art. 734 inquina de nulidade cláusula excludente da responsabilidade de indenizar, o que já vinha reconhecido em entendimento sumular (Súmula 161 do STF: “Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não

indenizar”).

No tocante à bagagem, a lei faculta ao transportador exigir a declaração de seu valor no momento do embarque, com vistas à fixação do valor de eventual indenização. A recusa por parte do passageiro confere ao transportador o direito de recusar o contrato de transporte. Assim entende Cláudio Luiz Bueno de Godoy (2008:690).

b) Tempo e modo contratados

É obrigação do contratante fornecedor de serviço de transporte efetuar o itinerário no tempo e no modo contratados, respondendo por perdas e danos, inclusive de natureza moral, salvo motivo de força maior (CC, art. 737).

Alterações no percurso, venda de passagens acima da lotação permitida, atrasos na saída ou chegada e outras situações semelhantes conduzem à indenização pelos danos materiais que o passageiro vier a sofrer em virtude de alterações dessa natureza e, ainda, pelos danos morais. Estes se provam simplesmente pelo “fato externo que o originou e pela experiência comum”, na feliz expressão do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (STJ, REsp n. 241813/SP, v.u., j. 23-10-2001, *DJ*, 4-2-2002), isto é, não há necessidade de demonstrar outra ocorrência distinta da falta de cumprimento do itinerário ou horário previstos no bilhete de embarque, demonstrações que, isoladamente, bastam para a configuração do dano moral indenizável.

O Código Civil não estabelece uma medida de atraso ao sujeitar o transportador “aos horários e itinerários, sob pena de responder por perdas e danos” (CC, art. 737), transferindo aos Tribunais a tarefa de estabelecerem um tempo mínimo tolerável e de ponderarem o *quantum* indenizatório moral para o desconforto, desgaste físico e apreensões que o passageiro sofre com essas ocorrências.

O Código Brasileiro de Aeronáutica, de aplicação subsidiária ao Código Civil como já anotado, explicita nos arts. 230 e 231 um limite de 4 horas de atraso para o embarque ou interrupção ou atraso de viagem. Somente a partir desse período o transportador estaria obrigado a embarcar o passageiro em voo que ofereça serviço

equivalente para o mesmo destino ou a restituição do valor do bilhete de passagem, arcando, ainda, com transporte, alimentação e hospedagem do passageiro.

Esse limite encontrado pelo legislador aeronáutico não interfere no campo da responsabilização pelos danos causados, prevista no Código Civil, servindo apenas para autorizar a inclusão, no *quantum* indenizável, dos valores dos serviços impostos pelos arts. 230 e 231, se não forem realizados pronta e adequadamente pelas empresas prestadoras de serviço aéreo.

c) Dever de obediência aos regulamentos

O agir com civilidade no veículo de transporte é apresentado por verbos que indicam atitude de *sujeição* [sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador] e, em maior intensidade, *de abstenção* [abstendo-se de quaisquer atos que: (1) causem incômodo ou prejuízo aos passageiros; (2) danifiquem o veículo; ou (3) impeçam a execução normal do serviço].

Pressupõe-se que as normas estabelecidas visem à segurança, uma vez que transportar passageiros é atividade de risco, cabendo a todos contribuir para que acidentes e danos materiais e pessoais não ocorram. Três áreas são reforçadas com o dever de abstenção: a conduta social (não incomodar os passageiros), os bens patrimoniais (não causar prejuízo aos passageiros e ao veículo) e o adequado cumprimento do contrato de transporte (não impedir a execução normal do serviço).

A preocupação do legislador com essas áreas – segurança, urbanidade, proteção ao patrimônio próprio e de terceiros e contratual – apenas dá forma, como nos lembra Maria Helena Diniz (2008:519), ao princípio geral da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, *in verbis*: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Aquele que se dispõe a ser conduzido de um ponto geográfico a outro está ciente de que normas de segurança e de urbanidade deverão ser obedecidas e, assim, aderir ao contrato de transporte implica cumprimento de sua parte de certos deveres inerentes a esta modalidade contratual¹¹¹.

Se o passageiro, por transgressão das normas e instruções regulamentares,

contribui para evento que cause dano pessoal ou ao patrimônio da transportadora ou de terceiros, responde civilmente, podendo ser acionado judicialmente e obrigado a ressarcir os prejuízos sofridos pelas pessoas atingidas.

Não obstante, se esse evento também causar danos pessoais ou patrimoniais ao passageiro que transgrediu as normas regulamentares, a apuração do valor da indenização por ele pleiteada deverá ser *equitativamente* reduzida pelo juiz da causa, na medida em que houver concorrido para a ocorrência do dano. Importa acrescentar a essa disposição legal (CC, art. 738, parágrafo único) que se o evento danoso for imputado exclusivamente à vítima, a redução deverá ser integral, isto é, nenhuma indenização lhe é devida.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, mesmo havendo concorrência de culpa do passageiro, a obrigação do transportador permanece: “Transporte. Ônibus. Bagagem. Interrupção da viagem. Culpa da empresa. A empresa que não verifica as condições da bagagem quando da partida e impede o passageiro de seguir viagem no meio do trajeto, alegando que um aparelho de televisão estava mal acondicionado, cumpriu mal o seu contrato e por isso deve indenizar o dano para o qual concorreu. Recurso conhecido e provido” (REsp n. 475.261/MT, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 20-5-2003, DJ, 4-8-2003, p. 317). Neste acórdão o Relator assinala que os passageiros contribuíram para a interrupção da viagem:

“As duas partes agiram mal: os passageiros, por levarem em sua bagagem aparelho mal acondicionado; a empresa, por permitir que isso acontecesse e somente cuidasse de aplicar a lei quando a viagem estava a meio, impedindo que os autores concluíssem o percurso”.

“Evidentemente que essa situação, reconhecida no r. acórdão, significa que a empresa cumpriu mal a sua obrigação e prestou serviço defeituoso. É inaceitável que no meio da viagem de volta, iniciada dias antes, obrigue-se o transportado a desembarcar, por verificar que o pequeno aparelho de televisão não estava em caixa adequada para o transporte. Isso deveria ter sido verificado no início do trajeto; não acontecendo, o transtorno da interrupção decorreu de ato culposos da empresa.”

Há outros exemplos jurisprudenciais¹¹².

d) Recusa de passageiros

Não pode haver recusa de passageiros, salvo nos casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem (CC, art. 739).

Normas expedidas por autoridades sanitárias, administrativas, portuárias e judiciais regem as condições de embarque de passageiros, podendo, por exemplo, ser encontradas as emitidas pelo Juizado da Infância e Juventude, no que se refere a viagens de menores.

Outro exemplo: a Resolução n. 7, de 28 de fevereiro de 2007, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC –, determina que todos os passageiros de voos internacionais sujeitam-se a restrições no transporte de substâncias líquidas, incluindo gel, pasta, creme, aerossol e similares, nas bagagens de mãos, obrigando-os a conduzir os líquidos em frascos com medidas específicas. A resistência do passageiro em obedecer a essa norma é motivo justificado para recusa de embarque aéreo.

Além das hipóteses previstas em regulamentos, instruções, portarias e resoluções emitidas pelas autoridades, no interesse vinculado à área de sua atribuição administrativa ou competência judicial, o transportador e seus agentes podem fundamentar sua recusa em normas não escritas, em atenção ao próprio interessado ou a outros passageiros no que se refere aos requisitos de proteção, segurança, higiene, saúde e, até mesmo, de conforto. Indivíduo embriagado ou agindo de forma inconveniente ou, ainda, em trajes sumários; aparentando estar em fase ativa de doença infectocontagiosa (catapora, varíola, sarampo e outras); portador de doença grave, sem autorização médica; portador de doença psiquiátrica, sem acompanhamento adequado; ou, ainda, pessoa acompanhada de animal perigoso etc., devem e podem ser barrados ao embarque.

Recusas não justificadas ou comprovadamente discriminatórias podem dar ensejo a penalidades de ordem criminal e à obrigação de ressarcimento pelos danos sofridos pela pessoa que teve seu embarque recusado.

e) Direito de desistência

Este e o próximo item – conclusão de itinerário – tratam da rescisão do contrato por vontade do passageiro (CC, art. 740) e sua interrupção por motivo alheio à vontade do transportador.

Autoriza-se ao passageiro rescindir o contrato de transporte mesmo se já iniciada a viagem. Contudo, se a desistência se der *antes*, o passageiro terá direito à restituição do valor da passagem, *se a comunicação de desistência for feita em tempo de ser negociada*.

A expressão “em tempo de ser negociada” significa que o passageiro somente terá direito à restituição se sua manifestação de desistência ocorrer a tempo de possibilitar a revenda do bilhete, pelo transportador, a outro interessado. Esse período pode variar conforme a modalidade de viagem e se estabelece pela prática de mercado. Viagens de ônibus que ocorrem a cada dez minutos e viagens internacionais exigem prazos distintos para renegociação de seus bilhetes. O legislador impôs que esse prazo seja razoável, consoante a natureza do contrato firmado, mas não exigiu que a revenda do bilhete ocorresse efetivamente. Significa dizer que, se o passageiro respeitou prazo suficiente para a comunicação de seu arrependimento, pouco importa, para fins de restituição do valor pago, se o transportador efetivamente renegociou o bilhete.

Se o passageiro não embarcar, nem comunicar previamente sua desistência (ou mesmo se comunicar sua desistência a destempo), isto é, arrepender-se sem se dar ao trabalho de avisar o transportador, ainda assim terá direito à restituição. Neste caso, contudo, deverá provar que *outro passageiro* foi conduzido em seu lugar. Essa mesma solução é dada se a desistência ocorrer *depois* de iniciada a viagem, o passageiro terá direito à restituição do valor correspondente ao trecho não usufruído.

Nessas três situações, a restituição não é integral: o transportador tem o direito de reter até 5% (cinco por cento) da importância a título de multa compensatória.

Resumindo, temos:

MOMENTO			VALOR
---------	--	--	-------

DA RESILIÇÃO	CIRCUNSTÂNCIA	SOLUÇÃO	MINÍMO DE RESTITUIÇÃO
<i>Antes de iniciada a viagem.</i>	Houve comunicação em tempo oportuno.	O passageiro tem direito à restituição do valor do bilhete.	Valor da passagem menos 5%.
<i>Antes de iniciada a viagem.</i>	Não houve comunicação ou esta se deu em tempo não suficiente para a revenda do bilhete.	O passageiro tem direito à restituição do valor do bilhete, <i>se provar que outro passageiro viajou em seu lugar.</i>	Valor da passagem menos 5%.
<i>Depois de iniciada a viagem.</i>	Trecho ou trechos não foram utilizados pelo passageiro.	O passageiro tem direito à restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, <i>se provar que outro passageiro viajou em seu lugar.</i>	Valor do trecho não utilizado menos 5%.

f) Conclusão do itinerário

O transportador é obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo por sua conta as despesas de estada e alimentação da pessoa transportada, durante o período de espera (CC, art. 741).

O Código Civil não impõe limites temporais, isto é, não fixa o tempo de duração da interrupção da viagem e determina, caso ela ocorra “por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível”, a obrigatoriedade de conclusão do transporte contratado, arcando com as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

Essa disposição já estava presente no parágrafo único do art. 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica: “Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso de viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”.

Percebe-se, nesses dispositivos, a reafirmação da responsabilidade do

transportador pelos riscos da atividade, objetiva, independente de culpa, conforme clara expressão da lei, “ainda que em consequência de evento imprevisível”.

g) Direito de retenção

O exercício de direito de retenção sobre a bagagem e outros objetos pessoais do passageiro é garantido ao transportador e tem por objetivo fornecer meios de garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso (CC, art. 742).

Direito de retenção “consiste na guarda de coisa alheia em garantia enquanto não satisfeita, a favor daquele que a retém, obrigação lícita prevista na lei ou em contrato” (nesta obra, v. 3, item 19.6). É o direito que, nas espécies contratuais, ao lado do transportador, possuem o locatário sobre as benfeitorias úteis e necessárias (CC, art. 578), o depositário sobre o depósito para ressarcimento das despesas ou dos prejuízos sofridos (CC, art. 644), o comissário sobre os bens e valores em seu poder para reembolso das despesas adiantadas e pagamento das comissões (CC, art. 708) etc.

h) Responsabilidade solidária pelo transporte cumulativo

Transporte cumulativo é aquele realizado por distintos transportadores, obrigando-se cada um deles individualmente pelo percurso contratado.

Carvalho de Mendonça (1956, 6:547) o conceitua como “aquele em cuja conclusão e execução sucessiva participa mais de uma empresa de transporte”.

Em contratos assim estipulados, o transportador obriga-se solidariamente pelo resultado, isto é, responde primariamente pelo percurso assumido, mas, se ocorrer atraso, o dano devido aos passageiros ou ao titular da carga conduzida será determinado em razão da totalidade do percurso, mesmo que (o transportador) tenha ingressado na relação jurídica em substituição a outro contratante (CC, art. 733 e §§ 1º e 2º).

Percebe-se no contrato de transporte cumulativo a existência de um vínculo entre os vários transportadores, pelo qual cada um, ciente do destino final contratado, em

função de um único bilhete ou de um único conhecimento de transporte, responsabiliza-se pelo cumprimento de uma etapa representada por fração do percurso total. A *unidade da jornada* – contratada pelo passageiro que inicia a viagem ou pelo titular da carga que a entrega aos cuidados do transportador que dará início ao deslocamento solicitado – evidencia *unidade do contrato* e é por essa razão que *todos* os transportadores obrigam-se a levar o passageiro e/ou a mercadoria ao destino final, objeto de contratação.

A solidariedade passiva subsiste entre todos os transportadores pelo *resultado danoso* – atraso verificado no final da jornada ou dano ao passageiro ou à coisa transportada –, incluindo-se aqueles que substituíram os originalmente contratados, isto é, transportador que assume a tarefa em determinado trecho na posição inicialmente ocupada por outrem.

Esclarecidos os fatos e definido o momento da ocorrência do dano, o transportador que pagar o prejuízo pode acionar os demais pela parte ou pela totalidade do ressarcimento realizado. Se, por exemplo, o atraso ocorreu em alguns trechos ou se a avaria se deu no manuseio realizado numa das etapas da viagem, apurar-se-á a responsabilidade proporcional de cada um deles ou integral de um deles pelo resultado danoso.

Em resumo, os direitos, deveres e responsabilidades previstos no Código Civil, para o contrato de transporte de pessoas, são:

	DIREITOS	DEVERES	RESPONSABILIDADES
	• Exigir em ação de regresso, dos demais contratados em contrato cumulativo, o excesso suportado em pagamento de indenização (art.	• Transportar pessoas ao destino assumindo responsabilidade sobre os passageiros e suas	

TRANSPORTADOR

733).

- Exigir declaração de valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização (art. 734, parágrafo único).
- Estabelecer normas e fixá-las à vista dos usuários (art. 738).
- Recusar passageiros nos casos previstos em regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem (art. 739).
- Reter até 5% da importância a ser restituída nos casos de desistência manifestada pelo passageiro (art. 740, § 3º).
- Reter bagagem e outros objetos pessoais do passageiro para garantir-se do pagamento da

bagagens desde o início da viagem até a chegada ao destino (art. 734).

- No transporte cumulativo obriga-se a cumprir o trecho contratado (art. 733).
- Cumprir horários e itinerários previstos (art. 737).
- Em caso de interrupção por qualquer motivo, concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou com a anuência do passageiro, por modalidade diferente (art. 741).
- Transportar pessoas sem discriminação, não podendo recusá-los sem justificativa (art. 738).
- Reembolsar o passageiro nos casos de desistência e nas condições previstas na lei (art. 740).
- Transportar bagagens, sem adicional de preço, nos limites previstos em regulamento.

• Responde por dano (moral e material) causado aos passageiros e seus pertences ocorridos no percurso da viagem, salvo motivo externo de força maior (art. 734).

• No transporte cumulativo responde solidariamente perante o usuário e, regressivamente, perante os demais contratados pelo percurso contratado (art. 733).

• No caso de atrasos e descumprimento do itinerário, responde por perdas e danos, salvo motivo externo de força maior (art. 737).

• No caso de interrupção de viagem, durante a espera de novo transporte responde pelo pagamento das despesas de estada e alimentação dos passageiros (art. 741).

	passagem (art. 742).		
PASSAGEIRO	• Ser transportado, acompanhado de sua bagagem até o destino, sem outros acréscimos (arts. 730 e 734). • Ser indenizado em caso de atraso ou dano pessoal ou patrimonial sofrido durante a viagem (art. 734). • Rescindir o contrato antes de iniciada ou durante a viagem, recebendo, nas condições legais, o reembolso parcial da passagem (art. 740). • Ser consultado sobre proposta de prosseguir a viagem em veículo diferente, nos casos de interrupção (art. 741). • Ser	• Obedecer às normas da viagem, estabelecidas pelo transportador e pelas legislações regulamentares (art. 738). • Abster-se de atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros (art. 738). • Abster-se de atos que danifiquem o veículo (art. 738). • Abster-se de atos que impeçam a execução normal do veículo (art. 738). • Pagar o preço da passagem, sob pena de ter sua bagagem e pertences retidos pelo transportador (art. 742).	O passageiro não se sujeita a indenizar o transportador, salvo se tiver concorrido ao dano pela infração de normas e instruções regulamentares, ficando responsável civilmente perante o transportador e os demais passageiros. Sendo-lhe imputada culpa pelo evento e, dele resultar-lhe dano, o juiz reduzirá equitativamente a indenização na medida de sua contribuição (art. 738, parágrafo único). Evidentemente não poderá ser indenizado se ficar comprovado que é o único e exclusivo responsável pelo evento danoso.

	reembolsado das despesas de estada e alimentação, nos casos de interrupção ou atrasos (art. 741).		
--	---	--	--

16.8. Transporte de bagagem

O contrato de transporte de bagagem é sempre acessório do contrato de transporte de pessoas, sendo dele dependente, conforme lúcida exposição de Fran Martins (1993:290):

“O transporte de bagagem não forma contrato à parte do transporte de pessoas – na realidade, é um acessório deste, nele se integrando. Ao contratar o transporte, pagando o bilhete de passagem, o passageiro adquire o direito de fazer transportar consigo sua bagagem, e o condutor assume a obrigação de fazer este transporte. Não haverá outro preço para a bagagem, a não ser que, de acordo com o previamente fixado no regulamento da empresa transportadora, essa seja excessiva: excesso de peso, de tamanho, de volume etc. Nestas condições está o passageiro sujeito a pagar o transporte de excesso. O excesso, em tal caso, rege-se pelas normas do transporte de coisas”.

16.9. Transporte de coisas

No transporte de coisas, o transportador obriga-se a transferir objetos individualizados pelo expedidor, do ponto de expedição até determinado local ou endereço, mediante remuneração de frete.

16.9.1. Contrato de transporte regular e fretamento

Cumprir distinguir, inicialmente, o contrato de transporte regular de cargas e o contrato de fretamento, observando que ambos cumprem o papel de propiciar ao empresário o deslocamento de mercadorias de um ponto para outro ponto geográfico.

O primeiro identifica-se com o conceito geral; seu exercício é realizado pelas chamadas empresas transportadoras, e a obrigação de transferência de coisas (encomendas, mercadorias etc.) se realiza em terra, água, mar ou em todas essas vias, conforme sua especialização empresarial.

O segundo é denominado *contrato de fretamento* e envolve não apenas o serviço de transferência dos objetos expedidos ao destinatário, mas, além disso, o *uso* da própria embarcação, total ou parcialmente, para uma ou mais viagens. Esse contrato, por pressupor a necessidade de ocupação de um espaço no interior da embarcação por parte do expedidor, é operado diretamente por armadores de navios, empresas de navegação. Nesse tipo de contrato, denomina-se fretador quem dá e afretador quem recebe a embarcação a frete (CCom, art. 566).

Distinguem-se, segundo a Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997 (art. 2º, incisos I, II e III):

a) *afretamento por tempo*, que é o “contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada para operá-la por tempo determinado, sendo a remuneração do fretador estipulada *pro rata tempore*”;

b) *afretamento a casco nu*, definido como “contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação, sendo a remuneração do fretador estipulada *pro rata tempore*”; e

c) *afretamento por viagem*, “contrato em virtude do qual o fretador se obriga a colocar toda ou parte de uma embarcação armada à disposição do afretador para execução de serviços de transporte, em uma viagem, sendo a remuneração do fretador estipulada por um valor fixo”.

No fretamento (ou afretamento) o documento a ser expedido não é o conhecimento de transporte, mas a carta-partida ou carta de fretamento, regulada pelos arts. 567-574 do Código Comercial.

16.9.2. Regras comuns ao contrato de transporte de coisa

As regras comuns ao contrato de transporte de coisa estão igualmente previstas no

Código Civil e podem ser resumidas pelos termos:

- Identificação da coisa e do destinatário;
- Expedição de conhecimento de transporte;
- Recusa decorrente de faculdade contratual ou de obrigação legal;
- Faculdade de desistência e alteração do destinatário por parte do expedidor;
- Obrigação de zelar pela entrega;
- Responsabilidade solidária pelo contrato cumulativo.

São elas:

a) Identificação da coisa e do destinatário

O art. 743 exige que “a coisa entregue ao transportador deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço”.

A exigência de identificação da coisa a ser transportada e do nome e endereço do destinatário serve a, pelo menos, quatro propósitos básicos.

Primeiramente, serve para cumprir as exigências legais na emissão do conhecimento de transporte, conforme decorre dos diversos diplomas que tratam da matéria, nas distintas modalidades de transporte: terrestre (art. 2º do Decreto n. 19.413/30), marítimo (art. 575 do Código Comercial), aéreo (art. 235 da Lei n. 7.565/86) e multimodal (art. 10 da Lei n. 9.611/98).

Em segundo lugar porque dessa exigência decorre a limitação do valor devido em caso de avaria ou perda (CC, art. 750) e seus reflexos sobre relações com terceiros, como é o caso de depositário distinto do transportador e dos responsáveis no caso de transporte cumulativo (CC, art. 756).

Em terceiro lugar em razão de a lei prever casos de recusa no art. 746: risco à saúde das pessoas ou danos ao veículo e a outros bens. O transportador responde perante terceiros se a coisa que conduz vier a causar danos pessoais ou patrimoniais, pelo simples transporte ou por seu incorreto manuseio, razão pela qual pode exigir

que o expedidor preste declaração por escrito, discriminando as coisas a serem transportadas (CC, art. 744, parágrafo único).

Em quarto lugar, no que se refere ao nome do destinatário, a exigência visa permitir que a entrega da coisa se faça a pessoa certa. O art. 755 do Código Civil declara que o transportador deve obter instruções ao remetente, no caso de ter dúvidas acerca de quem seja o destinatário e, se isto não lhe for possível, “deve depositar a mercadoria em juízo”, acrescentando “se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, o transportador deverá vendê-la, depositando o saldo em juízo”. As soluções possíveis, apontadas pelo legislador, implicam custos e nem sempre são de rápida instrumentalização. A identificação, portanto, tem função prática: evitar entraves no momento da entrega, reduzir os riscos de litígio e tornar eficiente e econômico o cumprimento do contrato.

b) Expedição de conhecimento de transporte

O conhecimento de transporte é documento de expedição obrigatória (CC, art. 744) e prova o contrato realizado entre remetente e transportador. Estudamos anteriormente sua natureza e função jurídica (v. itens 16.6, 16.6.2 e 7.3.4) e os efeitos das declarações sobre o valor de indenização.

Para poder emitir o conhecimento de transporte sem erros, o transportador “pode exigir que o remetente lhe entregue, devidamente assinada, a relação discriminada das coisas a serem transportadas, em 2 (duas) vias, uma das quais, por ele devidamente autenticada, ficará fazendo parte integrante do conhecimento” (CC, art. 744, parágrafo único).

Preceito semelhante ocorre no Regulamento Ferroviário (Decreto n. 1.832, de 4 de março de 1996), ao dispor no art. 22 que “o expedidor é responsável pelo que declarar e sujeitar-se-á às consequências de falsa declaração”, autorizando a administração ferroviária a proceder à abertura dos volumes, para conferência.

Por essa razão, em caso de inexatidão ou falsidade, o expedidor responde por prejuízos causados ao transportador (CC, art. 745). Quais prejuízos? Os decorrentes do contrato e respectivo seguro e, ainda, os que decorram de indenizações que o

transportador venha a pagar em razão de prejuízos causados a terceiros, como por exemplo: o operário que, desconhecendo a periculosidade do conteúdo, venha a sofrer lesões; pessoas que se encontram nas proximidades do veículo que conduz gás altamente tóxico e são atingidas em virtude de vazamento proveniente de acomodação inadequada.

O dever de indenizar vem igualmente previsto na legislação sobre transporte multimodal de cargas (Lei n. 9.611, de 19 de fevereiro de 1998), que, no art. 21, detalha as causas de indenização: “perdas, danos ou avarias resultantes de inveracidade na declaração de carga ou de inadequação dos elementos que lhe compete fornecer para a emissão do Conhecimento”.

c) Recusa decorrente de faculdade contratual ou de obrigação legal

O transportador *pode* recusar o transporte se a encomenda, mercadoria ou carga estiver embalada de forma inadequada ou que coloque em risco a saúde das pessoas ou danifique o veículo e outros bens (CC, art. 746), bem como *deve* recusar transportar coisas não permitidas à comercialização, ao transporte ou desacompanhadas de documentação obrigatória (CC, art. 747), sob pena de responder com o infrator.

Observam-se nesses dois dispositivos casos distintos: o primeiro dispõe sobre *faculdade* de deixar de transportar e, o segundo, de *obrigação legal*. A este respeito o art. 115 do *Código Comercial* já estipulava a responsabilidade dos condutores e comissários de transporte “no cumprimento das formalidades das leis ou regulamentos fiscais em todo o curso da viagem, e na entrada do lugar do destino”, mesmo quando receberem “ordem do carregador para obrarem em contravenção das mesmas leis ou regulamentos”.

A desobediência ao dever legal de recusar implica responsabilidade do transportador perante os órgãos do Estado. No contrato de transporte multimodal de cargas, por exemplo, “o expedidor, o operador de transporte multimodal e qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal são responsáveis solidários, perante a Fazenda Nacional, pelo crédito tributário exigível” (Lei n.

9.611/98, art. 28).

d) Faculdade de desistência e alteração do destinatário por parte do expedidor

O remetente pode desistir do transporte ou, ainda, alterar o destinatário, sujeitando-se, contudo, às despesas e danos que acarretar (CC, art. 748).

A desistência ou arrependimento é caso de rescisão do contrato por ato unilateral do expedidor. No contrato de transporte de pessoas, a lei faculta ao passageiro interromper o trajeto mesmo quando já iniciada a viagem, recebendo de volta o valor referente ao trecho não percorrido, se demonstrar que outro passageiro ocupou o seu lugar. Esta clareza redacional não ocorre no transporte de carga.

A redação legal quanto ao arrependimento no contrato de transporte de carga permite duas interpretações. Podemos ler o artigo de duas formas distintas:

1ª) Até a entrega da coisa (*ao transportador*), pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando, em ambos os casos, os acréscimos de despesas decorrentes de contraordem, mais as perdas e danos que houver.

2ª) Até a entrega da coisa (*ao destinatário*), pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando, em ambos os casos, os acréscimos de despesas decorrentes de contraordem, mais as perdas e danos que houver.

A primeira sugere que arrependimento deve dar-se *antes da entrega da coisa ao transportador*, isto é, em momento anterior ao do início do deslocamento da mercadoria, encomenda ou carga. A redação do art. 748, com a expressão “*até a entrega da coisa*”, pode o remetente desistir do transporte”, permite concluir que o legislador refere-se à entrega da coisa *ao* transportador e não à entrega que o transportador faria ao destinatário. A leitura, neste caso, se faz a partir do conceito de entrega que se encontra no art. 743: “A coisa, entregue *ao* transportador, deve estar caracterizada [...]”.

Poder-se-ia pretender rejeitar esta primeira interpretação sob o argumento de que não teria sentido exigir do remetente “os acréscimos de despesa decorrentes da

contraordem, mais as perdas e danos que houver”, se a coisa permaneceu em seu poder. Se nada entregou, não haveria prejuízos ou danos porque o deslocamento não se iniciou. Observamos, contudo, que o transportador, a partir do consenso com o expedidor (o contrato é simplesmente consensual e não real – v. o item 16.3), pode ter realizado despesas, como, por exemplo, contratos com outros suboperadores, reserva de espaço ou de veículos para o deslocamento que não mais ocorrerá. Neste caso deverá ser indenizado.

Numa segunda interpretação, a leitura conduziria a se entender que o artigo indica a entrega da coisa *ao destinatário* e, neste caso, a solução se assemelha ao tratamento dado ao transporte de pessoas: o expedidor pode a qualquer tempo, *antes de entregar a coisa ao consignatário*, desistir da remessa e pode, ainda, alterar a quem se fará a entrega.

Esta segunda linha interpretativa é reforçada pela antiga redação da matéria prevista no art. 113 do Código Comercial, aqui transcrito com os convenientes parênteses elucidativos em razão dos termos arcaicos utilizados em 1850: “Variando o carregador (*o expedidor*), a consignação dos efeitos (*o local de entrega ou o destinatário das mercadorias*), o condutor (*o transportador*) ou comissário de transportes (*agente de expedição*) é obrigado a cumprir a sua ordem, recebendo-a antes de feita a entrega no lugar de destino”.

A redação dada pelo legislador de 1850 é, neste caso, superior ao do legislador de 2002 porque não permite dualidade interpretativa, deixando claramente disposto que o expedidor pode desistir e dar novas ordens ao transportador até o momento anterior à *entrega no lugar do destino*.

e) Obrigação de zelar pela entrega

O transportador é obrigado a realizar a entrega no prazo ajustado ou previsto, obrigando-se desde o momento que a receber a mantê-la em bom estado até o cumprimento junto ao destinatário, respondendo por perdas e avarias (CC, arts. 749 e 750). Facultativamente, o contrato pode prever cláusula de aviso ao destinatário ou de entrega em domicílio (CC, art. 752).

No caso de longa interrupção durante o trajeto o transportador é obrigado a buscar instruções do expedidor e agir conforme a situação exigir, ponderando quanto à responsabilidade pela descontinuação do transporte.

No impedimento *sem motivo imputável* ao transportador e, tendo o expedidor deixado de manifestar-se, abrem-se três caminhos ao condutor: (a) depositar a coisa em juízo; (b) vendê-la, depositando o valor correspondente e informando o remetente, e, ainda, (c) conservar o objeto em custódia, mediante remuneração previamente contratada ou, na sua falta de ajuste, segundo os usos adotados (CC, art. 753, §§ 1º e 4º).

Se, entretanto, o impedimento decorrer de *motivo imputável* ao transportador, este, dando aviso ao remetente, poderá depositar a coisa por sua conta e risco. A venda neste caso não é permitida, salvo se o produto transportado for perecível, em que, igualmente, se expedirá aviso ao remetente.

Esses quatro dispositivos – arts. 749, 750, 751 e 753 – tratam do modo como deve conduzir-se o transportador no trato da comissão que recebeu: deve fazê-lo com diligência e zelo (art. 749), durante todo o trajeto até a entrega, tomando cuidado de, não encontrando o destinatário, depositar a coisa em juízo (art. 750) ou armazená-la em seus depósitos (art. 751) e a proceder com boa-fé, discernindo adequadamente situações em que assume ter dado causa ao atraso ou daquelas em que a interrupção não lhe possa ser imputada (art. 753).

A crítica que se faz encontra-se no excesso de poder discricionário que o legislador entregou ao transportador: cabe a ele decidir ter dado causa ou não à interrupção e, ainda, faculta-lhe vender extrajudicialmente a coisa em seu poder.

Evidentemente, a quem muito se concede, muito deve ser exigido. Se o transportador, agindo de má-fé, vender a coisa transportada em situação não autorizada pelo legislador, responderá pelos prejuízos causados, com agravação em relação aos danos morais em razão de prática empresarial desprovida do conteúdo ético esperado pelo ordenamento jurídico.

O art. 754 impõe a obrigação de o destinatário conferir a coisa que lhe for

entregue, sob pena de decadência do direito de reclamar. Se os danos causados não forem perceptíveis desde logo, o direito de reclamar decai em dez dias.

Esse exíguo prazo refere-se à decadência do direito de reclamação, o que não impede, uma vez decorrido, que o interessado ingresse com ação condenatória por danos materiais e morais no prazo de prescrição previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) ou no Código Civil (art. 206, § 3º, V), conforme a regência do contrato submetido a exame.

Deve-se observar que quanto aos atrasos de entrega o transportador é responsável perante o consignatário e o expedidor, salvo se a coisa foi remetida em nome próprio. É possível que entre expedidor e destinatário haja relação de natureza mercantil (remessa de equipamento ou peça de maquinário requerida com urgência), vindo ambos a sofrer prejuízos pelo atraso: o destinatário, em decorrência de cessação de atividade industrial pelo não recebimento a tempo, e o remetente, pelo cancelamento do contrato pelo não cumprimento do prazo de entrega.

f) Responsabilidade solidária no contrato cumulativo

No contrato de transporte cumulativo, o transportador obriga-se solidariamente pelo resultado: o dano devido será determinado em razão da totalidade do percurso, permitido o direito de regresso de uns contra os outros (CC, art. 756). A este respeito remete-se ao comentário que se faz ao contrato cumulativo de transporte de pessoas (CC, art. 733, item 16.7, alínea *h*).

Em resumo, os direitos, deveres e responsabilidades previstos no Código Civil, para o contrato de transporte de coisas, são:

	DIREITOS	DEVERES	RESPONSABILIDADES
		• Emitir conhecimento de transporte (art. 744). • Recusar coisa cujo transporte ou comercialização não	

TRANSPORTADOR

- Exigir em ação de regresso, dos demais contratados em contrato cumulativo, o excesso suportado em pagamento de indenização (arts. 733 e 756).
- Exigir declaração assinada contendo relação discriminada das coisas a serem transportadas (art. 744).
- Ser indenizado pelos prejuízos que sofrer em caso de informação inexata ou falsa descrição sobre a coisa transportada (art. 745).
- Receber acréscimos de despesas e perdas e danos decorrentes de contraordem do remetente (art. 748).
- Depositar a coisa em juízo, vendê-la depositando o valor ou depositá-la, no caso de interrupção do transporte sem motivo imputável ao transportador (art. 753, §§ 1º, 3º e 4º).
- Depositar a coisa, por sua conta e risco, quando a interrupção do transporte lhe for imputável (art. 753,

sejam permitidos ou que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento (art. 747).

- Transportar a coisa ao destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado e previsto (art. 750).
- Depositar a coisa em juízo quando o destinatário não for encontrado (art. 750) e quando persistir dúvida sobre a quem entregá-la (art. 755).
- Dar aviso ao destinatário, quando convencionado (art. 752).
- Entregar a coisa no domicílio do destinatário, quando convencionado (art. 752).
- Solicitar instruções ao remetente em caso de interrupção do transporte (art. 753).
- Zelar pela coisa, mesmo em caso de interrupção do transporte, por cujo perecimento ou deterioração

- Responde por dano (moral e material) ocorrido no percurso do transporte, salvo motivo externo de força maior (art. 733).
- No transporte cumulativo responde solidariamente perante o usuário e, regressivamente, perante os demais contratados pelo percurso contratado (art. 733).
- Responde por danos a terceiros causados em decorrência do transporte de cargas (art. 745, por extensão).
- Responde perante as autoridades, inclusive as fiscais, pela falta do dever de recusar coisa cuja comercialização seja proibida ou esteja desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento (art. 747, por extensão).
- Responde por perda parcial ou avaria (art. 754, parágrafo único).

	§ 2º), não podendo, contudo, vendê-la, salvo se perecível.	responderá, salvo força maior (art. 753). • Entregar a coisa ao destinatário indicado no conhecimento de transporte (art. 754). • Na dúvida sobre a quem entregar a mercadoria e havendo risco de deterioração pela demora, o transportador deve vender a mercadoria, depositando o dinheiro em juízo (art. 755).	
REMETENTE	• Exigir uma via do conhecimento de transporte (art. 744). • Desistir da remessa (art. 748). • Alterar o destinatário (art. 748). • Estipular, mediante preço, que o transportador dê aviso ao destinatário ou faça a entrega em seu domicílio (art. 752). • Ser consultado e dar novas instruções nos casos de interrupção do transporte (art. 753). • Ser indenizado pelo transportador por prejuízos causados por atrasos, por reflexos de contrato	• Pagar o preço do transporte – frete (art. 730). • Dar informações corretas sobre a coisa a ser transportada (art. 743). • Quando solicitado, relacionar por escrito de maneira discriminada as coisas a serem transportadas, subscrevendo o documento (art. 744). • Embalar adequadamente a coisa a ser transportada (art. 747). • Abster-se de entregar para o transportador coisa	• Indenizar o transportador por prejuízos decorrentes de informações inexatas ou falsas (art. 745).

	mantido com o consignatário ou, ainda, por atrasos, avarias, perda parcial ou total quando for o próprio consignatário.	cuja comercialização não seja permitida (art. 747). • Apresentar, com a coisa a ser expedida, documentos que sejam exigidos por lei ou regulamento (art. 747).	
--	---	---	--

16.9.3. Contrato de transporte multimodal

Contrato multimodal de cargas “é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transportes, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal” (Lei n. 9.611/98, art. 2º).

O operador multimodal nem sempre é transportador, embora se obrigue a realizar serviços de transporte, contratando e subcontratando, quando necessário, empresas de transporte e outras, como, por exemplo, as de coleta, de armazém, de arrumação da carga etc. Isso ocorre porque sua obrigação compreende mais do que o simples ato de transportar, incluindo, ainda, “os serviços de coleta, unitização¹¹³, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega da carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive de consolidação e desconsolidação documental de cargas”¹¹⁴, conforme se depreende da leitura do art. 3º da Lei n. 9.611, de 19 de fevereiro de 1998.

Distintamente do que ocorre no contrato cumulativo, no contrato multimodal o operador contratado é o *responsável primário* pela execução dos serviços desde o recebimento da carga até sua entrega no destino, e pelos prejuízos decorrentes de perda, danos ou avaria. Os transportadores contratados ou subcontratados pelo operador de transporte multimodal podem, entretanto, ser acionados em ação regressiva para satisfação do valor da indenização que o operador vier a pagar em virtude de prejuízos causados ao expedidor.

Capítulo 17

CONTRATO DE SEGURO

Sumário: 17.1. Breves noções históricas. 17.2. Conceitos, noções e definições. 17.3. Legislação aplicável. 17.4 Características. 17.5. Formação e desenvolvimento contratual. 17.5.1. Emissão da apólice ou do bilhete de seguro 17.5.2. A boa-fé na formação do contrato. 17.5.3. Objeto da prestação. 17.5.4. Nulidade na formação do contrato. 17.5.5. Sujeitos da relação de seguro. 17.6. Direitos e obrigações das partes. 17.7. Espécies contratuais. 17.7.1 Seguro de dano. 17.7.2. Seguro de pessoa.

17.1. Breves noções históricas

Muitos institutos que conhecemos e estudamos no Direito Empresarial têm sua origem e desenvolvimento no comércio medieval. Assim, a letra de câmbio surge com o Código Savary, em 1673, dando impulso à criação de bancos e de contratos bancários (v. itens 2.1 e 14.1), as notas promissórias já eram utilizadas em período anterior a 1400 (v. item 3.1), o cheque e o contrato de comissão são utilizados mais frequentemente desde o século XVII (v. itens 4.2 e 13.2), a legislação sobre conhecimento de transporte retroage a 1293 (v. item 7.3.1).

Grande parte do desenvolvimento do comércio medieval é atribuído ao progresso da tecnologia jurídica do contrato de seguro e de sua desvinculação com a prática da usura, proibida pelas leis canônicas (cf. Filipe Themudo Baratta, 1998:174-175)¹¹⁵.

As origens históricas do seguro ligam-se à do contrato de transporte marítimo. António Menezes Cordeiro (2003:59) menciona legislação de D. Fernando, nono rei de Portugal (1315-1383), que “instituiu em Lisboa e no Porto uma bolsa, para a qual contribuíam todos os navios com mais de cinquenta tonéis e que serviria para acudir em caso de naufrágio”. Essa modalidade de contrato de seguro – socorro mútuo –, além de incentivar o desenvolvimento da indústria e do comércio marítimos,

fornecendo meios de reduzir os prejuízos decorrentes do risco da navegação, tinha por escopo garantir os navios, muitos pertencentes ao rei, que, assim agindo, transferia “para os outros proprietários uma parte dos riscos e dos custos de seus próprios navios” (Filipe Themudo Baratta, 1998:175)¹¹⁶.

Além dos contratos portugueses de mútuo, segundo Menezes Cordeiro (2003:545), surge a assunção de obrigação sobre o risco de terceiro, como cláusula acessória a um contrato principal: o transportador, majorando o valor do frete, comprometia-se a entregar a coisa transportada, independentemente do que viesse a ocorrer. As companhias seguradoras, assim entendidas as empresas constituídas para o fim de comercializar contratos de risco como conhecemos, são de concepção italiana, construídas igualmente no século XIV.

Atribui-se, entretanto, a um português, Pedro de Santarém Lusitano ou Petrus Santerna, a primeira obra doutrinária sobre seguros, publicada em 1542, o *Tractatus de assecurationibus & sponsionibus mercatorum nunc primum in lucem datus, cum repertorio & summarii*, específica sobre seguros marítimos¹¹⁷.

17.2. Conceitos, noções e definições

O contrato de seguro encontra-se definido no art. 757 do Código Civil brasileiro: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Definição que se completa no parágrafo único: “Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada”.

Encontramos neste dispositivo conceitos que precisam ser, desde logo, esclarecidos: prêmio, riscos e entidade legalmente autorizada.

Prêmio é a importância em dinheiro paga pelo segurado; é a contraprestação pecuniária a cargo daquele que pretende garantir-se na eventualidade de prejuízos sobre sua pessoa ou sobre seus bens.

Risco é a possibilidade de ocorrência de evento futuro e incerto prejudicial à

pessoa ou aos bens do segurado ou de terceiros beneficiários. O risco é inerente ao contrato e o segurador o assume no lugar do segurado, como Menezes Cordeiro (2003:544) prefere salientar: “No contrato de seguro, uma pessoa transfere para outra o risco de verificação de um dano, na esfera própria ou alheia, mediante o pagamento de determinada remuneração”.

Entidade legalmente autorizada refere-se à classe de pessoas jurídicas sujeitas à permissão de órgãos públicos federais para funcionamento no País. Mencionamos (v. v. 1, item 14.8.6) que “algumas sociedades, em razão de sua atividade ou origem, subordinam-se à obtenção de autorização para funcionamento, alteração ou modificação de seus atos de constituição. Assim ocorrendo, a autorização será outorgada sempre pelo Poder Executivo federal, e, uma vez concedida, salvo estipulação em contrário, obrigará o exercício das atividades até doze meses depois da publicação do ato autorizador”. Por força dos arts. 36 e 74 a 77 do Decreto-lei n. 73, de 21 de dezembro de 1966, as sociedades de seguros, resseguros, previdência e capitalização estão sujeitas à autorização legal e devem constituir-se sempre sob a forma de sociedades anônimas ou cooperativas (Decreto-lei n. 73/66, art. 24), sendo que as últimas somente podem operar em seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho. As seguradoras não podem explorar nenhum outro ramo de atividade empresarial, mas somente a cobertura securitária (Decreto-lei n. 73/66, art. 73).

Dessas considerações é possível extrair conceito mais preciso: contrato de seguro é aquele em que cooperativa ou sociedade anônima regularmente constituídas exclusivamente para esse fim e legalmente autorizadas pelo Poder Executivo federal obrigam-se, mediante o recebimento de retribuição em dinheiro, à *garantia de interesse legítimo do contratante, ou de terceiro por ele indicado*, contra eventos incertos e futuros, predeterminados em contrato.

A expressão grifada merece uma explicação. Poderíamos ser tentados a substituí-la por outra mais compreensível, como, por exemplo, “pagamento de *prejuízo* decorrente de eventos incertos e futuros”. A razão do uso daquela expressão “*garantia de interesse legítimo*”, escolhida pelo legislador, tem fundamento no fato de que no seguro de dano há *indenização por prejuízo*, mas, no seguro de pessoa (de

vida e de acidentes pessoais) não há essa função indenitária; quem o contrata não busca indenizar vida, morte ou perda pessoal, mas pretende obter prestação em dinheiro para uma necessidade futura eventual¹¹⁸.

Adotou o legislador brasileiro a teoria dualista – indenizatória para os seguros de dano e da necessidade eventual para os seguros de vida – entre as quatro conhecidas pela doutrina¹¹⁹.

17.3. Legislação aplicável

A legislação brasileira sobre seguros pode ser agrupada, para efeitos didáticos, segundo a principal matéria normatizada. Temos assim: (a) **sobre a profissão do corretor de seguros** a Lei n. 4.594/64; (b) **sobre os seguros marítimos**: arts. 666 a 748 do Código Comercial, à exceção dos arts. 731 a 739, que se encontram revogados, e Lei n. 8.374/91, que trata do seguro obrigatório de danos pessoais por embarcações ou por sua carga; (c) **sobre seguros agrários**: Lei n. 2.168/54; (d) **sobre os seguros privados**: o Decreto-lei n. 73/66, que dispõe sobre o sistema nacional de seguros privados e regula as operações de seguros e resseguros. Este diploma sofreu algumas alterações legislativas, sendo as mais recentes as introduzidas pela Lei n. 10.190/2001 e pela Lei Complementar n. 206/2007. Encontra-se regulamentado pelo Decreto n. 60.459/67; (e) **sobre os seguros obrigatórios de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT**, previstos no art. 20 do Decreto-lei n. 73/66: Decreto n. 61.867/67, com valores atualizados pelo Decreto n. 85.266/80 e pela Lei n. 6.194/74; (f) **sobre as sociedades de capitalização**: o Decreto-lei n. 261/67; (g) **sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde**: a Lei n. 9.656/98 e a Lei n. 10.185/2001, que dispõe sobre a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde; (h) **sobre a previdência privada**: a Lei Complementar n. 109/2001; (i) **sobre resseguros, retrocessão, cosseguros** e outros, a Lei Complementar n. 126/2007.

No Código Civil encontra-se a regulamentação do seguro de dano (arts. 778-788) e do seguro de pessoa (arts. 789-802), seguindo a tradição do Código de 1916 que regulamentou a matéria securitária nos arts. 1.432-1.476. À exceção dos arts. 1.466-

1.470, que tratavam do seguro de mútuo¹²⁰, os demais dispositivos do Código Civil de 1916 cobriam o mesmo universo que a codificação de 2002.

No que se refere aos seguros regidos por leis especiais – seguro obrigatório, marítimo, agrário etc. – a aplicação do regramento previsto nas disposições gerais civis sobre seguro (CC, arts. 757-776) é subsidiária ao que dispuserem as leis especiais. A dicção do art. 777 do Código Civil não deixa margem a dúvidas: “o disposto no presente capítulo aplica-se, no que couber, aos seguros regidos por leis próprias”.

17.4. Características

O contrato de seguro é bilateral, oneroso, aleatório, consensual e de adesão.

Bilateral. Diz-se bilateral porque as partes obrigam-se a prestações recíprocas: o segurado deve pagar o prêmio nas datas de vencimento e o segurador obriga-se ao pagamento da *indenização* devida em caso de ocorrência de dano ou do *capital* contratado.

Oneroso. É oneroso porque o contrato envolve vantagens de natureza patrimonial: cada contratante sujeita-se a pagar ao outro prestação em dinheiro.

Aleatório. O seguro sujeita-se a uma álea – acontecimento incerto e futuro –, que é a possibilidade de determinada situação indenizável vir a ocorrer. O risco é o objeto do contrato: não ocorrendo o evento, o segurador recebe o prêmio sem ter sido obrigado a desembolsar o valor estipulado; ocorrendo o evento, o segurado ou o terceiro beneficiário recebem a indenização ou o capital contratados.

Consensual. A consensualidade é sustentada por Orlando Gomes¹²¹, por Fábio Ulhoa Coelho¹²² e por Cláudio Luiz Bueno de Godoy¹²³. Em sentido contrário, Maria Helena Diniz¹⁰ prefere denominá-lo contrato formal.

Entendemos que o contrato é meramente consensual porque a apólice, o bilhete de seguro ou o documento de pagamento do respectivo prêmio servem apenas como elementos *probatórios* da existência do contrato, conforme deflui da redação do art. 758, que não exige solenidade na contratação do seguro. Recebendo o valor do

prêmio sem reclamação e, antes mesmo da emissão da apólice, obriga-se o segurador perante o segurado. A praxe de mercado dá força a esta afirmação. Em geral os contratos são consumados por via telefônica e o segurado recebe correspondência tão somente relativa às parcelas devidas. A apólice nem sempre é expedida pela seguradora ou, muitas vezes, somente chega ao segurado tempos depois da contratação¹²⁴.

De adesão. Destinado a um amplo mercado, o contrato de seguro é oferecido com cláusulas estabelecidas pelo segurador, cabendo ao pretendente ao seguro aceitá-las ou não e, rejeitando-as, ficar sem a cobertura pretendida. A apólice, contudo, não pode “conter cláusula que permita rescisão unilateral” ou “por qualquer modo subtraia sua eficácia e validade além das situações previstas em Lei” (Decreto-lei n. 73/66, art. 13). Na busca da segurança jurídica possível – pois estamos diante de um contrato aleatório – cabe ao segurador encontrar soluções que expressem razoabilidade, sob pena de declaração de abusividade e, conseqüentemente, sua nulidade.

Por se tratar de contrato de adesão, a seguradora deve provar que deu ciência das limitações impostas ao segurado no momento da contratação, sob pena de sua invalidação.

17.5. Formação e desenvolvimento contratual

O contrato se aperfeiçoa, como já estudado, com o simples consenso entre as partes: o interessado aceita as cláusulas do contrato e a seguradora declara-se satisfeita com as informações por ele prestadas.

17.5.1. Emissão da apólice ou do bilhete de seguro

A emissão da apólice é o passo seguinte, devendo ser precedida de proposta escrita, com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco (CC, art. 759). A emissão da apólice pode ser substituída pela expedição do bilhete de seguro.

A apólice e a sua forma reduzida, o bilhete de seguro, são títulos que instrumentam

o contrato de seguro e devem expressar necessariamente quatro cláusulas essenciais relativas: aos riscos assumidos, ao início e ao fim de sua validade, ao limite da garantia e ao prêmio devido. A emissão pode ser feita à ordem, nominativa ou ao portador, salvo no contrato de pessoas, ao qual se veda a emissão ao portador. Nesses últimos a apólice e o bilhete trarão, ainda, obrigatoriamente, o nome do segurado e do beneficiário.

No caso de cosseguros, a apólice deve indicar o segurador que administrará o contrato e representará os demais (CC, art. 761). Considera-se cosseguro a “operação de seguro em que duas ou mais sociedades seguradoras, com anuência do segurado, distribuem entre si, percentualmente, os riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas” (Lei Complementar n. 126/2007, art. 2º, II).

Além desses requisitos, nos contratos de seguro amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, impõe-se que as cláusulas restritivas sejam redigidas de modo a não “dificultar a compreensão de seu sentido e alcance” (CDC, art. 46), com “caracteres ostensivos e legíveis” (CDC, art. 54, § 3º) e “destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão” (CDC, art. 54, § 4º). Cláusulas restritivas em contrato de seguro que não obedeçam a esses princípios de transparência e de informação não subsistem em relação aos consumidores, vinculando, entretanto, a seguradora pelo que se obrigou.

17.5.2. A boa-fé na formação do contrato

O princípio da boa-fé objetiva tem seus contornos lapidados no contrato de seguro, tendo o legislador, sobreposto, ao princípio geral previsto no art. 422, o do art. 765, substituindo a expressão “probidade” por “veracidade” (CC, art. 765). Assim, a expressão “obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé” foi substituída pela obrigação de ambos os contratantes guardarem “a mais estrita boa-fé e *veracidade*, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Essa distinção aproxima o foco da conduta pretendida pelo legislador: a probidade requerida é detalhada com a exigência de veracidade dos dados que servirão para a

conclusão do contrato e à aceitação por parte de ambos os contratantes. Probidade é integridade de caráter e veracidade é o apego à verdade. Revela-se a conduta honesta das partes celebrantes por seu apego à verdade acerca dos elementos essenciais do contrato: objeto e circunstâncias e as declarações que os descrevem.

Clóvis Beviláqua (1975, 2:573) acentua que, no contrato de seguro, o requisito da boa-fé revela-se “com maior energia, porque é indispensável que as partes confiem nos dizeres uma da outra. Pela mesma razão, é posto em relevo, no seguro, o dever comum de dizer-se a verdade”.

A formação do contrato, por definição, pressupõe risco, isto é, a possibilidade de evento incerto e futuro capaz de ser objeto de contratação securitária. Se o risco não mais existe – é risco passado – como, por exemplo, a contratação sobre entrega de mercadoria que já ocorreu e o segurador tem ciência desse fato, age com má-fé e, como sanção, deve pagar em dobro, ao segurado, o prêmio estipulado ao contrato por eles celebrado.

Observe-se que o dispositivo que penaliza o segurador (CC, art. 773) menciona “pagar” e não o verbo “restituir”, significando que, além da simples restituição, ficará sujeito a entregar o equivalente ao dobro do valor que recebeu ou pretendia receber. A restituição decorre da nulidade do contrato por impossibilidade do objeto da contratação, mas o pagamento em dobro é pena pela má-fé do contratante. Restitui-se, portanto, o quanto o segurado pagou, em decorrência da nulidade, e, em razão do abuso, paga-se o equivalente ao dobro do valor do prêmio.

Dispositivo semelhante no Código Comercial declara nulo o contrato de seguro marítimo “sobre objetos que na data do contrato se achavam já perdidos ou salvos” (CCom, art. 677, n. 9), impondo, em caso de fraude do segurador, a condenação a “*retornar* o prêmio recebido, e a *pagar* ao segurado outra igual quantia” (CCom, art. 679). Nesta redação as duas ações – retornar e pagar – encontram-se corretamente empregadas, reforçando a interpretação que oferecemos ao art. 773 do Código Civil.

É a aplicação do princípio da boa-fé, igualmente considerado pelo legislador nas sanções impostas ao outro polo celebrante, ao qual se exige preste declarações exatas e não omita circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do

prêmio, sob pena de perder a garantia, obrigando-se a pagar o prêmio vencido (CC, art. 766).

17.5.3. Objeto da prestação

O objeto da prestação é sempre o pagamento de importância em dinheiro, salvo se as partes convencionarem a reposição da coisa (CC, art. 776). Permite esse dispositivo que as partes contratem outra forma de realização da obrigação do segurador. Não se trata de cláusula potestativa imposta ao segurado pelo segurador, mas de faculdade de ambos convencionarem a reparação da coisa danificada ou perdida.

Disposição semelhante se encontrava no art. 1.458 do Código Civil de 1916, sobre a qual Clóvis Beviláqua (1975, 2:586) traz o seguinte comentário: “Fica excluído qualquer outro modo de pagamento, mas não o desconto dos prêmios não pagos, e de empréstimos feitos por conta do valor do seguro. Embora, porém, a regra seja o pagamento em dinheiro, a apólice poderá estipular que, no caso de sobrevir dano ou a perda total, o ressarcimento se opere pela reparação ou reconstrução da coisa segura. Em matéria de seguro contra o fogo, por exemplo, o segurador estipula a faculdade de reedificar o prédio destruído pelo incêndio, nas condições que ele se achava anteriormente”.

17.5.4. Nulidade na formação do contrato

Sabemos que os casos comuns de nulidade dos negócios jurídicos (CC, art. 104) reportam-se à incapacidade dos agentes, à ilicitude, impossibilidade ou indeterminação do objeto e à desobediência quanto à forma (prescrita ou não defesa em lei).

Em relação à impossibilidade do objeto, vimos que o art. 773 do Código Civil penaliza o segurador quando contrata ciente de risco ocorrido.

Outra hipótese de nulidade é a de contrato de seguro que prevê a “garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro” (CC, art. 762). A nulidade, neste caso, igualmente atingindo o objeto,

refere-se à ilicitude. Não é lícita a contratação dessa garantia securitária porque o interesse manifestamente repousa sobre ato doloso de quem dele se aproveita (segurado, beneficiário ou de seus representantes).

Tullio Ascarelli (2001:306-307), dissertando sobre o interesse segurável, afirma, com toda propriedade, “é preciso que o beneficiário do seguro se encontre em situação tal que o sinistro se converta, para ele, em um dano, e, por isso, tenha interesse na *não ocorrência* do sinistro”. A esse princípio, que considera “fundamental na legislação e na prática”, o comercialista italiano denomina “esteio da instituição”:

“Se fosse possível segurar-se alguém, de um evento, a respeito de cuja verificação não tivesse um interesse contrário, o seguro não seria nem socialmente útil e nem mesmo tecnicamente possível, porque o beneficiário tornar-se-ia um provocador de sinistro para lucrar com a indenização.

[...]

Na praxe, aquele princípio costuma ser expresso na conhecida máxima de que o seguro não deve ser fonte de lucro para o segurado (beneficiário)”.

17.5.5. Sujeitos da relação de seguro

São sujeitos da relação de seguro: (a) o segurador, pessoa jurídica sob forma de sociedade anônima ou cooperativa, autorizada pelo Poder Executivo federal a exercer exclusivamente a atividade securitária, não podendo empregar-se em outras áreas empresariais; (b) o contratante do seguro, pessoa física ou jurídica que paga retribuição em dinheiro denominada prêmio à seguradora para ter garantido direito à indenização de prejuízos relativos a coisa ou ao pagamento de capital em eventos previstos nos seguros de pessoa. Em geral o contratante do seguro é o próprio segurado, podendo, contudo, ser pessoa que possui interesse indireto na contratação. Fábio Ulhoa Coelho (2007, 3:351) lembra o exemplo da mulher divorciada que contrata seguro sobre a vida de seu ex-marido para beneficiar o filho do casal.

Além dessas duas partes contratantes, suficientes para a conclusão de um contrato de seguro em que o interesse garantido pertence direta ou indiretamente ao próprio

segurado, outras pessoas podem constar da apólice de seguros, em razão de interesses diversos na formação ou no desenvolvimento do contrato. Temos, assim, os estipulantes, os beneficiários, os representantes das partes e os corretores de seguros.

a) Estipulantes

Nos contratos contratados à conta de outrem, surge a figura do estipulante, pessoa que contrata o seguro a favor de terceiros, podendo ele próprio figurar como beneficiário. Assim contratado o seguro, o segurador pode opor defesas contra os segurados fundado nas que tenha contra o estipulante (CC, art. 767).

Que defesas? As decorrentes da gestão do estipulante. Exemplos: se o estipulante deixou de repassar os prêmios à seguradora, caindo em mora, a seguradora pode recusar o pagamento de sinistro aos segurados; se o estipulante deixar de fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, impedindo a contratação em relação a alguns proponentes.

O estipulante integra necessariamente os contratos de seguros obrigatórios¹²⁵.

Nos seguros facultativos, firmados em apólices coletivas, o estipulante é representante dos segurados; em razão dessa função, por conflito de interesses, algumas pessoas são proibidas de figurar como estipulantes (Resolução do CNSP n. 107/2004, art. 2º): a) as corretoras de seguros, seus sócios, dirigentes, administradores, empregados, prepostos ou representantes; b) os corretores; e c) as sociedades seguradoras, seus dirigentes, administradores, empregados, prepostos ou representantes.

O § 3º do art. 21 do Decreto-lei n. 73/66 delegou ao Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP – a expedição de norma regulando os direitos e as obrigações do estipulante; estas últimas encontram-se fixadas pelo art. 3º da Resolução n. 107/2004, da CNSP. Por esta norma, cabe ao estipulante:

I – fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;

II – manter a sociedade seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos

segurados, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;

III – fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;

IV – discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, na forma estabelecida pelo art. 7º desta Resolução, quando este for de sua responsabilidade;

V – repassar os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;

VI – repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice, quando for diretamente responsável pela sua administração;

VII – discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da sociedade seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao seguro, emitidos para o Segurado;

VIII – comunicar, de imediato, à sociedade seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;

IX – dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;

X – comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado;

XI – fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido; e

XII – informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da sociedade seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em caractere tipográfico maior ou igual ao do estipulante.

b) Beneficiários

Beneficiária é a pessoa designada no contrato de seguro como credora da indenização ou do capital, podendo ser o próprio segurado ou terceiro que demonstre ter interesse sobre o objeto de contratação. No seguro de vida por morte do segurado, a esposa e os filhos podem figurar como beneficiários e receber o capital contratado na ocorrência de falecimento do chefe da família.

c) Representantes das partes

Os contratantes podem ser representados por procuradores que celebrarão o contrato em nome de seus representados. O estipulante é um desses representantes, por decorrência da lei, podendo existir os que se tornam mandatários dos contratos por mandato voluntário.

Além dos estipulantes e dos mandatários são considerados representantes do segurador os agentes autorizados (CC, art. 775). São agentes autorizados de seguros todas as pessoas que agem no interesse da seguradora na promoção e comercialização: podem ser corretores de seguros ou pessoas, com ou sem vínculo empregatício que atuam no mercado de seguros. Esta função, muitas vezes, é exercida por bancos que comercializam produtos securitários de seguradora do mesmo grupo econômico ou de outras seguradoras não ligadas a instituições financeiras, recebendo comissões pelo exercício dessa atividade.

d) Corretores de seguros

Os corretores de seguros têm sua profissão regulada pela Lei n. 4.594, de 29 de dezembro de 1964, que os define como “intermediários legalmente autorizados a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as sociedades de seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado (art. 1º)”.

Figuram os corretores de seguro dentre outros legalmente designados como corretores:

- Corretores de mercadorias, anteriormente nomeados por ato das Juntas Comerciais na vigência da anterior Lei de Registro de Comércio (Lei n. 4.726/65, art

10, III), a quem competia fixar o número, processar a habilitação e a nomeação, fiscalizar, punir, exonerar os tradutores públicos e intérpretes comerciais, leiloeiros, avaliadores comerciais, corretores de mercadorias e os prepostos ou fiéis desses profissionais. Com a revogação da Lei n. 4.726/65, expressa no art. 67 da Lei n. 8.934/94, que introduziu o registro público das empresas mercantis, sem que houvesse menção aos corretores de mercadorias entre os agentes sujeitos à matrícula (art. 32, I), estes perderam essa condição, não mais estando sujeitos às Juntas Comerciais;

- Corretores de navios – intermediários nas negociações com transportes marítimos, fretamentos, seguros marítimos e outras atividades ligadas a navios – que eram nomeados por atos do Presidente da República e se sujeitavam às administrações das alfândegas para o exercício de seu mister. O Decreto n. 5, de 4 de abril de 1966, retirou-lhes a exclusividade de seu exercício, permitindo que suas atribuições pudessem ser exercidas por armadores e seus prepostos;

- Corretores de valores mobiliários têm por função: (1) operar na Bolsa de Valores e seu exercício é realizado sempre por sociedades registradas previamente no Banco Central do Brasil, nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei n. 4.728/65, mediante prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários (art. 16 da Lei n. 6.385/76) quando operarem a distribuição de emissão no mercado; (2) a compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria e quando exercerem a mediação ou corretagem na Bolsa de Valores.

Todas essas profissões pressupõem a existência de um contrato de corretagem cujo objeto é:

- a) A execução de mediação de negócios, sem vínculo de mandato, de prestação de serviços ou relação de dependência (CC, art. 722);

- b) A prestação de informações sobre o andamento dos negócios e de esclarecimentos acerca da segurança ou risco dos negócios, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência (CC, art. 723);

- c) O pagamento de remuneração somente quando ocorre o resultado previsto no contrato de mediação ou, em virtude de arrependimento das partes (CC, art. 725).

Acertadamente, Maria Helena Diniz (2007, 3:443) lembra que o objeto do contrato “não é propriamente o serviço prestado pelo corretor, mas o resultado desse serviço”.

Verifica-se, pois, que, essencialmente, o contrato de corretagem envolve mediação, aconselhamento e resultado.

17.6. Direitos e obrigações das partes

No Código Civil encontram-se as disposições gerais sobre os direitos e obrigações dos contratantes de seguros, que podem ser resumidos nos seguintes quadros:

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SEGURADOR		
DIREITOS	Receber o prêmio contratado, nas datas de vencimento, mesmo quando o segurado tiver prestado informações inexatas ou omitido circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou taxa do prêmio.	Arts. 757, 763 e 766.
	Recusar indenização ao segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio.	Art. 763.
	Resolver o contrato ou cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença de prêmio na hipótese de se comprovar inexistir má-fé do segurado na inexatidão ou omissão nas declarações prestadas à contratação.	Art. 766, parágrafo único.
	Opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante.	Art. 767.
	Dar aviso de sua decisão de resolver o contrato, em até quinze dias após receber do segurado o aviso de agravamento de risco.	Art. 769, § 1º.
	Garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, assumindo no cosseguro a proporção do risco assumido.	Arts. 757 e 761.
	Emitir apólice de seguro.	Art. 759.
	Guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações	Art. 765.

OBRIGAÇÕES	a ele concernentes.	
	Rever o valor do prêmio se a redução do risco for considerável.	Art. 770.
	Pagar, no limite fixado em contrato, as despesas de salvamento consequente ao sinistro.	Art. 771, parágrafo único.
	Atualizar monetariamente a indenização, por índices oficiais, e pagar juros, quando incidir em mora.	Art. 772.
	Pagar em dobro o prêmio na expedição de apólice quando já ciente de que o risco era passado.	Art. 773.
	Pagar em dinheiro o prejuízo do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa.	Art. 776.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (OU SEGURADO)		
DIREITOS	Ser garantido contra riscos predeterminados incidentes sobre sua pessoa ou coisa.	Art. 757.
	Receber apólice, bilhete ou documento comprobatório do pagamento de seguro.	Arts. 758-760.
	Receber indenização na ocorrência de sinistro, em dinheiro, salvo se convencionada a reposição da coisa.	Arts. 763 e 776.
	Exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato no caso de redução considerável de risco.	Art. 770.
	Receber indenização atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios na hipótese de ocorrência de mora no pagamento de sinistro por parte do segurador.	Art. 772.
	Receber em dobro o valor do prêmio quando a expedição de apólice se deu	Art.

	quando o risco era passado e o segurador tinha conhecimento dessa circunstância.	773.
OBRIGAÇÕES	Pagar o prêmio estipulado, até a data de vencimento, mesmo se não se verificar o risco, em previsão do qual se faz o seguro.	Arts. 757, 763 e 764.
	Guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.	Art. 765.
	Prestar declarações exatas e não omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio. Sujeitando-se, neste caso, ao pagamento do prêmio vencido.	Art. 766.
	Não agravar o risco objeto do contrato.	Art. 768.
	Comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto.	Art. 768.
	Comunicar ao segurador o sinistro logo que o saiba.	Art. 771.
	Tomar as providências imediatas para minorar as consequências de sinistro sofrido.	Art. 771.

Além desses, o Enunciado do CJF n. 542, redigido na VII Jornada de Direito Civil a analisar o disposto nos arts. 765 e 796 do Código Civil, entendeu que “a recusa de renovação das apólices de seguro de vida pelas seguradoras em razão da idade do segurado é discriminatória e atenta contra a função social do contrato”.

17.7. Espécies contratuais

Duas espécies contratuais são regulamentadas no Código Civil – o seguro de dano e o seguro de pessoa. Legislação extravagante trata de outras modalidades de seguro:

obrigatório de automóveis, marítimos, agrários, mútuo etc.

Seguro de dano ou de coisas, delineado nos arts. 778-788 do Código Civil, é o contrato que visa garantir proteção ao contratante contra riscos predeterminados relativamente às coisas de seu patrimônio. Nesta modalidade o segurador obriga-se a pagar indenização se o dano vier a ocorrer.

Seguro de pessoa, regulado pelos arts. 789-802, é aquele em que o contratante desembolsa determinada retribuição pecuniária a companhia seguradora que, em contrapartida, obriga-se a pagar – ao contratante ou a terceiros indicados como beneficiários – importância de capital ou de renda em ocorrendo evento contratualmente previsto.

Seu tratamento distinto, além das funções a que se destinam, é identificado na obrigação garantida pelo contrato: no seguro de danos o segurador obriga-se ao pagamento de *indenização* por dano à coisa, e no seguro de pessoa obriga-se ao pagamento de *capital ou de renda* em decorrência de evento relacionado à vida ou à integridade física de ser humano.

Há outras distinções, objeto de estudo nas duas próximas seções.

17.7.1. Seguro de dano

Na formação do contrato de seguro de dano, entre as declarações que o pretendente deve fazer encontra-se a relativa ao valor do interesse segurado, isto é, a importância pela qual entende deva ser indenizado no caso de avaria, perda total da coisa ou prejuízos suportados por terceiro em razão do sinistro envolvendo o bem segurado.

Dois princípios regem o valor da garantia: a *equivalência* com o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato e a *boa-fé* que exige que o segurado faça declarações exatas e não omita circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta.

Culposa ou dolosamente é possível que o titular do interesse segurado declare valor superior ou inferior ao estimado pelo mercado.

No primeiro caso – a declaração de valor superior ao valor estimado no mercado

–, a adequação será feita no momento da indenização, incidindo o disposto no art. 781 do Código Civil: *a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro*; o segurado receberá o valor que o bem é estimado no mercado.

Qual é a razão de a lei não permitir que o segurado faça seguro por valor superior ao que a coisa vale?

Segundo magistério de Clóvis Beviláqua (1975, 2:568) “quem assegura uma coisa por mais do que valha, desnatura o contrato de seguro, e faz presumir a intenção dolosa de lucrar o seguro pelo sacrifício do objeto segurado”.

O seguro tem a função de proteger o titular de um sinistro, isto é, de *fato eventual produtor de dano* (cf. Beviláqua, 1975, 2:570), e, que, por conceito, resulta sempre de força maior ou caso fortuito. Se o valor do seguro pudesse ser superior ao valor da coisa segurada, o segurado teria interesse na ocorrência do sinistro e atuaria contrariamente à justa intenção da contratação. No contrato de seguro presume-se que o segurado sempre tem interesse na não ocorrência do sinistro; é o princípio fundamental dessa modalidade contratual, conforme ensino de Tullio Ascarelli (2001:306-307).

Pode ocorrer que a pretensão à contratação de garantia superior se dê com outro segurador, na vigência de um contrato de seguro. Neste caso, o segurado deve previamente comunicar sua intenção ao primeiro segurador, fazendo-o por escrito e indicando a soma que pretende segurar-se, para que a garantia não ultrapasse o valor do interesse segurado e venha a acarretar sua perda na hipótese de se verificar má-fé do segurado (CC, art. 766, parágrafo único).

No segundo caso – declaração por valor inferior – a pretensão do segurado pode situar-se, culposamente, na ignorância sobre o valor de mercado ou, dolosamente, visando à redução do valor do prêmio.

Ocorrendo perda total, o segurado receberá o valor de garantia, e, no sinistro com perda parcial, proporção equivalente à avaria sofrida em relação ao valor total de garantia (CC, art. 783). Por exemplo: o segurado, para um bem estimado em R\$

100.000,00, contrata a garantia em R\$ 80.000,00. Ocorrendo perda total, receberá o valor segurado – R\$ 80.000,00 – e, se a perda for parcial, digamos, 50% da coisa segurada, receberá R\$ 40.000,00.

Evita-se, com a adequação proporcional, o enriquecimento sem causa por parte do segurado que tendo pago por um limite de garantia receba exatamente quantia proporcional ao que pagou.

A respeito do seguro por danos outras questões foram disciplinadas pelo Código Civil e referem-se à: (a) abrangência da indenização; (b) exclusão de sinistro; (c) vigência do seguro no contrato de transporte de coisas; (d) aplicação dos institutos da cessão e da sub-rogação ao contrato de seguros; (e) perdas e danos no seguro de responsabilidade civil.

a) Abrangência da indenização

O risco do seguro compreende todos os prejuízos resultantes ou consequentes: os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar os danos ou salvar a coisa (CC, art. 779).

Prejuízos resultantes são os que derivam diretamente do sinistro; consequentes são os estragos ocasionados pelos meios utilizados para contê-lo, minorar os danos ou salvar a coisa. São exemplos: os estragos causados pela água utilizada para conter o incêndio; a remoção da coisa a um lugar seguro; a parede ou o muro destruídos para salvar a coisa que não podia ser alcançada pelas serventias regulares etc.

b) Exclusão de sinistro

Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado (CC, art. 784). Decorre essa disposição do fato de a garantia securitária prevenir a possibilidade de dano oriundo de circunstâncias externas à coisa segurada.

Danos por “defeito próprio da coisa que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie” (CC, art. 784, parágrafo único), desconhecidos da seguradora, alteram substancialmente a análise dos riscos assumidos e se inserem no campo das

omissões que *podem acarretar* a perda do direito de garantia.

Dizemos “podem acarretar” porque é imperativo indagar se a falta de declaração por parte do segurado resulta de omissão deliberada ou de ignorância do fato. No primeiro caso, a pena de perda de garantia resulta da violação do princípio da boa-fé e veracidade; no segundo caso, o segurador tem direito de resolver o contrato antes da ocorrência do sinistro ou cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Ambas as soluções decorrem do disposto no art. 766 do Código Civil.

c) Vigência do seguro no contrato de transporte de coisas

No contrato de transporte de coisas a garantia securitária tem início no momento em que a coisa é recebida pelo transportador e cessa com a sua entrega ao destinatário (CC, art. 780), compreendendo, portanto, recebimento, interrupções, atrasos, manuseio e armazenamento.

Inspira-se o legislador de 2002 no art. 706 do Código Comercial, que disciplina os limites temporais da vigência dos riscos no contrato de transporte intermodal:

“Fazendo-se seguro sobre fazendas a transportar alternadamente por mar e terra, rios ou canais, em navios, barcos, carros ou animais, os riscos começam logo que os efeitos são entregues no lugar onde devem ser carregados, e só expiram quando são descarregados a salvamento no lugar do destino”.

Outra poderia ser a solução legislativa, como, por exemplo, considerar o efetivo início da jornada, como ocorre com o contrato exclusivamente marítimo (CCom, art. 702). O Código Civil prestigiou, entretanto, o princípio da unidade conceitual, uma vez que, ao regular contrato de transporte de coisas, fixou o início da responsabilidade do transportador “no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado” (CC, art. 750). Dispor responsabilidade distinta ao segurador, dando-a por iniciada em momento posterior à entrega pelo expedidor, implicaria admitir período sem cobertura securitária para a coisa transportada.

d) Aplicação dos institutos da cessão e da sub-rogação

Aplica-se aos contratos de seguro a cessão a terceiro, desde que não seja proibida pelo contrato, devendo ser feita segundo a modalidade de emissão da apólice ou do bilhete de seguro: (1) na emissão ao portador, a transferência se dá pela simples tradição; (2) se a emissão é nominativa, a seguradora deve ser comunicada por aviso escrito subscrito pelo segurado e pelo cessionário; (3) quando emitido à ordem, o documento deve ser endossado em preto, datado pelo endossante e pelo endossatário.

Sub-rogação é a assunção dos direitos de crédito por aquele que satisfaz a dívida, podendo operar-se por convenção (CC, art. 347), de pleno direito (CC, art. 346) ou por força de lei, como é o caso do contrato de seguro (CC, art. 786).

Ocorre a sub-rogação ao segurador dos direitos creditórios e ações correspondentes que o segurado teria contra o autor do dano. Evidentemente, salvo dolo, a sub-rogação não ocorrerá se o dano tiver sido causado por pessoa que mantém laços de consanguinidade ou afinidade com o segurado.

e) Perdas e danos no seguro de responsabilidade civil

Duas modalidades de seguro de responsabilidade civil são apreciadas nos arts. 787 e 788: o primeiro refere-se ao contrato facultativo e, o segundo, ao chamado seguro obrigatório.

No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento por perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, conforme redação do *caput* do art. 787 do Código Civil. Não se distinguem os danos, que podem ser materiais (emergentes ou efetivos e o lucro cessante) ou morais, sendo devidas *todas as perdas e danos* havidas pelo terceiro, salvo se o contrato contiver cláusula limitativa de fácil leitura e compreensão e em destaque.

O seguro de responsabilidade civil visa dar garantia ao segurado, ocorrendo, com o contrato, a transferência dos riscos à seguradora. Contudo, a responsabilidade pelos atos que causam dano a terceiros é primariamente do agente que lhes dá causa. Por esta razão, se a seguradora tornar-se insolvente, persiste a responsabilidade do segurado pelos prejuízos a terceiros, decorrentes de atos de responsabilidade civil.

Algumas obrigações foram deixadas a cargo do segurado: (1) **dever de**

comunicação: O segurado deve dar aviso à seguradora em dois momentos: logo que saiba de fato que possa acarretar-lhe responsabilidade incluída na garantia securitária e no momento em que tomar conhecimento de ter sido acionado em ação por indenização coberta por segurado; (2) **dever de abstenção de ato:** ao segurado é proibido reconhecer sua responsabilidade, confessar a ação, transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.

No seguro de responsabilidade legalmente obrigatório, como ocorre no transporte de passageiros e na condução de veículos por via terrestre, aérea ou marítima, o segurador deve pagar a indenização diretamente ao terceiro prejudicado. Assim, ocorrendo atropelamento de pedestre, a seguradora deverá, por força do chamado seguro obrigatório de vias terrestres, mais conhecido pela sigla DPVAT (danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre), pagar a indenização devida à vítima ou a seus beneficiários, em caso de morte.

Permite-se, expressamente, a ação direta do terceiro, vítima do dano, à seguradora, não obstante não ser parte no contrato de seguro (CC, art. 788, parágrafo único).

Seguradora acionada diretamente não pode opor exceção de contrato não cumprido, isto é, alegar que o proprietário do veículo causador do acidente deixou de recolher o seguro obrigatório anual. A defesa de seu direito pode ser exercida por ação de regresso contra o causador do acidente, mas não ao beneficiário do seguro, vítima do acidente. Antes da vigência do Código Civil de 2002, a Súmula 257 do STJ, publicada em 29 de agosto de 2001, já deixava expressa essa vedação: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização”.

Discute-se na doutrina, a exemplo do que ocorre nos contratos de seguros obrigatórios, a possibilidade de terceiro, nos casos *facultativos* de seguro de responsabilidade civil, acionar diretamente a seguradora em busca da satisfação dos prejuízos causados por segurado por ela garantido.

A jurisprudência de nossos tribunais superiores tem respondido afirmativamente a essa indagação: (1) REsp n. 294.057/DF, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta

Turma, j. em 28-6-2001, *DJ*, 12-11-2001, p. 155: Ação direta contra seguradora. A ação do lesado pode ser intentada diretamente contra a seguradora que contratou com o proprietário do veículo causador do dano. Recurso conhecido e provido. (2) REsp n. 154.781/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 14-12-1999, *DJ*, 20-3-2000, p. 75: Acha-se legitimada a vítima a intentar a ação diretamente contra a seguradora em virtude de haver esta já ressarcido parcialmente os danos por ela sofridos em seu estabelecimento comercial, cingindo-se a presente demanda a postular a complementação da indenização. Aplicação, ademais, do princípio da instrumentalidade do processo. Alegações relativas ao ônus probatório e a julgamento *extra petita* que não foram objeto de análise pela decisão recorrida. Ausência do requisito do prequestionamento. Inocorrência, de todo modo, de ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC. Pretensão ainda de revolver matéria probatória (Súmula n. 7-STJ) Recurso especial não conhecido.

17.7.2. Seguro de pessoa

O contrato de seguro de pessoas possui características distintas do contrato por danos. Ao contrário do que ocorre no contrato de seguro de danos, regido pelo princípio da equivalência entre a garantia segurada e o efetivo valor do interesse segurado, no contrato de pessoas, é livre tanto a estipulação do capital a ser pago pelo segurador quanto a contratação de mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores (CC, art. 789).

Outra distinção: não se permite no contrato de seguro de pessoas a sub-rogação pelo segurador dos direitos e ações do segurado ou, no caso de morte, do beneficiário, contra o causador do sinistro (CC, art. 800).

Essas duas distinções decorrem do ordenamento civil. Há uma terceira peculiaridade do contrato de seguro de pessoa que o distancia do contrato de dano. É a disposição prevista no art. 784, VI, do Código de Processo Civil de 2015: os contratos de pessoa estipulados sobre a vida de alguém – denominados simplesmente contratos de seguro de vida em caso de morte (v. alínea *a*, *infra*) – são títulos executivos extrajudiciais, o que não ocorre com os contratos de seguro de dano.

O Código Civil regula algumas situações próprias do contrato de seguro de pessoas: sua abrangência; a possibilidade de estipulação sobre a vida de outrem; a existência de beneficiários indicados pelo contrato ou pela lei; o tratamento legal quanto às dívidas e à herança; as cláusulas de prêmio, de carência, de suicídio e cláusulas restritivas e de transação para redução do capital; o exercício das funções pelo estipulante.

a) Abrangência do seguro de pessoa

As estipulações sobre riscos nos contratos de seguro de pessoa referem-se aos casos de acidentes pessoais, de sobrevida, de morte, saúde, incapacidade, invalidez parcial ou total, diárias por incapacidade temporária etc. Dessas, o Código Civil não trata das garantias relativas ao reembolso de despesas hospitalares ou de tratamento médico, custeio de despesas de luto e de funeral do segurado (CC, art. 802).

Os mais importantes seguros de pessoas são os três primeiros citados: acidentes, sobrevida e morte, que são genericamente classificados como seguros de vida, porque visam “garantir riscos atinentes à duração da vida humana” ou, ainda, garantia sobre a incerteza dessa duração (cf. Tzirulnik, Cavalcante e Pimentel, 2003:154).

No seguro de acidentes pessoais o risco coberto é o evento que cause lesão à integridade física do segurado. As garantias perseguidas pelo segurado situam-se nos riscos de morte ou a invalidez total ou parcial causados por acidente. Acidente nada mais é que qualquer “causa súbita, involuntária, violenta e causadora de lesão física”¹²⁶ capaz de provocar morte ou invalidez do segurado e pode ocorrer em inúmeras situações, como em atos de mobilidade, laborais ou de lazer do segurado, recebendo, em função disso, especialização legislativa, como ocorre com o seguro social de acidentes do trabalho¹²⁷ que recebe tratamento legislativo distinto do seguro por acidentes pessoais.

No seguro de sobrevivência a determinado tempo de duração da vida humana, “o segurador paga uma determinada soma ou renda, se o segurado viver no momento de vencer-se o seguro” (Beviláqua, 1975, 2:599), podendo ser estipulado por certo prazo, ao final do qual o segurador obriga-se a pagar o capital contratado ou valor de

renda vitalícia a partir de certo tempo.

No seguro de vida para o caso de morte do segurado, geralmente contratado com seguro de acidentes pessoais, prevê-se o risco da morte por causas naturais e por razões externas à natureza humana (acidentárias).

b) Estipulação sobre a vida de outrem

Permite-se estipulação sobre a vida de outrem, mas o “proponente é obrigado a declarar, sob pena de falsidade, o seu interesse pela preservação da vida do segurado” (CC, art. 790).

A que interesse reporta-se o legislador? O parágrafo único desse artigo, ao presumir sua presença “quando o segurado é cônjuge, ascendente ou descendente do proponente”, informa que o interesse, nos casos que menciona, situa-se na afetividade natural que decorre dos laços consanguíneos.

Ao lado desse interesse na preservação da vida do ente querido, há os que decorrem de uma infinidade de situações em que o terceiro tenha obrigações patrimoniais com o segurado ou beneficiário indicado na apólice. O contratante deve demonstrar que a morte do segurado lhe trará prejuízos econômicos. Não fosse assim qual interesse teria o contratante na preservação da vida de alguém, considerando que a morte do segurado irá render-lhe o capital estipulado no contrato? Seu interesse, uma vez ausentes quaisquer laços afetivos ou econômicos com o segurado, estaria concentrado na morte e não na preservação de sua vida e, neste caso, violaria o fundamento sobre o qual repousam os contratos de seguro, o princípio da não ocorrência do sinistro (v. item 17.5.4). Seria, no dizer de Clóvis Beviláqua (1975, 2:600), “uma aposta de mau gosto, e poria em perigo a existência do terceiro”.

Se, entretanto, o segurado é devedor de pensão alimentar vitalícia, mantê-lo vivo é, de fato, o interesse do contratante, para que possa usufruir por mais tempo desse benefício.

Há sobre essa matéria uma percuciente observação de Tzirulnik, Cavalcanti e Pimentel (2003:166) quando afirmam que o valor da garantia segurada pelo contratante no seguro sobre a vida de seu devedor deverá “corresponder,

rigorosamente, ao valor do débito quando da contratação e, em ocorrendo o sinistro, o valor a ser pago pela seguradora será o valor do débito nesse momento”. De fato, assim deve ser, sob pena de havendo contratação por sobrevalor, excedente ao da dívida do segurado, a preservação já não seria por sua vida porque muito mais rentável é sua morte.

c) Beneficiários indicados pelo contrato ou pela lei

O contratante de seguro de pessoa pode indicar beneficiários, pessoas que receberão o pagamento do capital estipulado, em ocorrendo o evento de sua morte. Essa indicação pode dar-se a *título gratuito*, que é o caso mais comum, ou a *título oneroso*, quando se destinar a garantir uma obrigação, modalidade hoje difundida nos contratos bancários, pelo qual, falecendo o mutuário ou o devedor, as parcelas vincendas são quitadas pelo seguro contratado.

Se o contrato de seguro não se destina a garantir uma obrigação, a estipulação do beneficiário se faz a título gratuito e, neste caso, o contratante pode, a qualquer tempo, alterá-la, por ato *inter vivos* ou por disposição de última vontade. Essa modificação deve chegar ao conhecimento da seguradora a tempo de ser cumprida porque se tardia, isto é, em momento posterior ao pagamento realizado ao beneficiário anteriormente indicado, não mais poderá ser exigida (CC, art. 791, parágrafo único).

A indicação de beneficiário é facultativa; na sua falta, são considerados beneficiários o cônjuge não separado judicialmente, por 50% do valor, e os herdeiros do segurado, pelo restante. Se o segurado não for casado e não tiver herdeiros receberá o capital qualquer pessoa que demonstrar que a morte do segurado a privou dos meios necessários para sua sobrevivência.

Para evitar conflitos posteriores que podem surgir em razão de uniões não regularizadas, o legislador declarou válida a instituição de companheiro como beneficiário, “se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato” (CC, art. 793).

d) Tratamento legal quanto às dívidas e à herança

Nos contratos de seguro de vida, incluindo o de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não se sujeita às dívidas, nem é considerado herança, conforme dispõe o art. 794 do Código Civil.

A razão pela qual o capital pago ao beneficiário, em caso de morte, não se sujeita ao pagamento de dívidas do segurado, nem se presta à partilha de bens está na singela constatação de que essa soma de dinheiro jamais integrou ou integrará o patrimônio do falecido. É, antes, obrigação do segurador devida ao beneficiário indicado. O contratado não é credor da seguradora e o beneficiário não é, por esta qualidade, devedor solidário por dívidas do segurado. Pelo fato de não se considerar herança, não pode haver cobrança do devedor por dívidas do espólio; caso contrário, haveria exigência de dívida de terceiro (o espólio) sobre patrimônio de pessoa não obrigada legalmente ou por contrato (o beneficiário).

Por estes e outros fundamentos decorre a disposição do art. 833, VI, do Código de Processo Civil de 2015 que arrola, entre as coisas impenhoráveis, o seguro de vida. Enquanto não ocorrido o evento morte, há somente uma expectativa de direito àquela soma por parte do beneficiário. Ocorrida a morte do contratante, o beneficiário, credor da seguradora, possui patrimônio distinto daquele e não responderá por suas dívidas. Entretanto, recebido o valor do seguro, o beneficiário, por débitos de sua responsabilidade, poderá sofrer execução sobre seu patrimônio, agora acrescido com o capital pago pela seguradora.

e) Cláusulas de prêmio, de carência, de suicídio, cláusulas restritivas e transação para redução do capital

Prêmio. O pagamento de prêmio obedece à regra pela qual o seguro de vida foi contratado: se temporário, o pagamento será obrigado durante o prazo limitado no contrato e, se vitalício, por toda a vida (CC, art. 796).

Ocorrendo atraso de parcela, não há ação – de cobrança ou executiva – por parte da seguradora porque o sistema jurídico lhe propiciou meios mais efetivos e eficientes de fazer cumprir o contrato celebrado, permitindo-lhe a resolução do contrato, com a restituição da reserva já formada, ou a redução do capital garantido,

proporcionalmente ao prêmio pago. Se nenhuma dessas opções, previstas no parágrafo único do art. 796 do Código Civil, foi contratualmente prevista, a solução é permitir ao segurado a escolha (2003:184).

Carência. No seguro de vida para o caso de morte, os contratantes podem estipular certo prazo de carência. Fixado, por exemplo, período de carência de um ano e o falecimento do segurado ocorrer dentro desse prazo, a seguradora deve pagar o valor correspondente à reserva técnica já formada, mas não responde pelo pagamento do sinistro.

A reserva a que se refere o dispositivo (CC, art. 797, parágrafo único) é a reserva matemática¹²⁸, isto é, o cálculo atuarial provisionado pelo segurador para suplementar o “valor do prêmio pago no fim do contrato, quando seu valor é inferior ao do risco” (2007, 3:345-346).

Suicídio. O contrato de seguro não pode incluir, entre as hipóteses de exclusão de pagamento de capital, o suicídio do segurado porque esse evento não impede o recebimento do capital pelo beneficiário. Há, contudo, uma exceção: o pagamento não será devido se o suicídio ocorrer nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato ou de sua recondução depois de suspenso.

Salvo esta hipótese, portanto, a estipulação restritiva, prevendo o não pagamento para o caso de suicídio, será considerada nula.

Cláusulas restritivas. Outras cláusulas restritivas também são vedadas pelo Código Civil: utilização de meio de transporte mais arriscado, prestação de serviço militar, prática desportiva ou de atos de humanidade, em auxílio de outrem (CC, art. 799).

Em outras palavras: se esses atos contribuíram ou foram causa da morte ou da incapacidade do segurado, ainda que previstos em contrato, a obrigação do segurador subsiste.

Transação para redução do capital. É vedada transação para pagamento reduzido do capital segurado, sob pena de nulidade da cláusula (CC, art. 795). Com o falecimento do segurado, a companhia seguradora poderia ser tentada a pagar menos

do que contratou, propondo ao beneficiário a redução do valor devido como condição para o pagamento sem entraves administrativos ou judiciais. A regra tem, portanto, intuito moralizador e, mesmo em caso de invalidez, tutela o interesse do segurado porque mantém íntegro o valor previamente estipulado, não havendo razão para transação sobre aspecto inquestionável do contrato: o dever de pagar o quanto estipulado.

f) Exercício das funções pelo estipulante

Diz o art. 801 do Código Civil que, no contrato de seguro coletivo de pessoas, o estipulante não representa o segurador e qualquer modificação contratual depende da anuência expressa de 75% dos segurados integrantes da apólice de seguro em grupo.

Para a contratação de seguro em grupo, em apólice coletiva, as pessoas contratantes devem manter elo que as vincule de alguma forma com o estipulante, como, por exemplo, ser empregado de uma mesma empresa ou associado de entidade comum. O estipulante representa o grupo e é o único responsável perante o segurador, cabendo-lhe dar as informações necessárias à concretização do contrato e, depois de firmado, recolher os prêmios devidos. Embora represente os segurados, não cabe a ele propor modificações da apólice em vigor à seguradora, nem tampouco representá-la perante aqueles. A faculdade de alterar as cláusulas contratadas é atribuída exclusivamente ao grupo que, para manifestá-la, deverá fazê-lo pela adesão expressa de segurados que representem $\frac{3}{4}$ do grupo.

BIBLIOGRAFIA

- AGUIAR JR., Ruy Rosado (org.). *Jornada de Direito Civil*. Brasília: CJP, 2007.
- ALVES, João Luiz. *Código Civil da República dos Estados Unidos do Brasil* 3. tir. rev. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1926.
- ANDREZA, Andrea Fernandes. O Sistema Contratual do Cartão de Crédito no Brasil – artigo publicado no *Estudo em homenagem ao acadêmico Ministro Sydney Sanches*. São Paulo: Fiúza Editores, 2003. Citado por ABRÃO, Carlos Henrique. *Cartões de Crédito e Débito*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005.
- ASCARELLI, Tullio. *Teoria Geral dos Títulos de Crédito*. Campinas: Red Livros, 1999.
- _____. *Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado*. Campinas: Bookseller, 2001.
- BARATA, Filipe Themudo. *Navegação, Comércio e Relações Políticas: os Portugueses no Mediterrâneo Ocidental (1385-1466)*. Coimbra: Calouste Gulbenkian, 1998.
- BESHELL, Barbara. *An Introduction to Franchising*. IFA – Educational Foundation (International Franchise Association – Educational Foundation, disponibilizado em: <www.franchise.com>, 2000.
- BEVILÁQUA, Clóvis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado*. Rio de Janeiro: Ed. Rio, ed. histórica, 1975, v. 1 e 2.
- BEZERRA FILHO, Manoel Justino. *Nova Lei de Recuperação e Falências Comentada*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
- BORGES, Eunápio. *Títulos de Crédito*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1975.
- BRAUDEL, Fernand. *O Jogo das Trocas*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

BULGARELLI, Waldirio. *Títulos de Crédito*. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

_____. *Contratos Mercantis*. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

CALÁBRIA, Marco Antonio Rocha *A Representação Comercial Autônoma e o Empresário*. Campinas: Alínea, 2000.

CARVALHO DE MENDONÇA, J. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. 5. ed. atualizada por Achiles Beviláqua e Roberto Carvalho de Mendonça Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955, v. VII.

_____. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. 5. ed. posta em dia por Achiles Beviláqua e Roberto Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956 v. VIII.

_____. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, atualizado por Ricardo Negrão. Campinas: Bookseller, 2000, v. I.

CARVALHO NETO, Frederico da Costa *Nulidade da Nota Promissória Dada em Garantia nos Contratos Bancários*. São Paulo: J. de Oliveira, 2003.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 3.

_____. *Curso de Direito Comercial*. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1.

_____. A relação de trabalho na representação comercial. In *Representação Comercial e Distribuição – Estudos em homenagem ao Prof. Rubens Requião*, coord. J. Hamilton Bueno e Sandro G. Martins. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____. *Curso de Direito Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 3.

_____. *Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa*. 20. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, v. 1-3.

_____. *Novo Manual de Direito Comercial*. 29. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017

CORDEIRO, António Menezes *Manual de Direito Comercial*. Coimbra: Almedina,

2003.

CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano *Manual de Direito Romano*. Rio de Janeiro: Cadernos Didáticos, s/ data.

CORREIA, Miguel J. A. Pupo. *Direito Comercial*. 6. ed. Lisboa: Ediforum, 1999.

COSTA, Wille Duarte da. *Títulos de Crédito e o Novo Código Civil*. In RODRIGUES, Frederico Viana (coord.) *Direito de Empresa no Novo Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

DELMANTO, Celso; DELMANTO JR., Roberto *Código Penal Comentado*. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

DINIZ, Maria Helena *Curso de Direito Civil Brasileiro*. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. *Código Civil Anotado*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

_____. *Compêndio de Introdução à Ciência do Direito*. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

DONINI, Antonio Carlos *Factoring: os projetos de leis no Congresso*. *Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. 2004.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda *Novo Dicionário da Língua Portuguesa – Século XXI*. 3. ed. coord. e editada por Margarida dos Anjos e Marina Baird Ferreira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

_____. *Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa*. 5. ed. coord. e editada por Margarida dos Anjos e Marina Baird Ferreira. Curitiba: Positivo, 2010.

GARNER, Bryan A. – Editor in Chief *Black's Law Dictionary*. 8. ed. St. Paul – Mn: Thompson West, 2004.

GODOY, Claudio Luiz Bueno de. *Código Civil Comentado*. 2. ed. São Paulo:

Manole, 2008.

GOMES, Orlando. *Contratos*. 26. ed. atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

GONÇALVES, Carlos Roberto *Direito Civil Brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, v. III.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O Contrato de Representação Comercial no Contexto do Código Civil de 2002. *Representação Comercial e Distribuição*. São Paulo: Saraiva, 2006.

GRAHAL, Orival. *Título de Crédito Eletrônico*, 2003. Dissertação de Mestrado apresentada à banca da Universidade Católica de Brasília, disponível em: <www.bdttd.ucb.br/tede/tde_arquivos/9/TDE-2004-07-20T12:0013Z>.

HUNT, Edwin S.; MURRAY, James M. *Uma História do Comércio na Europa Medieval*. Lisboa: Dom Quixote, 2000.

LOBO, Jorge. Comentários aos artigos 35-69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2005.

LOPES, Serpa. *Curso de Direito Civil*. 4. ed. atualizada por José Serpa Santa Maria. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993.

LOPEZ, Teresa Ancona. Princípios Contratuais. In: FERNANDES, Wanderle coord., *Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais*. São Paulo: Saraiva, 2007.

LOUREIRO, Francisco Eduardo. Novo Código Civil: contratos e certificação digital. In: REIS, Selma Negrão Pereira dos (coord.); OLIVEIRA, Rogério Alvarez de FRANCO, Eloísa Virgili Canci (orgs.). *Questões de Direito Civil e o Novo Código*. São Paulo: Ministério Público do Estado e Imprensa Oficial, 2004.

MARQUES, Cláudia Lima. *Contratos no Código de Defesa do Consumidor*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. *Comentários ao Código de Defesa do Consumidor*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

MARTINS, Francisco. *Contratos e Obrigações Comerciais*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

_____. *Títulos de Crédito*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, v. I e II.

_____. *Títulos de Crédito*. 15. ed. atualizada por Joaquim Penalva Santos e Paulo Penalva Santos. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

MARTINS, Pedro A. Batista. Sobre o uso aos Títulos de Crédito no Novo Código Civil. In: *Direito de Empresa no Novo Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

MASTRANGELO, Cláudio. *Agências Reguladoras e Participação Popular*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

MIGUEL, Paula Castello. *Contratos entre Empresas*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

MONTEIRO, António Pinto. *Contrato de Agência*. Coimbra: Almedina, 2004.

MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de Direito Civil – Direito das Obrigações*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1973.

NEGRÃO, Ricardo. *A Eficiência do Processo Judicial na Recuperação de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2010.

NEGRÃO, Theotônio; GOUVÊA, José Roberto. *Código Civil e Legislação Civil em Vigor*. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

_____. *Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor*. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

NEGREIROS, Teresa. *Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-fé*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade *Código Civil Comentado*. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

_____. *Código Civil Comentado*. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

_____. *Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante* 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 2ª tir.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Hauer de. Agência e representação comercial: necessidade de harmonização da disciplina jurídica. In: *Representação Comercial e Distribuição*. São Paulo: Saraiva, 2006.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, v. 1.

PIETZSCHKE, Fritz (org.) *Novo Michaellis*. 12. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1972.

PONTES DE MIRANDA *Tratado de Direito Cambiário*. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2000, v. I, II, III e V.

REALE, Miguel. *Lições Preliminares de Direito*. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de Direito Comercial*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

REQUIÃO, Rubens Edmundo. Os contratos de agência, de representação comercial o contrato de distribuição. O art. 710 do Código Civil. In: *Representação Comercial e Distribuição*. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____. *Curso de Direito Comercial*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 2.

RESTIFFE, Paulo Sérgio *Manual do Novo Direito Comercial*. São Paulo: Dialética, 2006.

RIBEIRO, Maria de Fátima. *O Contrato de Franquia*. Coimbra: Almedina, 2001.

RIPERT, Georges. *A Regra Moral nas Obrigações Civis*. Campinas: Bookseller,

2000.

RIZZARDO, Arnaldo. *Factoring*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

RODRIGUES, Dirceu A. Victor *Dicionário de Brocardos Jurídicos*. 7. ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1972.

RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, v. 3.

ROSA JR., Luiz Emygdio F. da. *Títulos de Crédito*. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

ROSENVALD, Nelson. Comentários aos arts. 421-652. In: PELUSO, Cezar *Código Civil Comentado – doutrina e jurisprudência*. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008.

SÁNCHEZ, Esperanza Gallego *La Franquicia*. Madri: Trivium, 1991. Citada por RIBEIRO, Maria de Fátima. *O Contrato de Franquia*. Coimbra: Almedina, 2001.

SHIMURA, Sérgio. *Título Executivo*. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

SIANO, James. *A visão do contrato de transporte terrestre de pessoas e coisas à luz do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor*. São Paulo: PUC-SP dissertação defendida em 26 de maio de 2006.

SIBBETT, Trevor. *European sources for research of actuarial history and the scope for translation*, in “Exploring Actuarial History” Seminar, 14 June 2007, obtido em: <www.actuaries.org.uk/_data/assets/>, em dezembro de 2008.

SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. 15. ed. atualizada por Nagib Slaibi Filho e Geraldo Magela Alves. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

_____. *Noções Práticas de Direito Comercial*. 6. ed. Curitiba: Guaíra, 1946.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A Cédula de Crédito Bancário *RDBMCA*, n. 22, out./dez. 2003.

_____. Contrato de Agência e Distribuição no Novo Código Civil. *Revista Síntese de Direito Civil e Processo Civil*, Porto Alegre: Síntese, ano IV, n. 24, jul./ago. 2003.

- TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. *Contrato de Seguro*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
- VAMPRÉ, Spencer. *Tratado Elementar de Direito Comercial*. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1922, v. III.
- VIVANTE, Cesare. *Instituições de Direito Comercial*. Trad. de J. Alves de Sá sobre a 10. ed. Lisboa: A. M. Teixeira & Cia. Ltda., 1910.
- Vocabulário do Mercado de Capitais*, Rio de Janeiro, Comissão Nacional de Bolsas de Valores, 1990.
- WALD, Arnoldo; MORAES, Luiza Rangel de. Agências Reguladoras *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, a. 36, n. 141, jan./mar. 1999.
- WIEACKER, Franz *História do Direito Privado Moderno*. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1967.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

(Os números referem-se aos itens.)

Abrão, Carlos Henrique – 9.10.5, 15.3.3

Aguiar, Ruy Rosado de – 3.3.1, 5.5, 5.11, 15.3.5, 16.7a, 16.7c, 17.7.1e

Almeida, João Ferreira – 8.4d

Alves, João Luiz – 7.2.2a, 12.9

Andreza, Andrea Fernandes – 15.3.3

Andrighi, Nancy – 3.5, 6.4a, 6.4c, 8.4b, 8.4c

Aragão, Alexandre Santos de – 16.5

Ascarelli, Tullio – 5.1, 7.2.4, 7.2.5a, 7.2.5b, 7.2.6a, 7.3.2, 17.5.4, 17.7.1

Aurégio, Marco – 5.12

Azevedo, Antonio Junqueira de – 12.1, 12.2, 17.2

Baleeiro, Aliomar – 2.4

Barata, Filipe Themudo – 2.1, 2.5.1c, 7.3.1, 16.1, 17.1

Barbosa, Hélio Quaglia – 16.7a

Barros, Humberto Gomes de – 8.4c, 16.7a

Benjamin, Antônio Herman V. – 8.4a

Beshell, Barbara – 11.3

Beviláqua, Clóvis – 2.6, 2.9d, 9.3a, 9.7.1, 9.7.2, 9.10.1, 9.10.2, 9.10.3, 12.2, 12.7, 12.8a, 12.9, 17.3, 17.5.2, 17.5.3, 17.7.1, 17.7.2a, 17.7.2b

Boaz – 8.4d

Borges, João Eunápio – 1.1, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 2.5.4f, 3.1, 5.1

Braudel, Fernand – 13.2

Bulgarelli, Waldirio – 2.6, 3.1, 3.4, 5.1, 5.7, 5.8.2, 6.3, 7.2.5a, 7.3.5, 9.3, 9.3a, 9.10.7, 10.3.1, 13.2, 15.2, 15.5.2

Calábria, Marco Antonio Rocha – 10.2.4

Calmon, Eliana – 16.7a

Carneiro, Athos – 3.3.1

Carvalho Neto, Frederico da Costa – 4.2

Castro Filho – 4.1a, 4.12a, 5.7, 16.7c

Cavalcanti, Flávio de Queiroz B. – 17.7.2a, 17.7.2b, 17.7.2c

Cernicchiaro, Luiz Vicente – 8.4e

Coelho, Fábio Ulhoa – 1.2.1, 1.4.2, 1.5, 1.6.1, 1.6.2, 2.3, 2.3.1a, 2.5.4, 2.5.4e, 2.7, 3.4, 4.1c, 4.11b, 4.12a, 5.5, 5.11, 5.12, 6.3, 7.1, 7.2.5a, 7.2.11, 8.2, 8.3, 8.4a, 8.5, 9.1, 9.3, 9.9.2, 9.10.2, 9.10.5, 9.10.7, 10.1, 10.2.5, 11.2, 11.4, 12.7, 14.2, 14.3.1, 15.2, 15.4.3g, 17.4, 17.5.5

Comparato, Fábio Konder – 15.4.3e

Constâncio, Francisco Solano – 1.1

Cordeiro, António Menezes – 11.1, 17.1, 17.2
Correia, Alexandre – 8.4d
Correia, Miguel J. A. Pupo – 1.2.3, 1.2.4, 1.4.2, 2.5.1a, 3.3.1, 4.11b, 7.1, 7.2.5a, 16.6.1
Costa, Wille Duarte da – 1.5
Cueva, Ricardo Villa Bôas – 5.3
Delmanto, Roberto – 5.12
Delmanto Jr., Roberto – 5.12
De Plácido e Silva – 5.2.2, 7.2.5a, 7.3.4
Diniz, Maria Helena – 4.6, 8.2, 8.4a, 8.5, 9.3a, 9.9.1, 9.10.2, 9.10.5, 10.1, 12.2, 12.3b, 13.8, 14.1, 14.3.1, 14.6, 15.2
15.4.1, 15.4.3b, 16.7c, 17.4, 17.5.5d
Direito, Carlos Alberto Menezes – 3.3.1, 3.4, 4.12a, 5.5
Donini, Antonio Carlos – 15.4.3e, 15.4.3g
Einert, Karl – 2.1
Fernandes, Wanderley – 8.4c
Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda – 7.2.4, 9.9.1
Ferreira, Waldemar – 5.8.2, 7.3.5
Garner, Bryan A. – 15.4.3f
Germano, Alexandre – 5.7
Godoy, Cláudio Luiz Bueno de – 16.7a, 17.4
Gomes, Orlando – 8.2, 8.4a, 8.4c, 8.4f, 8.4g, 8.5, 8.5c, 8.5d2, 8.5d3, 9.10.2, 9.10.5, 10.2.2, 12.1, 12.2, 13.8, 15.2
15.4.1, 15.6.1, 15.6.3, 16.3, 17.2, 17.4
Gonçalves, Carlos Roberto – 5.7, 10.2.2, 12.2, 15.2
Gonçalves, Fernando – 5.3, 6.4b, 16.7a
Gonçalves Neto, Alfredo de Assis – 10.1, 10.2.2
Gouvêa, José Roberto Ferreira – 1.6.3, 4.3b, 5.3, 9.7.3, 12.3a
Graham, Orival – 1.6.3
Hunt, Edwin S. – 2.1, 2.5.1c, 3.1, 14.1, 14.3, 16.1
Kant – 8.4a
Lacerda, Paulo – 5.8.2
Lagarde – 2.3
Leite, Gueiros – 5.5
Lopes, Serpa – 12.1, 12.2, 12.9
Lopez, Teresa Ancona – 8.4b, 8.4c
Loureiro, Francisco Eduardo – 1.6.3
Lusitano, Pedro de Santarém – 17.1
Machado, Marcondes – 5.7
Machado, Mauro Conti – 15.4.4
Marino, Francisco Paulo de Crescenzo – 12.1, 12.2, 17.2
Marques, Cláudia Lima – 8.4a
Martins, Fran – 1.1b, 2.1, 2.3, 2.3.1a, 2.3.4b, 2.3.8, 2.3.9, 2.4, 2.5.2d, 2.5.4, 2.5.4f, 2.7, 3.3.1d, 3.4, 4.12a, 5.1, 5.2.2
5.9.1, 7.3.4, 8.3, 9.5, 11.1, 11.8d, 15.4.3, 16.2, 16.3, 16.8

Martins, Pedro A. Batista – 1.5
Masschaele, James – 16.1
Mastrangelo, Cláudio – 16.5
Meira, Castro – 15.4.1
Mendonça, J. X. Carvalho – 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2, 1.4.3, 2.5.4f, 5.1, 5.8.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6a, 7.2.6b, 7.2.11, 9.3
9.3a, 9.9.1, 12.8a, 13.2, 13.8, 14.1, 16.3, 16.6, 16.7h
Miguel, Paula Castello – 8.3, 8.5c
Miranda, Décio – 2.4
Monteiro, Antonio Pinto – 10.2.1
Monteiro, Barros (Min.) – 3.3.1d, 5.4.3, 15.4.3g, 17.7.1e
Monteiro, Washington de Barros – 9.7.2, 9.10.5, 12.2, 12.9
Moraes, Luiza Rangel de – 16.5
Moreira, Barbosa – 9.9.2, 12.3a
Murray, James M. – 2.1, 2.5.1c, 3.1, 14.1, 14.3, 16.1
Naves, Nilson – 3.3.1f, 15.4.3g
Negrão, Ricardo – 11.5c
Negrão, Theotônio – 1.6.3, 4.3b, 4.9, 5.3, 9.7.3, 12.3a
Negreiros, Teresa – 16.7c
Nery, Rosa Maria de Andrade – 1.6.3, 3.3.1, 9.7.3, 9.9.2, 9.10.2, 9.10.5, 12.5b
Nery Jr., Nelson – 1.6.3, 3.3.1, 8.4b, 9.7.3, 9.9.2, 9.10.2, 9.10.5
Noemi – 8.4d
Noronha, João Otávio – 15.4.1
Oliveira, Carlos Alberto Hauer de – 10.2.5
Pargendler, Ari – 5.3, 15.4.4
Passarinho Jr., Aldir – 5.3, 5.4.4, 6.4a, 16.7c
Peluso, Cezar – 8.4c
Pereira, Caio Mário da Silva – 12.4
Pereira, Milton – 9.12.1
Pimentel, Ayrton – 17.7.2a, 17.7.2b, 17.7.2e
Pontes de Miranda – 2.1, 2.3.1a, 2.3.2a, 2.3.3b, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.4c, 2.5.4g, 2.9e, 3.1, 4.2, 4.7a, 4.7b, 4.10
4.11e, 4.12a, 5.1, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.9.3
Reale, Miguel – 8.4a
Requião, Rubens – 1.4.2, 2.1, 2.3, 2.3.3b, 2.5.1a, 2.5.4, 2.5.4f, 4.2, 4.7b, 4.11e, 5.1, 5.2.3, 5.9.1, 7.2.5a, 7.2.5b
Requião, Rubens Edmundo – 10.2.5
Restiffe, Paulo Sérgio – 8.4c, 11.3, 15.2, 15.4.3g
Ribeiro, Antônio de Pádua – 1.6.2
Ribeiro, Eduardo – 5.5
Ribeiro, Maria de Fátima – 11.1, 11.2, 11.3, 11.6
Ribeiro, Moura (Min.) – 5.5
Ribeiro, Pádua (Min.) – 1.6.2
Ripert, Georges – 8.4e

Rizzardo, Arnaldo – 15.4, 15.4.3e, 15.4.3f, 15.4.3g
Rocha, Cesar Asfor – 4.1a, 15.4.3g
Rodrigues, Dirceu A. Victor – 15.4.3c
Rodrigues, Silvio – 12.2, 12.9
Rosa Jr., Luiz Emygdio F. da – 1.4.1, 2.6b, 2.9e, 7.2.5a
Rosenvald, Nelson – 8.4b, 8.4c
Salomão, Luis Felipe – 3.3.1f, 4.1a, 5.11, 8.4c
Sanches, Sydney – 15.3.3
Sánchez, Esperanza Gallego – 11.1
Sanseverino, Paulo de Tarso – 5.5, 5.8
Santa Maria, José Serpa – 12.1
Santerna, Petrus – 17.1
Savary, Jacques – 2.1, 17.1
Sciascia, Gaetano – 8.4d
Shimura, Sérgio – 5.1, 5.7
Siano, James – 7.3.2, 16.3
Sibbett, Trevor – 17.1
Sobrinho, Frei João – 17.1
Sorani – 5.8.2
Souza, Irineu Evangelista de – 16.2
Tavares, Fonseca – 6.1
Teixeira, Sálvio de Figueiredo – 4.1a, 4.12a, 5.4.4, 5.5, 8.5c, 8.5e, 9.7.3, 10.3.1, 16.7b
Theodoro Jr., Humberto – 6.1, 6.3, 10.1, 10.2.2, 10.2.8
Telles, Araldo – 15.4.3e
Toledo, Paulo F. C. Salles de – 9.10.5
Torres, Magarinos – 5.8.2
Trindade, Dias – 5.5
Tzirulnik, Ernesto – 17.4, 17.7.2a, 17.7.2b, 17.7.2e
Vampré, Spencer – 7.2.4
Viana, Oséas – 5.7
Vidari – 5.8.2, 16.3
Vieira, Luiz Augusto Salles – 5.8.3
Vivante, Cesare – 1.1, 1.2.3, 1.4, 16.3
Wald, Arnaldo – 16.5
Wieacker, Franz – 8.4a
Zveiter, Waldemar – 4.5, 14.3.3, 16.7a

ÍNDICE DA LEGISLAÇÃO

(somente quando acompanhada de dispositivos legais)

(Os números referem-se aos itens.)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PRINCIPAIS CÓDIGOS

Constituição Federal (CF):

- art. 21: 16.4
- art. 30: 16.4, 16.7

Código Civil de 1916 – Lei n. 3.071/16 (CC 1916)

- art. 85: 8.4e
- art. 1.062: 2.3.2d, 2.4
- art. 1.070: 9.10.5
- art. 1.071: 9.10.5
- art. 1.135: 9.9.1
- art. 1.140: 9.10.2
- art. 1.158: 9.10, 9.10.1
- art. 1.162: 9.10
- art. 1.163: 9.10, 9.10.1
- art. 1.278: 7.2.2a
- arts. 1.432-1.476: 17.3
- art. 1.458: 17.5.3
- art. 1.533: 4.1a

Código Civil de 2002 – Lei n. 10.406/2002 (CC 2002)

- art. 100: 9.2a
- art. 104: 17.5.4
- art. 105: 12.3a
- art. 108: 8.5b, 9.2, 9.4, 12.5a
- art. 112: 8.4e
- art. 113: 8.4c
- art. 114: 8.5d2
- arts. 115-120: 12.1
- art. 117: 8.5d1
- art. 118: 8.5d1
- art. 121: 4.1a
- art. 127: 15.6.2
- art. 128: 15.6.2

- art. 131: 4.1a
- art. 157: 8.4f, 8.5d3
- art. 166: 12.9
- art. 187: 8.4c
- art. 206, § 3º: 1.5, 16.9.2e
- art. 211: 9.7.2
- art. 215: 12.5.b
- art. 225: 1.6.3
- art. 226: 9.4
- art. 227: 9.4
- art. 275: 2.5.4g
- art. 286 e ss.: 4.6, 13.5.1
- art. 288: 15.4.3e
- art. 289: 15.4.3e
- art. 291: 15.4.3e
- art. 292: 15.4.3e
- art. 294: 15.4.3e
- art. 295: 15.4.3e
- art. 298: 15.4.3e
- art. 317: 8.4e
- art. 346: 17.7.1d
- art. 347: 17.7.1d
- art. 392: 8.5d2
- art. 401: 12.9
- art. 406: 2.3.2d, 14.5.2, 15.4.3g
- art. 421: 8.2, 8.4a, 8.4b
- art. 422: 8.2, 8.4c, 17.5.2
- art. 425: 8.4a, 8.5a
- art. 436: 8.4g
- art. 437: 8.4g
- art. 438: 8.4g
- art. 439: 12.8a
- art. 441: 9.7.2
- art. 442: 9.7.2
- art. 443: 9.7.2
- art. 450: 9.7.3
- art. 474: 8.5d1
- art. 476: 8.5d1, 12.2
- art. 477: 8.5d1, 9.6
- art. 478: 8.4e, 8.4f

- art. 480: 8.4e
- art. 481: 9.1, 9.2a
- art. 482: 9.2
- art. 483: 9.2a
- art. 484: 9.9, 9.9.1
- art. 486: 9.3b
- art. 487: 9.3b
- art. 488: 9.3b
- art. 489: 9.2b
- art. 490: 9.7.1
- art. 491: 9.6
- art. 491: 9.8
- art. 492: 9.7.1, 9.8, 9.10.5
- art. 493: 9.7.1
- art. 494: 9.7.1, 9.8
- art. 500: 9.9, 9.9.2
- art. 501: 9.9, 9.9.2
- art. 502: 9.7.1
- art. 503: 9.7.2
- art. 505: 9.10.2
- art. 506: 9.10.2
- art. 507: 9.10.2
- art. 508: 9.10.2
- art. 509: 9.10.3
- art. 510: 9.10.3
- art. 511: 9.10.3
- art. 512: 9.10.3
- art. 514: 9.10.4
- art. 517: 9.10.4
- art. 518: 9.10.4
- art. 519: 9.10.4
- art. 520: 8.4g, 9.10.4
- art. 521: 9.10.5
- art. 522: 9.10.5
- art. 523: 9.10.5
- art. 524: 9.10.5
- art. 525: 9.10.5
- art. 526: 9.10.5
- art. 529: 9.7.1, 9.10.6
- art. 530: 9.10.6

- art. 531: 9.10.6
- art. 532: 9.10.6
- art. 534: 9.12.1
- art. 536: 9.12.1
- art. 537: 9.12.1
- art. 578: 16.7g
- art. 581: 9.7.3
- art. 582: 9.7.3
- art. 586: 14.5
- art. 591: 15.4.3g
- art. 597: 15.5
- art. 627: 14.3.1
- art. 640: 14.3.1
- art. 644: 16.7g
- art. 653: 10.2.9, 12.1, 12.5, 13.1, 13.4
- art. 654: 4.6, 12.3a, 12.5b
- art. 656: 12.5
- art. 657: 12.5a
- art. 661: 12.5b
- art. 662: 12.8a
- art. 665: 12.6
- art. 667: 12.2, 12.6, 12.7
- art. 668: 12.7, 12.9
- art. 669: 12.7
- art. 670: 12.7
- art. 672: 12.3d
- art. 673: 12.3d, 12.8a
- art. 675: 12.7, 12.8a
- art. 676: 12.7
- art. 679: 12.7
- art. 680: 12.3e
- art. 682: 2.5.3d, 4.8, 12.9
- art. 683: 12.9
- art. 684: 12.9
- art. 685: 12.9
- art. 686: 12.8b, 12.9
- art. 687: 12.9
- art. 690: 12.9
- art. 692: 12.3a
- art. 693: 10.2.9, 13.1, 13.4

- art. 694: 10.2.9
- art. 695: 13.5.2
- art. 696: 13.5.2a
- art. 697: 10.2.9
- art. 698: 10.2.9, 13.8
- art. 699: 13.5.2c
- art. 700: 13.5.2c
- art. 701: 13.6
- art. 703: 13.6
- art. 705: 13.6
- art. 706: 13.5.2d
- art. 707: 13.7
- art. 708: 13.5.2e, 16.7g
- art. 709: 13.4
- art. 710: 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.6, 10.2.8, 13.4
- art. 711: 10.2.2, 10.2.6, 10.2.7
- art. 712: 10.2.2, 10.2.3
- art. 713: 10.2.6, 10.2.7
- art. 714: 10.2.10
- art. 716: 10.2.10
- art. 717: 10.2.11
- art. 718: 10.2.10, 7.2.11
- art. 719: 10.2.5
- art. 720: 10.2.7
- art. 721: 10.1, 10.2.9, 13.4
- art. 722: 17.5.5d
- art. 723: 17.5.5d
- art. 725: 17.5.5d
- art. 730: 16.2, 16.4
- arts. 730-733: 16.4
- art. 732: 16.4
- art. 733: 16.7h, 16.9.2f
- art. 734: 16.7a, 16.7h
- arts. 734-735: 16.7a
- arts. 734-742: 16.7
- art. 735: 16.7
- art. 737: 16.7b, 16.7h
- art. 738: 16.7c, 16.7h
- art. 739: 16.7d, 16.7h
- art. 740: 16.7e, 16.7h

- art. 741: 16.7f, 16.7h
- art. 742: 16.7g, 16.7h
- art. 743: 16.9.2a, 16.9.2d
- arts. 743-756: 16.4
- art. 744: 16.9.2a, 16.9.2b, 16.9.2f
- art. 745: 16.9.2b, 16.9.2f
- art. 746: 16.9.2c
- art. 747: 16.9.2c, 16.9.2f
- art. 748: 16.9.2d, 16.9.2f
- art. 749: 16.9.2e
- art. 750: 16.9.2a, 16.9.2e, 16.9.2f, 17.7.1c:
- art. 751: 16.9.2e
- art. 752: 16.9.2e, 16.9.2f
- art. 753: 16.9.2e
- art. 754: 16.9.2e, 16.9.2f
- art. 755: 16.9.2a, 16.9.2f
- art. 756: 16.9.2a, 16.9.2f
- art. 757: 17.2, 17.6
- arts. 757-776: 17.3
- art. 758: 17.4, 17n12, 17n14, 17.6
- art. 759: 17n14, 17.5.1, 17.6
- art. 761: 17.5.1, 17.6
- art. 762: 17.5.4
- art. 763: 17.6
- art. 764: 17.6
- art. 765: 17.5.2, 17.6
- art. 766: 17.6, 17.7.1, 17.7.1b
- art. 767: 17.5.5a, 17.6
- art. 770: 17.6
- art. 771: 17.6
- art. 772: 17.6
- art. 773: 17.5.2, 17.5.4, 17.6
- art. 776: 17.5.3, 17.6
- art. 777: 17.3
- arts. 778-788: 17.3, 17.7
- art. 779: 17.7.1a
- art. 780: 17.7.1c
- art. 781: 17.7.1
- art. 784: 17.7.1b
- art. 786: 17.7.1d

- art. 787: 17.7.1e
- art. 788: 17.7.1e
- art. 789: 17.7.2
- arts. 789-802: 17.3, 17.7
- art. 790: 17.7.2b
- art. 791: 17.7.2c
- art. 793: 17.7.2c
- art. 794: 17.7.2d
- art. 795: 17.7.2e
- art. 796: 17.7.2e
- art. 800: 17.7.2
- art. 801: 17.7.2f
- art. 802: 17.7.2a
- art. 818: 2.5.4b
- art. 827: 2.5.4c
- art. 831: 2.5.4c
- arts. 851-853: 12.5b
- art. 887: 1.4
- art. 889: 1.6
- art. 897: 4.9
- art. 903: 1.5
- art. 904: 1.2.1
- art. 910: 1.2.1
- art. 921: 1.2.1
- art. 1.002: 8.5c
- art. 1.003: 8.4a, 8.5c
- art. 1.179: 9.4
- arts. 1.361-1.368: 15.6.1
- art. 1.365: 15.6.4
- art. 1.525: 12.4
- art. 1.542: 12.4
- art. 1.647: 1.5

Código Comercial – Lei Imperial n. 556/1850 (CCom)

- art. 35: 16.6
- art. 87: 9.2a
- art. 99: 7.3.1, 16.2, 16.3
- art. 100: 7.3.1, 9.2a
- art. 101: 9.2a, 16.3
- art. 113: 16.9.2d
- art. 115: 16.6

- art. 170: 13.5.2a
- art. 171: 13.5.2a
- art. 175: 13.5.2a
- art. 191: 9.1
- art. 200: 9.2a
- art. 201: 9.9.1
- art. 219: 5.1
- art. 427: 5.1
- arts. 457-796: 16.4
- art. 566: 7.3.1, 16.1, 16.9.1
- art. 575: 7.3.4, 7n28, 16.9.2a
- arts. 666-748: 17.3
- art. 677: 17.5.2
- art. 679: 17.5.2
- art. 702: 17.7.1c
- art. 706: 17.7.1c
- arts. 731-739: 16.4

Regulamento 735

- art. 249: 5.1

Código de Defesa do Consumidor – Lei n. 8.078/90 (CDC)

- art. 3º: 8.5e, 9.1
- art. 6º: 5.3, 15.3.5
- art. 27: 16.9.2e
- art. 30: 8.4a
- art. 35: 8.4a
- art. 39, II: 8.4a
- art. 39, III: 15.3.5
- art. 46: 17.5.1
- art. 54: 17.5.1

Código Penal – Lei n. 2.848/40 (CP)

- art. 172: 5.12

Código de Processo Civil – Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC15)

- art. 105: 12.3a
- art. 125: 9.7.3
- art. 188: 1.6.3
- art. 294: 15.6.5a
- art. 509, § 2º: 4.1a
- art. 784: 2.9, 4.1a, 7.3.2, 17.7.2
- art. 798: 2.9
- art. 700: 2.9f, 4.13

Código Tributário Nacional – Lei n. 5.172/66 (CTN)

- art. 161, § 1º: 2.3.2d, 15.4.3g

DECRETOS, DECRETOS-LEI, LEIS, MEDIDAS PROVISÓRIAS

(em ordem de data)

Decreto n. 917, de 1890

- art. 2º: 5.1
- art. 5º: 6n22

Decreto n. 1.102/03

- art. 6º: 7.2.4
- art. 11: 7.2.2b
- art. 14: 7.2.2a
- art. 15: 7.2.4, 7.2.6a, 7.2.6e
- art. 16: 7.2.6g
- art. 17: 7.2.4
- art. 18: 7.2.4
- art. 19: 7.2.7
- art. 22: 7.2.4
- art. 23: 7.2.9b
- art. 25: 7.2.9b
- art. 26: 7.2.2a, 7.2.6h
- art. 35: 7.2.6c

Decreto n. 2.044/08 – Lei Saraiva (Letra de Câmbio e Nota Promissória) (LS)

- art. 1º: 2.3.6, 2.3.9, 2.4
- art. 6º: 5.1
- art. 7º: 5.1
- art. 11: 2.4
- art. 14: 2.4
- art. 15: 5.8.1
- art. 17: 2.3.4c
- art. 19: 2.3.4b, 2.4
- art. 20: 2.4, 2.7
- art. 22: 5.9.3
- art. 28: 2.4
- art. 40: 5.9.3
- art. 48: 2.4, 2.9e
- art. 51: 2.4, 2.9
- art. 52: 2.4, 2.9e, 3.4
- art. 54: 3.2, 3.3.1, 3.3.3, 5.1

Lei n. 2.591/12

– art. 11: 4.11e

Lei n. 2.681/12

– art. 3º: 16.3

Lei Orçamentária n. 2.919/14

– art. 3º: 5n7

Decreto n. 16.041/23

– art. 14: 5.1

Decreto n. 19.413/30

– art. 1º: 7.3.1

– art. 2º: 7.3.4, 16.9.2a

Decreto n. 20.454/31

– art. 1º: 7.3.5

Decreto n. 22.626/33

– art. 1º: 2.3.2d, 15.4.3g

– art. 4º: 2.3.2d, 6.4b, 8.4a, 14.5.2a

Decreto-lei n. 2.063/40

– art. 199: 12.3b

Lei n. 4.594/64

– art. 1º: 17.5.5d

Lei n. 4.595/64

– art. 17: 4.3b, 14.1

– art. 25: 14n6

Lei n. 4.726/65 – Lei de Registro de Comércio anterior

– art. 10: 17.5.5d

Lei n. 4.728/65 – Lei de Mercado de Capitais

– art. 5º: 17.5.5d

– art. 11: 17.5.5d

– art. 66: 15.6

Lei n. 4.769/65

– art. 2º: 15.4.1

Lei n. 4.886/65

– art. 1º: 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.5

– art. 2º: 10.2.6

– art. 27: 10.2.4, 10.2.6, 10.2.11

– art. 31: 10.2.6

– art. 32: 10.2.6, 10.2.10

– art. 33: 10.2.6

– art. 34: 10.2.7

– art. 35: 10.2.11

Decreto-lei n. 73/66

- art. 13: 17.4
- art. 20: 17.3, 17.5.5a
- art. 21: 17.5.5a
- art. 24: 17.2
- art. 36: 17.2
- art. 73: 17.2
- art. 74: 17.2
- art. 75: 17.2

Decreto n. 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra (LUG)

- art. 1º: 2.3
- art. 2º: 2.3, 2.3.5, 2.3.6
- art. 3º: 2.3.3b
- art. 4º: 2.3.8, 2.5.1b
- art. 5º: 2.3.2d
- art. 9º: 2.3.9, 2.5.1b, 15.4.3e
- art. 10: 2.5.1a
- art. 11: 2.5.1b
- art. 12: 2.5.3b
- art. 13: 1.4.3
- art. 14: 1.4.3
- art. 15: 2.5.3b, 2.5.3c, 3.4, 15.4.3e
- art. 17: 1.4.2, 2.9b
- art. 18: 2.5.3d
- art. 19: 2.5.3d
- art. 20: 2.5.3a
- art. 22: 2.5.1b, 2.5.2c, 3.4
- art. 25: 1.4.3, 2.8b
- art. 26: 2.5.2d
- art. 28: 2.3.3
- art. 30: 1.4.3, 5.8.1
- art. 31: 3.4, 5.8.1
- art. 32: 2.5.4d, 2.5.4e, 2.5.4f
- art. 33: 2.3.4
- art. 34: 2.8c
- art. 35: 3.4
- art. 36: 2.3.4c, 3.4, 5.9.3
- art. 38: 2.4
- art. 39: 1.4.3, 2.7
- art. 43: 2.5.4d
- art. 41: 2.3.2c

- art. 43: 2.3.4b, 2.5.2d, 2.8a, 3.4
- art. 44: 2.5.1b, 2.5.2d, 2.7, 2.8a, 2.8c, 3.4, 5.9.1
- art. 45: 2.5.1b, 2.7
- art. 46: 2.5.1b, 2.7, 2.9
- art. 47: 2.5.4g
- art. 48: 5.11
- art. 50: 1.4.3
- art. 53: 2.5.1b, 2.5.2d, 2.5.2e, 2.7, 2.8a, 2.9, 3.4
- art. 54: 2.5.2e
- art. 57: 1.4.3
- art. 64: 2.5.1c
- art. 65: 2.5.1c
- art. 66: 2.5.1c
- art. 67: 2.9c
- art. 68: 2.5.1c
- art. 70: 2.4, 2.9d, 2.9e, 3.4
- art. 75: 3.2, 3.3.1, 3.3.3
- art. 76: 3.3.3
- art. 77: 3.4
- art. 78: 3.4
- Anexo II, art. 2º: 2.4
- Anexo II, art. 3º: 2.4
- Anexo II, art. 5º: 2.4, 2.7
- Anexo II, art. 6º: 2.4
- Anexo II, art. 7º: 2.3.2c, 2.4
- Anexo II, art. 9º: 2.4
- Anexo II, art. 10: 2.3.4b, 2.4
- Anexo II, art. 13: 2.4
- Anexo II, art. 15: 2.4, 2.9e
- Anexo II, art. 16: 2.4
- Anexo II, art. 17: 2.4
- Anexo II, art. 19: 2.4
- Anexo II, art. 20: 2.4

Decreto n. 57.595/66 – Lei Uniforme do Cheque (LUC)

- art. 3º: 4.3b
- art. 5º: 4.3b
- art. 6º: 4.3b
- art. 8º: 4.3b
- art. 11: 4.3b
- art. 13: 4.3b

- art. 14: 4.3b
- art. 21: 4.3b
- art. 26: 4.3b
- art. 29: 4.3b
- art. 31: 4.3b
- art. 32: 4.3b
- art. 36: 4.3b
- art. 40: 4.3b
- art. 42: 4.3b
- art. 45: 4.3b
- art. 46: 4.3b
- art. 52: 4.3b
- Anexo II (art. 2º): 4.3b
- Anexo II (arts. 2º a 30): 4.3b

Decreto-lei n. 167/67

- art. 5º: 6.4a, 6.4b
- art. 9º: 6.2
- art. 10: 6n6
- art. 14: 6.2
- art. 20: 6.2
- art. 25: 6.2
- art. 28: 6.2
- art. 60: 6n9

Decreto n. 61.934/67

- art. 3º: 15.4.1

Lei n. 5.474/68 – Lei de Duplicatas (LD)

- art. 1º: 5.2.2
- art. 2º: 5.3, 5.9.1
- art. 3º: 5.3
- art. 6º: 5.4
- art. 7º: 5.4, 5.4.3
- art. 8º: 5.4.3, 5.4.4
- art. 9º: 5.9.2, 5.9.3
- art. 11: 5.9.4
- art. 12: 5.8.1, 5.8.2
- art. 13: 5.4.3, 5.7, 5.8.2, 5.9.1
- art. 14: 1.6.2, 5.8.1
- art. 15: 1.6.2, 5.3, 5.4.3, 5.5, 5.9.1
- art. 20: 5.6
- art. 22: 5.6

- art. 23: 5.5
- art. 24: 5.3
- art. 25: 5.3, 5.5, 5.9.1, 5.11, 15.4.3e

Decreto-lei n. 413/69

- art. 5º: 6.4a
- art. 9º: 6.2
- art. 15: 6.2
- art. 52: 6n9

Decreto-lei n. 857/69

- art. 2º: 2.3.2b, 9.3b

Decreto-lei n. 911/69

- art. 3º: 15.6.1, 15.6.5a
- art. 5º: 15.6.5c

Lei n. 5.764/71

- art. 82: 7.2.12

Lei n. 6.268/75

- art. 3º: 2.3.3a, 5.3, 6n12

Lei n. 6.313/75

- art. 5º: 6.2

Lei n. 6.385/76

- art. 16: 17.5.5d

Lei n. 6.404/76 – Lei das Sociedades por Ações (LSA)

- art. 24: 12.5b
- art. 31: 12.5b
- art. 118: 12.9
- art. 119: 12.5b
- art. 126: 12.5b, 12.9
- art. 146: 12.5b

Lei n. 6.729/79

- art. 3º: 10.3.2
- art. 5º: 10.3.2
- arts. 6º-15: 10.3.2
- art. 17: 10.3.2
- art. 18: 10.3.2
- art. 19: 10.3.2
- art. 20: 10.3.2
- art. 21: 10.3.2
- arts. 22-27: 10.3.2
- art. 28: 10.3.2

Lei n. 6.830/80

– art. 1º: 15.4.1

Lei n. 6.840/80

– art. 5º: 6.2

Lei n. 7.132/83

– art. 1º: 15.5.1

Lei n. 7.357/85 – Lei do Cheque (LC)

– art. 1º: 4.1a, 4.4

– art. 2º: 4.1a, 4.3b

– art. 3º: 4.3b

– art. 4º: 4.3b

– art. 7º: 4.3b, 4.11e

– art. 8º: 4.3b

– art. 9º: 4.3b, 4.11b

– art. 11: 4.3b

– art. 13: 4.3b, 4.10

– art. 14: 4.3b

– art. 16: 4.3b, 4.4, 4.12a

– art. 18: 4.6

– art. 21: 4.6

– art. 26: 4.6, 4.8

– art. 27: 4.6, 4.8

– art. 29: 4.9

– art. 32: 4.1a, 4.4, 4.5, 4.12a

– art. 33: 4.3b, 4.4, 4.12, 4.12a, 4.12c

– art. 35: 4.5

– art. 36: 4.3b, 4.5

– art. 42: 4.3b

– art. 44: 4.3b, 4.11c

– art. 45: 4.3b, 4.11c

– art. 46: 4.11d

– art. 47: 4.1a, 4.12, 4.12c, 4.13

– arts. 51-54: 4.13

– art. 52: 4.3b, 5.11

– art. 53: 4.3b

– art. 56: 4.7a

– art. 57: 4.7a

– art. 58: 4.7b

– art. 59: 4.12, 4.12c

– art. 61: 4.3b

– art. 62: 4.3b, 4.13

- art. 63: 4.3b
- art. 64: 4.3b
- art. 66: 4.3b

Lei n. 7.565/86 – Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA)

- art. 227: 16n21
- art. 230: 16.7b
- art. 231: 16.7b
- art. 235: 7.3.4, 16.9.2a

Lei n. 8.934/94

- art. 32: 7.2.1, 17.5.5d
- art. 67: 17.5.5d

Lei n. 8.955/94

- art. 2º: 11.3
- art. 3º: 11.7
- art. 4º: 11.8
- art. 5º: 11.5
- art. 6º: 11.4, 11.5
- art. 7º: 11.8

Lei n. 8.981/95

- art. 28: 15.4

Lei n. 9.069/95

- art. 69: 4.6

Lei n. 9.249/95

- art. 15: 15.4

Decreto n. 1.832/96

- art. 20: 7.3.3
- art. 22: 16.9.2b

Lei n. 9.279/96 – Código da Propriedade Industrial (CPI)

- art. 62: 9.4
- art. 78: 12.5b
- art. 119: 12.5b
- art. 121: 9.4
- art. 136, I: 9.4
- art. 142: 12.5b
- art. 211: 9.4, 11.4
- art. 217: 12.5b

Lei n. 9.432/97

- art. 2º: 16n15

Lei n. 9.492/97

- art. 40: 5.11

Lei n. 9.611/98

- art. 2º: 7.3.3, 16.9.2a
- art. 5º: 7n26
- art. 10: 7.3.4
- art. 21: 16.9.2b
- art. 28: 16.9.2c

Lei n. 9.973/2000

- art. 3º: 7.2.10, 16.9.3
- art. 5º: 7n3
- art. 6º: 7.2.10
- art. 8º: 7.2.10, 7n4
- art. 10: 7.2.10
- art. 11: 7.2.11

MP n. 2.170/2001

- art. 3º: 6.4b
- art. 5º: 14.5.2a

Lei n. 10.192/2001

- art. 1º: 2.3.2b, 9.3b

Lei n. 10.233/2001

- art. 20: 16.5.2
- art. 24: 16.5.2
- art. 25: 16.5.2
- art. 26: 16.5.2
- art. 27: 16.5.2

Lei n. 10.931/2004

- arts. 18-20: 6.2
- arts. 26-27: 6.2
- art. 28: 6n8
- art. 31: 16.6.1
- art. 44: 6n9
- art. 51: 15.6.1

Lei n. 11.076/2004

- art. 1º: 7.2.11
- art. 5º: 7.2.11

Lei n. 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF)

- art. 6º: 9.10.5
- art. 49: 9.10.5
- art. 51: 5.3
- art. 52: 9.10.5
- art. 77: 2.3.4b, 3.4

- art. 81: 2.3.7, 3.3.1e
- art. 83: 7.2.2a, 12.7, 13.7
- art. 85: 9.10.5
- art. 86: 9.6
- art. 94: 13.5.2b
- art. 99: 2.3.4b
- art. 116: 7.2.2a, 12.7
- art. 117: 8.5d1, 9.10.5
- art. 118: 8.5d1
- art. 119: 9.6, 9.10.5, 12.7
- art. 120: 12.3c, 12.9, 13.7
- art. 122: 2.3.7
- art. 128: 2.3.4b
- art. 129: 5.9.3
- art. 168: 5.12

Lei n. 11.182/2005

- art. 3º: 16.5.1
- art. 8º: 16.5.1

Lei 11.977/2009

- art. 37: 5.10
- art. 39: 5.10

Lei 13.775/2018

- art. 4º, § 3º: 5.10

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

(Os números referem-se aos itens.)

Abertura de crédito, 14.5.1

Abstração

- cédula de crédito, 6.3
- cheque, 4.1c
- definição, 1.4.2

Ação cambial

- cheque, 4.13
- defesas cambiais, 2.9a
- duplicata, 5.11
- letra de câmbio, 2.9
- nota promissória, 3.5

Ação causal

- letra de câmbio, 2.9e

Ação de busca e apreensão de coisa alienada – 15.6.5a

Ação de depósito – 15.6.5b

Ação de enriquecimento sem causa

- cheque, 4.3b, 4.13
- letra de câmbio, 2.9e

Ação de execução na alienação fiduciária – 15.6.5b

Ação estimatória, 9.7.2

Ação monitória

- aval, 5.8.3
- cheque, 4.13
- letra de câmbio, 2.9f

Ação redibitória, 9.7.2

Accipiens, 8.4d

Aceite

- letra de câmbio, 2.5.2
- duplicata, 5.4

Afretamento, *v. fretamento*

Agência

- conceito, 10.2.1
- e distribuição e revenda, distinções, 10.2.8
- e mandato e comissão, distinções, 10.2.9

- elementos acessórios do contrato, 10.2.7
- elementos essenciais do contrato, 10.2.6
- extinção do contrato, 10.2.11
- natureza contratual, 10.2.3
- retribuição, 10.2.10
- zona de atividade, 10.2.6c

Agências reguladoras

- agência nacional de aviação civil – ANAC, 16.5.1
- agência nacional de transportes aquaviários – ANTAQ, 16.5.2
- agência nacional de transportes terrestres – ANTT, 16.5.2
- conceito, 16.5

Alienação fiduciária em garantia

- conceito, 15.6.1
- elementos do contrato, 15.6.4
- modalidades, 15.6.3
- objeto, 15.6.2
- proteção processual, 15.6.5

Amostra, 9.9

Apólice, 17.5.1

Armazém-geral

- administradores, 7.2.1
- conceito, 7.2.1
- direitos e deveres, 7.2.2a

Arrendamento mercantil

- definição legal, 15.5.1
- modalidades, 15.5.3
- noções, 15.5
- objeto, 15.5.2
- obrigações dos contratantes, 15.5.4

Arrendamento operacional, 15.5.3

Assinatura digital ou criptográfica, 1.6.3

Atividade bancária

- origem e conceito, 14.1

Atos ilícitos, 8.1

Autonomia, 1.4.2

Auxiliares do comércio, 7.2.1

Aval

- ação monitoria, 5.8.3
- antecipado, 2.5.4f
- antes do vencimento, 5.8.1

- cheque, 4.3b, 4.9
- duplicata, 5.8
- em ato separado, 4.3b
- em branco, 2.5.4b, 5.8
- em preto, 2.5.4b
- letra de câmbio, 2.5.4
- posterior ao vencimento, 5.8.1
- simultâneo, 2.5.4g
- sucessivo, 2.5.4g

Basic disclosure document, 11.7

Beneficiários de seguro, 17.5.5b

Bilhete

- de mercadoria, 1.3
- de passagem, 16.6.1
- de seguro, 17.5.1

Boleto bancário, 5.5

Cambiale agrária, 6.1

Câmbio *trajecticum*, 2.1

Cartões com valores armazenados, 15.3.3

Cartões de credenciamento, 15.3.3

Cartões de crédito

- características, 15.3.3
- conceito, 15.3.1
- espécies, 15.3.2
- natureza das empresas emissoras, 15.3.4
- obrigações contratuais, 15.3.5

Cartões de débito, 15.3.3

Cartões fidelidade, 15.3.3

Cartularidade, 1.4.1

Causa subjacente ou simultânea, 1.4.2

Cessão de crédito

- cheque, 4.6

Cédula de crédito

- bancário, 14.3.2, 14.5.1
- características, 6.3
- definição legal, 6.2
- distinções, 6.1
- encargos moratórios, 6.4
- espécies, 6.2
- finalidade, 6.2

- origem, 6.1
- requisitos, 6.3

Certificado de depósito agropecuário

- definição legal, 7.2.11

Chamamento sucessivo, 9.7.3

Cheque

- ação de enriquecimento sem causa, 4.3b
- ações judiciais, 4.13
- adiantamento de pagamentos, 4.3b
- administrativo, 4.11b
- alterações no texto, 4.7b
- ao portador, 4.11a
- apresentação, 4.12a
- aval, 4.3b
- câmaras de compensação, 4.3b
- circulação, 4.6
- cláusula de intransmissibilidade, 4.3b
- cobrança de comissão, 4.3b
- conceito, 4.1
- conflitos, 4.3b
- contra instituição financeira, 4.3b
- criação, 4.4
- cruzado, 4.3b, 4.11b, 4.11c
- desapossamento, 4.3b
- direitos do portador, 4.3b
- disponibilidade financeira, 4.3b
- especial, 4.3b, 6.1
- incompleto, 4.3b, 4.4
- legislação em vigor, 4.3a
- modalidades de emissão, 4.11
- motivos de devolução, 4.3a
- nominativo, 4.11a
- oposição de pagamento, 4.4
- origem, 4.2
- pagamento, 4.12
- pagamento em domicílio de terceiro, 4.3b
- pagamento em moeda estrangeira, 4.3b
- para levar em conta, 4.11d
- pluralidade de exemplares, 4.7a
- pós-datação, 4.12b

- postal, 4.3b
- prazo para apresentação, 4.3b
- prescrição, 4.3b, 4.12
- protesto, 4.3b
- reservas legais, 4.3b
- revogação de emissão, 4.3b, 4.4
- saque contra o próprio sacador, 4.3b
- sem indicação de lugar de pagamento, 4.3b
- suprimimento de assinatura, 4.3b
- sustação, 4.4
- taxa de juros, 4.3b
- visado, 4.11e
- vistos, 4.3b

Circular de oferta de franquias, 11.7

Cláusula

- cambiária, 2.3.1
- de custos em contratos internacionais, 9.11
- de juros, 2.3.2d, 2.5.1b
- não à ordem, 2.5.1b
- pagamento em moeda estrangeira, 2.3.1b, 2.5.1b
- proibição de aceite, 2.5.1b
- sem garantia, 2.5.1b
- sem protesto, 2.5.1b

Código Savary, 2.1, 17.1.

Colaboradores independentes da empresa, 7.2.1

Compra e venda empresarial

- características, 9.2
- conceito, 9.1
- direito dos contratantes, 9.6
- e compra e venda civil, distinções, 9.1
- elementos formadores, 9.3
- modalidades especiais, 9.9
- obrigações do comprador, 9.8
- obrigações do vendedor, 9.7

Conceitos

- abertura de crédito, 14.5.1
- agência, 10.2.1
- agências reguladoras, 16.5
- alienação fiduciária em garantia, 15.6
- apólice, 17.5.1

- armazéns-gerais, 7.2.1
- atividade bancária, 14.1
- bilhete de passagem, 16.6.1
- bilhete de seguro, 17.5.1
- cartão com valor armazenado, 15.3.3
- cartão de crédito, 15.3
- cartão de débito, 15.3.3
- cédula de crédito, 6.2
- certificado de depósito agropecuário, 7.2.11
- conhecimento de transporte, 7.3.1, 16.6.2
- contrato, 8.2
- cheque, 4.1
- consignação em folha de pagamento, 14.5.1
- crédito documentário, 15.1
- depósito bancário, 14.3.1
- duplicata, 5.2.4
- fatura, 5.2.2
- faturização, 15.4.1
- letra de câmbio, 2.3
- mútuo bancário, 14.5
- nota fiscal, 5.2.1
- nota fiscal-fatura, 5.2.3
- nota promissória, 3.2
- prêmio de seguro, 17.2
- representação comercial autônoma, 10.2.2
- risco, 17.2
- seguro, 17.2
- seguro de dano, 17.7
- seguro de pessoa, 17.7
- título de crédito, 1.4
- *warrant*, 7.2.4
- *warrant* agropecuário, 7.2.11

Concessão comercial, v. revenda

Conforme obligatorio, 5.1

Conhecimento de depósito

- circulação, 7.2.7
- natureza jurídica, 7.2.5a
- noções, 7.2.4
- requisitos, 7.2.6
- responsabilidade dos endossantes, 7.2.9

Conhecimento de transporte

- características, 7.3.2
- circulação, 7.3.5
- conceito, 7.3.1
- espécies, 7.3.3
- definição legal, 7.3.1
- origem, 7.3.1

Consignação em folha de pagamento, 14.5.1

Conta conjunta, 14.3.3

Contas assinadas, 5.1

Contrato

- bancário histórico, 14.2
- bilateral imperfeito, 12.2
- classificação, 8.5
- cláusulas gerais, 8.2
- conceito, 8.2
- de agência, v. *agência*
- de cartão de crédito, 15.3
- de compra e venda
 - a termo, 9.5
 - complexa, 9.5
 - critérios para determinação do preço, 8.3b
- de desconto e redesconto, 14.4
- de distribuição, 10.1
 - distinções, 10.1
- de franquia, v. *franquia*
- de mandato, v. *mandato*
- de *pilotage*, 11.6
- de seguro, v. *seguro*
- de transporte
 - classificação jurídica, 16.3
 - de bagagem, 16.8
 - de coisas, 16.9
 - de pessoas, 16.7
 - definição legal, 16.2
 - direitos, deveres e responsabilidades, 16.7
 - espécies e estrutura legislativa, 16.4
 - formação e prova, 16.6
 - multimodal, 16.9.3
 - noções, 16.2

- origens, 16.1
- regular e fretamento, 16.9.1
- empresariais, distinções, 8.3
- estimatório, 9.12.1
- internacional, cláusulas de custos, 9.11
- modernos de crédito e de fomento
 - classificação, 15.2
- princípios informadores, 8.4
- unilateral, bilateral e plurilateral, distinções, 8.1

Conventional factoring

- na liquidação de créditos, 15.4.3d
- natureza bancária, 15.4.3g

Corretor, 7.2.1

Crédito documentário, 9.10.7

Defesa cambial

- direito pessoal, 4.1c
- matéria, 2.9a

Depositante (armazém-geral)

- direitos e deveres, 7.2.2b

Depósito bancário

- classificações, 14.3.2
- conceito, 14.3.1
- origem, 14.3

Desconto e redesconto, 14.4

Direito de desistência, 16.7e

Direito de retenção, 16.7g

Distribuição

- significado do vocábulo, 10.1

Duplicata

- aspectos penais, 5.12
- classificação, 5.1
- conceito, 5.2.4
- criação, 5.3
- espécies, 5.2.5
- origem, 5.1
- pagamento, 5.9
- simulada, 5.12
- virtual, 1.6.2

Efeitos móveis e semoventes, 9.3a

Emptio rei speratae, 9.3a

Emptio spei, 9.3a

Endosso

- cambial, 2.5.3
- no cheque, 4.6
- no cheque – modalidades, 4.8
- na duplicata, 5.7

Equivalência obrigacional, 2.5.4e

Estipulantes, 17.5.5a

Estrada de Ferro Mauá, 16.2

Evicção, 9.7.3

Exceptio non adimpleti contractus, 8.5d1

Extrato de fatura, 5.1

Factoring, v. *faturização*

Factoring de vencimento, 15.4.3d

Falido

- e mandato, 12.3c, 12.9

Fatura

- conceito, 5.2.2
- cambiária, 5.1
- conformada, 5.1
- conta e duplicata de prestação de serviços, distinções, 5.6
- protestável, 5.1

Faturização

- cláusulas essenciais, 15.4.3
- conceito, 15.4.1
- direito de regresso, 15.4.4
- distinção com mútuo bancário, 15.4.3g
- garantias, 15.4.5
- sujeitos da relação, 15.4.2

Fiança, 2.5.4c

Financial lease, 15.5.3

Financiamento bancário, 14.5.1

Fomento mercantil, v. *faturização*

Fonte de obrigação, 8.1

Franchising, v. *franquia*

Franquia

- circular de oferta, 11.7
- contrato de *pilotage*, 11.6
- de conversão, 11.3
- de distribuição, 11.3

- de marca, 11.3
- de negócio, 11.3
- de produção, 11.3
- de produto, 11.3
- de serviço, 11.3
- definição legal, 11.3
- extinção do contrato, 11.8
- formação e elementos do contrato, 11.5
- função econômica, 11.2
- modalidades, 11.3
- natureza do contrato, 11.4
- origens, 11.1
- pré-contrato, 11.6
- quadro de direitos e obrigações, 11.3

Fretamento, 16.9.1

Hedging, 9.12.2

Incoterm, 9.11

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, 1.6.3

Inoponibilidade das exceções pessoais, 1.4.2, 2.9b, 4.1c, 4.10

International Chamber of Commerce, 9.10.7

Leasing, v. *arrendamento mercantil*

Leasing bancário, 15.5.3

Letra de câmbio

- conceito, 2.3
- direito aplicável, 2.2
- época de pagamento, 2.3.4
- evolução histórica, 2.1
- incompleta, 2.5.1a
- requisitos formais, 2.3

Literalidade

- cédula de crédito, 6.3
- definição, 1.4.3

Livrança, 1.2.4

Mandato

- características do contrato, 12.2
- cláusulas de substabelecimento, 12.6
- coletivo, 12.3e
- definição legal, 12.1
- e falência, 12.9
- efeitos do mandato em relação a terceiros, 12.8

- excesso de mandato:
 - conhecido pelo terceiro, 12.8a
 - não conhecido pelo terceiro, 12.8b
- extinção do contrato, 12.9
- plural, 12.3d
- reconhecimento de firma, 12.5c
- requisitos
 - formais, 12.5
 - objetivos, 12.4
 - subjetivos, 12.3
- substabelecimento, 12.6

Matrícula

- de leiloeiro, 7.2.1
- intérprete comercial, 7.2.1
- tradutor público, 7.2.1

Maturing factoring, 15.4.3d

Mercadoria

- do mesmo gênero, 7.2.3
- misturada, 7.2.3

Modelo, 9.9

Mútuo bancário

- espécies contratuais, 14.5.1

Negócios unilaterais, 8.1

Nexum, 8.4d

Nota fiscal

- conceito, 5.2.1
- eletrônica, 1.6.3
- fatura, 5.2.3

Nota promissória

- a certo tempo da vista, 3.4
- conceito, 3.2
- direito aplicável, 3.4
- história, 3.1
- incompleta, 3.3.2
- requisitos, 3.3
- requisitos não essenciais, 3.3.3
- rigor formal, 3.3.4
- vinculação a contrato, 3.5

Obrigações

- consecutiva, 4.1b

- líquida, 4.1

Old line factoring, 15.4.3d

Ordennance sur Le Commerce de Terre, 2.1

Pacta sunt servanda, 8.4e

Pacto

- comissório, 9.10.1
- de melhor comprador, 9.10.1

Pagamento

- antecipado, 5.9.3
- cambial, 2.6
- cheque, 4.12
- por intervenção, 2.6b
- prazo, 5.9.2
- prorrogação, 5.9.4
- recuperatório, 2.6

Pilotage, 11.6

Preempção, 9.10.4

Preferência, 9.10.4

Prescrição

- cheque, 4.12
- cheque – causas de suspensão, 4.3b
- letra de câmbio, 2.9d

Primagem, 7n27

Princípios

- autonomia da vontade, 8.4a
- boa-fé objetiva, 8.4c
- consensualismo, 8.4d
- equilíbrio econômico, 8.4f
- força obrigatória, 8.4e
- função social do contrato, 8.4b
- relatividade dos efeitos do contrato, 8.4g

Protesto

- cambial, 2.8
- de cheque – agente incumbido, 4.3b
- de duplicata, 5.9.1

Protótipo, 9.9

Quadros

- agência, distribuição, mandato e comissão – distinções, 10.2.9, 13.4
- causas de extinção do contrato de mandato, 12.9
- circular de oferta de franquias, 11.7

- classificação das novas técnicas contratuais, 15.2
- cláusulas de substabelecimento, 12.6
- contratos de distribuição – distinções, 10.1
- de direitos, deveres e responsabilidade no contrato de transporte de coisas, 16.9.2f
- de direitos, deveres e responsabilidade no contrato de transporte de pessoas, 16.7h
- de direitos e obrigações na franquias, 11.3
- direito de desistência no contrato de transporte, 16.7e
- direitos e obrigações no seguro, 17.6
- empresalidade dos agentes, 10.2.5
- espécies de cartões de crédito, 15.3.2
- espécies de contratos de transporte e estrutura legislativa, 16.4
- espécies de mútuos bancários e outras operações ativas, 14.5.1
- grau de responsabilidade no substabelecimento, 12.6
- legislação do contrato de transporte, 16.4
- mandato plural, 12.3b
- modalidades de contratos de alienação fiduciária, 15.6.3
- obrigações dos contratantes no contrato de mandato, 12.7
- sujeitos da relação contratual no fomento mercantil, 15.4.2

Quanti minoris, 9.7.2

Quid senti onus, sentire debet commodum et contra, 15.4.3d

Recusa de passageiros, 16.7d

Regulamento de transporte, 16.7c

Representação comercial autônoma

- conceito, 10.2.2

Representante comercial, 7.2.1, 10.2.2

Ressaque, 2.6c

Renting, 15.5.3

Retail cards, 15.3.3

Retrovenda, 9.10.2

Revenda

- como concessão mercantil, 10.3.
- convenções, 10.3.6
- de automóveis, 10.3.2
- direitos e deveres, 10.3.5
- formalidade contratual, 10.3.7
- indenizações, 10.3.9
- resolução do contrato, 10.3.8
- zona de atuação, 10.3.4

Right of stoppage in transitu, 9.6

Saque, 2.5.1

Seguro

- apólice, 17.5.1
- beneficiários, 17.5.5b, 17.7.2c
- bilhete de seguro, 17.5.1
- características, 17.4
- carência, 17.7.2e
- cláusulas restritivas, 17.5.1, 17.7.2e
- conceitos, 17.2
- corretores de, 17.5.5d
- de dano, 17.7.1
- de dano – conceito, 17.7
- de pessoa, 17.7.2
- de pessoa – conceito, 17.7
- definições, 17.2
- direitos e obrigações das partes, 17.6
- e dívidas, 17.7.2d
- e herança, 17.7.2d
- e suicídio, 17.7.2e
- espécies contratuais, 17.7
- estipulação sobre a vida de outrem, 17.7.2b
- estipulantes de, 17.5.5a, 17.7.2f
- formação e desenvolvimento contratual, 17.5
- legislação aplicável, 17.3
- noções, 17.2
- noções históricas, 17.1
- nulidade na formação do contrato, 17.5.4
- objeto da prestação, 17.5.3
- prêmio, 17.2, 17.7.2e
- regido por leis especiais, 17.3
- risco, 17.2
- sujeitos da relação, 17.5.5

Self leasing, 15.5.3

Sponsio, 8.4d

Stabilito di compravendita, 5.1

Stipulatio, 8.4d

Súmula

- PTAC (11): 6n2
- STF (121): 14.5.2
- STF (387): 3.3.2
- STF (596): 6.4b, 14.5.2b

- STF (648): 14.5.2b
- STJ (30): 14.5.2c
- STJ (93): 6.4b
- STJ (145): 16.7
- STJ (233): 6.1
- STJ (248): 5.6
- STJ (257): 17.7.1e
- STJ (503): 2.9fn61
- STJ (504): 2.9fn61

Taxa de juros

- capitalização, 6.4b
- cédula de crédito, 6.4a

Teoria dos equivalentes, 2.3

Título

- à ordem, 1.2.1
- a prazo, 1.2.5
- à vista, 1.2.5
- abstrato, 1.2.5
- ao portador, 1.2.1
- atributivo de direitos, 1.2.3
- autônomo, 4.1c
- causal, 1.2.5
- cooperativa, 7.2.12
- desmaterializado, 1.6
- eletrônico, 1.6
- espécies reguladas, 1.3
- estrangeiro, 1.2.5
- executivo, 4.1a
- exigibilidade, 4.1a
- formal, 4.1b
- impróprio, 1.1, 1.2.2
- misto, 1.2.1
- nacional, 1.2.5
- nominativo, 1.2.1
- participação social, 1.2.4
- prestação, 1.2.3
- privado, 1.2.5
- próprio, 1.1, 1.2.2, 1.2.4
- público, 1.2.5
- regulado pelo Código Civil, 1.5

- representativo, 1.2.4, 7.1
- representativo de direito real, 1.2.3
- virtual, 1.6

Trade acceptance, 5.1

Tradens, 8.4d

Tradição

- alegórica, 9.7.1

Transporte cumulativo

- de coisas, 16.9.2f
- de pessoas, 16.7h

Trapicheiro, 7.2.1

Triplicata, 5.5

Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits, 9.10.7

Uniform Franchise Offering Circular, 11.7

Valor Residual, 15.5.4

Venda

- a contento, 9.10.3
- com reserva de domínio, 9.10.5
- de coisa móvel à vista de amostras, 9.9.1
- de imóvel *ad mensuram e ad corpus*, 9.9.2
- sobre documentos, 9.10.6
- sujeita a prova, 9.10.3

Venire contra factum proprium – 8.4c

Warrant

- agropecuário, 7.2.11
- circulação, 7.2.7
- conceito, 7.2.4
- natureza jurídica, 7.2.5a
- noções, 7.2.4
- produtor rural, 7.2.10
- requisitos, 7.2.6
- responsabilidade dos endossantes, 7.2.8

Zona de atuação

- da revenda, 10.3.4
- do agente, 10.2.6c

¹ Segundo Houaiss (*Dicionário Eletrônico da Língua Portuguesa*), a palavra quirógrafo tem sua datação anotada por Francisco Solano Constâncio, *Novo Dicionário Crítico e Etymológico da Língua Portuguesa* Paris, 1836. Compõe-se de *quirós* (do grego *kheir*, *kheirós*, “mão”) e *grafos* (escrever, inscrever).

² Embora no sítio eletrônico do Palácio do Planalto (www.planalto.gov.br) este diploma legal apareça como revogado pelo Decreto de 25-4-1991, isso não ocorreu. O Decreto n. 19.473/30 e os que se seguiram gozam de força de lei e não poderiam ser revogados por um decreto presidencial, conforme também anota a 60ª edição do *Código Comercial* da Ed. Saraiva (p. 66).

³ Fábio Ulhoa Coelho prefere dizer que “o princípio da autonomia das obrigações cambiais se desdobra em dois outros subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. Qualifico-os de subprincípios porque, na verdade, nada acrescentam ao que já se encontra determinado pelo princípio da autonomia. A abstração e a inoponibilidade correspondem a modos diferentes de se reproduzir o preceito da independência entre as obrigações documentadas no mesmo título de crédito” (2016, 1:383). Diversamente entendemos que são consequências práticas – e não subprincípios – da aplicação do princípio da autonomia.

⁴ Anoto que as expressões aqui utilizadas “independência” e “abstração” possuem correspondentes homógrafos, cujos significados, contudo, referem-se a classificações dos títulos de crédito. Independentes ou completos são os títulos que contêm “*tudo* aquilo ou *só* aquilo que a lei determina” (Eunápio Borges, 1975:16) e abstratos referem-se aos que não mencionam na emissão a causa, em oposição a títulos causais, como a duplicata, por exemplo.

⁵ BRASIL. Senado Federal *Código Civil Anteprojeto*, Brasília, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1989, v. 5, t. 2, p. 57, citado por Pedro A. Batista Martins. Sobrevoos aos Títulos de Crédito no Novo Código Civil. In *Direito de Empresa no Novo Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 560.

⁶ O CPC15 não reproduziu a norma (v. art. 188 e ss. do novo CPC) e não precisava fazê-lo, porque cada Tribuna disciplinou, no âmbito de sua competência, a matéria procedimental.

⁷ Embora a Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, tenha acrescentado a palavra “vetado” no parágrafo único do art. 154, certo é que a redação dada pela Lei n. 11.280 continua em vigor. Veja-se neste sentido Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa (2009:291-292) e Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2007:420).

⁸ Rubens Requião prefere denominar os equivalentes “Requisitos Supríveis”, porque a Lei Uniforme “permite que algumas menções sejam supridas, amenizando, assim, a essencialidade de tais requisitos” (1995, 2:318 e 325). Fran Martins assinala esses requisitos sob a rubrica de “requisitos não essenciais na Lei Uniforme” (2010:86).

⁹ Enunciado n. 20, aprovado na Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, entre 11 e 13 de setembro de 2002: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês”.

¹⁰ O art. 81 da Lei de Falências dispõe que a falência da sociedade acarreta a falência dos sócios ilimitadamente responsáveis, salvo se, por força de alteração contratual, tenham se retirado há mais de dois anos ou se a retirada ocorreu em período inferior, inexistam, na data do arquivamento da alteração social, dívidas não solvidas habilitadas na falência. A data do saque documenta o momento em que nasceu a obrigação da sociedade agora em estado falimentar, bastando verificar a situação do sócio solidário em relação à data de saque, comparando-a com o documento registrado na Junta Comercial, quanto à sua retirada.

¹¹ Observe que o Decreto n. 57.663/66 promulga duas convenções: “para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias” e “para regular certos conflitos de leis em matéria de letras de câmbio e notas promissórias e protocolo”.

¹² Neste sentido é o entendimento da jurisprudência: “Promissória – Prescrição trienal da lei uniforme. 1) O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu unanimemente que tem eficácia imediata no país a Convenção Internacional aprovada pelo Congresso em Decreto Legislativo e promulgada por decreto do Presidente da República (RE 71.154 na *RTJ*, 58/70). 2) A Lei Uniforme sobre Cambiais e Promissórias está vigente no Brasil, porque o Decreto Legislativo n. 54/1964 aprovou, e o Decreto Executivo n. 57.663 de 24-1-66 promulgou a Convenção de Genebra, da qual se originou esse diploma. 3) Pela Lei Uniforme de Cambiais, art. 70, a prescrição da ação executiva cambial para cobrança de promissória passou a ser de 3 anos, revogadas as disposições da Lei n. 2.044/1908, que estabeleciam o prazo de 5 anos. 4) A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sustenta a eficácia imediata da lei que reduz prazos prescricionais, aplicando-a aos que estiverem em curso, ressalvadas as causas pendentes (Súmula 445)” (RE n. 76236, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 5-9-1973, *DJ*, 5-11-1973, *RTJ*, 67-03, p. 601). Veja-se também RE n. 91.050/RJ, Rel. Min. Décio Miranda, j. 8-4-1983.

¹³ A Lei Uniforme menciona ainda a falência do sacador em letra não aceitável, hipótese que se insere na reserva do art. 10 do Anexo II (v. item 2.3.4, *b* e quadro da reserva no item 2.4, art. 10).

¹⁴ Portugal preferiu adotar, na tradução de sua Lei Uniforme, a denominação “livrança”, abandonando a expressão “nota promissória” que, ao lado de “bilhete à ordem” (tradução do francês *billet à l'ordre*), já constava do Código Comercial Português de 1833 (art. 104), conforme anota Miguel J. A. Pupo Correia (1999:116, nota 109).

¹⁵ “Nota Promissória. Assinatura no verso. Validade. É nota promissória a declaração que contém todos os requisitos da lei, embora a assinatura do emitente tenha sido lançada no verso do documento, desde que disso não surja dúvida alguma sobre a natureza da obrigação assumida pelo subscritor. Art. 54 do Dec. 2044/1908. Art. 75 da Lei Uniforme. Recurso não conhecido” (REsp n. 474.304/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, 26-5-2003, *DJ*, 4-8-2003, p. 316).

¹⁶ O art. 81 da Lei de Falências dispõe que a falência da sociedade acarreta a falência dos sócios ilimitadamente responsáveis, salvo se, por força de alteração contratual, tenham se retirado há mais de dois anos ou, se a retirada ocorreu em período inferior, inexistam, na data do arquivamento da alteração social, dívidas não solvidas habilitadas na falência. A data do saque documenta o momento em que nasceu a obrigação da sociedade agora em estado falimentar, bastando verificar a situação do sócio solidário em relação à data de saque, comparando-a com o documento registrado na Junta Comercial, quanto à sua retirada.

¹⁷ A jurisprudência há muito assentou a essencialidade dos dois últimos requisitos: “Nota Promissória. Data e lugar de sua emissão. São requisitos essenciais, de acordo com a orientação do STJ: REsp’s 3.835, 7.928, 8.749 e 12.013 Recurso especial conhecido e provido” (REsp n. 39.343/RS, Rel. Min. Nilson Naves, Terceira Turma, j. 14-6-1994, *DJ*, 8-8-1994, p. 19564). Contudo, esses requisitos podem ser sanados por elementos constantes do contrato vinculado, conforme recente julgado: “Direito cambiário e processual civil. Nota promissória vinculada a contrato de prestação de serviços advocatícios. Ausência de indicação de data da emissão da nota. Executividade. Omissão sanada pelo contrato a ela vinculado. [...] 2. Descabe extinguir execução pelo só fato de inexistir data de emissão da nota promissória, quando possível tal aferição no contrato a ela vinculado, mesmo porque ‘a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto’ (Súmula 387/STF). [...] 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp n. 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19-8-2010, *DJe*, 3-9-2010).

¹⁸ Neste sentido: “Recurso especial. Emenda da inicial. Ausência de prequestionamento. Contrato de confissão de dívida garantido por aval. Nota Promissória. Contrato originário. Título executivo. Requisitos do título executivo Exame *ex officio*. 1. O tema da emenda da inicial, no caso de irregularidades nos demonstrativos do débito, carece de prequestionamento. 2. Conforme jurisprudência desta Corte, o contrato de confissão de dívida é título executivo, podendo executar-se a nota promissória a ele vinculada. 3. Os requisitos do título executivo dizem respeito à condição da ação, podendo ser examinados de ofício pelo Tribunal. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte” (REsp n. 399.681/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 10-9-2002, *DJ*, 25-11-2002, p. 230).

¹⁹ Objeção de não executividade, exceção de executividade ou de pré-executividade ou, ainda, “oposição por simples requerimento” (expressão anotada por Araken de Assis, *Manual do Processo de Execução*. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 521) são termos equivalentes que exprimem modalidade excepcional de defesa por parte do devedor executado, sem a necessidade de se valer da forma usual de oposição, os embargos à

execução. Aceita pela jurisprudência, é francamente utilizada nos processos executórios, sempre sob o fundamento de que a matéria suscitada envolve pressupostos processuais, matéria de ordem pública que o magistrado deve examinar de ofício. Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery assim o definem: “É meio de defesa que prescinde da segurança do juízo para ser exercido, justamente porque versa sobre matérias de ordem pública, a respeito das quais o juiz deve pronunciar-se de ofício. Se a ação de execução não poderia ser proposta em virtude de, por exemplo, faltar eficácia executiva ao título, não se pode onerar o devedor com a segurança do juízo para poder se defender. Admite-se a defesa sem a segurança do juízo, por meio de objeção de pré-executividade, desde que a matéria objeto dessa defesa seja de ordem pública, ou seja, aquelas sobre as quais o juiz tem o dever de examinar e decidir *ex officio*, independentemente de provocação da parte ou interessado” (1999:1185).

²⁰ Recorde-se aqui o quanto anotamos no quadro do item 2.4, art. 17, no Capítulo 2: A quase totalidade dos autores entende que o prazo prescricional é totalmente regido pelo art. 70 da Lei Uniforme, isto é, a ação contra o aceitante prescreve em 3 anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea I). Para Fran Martins, com a reserva, o quadro do art. 70 da LUG se modifica: a ação contra o aceitante prescreve em 5 anos (LS, art. 52) da data em que a ação pode se proposta e não em 3 anos do vencimento (LUG, art. 70, alínea I).

²¹ Neste sentido: “Embargos de declaração. Agravo regimental desprovido. Omissão inexistente. 1. A pretensão recursal já foi devidamente rebatida no Acórdão do agravo regimental (fls. 88 a 95) e dos respectivos embargos de declaração (fls. 98 a 103), estando expressamente consignado que o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 43 da Lei Uniforme não estabelece a obrigatoriedade do protesto para o exercício do direito de ação contra sacado no caso de falta de pagamento no dia do vencimento do título e que desnecessário o protesto por falta de pagamento da nota promissória, para exercício do direito de ação do credor contra o seu subscritor e respectivo avalista. Mencionados, ainda, trechos de precedente desta Corte e vasto posicionamento doutrinário, não se podendo cogitar de omissão. 2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 414.958/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 10-12-2000, DJ, 31-3-2003, p. 217).

²² V. por exemplo: “Processo Civil. Ação de Execução. Emissão de título de crédito – nota promissória – vinculada a contrato de abertura de crédito. Ausência de exigibilidade. Título cambial emitido como garantia de dívida bancária. Ausência de circulação. Perda da natureza cambiária. – Ausente a circulação do título de crédito, a nota promissória que não é sacada como promessa de pagamento, mas como garantia de contrato de abertura de crédito, a que foi vinculada, tem sua natureza cambial desnaturada, subtraída a sua autonomia – A iliquidez do contrato de abertura de crédito é transmitida à nota promissória vinculada, contaminando-a, pois o objeto contratual é a disposição de certo numerário, dentro de um limite prefixado, sendo que essa indeterminação do *quantum* devido comunica-se com a nota promissória por terem nascido da mesma obrigação jurídica” (AgRg no REsp n. 275.058/RS, Rel. Min. Nancy Andrichi, Terceira Turma, j. 17-5-2001, DJ, 11-6-2001, p. 206).

²³ É possível, contudo, ao autor da execução demonstrar que o cheque não circulou, justificando a impossibilidade de juntá-lo ao pedido ou apresentá-lo posteriormente, como entende a jurisprudência, nesses dois casos: (a) “I – A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias de cheques, ainda que autenticadas. II – Devolvidos no entanto, os originais dos cheques ao credor por decisão judicial, tendo em vista inexistência de cofre no cartório, e reapresentados em audiência, sem qualquer impugnação à autenticidade da cópia apresentada, não há falar em nulidade. Recurso não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia” (REsp n. 330.086/MG, DJ, 22-9-2003, p. 315, Rel. Min. Castro Filho, j. 2-9-2003, STJ, Terceira Turma); (b) “Não se inviabiliza a execução pelo só fato de inicial não ter sido acompanhada do original do cheque em que se funda, em face de referido título encontrar-se em autos de inquérito policial. O requisito do prequestionamento só se acha suprido, em havendo omissão no aresto da apelação, se o Órgão julgador, ao decidir os aclaratórios, tiver efetivamente enfrentado as questões nele veiculadas, suprimindo a omissão apontada, sob pena de, se ofensa à lei federal houver, ser aos arts. 458, II, e 535 do Código de Processo Civil, o que não se veiculou na espécie. Não se conhece do recurso especial pelo dissídio pretoriano sem a demonstração analítica da divergência. Recurso não conhecido” (REsp n. 106.035/RS, DJ, 18-10-1999, p. 233, RSTJ, v. 128, p. 327, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 15-6-1999, STJ, Quarta Turma).

²⁴ Divergindo do autor quanto à classificação, entendemos que abstração e inoponibilidade são consequências práticas da aplicação do princípio da autonomia. Importante fixar que a abstração e a inoponibilidade derivam da autonomia (seja como subprincípio, seja como realidade prática).

²⁵ Discorrendo sobre a origem do cheque, Frederico da Costa Carvalho Neto escreve: “Há controvérsia cor relação a sua origem, na medida em que alguns documentos exerceram a mesma função do cheque, uma ordem de pagamento a terceiro. Consenso, existe com relação à semelhança de ordens de pagamentos que já na segunda metade da Idade Média circulavam e vinculavam aqueles que nela intervinham. Esses documentos foram denominados na Itália como ‘polizze notata fede’ e na Inglaterra de ‘bills of saccario’. Mas foi na Inglaterra que o cheque ganhou as características atuais tendo sido incorporado nos Estados Unidos e em outros países” (2003:63-64).

²⁶ A lei não exige que a inscrição da data se faça por extenso, tornando-se prática usual que o mês seja assim grafado. Fábio Ulhoa Coelho (2016:1,441) lembra que o “direito brasileiro já contemplou norma obrigando que o mês se indicasse por extenso no cheque”, mencionando o D. n. 22.393/33 e a posição de Fran Martins quanto à afirmação de sua vigência.

²⁷ Fran Martins anota: “Título próprio do direito brasileiro, criado em face de circunstâncias especiais de nossas atividades mercantis em suas relações com o fisco, a duplicata vem prestando inestimáveis serviços ao desenvolvimento do comércio, a ponto de ser chamada por Tullio Ascarelli de ‘título príncipe do direito brasileiro’ (...) Apesar de ser o nosso direito o que melhor regula o assunto, não é o Brasil o único país a utilizar títulos especiais para a cobrança das importâncias relativas às vendas a prazo. Em uns poucos outros, a

prática comercial levou à criação de títulos que têm alguma semelhança com a duplicata; e a influência direta do direito brasileiro se faz sentir em determinadas legislações, que transplantaram princípios de nossas leis, instituindo títulos semelhantes aos nossos” (2010:425).

²⁸ Art. 427. Tudo quanto neste Título fica estabelecido a respeito das letras de câmbio, servirá de regra igualmente para as letras da terra, para as notas promissórias e para os créditos mercantis, tanto quanto possa ser aplicável.

²⁹ O § 8º do art. 3º da Lei Orçamentária n. 2.919, de 1914, *com a redação original*, dispunha: “Fica o Governo autorizado a providenciar em regulamento de modo a tornar efectiva a cobrança do imposto de sello proporcional a que estão sujeitas pelo n. 4 do § 1º da Tabella A do decreto n. 3.564, de 1900, as facturas ou contas assignadas (*art. 219 do Codice Commercial*), podendo estabelecer que sejam as mesmas equiparadas às letras de câmbio e às notas promissórias (reguladas pela lei n. 2.044, de 31 de dezembro de 1908), assim como que o imposto seja igualmente cobrado sobre a triplicata das mesmas facturas ou contas e que possam estas ser levadas a protesto pelo vendedor no caso de recusa pelo comprador de assignatura das duplicatas, instituindo, porém, neste caso, os necessários meios de defesa para este”.

³⁰ “Art. 19. A nota fiscal conterà, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: § 7º A nota fiscal poderá servir como fatura, feita a inclusão dos elementos necessários no quadro ‘FATURA’, caso em que a denominação prevista nas alíneas *n* do inciso I e *d* do inciso IX, passa a ser Nota Fiscal-Fatura” (Ajuste SINIEF, na redação que levou o n. 3/94).

³¹ A padronização, proposta do Ministério da Indústria e do Comércio (antigo nome do atual Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços), conforme dispôs o art. 27 da Lei de Duplicatas, foi atendida pela Resolução n. 102 de 26 de novembro de 1968, do Banco Central do Brasil.

³² Os modelos 1 (duplicata mercantil) e 1 A (duplicata de prestação de serviços) referem-se a operações liquidáveis em um só pagamento, isto é, o valor da duplicata é idêntico ao da fatura. Os modelos 2 e 2 A são indicados para as mesmas respectivas espécies e correspondem às operações com pagamento parcelado (uma emissão para cada parcela), e os modelos 3 e 3 A correspondem às operações com pagamento parcelado, mas uma só emissão e discriminação no corpo da duplicata de cada uma das parcelas, com seus respectivos vencimentos.

³³ Nota de rodapé mencionada por Carvalho de Mendonça: *A cambial*, § 93. No mesmo sentido Paulo de Lacerda *A cambial*, n. 135; Magarinos Torres, *Nota promissória*, n. 124; Arruda, *Dec. n. 2.044, anotado*, v. 1, p. 66, n. 6, e Waldemar Ferreira, na *Revista Jurídica*, 11/418, e nos *Estudos de Direito*, p. 155-156. Sorani (*Della cambiale*, § 309) e Vidari (*Corso*, v. 7, n. 6.825) no mesmo sentido doutrinam no direito italiano, dizendo que, assim como o endosso depois do vencimento é possível com os efeitos da cessão civil, o aval depois do vencimento pode valer como fiança. No sistema brasileiro não há analogia nos dois casos: o endosso é o meio de transferência, o aval não é

fiança.

³⁴ A este respeito Humberto Theodoro Júnior cita o texto de encaminhamento da MP n. 2.160, do então Ministro da Economia Pedro Malan ao Presidente da República: “Há muito tempo, o mercado financeiro necessita de um título de crédito que espelhe com realidade as relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes e que, principalmente, torne a formalização das diversas operações de crédito menos onerosa e complicada, conferindo maior flexibilidade e agilidade na mobilização do crédito, cumprindo, assim, com a extraordinária função econômica para a qual foi concebida a primeira cédula, inspirada na legislação italiana, especificamente na ‘Cambiale Agrária’, utilizada na concessão de crédito para a atividade agropecuária, matéria que cuidou o Decreto-Lei Real n. 1.509, de 24 de julho de 1927 (que disciplinou o crédito agrário), regulamentado pelo Decreto Ministerial de 23 de janeiro de 1928, decreto esse que foi convertido na *Legge 5 luglio* 1928, n. 1.760” (A Cédula de Crédito Bancário, *RDBMCA*, n. 22, out./dez. 2003, p. 19).

³⁵ Súmula 11: “Contrato de conta corrente – Execução por título extrajudicial – O contrato de conta corrente, feito por estabelecimento bancário a correntista assinado por duas testemunhas e acompanhado do extrato da conta corrente respectiva, é título executivo extrajudicial” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 283.540 – SP j. 21-10-82 – Pleno. Rel.: Fonseca Tavares. Publicado no *DJE* n. 194:29, de 15 de outubro de 1987).

³⁶ A disciplina da Cédula de Crédito Bancário iniciou-se com a MP n. 1.925, de 14 de outubro de 1999, seguida pelas diversas edições sob n. 2.065 e 2.160. Em 2004 foi sancionada a Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, que a regulamentou nos arts. 26-45, revogando a MP n. 2.160.

³⁷ Confira-se também em *RDBMCA* n. 22, p. 21-22, no artigo citado de Humberto Theodoro Júnior, e, ainda, BULGARELLI, Waldirio. *Títulos de Crédito*. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 465-466.

³⁸ Confira-se: art. 10 do Decreto-lei n. 167/67; art. 10 do Decreto-lei n. 413/69; art. 1º da Lei n. 6.313/75; art. 1º da Lei n. 6.840/80; art. 28 da Lei n. 10.931/2004, respectivamente, para as Cédulas de Crédito Rurais, Cédulas de Crédito Industriais, Cédulas de Crédito à Exportação, Cédulas de Crédito Comerciais e Cédulas de Crédito Bancário. Para as Cédulas de Crédito Imobiliárias o legislador não utiliza a expressão “certa, líquida e exigível”, mas o faz com outras palavras: “exigível pelo valor apurado de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato que lhe deu origem” (art. 20 da Lei n. 10.931/2004).

³⁹ Decreto-lei n. 167/67: “Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas”. O art. 52 do Decreto-lei n. 413/69 manteve essa mesma redação e as Leis n. 6.313/75 e 6.840/80 determinaram sua aplicação às cédulas de crédito à exportação e às de crédito comercial. O art. 44 da Lei n. 10.931/2004 estabelece a aplicação da legislação cambial “no que não contrariar o disposto nesta Lei”, mantendo, no mais, idêntica redação.

⁴⁰ Somente quando emitida cartularmente (mas não na forma escritural).

⁴¹ Exige qualificação completa do devedor e do credor.

⁴² A Lei n. 6.268, de 24 de novembro de 1975, impôs, para efeito de registro de protesto, “a identificação do devedor pelo número de sua cédula de identidade, de inscrição no cadastro de pessoa física, do título eleitoral ou da

carteira profissional” (art. 3º).

⁴³ Idem.

⁴⁴ Identificação da garantia somente se pactuada.

⁴⁵ A garantia pode ser feita na própria cédula ou em documento separado e, neste caso, com menção na cédula.

⁴⁶ Cláusula à ordem: somente se o título for endossável.

⁴⁷ Somente quando emitida cartularmente.

⁴⁸ Somente no caso de contar com garantia real.

⁴⁹ O disposto nos art. 5º das legislações (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) que regulamentam todos os demais títulos (exceção às cédulas bancária e imobiliária) remete a fixação ao CMN: “As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação”.

⁵⁰ *V.*, para o crédito rural, o art. 5º do Decreto-lei n. 167/67 que expressamente dispõe: “(...) podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação”.

⁵¹ Assim entendem Tullio Ascarelli (*Teoria Geral dos Títulos de Crédito*. Campinas: Red Livros, 1999, p. 187) Rubens Requião (*Curso de Direito Comercial*. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 2, p. 466); Waldirio Bulgarelli (*Títulos de Crédito*. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 428); Pupo Correia (*Direito Comercial*. 6. ed. Lisboa: Ediforum, 1999, p. 107); Fábio Ulhoa Coelho (*Manual de Direito Comercial*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 300); De Plácido e Silva (*Noções Práticas de Direito Comercial*. 6. ed. Curitiba: Guairá, 1946, p. 541); Luiz Emydgio F. da Rosa Jr. (*Títulos de Crédito*. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 79).

⁵² Anota-se o comentário de Carvalho de Mendonça (*Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, cit., p. 95-96), autor da redação do Decreto n. 1.102/1903: “Títulos à ordem são aqueles nos quais o signatário se obriga a entregar ou mandar entregar à pessoa indicada ou à ordem desta, em lugar e tempo determinados, certa quantia em dinheiro ou certa quantidade de coisas fungíveis. Transferem-se eles por meio de brevíssima declaração escrita e subscrita no dorso do próprio título. Daí a denominação de endosso atribuída a esse meio de transferência”.

“Desse modo se efetua a sua circulação, garantida com o direito do possuidor exigir o pagamento da prestação na medida e de acordo com os termos do escrito, sem que lhe possa opor o devedor exceções que lhe não sejam pessoais ou que não assentem em vício interno ou externo do título. Assim, o portador goza o apreciável benefício de poder, quando queira, sem delongas, converter o documento em dinheiro” (Ramella, *Titoli all'ordine*, v. 1^o, n. 1).

⁵³ “Se a expressão *conhecimento de depósito* define perfeitamente a verdade das coisas, a expressão *warrant* parece, à primeira vista, não ser apropriada para designar o instrumento destinado ao serviço do penhor” [...] “a lei brasileira manteve o nome de *warrant*, por ter sido adotado desde a Lei n. 1.746, de 13 de outubro de 1869, e seguido no Dec. n. 2.502, de 24 de abril de 1897, e na Lei n. 559, de 31 de dezembro de 1898 (art. 3, n. IX) assumindo assim foros de cidade, como principalmente, para de todo afastar o preconceito que poderia acompanhar a expressão *nota ou cautela de penhor*. Eis a causa do anglicismo” (MENDONÇA, J. X. Carvalho de *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, cit., p. 628-629).

⁵⁴ A Lei n. 9.973/2000, ao fixar regras para os *warrants* agropecuários (v. item 7.2.10), ampliou a extensão dos riscos exigindo que a cobertura abranja “incêndio, inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriore” (art. 6^o, § 6^o), circunstâncias hoje adotadas pelos armazéns-gerais de qualquer natureza, embora não vislumbradas pelo legislador de 1903.

⁵⁵ Concelho: divisão de distrito.

⁵⁶ Tullio Ascarelli assim se posiciona sobre essa característica dos títulos representativos: “Problema mais difícil é o da abstração nos títulos representativos e, mais precisamente, no conhecimento marítimo, no conhecimento de depósito e no conhecimento terrestre (de acordo com o regime do código do comércio), isto é, nos títulos de depósitos (conhecimento marítimo e conhecimento terrestre). [...] O conhecimento de transporte (terrestre), o conhecimento marítimo (fluvial ou aéreo) e conhecimento de depósito incorporam, de qualquer forma, um direito obrigacional: isto é, o direito de exigir a entrega de uma quantidade de mercadoria especificada. [...] Esse direito é justamente o relativo à entrega (ou, mais precisamente, como veremos, à reentrega) de mercadoria especificada, individuada. É ensinamento geral que esse direito é literal, mas causal, e, não abstrato e isso porque constantemente se prende a uma causa, o *receptum*; depósito, ou transporte. E, indubitavelmente, não só esses títulos se prendem ao *receptum*, seja depósito ou transporte, mas é a disciplina do *receptum* (depósito ou transporte) que regula a

obrigação mencionada nos mesmos” (Ascarelli, 1999:187-188).

⁵⁷ O art. 585 do CPC73 e seu correspondente no CPC15 (art. 784) não arrolam o conhecimento de transporte entre os títulos executivos extrajudiciais.

⁵⁸ SIANO, James. *A visão do contrato de transporte terrestre de pessoas e coisas à luz do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor*, São Paulo, PUC-SP, dissertação defendida em 26 de maio de 2006.

⁵⁹ Operador de Transporte Multimodal “é a pessoa jurídica contratada como principal para a realização de Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros” (art. 3º da Lei n. 9.611/98), podendo ser transportador ou não (parágrafo único do mesmo artigo).

⁶⁰ Primagem: segundo De Plácido e Silva: “Do francês *primage*, entendia-se a porcentagem ou a gratificação que era atribuída ao capitão do navio, como recompensa aos cuidados despendidos ou a despender no transporte das mercadorias confiadas ao navio. Esta gratificação, que podia ser *fixada* ou *proporcional* ao valor do frete, podia estar compreendida no frete ou ser estipulada à parte” (*Vocabulário Jurídico*. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense 1998, p. 638).

⁶¹ Fran Martins (2010:555) assinala que, “apesar de determinar o Código que o conhecimento marítimo deve conter ‘a assinatura ... do carregador’ (art. 575, n. 5), na prática geralmente assim não acontece, continuando os conhecimentos marítimos, entretanto, a desempenhar as suas funções, que são a de provar que as mercadorias foram embargadas no navio, destacar a propriedade das mercadorias nele descritas e, finalmente, evidenciar os ‘termos e condições do transporte entre os armador e o embarcador’”.

⁶² Franz Wieacker aponta o Código Civil de Napoleão como sendo o diploma precursor do estabelecimento da liberdade contratual: “Só com o *Code Civil* a igualdade jurídica dos cidadãos (designadamente também no direito fundiário e sucessório), a liberdade da esfera jurídica dos particulares, particularmente na liberdade de atuação contratual e econômica, se tornam axiomas vivos de uma nova imagem da sociedade” (*História do Direito Privado Moderno*. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1967, p. 390).

⁶³ Assim classifica Teresa Ancona Lopez (Princípios Contratuais. In: FERNANDES, Wanderley (coord. *Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais* São Paulo: Saraiva, 2007, p. 51-57. Nelson Rosenvald prefere outra classificação às funções: (a) paradigma interpretativo (CC, art. 113); (b) controle contra abusos (CC art. 187); e (c) integrativa (CC, art. 422) [ROSENVALD, Nelson. Comentários aos arts. 421-652. In: PELUSO Cezar. *Código Civil Comentado* – doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008, p. 412]. Nesse sentido, também Paulo Sérgio Restiffe [*Manual do Novo Direito Comercial*. São Paulo: Dialética, 2006, p. 266].

⁶⁴ “Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas: o que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava a seu parceiro; assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz Compra-a tu. E tirou o calçado. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois, hoje, testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilon e a Malom” [Rute 4, 7-9]. *Bíblia Sagrada*. 2. ed. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Revista e Atualizada no Brasil. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1996, em letra grande, p. 370.

⁶⁵ Article 1.156 – Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804: “On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes”.

⁶⁶ Distinção necessária entre *estabelecimento empresarial* do empresário individual e *patrimônio* da sociedade empresária. Para melhor apreciação desse importante ponto, v. item 5.5.2 do v. 1 desta obra.

⁶⁷ Se não fizer uso da denúncia da lide, alguns entendem que o comprador não perde o direito de demandar por perdas e danos em ação direta. Nesse sentido, na vigência do antigo art. 70, I, do CPC/73, correspondente ao atual art. 125, I, do CPC/15: Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (2009:208, nota n. 6): “Em resumo, é preciso distinguir: embora, de acordo com a jurisprudência dominante, não tendo havido denúncia da lide, perca o adquirente o direito de ser ressarcido da evicção, daí não se segue que fique impedido, por meio de ação direta, de recobrar o preço (que é um *minus* em relação à indenização que da evicção resulta)”. Em sentido contrário anotam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (2007:83): “[...] se não for feita a denúncia da lide na forma da lei processual, o adquirente não poderá mais exercer o direito decorrente da evicção. Verificada esta, não terá direito à indenização. Esse entendimento é majoritário na doutrina: Mesquita, *Ajuris* 22/81”.

⁶⁸ Expressões em *itálico* para indicar, conforme exposto, que a Lei n. 11.101/2005, em confronto com a legislação revogada, manteve o *status quo* desses credores.

⁶⁹ A expressão em *itálico* é adotada em razão do tratamento legislativo. Anotamos, contudo: “A equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica (art. 50, XII), ocasiona remissão de parte da dívida. O vocábulo é, como bem atenta Bezerra Filho, ‘equivoco’ e, em termos jurídicos ‘nada significa’ (*Nova Lei de Recuperação e Falências Comentada* 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 143). Contudo, considerando o espírito da lei e a função econômica do instituto de recuperação, é correto entender, como faz Coelho, que ‘a medida insere-se no contexto de renegociação do devedor que explora a empresa em situação crítica. Por ela, bancos e empresas de fomento mercantil padronizam os encargos financeiros de seus créditos, ajustando-os ao menor dos praticados no mercado (em idênticas condições, bem entendido). Trata-se de impor a determinados

credores redução de seu direito creditório, sob a justificativa de que ela não lhes acarretará prejuízo’ (2005:141). É este também o ensino de Lobo (Comentários aos artigos 35-69. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 126) ao entender que se trata de uniformização dos encargos, ‘adotando-se parâmetros que permitam o reerguimento da empresa em crise’”.

⁷⁰ “(...) após a conclusão do contrato de compra e venda entre importador e exportador, ajustados os termos e as condições do negócio, aciona-se o mecanismo do crédito documentado. O comprador (importador) solicita ao seu banco (no seu país) a abertura de um crédito (acreditivo) ao exportador, no país deste. O banco comunica então à sua filial ou correspondente, no país do exportador, a abertura do crédito em favor do exportador, expedindo em favor deste uma carta de crédito. Quando esse crédito, aberto pelo banco do comprador ao vendedor, é confirmado e irrevogável, a garantia do vendedor passa a ser total, pois que o banco do comprador assume então a responsabilidade direta da obrigação. O vendedor pode então usar esse crédito antes ou por ocasião da entrega da mercadoria. Antes, através da emissão de uma letra de câmbio contra o banco, a tempo certo de vista, descontando-a junto a um banco em seu país, o qual, de posse dela, apresentá-la-á ao banco do comprador, junto com os

documentos, por ocasião do despacho das mercadorias, para o aceite, representando-a novamente na ocasião do vencimento. Também poderá o vendedor emitir letra de câmbio à vista e apresentá-la ao banco do comprador, juntamente com os documentos da mercadoria, a qual, após examiná-los, fará o pronto pagamento. Por seu turno, o comprador fica garantido, pois que o banco só aceitará ou pagará o preço após o exame da regularidade dos documentos representativos da mercadoria” (BULGARELLI, Waldirio *Contratos Mercantis*. 9. ed. São Paulo Atlas, 1997, p. 233).

⁷¹ No original: “Las actividades de la CCI cubren un amplio espectro, que va desde el arbitraje y la resolución de conflictos, hasta la defensa del libre comercio y el sistema de economía de mercado, la autorregulación de empresas, la lucha contra la corrupción o la lucha contra el crimen comercial”.

⁷² Observação precisa de Alfredo de Assis Gonçalves Neto (O Contrato de Representação Comercial no Contexto do Código Civil de 2002. In: *Representação Comercial e Distribuição*.

São Paulo: Saraiva, 2006, p. 214) que se reporta ao fato de o Código Civil utilizar-se de um termo consagrado (distribuição) que abrange todo tipo de contrato que visa à colocação, por terceiros, de produtos no mercado, como subcategoria de contrato de agência, como se vê da leitura do parágrafo único do art. 710 do Código Civil.

⁷³ Cfr. António Pinto Monteiro (2004:45). Este autor nos lembra que expressão equivalente é utilizada pelas legislações italiana (art. 1742 do Codice Civile), espanhola (Lei n. 12/1992, de 27 de maio) e alemã (§ 84 do HGB).

⁷⁴ O art. 10 da Lei n. 6.729/79 estabelece: “O concedente poderá exigir do concessionário a manutenção de estoque proporcional à rotatividade dos produtos novos, objeto da concessão, e adequado à natureza dos clientes do estabelecimento, respeitados os limites prescritos nos §§ 1º e 2º seguintes”.

Dentre os limites a que se refere, encontra-se a limitação de estoques, prevista no § 1º: “É facultado ao concessionário limitar seu estoque: a) de veículos automotores em geral a sessenta e cinco por cento e de caminhões em particular a trinta por cento da atribuição mensal das respectivas quotas anuais por produto diferenciado, ressalvado o disposto na alínea *b* seguinte; b) de tratores, a quatro por cento da quota anual de cada produto diferenciado; c) de implementos, a cinco por cento do valor das respectivas vendas que houver efetuado nos últimos doze meses; d) de componentes, o valor que não ultrapasse o preço pelo qual adquiriu aqueles que vendeu a varejo nos últimos três meses”.

⁷⁵ O contrato não escrito pode gerar obrigações para as partes, desde que a parte prejudicada demonstre ter concluído o contrato, realizado despesas para instalação da empresa, obtido autorização da outra parte e outros atos que revelam a existência de consensualidade.

Veja-se neste sentido: SÃO PAULO, *Tribunal de Justiça de São Paulo*, 19ª Câmara de Direito Privado, Ap. n. 963.918-5, julgada em 6 de junho de 2006, Rel. Des. Ricardo Negrão: “Interesse processual – Ação de rescisão contratual – Contrato de franquia não assinado – Alegação de inexistência da contratação – Improcedência – Falta de indicação séria da requerida quanto à tese de inexistência de negócio contínuo entre as partes – Negativa geral da corrê – Colação de documentos que atestam o oferecimento, em anúncios publicitários, de contratos de franquias por parte das apeladas – Realização do contrato de franquia – Redução das cláusulas a escrito – Exercício efetivamente concretizado pelo autor – Abundante prova documental neste sentido – Interesse processual presente – Preliminar rejeitada – Rescisão contratual parcialmente procedente – Recurso improvido”.

⁷⁶ Fran Martins menciona a prática norte-americana nesse sentido: “Nos Estados Unidos existem empresas que permitem a rescisão do contrato, *mesmo sem causa*. Esse procedimento é justificado pelo fato de ser a franquia um contrato de boa-fé. Se, por qualquer motivo, não interessa mais ao franqueado a continuação da franquia, basta o mesmo comunicar ao franqueador a sua intenção do desfazimento do contrato, sem necessidade de explicar os motivos por que assim o faz”. In: *Contratos e Obrigações Comerciais*. 12. ed. Rio de Janeiro, Forense: 1993 p. 589.

⁷⁷ Cf. Orlando Gomes (2008:425): “Justamente porque se faz essa confusão e não há vocábulo próprio para qualificar o negócio jurídico unilateral de atribuição de poderes de representação, este é denominado também *mandato*, como se não fosse coisa diferente do contrato que tem esse nome. O resultado dessa sinonímia absurda é a confusão entre *mandato* e *representação*, que leva à falsa ideia de que toda *representação voluntária* é *mandato*. Há que se distinguir, pois, o *contrato* do *ato jurídico unilateral*, o *mandato* da *procuração* em sentido técnico. A própria contextura da *procuração* denuncia o caráter unilateral do negócio jurídico nela consubstanciado, pois, nesse ato, o representante não intervém”.

⁷⁸ Como bem ensina Serpa Lopes (1993:280): “Embora, em nosso Direito, *representação* constitua elemento *essencial* do mandato, diferentemente do direito alemão, impõe-se, contudo, manterem-se inconfundíveis as duas figuras. Em primeiro lugar, a representação pode ser *voluntária*, como no caso do mandato, ou *legal*, como no do tutor e do marido, enquanto o mandato pressupõe uma representação determinada direta ou indiretamente pela vontade do mandante [...]”.

⁷⁹ Entre eles Silvio Rodrigues (*Direito Civil*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, v. 3, p. 275), Orlando Gomes (*Contratos*. 26. ed. Atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 426), Carlos Roberto Gonçalves (*Direito Civil Brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008 v. 3, p. 388).

⁸⁰ Entre esses Washington de Barros Monteiro (*Curso de Direito Civil – Direito das Obrigações* 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1973, 2ª parte, p. 243).

⁸¹ Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (2009:180, nota 1) resgatam inúmeros casos nesse sentido: STJRT 698/225; RT 696/170; JTJ 157/175, RBDP 43/187, Rel. Des. Barbosa Moreira.

⁸² Silvio Rodrigues entende que a exceção não deve ser avaliada com o mesmo peso para os contratos gratuitos e onerosos: “Não se deve, a meu ver, aplicar a parte final desta regra com igual rigor, tanto para o caso de contrato remunerado como para o de mandato gratuito. Enquanto ela é verdadeira para esta última hipótese não pode sê-lo para a de mandato oneroso. O caráter especulativo do mandato oneroso impõe ao mandatário a responsabilidade pelos prejuízos que sua deserção provocar, ainda que prove ter renunciado ao mandato para evitar prejuízo considerável” (1997, 3:289).

⁸³ “A palavra comissão, na técnica legal, oferece três sentidos: 1^a) o contrato a que aludimos; 2^a) a remuneração devida pelo comitente ao comissário; 3^a) o próprio comércio de comissão”(Mendonça, 1956, 6:283, nota 2).

⁸⁴ Efeitos: expressão antiga, adotada na redação de artigos do Código Comercial de 1850, que se refere às coisas móveis e semoventes destinadas ao comércio.

⁸⁵ É o que dispõe o art. 25 da Lei n. 4.595/1964. Há, contudo, exceções: as cooperativas de crédito não são sociedades por ações, mas, como seu nome define, sociedades cooperativas. Algumas empresas equiparadas às instituições financeiras podem estabelecer-se sob outra forma societária, como, por exemplo, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários; os agentes de câmbio; as sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte que podem ser companhias fechadas ou sociedades limitadas (Resolução n. 3.567, do Banco Central do Brasil, de 29-5-2008, art. 1º, § 1º) etc.

⁸⁶ Cf. Edwim S. Hunt e James M. Murray (2000:328) que, ainda, esclarecem a função do depósito sem reserva: “assumia na maior parte dos casos a forma de moeda confiada ao banco de modo a facilitar a transferência de fundos para outros mercados. Normalmente, as ordens de transferência eram dadas oralmente. As instruções escritas, algumas das quais se assemelham *grosso modo* aos atuais cheques bancários, surgiram em alguns centros a partir do século XV, mas existem poucos dados que possam sugerir que a sua utilização era uma prática comum ou mais do que uma confirmação das instruções orais”.

⁸⁷ Assim também ensina Fábio Ulhoa Coelho: “Há, porém, uma circunstância que particulariza o depósito bancário afastando-o do irregular: o banco titulariza a *propriedade* dos valores depositados. Ele não é simples detentor da custódia destes, como ocorre com o depositário no depósito irregular. A relação entre os contratantes do depósito bancário é fiduciária, ou seja, o banco pode usar o dinheiro de seus clientes para pagar as suas próprias despesas (salário de pessoal, aluguel de agência, serviços de terceiros etc.) ou para emprestar a outros clientes” (2016, 3:134-135).

⁸⁸ Em geral, na cessão de crédito, o cedente não responde pela solvência do devedor (CC, art. 296). Para poder exercer o direito de regresso contra a empresa descontante dos títulos o banco deve fazer constar expressamente a obrigação de o cedente responder pela dívida se o devedor do título não pagá-lo no vencimento.

⁸⁹ Esse decreto, com forma de lei, encontra-se ainda em vigor e o dispositivo citado traz a seguinte redação: “É proibido contar juros dos juros; esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”.

⁹⁰ A evolução tecnológica vem oferecendo instrumentos que dispensam a base física, historicamente impressos em cartões plásticos de dimensões convencionadas (8,5 cm x 5,5 cm). Muitas operações ocorrem via *internet*, pelo simples lançamento dos números impressos, outras pela leitura magnética da tarja estampada no verso e, mais recentemente, pelo armazenamento do código identificador em outras mídias, tais como comunicadores pessoais (celulares) que se conectam diretamente com os terminais eletrônicos e computadores dos fornecedores.

⁹¹ ANDREZA, Andrea Fernandes. O Sistema Contratual do Cartão de Crédito no Brasil – artigo publicado : *Estudo em homenagem ao acadêmico Ministro Sydney Sanchez*, São Paulo, Fiúza Editores, 2003, citado por ABRÃO, Carlos Henrique (2005:107).

⁹² A Circular n. 2.715, de 28 de agosto de 1996, do Banco Central do Brasil, expressamente dispôs: “Art. 1º. Permitir às instituições financeiras: I – a realização de operações de crédito com empresas cujo objeto social exclusivo ou não, seja a prática de operações de compra de faturamento (*factoring*); II – o aporte de recursos a empresas de *factoring* e promotoras de vendas”.

⁹³ BRASIL. *Superior Tribunal de Justiça*. As empresas que se dedicam à atividade de *factoring* estão sujeitas a registro no Conselho Regional de Administração. Precedente da Segunda Turma: REsp n. 497.882/SC, Rel. Mi João Otávio de Noronha, *DJ*, 24-5-2007. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp n. 760.539/RS, Re Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 16-10-2008, *DJe*, 6-11-2008).

⁹⁴ Assim traduz Dirceu A. Victor Rodrigues: “Quem sente o ônus, deve sentir a vantagem e vice-versa” (1972:283).

⁹⁵ Arnaldo Rizzardo (2004:121) assim expõe: “Não é sem razão que a se faculta ao *factor* a escolha dos créditos. Ao receber o borderô dos títulos, tem ele a faculdade de rejeitar os que não lhe interessam. [...] Considera-se o custo de quem vende os seus créditos, pagando um ágio ou um *plus*, relativamente ao valor inserido nos títulos. Não haveria sentido permitir-se, posteriormente, ao cessionário, ir contra aquele que pagou o título, o que se verifica pela diferença a menos recebida, quanto ao montante contido na cártula. Uma vez admitido o direito de regresso, não encontra qualquer justificativa a remuneração ao faturizador. E a remuneração envolve precisamente o *quantum* correspondente ao risco que assume o *factor* pelas vicissitudes do crédito, inserindo-se nele a possibilidade de insolvência do devedor. Assim, o crédito é comprado pelo *factor*, que paga um preço abatido o correspondente ao risco [...]”.

⁹⁶ Falência. Julgamento de improcedência por supor, o i. magistrado, que houve simulação das partes ao firmar o contrato de “*factoring*”, mascarando verdadeiro contrato de mútuo, só permitido às instituições bancárias. Nota promissória emitida para pagamento dos títulos que foram cedidos pela faturizada na operação e não pagos. Faturizadora que não pode atuar em regresso pelo inadimplemento das obrigações adquiridas do devedor. Interpretação do disposto no art. 296 do Código Civil, que deve considerar a expressão “solvência” como sinônimo de falência, recuperação judicial, insolvência civil, não como garantia ao pagamento. Descaracterização do contrato. Iliquidez reconhecida. Sentença de improcedência mantida (TJSP, 2ª CRDE, j. 29-7-2019, Rel. Des. Araldo Telles).

⁹⁷ Há quem sustente a possibilidade de se poder estipular, no contrato de *factoring*, cláusula que obrigue o cedente a responder pela solvência do devedor. Antonio Carlos Donini admite a cláusula em “casos justificáveis de risco,

ainda que subjetivo, mas evidente ou aparente entre as partes”: “O Prof. Fábio Konder Comparato em pioneiro trabalho desenvolvido sobre o instituto de *factoring* reconheceu a possibilidade de cessão *pro solvendo*, advertindo, entretanto, que, nesse caso, o fator a ser cobrado deverá ser menor que quando o faturizador assume os riscos pela insolvência do devedor: ‘A comissão representa a contraprestação das garantias fornecidas contra o risco de inadimplemento, bem como a remuneração do serviço de gestão dos créditos. Se a cessão se perfaz *pro solvendo*, é óbvio que essa comissão é reduzida’. Somos favoráveis à aplicação da lei e, a partir do cumprimento dela, é possível e legal na operação de *factoring* estabelecer que a cessão de crédito poderá ser com garantia ou não (*pro soluto* ou *pro solvendo*)” (*Factoring: os projetos de leis no Congresso. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais*, São Paulo, Revista dos Tribunais, abr./jun. 2004, n. 24, p. 139).

⁹⁸ Sobre os contratos aleatórios v. 9.3 a, no tópico sobre existência e individualidade da coisa alienada.

⁹⁹ “Factoring – the buying of accounts receivable at a discount. The price is discounted because the factor (who buys them) assumes the risk of delay in collection and loss on the accounts receivable” (GARNER, 2004:630).

¹⁰⁰ V. neste sentido: “Tratando-se de empresa que opera no ramo de *factoring*, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros deve obedecer à limitação prevista no art. 1º do Decreto n. 22.626, de 7-4-1933” (REsp n. 330.845/RS, relatado pelo eminente Min. Barros Monteiro *DJ*, 15-9-2003). O fato de a empresa de *factoring* ser vinculada a instituição financeira tampouco altera tal disciplina. Os juros moratórios podem ser convencionados no limite previsto no Decreto n. 22.626/33, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte. “O valor da indenização por dano moral não pode escapar ao controle do Superior Tribunal de Justiça” (REsp n. 53.321/RJ, Min. Nilson Naves). Redução da condenação a patamares razoáveis, considerando as peculiaridades da espécie. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (REsp n. 623.691/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 27-9-2005, *DJ*, 28-11-2005, p. 296).

¹⁰¹ COELHO, Fábio Ulhoa, 2016, 3:147; RIZZARDO, Arnaldo, 2004:141-147; DONINI, Antonio Carlos, 2004:137.

¹⁰² O Ministro Ari Pargendler teve oportunidade de julgar situação em que a nota promissória objeto de operação de *factoring* tinha origem em obra de construção civil inacabada: “Civil. Dano moral. O só inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral. *Factoring*. A nota promissória emitida em garantia do pagamento do preço de imóvel em construção autoriza o emitente a opor exceções de natureza pessoal (v. g., atraso na entrega da obra) contra o respectivo portador, se é empresa de *factoring*” (REsp n. 151.322/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 5-9-2002, *DJ*, 2-12-2002, p. 303).

¹⁰³ Para o conceito de empresa coligada v. o Capítulo 25 do primeiro volume desta obra, no estudo sobre grupo de fato (item 25.5.1).

¹⁰⁴ Para entender os benefícios da instituição do patrimônio de afetação em caso de insolvência do incorporador, v. item 21.4.11 no terceiro volume desta obra.

¹⁰⁵ Hunt e Murray citando James Masschaele [*Transport Costs in Medieval England*, *Economic History Review* 46,2 (1993):266-279] assinalam que “o custo do transporte de cereais por carro era surpreendentemente baixo, mas remontava, não obstante, ao dobro do preço cobrado pelo transporte da mesma carga por via fluvial” (2000:79).

¹⁰⁶ Bateiras: pequenas embarcações fluviais de fundo chato.

¹⁰⁷ Navegação *marítima* é a realizada em mares; *fluvial*, em rios; e *lacustre*, em lagos e lagoas. O art. 2º da Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 1997, define, quanto à via utilizada e função operacional, as seguintes classes de navegação: “VII – *navegação de apoio portuário*: a realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias; VIII – *navegação de apoio marítimo*: a realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos; IX – *navegação de cabotagem*: a realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores; X – *navegação interior*: a realizada em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional; XI – *navegação de longo curso*: a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros; XIV – *navegação de travessia*: aquela realizada: a) transversalmente aos cursos dos rios e canais; b) entre 2 (dois) pontos das margens em lagos, lagoas, baías, angras e enseadas; c) entre ilhas e margens de rios, de lagos, de lagoas, de baías, de angras e de enseadas, numa extensão inferior a 11 (onze) milhas náuticas; d) entre 2 (dois) pontos de uma mesma rodovia ou ferrovia interceptada por corpo de água”.

¹⁰⁸ São tubulações que conduzem produtos ou materiais a grandes distâncias.

¹⁰⁹ Veja nesse sentido: (a) 1. A empresa prestadora de serviço é responsável pelos danos causados ao usuário em decorrência do serviço ou de sua falta. 2. Fugem do nexo de causalidade os eventos ocorridos em decorrência de caso fortuito ou força maior. 3. Assalto ocorrido nas escadas de acesso ao metrô não pode ser considerado como falta do serviço, equiparando-se a assalto ocorrido em transporte coletivo. 4. Recurso especial provido (REsp n 402.708/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24-8-2004, *DJ*, 28-2-2005, p. 267); (b) O assalto à mão armada dentro de coletivo constitui força maior que afasta a responsabilidade da transportadora pelo evento danoso (AgRg no REsp n. 866.619/TO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 3-12-2007, *DJ*, 12-12-2007, p. 417); (c) 1. A morte decorrente de assalto à mão armada, dentro de ônibus, por se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço de transporte (força maior), constitui-se em causa excludente da responsabilidade da empresa concessionária do serviço público. 2. Entendimento pacificado pela Segunda Seção. 3. Recurso especial conhecido e provido (REsp n. 783.743/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 12-12-2005, *DJ*, 1º-2-2006, p. 571).

¹¹⁰ Outros exemplos extraídos da prática jurisprudencial: (a) I – Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado “de que tratando-se de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor” (REsp n 538.685, Rel. Min. Raphael de Barros Monteiro, *DJ*, 16-2-2004). II – De igual forma, subsiste orientação da Segunda Seção, na linha de que “a ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior”, de modo que “cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de voo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se

exigindo prova de tais fatores” (AgRg no Ag. n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros *DJ*, 9-10-2006). III – Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a indenização por dano material em R\$ 194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na quantia de R\$ 5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso especial (REsp n. 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 20-9-2007 *DJ*, 8-10-2007, p. 287); (b) I – Não tendo a empresa ferroviária provado a culpa da vítima, nem assim elidido sua responsabilidade, comprovando caso fortuito ou força maior, não se exonera da obrigação de indenizar pela morte do menor. II – É dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro e transportá-lo com segurança até o seu destino. III – Recurso conhecido e provido (REsp n. 217.528/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, j. 15-2-2001, *DJ*, 9-4-2001, p. 354); (d) Responsabilidade civil. transporte. Ônibus. Explosão de um pacote. Reconhecida, na instância ordinária, a culpa do motorista do ônibus, por autorizar o transporte irregular de um pacote contendo artefato que explodiu e causou a morte de diversos passageiros, procede a ação de indenização promovida contra a transportadora, art. 17 da Lei 2.681/1912. Divergência não configurada. Recurso não conhecido (REsp n. 95.426/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 10-9-1996, *DJ*, 14-10-1996, p. 39015).

¹¹¹ A respeito da boa-fé objetiva, em “Princípios Contratuais” (capítulo da obra *Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 45), Teresa Ancona Lopez lembra que “é importante que se destaque e se dê autonomia à *boa-fé* objetiva, que, sendo um conceito dúctil, vai sempre se adaptar às circunstâncias do caso concreto. O princípio da boa-fé objetiva tem fundamento constitucional na cláusula geral de dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático (art. 1º, III, da CF/88) e no art. 3º, I, que determina ser objetivo fundamento da República uma sociedade livre, justa e solidária. É precisamente esta solidariedade que embasa a cláusula geral de boa-fé. Teresa Negreiros, mostrando a oposição entre indivíduo e pessoa, aponta que o Direito Civil apresenta-se ‘como um conjunto de deveres das pessoas em relação umas às outras, e não mais como um sistema marcado pela garantia dos direitos dos indivíduos em oposição a outros indivíduos e ao próprio Estado’” (NEGREIROS, 1998:272).

¹¹² BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, (a) REsp n. 226.348/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 19-9-2006, *DJ*, 23-10-2006, p. 294: I – É dever da transportadora preservar a integridade física do passageiro e transportá-lo com segurança até o seu destino. II – A responsabilidade da companhia de transporte ferroviário não é excluída por viajar a vítima como “pingente”, podendo ser atenuada se demonstrada a culpa concorrente. Precedentes. Recurso especial; parcialmente provido; (b) REsp n. 388.300/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 17-9-2002, *DJ*, 25-11-2002, p. 238: I. Admissível a concorrência de culpa em transporte ferroviário, quando verificado comportamento aventureiro da vítima, a dificultar, consideravelmente, a eficiência do serviço de fiscalização da empresa transportadora, que, alertada, já tomava as medidas necessárias para a retirada do passageiro de local indevido, onde deliberadamente se alojara por ousadia, já que distante do carro destinado ao transporte, onde não fora detectado excesso de lotação. Redução do valor, em face da concorrência de culpas, à metade. II. Danos morais e materiais devidos, estes, na esteira de precedentes jurisprudenciais, em 2/3 do salário mínimo até a idade em que o *de cujus* completaria 25 anos, reduzida para 1/3 a partir de então, em face da suposição de que constituiria família, aumentando suas despesas pessoais com o novo núcleo formado, extinguindo-se a obrigação após alcançada a sobrevivência provável, de acordo com tabela utilizada pela Previdência Social. III. Prestações vincendas garantidas, a critério da ré, ou pela formação de capital, ou mediante caução. IV. Inexistindo

prova de trabalho assalariado, indevido o 13º salário no cálculo da pensão. V. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.

113 Unitizar significa reunir cargas em um só volume, para fins de transporte, conforme definição do *Novo Aurélio Século XXI*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

114 Consolidação ou, em inglês, *box rate*: ao consolidar a carga, o operador otimiza o uso de um *container* no embarque marítimo, armazenando nele lotes de mercadorias de distintos expedidores. Assim fazendo, o frete a ser pago é fracionado entre os diversos embarcadores na proporção do espaço ocupado no *container*, reduzindo substancialmente o valor devido por cada um de seus clientes.

115 Esse autor relata a curiosa conclusão de Frei João Sobrinho, que, em 1483, na obra *De Justitia Commutiva*, debruça-se a revelar a natureza de um contrato entre dois comerciantes, João e Pedro: “Um mercador muito rico João, tendo sabido que um outro mercador, Pedro, dispunha de mercadorias num navio e as receava perder, dada a ameaça que representavam os piratas, fala assim a Pedro: Quanto me queres dar, e eu tomarei à minha conta que a tua nau se salve? No caso contrário pagar-te-ei tudo o que perderes. Finalmente, acordam pela segurança das mi libras, valor estimado das mercadorias em cinquenta libras, ou seja, no caso de a nau chegar com felicidade, Pedro pagará a João cinquenta libras; se não, João pagará a Pedro tudo o que este perdeu”. Sobre esse negócio, Frei Sobrinho concluiu tratar-se de contrato “usurário de ambas as partes, pois cada um procura pôr-se a si em ganho, e ao outro em perda”, acrescentando os seguintes fundamentos: “É ilícito e injurioso transacionar o destino que só a Deus pertence. É ilícito vender o risco, pois este é pessoal. É um contrato vão e inútil, pois, através dele, não se transfere nem o domínio, nem o uso. É pecaminoso um contrato baseado na dúvida sobre o destino de uma coisa alheia, o que é contrário à própria ideia de segurança, objetivo do contrato de seguro”.

116 Esse autor explica essa afirmação: “Ao contrário do que muitos autores afirmam, as bolsas não foram acordos entre particulares, antes nasceram com uma nítida inspiração régia. A Bolsa do Porto terá tido melhor sorte do que a de Lisboa, ou pelo menos os proprietários de navios do Porto mostraram maior empenho em preservarem a sua bolsa. Tal conclusão radica na decisão da vereação desta cidade de a manter em funcionamento. Ao contrário, no documento em que o rei suscita à vereação do Porto uma posição sobre a Bolsa, ele demonstra um menor interesse pela manutenção da Companhia das Naus do Norte. Por razões opostas, em Lisboa a questão se apresentava de forma diferente. Como certamente os barcos régios estavam inscritos na capital do reino, era sobre os proprietários de navios de Lisboa que recaía o encargo de suportar parte dos riscos das embarcações régias”.

117 Cf. CORDEIRO, António Menezes *Manual de Direito Comercial*. Coimbra: Almedina, 2003, p. 62, e SIBBETT, Trevor. *European sources for research of actuarial history and the scope for translation*. In: “Exploring Actuarial History” Seminar, 14 June 2007, obtido em www.actuaries.org.uk/_data/assets/, em dezembro de 2008.

118 Os atualizadores da obra *Contratos*, de Orlando Gomes, bem assinalam a feliz escolha legislativa: “Buscando atender à distinção entre seguro de dano e seguro de pessoa, o legislador de 2002 aprimorou o conceito de contrato de seguro, antes constante do art. 1.432 do Código Civil de 1916. Em vez de definir a obrigação do segurador como sendo a de indenizar o prejuízo sofrido pelo segurado, aludiu à obrigação de ‘garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa’. Deste modo, o conceito legal passa a abranger não somente o seguro de dano, mas também o de pessoa, que não possui função indenizatória” (*Contratos*. 26. ed. Atualizada por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 507).

119 São as teorias: indenizatória, da necessidade eventual, dualista e teoria do risco. Ao expô-las, António Menezes Cordeiro adere, no conceito que formula, à última, com o seguinte fundamento: “a teoria do risco, por fim, vê no seguro um contrato que determina a suportação, pela entidade segurado, do risco que, nele próprio, se define. Embora formal, esta concepção parece dar corpo às diversas situações em jogo no seguro” (2003:550).

120 Segundo Clóvis Beviláqua, “as sociedades de seguro de mútuo constituem-se pela reunião de certo número de pessoas que põem em comum determinado prejuízo, para que a repercussão do mesmo se atenuie pela dispersão”

(1975, 2:592). É uma verdadeira associação de ajuda em que cada um dos integrantes é segurador dos outros participantes, mutuamente. Hoje seu regramento encontra-se no Decreto-lei n. 2.063/40 que as trata a partir do art. 14, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n. 3.908/41. Três outros diplomas posteriores, os Decretos-lei n. 4.609/42, o n. 7.377/45 e o n. 8.934/46, trataram de concessão de garantia subsidiária do governo, da inclusão de imóveis no ativo dessas sociedades e da extensão da legislação social aos empregados de sociedades mútuas. Exige-se, para constituição, um número mínimo de 500 (quinhentos) sócios fundadores, residentes no País.

¹²¹ Segundo Orlando Gomes: “O contrato é simplesmente consensual, a despeito de ser obrigatória a *forma* escrita. Não é mister, com efeito, a prática de qualquer ato por parte dos contratantes para que se aperfeiçoe. Basta o consenso manifestado pela forma própria” (2008:505).

¹²² Para Fábio Ulhoa Coelho, “no Brasil, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a apólice, o bilhete de seguro ou qualquer outro documento comprobatório do pagamento de prêmio servem de meio de facilitação de prova da existência do contrato (art. 758), mas não são constitutivos da obrigação contratual. O seguro, assim, na lei brasileira, é consensual, porque independe de formalidade específica (Tzirulnik-Pisa, 1993; Gomes 1959:475) (2007 3:345-346).

¹²³ Bueno de Godoy assevera que “o Código Civil (...) assenta o caráter consensual do contrato, perfeito e acabado com o consenso das partes. O que se estabelece, entretanto, é a forma escrita para comprovação de sua existência” (2008:690).

¹²⁴ Afirmar Maria Helena Diniz: “É um contrato *formal*, visto ser obrigatória a forma escrita, já que não obriga antes de reduzido a escrito, considerando-se perfeito o contrato desde o momento em que o segurador remete a apólice ao segurado, ou faz nos livros o lançamento usual da operação (CC, arts. 758 e 759). A forma escrita é exigida para a substância do contrato” (2007, 3:520).

¹²⁵ São os contratos de seguro previstos no art. 20 do Decreto-lei n. 73/66, com a alteração de inúmeras leis posteriores: de danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais; de responsabilidade civil do proprietário de aeronaves e do transportador aéreo; de responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas; de edifícios divididos em unidades autônomas; de bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de instituições financeiras públicas; em garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de imóveis; em garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção civil, inclusive obrigação imobiliária; de edifício dividido em unidades autônomas; de incêndio e transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, situados no País ou nele transportados; de crédito à exportação, quando concedido por instituições financeiras públicas; de crédito à exportação, quando julgado conveniente pelo CNSP, ouvido o Conselho Nacional do Comércio Exterior (Concex); de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não; de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não; de responsabilidade civil dos transportadores terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por danos à carga transportada.

¹²⁶ O inciso I do art. 3º da Resolução n. 117, de 22 de dezembro de 2004, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP –, define acidente pessoal como “o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer

outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial, do segurado, ou que torne necessário tratamento médico, observando-se que: a) incluem-se nesse conceito: a.1) o suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor; a.2) os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto; a.3) os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores; a.4) os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestros; e a.5) os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas. b) excluem-se desse conceito: b.1) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; b.2) as intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto; b.3) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Contínuo ou Contínuo – LTC, ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo; e b.4) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no inciso I deste artigo.

¹²⁷ Cf. Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimentel (2003:158), que igualmente justificar a distinção entre o seguro de acidentes pessoais e o seguro de acidente de trabalho: “regidos por leis diferentes, com conceitos também diferentes, não há por que confundi-los ou considerar o facultativo como completo ou supletivo da previdência social. O seguro privado não pode ser assimilado ao de acidente de trabalho mantido pelo trabalhador junto ao Instituto Nacional do Seguro Social”.

¹²⁸ Reserva técnica é gênero do qual fazem parte a reserva técnica *stricto sensu* e a reserva matemática; somente a segunda é individualizada, utilizada para a devolução dos contratos individuais, como é o caso do dispositivo em estudo. Cf. TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B. e PIMENTEL (2003:186).